

특허법 2차 기출 주관식

문제 · 모범답안 · 채점기준

2010년 ~ 2026년 · 전 68문항

변리사 제2차시험 특허법

일러두기

1. 무엇을 담았는가

변리사 제2차시험 특허법 기출문제 68문항(2010~2026)을 **문제 · 모범답안 · 채점기준** 세 벌로 실었다. 학습 플랫폼에 수록된 것과 같은 내용이며, 종이로 통독할 수 있도록 다시 짰 것이다.

2. 현행법으로 본다

기출이라도 **출제 당시의 법이 아니라 현행법을 적용**해 풀이했다. 수험생이 대비하는 시험은 현행법으로 출제되기 때문이다. 따라서 부칙(시행일·적용례·경과조치)은 다루지 않으며, 발문이 구법 조문을 인용한 경우에만 현행 조문과의 대응관계를 밝혔다.

3. 채점기준을 함께 읽는다

각 문항의 채점기준은 배점이 어디에 붙는지를 쟁점 단위로 밝힌 표다. 답안을 먼저 써 본 뒤 채점기준으로 자기 답안을 대조하면, 모범답안을 눈으로 좇는 것보다 빠르게 배점 감각이 붙는다. 분량은 **배점 1점당 200자**를 상한으로 삼았다.

4. 인용에 관하여

판례 사건번호는 학원 데이터베이스와 교재에서 확인된 것만 실었다. 확인되지 않은 번호는 적지 않고 법리만 서술했다.

5. 표기

- 조문은 「특허법」을 기준으로 하며 다른 법률은 법명을 함께 적었다.
- 문항 머리의 **사례형 · 약술형**은 출제 형식, 오른쪽 숫자는 배점이다.

차례

2010년

제1문	甲의 특허 가능성 판단	30점	2
제2문	국내수요 불충족을 이유로 한 재정청구 가부 (§107①(2))	20점	6
제3문	청구항 3·4만 남기는 실무 보정서 작성	30점	10
제4문	PBP 청구항의 의의·활용 국면 및 허용성	20점	15

2011년

제1문	① 진보성 판단의 일반적 '순서'	30점	19
제2문	독립항·종속항 구분의 일반적 기준	20점	23
제3문	乙의 정당 승계인 여부 (§33① 위반 아님)	30점	27
제4문	공동심판 심결취소소송의 법적 성격(유사필수적 공동소송)	20점	32

2012년

제1문	설문①-1: 1특허출원(발명의 단일성) 일반론(\$45, 시행령 \$6의 3요건)	30점	36
제2문	확인대상발명 특정의 법리	20점	41
제3문	기술심리관의 제척사유 있는 소송관여가 재심사유인지	30점	44
제4문	문언침해 성립 여부 검토(구성요소완비의 원칙)	20점	49

2013년

제1문	도면 부제출의 법적효과와 국제출원일	30점	54
제2문	자진보정의 시기적·객관적 적법성	20점	59
제3문	기능적 청구항의 의의	30점	64
제4문	전용실시권 일반론 및 미등록 특허의 효력(\$100①·\$101①(2))	20점	69

2014년

제1문	제128조 제2항의 성격	30점	74
제2문	甲의 실시태양 3단계 구분 및 침해성립요건	20점	78
제3문	결합발명의 진보성 판단(구성의 곤란성·효과의 현저성)	30점	83
제4문	진보성 무효사유의 침해소송 내 주장 가부	20점	87

2015년

제1문	국어번역문·청구범위 법정 제출기간 및 미제출 시 조치·이유	30점	91
제2문	청구범위해석에 근거한 적극적 권리범위확인심판 청구이유	20점	96
제3문	조약우선권 주장의 주체적·시기적·객체적 요건	30점	100
제4문	(설문1) 무효심판 청구인 적격 - 이해관계인 개념	20점	104

2016년

제1문	) 乙 항변의 성격 — 권리남용의 항변	30점	108
제2문	[설문(1)] 간접침해의 의의·취지와 제127조 제1호의 요건	20점	112
제3문	특허권 공유의 법적 성격	30점	116
제4문	1) A회사 특허권의 유효성	20점	120

2017년

제1문	전용품에 새로운 구성요소(D)를 부가한 경우 간접침해 성립 여부	30점	125
제2문	표준특허·FRAND 선언의 개념과 침해금지청구권 행사 제한 여부	20점	129
제3문	정정제도의 취지 및 종류(무효심판 중 정정, 취소신청 중 정정, 정정무효심판 중 정정)와 각 요건·절차·효과	30점	133
제4문	공지예외 주장에서 '권리자에 의한 공개'의 의미 및 복수공지의 취급	20점	137

2018년

제1문	PCT 영어원문과 최종국어번역문의 법적 지위	30점	142
제2문	발명의 단일성 요건과 사안 포섭	20점	147
제3문	조약우선권 인정 요건과 청구항별 판단시점(제54조) 및 각 청구항 거절이유 타당성	30점	151
제4문	검토범위의 한정과 청구항 1·2	20점	156

2019년

제1문	무효사유·자유실시기술 주장을 소극적 권리범위확인심판에서 판단하는 것의 타당성	30점	162
제2문	분할출원과 우선권 주장의 승계 여부	20점	166
제3문	방법발명 특허권 소진의 이론적 근거·성립요건	30점	169
제4문	무효심판 청구의 취지 표준 작성례(무효 대상 청구항 1의 특정 + 심판비용 부담 + '라는 심결을 구합니다')	20점	173

2020년

제1문	乙의 무단 통상실시권 허락의 효력(제99조 제4항)	30점	183
-----	------------------------------	-----	-----

제2문	우선권주장 출원인의 동일성 요건(제55조 제1항)	20점 188
제3문	乙의 무권리자(모인)출원에 대한 甲의 조치	30점 191
제4문	공동발명자의 단독출원 가부 (제33조 제2항, 제44조)	20점 195

2021년

제1문	공동발명자 성립요건과 甲·乙·丙 각각의 지위 판단	30점 199
제2문	일사부재리(\$163) 적용 여부	20점 203
제3문	) 丙의 프린터 구입·사용의 직접침해 여부	30점 206
제4문	제128조 제5항 실시료 상당액 산정	20점 210

2022년

제1문	이 사건 발명에 대한 권리귀속(\$33①·\$37①, 2011다67705 — 재산권·양도성, 명시·묵시 이전)	30점 214
제2문	일사부재리 판단시점 판례 태도	20점 219
제3문	의약용도발명에서 약리기전의 지위	30점 222
제4문	심결취소소송의 성격과 변론주의 적용	20점 226

2023년

제1문	권리범위확인심판제도 취지 및 침해소송과의 차이	30점 231
제2문	-① 공지예외주장의 의의·요건(\$30①(1))과 사안 포섭	20점 236
제3문	乙에 대한 침해 주장 - 간접침해 성립	30점 240
제4문	선택발명 의의 및 진보성 요건	20점 244

2024년

제1문	보정요구서의 내용·취지 (\$46 절차보정+\$6 특별수권)	30점 249
제2문	확인대상발명의 특정 3측면	20점 255
제3문	무효심판 내 정정청구 취지	30점 259
제4문	판단의 구조(특허발명의 특정 → 확인대상발명의 특정 → 구성요소완비·균등론 → 법률의 제한·확장)	20점 264

2025년

제1문	전용실시권과 독점적 통상실시권의 의의·비교	30점 269
제2문	존속기간 연장등록출원제도 개관 (\$89, \$92의2 취지·요건)	20점 273
제3문	출원의 일부취하서의 법적 취급(보정 선택)	30점 277

제4문	[설문(1)] 공동발명자 판단 (甲·乙·丙의 실질적 기여)	20점 282
-----	----------------------------------	---------

2026년

제1문	구성요소완비의 원칙에 의한 문언침해와 재판상 자백의 성부	30점 287
제2문	신규성 일반론 (§29①(1)·(2))	20점 293
제3문	정정의 적법성 (§136①·④)	30점 298
제4문	공지예외 요건 (§30①·②) 및 12개월 요건 검토	20점 303

PART 1

2010

제1문	甲의 특허 가능성 판단 · 특허등록 조치 - 제30조 검토·부정	30점
제2문	국내수요 불충족을 이유로 한 재정청구 가부 (§107①(2)) · 이집트(WTO 회원국)로 수출하기 위한 재정청구 조건 (§107①(5))	20점
제3문	청구항 3·4만 남기는 실무 보정서 작성 · 최후거절이유통지 후 보정 제한 (§47③, ④, §51)	30점
제4문	PBP 청구항의 의의·활용 국면 및 허용성 · 청구범위 해석 학설(제법한정설 vs 물건동일설)과 판례의 변경	20점

2010년 제1문

사례형

30점

문제

甲은 살충 특성이 있는 신물질 A를 발명하여 특허출원을 하지 않고 노하우(know-how)로 관리하면서 이를 이용하여 농작물에 무해한 살충제를 개발하고 있었다.

乙은 丁이 직접 연구개발을 하였다고 하는 신물질 A에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 丁으로부터 승계받아 2007년 4월 5일 특허출원하여 2008년 7월 4일자로 특허등록(청구범위 제1항 신물질 A)을 받고, 신물질 A를 제조하여 2008년 8월 4일부터 판매하고 있다. 그리고 丙은 특허권자 乙이 제조하여 판매하고 있는 신물질 A를 구입하여 이를 포함하는 살충제를 제조하여 판매하고 있다.

한편, 甲은 丙이 신물질 A를 포함하는 살충제를 판매하고 있는 것을 발견하고 이를 조사하는 과정에서, 甲의 회사 직원이 영업비밀관리규정에 의하여 노하우로 관리하고 있었던 신물질 A에 관한 정보를 甲의 허락없이 불법으로 대가를 받고 丁에게 제공한 사실과 乙이 丁으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받아 특허출원 및 등록한 사실을 인지하였다. 그 후 甲은 乙의 특허권에 대하여 2009년 9월 1일자로 특허법 제33조 제1항의 규정을 이유로 무효심판을 청구하였고 2010년 7월 1일자로 위 특허등록을 무효로 하는 심결이 확정되었다.

위와 같은 사실관계를 기초로 하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 甲이 "신물질 A"에 대하여 특허를 받을 수 있는지 여부와 甲이 특허등록을 받기 위하여 취하여야 할 조치에 대하여 설명하시오. (10점)
- (2) 甲은 진정한 발명자로 "신물질 A"를 2007년 4월 5일자로 출원일을 소급하여 특허권을 받은 후에 乙 및 丙의 실시행위에 대하여 침해금지를 요구하는 소송을 제기하였다. 이에 대하여 乙 및 丙은 甲의 특허권에 대하여 법정실시권이 있다는 이유로 비침해를 주장할 수 있는지 설명하시오. (13점)
- (3) 신기술을 노하우로 관리하는 경우와 특허출원하는 경우의 장·단점을 비교하여 설명하시오. (7점)

모범답안

I. 설문 (1) — 甲이 특허를 받을 수 있는지와 취하여야 할 조치 (10점)

1. 문제의 소재

신물질 A의 발명자는 甲이고 乙의 특허는 무권리자의 특허로서 무효로 확정되었다. 甲이 지금 새로 출원하면 乙의 출원공개와 판매로 신규성이 부정되므로, 출원일을 무권리자의 출원일로 소급받을 수 있는지와 그러기 위하여 어떠한 조치를 취하여야 하는지가 문제된다.

2. 정당한 권리자의 보호방법

무권리자의 특허가 설정등록된 경우 정당한 권리자는 i) 무효심판으로 그 특허를 무효로 한 다음 출원일을 소급받아 스스로 특허를 받는 방법(§ 35)과 ii) 법원에 그 특허권의 이전을 청구하는 방법(§ 99의2) 중에서 선택할 수 있다. 사안에서는 이미 무효심결이 확정되어 乙의 특허권이 소멸하였으므로 이 전청구의 대상이 없고, 제35조에 따른 출원만이 문제된다.

3. 제35조에 따른 출원일 소급의 요건

(1) 주체적 요건

무권리자의 특허출원에 대하여 착오로 특허권의 설정등록이 있고, 발명자 또는 그 승계인인 정당한 권리자가 출원하여야 한다.

(2) 객체적 요건

정당한 권리자 출원의 명세서 또는 도면에 적힌 발명이 무권리자 출원의 발명 범위, 곧 무권리자가 출원할 때 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 적힌 사항의 범위에 포함되어 있어야 한다.

(3) 시기적 요건

무권리자의 특허가 제33조 제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제133조 제1항 제2호에 해당하여 무효로 한다는 심결이 확정되고, 그 확정된 날부터 30일 이내에 출원하여야 한다(§ 35).

4. 효 과

(1) 출원일의 소급

무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 보며, 존속기간은 무권리자의 특허출원일의 다음 날부터 기산한다(§ 88②).

(2) 심사청구기간의 특례

심사청구기간도 무권리자의 출원일의 다음 날부터 기산되므로 소급의 결과 이미 지나 있을 수 있다. 그리하여 그 기간이 지난 뒤라도 정당한 권리자가 특허출원을 한 날부터 30일 이내에는 출원심사를 청구할 수 있도록 하고 있다(§ 59③).

(3) 선출원과 신규성

무권리자의 특허출원은 선출원을 적용할 때 처음부터 없었던 것으로 보므로(§ 36⑤) 乙의 출원은 甲의 출원에 대하여 선출원의 지위를 가지지 아니한다. 또한 출원일이 소급하는 이상 그 후에 이루어진 乙의 출원공개나 판매는 신규성을 부정하는 자료가 되지 아니하고, 甲은 신물질 A를 영업비밀로 관리하여 왔을 뿐 스스로 공개한 바도 없다.

5. 사안의 포섭

甲은 신물질 A의 발명자이고 乙의 특허는 제33조 제1항 본문 위반을 이유로 2010년 7월 1일 무효로 확정되었으므로, 甲은 그 날부터 30일 이내에 신물질 A에 대하여 특허출원을 하면서 정당한 권리자임을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다. 나아가 출원일이 2007년 4월 5일로 소급하면 심사청구기간 3년은 2010년 4월 5일에 이미 지나 있으므로, 甲은 출원한 날부터 30일 이내에 출원심사를 청구하여야 한다.

6. 결론

甲의 출원은 2007년 4월 5일에 특허출원한 것으로 보게 되므로, 다른 거절이유가 없는 한 甲은 신물질 A에 대하여 특허를 받을 수 있다.

II. 설문 (2) — 乙과 丙이 법정실시권을 주장할 수 있는지 (13점)**1. 문제의 소재**

甲이 출원일을 소급받아 특허권을 취득한 이상 그 전부터 신물질 A를 실시하여 온 乙과, 그로부터 신물질 A를 구입하여 살충제를 제조·판매하는 丙이 각각 법정실시권을 이유로 침해가 아니라고 주장할 수 있는지가 문제된다.

2. 무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권**(1) 의의 및 취지**

특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우, 그 무효로 된 특허의 원특허권자가 무효심판청구의 등록 전에 자기의 특허 발명이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 통상실시권을 가진다(§ 104①(3)). 이를 강학상 중용권이라 한다. 등록을 적법한 것으로 믿은 자를 보호하는 한편 그 실시를 통하여 갖추어진 산업설비를 유지하는 것이 산업발전에 이바지한다는 산업정책적 고려에 따른 것이다.

(2) 요건

- ① **(주체)** 제104조 제1항 각 호에 열거된 자, 곧 무효로 된 특허의 원특허권자 등이거나 무효심판청구의 등록 당시에 이미 실시권을 취득하고 등록을 받은 자여야 한다.
- ② **(시기)** 무효심판청구의 등록 전의 실시여야 한다. 여기의 등록이란 심판청구의 사실을 공중에 알리기 위하여 특허원부에 하는 예고등록을 말한다.
- ③ **(선의)** 자기의 특허가 무효사유에 해당함을 알지 못하였어야 한다. 따라서 모인자 자신이나 무권리자임을 알고 권리를 양수한 자는 선의라고 할 수 없어 통상실시권을 가지지 못한다.
- ④ **(실시사업)** 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있거나 그 사업을 준비하고 있어야 한다.

(3) 대가

선사용권이 특허권자와의 이익조정이라는 공평의 이념에서 무상으로 인정되는 것과 달리, 중용권은 무권리자로 된 자의 설비와 사업을 보호하려는 산업정책 견지에서 인정되는 것이므로 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(§ 104②).

3. 乙에 대한 판단

乙은 무효로 된 특허의 원특허권자이므로 제104조 제1항 제3호의 주체에 해당한다. 또한 丁이 직접 연구개발하였다고 하여 그로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았으므로, 모인자를 정당한 권리자로 믿고 권리를 양도받은 선의의 무권리자이고 자기의 특허에 무효사유가 있음을 알지 못하였다. 나아가 무효심판이 청구된 2009년 9월 1일보다 앞선 2008년 8월 4일부터 신물질 A를 제조·판매하여 왔으므로 예고등록 전에 국내에서 실시사업을 하고 있었다. 따라서 乙은 그 실시하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 중용권을 가지고, 甲에게 상당한 대가를 지급할 것을 전제로 비침해를 주장할 수 있다.

4. 丙에 대한 판단**(1) 丙 자신의 중용권**

丙은 무효로 된 특허의 원특허권자가 아니고, 신물질 A를 스스로 생산한 것이 아니라 乙로부터 구입하였을 뿐이어서 등록된 실시권자도 아니므로 제104조 제1항 각 호의 어느 주체에도 해당하지 아니한다. 따라서 丙은 스스로 중용권을 주장할 수 없다.

(2) 권리소진

다만 특허권자나 제조·판매권을 가진 실시권자가 특허발명을 실질적으로 구현한 제품을 적법하게 판매하면 그 물건에 관한 특허권은 목적을 달성하여 소진된다. 乙은 중용권이라는 통상실시권에 기초하여 적법하게 신물질 A를 생산·판매한 것이므로, 이를 정당하게 양수한 丙이 그 물건을 사용하여 살충제를 제조·판매하는 행위에는 甲의 특허권의 효력이 미치지 아니한다. 침해금지소송에서는 권리소진의 항변이 허용되므로 丙은 이를 주장할 수 있다.

5. 결론

乙은 중용권을 이유로 비침해를 주장할 수 있으나, 丙은 법정실시권을 주장할 수는 없고 권리소진을 이유로 비침해를 주장할 수 있을 뿐이다.

Ⅲ. 설문 (3) — 노하우 관리와 특허출원의 장단점 (7점)**1. 비교의 기준**

발명을 완성한 자는 이를 특허출원하여 보호받을 수도 있고 공개하지 아니한 채 노하우로 보호할 수도 있다. 양자는 i) 공개 여부, ii) 성립요건과 특허요건, iii) 보호기간, iv) 보호범위와 독점·배타성, v) 침해에 대한 구제라는 기준에서 나뉘므로, 아래에서는 각 기준에 따라 장단점을 본다.

2. 공개 여부

특허는 출원일부터 1년 6개월이 지나면 공개되므로 경쟁자에게 회피설계나 개량의 단서를 준다. 반면 권리의 내용이 공시되어 실시권 설정이나 투자 유치가 쉽다. 노하우는 공개되지 아니하여 그러한 단서를 주지 아니하나, 공시가 없어 기술이전이나 협업에는 제약이 따른다.

3. 성립요건과 특허요건

특허는 발명의 정의(§ 2(1))를 만족하고 신규성·진보성 등의 특허요건을 갖추어야 하므로 그 대상이 제한되고, 출원·심사·등록에 비용과 시간이 든다. 노하우는 특별한 정의의 규정이 없고 특허요건도 요구되지 아니하므로, 특허의 대상이 되지 아니하는 판매방법이나 경영상의 정보까지 보호할 수 있고 그러한 부담도 없다.

4. 보호기간

특허권은 존속기간이 출원일 후 20년으로 제한되어 그 후에는 누구나 실시할 수 있다. 노하우는 비밀이 유지되는 한 기간의 제한이 없고, 뒤에 제3자가 같은 발명으로 특허를 받더라도 선사용에 의한 통상실시권으로 대항할 수 있다(§ 103). 다만 비밀이 깨지면 보호도 함께 사라진다.

5. 보호범위와 독점·배타성

특허의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 명확하게 정하여지고(§ 97) 그 권리는 독점·배타적이다. 노하우는 보호범위가 불명확하고 독점·배타성이 없다.

6. 침해에 대한 구제

특허는 권리를 부여하는 것이므로 특허법상 권리에 기하여 금지청구·손해배상 등 민사상·형사상 조치를 할 수 있고, 제3자가 독자적으로 개발한 경우에도 그 제조·판매를 막을 수 있다. 노하우는 계약의 내용에 의하여 보호될 뿐이고, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 의한 보호도 비공지성·경제적 유용성·비밀관리성을 갖춘 영업비밀에 대하여 부정한 취득·사용 등의 행위를 규제하는 데 그친다. 그리하여 제3자가 스스로 개발하거나 역설계로 같은 기술에 이른 경우에는 그 실시를 막을 수 없어, 보호의 강도는 특허가 훨씬 높다.

7. 결론

역설계로 쉽게 분석되는 기술은 특허출원이, 공정과 같이 비밀유지가 용이한 기술은 노하우 관리가 유리하다. 신물질 A는 판매를 통하여 분석될 수 있는 물질이므로 특허출원이 적절하였다고 할 것이다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
(1) 甲의 특허 가능성 판단	4	진정한 권리자성(\$33①), 신규성 상실(\$29①), 제36조 무효확정으로 해소
(1) 특허등록 조치 - 제30조 검토·부정	2	의사에 반한 공지에 해당하나 공지일(2008. 8. 4.)로부터 12개월(\$30①) 도과로 제30조 주장 불가
(1) 특허등록 조치 - 제35조 정당권리자 출원	4	제35조 요건, 무효심결확정일로부터 30일 이내 출원 시 무권리자 출원 시로 소급
(2) 乙의 중용권(\$104) 인정 여부	6	선의 요건(\$104①(3)), 무효심판청구 시 실시 사실, 대가지급(\$104②), 중용권 인정 결론
(2) 丙의 법정실시권 인정 여부	4	丙에게는 제104조 직접 적용 불가, 기관성 부정 → 중용권 원용 불가
(2) 丙의 권리소진 항변	3	乙의 적법(중용권) 실시에 따른 소진, 다만 '법정실시권' 항변 자체는 불가
(3) 노하우 관리 vs 특허출원 장단점 비교	7	존속기간·독점성·공개·안정성·보호대상·역설계 대응 등 비교 서술

배점 합계: 30점

축별 채점 기준

1. 논점 추출 (12점)

- **특점:** (1) 신규성 상실을 정확히 지적하고 제35조 정당권리자 소급출원을 핵심 조치로 제시. (2) 乙에게는 제104조 중용권, 丙에게는 소진 이론이라는 서로 다른 결론을 도출. (3) 노하우와 특허의 장단점을 대비 항목으로 정리.
- **감점:** 제30조(공지예외)만 언급하고 제35조를 놓친 경우, 乙·丙에 대해 법정실시권을 확실적으로 인정/부정한 경우, 진정 권리자·제36조 관계를 언급하지 못한 경우. 채점평 지적대로 노하우-특허 관계의 논점만 나열하고 세부 내용을 결한 답안은 감점.

2. 목차·구성 (7점)

- **특점:** 설문별로 목차 분리, 배점 비례(10:13:7) 분량 배분, (2)에서 乙과 丙을 목차로 분리하여 강약 조절.
- **감점:** 채점평 지적대로 선사용권·중용권·소진을 균등하게 나열(불필요한 § 103 장황 서술), 서론 과다, (3)의 배점(7점)에 비해 지나치게 짧거나 항목 나열식.

3. 답안 작성·논증 (11점)

- **특점:** 조문(§ 33, § 35, § 104) → 요건 → 사안 포섭 → 소결의 흐름. 제35조의 30일 기간 요건을 사안 일자(2010. 7. 1. 확정 → 2010. 7. 31.까지)에 대입. 제104조 제1항 제3호 '선의' 요건을 丁을 진정 권리자로 알았다는 사실에 포섭. 丙에 대해 법정실시권 부정 + 소진으로 결론 이원화.
- **감점:** 조문 전사식 나열, 乙 중용권 요건만 나열하고 사안 포섭 누락, 丙에 대해 '중용권 원용 가능'이라고 근거 없이 결론 낸 경우, 소진 이론과 법정 실시권 항변을 혼동한 답안.

감점 주의

- 제30조(공지예외)만 답하고 제35조를 누락하거나 반대로 제35조만 답하고 제30조 검토를 생략한 경우.
- 제30조의 유예기간을 구법상의 6개월로 서술한 경우(현행 § 30① 12개월). 사안에서는 어느 쪽 기간으로 보더라도 도과이나, 현행법 기간을 정확히 적시할 것.
- 제35조의 기간요건을 '무효심결 확정일로부터 30일'로 서술하지 않고, 구법상의 '등록공고일로부터 2년' 요건을 병기하는 경우(현행 § 35 단서는 심결확정일로부터 30일 요건만 규정).
- 乙·丙을 구분하지 않고 일괄로 중용권 인정 또는 소진 인정으로 처리.
- 丙에 대해 '법정실시권이 있어 비침해'라고 결론(설문은 '법정실시권으로 비침해 주장 가능한지'를 물으므로 丙은 부정이 원칙, 소진은 별론).
- 노하우 vs 특허 비교에서 존속기간·공개 여부·불안정성·보호대상 범위 중 2~3개만 나열하고 배점 대비 부실한 서술.
- 채점평 지적: 선사용권(§ 103) 등 무관 조문의 장황한 서술.

2010년 제2문

사례형

20점

문제

제약회사 甲은 후천성면역결핍증(AIDS) 치료제를 제조하는데 필수성분인 "물질 A"에 대한 우리나라와 이집트의 특허권자이며, 우리나라에서 "물질 A"를 포함하는 후천성면역결핍증 치료제를 생산하여 우리나라에 판매하고 있으나, 국민건강보험공단과의 약값 협의에서 연구개발비가 실질적으로 반영되지 아니한 약값이 책정되었다는 이유로 수량을 한정 판매하여 국내수요를 충족시키지 못하고 있다.

위와 같은 사실관계를 기초로 하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 제약회사 乙이 甲의 특허발명 "물질 A"에 대하여, 甲과 합리적인 조건하에서 통상실시권 허락에 대하여 협의를 하였으나 합의가 이루어지지 아니한 경우 국내수요를 충족시키지 못한다는 이유로 지식재산처장에게 재정을 청구할 수 있는지 설명하시오. **(6점)**

(2) 제약회사 乙이 후천성면역결핍증 환자가 급증하고 있는 이집트(WTO 회원국)에 "물질 A"를 수출하고자 하는 경우 지식재산처장에게 재정을 청구하기 위한 조건을 설명하시오. **(9점)**

(3) (2)의 경우 지식재산처장이 재정을 함에 있어서, 乙에게 부과해야 할 조건 및 대가에 대하여 설명하시오. **(5점)**

모범답안

I. 설문 (1) — 국내수요 불충족을 이유로 한 재정청구의 가부 (6점)

1. 재정의 의의

재정이란 특허발명에 관하여 일정한 공익적 사유가 있음에도 당사자 사이의 합의가 이루어지지 아니한 경우에 지식재산처장의 처분으로 통상실시권을 설정하여 주는 것을 말한다(§ 107). 특허발명을 실시하지 아니하거나 불충분하게 실시하면서 제3자의 실시만을 막는 것은 실시의 장려를 통한 산업발전이라는 특허법의 목적에 어긋나므로, 강제로 실시하게 하여 그 폐해를 조정하려는 것이다.

2. 요건

(1) 재정사유

특허발명이 상당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되고 있지 아니하거나, 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우여야 한다(§ 107①(2)).

(2) 협의의 전치

특허발명을 실시하려는 자는 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건으로 통상실시권 허락에 관한 협의를 하였으나 합의가 이루어지지 아니하거나 협의를 할 수 없어야 한다(§ 107①본문). 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하려는 경우와 제4호의 경우에만 협의가 면제되므로, 제2호에 의한 재정에는 협의의 전치가 요구된다.

(3) 시기적 요건

제107조 제1항 제1호와 제2호는 특허출원일부터 4년이 지나지 아니한 특허발명에는 적용하지 아니한다(§ 107②).

3. 사안의 포섭

甲은 국내에서 물질 A를 실시하고 있으나 약값 협의가 이루어지지 아니하였다는 이유로 수량을 한정하여 판매함으로써 국내수요를 충족시키지 못하고 있으므로, 이는 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우에 해당한다. 乙은 이미 甲과 합리적인 조건으로 협의하였으나 합의에 이르지 못하였으므로 협의의 전치도 갖추었다.

4. 결론

물질 A에 대한 특허출원일부터 4년이 지났다면 乙은 제107조 제1항 제2호를 이유로 지식재산처장에게 재정을 청구할 수 있다.

Ⅱ. 설문 (2) — 이집트로의 수출을 위한 재정청구의 조건 (9점)

1. 문제의 소재

수입국에 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에도 재정을 청구할 수 있다(§ 107①(5)). 의약품에 대한 접근을 보장하기 위한 세계무역기구의 결정을 국내법에 받아들인 것으로서, 다른 재정사유와 달리 수입국과 의약품에 관한 고유한 요건이 요구되므로 이를 살펴본다.

2. 요 건

(1) 재정사유

자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품을 수입하려는 국가에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있어야 한다(§ 107①(5)).

(2) 수입국의 요건

수입국은 세계무역기구 회원국 중 i) 필요로 하는 의약품의 명칭과 수량, ii) 최빈개발도상국이 아닌 경우 그 의약품의 생산을 위한 제조능력이 없거나 부족하다는 확인, iii) 수입국에서 그 의약품이 특허된 경우 강제적인 실시를 허락하였거나 허락할 의사가 있다는 확인을 세계무역기구에 통지한 국가여야 한다(§ 107⑦).

(3) 대상 의약품

특허된 의약품, 특허된 제조방법으로 생산된 의약품, 의약품 생산에 필요한 특허된 유효성분, 의약품 사용에 필요한 특허된 진단키트 중 어느 하나에 해당하여야 한다(§ 107⑧).

(4) 협의의 전치

협의를 면제되는 것은 공공의 이익을 위한 비상업적 실시와 제4호의 경우에 한하므로, 제5호에 의한 재정에도 합리적인 조건으로 협의를 거쳐야 한다.

(5) 시기적 제한의 부적용

제107조 제2항의 4년 제한은 제1항 제1호와 제2호에만 적용되므로 제5호에 의한 재정에는 적용되지 아니한다. 또한 반도체 기술에 관한 제한(§ 107⑥)도 제5호에는 미치지 아니한다.

3. 절 차

乙은 특허권자인 甲을 피청구인으로 하여 재정청구서를 지식재산처장에게 제출하여야 하고, 지식재산처장은 청구별로 통상실시권 설정의 필요성을 검토한다(§ 107①③). 다만 제5호에 따른 재정청구가 제107조 제7항과 제8항에 해당하고 같은 조 제9항에 따른 서류가 모두 제출된 경우에는, 지식재산처장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 재정을 하여야 한다(§ 110④).

4. 사안의 포섭

이집트는 세계무역기구 회원국이고 후천성면역결핍증 환자가 급증하여 자국민 다수의 보건의 위협받고 있으며, 물질 A는 그 치료제의 필수성분으로서 제107조 제8항의 유효성분에 해당한다. 따라서 이집트가 제107조 제7항의 사항을 세계무역기구에 통지하고 乙이 甲과 합리적인 조건으로 협의를 거쳤다면, 물질 A의 출원일부터 4년이 지나지 아니하였더라도 재정을 청구할 수 있다.

5. 결론

乙은 위 요건을 갖추어 제107조 제1항 제5호에 따라 지식재산처장에게 재정을 청구할 수 있고, 그 요건과 서류가 모두 갖추어지면 지식재산처장은 정당한 사유가 없는 한 재정을 하여야 한다.

Ⅲ. 설문 (3) — 乙에게 부과하여야 할 조건과 대가 (5점)

1. 부과하여야 할 조건

(1) 수출 목적의 실시

제107조 제1항 제5호에 따른 재정을 하는 경우에는 생산된 의약품 전량을 수입국에 수출하여야 한다는 조건을 붙여야 한다(§ 107④(2)). 제1호부터 제3호까지의 재정에 국내수요 충족을 주목적으로 실시할 것이라는 조건이 붙는 것과 구별된다.

(2) 포장·표시와 공시

특허권자·전용실시권자 또는 재정에 의하지 아니한 통상실시권자가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시, 그리고 재정에서 정한 사항을 공시할 인터넷 주소를 재정서에 구체적으로 적어야 한다(§ 110②(3)). 수출된 의약품이 다시 흘러들어오는 것을 막기 위한 것이다.

(3) 그 밖의 기재사항

통상실시권의 범위와 기간, 그 밖에 특허발명을 실시할 때 법령이나 조약에 따른 내용을 이행하기 위하여 필요한 준수사항도 재정서에 적어야 한다 (§ 110②(1)(4)).

2. 대 가

(1) 상당한 대가

지식재산처장은 재정을 하는 경우 상당한 대가가 지급될 수 있도록 하여야 한다 (§ 107⑤).

(2) 수입국에서의 경제적 가치

제107조 제1항 제5호에 따른 재정을 하는 경우에는 그 특허발명을 실시함으로써 발생하는 수입국에서의 경제적 가치를 대가의 결정에 고려할 수 있다 (§ 107⑤(2)). 수입국의 지불능력을 반영하기 위한 것이다.

(3) 지급의 확보

대가와 그 지급방법 및 지급시기를 재정서에 구체적으로 적어야 하고 (§ 110②(2)), 지급시기까지 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 재정은 효력을 잃는다 (§ 113).

3. 결론

지식재산처장은 乙에게 생산된 의약품 전량을 이집트에 수출할 것과 포장·표시 및 공시할 인터넷 주소에 관한 조건을 붙여야 하고, 상당한 대가가 지급되도록 하되 이집트에서의 경제적 가치를 고려할 수 있다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
(1) 국내수요 불충족을 이유로 한 재정청구 거부 (§107①(2))	6점	재정의 의의·법적 성격, 제107조 제1항 제2호(불실시가 아닌 '국내수요 불충족') 해당성, 협의 전치(§107① 본문)·합리적 조건 요건 충족, 시기적 요건(§107②: 특허출원일부터 4년 경과) 검토, 결론
(2) 이집트(WTO 회원국)로 수출하기 위한 재정청구 조건 (§107①(5))	9점	제107조 제1항 제5호(자국민 다수 보건 위협 질병 치료용 의약품 수출) 해당성, 수입국 요건(§107⑦: WTO 통지 등), 대상 의약품 요건(§107⑧), 협의 전치 원칙 적용(단서 예외에 해당하지 않음), 시기적 요건(§107②은 제1항 제1호·제2호에만 적용되므로 제5호에는 적용되지 아니함), 사안 포섭
(3) 재정 시 부과 조건 및 대가 (§107④·⑤, §110②, §111 등)	5점	부과조건(§107④(2) 전항 수입국 수출; §110②(3) 포장·표시 및 인터넷 주소 공시), 대가 원칙(§107⑤) 및 수입국에서의 경제적 가치 고려(§107⑤ 후단 및 제2호), 재정서 기재사항(§110②), 재정서 송달의 효과(§111), 재정실시권의 이전 제한 (§102③), 등록 대항력(§118)

배점 합계: 20점

특별 채점 기준

1) 논점 추출 (40%)

- **특점:** 설문 (1)은 제107조 제1항 제2호, (2)는 제107조 제1항 제5호·⑦·⑧, (3)은 제107조 제4항·⑤·제110조 제2항·제111조의 조문을 정확히 특정.
- **특점:** 사안의 '국내수요 불충족'과 'WTO 회원국 수출'을 구분해 각각 다른 재정사유임을 인식.
- **감점:** 세 설문을 모두 제107조 제1항 제1호(불실시)로 처리하거나 제107조 제1항 제2호로 몽뚱그림.
- **감점:** 협의 전치 예외(§ 107① 본문 단서)의 적용 범위(공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하는 경우와 제4호에 한함)를 잘못 파악하여 제5호 예외 예외가 적용되는 것으로 서술.
- **감점:** 강제실시권 일반론·TRIPs 도하선언 배경만 장황하게 서술하고 조문 포섭 부재.

2) 목차·구성 (25%)

- **특점:** 설문별로 (1)-(2)-(3) 목차 분리, 각 설문 내 '요건 → 사안 포섭 → 결론' 구성.
- **특점:** 배점 비례(6:9:5) 분량 배분, (2)에 가장 많은 지면 할애.
- **감점:** 법전 조문을 그대로 옮겨쓰기(채점평 지적사항: "법전의 내용을 그대로 작성한 답안이 많았다").
- **감점:** 조문 번호 혼동(§ 107⑧ ↔ § 107④, § 111 ↔ § 110, § 102③ ↔ § 102⑤).

3) 답안 작성·논증 (35%)

- **특점:** 조문(§ 107) 인용 후 사안의 구체적 사실(약값 협의 결렬, 수량 한정 판매, 이집트 AIDS 급증)에 포섭.
- **특점:** (1)에서 '불실시'가 아닌 '국내수요 불충족(§ 107①(2))'로 정확히 접근하고, 제107조 제2항(특허출원일부터 4년) 요건도 함께 검토.
- **특점:** (2)에서 수입국이 WTO 회원국일 것 및 제107조 제7항 각호의 통지사항(의약품 명칭·수량, 제조능력 부재 확인, 강제실시 허락 의사 등), 대상 의약품 범위(§ 107⑧ 각호)를 조문 순서대로 포섭.
- **특점:** (3)에서 부과조건(§ 107④(2) 전항 수출, § 110②(3) 포장·표시 및 인터넷 공시)과 대가(§ 107⑤ 원칙 및 후단·제2호 수입국 경제적 가치 고려)를 적용 법규정과 함께 정확히 구분 서술.
- **감점:** 결론 모호, 조문 나열식 서술, 사안 포섭 부재.

감점 주의

- 채점평상 최대 감점 사유: **문제 요지와 무관하게 법전 조문을 그대로 옮겨 적기.** 반드시 사안(甲의 수량 한정 판매, 乙의 이집트 수출) 사실에 포섭 하는 문장을 쓸 것.
- (1)에서 제107조 제1항 제1호(불실시)로 잘못 접근하면 대폭 감점. 甲은 실시는 하고 있으나 국내수요를 못 채우므로 제107조 제1항 제2호가 정답.
- (1)·(2)에서 협의 전치의 예외 범위를 오인하는 경우 감점. 현행 제107조 제1항 본문 단서는 '공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하려는 경우와 제4호'에 한해 협의를 생략할 수 있도록 하며, **제5호는 원칙적으로 협의 전치를 요한다.**
- (2)에서 제107조 제1항 제5호(자국민 다수 보건 위협 질병 치료용 의약품 수출)임을 놓치고 제107조 제1항 제3호(공공이익)로 접근하면 문제 취지 오독으로 감점.
- (3)에서 부과조건·대가의 적용 법규정을 혼동(전항 수출은 § 107④(2), 포장·표시·인터넷 공시는 § 110②(3), 수입국 경제적 가치는 § 107⑤ 후단·제2호)하면 감점. 제107조 제6항(반도체 기술)·제107조 제7항(수입국 요건)·제104조의2(현행법에 부존재)를 부과조건 근거로 인용하지 말 것.
- 백지답안 방지: 조문만이라도 정확히 특정하고 사안에 한 문장이라도 포섭할 것.

2010년 제3문

사례형

30점

문제

甲은 차량용 공조장치에 장착되는 이온 발생장치를 개발하여 2009년 8월 3일자로 특허출원을 하였는데 출원시의 청구범위는 다음과 같다.

【청구범위】

[청구항 1] 구성요소 A, B, C, D를 포함하는 것을 특징으로 하는 이온 발생장치.

[청구항 2] 제1항에 있어서, 구성요소 A는 a인 것을 특징으로 하는 이온 발생장치.

[청구항 3] 제1항에 있어서, 구성요소 E를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이온 발생장치.

[청구항 4] 제1항 또는 제3항에 있어서, 구성요소 D는 d인 것을 특징으로 하는 이온 발생장치.

위 특허출원에 대하여 심사관은 청구항 1 및 청구항 2에 기재된 발명이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 특허를 받을 수 없다는 취지의 의견제출통지서를 2010년 4월 30일자로 甲에게 발송하였다.

(1) 甲은 2010년 4월 30일자 의견제출통지서에 기재된 심사결과에 수긍하여 청구항 3 및 청구항 4만이라도 특허를 받고자 한다. 이 경우 보정서에 기재할 청구범위를 작성하시오. (3점)

(2) 위 2010년 4월 30일자 의견제출통지서가 최후거절이유통지라고 가정할 경우, 청구범위의 보정에 어떠한 제한이 있는지 설명하시오. (9점)

(3) 甲은 위 2010년 4월 30일자 의견제출통지서에 대하여 청구범위를 보정하지 않고 의견서만 제출하여 거절결정이 되었고, 이 거절결정서는 2010년 7월 1일자로 甲에게 송달되었다. 이 경우, 甲이 청구범위를 보정하여 등록받고자 하는 경우와 청구범위를 보정하지 않으면서 등록받고자 하는 경우 각각 취하여야 할 조치에 대하여 설명하시오. (12점)

(4) 甲은 수신인을 특허심판원장으로 하여 청구범위를 보정한 보정서와 거절결정불복심판청구서를 동일자로 제출하였다. 이 경우 위 보정서가 어떻게 취급이 되는지와 거절결정불복심판의 절차 진행에 대하여 설명하시오. (6점)

모범답안

I. 설문 (1) — 보정서에 적을 청구범위 (3점)

1. 보정의 방향

진보성이 부정된 청구항 1과 그 종속항인 청구항 2를 삭제하여야 한다. 그런데 청구항 4는 제1항 또는 제3항을 선택적으로 인용하고 있어 실질적으로 A, B, C, d의 발명과 A, B, C, d, E의 발명을 함께 담고 있다. 청구항 1이 삭제되더라도 A, B, C, d의 발명은 남겨야 하므로, 이를 별도의 독립항으로 적어야 한다.

2. 보정 후의 청구범위

[청구항 1] 구성요소 A, B, C, D 및 E를 포함하는 것을 특징으로 하는 이온 발생장치.

[청구항 2] 제1항에 있어서, 구성요소 D는 d인 것을 특징으로 하는 이온 발생장치.

[청구항 3] 구성요소 A, B, C, d를 포함하는 것을 특징으로 하는 이온 발생장치.

[청구항 4] 삭제

3. 결론

위와 같이 적으면 종전 청구항 3의 발명은 청구항 1로, 청구항 4의 제3항 인용분은 청구항 2로, 그 제1항 인용분은 청구항 3으로 각각 남게 되어 甲이 특허를 받고자 하는 발명이 모두 보호된다. 이는 청구항의 삭제와 감축에 해당하므로 보정의 범위도 벗어나지 아니한다.

II. 설문 (2) — 최후거절이유통지에 대한 청구범위 보정의 제한 (9점)

1. 문제의 소재

최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 하는 보정은 심사의 지연을 막기 위하여 그 범위가 제한되므로, 어떠한 제한을 받고 이를 위반한 경우 어떻게 취급되는지가 문제된다.

2. 보정의 시기와 일반적 제한

특허출원인은 최후거절이유통지를 받은 경우 그 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다(§ 47①(2)). 그 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 적힌 사항의 범위에서 하여야 하고(§ 47②), 이를 벗어난 보정은 신규사항의 추가로서 거절이유가 되며 등록 후에는 무효사유가 된다.

3. 청구범위 보정의 제한

최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 하는 청구범위의 보정은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다(§ 47③).

(1) 청구범위의 감축

청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우이다. 구성요소를 하위개념으로 한정하거나 새로운 구성요소를 부가하여 범위를 좁히는 것이 이에 해당한다.

(2) 잘못 기재된 사항의 정정

명세서나 도면의 잘못 적힌 사항을 바로잡는 경우이다.

(3) 분명하지 아니한 기재의 설명

분명하지 아니하게 적힌 사항을 명확하게 하는 경우이다.

(4) 신규사항 보정의 원상회복

제47조 제2항의 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전의 청구범위로 되돌아가거나, 되돌아가면서 청구범위를 위 (1)부터 (3)까지에 따라 보정하는 경우이다.

4. 위반의 효과

(1) 보정의 각하

심사관은 위 보정이 제47조 제2항 또는 제3항을 위반하거나 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다(§ 51①). 다만 청구범위의 감축이나 신규사항 보정의 원상회복에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 생긴 경우는 각하하지 아니한다. 청구항의 삭제는 출원인에게 불리한 것이 아니고 이를 각하하면 오히려 심사가 지연되기 때문이다.

(2) 불 복

각하결정은 서면으로 하여야 하고 그 이유를 붙여야 한다(§ 51②). 각하결정에 대하여는 독립하여 불복할 수 없으나, 특허거절결정에 대한 심판에서 그 각하결정의 당부를 다룰 수 있다(§ 51③).

5. 결론

甲은 i) 최초 명세서 또는 도면에 적힌 사항의 범위를 벗어나지 아니하고(§ 47②), ii) 위 네 가지 사유에 해당하며(§ 47③), iii) 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생하지 아니하는 범위에서만 청구범위를 보정할 수 있다. 청구항 1·2를 삭제하고 나머지 발명을 청구항으로 정리하는 보정은 청구항의 삭제와 감축에 해당하고 새로운 거절이유를 발생시키지도 아니하므로 적법하다.

Ⅲ. 설문 (3) — 거절결정 후 甲이 취하여야 할 조치 (12점)

1. 문제의 소재

특허거절결정을 받은 출원인은 보정을 하면서 다시 심사를 받을 것인지, 보정 없이 거절결정의 당부를 다룰 것인지를 선택하여야 하므로 각각의 절차와 그 선택관계가 문제된다.

2. 청구범위를 보정하여 등록받고자 하는 경우 — 재심사의 청구

(1) 의의 및 취지

재심사의 청구란 출원인이 명세서 또는 도면을 보정하여 그 출원에 관한 재심사를 청구함으로써 심사관에게 다시 심사를 받는 것을 말한다(§ 67의2). 심판을 청구하지 아니하고도 심사관의 재심사를 받을 수 있게 하여 절차를 간소화하고 불필요한 심판청구의 부담을 덜어 주려는 것이다.

(2) 시기와 절차

특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 청구하여야 하고, 그 기간은 지식재산처장이 청구에 따라 또는 직권으로 30일 이내에서 한 차례만 연장할 수 있다(§ 67의2①본문, § 15①). 재심사를 청구하려는 자는 보정서에 그 취지를 적어 지식재산처장에게 제출하여야 하며, 청구와 함께 의견서를 제출할 수 있다(§ 67의2②).

(3) 보정의 범위

재심사를 청구할 때 하는 보정도 최초 명세서 또는 도면에 적힌 사항의 범위에서 하여야 하고(§ 47②), 청구범위의 보정은 설문 (2)에서 본 제47조 제3항의 네 가지 사유에 한정된다. 이를 위반하면 심사관은 그 보정을 각하한다(§ 51①).

(4) 제한과 효과

재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 특허여부의 결정이 있는 경우, 거절결정불복심판이 청구된 경우, 그 특허출원이 분리출원인 경우에는 재심사를 청구할 수 없다(§ 67의2①단서). 적법한 재심사의 청구가 있으면 종전의 특허거절결정은 취소된 것으로 보며(§ 67의2③), 재심사의 청구는 취할 수 없다(§ 67의2④).

3. 청구범위를 보정하지 아니하고 등록받고자 하는 경우 — 거절결정불복심판**(1) 청 구**

특허거절결정을 받은 자가 그 결정에 불복할 때에는 결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 특허심판원에 심판을 청구할 수 있다(§ 132의17). 이 절차에서는 명세서의 보정이 예정되어 있지 아니하고 거절결정의 당부만이 심리된다.

(2) 절차와 효과

심판은 심판관 합의체가 심리하며, 청구가 이유 있다고 인정될 때에는 심결로써 특허거절결정을 취소하여야 하고 이 경우 사건을 심사에 부칠 것이라는 심결을 할 수 있다(§ 176①②). 환송된 사건에서 심결의 이유는 심사관을 기속한다. 심결에 불복하는 자는 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있다.

4. 양자의 관계

두 절차는 같은 3개월의 기간에 선택적으로 행사되는 관계에 있다. 재심사를 청구하면 거절결정이 취소된 것으로 보므로 다시 심판을 청구할 수 없고, 심판을 청구하면 재심사를 청구할 수 없다. 보정으로 거절이유를 해소할 수 있으면 재심사를, 거절결정 자체를 다투려면 심판을 선택하여야 한다.

5. 사안의 포섭

甲은 2010년 7월 1일 거절결정등본을 송달받았으므로 그로부터 3개월 이내에, 청구항 1·2를 삭제하고 청구항 3·4의 인용관계를 바로잡는 보정서에 재심사를 청구한다는 취지를 적어 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 반대로 청구항 1·2의 진보성이 부정되지 아니한다고 다투려면 같은 기간에 보정 없이 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하여야 한다.

6. 결론

甲은 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에, 보정하여 등록받으려면 보정서에 취지를 적어 재심사를 청구하고, 보정 없이 다투려면 거절결정불복심판을 청구하여야 한다.

IV. 설문 (4) — 특허심판원장을 수신인으로 한 보정서의 취급과 심판의 진행 (6점)**1. 문제의 소재**

甲은 특허심판원장을 수신인으로 하여 보정서와 거절결정불복심판청구서를 함께 제출하였다. 거절결정 후에 제출된 그 보정서를 어떻게 취급할 것인지가 문제된다.

2. 보정서의 취급**(1) 부적법한 서류인지**

거절이유통지를 받은 후의 보정은 제47조 제1항 각 호에 정한 기간에만 할 수 있고, 특허거절결정을 받은 뒤에는 재심사를 청구하는 때에만 할 수 있다(§ 47①(3)). 그리고 재심사를 청구하려는 자는 보정서에 그 취지를 적어 지식재산처장에게 제출하여야 한다.

甲의 보정서는 i) 수신인을 특허심판원장으로 하여 지식재산처장에게 제출된 것이 아니고, ii) 재심사를 청구한다는 취지도 적혀 있지 아니하다. 그러므로 이를 재심사의 청구에 따른 보정으로 볼 수 없어 보정이 가능한 기간에 제출된 것이라고 할 수 없고, 결국 이 법 또는 이 법에 따른 명령이 정하는 기간에 제출되지 아니한 서류로 취급된다. 나아가 거절결정불복심판이 청구된 이상 甲은 재심사를 청구할 수도 없다(§ 67의2①단서).

(2) 반 려

지식재산처장 또는 특허심판원장은 부적법한 서류를 반려하여야 하며, 이는 재량이 인정되지 아니하는 기속행위이다. 다만 곧바로 반려하는 것이 아니라 반려하겠다는 취지와 그 이유 및 소명기간을 적은 서면을 보내 소명의 기회를 주어야 하고, 소명이 없거나 이유 없다고 인정되면 반려한다. 반려된 서류는 적법한 서류로 보지 아니하므로 보정의 효력은 발생하지 아니한다.

3. 심판의 진행

보정의 효력이 발생하지 아니하므로 심판은 보정 전의 청구범위, 곧 청구항 1부터 제4항까지를 대상으로 진행된다. 심판관 합의체는 거절결정의 당부를 심리하여 청구가 이유 있으면 거절결정을 취소하는 심결을, 이유 없으면 청구를 기각하는 심결을 한다.

4. 결론

甲의 보정서는 소명질차를 거쳐 반려되고, 거절결정불복심판은 보정 전의 청구범위를 기준으로 심리된다. 보정을 통하여 등록을 받으려면 심판을 청구하지 아니하고 기간 내에 보정서에 취지를 적어 재심사를 청구하였어야 한다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

설문	쟁점	배점	득점 포인트
(1)	청구항 3-4만 남기는 실무 보정서 작성	3점	청구항 1-2 삭제 표시, 청구항 3을 독립항 형식으로 정정(A,B,C,D+E), 청구항 4는 정정된 3항 인용 종속항으로 재작성. 불필요한 신설항 추가 지양
(2)	최후거절이유통지 후 보정 제한 (§47③, ④, §51)	9점	청구범위 감축·오기 정정·불명료 해소·신규사항 추가 삭제(§47③), 신규사항 추가금지(§47②), 2009.7.1. 이후 보정부터는 실질적 변경금지 조항 삭제→ 자유로운 감축보정 가능, 위반 시 제51조 각하(§47①(2)-(3) 보정이 모두 각하대상, §47③(1)-(4)에 따른 청구항 삭제 보정으로 인해 발생한 새 거절이유는 각하대상에서 제외)
(3)	보정 O → 재심사청구(§67의2), 보정 X → 거절결정불복심판(§132의17)	12점	2009.7.1. 이후 출원은 심사전치 폐지·재심사청구제도 도입, 거절결정등본 송달일부 3개월 내 청구, 각 절차의 진행·효과, 사안 포섭
(4)	특허심판원장에 제출된 보정서의 취급과 심판 진행	6점	심사전치 폐지로 심사관 이관 불가, 수신인이 지식재산처장 아닌 특허심판원장이므로 재심사청구 보정서로 볼 수 없어 반려, 심판은 보정 전 청구법위로 진행

※ 배점 합계 30점.

축별 채점 기준

1. 논점 추출(약 12점)

- (1) '보정서에 기재할 청구범위를 직접 작성'이라는 실무형 요구를 정확히 이해했는가. 채점평은 문제를 잘못 이해한 답안이 대부분이라 지적.
- (2) 2009.7.1. 이후 보정부터 청구범위 실질적 변경금지(구 § 47④) 조항이 삭제되어 자유롭게 감축보정 가능하다는 개정 포인트를 짚었는가(채점평 핵심 지적).
- (3) 2009.7.1. 이후 출원부터 심사전치 폐지·재심사청구제도 도입이라는 시점 쟁점을 포착했는가.
- (4) 일반적 심판절차가 아니라, 특허심판원장 수신 보정서의 반려 및 미보정 상태 심판진행이라는 특수 상황을 포착했는가.

2. 목차·구성(약 7~8점)

- 설문 (1)~(4)를 각 소목차로 구분하고 배점(3/9/12/6)에 비례한 분량 배분.
- (1)은 청구항을 그대로 기재하는 실무 형식으로 답하고, 학설·조문 나열 지양.
- (3)은 '보정하며 불복'과 '보정 없이 불복' 두 경로를 소목차로 분리.

3. 답안 작성·논증(약 10~11점)

- 조문 (§ 47, § 51, § 67의2, § 132의17) 근거 제시 후 사안 포섭.
- (1) 청구항 3을 독립항으로 재작성(A,B,C,D+E), 청구항 4는 정정된 3항 인용으로 재작성. 새로운 종속항 추가 X.
- (2) 최후거절이유 후 제47조 제3항 각하(감축, 오기정정, 불명료해소, 신규사항추가 삭제) + 신규사항 금지 + 개정으로 실질적 변경금지 삭제 언급 + 위반 시 제51조 각하(단, § 47③(1)-(4)에 따른 청구항 삭제 보정으로 인해 새로운 거절이유가 발생한 경우는 각하 예외).
- (3) 재심사청구서는 지식재산처장에게 제출되며, 거절결정불복심판은 특허심판원에 청구. 청구기간(3개월)·효과(거절결정 취소간주, 취하금지 등) 명시.
- (4) 수신인 오류로 재심사청구로 볼 수 없어 반려 → 심판은 보정 전 청구법위로 진행이라는 결론을 명확히.

감점 주의

- (1)에서 청구범위를 직접 작성하지 않고 서술식으로 설명하거나, 불필요한 새 종속항을 추가한 경우 감점(채점평 지적).
- (2)에서 법조문만 옮겨 적고 개정(2009.7.1. 이후 실질적 변경금지 삭제) 포인트를 놓친 경우 대폭 감점. 또한 제51조 제1항의 각하대상 범위를 '재심사청구시 보정은 각하대상 제외'로 오서술한 경우 감점(현행법상 재심사청구시 보정도 § 47②·③ 위반이면 각하 대상).
- (3)에서 재심사·불복심판 조문만 옮겨 적고 심사전치 폐지·재심사제도 도입 개정 취지·시점을 언급하지 않은 경우 감점. 청구기간을 '30일'로 서술한 경우 감점(현행: 3개월).
- (4)에서 일반적 심판절차만 기술하고 '수신인 오류→반려, 미보정 상태로 심판진행'이라는 사안 특유 결론을 도출하지 못한 경우 감점.
- 법전 배포 상태에서 조문 전사만 하는 답안은 전반적 감점(총평).

2010년 제4문

약술형

20점

문제

물건의 발명에 있어 하나 이상의 구성이 그것을 제조하는 방법이나 수단을 동원하여 표현된 이른바 제법한정 물건발명(Product by process) 청구항의 청구범위해석에 대하여 설명하시오.

모범답안

I. 서 설

1. 의 의

제조방법이 기재된 물건발명이란 청구범위가 전체적으로 물건으로 적혀 있으면서 그 구성 중 하나 이상이 그것을 제조하는 방법이나 수단으로 표현된 발명을 말한다. 일반적으로 「X 단계와 Y 단계를 거쳐 제조되는 화합물 Z」와 같은 형태로 적힌다.

2. 활용의 국면

물건과 제조방법이 모두 신규한 경우, 특히 그 물건이 신규하여 특허를 받을 수 있으나 구조적 특성을 규명하지 못하여 제조방법을 특정하지 아니하면 물건 자체를 한정할 수 없는 경우에 이용된다. 그리하여 물건을 구조나 성질로 직접 특정하기 어려운 화학·생명공학 분야에서 주로 쓰인다.

3. 허용성

물건의 발명에 관한 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 적어야 한다. 그러나 특허법은 청구범위에 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적도록 하고 있으므로(§ 42⑥), 제조방법에 의하여 물건을 특정하는 기재도 허용된다. 다만 제조방법이 적혀 있더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로, 그 유형은 여전히 물건의 발명이다.

II. 특허요건을 판단할 때의 해석

1. 문제의 소재

제조방법의 기재를 구성으로 보아 그 방법으로 제조된 물건에 한정하여 신규성·진보성을 판단할 것인지, 아니면 제조방법을 떠나 최종적으로 얻어지는 물건을 대상으로 판단할 것인지가 문제된다.

2. 학 설

(1) 제법한정설

청구범위에 적힌 사항은 모두 발명을 특정하는 구성이므로 제조방법의 기재도 구성으로 보아, 그 제조방법에 의하여 제조된 물건에 한정하여 특허요건을 판단하여야 한다고 본다.

(2) 물건동일설

제조방법은 물건을 특정하는 수단에 불과하므로, 그 방법을 떠나 최종적으로 얻어지는 물건 자체를 대상으로 특허요건을 판단하여야 한다고 본다.

3. 종전의 판례

종전 판례는 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지에 따라 나누어, i) 그러한 사정이 있는 경우에는 제조방법을 고려한 물건발명에 의하여 특허요건을 판단하고, ii) 그러한 사정이 없는 경우에만 제조방법 자체를 고려할 필요 없이 물건발명에 의하여 특허요건을 판단하였다(2004후3416).

4. 전원합의체 판례

판례는 물건의 발명에 관한 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 적어야 하는 것이므로 청구범위에 적힌 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 의미를 가질 뿐이라고 하였다. 그리하여 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단할 때에는 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라, 제조방법의 기재에 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여야 한다고 하여 종전의 판례를 변경하였다(2011후927 전원합의체).

나아가 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있더라도 그 본질이 물건의 발명이라는 점과 제조방법의 기재가 물건을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지이므로, 그러한 사정이 있는 발명과 없는 발명을 구분하여 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니라고 하였다.

5. 검 토

제조방법이 기재된 물건발명의 본질은 물건의 발명이고, 특별한 사정의 유무라는 불명확한 기준에 따라 해석을 달리하면 권리관계가 불안정해진다. 그러므로 물건동일설에 따라 종전의 판례를 변경한 전원합의체 판례가 타당하다. 그 결과 제조방법에 신규성이나 진보성이 있다고 하여 그 방법으로 제조된 물건이 당연히 신규성이나 진보성을 가지는 것은 아니고, 제조방법이 제조의 효율이나 수율에만 영향을 미쳐 물건의 구조나 성질에 차이를 가져오지 아니한다면 제조방법을 제외한 물건 자체로 파악하여야 한다.

6. 심사실무

제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미쳤는지를 가리기는 어렵다. 그리하여 심사관은 제조방법을 고려하지 아니한 물건 자체와 동일한 인용대상에 의하여 신규성이나 진보성이 부정된다는 합리적인 의심이 있으면 그 취지의 거절이유를 통지하고, 출원인의 의견서 등을 참작하여 심사를 진행한다.

Ⅲ. 권리범위를 판단할 때의 해석

1. 문제의 소재

특허요건을 판단할 때와 침해 단계에서 권리범위를 판단할 때 청구범위를 같은 기준으로 해석할 것인가가 문제된다.

2. 판 례

판례는 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 침해 단계에서 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단할 때에도 특허요건을 판단할 때와 마찬가지로, 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 특허발명을 파악한다고 하였다. 다만 특허요건을 판단할 때와는 달리, 그러한 해석방법으로 도출되는 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 그 권리범위를 청구범위에 적힌 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다고 하였다(2013후1726).

3. 검 토

특허요건의 판단과 권리범위의 판단에서 청구범위를 달리 해석하면 특허의 유효성과 침해의 판단이 어긋나게 되므로 원칙적으로 같은 기준에 따르는 것이 타당하다. 다만 물건 자체로 넓게 해석한 결과가 명세서가 개시한 실체를 크게 넘어서는 경우까지 그대로 권리범위를 인정하면 공중에 공개하지 아니한 부분까지 독점권을 주는 것이 되어 제3자에게 부당한 불이익이 된다. 그 한도에서 제조방법으로 권리범위를 제한하는 판례(2013후1726)의 태도가 타당하다.

IV. 결 론

제조방법이 기재된 물건발명은 그 본질이 물건의 발명이므로, 특허요건을 판단할 때에는 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여야 한다. 권리범위를 판단할 때에도 같은 기준에 따르되, 그 결과가 명백히 불합리한 경우에는 제조방법의 범위 내로 권리범위를 한정할 수 있다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
PBP 청구항의 의의·활용 국면 및 허용성	3점	물건 카테고리 청구항에 제조방법을 기재한 형식임을 밝히고, 물건의 구조적 특성을 규명하기 어려운 경우에 쓰인다는 점과 제42조 제6항(구조·방법·기능·물질 등의 기재) 하에서 허용됨을 서술
청구범위 해석(제법한정설 vs 물건동일설)과 판례의 변경	4점	두 견해의 논거를 대비하고 자기 입장을 밝히며, 종전 대법원 판례가 '제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정'의 유무로 나누어 해석하였음(2004후3416 등)과 2011후927 전원합의체가 이를 변경하였음을 함께 서술
특허성(신규성·진보성) 판단시 해석	5점	대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결의 법리(제조방법이 기재되어 있어도 물건 자체를 기준으로 신규성·진보성 판단)를 정확히 서술
권리범위(침해) 판단시 해석	5점	대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결 등에 따라 특허성 판단과 동일한 기준(물건 자체 기준) 적용, 다만 명세서·출원경과 등을 참작해 제조방법으로 한정 해석할 예외 인정
결론(일관된 해석의 필요성 및 사건)	3점	특허성 판단과 권리범위 해석의 일관성 원칙을 명확히 결론지음

배점 합계: 20점

특별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- (+) 특허성 판단·권리범위 판단 두 국면으로 나누어 해석 문제를 접근한 답안
- (+) 대법원 전원합의체 판결(2011후927) 및 권리범위 판단 판결(2013후1726)의 법리를 정확히 적시
- (+) 학설 대립을 정리하고 자기 입장을 논거와 함께 제시하며, 종전 판례와 전원합의체 판례를 대비하여 무엇이 변경되었는지를 명확히 제시
- (-) PBP의 의의·형식 설명에만 지면을 할애하고 해석론(핵심)이 빈약한 답안(채점평 지적: "정형화된 문제일수록 논점을 신중하게 잡아라")
- (-) 학설만 나열하거나 판례 변경의 내용을 밝히지 아니한 답안

2) 목차·구성(25%)

- (+) "의의·허용성 → 학설 → 종전 판례와 판례 변경 → 특허성 판단시 해석 → 권리범위 판단시 해석 → 결론"의 체계적 목차
- (+) 특허성 국면과 권리범위 국면을 소제목으로 명확히 구분
- (-) 학설과 판례를 뒤섞어 서술하거나 소제목 없이 나열식으로 작성한 답안
- (-) 정형화된 목차를 그대로 옮겨 적어 자기 논리가 드러나지 않은 답안(채점평 지적: "답안 패턴이 획일화")

3) 답안 작성·논증(35%)

- (+) 조문(§ 42⑥, § 97) → 학설 → 종전 판례 → 전원합의체 판례 → 검토 순의 논증 구조
- (+) 학설 대립시 자신이 지지하는 견해와 그 논거를 명확히 제시(채점평 명시 요구사항)
- (+) 전원합의체 판결의 결론(물건동일설) 및 그 근거(발명의 실체는 물건, 제조방법은 물건을 특정하는 수단에 불과)를 정확히 서술
- (-) 법조문·판례 문언을 그대로 옮겨 적기만 한 답안(채점평 지적: "법조문을 그대로 옮겨 적는 것은 지양")
- (-) 특허성 판단과 권리범위 해석의 관계에 대한 결론이 모호하거나 상호 모순되는 답안

감점 주의

- 청구범위 기재방법의 대통령령 위임근거를 제42조의2로 잘못 인용하는 경우 → 감점 (§42의2는 특허출원일 및 청구범위 유예제출에 관한 조문)
- 2011후927 전원합의체 판결을 모른 채 종전 대법원 판례의 '특별한 사정' 이분론만 인용하는 경우 → 감점 (종전 태도는 특허법원이 아니라 대법원의 것이었고, 2011후927 전합이 물건동일설에 따라 이를 변경하였다)
- 학설·판례만 나열하고 자기 입장을 밝히지 않는 답안(채점평 명시 감점 사유)
- PBP 청구항의 허용성 논의에 지면을 과도하게 할애하여 정작 해석론이 빈약한 답안
- 특허성 판단 기준과 침해 판단 기준을 이원적으로 서술하면서 그 정합성에 대한 검토가 없는 답안

PART 2

2011

제1문	① 진보성 판단의 일반적 '순서' · ② '용이도출' 여부의 구체적 판단방법	30점
제2문	독립항·종속항 구분의 일반적 기준 · 청구항 1~4의 구분	20점
제3문	乙의 정당 승계인 여부(\$33① 위반 아님) · 방법 K의 신규성 상실사유(丁의 2009.5.2. 논문발표, \$29①(1)·(2))	30점
제4문	공동심판 심결취소소송의 법적 성격(유사필수적 공동소송) · 인용심결에 대해 A가 甲만 상대로 제소한 경우 당사자 적격	20점

2011년 제1문

약술형

30점

문제

- (1) 진보성 판단의 일반적인 순서를 제시하고, 그 중 '용이도출(용이하게 발명할 수 있는지)' 여부의 판단방법을 구체적으로 설명하시오. (15점)
- (2) 아래 각 발명에 특유한 진보성 판단방법에 대하여 설명하시오. (15점)
1. 선택발명 (5점)
 2. 결합발명 (5점)
 3. 제법한정물건발명 (5점)

모범답안

I. 설문 (1) — 진보성 판단의 순서와 용이도출 여부의 판단방법 (15점)

1. 진보성의 의미

특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대하여는 특허를 받을 수 없다(§ 29②). 기술의 진보에 기여하지 아니하는 발명에까지 독점권을 주면 오히려 산업발전을 저해하기 때문이다. 진보성은 산업상 이용가능성과 신규성을 갖춘 발명을 전제로 판단하므로, 신규성이 없는 발명은 그 사유만으로 특허를 받을 수 없어 진보성을 따로 판단할 필요가 없다.

2. 진보성 판단의 순서

(1) 청구항에 적힌 발명의 특징

청구항에 적힌 사항을 기준으로 판단의 대상이 되는 발명을 특정한다. 이때 발명의 설명과 도면, 출원 당시의 기술상식을 참작하여 그 기술적 의미를 확정한다.

(2) 인용대상의 특정

제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명을 인용대상으로 특정한다. 신규성과 달리 둘 이상의 인용대상을 조합할 수 있으나, 그 수가 많아질수록 사후적 고찰에 이를 가능성이 커짐에 유의하여야 한다.

(3) 가장 가까운 인용대상의 선택과 차이점의 파악

청구항에 적힌 발명과 가장 가까운 인용대상을 선택하여 양자를 대비하고 차이점을 파악한다. 차이점을 확인할 때에는 구성요소 사이의 유기적 결합성을 감안하여, 유기적으로 결합된 것끼리는 분해하지 아니하고 결합된 일체로서 인용대상의 대응 구성요소와 대비하여야 한다.

(4) 용이도출 여부의 판단

가장 가까운 인용대상으로부터 청구항에 적힌 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 쉬운지를, 다른 인용대상과 출원 전의 기술상식 및 경험칙에 의하여 판단한다.

3. 용이도출 여부의 판단방법

(1) 판단의 요소와 자료

심사실무는 출원발명의 목적과 기술적 구성 및 작용효과를 종합적으로 검토하되, 청구항에 적힌 구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성과 효과의 현저성을 참작하여 종합적으로 판단하도록 하고 있다. 판단에 앞서 선행기술의 범위와 내용, 그 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준을 증거 등 기록에 나타난 자료에 의하여 파악한 다음, 출원 시를 기준으로 통상의 기술자의 관점에서 그 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살핀다. 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시된 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 판단하여서는 아니 된다(2024후10641). 또한 선행문헌은 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 그 문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비하여야 한다.

(2) 구성의 곤란성

판단의 중심은 구성의 곤란성에 있고, 이는 통상의 기술자가 공지기술로부터 동기 유발에 의하여 또는 통상의 창작능력의 발휘를 통하여 그 발명을 쉽게 생각해 낼 수 있는지의 문제이다.

① **(동기 유발)** i) 공지기술의 내용 중에 그 발명에 대한 시사가 있는 경우, ii) 공지기술과 과제가 공통되는 경우, iii) 기능·작용이 공통되는 경우, iv) 기술분야의 관련성이 있는 경우에는 쉽게 생각해 낼 수 있다고 본다.

② **(통상의 창작능력의 발휘)** i) 목적 달성을 위한 공지의 재료 중 가장 적합한 재료의 선택, ii) 수치범위의 최적화 또는 호적화, iii) 균등물에 의한 치환, iv) 기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경, v) 단순한 용도의 변경이 이에 해당한다. 차이점이 이러한 점에만 있다면 달리 진보성을 인정할 근거가 없는 한 진보성이 부정된다.

(3) 효과의 현저성

구성의 차이에 더하여 작용효과가 선행기술과 비교하여 현저하게 향상·진보된 때에는 진보성을 인정하여야 한다. 여기의 유리한 효과란 인용대상의 효과와 성질을 달리하는 이질적인 효과이거나, 성질은 같더라도 현저하게 우수하여 출원 시의 기술수준에서 통상의 기술자가 예측할 수 없었던 효과를 말한다. 현저한 효과는 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 되며, 목적의 특이성도 같은 자료가 된다.

효과와 현저성은 명세서에 적혀 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단한다. 다만 유리한 효과가 발명의 설명에 적혀 있지 아니하더라도 통상의 기술자가 그 기재로부터 이를 추론할 수 있는 때에는, 출원일 후에 의견서에서 추가 실험자료를 제출하는 등의 방법으로 주장·증명하는 효과도 참작하여 진보성을 판단한다(2000후3234). 반면 발명의 설명에 적혀 있지 아니하고 발명의 설명이나 도면의 기재로부터 미루어 짐작할 수도 없는 효과라면, 의견서 등에서 주장·증명하더라도 참작하여서는 아니 된다.

(4) 참고적 자료

상업적 성공이나 장기간 해결되지 아니한 과제의 해결과 같은 사정은 진보성을 인정하는 참고자료가 될 수 있으나, 그러한 사정만으로 진보성이 인정되는 것은 아니다.

4. 결론

진보성은 발명과 인용대상을 특정하고 가장 가까운 인용대상과 대비하여 차이점을 파악한 다음 그 차이의 용이도출 여부를 판단하는 순서로 이루어진다. 그 판단은 출원 시를 기준으로 통상의 기술자의 관점에서 사후적 고찰 없이, 구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성과 효과의 현저성을 참작하여 이루어져야 한다.

II. 설문 (2) — 발명의 유형별 특유한 진보성 판단방법 (15점)

1. 선택발명

(1) 의의

선택발명이란 선행발명에 구성요소가 상위개념으로 적혀 있고 그 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소의 전부 또는 일부로 하는 발명으로서, 선행발명에 직접적으로 개시되어 있지 아니한 사항을 선택한 발명을 말한다. 선행발명이 그 하위개념을 구체적으로 개시하고 있지 아니하여 신규성이 인정됨을 전제로 진보성이 문제된다.

(2) 구성의 곤란성

선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 상위개념인 선행발명과 비교하여 구성의 곤란성이 인정되어야 한다. 그 판단에서는 i) 상위개념의 크기, ii) 선행발명이 그 선택의 동기를 제공하거나 암시하고 있는지, iii) 선행발명에 적힌 하위개념과 구조적으로 유사한지를 고려한다. 구성의 곤란성을 따져 보지 아니한 채 효과의 현저성만으로 진보성을 판단하여서는 아니 된다(2019후10609).

(3) 효과의 참작

선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 것 가운데 특정한 것을 고른 것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 지나지 아니한다면 그 선택에 어려움이 있다고 할 수 없으므로, 효과는 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택인지를 가르는 표지가 된다. 특히 화학·의약 분야와 같이 구성만으로 효과를 예측하기 어려운 경우에는 효과가 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 되고, 구성의 곤란성 판단이 불분명하더라도 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과가 있으면 진보성이 부정되지 아니한다.

(4) 효과 판단의 기준

효과와 현저성은 명세서에 적혀 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하고, 그 효과가 의심스러운 때에는 기재의 범위를 넘지 아니하는 한도에서 출원 후 실험자료를 제출하여 증명할 수 있다(2019후10609). 하나의 청구항에 여러 하위개념이 포함된 경우에는 그중 가장 열등한 것의 효과가 선행발명의 실시형태 중 가장 우수한 것과 비교하여 현저하여야 하고(2013후1887), 다만 선택발명에 여러 효과가 있다면 그 가운데 일부라도 이질적이거나 현저하면 충분하다(2010후3424).

2. 결합발명

(1) 의의

결합발명이란 이미 알려진 복수의 구성요소를 결합하여 새로운 해결수단으로 구성한 발명을 말한다.

(2) 전체로서의 판단

청구항이 복수의 구성요소가 되어 있는 경우 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것이 아니라 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 그 대상이 된다. 따라서 구성요소를 분해하여 각각이 공지되었는지만 따져서는 아니 되고, 특유한 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서 구성의 곤란성을 살피되 그 결합에 따른 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다(2013후2620).

(3) 결합의 용이성

여러 선행발명을 결합하여 진보성을 부정하려면 그 결합에 이를 수 있다는 암시나 동기가 선행발명에 제시되어 있거나, 그렇지 아니하더라도 출원 당시의 기술수준과 기술상식 등에 비추어 통상의 기술자가 쉽게 결합할 수 있다고 인정되어야 한다. 구성요소들이 각각 공지되었다는 사정만으로 그 결합까지 쉽다고 볼 수는 없다.

3. 제조방법이 기재된 물건발명**(1) 의의**

청구범위가 전체적으로 물건으로 적혀 있으면서 그 구성 중 일부가 제조방법으로 표현된 발명을 말한다.

(2) 물건으로 파악

물건의 발명의 청구범위에 적힌 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특징하는 하나의 수단으로서 의미를 가질 뿐이다. 따라서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라, 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 선행기술과 비교하여야 한다(2011후927 전원합의체). 이로써 제조방법의 기재를 특별한 사정이 있는 때에만 고려하던 종전의 태도는 변경되었다.

(3) 귀결

그리하여 제조방법에 진보성이 있다고 하여 그 방법으로 제조된 물건이 당연히 진보성을 가지는 것은 아니고, 제조방법이 제조의 효율이나 수율에만 영향을 미쳐 물건의 구조나 성질에 차이를 가져오지 아니한다면 제조방법을 제외한 물건 자체로 판단하여야 한다. 다만 침해 단계에서 권리범위를 판단할 때에도 물건으로 파악하되, 그렇게 도출되는 권리범위가 명세서의 전체적인 기재로 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등 명백히 불합리한 사정이 있으면 청구범위에 적힌 제조방법의 범위로 한정할 수 있다(2013후1726).

4. 결론

선택발명은 하위개념 전부에 관한 구성의 곤란성을 중심으로 하되 효과를 그 추론자료로 삼아, 결합발명은 유기적으로 결합한 전체로서의 구성의 곤란성과 결합의 용이성을, 제조방법이 기재된 물건발명은 제조방법의 기재를 포함하여 특정되는 물건 자체를 각각 기준으로 삼아 판단하여야 한다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
설문(1)-① 진보성 판단의 일반적 '순서'	7	①청구항 발명 특정 → ②인용발명 특정(\$29①각호) → ③가장 가까운 인용발명 선택·대비하여 차이점 명확화 → ④사후적 고찰 배제하고 통상의 기술자 관점에서 용이도출 여부 판단, 순서를 단계적으로 기술
설문(1)-② '용이도출' 여부의 구체적 판단방법	8	목적 특성·구성 곤란성·효과 현저성 3요소, ①발명에 이를 동기(시사·과제·기능·기술분야 공통), ②통상의 창작능력 발휘(최적재료 선택·수치한정·균등을 치환·설계변경·구성요소 생략·용도변경), ③더 나은 효과(이질·동질현저), 상업적 성공 등 참작요소
설문(2)-1 선택발명 진보성	5	선택발명의 의의(상위→하위개념), 이질적 효과 또는 동질이나 현저한 효과 요구(대법원 판례), 명세서 기재요건(현저한 효과 명확 기재로 충분·비교실험자료 사후제출 가능)
설문(2)-2 결합발명 진보성	5	결합발명의 의의(주합/조합 구별), 유기적 결합 전체로서 구성곤란성 판단(대법원 판례), 결합의 암시·동기 유무 및 KSR 판결 맥락(TSM 완화)
설문(2)-3 제법한정 물건발명 진보성	5	PBP청구항 의의, 심사실무·판례상 '물건 자체'로 특정하여 공지기술과 대비(2015. 2. 12. 전합 판결 취지), 제법방법 자체는 원칙상 고려 대상 아님, 예외적 특별사정

배점 합계: 30점

축별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- **[+]** 설문(1)이 판단 '순서'와 '용이도출 판단방법'을 별개로 묻고 있음을 정확히 인식하고 두 논점을 분리 서술
- **[+]** 설문(2)의 세 발명유형별로 '특유한' 판단방법(일반론과 구별되는 특칙)에 집중
- **[-]** 채점평 지적: 순서를 묻는데 방법을 기재하는 오류(가장 흔한 감점 사유)
- **[-]** 진보성 일반론(의의·취지)에 지면 낭비, 서브노트 통암기식 나열
- **[-]** PBP청구항을 몰라 신규성 논의로 대체하거나 누락

2) 목차·구성(25%)

- **[+]** 설문(1)을 '판단순서'와 '용이도출 판단방법(일반적/구체적)' 소목차로 분리
- **[+]** 설문(2)를 3개 발명유형별 소목차로 배점 비례(각 5점) 균형 배분
- **[-]** 특정 발명유형(예: 선택발명)에만 편중되어 결합발명·PBP 소략
- **[-]** 문제의 소재·의의 서술이 과도해 본문 지면 부족

3) 답안 작성·논증(35%)

- **[+]** 조문(\$ 29②) → 심사기준 → 판례 → 소결 순의 정형적 논증
- **[+]** 선택발명: '이질 또는 동질현저 효과' 판례 문언 정확 인용
- **[+]** 결합발명: '유기적 결합 전체로서의 구성곤란성' 판례 문언, TSM/KSR 맥락 언급
- **[+]** PBP: 2015년 전원합의체 취지(물건 자체 기준) 반영
- **[-]** 판례 문언 부정확·판시 취지 왜곡
- **[-]** 사후적 고찰 금지 원칙 누락
- **[-]** 결론 없이 학설·판례 나열로 끝남

감점 주의

- 채점평 최대 지적: **'순서'를 물었는데 '방법'을 기재**하는 답안이 다수였고 좋은 점수를 받지 못함. 반드시 ①발명특정 → ②인용발명특정 → ③대비·차이점 확정 → ④용이도출 판단의 4단계 순서를 먼저 명시할 것.
- 진보성 일반론을 장황하게 서술하고 정작 발명유형별 '특유' 판단방법을 소략하게 처리하는 편중.
- PBP청구항 관련 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 취지(물건 자체를 기준으로 진보성 판단)를 언급하지 않고 구법상 논의만 기재.
- 선택발명에서 '이질적 효과 또는 동질이라도 현저한 효과' 요건을 '맞'으로 잘못 표현.
- 결합발명에서 '유기적 결합' 문언 없이 단순 결합 가부만 서술.

2011년 제2문

약술형

20점

문제

다음의 청구범위를 기준으로 아래 각 질문에 답하시오.

【청구범위】

【청구항 1】 인쇄용 잉크를 보관하는 잉크저장부재와 상기 잉크저장부재에 저장되어 있는 잉크를 분사하는 복수 개의 노즐로 구성되는 잉크제트프린터용 잉크 카트리지.

【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 노즐의 분사구의 형태가 원형인 것을 특징으로 하는 잉크제트프린터용 잉크 카트리지.

【청구항 3】 제2항에 있어서, 상기 노즐의 분사구의 형태가 4각형인 것을 특징으로 하는 잉크제트프린터용 잉크 카트리지.

【청구항 4】 제1항에 있어서, 상기 노즐이 하나인 것을 특징으로 하는 잉크제트프린터용 잉크 카트리지.

(1) 독립항과 종속항을 구분하는 일반적인 기준을 설명하시오. (5점)

(2) 위 각각의 청구항을 독립항 또는 종속항으로 구분하시오. (8점)

(3) 위 (2)의 구분에 따라 청구항 1 내지 4의 진보성 판단의 상호관계에 대하여 설명하시오. (7점)

(30점)

모범답안

I. 설문 (1) — 독립항과 종속항을 구분하는 일반적 기준 (5점)

1. 다항제와 독립항·종속항

청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 청구항이 하나 이상 있어야 하며(§ 42④), 그 기재방법에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다(§ 42⑥). 그 위임에 따른 시행령 제5조 제1항은 청구항을 적을 때에는 독립항을 적어야 하며 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속항을 적을 수 있다고 정하고, 같은 조 제4항은 다른 청구항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 적도록 하고 있다.

독립항은 발명의 본질적 특징에 관한 필수구성요소를 적은 청구항으로 발명의 넓이를, 종속항은 다른 항의 내용이 변경되면 그 발명의 내용도 변경되는 청구항으로 발명의 깊이를 나타낸다. 종속항을 적는 방법에는 상위개념을 하위개념으로 한정하는 내적 부가와 구성요소를 더하는 외적 부가가 있다.

2. 판례의 법리

종속항은 언제나 인용항의 번호를 적으나 독립항도 중복기재를 피하려고 인용형식으로 적을 수 있다. 따라서 인용형식이 없는 청구항은 더 살필 것 없이 독립항이고, 인용형식이 있는 청구항은 인용항을 구체화하는지에 따라 갈린다. 판례는 인용하는 청구항을 한정하거나 부가하여 구체화하고 있으면 종속항이나, 그 구성의 일부를 생략하거나 다른 구성으로 치환하고 있으면 인용형식에도 불구하고 독립항으로 보아야 한다고 한다(2004후3546). 인용항의 구성을 그대로 포함하지 아니하여 그보다 좁은 발명이 아니기 때문이다.

3. 사안의 포섭

청구항 1은 다른 청구항을 인용하지 아니하므로 그 자체로 독립항이다. 청구항 2 내지 4는 모두 인용형식을 취하고 있으므로, 인용항을 구체화한 것인지 그 구성을 치환한 것인지에 따라 갈린다.

4. 결론

인용형식이 없는 청구항은 언제나 독립항이고, 인용형식이 있는 청구항은 인용항을 한정·부가하여 구체화하는지라는 실질에 따라 나뉜다. 결국 종속항이 아닌 청구항은 모두 독립항이다.

II. 설문 (2) — 각 청구항의 구분 (8점)

1. 청구항 1

다른 청구항을 인용하지 아니하고 잉크저장부재와 복수 개의 노즐이라는 필수구성요소만으로 발명을 특정하고 있다. 인용형식이 없으므로 독립항이다.

2. 청구항 2

제1항을 인용하면서 그 구성요소인 노즐의 분사구 형태를 원형으로 한정하고 있다. 제1항의 구성을 모두 포함하면서 상위개념을 하위개념으로 한정한 내적 부가에 해당하므로 제1항의 종속항이다.

3. 청구항 3

(1) 제2항과의 관계

제2항을 인용하는 형식을 취하고 있다. 그런데 종속항은 인용항의 구성을 모두 포함하는 것이므로 이 형식을 그대로 새기면 분사구의 형태가 원형이면서 동시에 4각형인 것이 되어 양립할 수 없다. 결국 제2항의 구성을 그대로 포함하면서 이를 구체화한 것이 아니라 원형을 4각형으로 치환한 것이므로, 제2항의 종속항이라고 할 수 없다.

(2) 제1항과의 관계

그러나 제2항이 인용하는 제1항과의 관계에서 보면, 제1항의 노즐이라는 상위개념을 분사구가 4각형인 노즐로 한정한 것이다. 곧 제1항의 구성을 모두 포함하면서 이를 하위개념으로 한정하고 있으므로 실질적으로 제1항의 종속항에 해당한다.

(3) 기재의 흠

다만 인용되는 항의 번호를 제2항으로 적고 있어 실질과 어긋난다. 그 문언대로는 분사구가 원형이면서 4각형인 것으로 읽혀 발명이 명확하게 특정되지 아니하므로 현재의 기재는 제42조 제4항 제2호의 명확성 요건에 위반되고, 인용하는 항을 제1항으로 바로잡는 보정이 필요하다.

4. 청구항 4

제1항을 인용하는 형식을 취하고 있다. 그런데 이 형식을 그대로 새기면 노즐이 복수 개이면서 동시에 하나인 것이 되어 양립할 수 없고, 발명이 명확하게 특정되지 아니하여 현재의 기재는 제42조 제4항 제2호의 명확성 요건에 위반된다. 제1항의 복수 개의 노즐을 하나의 노즐로 바꾼 취지라면 '상기 복수 개의 노즐 대신 하나의 노즐인 것'이라고 적어야 하고, 그와 같이 적으면 제1항의 구성을 치환한 것이 되어 인용형식에도 불구하고 독립항이 된다.

5. 결론

청구항 1과 청구항 4는 독립항이고, 청구항 2와 청구항 3은 모두 제1항의 종속항이다. 청구항 3은 제2항을 인용하는 형식에도 불구하고 제1항을 한정한 것으로 보아야 한다는 점에 유의하여야 한다.

다만 청구항 3과 청구항 4는 현재의 기재로는 각각 원형이면서 4각형, 복수 개이면서 하나인 것으로 읽혀 제42조 제4항 제2호의 명확성 요건에 위반되므로, 앞서 본 바와 같이 인용하는 항을 바로잡거나 대신한다는 취지를 밝히는 보정이 필요하다.

Ⅲ. 설문 (3) — 청구항 1 내지 4의 진보성 판단의 상호관계 (7점)

1. 청구항별 판단의 원칙

다항제 아래에서 각 청구항은 독립항이든 종속항이든 상호 독립되어 청구항마다 독자적인 권리범위를 가지므로, 특허요건은 청구항마다 개별적으로 판단한다. 따라서 진보성도 각 청구항에 적힌 발명을 단위로 판단함이 원칙이다.

2. 독립항과 종속항의 상호관계

(1) 독립항의 진보성이 부정되지 아니하는 경우

종속항은 독립항의 구성을 모두 포함하면서 이를 한정하거나 부가하여 구체화한 것이어서 그 보호범위가 독립항보다 좁다. 그러므로 독립항의 진보성이 부정되지 아니하면 그 종속항의 진보성도 부정되지 아니하고, 심사관은 종속항을 따로 심사하지 아니하고 특허성을 인정할 수 있다.

(2) 독립항의 진보성이 부정되는 경우

이 경우에는 종속항에 한정되거나 부가된 구성이 있으므로, 그 구성을 포함한 전체로서 다시 판단하여야 한다. 독립항의 진보성이 부정된다는 이유만으로 종속항의 진보성까지 부정할 수는 없다.

(3) 독립항 상호 간

서로 독립한 청구항 사이에는 위와 같은 연동관계가 없으므로 각각 별도로 판단한다.

3. 사안의 포섭

청구항 2와 청구항 3은 모두 청구항 1의 종속항이므로, 청구항 1의 진보성이 부정되지 아니하면 청구항 2와 청구항 3의 진보성도 부정되지 아니한다. 청구항 3이 제2항을 인용하는 형식을 취하고 있다고 하여 달리 볼 것은 아니다.

반대로 청구항 1의 진보성이 부정되는 경우에는, 청구항 2는 분사구를 원형으로, 청구항 3은 4각형으로 각각 한정하고 있으므로 그 한정된 구성을 포함한 전체로서 별도로 판단하여야 한다. 청구항 4는 독립항이므로 청구항 1의 판단 결과와 관계없이 처음부터 별도로 판단한다.

4. 결론

진보성은 청구항마다 판단하되, 청구항 1의 진보성이 인정되면 그 종속항인 청구항 2와 청구항 3의 진보성도 인정되고, 청구항 1의 진보성이 부정되면 청구항 2와 청구항 3은 한정된 구성을 포함한 전체로서 별도로 판단하여야 하며, 독립항인 청구항 4는 어느 경우에도 별도로 판단하여야 한다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
설문(1) 독립항·종속항 구분의 일반적 기준	5점	특허법 시행령 제5조 제1항(독립항 기재 및 한정·부가에 의한 종속항 기재)과 제5조 제4항(다른 청구항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 적을 것)의 조문 인용을 분리, 종속항의 형식적 요건(인용형식)과 실질적 요건(한정·부가) 구분, 판례(인용형식이라도 실질적 한정·부가 없으면 독립항)의 기재, 종속항이 아니면 모두 독립항이라는 점
설문(2) 청구항 1~4의 구분	8점	청구항1 독립항(2점) / 청구항2 종속항 – 노줄 분사구를 원형으로 한정(2점) / 청구항3의 이중적 성격 – 제2항과의 관계에서는 치환이나 제1항과의 관계에서 사각형으로 한정 → 종속항(2점) / 청구항4 – 복수개 노줄을 하나로 치환 → 독립항(2점)
설문(3) 진보성 판단의 상호관계	7점	진보성은 청구항별 판단 원칙, 판례·심사기준: 독립항 진보성 인정 시 종속항 자동 인정 / 부정 시 종속항 별도 판단, 제1항 진보성 인정 시 제2·3항 자동 인정, 제1항 부정 시 제2·3항 별도 판단, 제4항은 독립항이므로 항상 별도 판단

축별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- **[+]** 청구항3의 형식적/실질적 이중해석 문제(제2항 종속인지 제1항 종속인지)를 정면으로 다룰 것 — 채점평이 명시적으로 요구한 핵심 논점
- **[+]** 청구항3이 제1항과 비교하면 종속항이 되며, 결국 제1항 진보성 인정 시 제3항 진보성도 자동 인정된다는 점까지 기술 (채점평: "그 점까지 기술한 답안은 거의 없다")
- **[+]** 청구항4가 '복수 개 → 하나'로 구성요소를 감소·치환한 점을 포착해 독립항으로 판단
- **[-]** 종속항 판단에서 '인용형식'만 기준으로 삼고 실질적 한정·부가 요건을 누락
- **[-]** 진보성 판단순서·방법 등 A-1문제와 중복되는 일반론을 장황하게 서술

2) 목차·구성(25%)

- **[+]** 설문 (1)(2)(3)을 목차로 뚜렷이 구분, 설문(2)는 청구항별로 소제목을 배치
- **[+]** 배점(5/8/7)에 비례한 분량 배분 — 설문(2) 청구항별 균등 배분, 설문(3) 경우의 수(제1항 진보성 있음/없음)로 나누어 서술
- **[-]** 문제의 소재·진보성 일반론에 과도한 지면 할애
- **[-]** 청구항3을 하나의 결론만 제시하고 이중적 해석 가능성을 목차상 분리하지 않음

3) 답안 작성·논증(35%)

- **[+]** 시행령 제5조 제1항(독립항·종속항의 정의) 및 제5조 제4항(인용형식) → 판례(인용형식이라도 실질적 한정·부가 없으면 독립항) → 사안 포섭 순서
- **[+]** 청구항3에 대해 제2항 기준(치환→독립항 해석 가능)과 제1항 기준(한정→종속항)을 모두 검토한 뒤 자기 입장(종속항)을 논거와 함께 제시
- **[+]** 설문(3)에서 판례·심사기준("독립항 진보성 인정 시 종속항 자동 인정, 부정 시 별도 판단") 명확히 인용
- **[-]** 조문·판례 전사만 하고 사안 포섭이 없는 경우
- **[-]** 청구항3·4의 결론만 제시하고 왜 그런지 판례 기준에 대입한 논증이 없는 경우

감점 주의

- 채점평 지적: 종속항이 아닌 모든 항은 독립항이라는 기본 명제를 놓치는 경우 다수
- 채점평 지적: 청구항3이 제2항 기준으로는 독립항이지만 제1항 기준으로는 종속항이라는 이중적 성격을 파악하지 못한 답안이 대부분 → 이 점을 반드시 기술
- 채점평 지적: 제1항 진보성 인정 시 제3항도 (제1항의 종속으로) 자동 인정된다는 점까지 논리적으로 연결한 답안이 거의 없음
- 청구항4를 '제1항 인용'이라는 형식만 보고 종속항으로 오판하지 말 것(구성요소 감소·치환 → 독립항)
- 진보성 일반론(29조 2항 등)을 장황하게 서술해 배점 대비 지면을 낭비하지 말 것
- 시행령 조문(제5조 제1항의 정의 규정, 제5조 제4항의 인용형식 규정)을 인용하지 않고 정의만 서술하면 감점
- 시행령 제5조 제1항은 독립항·종속항의 정의(한정·부가에 의한 구체화)만 규정하고, '인용형식' 요건은 제5조 제4항에서 도출됨을 혼동하지 말 것

2011년 제3문

사례형

30점

문제

甲은 구성 a+b+c로 이루어진 물건 발명의 특허권자이다. 丁은 구성 a+b+c로 이루어진 물건을 제조하는 방법 K를 발명하여 2009.5.2. 그에 관하여 논문을 발표하였고, 甲의 경쟁기업 乙은 丁으로부터 방법 K에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양수하여 2009.6.1. 특허출원하였으나, 출원서에 특허법 제30조 제2항소정의 “공지예외 적용대상”이라는 취지의 기재를 누락하였다. 乙은 2009.6.5. 지식재산처에 '공지예외 적용대상 증명서류 제출서'를 제출하면서 위 출원이 2009.5.2. 간행물 발표에 의하여 공개되었다는 점을 밝히고 공지예외 적용대상의 취지를 기재하고 관련 증명서류를 제출하였다.

한편, 乙은 구성 a+b로 이루어진 반제품을 생산하여 丙에게 공급하고 있으며, 丙은 乙로부터 공급받은 반제품에 乙의 허락 하에 방법 K를 적용하여 구성 a+b+c로 이루어진 물건을 생산하고 있다.

단 그 반제품은 구성 a+b+c로 이루어진 물건을 생산하는 용도 외의 용도는 없다.

(1) 방법 K의 특허등록 가능성에 관하여 설명하시오. (10점)

(2) 甲은 乙을 상대로 구성 a+b로 이루어진 반제품이 구성 a+b+c로 이루어진 물건 발명의 권리범위에 속한다는 권리범위확인심판을 청구하였다. 甲의 심판청구가 적법한 것인지 여부 및 甲의 주장의 인용 여부에 관하여 판단하시오. (20점)

모범답안

I. 설문 (1) — 방법 K의 특허등록 가능성 (10점)

1. 문제의 소재

특허출원은 제62조 각 호의 거절이유에 해당하지 아니하여야 특허를 받을 수 있다. 사안에서 방법 K는 발명자 丁이 아니라 그로부터 권리를 양수한 乙이 출원하였고, 출원 전에 논문으로 발표되어 제29조 제1항 각 호에 해당하게 되었다. 따라서 i) 제33조 제1항 본문과 관련하여 乙이 정당한 승계인인지, ii) 제29조 제1항 각 호와 관련하여 제30조의 주장으로 그 위반을 극복하였는지가 쟁점이 되고, 특히 후자에서는 출원서에 그 취지를 적지 아니한 흠을 뒤에 보완할 수 있는지가 문제된다.

2. 제33조 제1항 본문 위반 여부 — 정당한 승계인인지

특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있고, 특허출원 전에 이루어진 승계는 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(§ 37①, § 38①). 乙은 발명자 丁으로부터 방법 K에 관한 권리를 양수하여 자기 명의로 출원하였으므로 정당한 승계인이고, 무권리자의 출원으로서 제62조 제2호에 해당하지 아니한다.

3. 제29조 제1항 각 호 위반의 극복 — 공지예외의 적용

(1) 의의와 취지

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면, 신규성과 진보성을 적용할 때 그 발명은 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다(§ 30①). 자기 발명의 공개로 스스로 특허를 받지 못하게 되는 것은 가혹하고, 공개를 이유로 출원을 서두르게 하기보다 일정한 유예를 주는 것이 발명의 공개와 출원을 유도하는 데에 낫기 때문이다. 기간은 최선의 공지일로부터 기산한다.

(2) 절차적 요건과 그 보완

이를 적용받으려는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 제출하여야 한다(§ 30②). 다만 그 취지를 적지 아니하였거나 증명서류를 제출하지 아니한 경우에도, 보완수수료를 낸 때에는 i) 제47조 제1항에 따라 보정할 수 있는 기간이나 ii) 특허결정 또는 특허거절결정 취소심결의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간에 그 취지를 적은 서류와 증명서류를 제출할 수 있다(§ 30③). 단순한 실수나 제도에 대한 인식 부족으로 취지를 적지 못하여 특허를 받지 못하는 일을 막기 위한 것이다.

(3) 효과와 한계

공지예외가 적용되면 그 공지는 신규성과 진보성을 판단할 때 고려되지 아니한다. 그러나 출원일이 공지일로 소급하는 것은 아니므로, 공지일과 출원일 사이에 제3자가 같은 발명을 출원하였다면 선출원주의에 따라 특허를 받지 못할 수 있다.

4. 사안의 포섭

丁의 논문 발표일인 2009. 5. 2.부터 12개월 이내인 2009. 6. 1.에 출원이 이루어졌으므로 시기적 요건은 갖추었다. 乙은 출원서에 취지를 적지 못하였으나 그 후 취지를 적은 서류와 증명서류를 제출하였으므로, 보완수수료를 내고 위 기간에 제출한 이상 공지예외의 적용을 받을 수 있다. 따라서 丁의 논문은 방법 K의 신규성과 진보성을 부정하는 자료가 되지 아니한다.

5. 결론

乙은 정당한 승계인으로서 공지예외의 적용을 받을 수 있으므로, 다른 거절이유가 없는 한 방법 K는 특허를 받을 수 있다. 다만 논문 발표일과 출원일 사이에 제3자의 출원이 있었다면 선출원주의에 따라 특허를 받지 못할 수 있다.

II. 설문 (2) — 심판청구의 적법 여부와 甲 주장의 인용 여부 (20점)

1. 문제의 소재

확인대상발명인 반제품은 구성 c를 결여하고 있다. 그러한 물건을 대상으로 권리범위확인심판을 청구할 수 있는지와, 그것이 甲 특허발명의 권리범위에 속한다고 볼 수 있는지가 문제된다.

2. 심판청구의 적법 여부

(1) 주체적 요건

적극적 권리범위확인심판은 특허권자 또는 전용실시권자가 청구인이 되고(§ 135①), 과거에 확인대상발명을 실시한 적이 있거나 현재 실시하고 있는 이 해관계인이 피청구인이 된다.

(2) 객체적 요건

① (간접침해에 해당하는 물건을 확인대상발명으로 삼을 수 있는지) 구성요소를 결여한 물건은 구성요소완비의 원칙상 특허발명의 실시라고 할 수 없으므로 이를 확인대상발명으로 삼을 수 있는지 문제된다. 판례는 특허발명인 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하는 확인대상발명은 특허발명의 권리범위를 벗어날 수 없다고 하여 이를 허용한다(98후2580). 특허법이 그러한 물건에 관한 행위를 침해로 보고 있는 이상 그 물건에 대하여도 보호범위의 확인을 구할 실익이 있으므로 타당하다.

② (확인의 이익) 청구인이 특정한 확인대상발명이 피청구인이 실제로 실시하고 있는 형태와 동일하지 아니하면, 권리범위에 속한다는 심결이 확정되더라도 그 심결은 피청구인이 실제로 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없다. 그러므로 그러한 심판청구는 확인의 이익이 없어 각하되어야 한다(2002후2419). 그 동일성은 피청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지라는 사실확정에 관한 것이므로, 두 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 때에만 인정되고 요지가 같아 균등관계에 있다는 것만으로는 부족하다(2011후2626).

(3) 시기적 요건

권리범위확인심판은 현존하는 특허권의 범위를 확정하려는 것이므로 특허권의 존속 중에만 청구할 수 있다.

(4) 절차적 요건

심판청구서를 특허심판원장에게 제출하되, 특허발명과 대비할 수 있는 확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다(§ 140①③).

(5) 사안의 포섭

甲은 특허권자로서 그 존속 중에, 반제품을 현실적으로 생산하고 있는 乙을 피청구인으로 하여 그 반제품을 확인대상발명으로 특정하였다. 확인대상발명은 乙이 실제로 생산하고 있는 반제품과 사실적 관점에서 일치하고, 간접침해에 해당하는 물건도 확인대상발명으로 삼을 수 있으므로 甲의 심판청구는 적법하다.

3. 甲 주장의 인용 여부

(1) 문제의 소재

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(§ 97). 확인대상발명인 반제품은 청구범위의 구성 c를 생략하고 있어 구성요소완비의 원칙상 특허발명의 실시라고 할 수 없으므로 직접침해는 문제되지 아니하고, 법률에 의한 보호범위의 확장인 간접침해가 성립하는지가 문제된다.

(2) 간접침해의 의의 및 취지

간접침해란 특허발명 그 자체의 실시는 아니어서 직접침해는 아니지만, 직접침해의 전 단계로서 그대로 두면 침해의 개연성이 높은 일정한 행위를 침해로 보는 것을 말한다. 특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위가 이에 해당한다(§ 127(1)). 구성요소완비의 원칙에 따른 직접침해만을 고수하면 특허발명의 기술적 사상을 이용하여 이익을 얻고 특허권자에게 손해를 입히는 자에게 책임을 물을 수 없어 특허권의 효력이 현저히 감소하기 때문이다. 다만 이는 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 인정되어야 한다.

(3) 간접침해의 요건

- ① **(주체와 태양)** 특허권의 존속 중 정당한 권원 없는 자가 업으로서 위 행위를 하여야 하고, 그 자의 고의·과실은 묻지 아니한다.
- ② **(공용성)** 그 물건의 사용이 특허발명인 물건의 생산에 해당하여야 한다. 여기의 생산이란 특허발명의 구성요소를 충족하지 아니한 물건을 사용하여 그 구성요소를 충족하는 물건을 만들어 내는 모든 의식적 행위를 말하고 가공·조립도 포함된다(2007후3356).
- ③ **(전용성)** 그 물건에 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적·상업적 또는 실용적인 다른 용도가 없어야 하고, 단순히 이론적·실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도로는 다른 용도가 있다고 할 수 없다(2007후3356). 다른 용도가 없다는 점은 특허권자가 주장·증명하여야 한다(98후2580).

(4) 직접침해와의 관계

- ① **(확설)** 직접침해가 있어야 간접침해가 인정된다는 종속설과, 직접침해와 별도로 간접침해의 요건만 갖추면 된다는 독립설이 대립한다. 구별의 실익은 i) 정당한 권원을 가진 자에게 전용품을 공급하는 경우, ii) 최종 실시가 국외에서 이루어지는 경우, iii) 최종 실시가 업이 아닌 개인적·가정적으로 이루어지는 경우에 드러난다.
- ② **(판례)** 판례는 어느 한 설만을 취하지 아니하고 유형에 따라 달리 판단한다. 특히 i)에 관하여는 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 공급받아 실시하는 경우 그 제3자의 행위를 간접침해로 보면 실시권에 부당한 제약을 가하고 특허권이 부당하게 확장되므로 간접침해가 아니라고 하였다(2017다290095).

(5) 사안의 포섭

丙은 乙로부터 공급받은 반제품에 방법 K를 적용하여 구성 a+b+c의 물건을 만들어 내고 있으므로 공용성이 인정되고, 그 반제품은 위 물건을 생산하는 용도 외의 용도가 없으므로 전용성도 인정된다. 乙은 甲으로부터 아무런 허락을 받지 아니한 채 업으로서 그 반제품을 생산하여 공급하고 있다.

한편 丙 역시 甲의 허락 없이 국내에서 구성 a+b+c의 물건을 생산하고 있으므로 甲의 특허권을 직접침해한다. 丙이 乙로부터 받은 허락은 방법 K에 관한 것으로서 乙에 대한 관계에서만 정당한 권원이 될 뿐 물건발명의 특허권자인 甲에 대한 관계에서는 정당한 권원이 되지 못하므로, 실시권자에게 전용품을 공급한 위 판례의 경우와는 다르다. 결국 직접침해가 있는 이상 종속설과 독립설 어느 견해에 의하더라도 乙의 행위는 간접침해에 해당한다.

4. 결론

甲의 심판청구는 적법하고, 반제품은 甲 특허발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건으로서 그 권리범위에 속한다. 따라서 특허심판원은 甲의 청구를 인용하는 심결을 하여야 한다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특정 포인트
(1) 乙의 정당 승계인 여부(\$33① 위반 아님)	1	발명자 丁으로부터 특허받을 수 있는 권리를 적법 양수한 승계인임을 명시
(1) 방법 K의 신규성 상실사유(丁의 2009.5.2. 논문발표, \$29①(1)-(2))	2	논문발표 = 반포된 간행물 게재/공지에 해당함을 조문 인용하여 포섭
(1) 공지예외주장 요건(\$30①(1), \$30②) — 6개월(현행 12개월; 개정 반영) 요건과 취지기재·증명서류	3	출원 시 취지기재 누락 사실 지적, 출원 후 증명서류만 제출한 사정 포섭. 공개자(丁)-출원인(乙) 상이하나 승계 증명으로 충족 가능함 언급
(1) 취지기재 사후보정 가부에 관한 대법원 판례	3	특허법원과 대법원의 결론 대비, 대법원의 불허 입장 및 그 논거(별개 절차·법적안정성) 서술
(1) 결론 및 구제방안(취하 후 재출원)	1	신규성 위반으로 등록불가, 공지일로부터 (당시)6월/(현행)12월 내 재출원 시 제30조 적용 방안 제시
(2) 권리범위확인심판 의의·적법요건(\$135, \$140③)	2	특허권자 甲의 청구인적격, 乙의 실시, 확인의 이익, 확인대상발명의 특정
(2) 간접침해품에 대한 권리범위확인심판 청구 가부(대법원 판례)	4	형식논이상 문제점 vs. 판례가 긍정한 논거(방법발명 실시에만 사용되는 물건에 관한 판례 인용), 심판 적법성 결론
(2) 구성요소완비원칙(\$97, \$42⑥)에 의한 직접침해 판단	2	a+b는 c 결여 → 직접침해 성립 부정
(2) 간접침해(\$127(1)) 요건 — 생산성·전용성·업으로서 실시	4	각 요건 조문·판례로 서술. 특히 '전용성' 판단에서 '문제에서 타용도 없음'이 명시된 점을 포섭
(2) 사안 포섭 및 인용여부 결론	2	a+b가 a+b+c 생산에만 사용되는 물건 → 권리범위 속함 → 인용심결
목차·구성·논증(문제 전체)	7	로마숫자·세부목차, 조문→판례→포섭→소결 구조, 배점 비례 분량

합계: 30점

축별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- (1)에서 ① 무권리자 여부, ② 신규성 상실, ③ 제30조 공지예외 요건, ④ 출원 시 취지기재 누락의 사후보정 가부(대법원 판례)를 모두 짚었는가.
- (2)에서 ① 심판청구의 적법성(특히 간접침해품이 확인대상이 될 수 있는지) ② 본안(구성요소완비 + 간접침해 요건)을 분리하여 논점화했는가.
- 채점평 지적대로 '판례를 간과'하지 않고 취지기재 사후보정 불허의 대법원 판례의 취지·결론을 인용했는가(단, 사건번호를 인용할 때에는 정확한 판례번호를 사용해야 하며, 확인되지 않은 사건번호를 임의로 인용해서는 안 된다).
- 문제에서 '다른 용도는 없다'고 특정한 사실을 정확히 포착·인용했는가.

2) 목차·구성(25%)

- 설문(1)과 (2)를 배점(10:20)에 비례해 분량 배분했는가.
- (2)를 '심판청구 적법성'과 '甲 주장의 인용여부' 두 개의 대목차로 명확히 분리했는가(채점평이 '세부목차를 통한 논리적 설명' 강조).
- 일반론(권리범위확인심판·간접침해 의의)은 최소화하고 사안 포섭에 지면을 할애했는가.

3) 답안 작성·논증(35%)

- 조문(\$ 30, \$ 127, \$ 135, \$ 140③, \$ 97) → 판례 → 사안 포섭 → 소결의 순서로 논증했는가.
- 취지기재 사후보정 판례를 특허법원 vs. 대법원 대비로 서술하고 자기 입장(대법원 지지)을 밝혔는가.
- 간접침해 요건별로 사안 포섭이 구체적인가(특히 '전용성'에서 문제의 단서 활용).
- 최종 결론(등록 불가/인용심결)이 명확한가.
- 조문 인용 시 항·호 표기가 정확한가(예: \$ 127은 항 구분 없이 각 호로 구성되므로 '\$ 127(1)'로 표기).
- 채점평 지적 '결과만 제시·두서없는 서술' 회피.

감점 주의

- 취지기재 사후보정 불허의 대법원 판례를 모르고 특허법원 판례 입장으로 등록가능이라 결론내면 대폭 감점.
- 사건번호를 인용하면서 실제 사건번호와 다른 판례를 인용하는 경우 감점.
- 공지예외 기간을 현행 12개월로만 쓰거나 출제 당시 6월로만 쓰고 개정 사실을 언급하지 않는 것(현행 기준 12월로 결론, 출제 당시 6월임을 병기 권장).

- 간접침해품에 대해 권리범위확인심판 자체가 부적법하다고 결론내는 것(판례에 반함).
- 직접침해(구성요소완비) 판단만 하고 간접침해 요건 검토를 누락한 경우.
- '다른 용도 없음'이라는 문제 단서를 활용하지 못하고 전용성을 장황히 논한 경우.
- 방법 K의 신규성 상실 근거를 조문 없이 결론만 제시.
- (1)에서 무권리자 여부(§ 33①) 검토 누락.
- 제127조를 '제127조 제1항 제1호'와 같이 존재하지 않는 항으로 표기하는 경우(정확한 표기는 '§ 127(1)').

2011년 제4문

사례형

20점

문제

특허권자 A의 특허발명 X에 대하여 甲과 乙이 공동으로 특허무효심판을 청구하였다.

(1) 특허법상 공동심판의 심결취소소송의 성격을 설명하시오. (6점)

(2) 무효심판청구에 관한 인용심결에 대하여 특허권자 A가 甲만을 상대로 심결취소소송을 제기한 경우의 당사자 적격에 관하여 설명하시오. (7점)

(3) 무효심판청구에 관한 기각심결에 대하여 甲만이 특허권자 A를 상대로 심결취소소송을 제기한 경우의 당사자 적격에 관하여 설명하시오. (7점)

모범답안

I. 설문 (1) — 공동심판에 대한 심결취소소송의 성격 (6점)

1. 공동심판

동일한 특허권에 관하여 무효심판이나 권리범위확인심판 등을 청구하는 자가 2명 이상이면 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다(§ 139①). 각자 개별적으로 청구할 수도 있으므로 공동으로 청구할 것이 강제되지 아니하고, 이 점에서 공유인 권리에 관하여 공유자 모두가 청구인 또는 피청구인이 되어야 하는 경우(§ 139②③)와 다르다.

2. 유사필수적 공동심판

필수적 공동심판은 합일확정이 요구되는 심판을 말하며, 공동으로 심판을 청구할 것이 강제되는 고유필수적 공동심판과 그렇지 아니한 유사필수적 공동심판으로 나뉜다. 제139조 제1항에 따른 공동심판은 청구할 것 자체가 강제되지 아니하나, 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되면 그 특허는 제3자와의 관계에서도 무효로 되므로 청구인들 사이에 합일확정이 요구된다. 따라서 이는 유사필수적 공동심판에 해당한다(2007후1510).

3. 심결취소소송의 성격

공동심판이 유사필수적 공동심판인 이상 그 심결에 대한 취소소송도 유사필수적 공동소송의 성격을 가진다. 그리하여 공동으로 소를 제기하거나 공동으로 피고가 될 것이 강제되지 아니하여 일부만이 당사자가 되더라도 소는 적법하나, 합일확정의 요청상 심결은 당사자가 되지 아니한 자에 대하여도 분리하여 확정되지 아니한다.

4. 결론

공동심판에 대한 심결취소소송은 고유필수적 공동소송이 아니라 유사필수적 공동소송이다.

II. 설문 (2) — 인용심결에 대하여 甲만을 피고로 한 경우의 당사자적격 (7점)

1. 문제의 소재

당사자에게 심판의 심결에 대한 소는 그 심판의 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여야 하므로(§ 187단서), 인용심결에 대하여는 심판피청구인이 원고가 되고 심판청구인이 피고가 된다. 무효심결을 받은 A가 공동심판청구인 중 甲만을 피고로 삼은 경우 그 소가 적법한지, 제소되지 아니한 乙에 대한 심결이 제소기간의 경과로 분리하여 확정되는지가 문제된다.

2. 특허법원 판결의 대립

(1) 분리확정을 긍정한 판결

공동심판의 청구는 강제되지 아니하고 심리의 병합과 분리가 모두 임의적이어서 공동심판청구인별로 별개로 진행되어 각각 확정되는 것이 원칙이다. 그러므로 공동심판으로 하나의 심결이 작성되었더라도 제소기간에 소가 제기되지 아니한 청구인 부분의 확정을 차단할 근거가 없다고 하였다(특허법원 2006허5294).

(2) 분리확정을 부정한 판결

제139조 제1항에 따른 공동심판청구는 유사필수적 공동소송의 성격을 가지므로 합일확정의 요청상 심결은 형식적으로나 실질적으로 하나이고, 심판피청구인이 공동심판청구인 중 1명을 상대로 소를 제기한 이상 그 심결은 확정되지 아니한다고 하였다(특허법원 99허9571).

3. 대법원 판례

대법원은 청구인들이 공동으로 무효심판을 청구한 이상 청구인들은 유사필수적 공동심판관계에 있으므로, 패소한 특허권자가 공동심판청구인 중 일부만을 상대로 심결취소소송을 제기하였더라도 그 심결은 청구인 전부에 대하여 확정이 차단되고, 소가 제기되지 아니한 나머지 청구인에 대한 심결만이 제소기간의 경과로 분리·확정되지는 아니한다고 하여 분리확정을 부정하였다. 나아가 이는 고유필수적 공동소송이 아니므로 당사자의 변경을 가져오는 당사자 추가신청은 허용되지 아니한다고 하였다(2007후1510).

4. 사안의 포섭

A가 甲만을 피고로 하여 제기한 소는 적법하고, 제소되지 아니한 乙에 대한 심결도 확정이 차단된다. 다만 A는 제소기간이 지난 뒤에 乙을 피고로 추가할 수 없다. A가 승소하여 심결이 취소되고 심판절차가 다시 진행되면 乙은 심판청구인의 지위를 유지한 채 그 절차에 참여하게 되고, A가 패소하여 판결이 확정되면 그때 비로소 심결이 확정된다.

5. 결론

甲만을 피고로 한 A의 소는 적법하고, 乙에 대한 심결이 분리하여 확정되지는 아니한다.

Ⅲ. 설문 (3) — 기각심결에 대하여 甲만이 제소한 경우의 당사자적격 (7점)

1. 문제의 소재

기각심결에 대하여는 심판청구인이 원고가 되고 심판피청구인이 피고가 된다(§ 187단서). 공동심판청구인 중 甲만이 소를 제기한 경우 그 소가 적법한지, 제소하지 아니한 乙에 대한 심결이 분리하여 확정되는지가 문제된다.

2. 당사자적격

(1) 원고적격

특허취소결정 또는 심결에 대한 소는 당사자, 참가인 또는 참가신청이 거부된 자만 제기할 수 있으므로(§ 186②), 심판청구인인 甲은 원고적격을 가진다. 유사필수적 공동소송이므로 공동심판청구인 전원이 소를 제기할 것이 강제되지 아니한다.

(2) 피고적격

당사자계 심판의 심결에 대한 소이므로 그 심판의 피청구인인 특허권자 A를 피고로 하여야 한다(§ 187단서).

3. 심결의 분리확정 여부

이에 관하여는 아직 대법원 판례가 없다. 다만 학설은 유사필수적 공동심판의 성격상 공동심판청구인 모두에 대하여 출소기간이 지나야 심결이 확정되므로, 1명이라도 심결취소소송을 제기하면 심결은 확정되지 아니한다고 본다. 이 경우 출소기간이 지난 공동심판청구인은 스스로 심결취소소송을 제기할 수는 없으나, 심결이 확정된 것은 아니므로 승소의 확정판결로 다시 심판이 계속되면 그 절차에서 심판청구인의 지위를 유지한다. 설문 (2)에서 본 대법원 판례가 인용심결의 경우에 분리확정을 부정한 것과 궤를 같이하는 것으로서 타당하다.

4. 사안의 포섭

甲은 심판청구인으로서 원고적격을 가지고, 심판피청구인인 A를 피고로 삼았으므로 甲이 단독으로 제기한 소는 적법하다. 제소하지 아니한 乙에 대한 심결도 분리하여 확정되지 아니하며, 乙은 스스로 소를 제기할 수는 없으나 甲이 승소하여 심판이 다시 계속되면 심판청구인의 지위를 유지한다.

5. 결론

甲이 단독으로 A를 상대로 제기한 소는 적법하고, 乙에 대한 심결도 확정되지 아니한다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	득점 포인트
(1) 공동심판 심결취소소송의 법적 성격 (유사필수적 공동소송)	6점	학설 대립 정리(통상/유사필수적/제한적 유사필수적), 대법원 판례 태도, 무효심결의 대세효(§133③)·합일확정 필요성을 근거로 유사필수적 공동소송이 타당함을 논증
(2) 인용심결에 대해 A가 甲만 상대로 제소한 경우 당사자 적격	7점	원고 A의 원고적격(§186②), 甲 단독의 피고적격 인정(유사필수적 공동소송이므로 전원 피고 불요), 乙에 대한 심결 확정차단 여부, 乙의 피고 추가 가부(고유필수적 아님 → 추가 불허 판례), 乙의 절차 참여 방안
(3) 기각심결에 대해 甲만이 A를 상대로 제소한 경우 당사자 적격	7점	甲 단독의 원고적격(유사필수적 공동심판이므로 1인 제소 적법·확정차단), A의 피고적격(§187), 乙의 구제책 (제소기간 내: 공동소송참가·별소 후 변론병합 / 제소기간 후: 보조참가)

배점 합계: 20점

측별 채점 기준

1) 논점 추출(약 8점)

- **득점:** ① 세 설문 공통 전제인 '공동심판(§ 139①)이 유사필수적 공동소송인지'의 성격 규명을 먼저 정리하고 각 설문에 연결한 답안. ② 설문(2)에서 '누락된 乙의 피고 추가 가부', 설문(3)에서 '누락된 乙의 구제책(공동소송참가·보조참가)'까지 파생 논점을 포착한 답안(채점평이 '관련 내용을 좀 더 논하였으면 하는 아쉬움'을 지적).
- **감점:** 심결취소소송 일반론·행정소송성 논의만 장황히 나열, 세 설문을 동일 논리로 반복, 대세효(§ 133③)·합일확정 요청 등 근거 누락, 원·피고 적격 적용 법규정(§ 186②, § 187) 미제시.

2) 목차·구성(약 5점)

- **득점:** I. 문제의 소재 → II. 공동심판 심결취소소송의 법적 성격(공통론) → III. 설문(1) → IV. 설문(2) → V. 설문(3) 순으로 공통쟁점을 앞에 배치하고 각 설문에서 결론을 명확히 낸 구성. 각 설문에 원고적격/피고적격/누락자 처리 소목차 부여.
- **감점:** 채점평이 지적한 대로 '세부목차를 통한 논리적 설명'이 없는 답안(줄글 서술, 설문별 배점(6·7·7)에 비례하지 않은 분량, 학설·판례 미구분).

3) 답안 작성·논증(약 7점)

- **득점:** 조문(§ 139①, § 186②, § 187, 민소 § 68·§ 83) → 학설 대립 → 대법원 판례(2007후1510 취지: 공동심판청구인 1인만 상대로 소를 제기하여도 심결 전부 확정차단) → 사안 포섭 → 결론 순의 4단 논증. 자기 입장(유사필수적 공동소송설)을 명시하고 그 논거(대세효 § 133③·합일확정 요청)를 제시.
- **감점:** 판례 결론만 나열하고 논거 부재, 결론 모호, '고유필수적 공동소송이 아니므로 추가 불허'라는 판례 논거 누락, 설문(2)와 (3)에서 결론(당사자적격 인정)만 같게 쓰고 이유·구제책 서술 부실.

감점 주의

- 통상공동소송설만 서술하고 대법원 판례(유사필수적 공동소송설)를 간과 → 채점평이 명시적으로 지적한 감점 사유.
- 무효심결의 대세효 근거를 제136조(정정심판)으로 잘못 인용한 답안(정확한 근거는 § 133③).
- 설문(2)에서 '甲만을 피고로 삼아도 되는가'의 결론만 쓰고, 乙의 피고 추가 가부(민소 § 68 준용 여부·판례 불허)를 논하지 않은 답안.
- 설문(3)에서 甲의 원고적격만 언급하고 제소기간 도과한 乙의 지위(보조참가만 가능) 등 구제책을 놓친 답안.
- 심결취소소송을 민사소송으로 오해하거나 행정소송·항고소송성만 장황히 서술.
- 유사필수적 공동소송의 개념(공동소송 강제되지 않으나 합일확정 요구)을 정확히 정의하지 않고 결론만 도출.

PART 3

2012

제1문	설문①-1: 1특허출원(발명의 단일성) 일반론(\$45, 시행령 \$6의 3요건) · 설문①-2: 甲출원의 단일성 판단(조약우선권 소급 검토 포함)	30점
제2문	확인대상발명 특정의 법리 · 사안 포섭 - 불특정 판단	20점
제3문	기술심리관의 제척사유 있는 소송관여가 재심사유인지 · 재심에 의해 회복된 특허권 하에서 乙의 실시 요건	30점
제4문	문언침해 성립 여부 검토(구성요소완비의 원칙) · 생략발명·생략침해의 의의 및 사안 포섭	20점

2012년 제1문

사례형

30점

문제

甲은 물질 X의 발명자로서 이를 2010. 11. 1. 미국에 특허출원한 후 특허법 제54조의 조약에 의한 우선권을 주장하여 【청구항 1】에 물질 X를 【청구항 2】에 물질 X를 관절염 치료에 이용하는 발명 Y를 기재하여 2011. 10. 5. 우리나라에 특허출원하였다. 乙은 2009년초부터 물질 X에 대한 연구를 시작하였으며 2011. 5. 1. 화학분야 학회의 학술대회에서 물질 X와, 물질 X의 제조방법인 Z에 대하여 발표하고, 2012. 4. 5. 공지에 외주장을 수반하여 【청구항 1】에 물질 X를 【청구항 2】에 물질 X의 제조방법인 Z를 기재하여 우리나라에 특허출원하였다.

① 甲의 특허출원과 乙의 특허출원이 1특허출원범위를 만족하는지에 대해 각각 설명하십시오. (10점)

② 乙의 특허출원이 공지에외주장의 시기적 요건을 만족하는지의 여부에 대하여 설명하십시오. (6점)

③ 甲이 출원한 【청구항 2】의 발명 Y가 특허를 받기 위해 만족해야 할 요건과 명세서 기재시 유의점에 대하여 설명하십시오. (14점)

모범답안

I. 설문 ① — 甲·乙 출원이 하나의 특허출원의 범위를 만족하는지 (10점)

1. 문제의 소재

특허출원은 하나의 발명마다 하나의 특허출원으로 함이 원칙이나, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군의 발명에 대하여는 하나의 특허출원으로 할 수 있다(§ 45①). 甲과 乙의 각 출원이 일 군의 발명에 해당하는지를 본다.

2. 하나의 특허출원의 범위

(1) 원칙과 예외

하나의 발명이란 카테고리과 관계없이 하나의 청구항을 의미한다. 일 군의 발명이란 카테고리를 불문하고 하나의 청구범위에 표현될 수 있는 기술적 상호 관련성이 있는 복수의 발명을 말하며, 이를 만족함을 실무상 발명의 단일성이라 한다.

(2) 판단대상과 판단방법

단일성은 독립항을 우선 고려하여 판단하고, 독립항이 이를 만족하면 그에 종속된 종속항도 만족한다. 시행령 제6조는 i) 청구된 발명 간에 기술적 상호 관련성이 있을 것, ii) 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가질 것을 요구하고, 이때의 기술적 특징은 발명 전체로 보아 선행기술과 비교하여 개선된 것이어야 한다. 개선은 신규성을 구비한 것으로 새기며, 심사 실무는 신규성과 진보성을 구비한 것으로 파악한다. 물건과 그 제조방법·사용방법과 같이 카테고리가 다른 청구항 사이에도 공통되는 기술적 특징이 있으면 단일성이 인정된다.

3. 甲 출원의 판단

(1) 조약우선권주장에 의한 판단시점의 결정

기술적 특징이 선행기술과 비교하여 개선된 것인지는 판단시점을 기준으로 가려지므로, 우선권주장이 있으면 그 시점이 먼저 정하여져야 한다. 조약에 따라 당사국에 특허출원한 자가 같은 발명을 우리나라에 출원하면서 우선권을 주장하면, 제29조와 제36조를 적용할 때 그 당사국에 출원한 날을 우리나라에 특허출원한 날로 본다(§ 54①). 이를 위하여는 i) 제1국 출원이 정규의 최초 출원일 것, ii) 두 출원이 동일한 발명일 것, iii) 제2국 출원이 제1국 출원일부터 1년 이내일 것, iv) 출원인이 제1국 출원인과 같거나 정당한 승계인일 것을 요한다. 그 효과는 판단시점의 소급일 뿐 출원일이 소급하는 것은 아니고, 소급의 범위도 청구범위에 적힌 발명 중 제1국 출원의 최초 명세서 또는 도면에 적힌 발명에 한한다.

(2) 사안의 포섭

청구항 1의 물질 X와 청구항 2의 발명 Y는 물질 X를 공통의 기술적 특징으로 하므로 기술적 상호관련성과 동일한 기술적 특징이 인정된다. 문제는 국내 출원일인 2011. 10. 5. 전인 2011. 5. 1. 乙의 학회 발표로 물질 X가 공지되어 그것이 선행기술이 되는지이다. 그러나 甲은 미국 최초 출원일인 2010. 11. 1.부터 1년 이내에 우선권을 주장하여 출원하였고 나머지 요건도 갖추어졌다면 신규성·진보성의 판단시점이 그 날로 소급하므로, 위 공지는 甲 출원의 선행기술이 되지 아니한다. 다만 미국 출원의 대상은 물질 X이므로 발명 Y가 그 최초 명세서에 적혀 있지 아니하였다면 청구항 2는 실제 국내 출원일을 기준으로 심사된다. 어느 경우이든 공통의 기술적 특징인 물질 X는 우선일을 기준으로 개선된 것이므로 甲의 출원은 하나의 특허출원의 범위를 만족한다.

4. 乙 출원의 판단

청구항 1의 물질 X와 청구항 2의 제조방법 Z 역시 물질 X를 공통의 기술적 특징으로 하고, 물건과 그 제조방법의 관계에 있으므로 카테고리가 다르더라도 기술적 상호관련성이 인정된다. 乙 자신의 학회 발표가 선행기술로 취급되면 개선된 기술적 특징이 없게 되나, 설문 ②에서 보는 바와 같이 공지에외주용

주장이 적법하면 그 발명은 공지되지 아니한 것으로 보므로(§ 30①) 선행기술이 되지 아니한다. 따라서 乙의 출원도 하나의 특허출원의 범위를 만족한다.

5. 결론

甲과 乙의 출원은 모두 하나의 특허출원의 범위를 만족한다. 제45조 위반은 발명의 실체가 아니라 둘 이상의 발명을 하나의 출원으로 한 절차상의 하자에 그치므로 거절이유에만 해당하고(§ 62) 정보제공사유나 무효사유에는 해당하지 아니한다.

Ⅱ. 설문 ② — 乙의 공지예외적용주장이 시기적 요건을 만족하는지 (6점)

1. 공지예외적용의 의의와 취지

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 제30조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면, 그 출원된 발명에 대하여 신규성과 진보성을 적용할 때 그 발명은 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다(§ 30①). 자기 발명의 공개로 스스로 특허를 받지 못하게 되는 것은 가혹하고, 공개를 이유로 출원을 서두르게 하기보다 일정한 유예를 주어 발명의 공개와 출원을 유도할 필요가 있기 때문이다.

2. 시기적 요건

기간은 최선의 공지일부터 기산하여 12개월이다. 자기의 의사에 의하여 공지된 경우는 물론 그 의사에 반하여 공지된 경우에도 같다. 이때 출원일이 공지일로 소급하는 것은 아니므로, 공지일과 출원일 사이에 타인의 출원이 있으면 그 타인의 출원과의 관계에서 불이익을 입을 수 있어 유예기간이 있더라도 될 수 있으면 빨리 출원하여야 한다.

3. 사안의 포섭

乙의 학회 발표는 2011. 5. 1.이고 국내 출원일은 2012. 4. 5.이다. 공지일부터 12개월이 되는 날은 2012. 5. 1.이므로 乙의 출원은 그 기간 안에 있다.

4. 결론

乙의 공지예외적용주장은 시기적 요건을 만족한다. 다만 시기적 요건은 적법 여부를 이루는 하나의 요건일 뿐이므로, 공지가 제30조 제1항 각 호의 사유에 해당하여야 하고, 그 취지를 적은 서류와 이를 증명할 수 있는 서류를 제출하는 절차적 요건도 갖추어야 한다. 이 서류는 출원과 동시에 제출함이 원칙이나, 보완수수료를 내면 일정한 기간에 제출할 수 있어 사후에도 주장할 기회가 열려 있다(§ 30③).

Ⅲ. 설문 ③ — 발명 Y의 특허요건과 명세서 기재 시 유의점 (14점)

1. 발명 Y의 성격

청구항 2의 물질 X를 관절염 치료에 이용하는 발명 Y는 물질 X가 가지는 약리적 성질을 발견하여 이를 특정 질병의 치료라는 용도에 이용하는 것으로서 의약품발명에 해당한다. 사람을 대상으로 하는 치료방법이 아니라 물질과 용도의 결합으로 이루어진 물건의 발명으로 파악한다.

2. 발명 Y가 만족하여야 할 요건

(1) 발명의 성립성

의약품발명은 천연물질 등에서 치료에 필요한 성분과 그 효능을 찾아내는 것이어서 발견의 성격을 가진다. 그러나 그 과정에 무수한 노력과 실험 및 투자가 들고 창작적 요소가 있으며, 그 의약이 사람의 생명과 건강 증진에 이바지하여 관련 산업의 발전에 기여하므로, 발견임에도 발명의 성립성을 인정한다.

(2) 산업상 이용가능성

사람을 대상으로 하는 치료방법은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 아니하나, 발명 Y는 치료방법이 아니라 물질과 용도로 이루어진 물건의 발명이므로 산업상 이용가능성이 인정된다.

(3) 신규성과 진보성

물질 X 자체는 이미 청구항 1로 청구되어 있으나 그 관절염 치료 용도가 우선일인 2010. 11. 1. 전에 공지되었다고 볼 사정이 없고, 물질 X나 그 제조방법 Z로부터 통상의 기술자가 관절염 치료 용도를 쉽게 도출할 수 있다고 볼 사정도 보이지 아니한다. 다만 진보성은 선행발명들로부터 그 물질의 그 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도인지에 따라 판단되며, 선행발명에 임상시험 등으로 치료효과가 확인되어 있을 것까지 요구되지는 아니한다.

(4) 그 밖의 요건

공공의 질서나 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있다고 볼 사정이 없어 제32조에 해당하지 아니하고, 설문 ①에서 본 바와 같이 하나의 특허출원의 범위도 만족한다.

3. 명세서 기재 시 유의점

(1) 발명의 설명 — 약리효과와 뒷받침

약리효과와 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 출원 전에 명세서에 적힌 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면, 특정 물질에 그러한 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 적거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 적어야만 발명의 설명의 기재요건을 충족한다(2013후730). 여기의 약리기전이 명확히 밝혀진 경우란 약리적 효과가 추정되거나 유사한 기전을 가진 물질이 그 용도를 가진다는 점이 공지된 정도로는 부족하다. 또한 시험례는 투여량의 범위, 구체적인 투여방법, 투여 대상의 규모, 그중 치료효과를 보았다고 평가한 비율, 투여 전후를 비교하여 치료효과를 얻었다고 판단한 근거가 드러날 정도로 적어야 한다. 따라서 ㉠은 물질 X가 관절염 치료에 유효함을 보이는 시험례를 이 정도로 구체화하여 적어야 한다.

(2) 청구범위 — 용도의 특징

의약용도발명에서는 물질이 가지는 의약용도가 발명의 구성에 해당하므로, 청구범위에는 그 용도를 대상 질병 또는 약효로 명확히 적는 것이 원칙이다. 다만 용도가 약리기전만으로 적혀 있더라도 발명의 설명의 다른 기재나 기술상식에 의하여 의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 있으면 제42조 제4항 제2호의 명확성 요건을 충족한다(2007후5215). 명확성은 통상의 기술자가 발명의 설명·도면과 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위의 기재로부터 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하고, 청구범위에 쓰인 용어만을 기준으로 일률적으로 판단하지 아니한다(2014후1563). 따라서 청구항 2는 관절염 치료용 물질 X와 같이 대상 질병을 특정하여 적어야 한다.

(3) 약리기전의 지위와 사후 보완의 한계

약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재한 속성으로서 물질과 의약용도의 결합을 도출해내는 계기에 불과하므로, 청구범위에 적힌 약리기전은 용도를 특정하는 한도에서만 의미를 가질 뿐 그 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소가 되지 아니한다. 그리하여 물질과 용도로 적힌 청구항에 약리기전을 덧붙이는 정정은 용도를 중복하여 적는 것에 지나지 아니하여 청구범위의 감축에 해당하지 아니한다(2012후3664). 나아가 보정은 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 적힌 사항의 범위에서 하여야 하므로(§ 47②), 출원 시에 없던 시험례나 약리효과와 자료를 뒤에 보태어 기재요건의 흠을 치유하는 데에는 한계가 있다. 결국 ㉠은 출원 시부터 약리효과와 시험례와 대상 질병으로 특정한 용도를 명세서에 갖추어 두어야 한다.

4. 결론

발명 Y는 의약용도발명으로서 성립성과 산업상 이용가능성이 인정되고 신규성·진보성도 갖추 수 있다. 다만 명세서에는 관절염 치료라는 약리효과를 뒷받침하는 구체적인 시험례를 적고, 청구범위에는 그 용도를 대상 질병으로 명확히 특정하여야 하며, 이는 출원 시에 갖추어야 하고 뒤에 보정으로 보태는 데에는 한계가 있음에 유의하여야 한다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
설문①-1: 1특허출원(발명의 단일성) 일반론(\$45, 시행령 \$6의 3요건)	3점	기술적 상호관련성·동일/상응하는 기술적 특징·선행기술 대비 개선의 3요건 명시, 카테고리 상이 시 판단법
설문①-2: 甲출원의 단일성 판단(조약우선권 소급 검토 포함)	3.5점	청구항1(물질X)-청구항2(용도발명Y) 간 기술적 특징 공통, 제54조 조약우선권 적용 시 판단시점 2010.11.1로 소급 → 乙의 2011.5.1. 공지가 선행기술 아님 → 단일성 충족
설문①-3: 乙출원의 단일성 판단(공지예외의 연계)	3.5점	청구항1(물질X)-청구항2(제조방법Z) 간 물질X 공통, 공지예외주장 적법 시 자기공지가 선행기술 아님 → 단일성 충족
설문②-1: 공지예외적용의 의의·취지와 시기적 요건 (\$30①)	4점	현행 \$30①의 12개월 요건, 취지(자기 공개로 특허를 받지 못하는 가혹함의 완화), 기산점은 최선의 공지일 이고 의사에 반한 공지도 같다는 점, 출원일이 공지일로 소급하지 아니하여 그 사이 타인의 출원에 불이익을 입을 수 있다는 점
설문②-2: 乙 사안 포섭	2점	공지일 2011. 5. 1. → 출원일 2012. 4. 5.로 12개월 이내 → 시기적 요건 충족. 시기적 요건은 하나의 요건일 뿐이므로 \$30① 각 호의 사유 해당 여부와 취지 서류·증명서류 제출(\$30③ 보완 포함)까지 덧붙이면 가점
설문③-1: 청구항2가 의약용도발명임을 특정	1점	물질X를 관절염 치료에 이용 = 의약용도발명(물건발명 취지) 전제 확립
설문③-2: 특허요건(성립성·산업상 이용가능성·신규성·진보성)	7점	성립성 — 발견의 성격을 가지나 창작적 요소와 산업 기여를 이유로 발명의 성립성을 인정 한다는 근거 제시(★악리데이터 판례 2013후730 은 명세서 기재요건 판례이므로 성립성 근거로 들면 감점), 산업상 이용가능성(치료방법이 아닌 물건의 발명이므로 인정), 신규성·진보성 검토
설문③-3: 명세서 기재 유의점 (\$42③(1)·④)	6점	발명의 설명 — 악리데이터 등이 나타난 시험례 기재(2013후730), 그 기재정도(투여량 범위·투여방법·투여 대상 규모·치료효과·비율·투여 전후 비교 근거)까지 쓰면 가점. 청구범위 — 대상 질병 또는 약효로 명확히 기재, 악리기전만이어도 명확성 충족 가능(2007후5215), 명확성 판단기준(2014후1563). 악리기전은 구성요소가 아니어서 이를 덧붙이는 정정은 감축이 아니라는 점(2012후3664)과 보정범위의 한계(\$47②)까지 짚으면 가점

배점 합계: 30점

특별 채점 기준

1) 논점 추출(40%, 12점)

- **특점 포인트**
- ①에서 조약우선권 소급효(\$ 54)와 공지예외(\$ 30)가 단일성의 '선행기술 대비 개선' 요건에 연결됨을 포착.
- ②에서 '시기적 요건'에 국한된 질문임을 파악하고 현행 \$ 30①의 12개월 요건으로 곧바로 포섭함.
- ③에서 발명Y가 '의약용도발명'임을 선(先) 특정하고, 요건과 명세서 기재를 분리 서술.
- **감점 포인트**
- 발명Y를 '치료방법'으로 오인하여 의료행위의 산업상 이용가능성만 장황하게 다룸.
- 공지예외 시기적 요건만 물었는데 절차적 요건(취지서·증명서류 30일)만 채워 서술.
- 조약우선권·공지예외의 단일성 요건과의 연계를 놓침.

2) 목차·구성(25%, 7.5점)

- **특점 포인트**
- 설문별로 별도의 로마자 목차, 각 설문 내에서 일반론 → 사안 포섭 → 결론의 흐름.
- 배점 14점인 ③에 가장 많은 지면 할애, 6점인 ②는 간결 처리.
- ③에서 특허요건과 명세서 기재를 각각 별도 소재목으로 분리.
- **감점 포인트**
- ②에 지면 편중, ③이 부실.
- 조문 나열만 하고 결론 없음.
- 채점평 지적: 알아보기 어려운 문장, 요약 없는 장황한 서술.

3) 답안 작성·논증(35%, 10.5점)

- **특점 포인트**
- 제45조·시행령제6조·제30조·제54조·제42조 제3항 제1호·제42조 제4항 조문 정확 인용.
- 판례(2013후730, 2007후5215, 2014후1563, 2012후3664) 취지 인용.

- 甲 우선권 소급 → 2011.5.1. 공지가 甲의 선행기술 아님 논증, 乙 공지예외 적용 → 자기공지 배제 논증.
- 명확한 결론('단일성 충족', '시기적 요건 충족', '실험례 기재 필수').
- **감점 포인트**
- 조문 전사식 나열만 하고 사안 포섭 없음.
- 결론이 애매하거나 본문과 모순.
- 현행 § 30①의 12개월이 아닌 종전 기간을 기준으로 결론 도출.

감점 주의

- 발명Y를 방법발명(치료방법)으로 파악 → 산업상 이용가능성 부정으로 결론짓는 오류(해설 공통 지적).
- ★기출이라도 **현행법으로 풀이**한다. 공지예외적용기간의 개정 경과나 부칙(시행일·적용례)은 답안에서 다루지 아니하고, 현행 § 30①의 12개월만으로 포섭할 것.
- 甲의 조약우선권 소급효를 언급하지 않아 乙의 2011.5.1. 공지가 甲출원의 선행기술이 된다고 판단하는 오류.
- 명세서 기재 유의점에서 청구범위(대상 질병·약효 명기)와 발명의 설명(약리효과 시험례)을 구분하지 않고 뭉뚱그림.
- 채점평 지적: 장황한 서술보다 질문에 대한 정확한 요약이 고득점.

2012년 제2문

사례형

20점

문제

A 발명의 특허권자 甲이 B를 실시하고 있는 乙에 대하여 2011. 11. 24. 적극적권리범위 확인심판을 청구하였다.

(1) 확인대상발명(B)의 일부 구성이 불명확하여 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되지 않은 경우의 절차에 대하여 설명하시오.

(14점)

(2) 만약, 甲이 확인대상발명(B)의 설명서 및 도면을 보정한 경우 요지변경에 해당하는지 여부에 대하여 설명하시오. (6점)

모범답안

I. 설문 (1) — 확인대상발명이 특정되지 아니한 경우의 절차 (14점)

1. 문제의 소재

권리범위확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비할 수 있는 설명서와 필요한 도면을 첨부하여야 한다(§ 140③). 확인대상발명 B는 일부 구성이 불명확하여 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 특정되지 아니하였다. 확인대상발명의 특징이 어느 국면에서 무엇을 요구하는지를 먼저 가린 뒤, 특정되지 아니한 경우 특허심판원이 취하여야 할 조치를 본다.

2. 확인대상발명의 특정

(1) 두 국면의 구별

확인대상발명의 특징은 청구취지로서의 특징과 청구원인으로서의 특징으로 나누어 볼 필요가 있다. 구별의 실익은, 청구취지로서 특징이 명확하면 일사부재리의 효력이 미치는 범위가 명확하므로 청구원인으로서 특징이 다소 불명확하더라도 권리범위에 속하는지를 판단할 수 있는 경우에는 각하하지 아니하고 본안심결을 할 수 있다는 데에 있다.

(2) 청구취지로서의 특정

심판의 대상을 정하는 것이므로 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 기재되어야 한다. 확인대상발명을 식별할 수 있는 제품명이나 제품번호가 있으면 이를 적는 것만으로도 다른 것과 구별할 수 있을 정도로 특정한 것으로 볼 수 있고, 설명서와 도면으로 그 구성을 적는 방법도 적절하다.

(3) 청구원인으로서의 특정

특허발명의 구성과 확인대상발명의 구성을 비교하여 권리범위에 속하는지를 판단하기 위한 것이므로, 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 기재하여야 한다. 특허발명의 대응되는 부분의 구체적인 구성이 차이점을 판단함에 필요한 정도로 적혀 있으면 충분하고, 실시 제품의 구성을 전부 적을 필요는 없다. 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서와 일치하지 아니하는 도면이 있더라도 나머지 기재와 도면을 종합하여 속부를 판단할 수 있으면 특정된 것으로 본다(2017후2291, 2010후296). 다만 속부를 판단할 수 없게 모호하거나 특징의 결과에 따라 결론이 달라진다면 특정되었다고 할 수 없다.

3. 특정되지 아니한 경우의 절차

(1) 직권조사

확인대상발명이 구체적으로 특정되었는지는 심판청구의 적법요건이므로, 당사자의 명확한 주장이 없더라도 특허심판원이나 법원이 직권으로 조사하여 밝혀야 한다.

(2) 보정명령

청구취지로서의 특징이 불명확하다면 특허심판원은 요지변경이 되지 아니하는 범위에서 확인대상발명의 설명서와 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 하여야 한다(2010후3356). 심판장은 심판청구서가 제140조 제3항을 위반한 경우 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 하고, 지정된 기간에 보정하지 아니하면 결정으로 심판청구서를 각하한다(§ 141①②).

(3) 보정에도 미흡한 경우

그런데도 특징에 미흡함이 남는다면 심결이 확정되더라도 일사부재리의 효력이 미치는 범위가 명확하다고 할 수 없으므로, 나머지 구성만으로 권리범위에 속하는지를 판단할 수 있는 경우라도 심판청구를 각하하여야 한다(2010후3356).

(4) 청구원인으로서의 특정만 불명확한 경우

이와 달리 청구취지로서의 특징은 갖추어져 일사부재리의 객관적 범위를 정할 수 있고 청구원인으로서의 특정만 다소 불명확한 경우에는, 나머지 구성만으로 속부를 판단할 수 있다면 각하하지 아니하고 본안심결을 할 수 있다(2010후296).

4. 사안의 포섭

확인대상발명 B는 일부 구성이 불명확하여 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 특정되지 아니하였으므로 청구취지로서의 특징을 흠결한 경우이다. 따라서 특허심판원은 직권으로 이를 조사하고, 甲에게 요지변경이 되지 아니하는 범위에서 설명서와 도면의 보정을 명하여야 한다. 甲이 이에 응하지 아니하면 결정으로 심판청구서가 각하되고, 보정을 하였으나 여전히 특정되지 아니한다면 나머지 구성만으로 속부를 판단할 수 있더라도 심판청구는 각하된다.

5. 결론

특허심판원은 직권조사에 이어 요지변경이 되지 아니하는 범위에서 보정을 명하고, 그에도 특정에 미흡함이 남으면 본안에 나아가지 아니하고 심판청구를 각하하여야 한다. 이는 일사부재리의 효력이 미치는 범위를 명확히 하기 위한 것이다.

II. 설문 (2) — 확인대상발명 보정의 요지변경 해당 여부 (6점)

1. 문제의 소재

확인대상발명은 청구취지의 일부를 이루므로 그 보정은 요지변경이 되지 아니하는 범위에서만 허용됨이 원칙이나, 甲이 청구한 적극적 권리범위확인심판에는 특칙이 있다.

2. 요지변경 금지의 원칙

심판청구서의 보정은 요지변경이 되지 아니하는 범위에서만 할 수 있다(§ 140② 본문). 이를 함부로 인정하면 심판사무를 복잡하게 하고 질차를 지연시키며 피청구인의 방에도 곤란을 주기 때문이다. 여기의 요지란 청구의 취지와 이유 등 심판청구서 전체의 취지를 살펴 등록된 권리를 중심으로 동일성을 해하지 아니하는 범위를 말한다.

3. 요지변경에 해당하지 아니하는 경우

확인대상발명의 보정이 i) 설명서와 도면에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것이거나 ii) 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여, 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 발명의 동일성이 유지된다면 요지변경에 해당하지 아니한다(2012후44). 여기의 동일성은 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란하게 할 염려가 있는지의 관점에서 파악하는 것이어서, 신규성이나 선출원에서의 동일성 개념과는 그 근거를 달리한다.

4. 적극적 권리범위확인심판의 특칙

특허권자 등이 청구한 권리범위확인심판에서 피청구인이 확인대상발명이 자신의 실시발명과 다르다고 주장하는 경우, 청구인이 그 실시발명과 동일하게 하기 위하여 설명서 또는 도면을 보정하는 때에는 요지변경이 되더라도 허용된다(§ 140②Ⅲ). 적극적 심판에서는 확인대상발명을 특정할 의무가 있는 자와 실제 실시자가 달라 피청구인의 협력 없이는 정확한 특징이 어려우므로 청구인의 불리함을 보상하려는 것이며, 그리하여 특정 의무자와 실시자가 같은 소극적 심판에는 적용되지 아니한다.

5. 사안의 포섭과 결론

甲의 보정이 乙의 다르다는 주장에 따라 그 실시발명과 동일하게 하기 위한 것이라면 요지변경이 되더라도 허용된다. 그렇지 아니한 경우에는 불명확한 부분의 구체화나 당연히 있어야 할 구성의 부가에 그쳐 동일성이 유지되는 한 요지변경이 아니고, 그 범위를 벗어나면 요지변경으로서 허용되지 아니한다. 한편 심결취소소송 단계에서는 심판청구요건의 흠을 치유하는 보정이 허용되지 아니하므로(99후2372) 보정은 심결 시까지 하여야 한다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	득점 포인트
(1) 확인대상발명 특정의 법리	4점	청구취지로서의 특정 (사회통념상 다른 것과 구별될 수 있는 정도)과 청구원인으로서의 특정 (특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼)을 나누어 제시하고, 구별의 실익 (청구취지 특정이 명확하면 청구원인 특정이 다소 불명확해도 속부 판단이 가능하면 본안심결 — 2010후296, 2017후2291)까지 밝힐 것. 발문의 '다른 것과 구별될 수 있는 정도'는 청구취지로서의 특정을 가리킨다 (2010후3356)
(1) 사안 포섭 - 불특정 판단	2점	B의 일부 구성 불명확 → 확인대상발명이 특정되지 않음을 결론
(1) 특허심판원의 절차 - 보정명령·직권조사	5점	①직권조사사항, ②요지변경이 되지 않는 범위 내 보정명령(§141), ③보정불응·특정 불가시 각하
(1) 보정명령 없이 본안판단 가부	3점	일사부재리 효력 범위 불명확 → 나머지 구성만으로 판단 가능해도 각하해야 함(판례)
(2) 요지변경 원칙 조문 (§140②본문)	2점	심판청구서 보정은 원칙적으로 요지변경 불허 명시
(2) 요지변경 아닌 것으로 본 판례 태도	2점	불명확 구체화·당연구성 추가·수치정정·생산방법 부가 등 동일성 유지 판례
(2) 적극적 권리범위확인심판의 특칙 (§140②(3))	2점	★주 논점. 피청구인이 자신의 실시발명과 다르다고 주장하는 경우 청구인이 그 실시발명과 동일하게 하기 위한 확인대상발명 보정은 요지변경이라도 허용 된다는 점과 그 취지(특정 의무자와 실시자가 달라 피청구인 협력 없이는 정확한 특정이 곤란 → 청구인의 불리함 보상), 소극적 심판에는 적용되지 아니한다는 점. 사안은 甲 이 청구한 적극적 심판이므로 정면으로 적용된다

축별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- **득점:** 설문(1)에서 '절차'를 물었음을 정확히 인식하여 ①특정 판단 법리, ②심판원의 조치(보정명령·직권조사·각하)를 모두 포착; 최근 대법원 판례(확인대상발명 자체의 사회통념상 특정 요구)를 별도 논점으로 적시; 설문(2)에서 제140조 제2항본문 인용과 요지변경 판단기준 판례를 적시
- **감점:** 특정 판례만 나열하고 심판원 절차(보정명령→각하)를 누락; 최근 판례 취지(자체 특정)와 종전 판례(대비 가능성 특정)의 차이를 구별 못함; 확인의 이익, 심판청구 요건 등 무관한 일반론 장황 서술

2) 목차·구성(25%)

- **득점:** (1)14점·(2)6점의 배점에 비례해 분량 배분; 목차를 '특정법리→사안포섭→불특정시 절차→본안판단 가부→결론' 순으로 체계화; (2)는 원칙→판례→사안포섭→(보론)으로 간결하게 구성
- **감점:** 설문(1)에서 특정 판례에만 지면 편중하고 절차 부분이 빈약; 제140조 제2항 제3호(확인 이익)를 주 논점처럼 크게 다룸; 서론·일반론 장황

3) 답안 작성·논증(35%)

- **득점:** 조문 (§140②③, §141①②) → 판례(청구취지·청구원인 특정의 구별, 직권조사, 보정명령 후 각하) → 사안 포섭의 순서를 지킴; 판례의 이유(일사부재리 효력 범위 불명확)까지 논증; 요지변경 판단에서 '**동일성**'을 **절차 지연·방어권 곤란의 염려라는 관점에서 파악하고 신규성·선출원의 동일성과 근거가 다름**을 밝히면 가점(2012후44)
- **감점:** 판례 판시내용을 부정확·모호하게 인용; 결론이 애매("경우에 따라 다를 수 있다"만 반복); 조문 미인용; 실무 절차 이해 부족(채점평 지적사항)

감점 주의

- **채점평 지적:** 실무 절차(보정명령→불응시 각하)의 이해 부족은 감점 사유. 단순히 판례만 인용하고 심판원이 실제로 무엇을 하는지 서술 못하면 감점.
- 문장을 알아보기 어렵게 작성하거나 요지 정리 없이 늘어놓으면 감점(채점평).
- ★ §140②(3)을 '확인 이익' 규정으로 오해하는 서술은 감점 — 이는 **요지변경의 예외**를 정한 규정이며, 사안처럼 적극적 권리범위확인심판의 청구인이 확인대상발명을 보정한 경우에 정면으로 문제된다.
- 99후2372를 '대비 가능성만 본 종전 판례'로 인용하면 감점 — 이 판결의 취지는 **심결취소소송 단계에서 확인대상발명의 보정이 허용되지 아니한**다는 것이다.
- 설문(2)에서 요지변경 여부를 단정하지 않고 원칙만 서술하면 감점 — 판례 기준 적용해 '동일성 유지 범위 내이면 요지변경 아님'이라는 결론 명시 필요.
- 확인대상발명 자체의 특정 요구라는 최근 판례 취지를 놓치고 종전 판례(대비 가능성만)만 인용하면 감점.

2012년 제3문

사례형

30점

문제

甲은 발명 P(A+B+C+D)에 대하여 2009. 2. 20. 특허를 취득하였다. 乙은 2009.6.1.부터 발명 P를 판매하여 왔다. 2009. 7. 10. 甲은 乙이 자신의 특허를 침해하고 있다고 판단하여, 침해를 금지해 줄 것을 요청하는 경고장을 乙에게 발송하였다. 乙은 발명 P 판매를 중지하고, 甲의 특허발명 P는 A+B라는 비교대상발명 1과 C+D라는 비교대상발명 2를 결합하여 당업자라면 용이하게 발명할 수 있는 것이기 때문에 진보성을 결여한 발명이라고 주장하면서 특허무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 2010.6.1. 심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 이에 대하여 甲은 2010. 6. 25. 특허법원에 특허무효심결의 취소를 구하는 심결취소소송을 제기하였다. 이 사건에 관여하는 기술심리관 丁은 사건을 검토하던 중 甲의 특허발명이 자신이 지식재산처 심사관으로 재직 중 특허등록결정을 하였던 발명이라는 사실을 확인하였다. 2011. 2. 2. 특허법원은 원고의 청구를 기각하는 판결을 내렸다. 甲은 대법원에 상고할 것을 포기하였고 결국 특허법원의 판결은 확정되었다. 이후 甲은 기술심리관 丁이 지식재산처 심사관으로서 자신의 특허출원을 심사하였던 사실을 알고 재심을 청구하였다.

- (1) 甲의 재심청구가 재심사유에 해당되는지 설명하시오. (8점)
- (2) 甲의 특허권이 재심에 의하여 회복된다면 乙이 발명 P를 실시하기 위한 요건을 설명하시오. (12점)
- (3) 기술심리관 丁이 취했어야 할 적절한 조치를 설명하시오. (5점)
- (4) 위에 기술된 사실관계와는 달리 만약 甲이 소송의 심리 중에 기술심리관 丁이 지식재산처 심사관으로서 甲의 특허발명의 심사에 관여했었다는 사실을 알게 되었을 때 甲이 취할 수 있는 조치를 설명하시오. (5점)

모범답안

I. 설문 (1) — 甲의 재심청구가 재심사유에 해당하는지 (8점)

1. 문제의 소재

甲이 재심을 구하는 대상은 확정된 심결이 아니라 특허법원의 확정판결이다. 그 재심의 근거와 사유를 먼저 가린 뒤, 심사관으로서 등록결정을 하였던 丁이 기술심리관으로 그 소송에 관여한 것이 재심사유가 되는지를 본다.

2. 심결취소소송의 확정판결에 대한 재심

제178조의 재심은 확정된 특허취소결정 또는 확정된 심결을 대상으로 하는 것이므로, 특허법원의 확정판결에 대하여는 행정소송법 제8조에 따라 준용되는 민사소송법 제451조에 의하여 재심을 청구한다. 같은 조 제1항 제2호는 법률상 그 재판에 관여할 수 없는 법관이 관여한 때를 재심사유로 정하고, 같은 항 단서는 당사자가 상소로 그 사유를 주장하였거나 이를 알고도 주장하지 아니한 때에는 재심을 청구할 수 없다고 하여 재심의 보충성을 정한다.

3. 기술심리관 丁의 제척사유

특허법원은 기술분야의 전문성을 보좌하기 위하여 기술심리관을 두고, 법원은 결정으로 기술심리관을 심결취소소송의 심리에 참여하게 할 수 있다(법원조직법 제54조의2 제1항·제2항). 기술심리관도 소송의 중립과 공정을 유지하기 위하여 제척·기피의 대상이 되므로 그 제척에는 제148조가 준용된다(§ 188의2①). 제148조 제6호는 사건에 대하여 심사관으로서 특허여부결정에 관여한 경우를 제척사유로 정하는데, 丁은 심사관으로서 이 사건 특허의 등록결정을 한 자로서 그 특허의 무효심결에 대한 취소소송에 기술심리관으로 관여하였으므로 제척사유가 있다.

4. 제척사유 있는 기술심리관의 관여가 재심사유인지

민사소송법 제451조 제1항 제2호는 문언상 법관을 대상으로 하므로, 법관이 아닌 기술심리관의 관여가 이에 해당하는지가 문제된다. 그러나 소송의 심리에 참여하는 기술심리관은 재판장의 허가를 받아 해당 기술분야에 관하여 질문할 수 있고 재판의 합의에 의견을 진술할 수 있어(법원조직법 제54조의2 제3항) 재판의 형성에 실질적으로 관여한다. 제척은 법률이 정한 사유가 있으면 당연히 직무집행에서 배제되는 제도인데, 그러한 사유를 안고 재판의 합의에 관여하였다면 재판의 공정을 해하는 정도가 법관의 경우와 다르지 아니하다. 따라서 위 재심사유에 해당한다고 봄이 타당하다.

5. 결론

丁에게는 제148조 제6호의 제척사유가 있음에도 소송의 심리에 관여하였으므로 민사소송법 제451조 제1항 제2호의 재심사유에 해당한다. 甲이 상고를 포기하였으나 그때에는 이 사유를 알지 못하였으므로 재심의 보충성에도 반하지 아니한다. 다만 재심은 그 사유를 안 날부터 30일 이내에 청구하여야 하므로 이 기간의 준수가 전제된다.

II. 설문 (2) — 乙이 발명 P를 실시하기 위한 요건 (12점)

1. 문제의 소재

특허권의 침해란 특허권의 존속 중 정당한 권원이 없는 자가 업으로서 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 실시하는 것을 말한다. 무효심결의 확정으로 처음부터 없었던 것으로 되었던(§ 133③) 甲의 특허권이 재심에 의하여 회복되는 이상, 乙이 발명 P를 실시하려면 그 침해가 성립하지 아니하여야 한다. 사안에서는 정당한 권원으로서 제182조의 통상실시권이, 보호범위에 속하지 아니하게 하는 제한사유로서 제181조가 문제된다.

2. 회복된 특허권의 효력 제한

(1) 물건에 대한 제한

무효가 된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우, 특허권의 효력은 그 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 수출 또는 수입하거나 국내에서 생산 또는 취득한 물건에는 미치지 아니한다(§ 181①(1)).

(2) 행위에 대한 제한

또한 특허권의 효력은 i) 그 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 한 그 발명의 선의의 실시, ii) 물건의 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을, iii) 방법의 발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 그 기간에 선의로 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위에 미치지 아니한다(§ 181②).

(3) 한계

이는 그 기간에 이미 이루어진 실시와 그 기간에 취득한 물건을 면책하는 데 그치고, 장래에 걸쳐 실시할 권원을 주는 것이 아니다.

3. 선사용자의 통상실시권

(1) 의의와 취지

제181조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 그 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 국내에서 선의로 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는, 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 관하여 통상실시권을 가진다(§ 182). 확정된 심결이라는 공권적 판단을 신뢰한 선의의 실시자를 보호하고, 그 실시로 갖추어진 산업설비를 유지하려는 것이다.

(2) 요건

i) 무효가 된 특허권이 재심에 의하여 회복되는 등 제181조 제1항 각 호에 해당할 것, ii) 그 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전의 실시일 것, iii) 선의일 것, 곧 그 심결에 재심사유가 있음을 알지 못하였을 것, iv) 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있거나 그 사업을 준비하고 있을 것을 요한다.

(3) 효과

확정된 심결을 신뢰한 자의 보호에 중점이 있어 대가를 지급하지 아니하는 무상의 통상실시권이며, 그 범위는 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위이다. 청구항별로 무효가 된 특허권이 회복된 경우에는 청구항별로 인정된다(§ 215).

4. 사안의 포섭

乙은 2009. 7. 10. 甲의 경고장을 받고 발명 P의 판매를 중지하였다. 따라서 무효심결이 확정된 2011. 2. 2. 후 재심청구 등록 전에 국내에서 실시사업을 하고 있었거나 그 사업을 준비하고 있었는지가 관건이다. 생산설비와 재고를 유지하는 등 사업의 준비를 계속하고 있었다면 그 범위에서 무상의 통상실시권을 가지나, 사업을 완전히 정리하였다면 이 요건을 갖추지 못한다. 같은 이유로 그 기간에 실시가 없었다면 제181조의 면책도 대상이 없다. 한편 乙은 스스로 무효심판을 청구한 자이나 재심사유인 丁의 제척사유는 알지 못하였으므로 선의가 부정되지는 아니한다.

5. 결론

乙이 심결 확정 후 재심청구 등록 전에 국내에서 실시사업을 하거나 그 준비를 하고 있었다면 그 범위에서 무상의 통상실시권을 가져 계속 실시할 수 있다. 그렇지 아니하다면 제181조의 면책은 그 기간의 실시와 물건에 그치므로, 장래의 실시를 위하여는 甲으로부터 전용실시권이나 통상실시권을 설정받는 등 별도의 권원을 갖추어야 한다.

III. 설문 (3) — 기술심리관 丁이 취했어야 할 조치 (5점)

1. 기술심리관의 제척·기피와 회피

기술심리관도 소송의 중립과 공정을 유지하기 위하여 제척·기피의 대상이 되며, 그에 관하여는 제148조와 민사소송법 제42조부터 제45조까지, 제47조 및 제48조가 준용된다(§ 188의2①). 기술심리관에 대한 제척·기피의 재판은 그 소속법원이 결정으로 한다(§ 188의2②). 나아가 기술심리관은 제척 또는 기피의 사유가 있다고 인정하면 특허법원장의 허가를 받아 회피할 수 있다(§ 188의2③).

2. 사안의 포섭

丁은 사건을 검토하던 중 이 사건 특허가 자신이 심사관으로 재직하며 등록결정을 한 발명임을 확인하였으므로, 제148조 제6호의 제척사유가 있음을 스스로 알게 되었다. 제척사유가 있는 자는 법률상 당연히 직무집행에서 배제되므로, 丁은 그 사실을 안 즉시 특허법원장의 허가를 받아 회피하여 소송의 심리에서 물러났어야 한다.

3. 결론

丁은 지체 없이 회피하였어야 한다. 그럼에도 그대로 심리에 관여한 것은 위법하고, 그 결과 확정판결에 재심사유를 남기게 되었다.

IV. 설문 (4) — 심리 중에 알게 된 경우 甲이 취할 수 있는 조치 (5점)

1. 제척의 재판 신청

기술심리관의 제척에는 민사소송법 제42조부터 제45조까지가 준용되므로(§ 188의2①), 甲은 丁에게 제척의 이유가 있음을 밝혀 그 합의부에 제척의 재판을 신청할 수 있고, 그 이유와 소명방법은 신청한 날부터 3일 이내에 서면으로 제출하여야 한다. 제척은 법률이 정한 사유가 있으면 당연히 직무집행에서 배제되는 것이므로 그 재판은 확인적 성질을 가지고, 법원은 직권으로도 이를 할 수 있다. 기술심리관에 대한 제척의 재판은 그 소속법원이 결정으로 한다 (§ 188의2②).

2. 소송절차의 정지

제척의 신청이 있으면 법원은 그 재판이 확정될 때까지 소송절차를 정지하여야 한다. 다만 신청이 각하된 경우나 종국판결을 선고하는 경우 등에는 그러하지 아니하다(민소 § 48 준용).

3. 불복

신청이 방식에 어긋나거나 소송의 지연을 목적으로 함이 분명하여 각하된 경우, 또는 이유 없다는 결정이 있는 경우에는 즉시항고할 수 있다(민소 § 47② 준용). 반면 신청에 정당한 이유가 있다는 결정에 대하여는 불복할 수 없다.

4. 종국판결에 대한 상고

이러한 조치에도 제척사유 있는 丁이 관여한 채로 판결이 선고되었다면, 甲은 그 판결에 대하여 상고하면서 재판에 관여할 수 없는 자가 관여하였음을 다룰 수 있다.

5. 결론

甲은 제척의 재판을 신청하여 丁을 직무집행에서 배제시키고, 각하되거나 이유 없다는 결정을 받으면 즉시항고하며, 끝내 배제되지 아니한 채 판결이 선고되면 상고로 다룰 수 있다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
(1) 기술심리관의 제척사유 있는 소송관여가 재심사유인지	8점	① ★재심의 근거를 정확히 특정 — 재심 대상은 특허법원의 확정판결 이므로 확정된 심결을 대상으로 하는 §178 이 아니라 행정소송법 §8 에 따라 준용되는 민사소송법 §451 이다 ② 기술심리관의 제척은 §188의2④이 §148을 준용 → §148(6) 해당 ③ 민소 §451①(2)의 문언은 '법관' 이므로 기술심리관이 이에 해당하는지를 정면으로 논할 것 — 기술심리관은 재판장의 허가를 받아 질문하고 재판의 합의에 의견을 진술 하므로(법원조직법 제54조의2 제3항) 재판의 형성에 실질적으로 관여한다는 점을 근거로 긍정 ④ 재심의 보충성(민소 §451① 단서)과 제기기간
(2) 재심에 의해 회복된 특허권 하에서 乙의 실시 요건	12점	① 제181조(재심에 의해 회복된 특허권의 효력제한): 심결확정 후 재심청구등록 전 선의 실시·생산·취득에 효력 불미침 ② 제182조 (선사용자의 통상실시권): 심결확정 후 재심등록 전 선의로 국내에서 실시사업/사업준비 중인 자에게 통상실시권(무상) 부여 ③ 사안 포섭: 乙은 경고 후 판매를 중지하였으므로 심결 확정 후 재심청구 등록 전에 실시사업 또는 그 준비 가 있었는지를 구체적으로 검토할 것(없었다면 §181의 면책도 대상이 없다) ④ §182 의 효과(무상 , 실시준비하는 발명 및 사업목적의 범위, 청구항별 인정 §215) ⑤ 요건 불비 시 甲으로부터 실시권을 설정받는 등 별도 권원 필요
(3) 기술심리관 丁의 적절한 조치	5점	① 제148조 제6호 제척사유 존재(§188의2④ 준용) ② 회피(§188의2③, 특허법원장 허가) ③ 스스로 회피할 의무
(4) 甲이 취할 수 있는 조치	5점	① 제척재판신청(§188의2④ 준용 민소§42) ② 기각 시 즉시항고(§188의2④ 준용 민소§47) ③ 종국판결에 대한 상소로 절대적 상고이유 (민소§424④(2)) 주장

합계: 30점

※ 조문 병기: 기술심리관의 제척·기피·회피는 **현행 특허법 제188조의2**(현행 § 222는 '서류의 제출 등'에 관한 조항으로 본 문제와 무관), 제148조·제178 조·제181조·제182조 역시 현행에도 동일 조번호 유지. **제188조의2 제1항은 제148조 및 민사소송법 제42조부터 제45조까지, 제47조 및 제48조를 준용**함에 유의.

특별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- (1) 재심의 근거를 **행정소송법 §8 → 민소 §451**로 잡고(§ 178 은 확정 심결에 대한 재심이므로 사안의 근거가 아님), § 188의2①→§ 148(6)의 준용으로 제척사유를 확정 한 뒤, **'법관' 문언과 기술심리관의 관계**를 논점으로 드러냈는가 → 최우선 채점 포인트
- (2) 제181조과 제182조를 **모두** 언급하되 사안(乙이 판매중지한 상태)에서 제182조 요건 충족여부(실시사업 계속·준비)를 구체적으로 판단했는가
- (3) 회피(§ 188의2③)를 정확히 지목했는가
- (4) 제척신청·즉시항고·상고이유의 3단계 조치를 모두 적시했는가
- 감점: **재심의 근거를 §178②로 잡는 것**(사안은 확정판결이지 확정 심결이 아니다), 민소 § 451①(2)의 '법관' 문언을 '자'로 바꿔 써 쟁점을 뒀는 것, 제181조만 쓰고 제182조 누락, 회피 대신 기피만 언급

2) 목차·구성(25%)

- 4개 소문 각각을 별도 목차(I~IV)로 구분
- 배점 비례 분량: (2)에 가장 많은 지면(§ 181·§ 182 각 요건별 세분), (3)·(4)는 간결하게
- 채점평 지적: "제182조를 강약 없이 균등하게 기술" → 요건·효과·사안포섭 구조로 강약 배분
- 감점: (1)에 재심 일반론 상황 서술, (2)에서 제181조·제182조 조문 전사만 나열

3) 답안 작성·논증(35%)

- 조문(§ 148, § 181, § 182, § 188의2, 법원조직법 법원조직법 제54조의2, 행정소송법 § 8, 민소 § 451) → 준용관계 확인 → 사안 포섭 → 결론의 4단 논증
- (1) 준용의 연쇄(§ 188의2①→§ 148(6) / 행정소송법 § 8→민소 § 451①(2)) 명시
- (2) 乙의 "선의"."실시사업 또는 준비"."국내"."심결확정후 재심등록전" 4요건 개별 포섭
- (4) 즉시항고(민소 § 47 준용)와 상소(민소 § 424①(2) 절대적 상고이유)의 병렬 조치 제시
- 감점: 조문 전사식 나열, 준용 연결고리 생략, "~일 것이다"식 애매한 결론

감점 주의

- **채점평 지적 1:** B·1을 아예 백지로 두거나 성의없이 작성 → 마지막까지 답안 작성 태도 필수
- **채점평 지적 2:** 선사용자 통상실시권(§ 182)을 강약 없이 균등 서술 → 사안 포섭에 강조
- **채점평 지적 3:** 회피·제척신청 논점만 적고 세부 조문·절차 누락
- 재심의 보충성(상소로 주장했거나 알고도 주장 안 한 경우 재심 불가)을 (1)에서 언급 시 가점
- (2)에서 乙이 이미 판매중지한 사실 때문에 제182조의 "실시사업/사업준비" 요건 충족이 불확실함을 지적하면 우수답안

- 제188조의2 제1항의 준용 범위를 민소법 제42조~제45조로만 한정하여 인용하면 감점 (§ 47 즉시항고·§ 48 소송절차 정지까지 준용됨)
- 기술심리관 제척·기피·회피 조항을 제222조로 오인용하면 감점 (§ 222는 '서류의 제출 등' 조항)

2012년 제4문

사례형

20점

문제

甲은 乙의 특허발명 A+B+C에서 비교적 중요하지 않은 구성요소 C를 생략하여 A+B만으로 된 물건을 생산하여 판매하고 있다.

(1) 甲의 실시가 乙의 특허발명을 침해하는지의 여부에 대해 학설의 논거와 판례의 태도를 검토하시오. (12점)

(2) 위와 같이 乙의 특허발명에서 일부 구성요소를 생략한 경우 균등론의 적용이 가능한지 여부에 대하여 판단하시오. (8점)

모범답안

I. 설문 (1) — 甲의 실시가 乙의 특허발명을 침해하는지 (12점)

1. 문제의 소재

甲은 乙의 특허발명 A+B+C 중 구성요소 C를 생략한 A+B를 실시하고 있다. 구성요소가 하나 결여되어 문언침해가 성립하지 아니함은 분명하므로, 중요도가 낮은 구성요소를 생략한 실시를 그럼에도 침해로 볼 것인가가 문제된다.

2. 보호범위와 구성요소완비의 원칙

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(§ 97). 그리하여 판례는 특허발명의 모든 구성요소는 필수적이고 침해가 성립하려면 그 모든 구성요소가 갖추어져야 한다는 구성요소완비의 원칙을 취한다(2000후617). 甲의 실시에는 C에 대응하는 구성이 없으므로 문언침해는 성립하지 아니한다.

3. 구성요소를 생략한 실시를 침해로 볼 것인지

(1) 문제의 배경

구성요소완비의 원칙을 지나치게 엄격히 적용하면 중요도가 매우 낮거나 본질적 기능과 무관한 구성요소만이 결여되고 나머지가 모두 실시되는 경우에 보호범위에서 벗어나게 되어 특허권이 유명무실해질 수 있다. 여기에서 그러한 실시도 침해로 보아야 한다는 논의가 나온다.

(2) 학설

① **(긍정설)** 중요도가 낮은 구성요소를 덜어내는 것만으로 침해를 벗어나게 하면 모방자를 방치하는 결과가 되어 특허권자의 실효적 보호에 미흡하므로 침해로 보아야 한다.

② **(부정설)** i) 구성요소의 중요도는 주관적 판단에 의할 수밖에 없어 보호범위를 불명확하게 하고 법적 안정성을 해치며, ii) 청구범위는 출원인이 스스로 보호받으려는 사항을 적은 것이므로 자신이 적어 넣은 구성요소를 등록 후에 중요하지 아니하다며 덜어내는 것은 허용될 수 없고, iii) 이를 인정하면 청구범위의 문언에 구속되지 아니하는 결과가 되어 주변한정주의에 반한다.

(3) 판례

판례는 확인대상발명이 특허발명의 청구항에 적힌 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 있는 경우에는 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 하여, 구성요소를 생략한 실시를 침해로 보지 아니한다(2000후617).

(4) 반제품의 생산과 구성요소완비의 원칙

다만 판례는 i) 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 거쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, ii) 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, iii) 그 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여, iv) 그 부품 전체 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 보아 직접침해가 성립한다고 한다(2019다222782).

이는 구성요소가 형식적으로 모두 갖추어지지 아니하였더라도 구성요소완비의 원칙을 적용할 수 있는 상태에 이르렀다면 침해로 본다는 것이다. 곧 생략을 이유로 침해를 부정하는 것은 남은 구성만으로는 특허발명의 작용효과를 구현할 수 없는 경우를 전제로 하는 것이지, 구성요소를 몇 개 적게 적었다는 형식만으로 언제나 침해를 벗어난다는 뜻이 아니다.

(5) 검토

청구범위에 적힌 구성요소 가운데 무엇이 중요하고 무엇이 중요하지 아니한지를 사후에 가려내는 것은 그 기준이 모호하여 제3자가 보호범위를 예측할 수 없게 한다. 또한 다항제 아래에서 출원인은 주요부만으로 독립권을 세우고 비요부를 더한 것을 종속항으로 적을 수 있으므로, 비요부가 결여된 실시에 대

하여도 독립항의 침해를 주장할 수 있다. 그렇다면 생략을 그 자체로 침해로 보지 아니하더라도 특허권자에게 큰 불이익이 없고, 무용한 구성요소를 청구 범위에 넣은 것은 출원인의 책임으로 돌릴 문제이다. 따라서 부정설이 타당하고 판례(2000후617)의 태도도 같다.

4. 사안의 포섭

甲이 생략한 C는 비교적 중요하지 아니한 구성요소이나, 그렇다면 乙이 스스로 청구범위에 적어 넣은 필수적 구성요소임에는 다름이 없다. 甲의 실시에는 그에 대응하는 구성이 없으므로 구성요소완비의 원칙에 따라 보호범위에 속하지 아니한다. 甲은 A+B로 된 물건을 완성품으로 생산·판매하고 있을 뿐 뒤에 C를 더하는 가공·조립이 예정되어 있지도 아니하므로, 반제품의 생산을 실시로 보는 위 법리가 적용될 여지도 없다.

5. 결론

甲의 A+B 실시는 문언침해에 해당하지 아니하고, 구성요소를 생략하였다는 이유만으로 따로 침해가 되지도 아니하므로 乙의 특허권을 침해하지 아니한다. 다만 이는 균등론에 의한 판단과는 별개이므로 설문 (2)에서 따로 본다.

II. 설문 (2) — 구성요소를 생략한 경우 균등론의 적용 가부 (8점)

1. 문제의 소재

균등론은 청구범위에 적힌 구성이 변경된 경우에 적용되는 것인데, 구성요소를 아예 덜어낸 경우에도 이를 적용할 수 있는지가 문제된다.

2. 균등론의 의의와 요건

(1) 의의와 취지

균등론이란 확인대상발명과 청구항에 적힌 발명의 구성요소가 완전히 일치하지 아니하더라도, 통상의 기술자가 이를 쉽게 변경하여 실질적으로 동일한 효과를 얻을 수 있는 때에는 균등한 것으로서 보호범위에 포함된다고 보는 이론이다. 구성 중 경미한 부분에 변경을 가하여 청구범위를 벗어나려는 경우를 미리 문언으로 포괄하기 어렵고, 아무런 창작을 더하지 아니한 모방자를 방지함은 정의와 공평에 반하기 때문이다.

(2) 요건

판례는 청구범위에 적힌 구성요소들과 그 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있음을 전제로, i) 청구범위에 적힌 구성 중 변경된 부분이 있더라도 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, ii) 그러한 변경에 의하더라도 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, iii) 그 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도이면, iv) 특별한 사정이 없는 한 균등한 것으로서 보호범위에 속한다고 한다(2013다14361). 앞의 세 요건은 특허권자가, 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하거나 출원과정에서 의식적으로 제외되었다는 등의 특별한 사정은 실시자가 주장·증명한다.

3. 구성요소를 생략한 경우에 적용할 수 있는지

(1) 원칙

균등론은 청구범위에 적힌 구성에 대응하는 구성이 확인대상발명에 있음을 전제로 그 변경을 문제 삼는다. 구성요소가 결여된 경우에는 대비할 대상이 없어 변경의 유무나 용이성을 판단할 수 없으므로 원칙적으로 적용할 수 없다. 판례가 필수적 구성요소 중 일부만을 갖춘 확인대상발명은 권리범위에 속하지 아니한다고 한 것도 같은 취지이다(2000후617).

(2) 변경 개념의 유연화

다만 판례는 구성의 치환 내지 변경을 변경이라는 하나의 용어로 표현하는데, 이는 치환을 포괄하는 상위개념으로서 청구항의 구성과 확인대상발명의 구성이 반드시 하나씩 대응할 것을 요구하지 아니함을 전제한 것이다(2013다14361). 그리하여 덜어낸 구성요소의 기능을 남은 구성요소들이 실질적으로 수행한다면 그 전체를 구성의 변경으로 평가하여 균등론으로 포섭할 여지가 있고, 구성요소를 생략한 실시를 균등침해의 한 유형으로 파악하려는 최근의 경향도 여기에 있다.

4. 사안의 포섭

甲의 실시에는 C에 대응하는 구성이 없고, C가 수행하던 기능을 A와 B가 실질적으로 대신한다고 볼 사정도 없다. 따라서 변경으로 평가할 대상 자체가 없다. 나아가 C를 덜어냄으로써 작용효과가 열악해진다면 실질적으로 동일한 작용효과라는 요건도 충족하지 못한다.

5. 결론

구성요소를 생략한 경우에는 원칙적으로 균등론을 적용할 수 없고, 덜어낸 구성요소의 기능을 남은 구성요소가 실질적으로 수행하는 때에 한하여 이를 변경으로 보아 적용할 여지가 있을 뿐이다. 사안에는 그러한 사정이 없으므로 균등침해도 성립하지 아니한다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
(1) 문언침해 성립 여부 검토(구성요소완비의 원칙)	2점	제97조, 청구범위해석 원칙, C 결여 → 문언침해 부정 명시
(1) 생략발명·생략침해의 의의 및 사안 포섭	2점	중요도 낮은 구성요소 C 생략, 효과 열악·동일 여부 검토
(1) 학설 대립(긍정설·부정설) 및 논거	3점	실효적 보호 vs. 법적 안정성·중요도 판단 주관성
(1) 판례 태도 및 사건	3점	2000후617(확인대상발명이 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖춘 경우 권리범위에 속하지 아니함)을 사건번호와 함께 정확히 인용할 것. 사건은 중요도 판단의 주관성으로 인한 법적 안정성 저해, 출원인이 스스로 적은 구성요소라는 점, 주변한정주의를 논거로. 다항제 논거 (주요부로 독립함을, 비요부를 더한 것으로 종속함을 세우면 비요부 결여 실시에도 독립항 침해를 주장할 수 있으므로 특허권자에게 큰 불이익이 없다)를 들면 가점
(1) 반제품 사건 (2019다222782)과의 관계	—	★가점. 국내에서 부품 전부 또는 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고 → 하나의 주체에게 수출되어 마지막 가공·조립이 예정 → 그 가공·조립이 극히 사소·간단 → 그것만으로도 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서의 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면 예외적으로 국내에서 실시 제품이 생산된 것과 같이 보아 직접침해 . 곧 구성요소완비의 원칙을 적용할 수 있는 상태에 이르렀는지 기준임을 밝히고, 사안은 甲이 A+B를 완성품으로 판매할 뿐 뒤의 가공·조립이 예정되어 있지 아니하여 적용 여지가 없음을 지적하면 가점
(1) 사안 결론(침해 부정)	2점	甲의 A+B 실시는 특허침해에 해당하지 않음
(2) 균등론의 의의·요건	3점	판례 문언대로 — i) 과제의 해결원리 동일, ii) 변경에 의하더라도 실질적으로 동일한 작용효과, iii) 그 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도일 것(이상 특허권자 주장·증명), iv) 자유실시기술 해당·출원과정에서의 의식적 제외 등 특별한 사정이 없을 것(실시자 주장·증명) — 2013다14361
(2) 구성요소의 생략에 균등론을 적용할 수 있는지	3점	원칙 — 대응하는 구성이 있어야 변경 여부를 판단할 수 있으므로 결여된 경우에는 적용 불가. 예외 — 판례가 '치환 내지 변경'을 ' 변경 '이라는 상위개념으로 표현하여 구성의 일 대 다·다 대 일 대응을 허용하므로, 덜어낸 구성요소의 기능을 남은 구성요소가 실질적으로 수행하면 변경으로 평가할 여지가 있고, 생략을 균등침해의 한 유형으로 파악하려는 최근 경향 을 함께 짚으면 가점
(2) 사안 포섭 및 결론 (적용 불가)	2점	C의 기능을 A+B가 대체 수행하는 사정 없음 → 균등침해 불성립

배점 합계: 20점

축별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- **특점:** 설문(1)에서 문언침해→생략침해 순서로 검토, 학설·판례·사건을 구분하여 논증. 설문(2)에서 '생략이 치환에 포함되는가'를 핵심 논점으로 포착.
- **감점:** 채점평 지적 — "문제의 요지와는 관계없이 균등론에 대해서만 암기한 내용을 그대로 작성한 답안이 많았다." 균등론 5요건만 나열하고 생략과의 관계를 논하지 않으면 감점. 문언침해 검토를 생략하거나, 반대로 직접침해·간접침해·이용침해 등 무관한 침해유형을 나열한 답안 감점.
- **감점:** 설문(1)에서 균등침해까지 함께 논한 경우(설문(2)와 중복) 감점.

2) 목차·구성(25%)

- **특점:** I. 문제소재 → II. 문언침해 → III. 생략침해(학설·판례·사건) → IV. 사안 해결의 목차 체계화. 배점(12:8) 비례 분량.
- **감점:** 생략발명 정의·학설·판례를 구분 없이 뒤섞어 서술. 균등론 일반론에 지면 편중.

3) 답안 작성·논증(35%)

- **특점:** 조문(§ 97, § 42⑥) → 판례(구성요소 유기적 결합) → 학설 대립 → 사건 → 사안 포섭의 논증 흐름. 학설 대립 시 자기 입장(부정설=판례)과 논거 제시.
- **감점:** 채점평 지적 — "단순히 공부한 내용을 암기하고 그대로 옮겨놓은 답안". 생략과 치환의 개념적 차이를 논증 없이 결론만 기재, 사안 포섭 없이 일반론으로 끝낸 답안.

감점 주의

- 문언침해 검토를 아예 누락하고 바로 생략침해로 진입 → 감점

- 균등론의 5요건만 장황히 나열하고 '생략≠치환'의 핵심 논점을 놓침(채점평 지적사항)
- 학설의 논거 없이 긍정설/부정설 명칭만 기재
- 판례를 사건번호 없이 '대법원은 ...라고 판시하였다'로만 인용하거나 판시 취지를 부정확하게 기재
- 설문(1)에서 균등론을 상세히 다루어 설문(2)와 중복
- 사안 포섭 없이 일반론으로만 결론 도출

PART 4

2013

제1문	도면 부제출의 법적효과와 국제출원일·국내단계 진입 시 제출서류	30점
제2문	자진보정의 시기적·객관적 적법성·최후거절이유통지 대응 보정의 각하 적법성	20점
제3문	기능적 청구항의 의의·필요성	30점
제4문	전용실시권 일반론 및 미등록 특약의 효력(\$100①·\$101①(2))·2011.6.30 이전 실시의 침해 여부 판단(대법원 2011도4645)	20점

2013년 제1문

사례형

30점

문제

甲은 영어로 된 아래의 [명세서(現 발명의 설명)] 및 [청구의 범위(現 청구범위)]로 한국지식재산처를 수리관청으로 PCT출원을 2011년 6월 1일자로 하였다. 이에 대하여 甲은 수리관청으로부터 출원에 도면이 포함되어 있지 않다는 취지의 통지를 받았으나, 본 발명이 물질 발명에 관한 것으로 도면이 필요 없다는 취지로 상기 통지에 대한 의견을 지정기간 내인 2011년 8월 5일자로 제출하였다.

[명세서]

실시에 1 은 A 또는 a 수단에 의하여 반복 배양되는 줄기세포 P에 관한 것이다.

실시에 2 는 줄기세포 P를 이용하여 손상된 인간의 세포를 복원시키는 치료 방법에 관한 것이다.

[청구의 범위]

제1항 A 수단에 의하여 반복 배양되는 줄기세포 P

제2항 줄기세포 P를 이용하여 손상된 세포를 복원시키는 치료방법

그 후, 甲은 국제조사기관으로부터 제1항과 제2항은 단일성을 만족하지 않는다는 이유로 추가수수료납부명령을 받았지만 이를 납부하지 아니하였다. 그리고 甲은 국제조사보고서를 받은 후 국제예비심사보고서 작성 전에 국제조사보고서상의 특허요건 및 기재요건을 충족시키고자, [명세서]에 "실시에 3은 줄기세포 P를 이용하여 손상된 동물의 세포를 복원시키는 치료방법에 관한 것이다"를 추가하는 보정을 하였고, [청구의 범위] 제1항에는 "a 수단에 의하여 반복 배양되는 줄기세포 P"로 보정(단, a는 A의 하위개념임)을 하였고, 제2항에는 "줄기세포 P를 이용하여 손상된 동물의 세포를 복원시키는 치료방법"이라고 동물로 한정하는 보정을 하였다.

甲은 국제예비심사보고서를 받고 지정국인 한국지식재산처에 국내절차를 진행하려고 한다.

위 사실만을 근거로 다음 물음에 답하시오.

- (1) 甲이 도면을 제출하지 않은 경우의 법적 효과에 대하여 국제출원일과 연계하여 설명하시오. (5점)
- (2) 甲이 지정국에 국내절차를 진행하는 경우 제출해야 할 서류에 대하여 설명하시오. (7점)
- (3) 국내절차의 심사관 입장에서, 국제예비심사단계에서 이루어진 보정에 대한 적법성의 여부를 설명하시오. (12점)
- (4) 甲이 국제조사기관의 단일성 판단에 대한 추가수수료납부를 하지 아니한 경우의 법적효과를 설명하고, 국제조사기관에서의 단일성 판단결과가 지정국의 심사관에 미치는 영향에 대하여 설명하시오. (6점)

모범답안

문제 1 모범답안 (30점)

I. 실문 (1) — 도면을 제출하지 아니한 경우의 법적 효과 (5점)

1. 국제출원일의 인정요건

지식재산처장은 i) 발명의 설명 또는 청구범위가 제출되지 아니한 경우, ii) 출원인의 성명이나 명칭을 적지 아니한 경우, iii) 국제출원 자격이 없는 자가 출원한 경우, iv) 특허협력조약에 따른 국제출원이라는 표시가 없는 경우, v) 소정의 언어로 작성되지 아니한 경우, vi) 지정국이 하나도 없는 경우에는 국제출원일을 인정하지 아니하고 보안을 명하여야 한다(§ 194①). **도면은 이 인정요건에 포함되지 아니하므로 도면이 없더라도 국제출원일은 인정된다.**

2. 누락 부분 등에 대한 보완

도면의 전부 또는 일부가 누락되었거나 잘못 제출된 경우에는 2개월 이내에 그 누락된 부분 또는 정정 부분을 제출하도록 보안을 명하여야 하고 (§ 194③④), 출원인은 보완명령과 관계없이 접수일부터 2개월 이내에 스스로 제출할 수도 있다.

3. 보완 여부에 따른 효과

(1) 보완서류를 제출한 경우

보완서류의 접수일을 국제출원일로 인정한다. 다만 그 접수일이 제194조 제4항에 따라 인정되는 날보다 앞서는 경우에는 그러하지 아니하므로, 결국 인정요건을 모두 충족한 날과 누락 부분이 도달한 날 중 **늦은 날**이 국제출원일이 된다.

(2) 제출하지 아니한 경우

국제출원인이 도면에 관하여 적고 있으나 그 출원에 도면이 포함되어 있지 아니함에도 출원인이 기간에 도면을 제출하지 아니하면, **그 도면에 관한 기재는 없는 것으로 본다**(§ 194④ 후단).

4. 사안의 포설 및 결론

甲은 지정기간 내에 도면이 필요 없다는 취지의 의견서를 제출하였을 뿐 도면을 제출하지 아니하였다. 도면은 국제출원일의 인정요건이 아니므로 국제출원일은 최초 접수일인 2011. 6. 1.로 유지되고 늦추어지지 아니한다. 다만 발명의 설명에 도면에 관한 기재가 있었다면 그 기재는 없는 것으로 보게 된다.

Ⅱ. 설문 (2) — 국내단계 진행 시 제출하여야 할 서류 (7점)**1. 국내 진입 의사 표시 서면**

국제특허출원의 출원인은 국내서면제출기간에 출원인·대리인·발명자의 성명 및 주소, 발명의 명칭, 국제출원일 및 국제출원번호를 적은 서면을 지식재산처장에게 제출하여야 한다(§ 203①). 국어로 출원한 출원인도 제출하여야 한다. 외국어로 출원한 경우에는 제201조 제1항의 국어번역문을 함께 제출함이 원칙이나, 그 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 적어 제출하는 경우에는 함께 제출하지 아니할 수 있다(§ 203②). 이 서면을 제출하지 아니하거나 방식에 위반된 경우에도 곧바로 무효로 되지 아니하고, 지식재산처장이 기간을 정하여 보정을 명한 뒤 그 기간에 보정하지 아니한 때에 무효로 할 수 있다(§ 203③④).

2. 원문에 대한 국어번역문

외국어로 출원한 출원인은 우선일부터 2년 7개월(국내서면제출기간) 이내에 국제출원일까지 제출한 발명의 설명·청구범위·도면(설명부분에 한정한다)과 요약서의 국어번역문을 제출하여야 한다(§ 201① 본문). 다만 그 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 위 서면에 적어 국내서면제출기간 만료일 전 1개월부터 만료일까지 제출한 경우에는 만료일부터 1개월이 되는 날까지 제출할 수 있다(§ 201① 단서). 국내서면제출기간에는 새로운 국어번역문으로 갈음할 수 있으나 심사청구 후에는 그러하지 아니하며, 기준일까지 제출된 것이 최종 국어번역문이 된다(§ 201③⑤). 발명의 설명과 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하면 취하한 것으로 보며(§ 201④), 도면의 설명부분과 요약서의 번역문을 제출하지 아니한 때에는 그 기재가 없었던 것으로 보고 보정명령의 대상이 된다.

3. 국제단계에서 한 보정서의 국어번역문

특허협약조약 제19조(1)의 보정은 청구범위만을 대상으로 하나, 제34조(2)(b)의 보정은 발명의 설명·청구범위 및 도면을 대상으로 하고 국제예비심사보고서가 작성되기 전에 할 수 있다. 甲은 국제예비심사보고서 작성 전에 발명의 설명에 실시예 3을 추가하고 청구항 1과 2를 아울러 보정하였으므로 제34조(2)(b)의 보정에 해당한다. 따라서 甲은 기준일까지 그 보정서의 국어번역문을 제출하여야 하고(§ 205①), 제출하면 그에 따라 제47조 제1항의 보정을 한 것으로 본다(§ 205②). 제출하지 아니하면 그 보정서는 제출되지 아니한 것으로 보아(§ 205③) 보정 전의 원문을 기준으로 심사가 진행된다.

4. 결론

甲은 국내 진입 의사 표시 서면, 발명의 설명·청구범위·도면 설명부분 및 요약서의 국어번역문, 제34조 보정서의 국어번역문을 제출하고 출원심사의 청구와 수수료 납부를 하여야 한다. 국어번역문은 위 서면에 취지를 적어 제출기간을 1개월 연장받을 수 있다.

Ⅲ. 설문 (3) — 국제예비심사단계에서 한 보정의 적법성 (12점)**1. 문제의 소재**

甲은 국제예비심사보고서가 작성되기 전에 특허협약조약 제34조(2)(b)에 따라 발명의 설명과 청구범위를 보정하였다. 이 보정은 甲이 기준일까지 그 보정서의 국어번역문을 제출하면 그에 따라 제47조 제1항의 보정을 한 것으로 보아 기준일이 지나기 전이라도 국내법의 적용을 받고(§ 205②), 제출하지 아니하면 그 보정서는 제출되지 아니한 것으로 보아 국내단계에서는 보정이 없었던 것이 되어 원문을 기준으로 심사가 진행된다(§ 205③). 따라서 번역문이 제출되어 국내법의 보정으로 다루어짐을 전제로 그 보정이 신규사항을 추가한 것인지를 본다. 다만 청구항 2의 보정은 대상을 동물로 한정하여 사람을 덜어낸 것이므로, 하위개념으로 한정하는 보정과 달리 제외 클레임 보정의 법리에 따라 살펴야 한다.

2. 신규사항 추가 여부의 판단**(1) 보정의 범위**

외국어로 출원된 국제특허출원의 보정은 제47조 제2항의 전단과 후단이 정하는 범위를 모두 만족하여야 한다. 곧 국제출원일까지 제출한 발명의 설명·청구범위 또는 도면, 즉 원문에 적힌 사항의 범위에서 하여야 하고(§ 47② 전단, § 208③), 최종 국어번역문 또는 국제출원일까지 제출한 도면에 적힌 사항의 범위에서도 하여야 한다(§ 47② 후단, § 208④). 어느 하나의 범위라도 벗어나면 신규사항의 추가로서 위법하다. 여기의 적힌 사항이란 명시적으로 적힌 사항이거나, 명시적 기재가 없더라도 통상의 기술자가 출원 시의 기술상식에 비추어 적혀 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항을 말한다. 따라서 상위개념을 하위개념으로 한정하는 보정이라도 그 하위개념이 개시되어 있거나 기술상식상 상위개념으로부터 바로 인식될 정도가 아니면 신규사항의 추가에 해당하고, 실시예를 추가하는 보정도 원칙적으로 그러하다.

(2) 제외 클레임 보정

이에 대하여 청구항에서 일정한 사항을 제외하는 이른바 제외 클레임 보정은, 그 제외하는 한정에 의하여 최초 명세서 등에 적힌 것으로 볼 수 없는 새로운 기술적 사항이 도입되는 것이 아니라면 허용된다. 특히 의료방법에 관한 발명에서 그 대상이 사람인지 동물인지가 명시되어 있지 아니하고 그 발명이 특정

동물만을 대상으로 하는 것은 아님이 자명한 경우, 사람에게 해당하는 부분을 덜어내기 위하여 대상을 한정하는 보정은 신규사항이 추가된 것으로 보지 아니한다.

3. 각 보정의 검토

(1) 실시예 3의 추가

국제출원일까지 제출한 발명의 설명에는 실시예 1(줄기세포 P)과 실시예 2(손상된 **인간**의 세포를 복원시키는 치료방법)만 적혀 있었다. '손상된 **동물**의 세포를 복원시키는 치료방법'인 실시예 3은 인간을 대상으로 한 기재로부터 통상의 기술자가 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이라고 보기 어렵다. 이는 청구항에서 일정 부분을 덜어내는 것이 아니라 동물을 대상으로 하는 치료방법이라는 기술적 사항을 적극적으로 들어오는 것이므로, 아래 청구항 2의 보정과 달리 **신규사항의 추가로서 위법**하다.

(2) 청구항 1의 보정

청구항 1을 'A 수단'에서 그 하위개념인 'a 수단'으로 한정한 보정이다. 실시예 1에 '**A 또는 a** 수단'에 의하여 반복 배양되는 줄기세포 P'가 적혀 있으므로 a는 원문과 최종 국어번역문에 모두 적힌 사항이고, 상위개념을 하위개념으로 한정한 것이어서 청구범위의 감축에 해당한다. 따라서 **적법**하다.

(3) 청구항 2의 보정

최초의 청구항 2는 '손상된 세포를 복원시키는 치료방법'으로서 그 대상이 사람인지 동물인지 명시되어 있지 아니하였고, 줄기세포로 손상된 세포를 복원시키는 방법이 특정 동물만을 대상으로 하는 것은 아님이 자명하다. 甲이 대상을 동물로 한정한 것은 사람에게 해당하는 부분을 덜어내기 위한 것으로, 사람을 대상으로 하는 치료방법이 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 아니한다는 거절이유를 회피하려는 데 그 취지가 있다. 이러한 한정으로 새로운 기술적 사항이 도입되는 것은 아니므로 **신규사항의 추가에 해당하지 아니하여 적법**하다. 다만 여기의 '동물'이 사람을 포함하는 의미로 읽힌다면 사람을 덜어낸 것이 되지 아니하므로, 사람을 제외한 동물을 뜻하는 것으로 명확히 특정되어야 한다.

4. 결론

청구항 1과 청구항 2의 보정은 적법하나, 실시예 3의 추가는 원문과 최종 국어번역문 어디에 적힌 사항의 범위도 벗어나 신규사항의 추가에 해당한다. 심사관은 제47조 제2항 위반을 이유로 거절이유를 통지하여야 하고(§ 63), 그 흠이 해소되지 아니하면 거절결정을 하여야 한다(§ 62). 이를 간과하고 등록된 경우 원문의 범위를 벗어난 보정은 무효사유가 되나(§ 133①), 국어번역문의 범위만 벗어난 보정은 거절이유에 그친다.

IV. 설문 (4) — 추가수수료를 내지 아니한 경우의 효과와 지정국에 대한 영향 (6점)

1. 내지 아니한 경우의 효과

(1) 납부명령 및 납부에 따른 효과

심사관은 국제출원이 특허협력조약 제17조(3)(a)의 단일성 요건을 충족하지 아니하는 경우 기간을 정하여 추가수수료의 납부를 명하여야 하고, 그 기간에 낸 경우에는 그 발명에 대하여도 국제조사를 수행한다. 반면 그 기간에 내지 아니하면 **청구범위에 가장 먼저 기재된 발명 또는 1군의 발명과 관련되는 부분(주발명)에 대하여만 국제조사보고서를 작성**하여야 하며, 이 경우 국제조사기관의 견해서에도 그 취지를 적고 그 일부에 대하여만 견해를 제시한다.

(2) 이의신청

납부명령을 받은 자는 i) 단일성 요건을 충족하고 있는 경우, ii) 명령받은 금액이 과다한 경우에는 그 이유를 적은 진술서를 첨부하여 이의신청을 할 수 있고, 3인의 심사관합의체가 심사·결정한다. 전부를 반환하는 결정이 있으면 이의신청료도 함께 반환한다.

(3) 사안의 포섭

甲은 지정된 기간에 추가수수료를 내지 아니하였으므로 주발명인 청구항 1에 대하여만 국제조사보고서가 작성되고 청구항 2는 조사되지 아니한다. 다만 甲은 단일성 요건을 충족한다는 이유로 이의신청을 하여 다룰 수 있었다.

2. 지정국 심사관의 영향

(1) 국제예비심사보고서의 법적 지위

국제예비심사보고서는 청구범위에 적힌 발명이 신규성·진보성 및 산업상 이용가능성을 가지는지에 대하여 **예비적이며 구속력이 없는 견해**를 표시하는 것이고, 국제조사보고서와 그 견해서 또한 마찬가지이다. 나아가 국제단계의 단일성 판단은 조사·심사의 범위를 정하기 위한 것에 지나지 아니한다.

(2) 사안의 포섭

따라서 지정국인 우리나라의 심사관은 국제조사기관의 단일성 판단에 구속되지 아니하고, 제45조와 그 시행령이 정하는 기준에 따라 스스로 판단한다. 국제조사가 이루어지지 아니한 청구항 2도 심사의 대상이 되고, 단일성이 없다면 거절이유를 통지하게 된다.

3. 결론

추가수수료의 미납으로 국제단계에서는 청구항 1에 대하여만 국제조사가 이루어지나 甲은 이의신청으로 다룰 수 있었고, 그 단일성 판단은 지정국을 구속하지 아니하므로 우리나라의 심사관은 청구항 1과 2 전부에 대하여 제45조에 따라 단일성을 다시 판단한다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특정 포인트
(1) 도면 부제출의 법적효과와 국제출원일	5	국제출원일 인정의 도달주의 원칙 및 제194조 제1항 각 호(\$192 자격, \$193① 언어, \$193① 발명의 설명·청구범위, \$193②(1)·(2) 사항 및 출원인 성명)의 예외 열거 방식 서술, 도면 누락 시 제194조 제3항·제4항에 따른 통지·2개월 기간(시행규칙 \$99①) 내 미제출 시 '도면에 관한 기재는 없는 것으로 봄' + 원서 도달일(2011.6.1.)이 국제출원일로 확정됨을 명시
(2) 국내단계 진입 시 제출서류	7	① 제203조 제1항 국내 진입 의사 표시 서면 + 미제출·방식위반 시 제203조 제3항·제4항의 '보정명령 후 미보정 시 무효처분' 절차, ② 제201조 제1항 발명의 설명·청구범위·도면(설명부분)·요약서의 국어번역문(국내서면제출기간, 제201조 제1항 단서에 따라 1개월 연장 가능 — 연장 취지를 위 서면에 적어 만료일 전 1개월부터 만료일까지 제출), ③ 제205조 PCT 34조 보정서 국어번역문, ④ 심사청구서·수수료 언급
(3) 국제예비심사단계 보정의 적법성	12	PCT 34조 보정임을 특정, 제205조 제2항·제3항의 분기 (번역문 제출 시 \$47① 보정으로 간주 / 미제출 시 보정서 부제출 간주 → 원문 기준 심사), 제208조 제3항·제4항에 따른 신규사항 판단의 이중기준(\$47② 전단·후단을 모두 만족 하여야 함 — \$208③ 원문 = 국제출원일까지 제출한 발명의 설명·청구범위·도면 + \$208④ 최종 국어번역문/국제출원일까지 제출한 도면), 청구항1(A→a, 하위개념) = 적법, 청구항2(대상 미명시 → 동물로 한정하여 사람을 제외) = 제외 클레임 보정으로서 적법 (심사기준 4202-4206면 ⑦ — 의료방법 발명의 대상이 사람인지 동물인지 명시되지 아니하고 특정 동물만을 대상으로 하지 아니함이 자명할 때 사람을 삭제하기 위한 한정은 신규사항 아님), 실시예3 추가=부적법(심사기준 ⑨)
(4) 추가수수료 불납 효과 및 지정국 구속력	6	추가수수료 불납 시 '청구범위에 가장 먼저 기재된 1군의 발명에 한하여' 국제조사보고서 작성(PCT \$17(3)(a)), 지정국 심사관은 국제조사기관의 단일성 판단에 구속되지 않음(속지주의)

배점 합계 = 30점

속별 채점 기준

1) 논점 추출 (40%)

- (+) 설문(3)에서 **PCT 34조 보정**임을 명확히 특정하고, 국제특허출원의 신규사항 판단 기준이 **제208조 제3항(국제출원일까지 제출한 원문)과 제208조 제4항(최종 국어번역문·국제출원일까지 제출한 도면)의 이중기준**임을 정확히 짚었는가.
- (+) 청구범위에서 사람을 덜어내는 **제외 클레임 보정(청구항2)**과 발명의 설명에 동물 대상 실시예를 적극적으로 들어오는 보정(실시예3)을 구별하여 **결론을 달리** 판단했는가.
- (+) 설문(4)에서 '**가장 먼저 기재된 1군 발명에 한한 국제조사보고서 작성(PCT \$17(3)(a))' + '지정국 심사관 불구속'** 두 축을 모두 짚었는가.
- (-) 채점평 지적: **의료업의 산업상 이용가능성(\$29① 본문)**, **PCT 19조 보정과 34조 보정의 비교**를 독립 목차로 세워 나열 → 대폭 감점(청구항2 보정의 취지를 밝히는 한 문장으로 언급하는 것은 무방).
- (-) 설문(2)에서 국내 진입 의사 표시 서면·번역문만 쓰고 **34조 보정서 번역문**을 누락 → 감점.

2) 목차·구성 (25%)

- (+) 4개 설문별로 소제목(I ~IV)을 구분하고, 배점 비례(5:7:12:6)로 분량을 배분했는가.
- (+) 설문(3)에서 청구항별·실시예별로 소목차를 나누어 논증했는가.
- (-) 서문·일반론(보정의 의의, PCT 개관 등) 장황 서술로 지면 낭비 → 감점.
- (-) 조문 전사식 나열, 학원 목차 그대로 옮겨쓴 흔적 → 감점.

3) 답안 작성·논증 (35%)

- (+) 조문(\$ 194, \$ 201, \$ 203, \$ 205, \$ 47②, \$ 208③④, PCT \$ 17(3)(a)) → 판례·심사기준 → 사안 포섭 → 결론 순서를 지켰는가.
- (+) 설문(3)에서 보정범위를 **한쪽 기준만** 쓰지 않고 **전단(원문)·후단(국어번역문) 두 범위를 모두 만족하여야 한다고** 명시했는가. 나아가 등록 후에는 **원문 범위 위반만 무효사유이고 번역문 범위 위반은 거절이유에 그친다**는 점까지 짚으면 가점.
- (+) 설문(2)에서 제203조 제1항 서면 미제출·방식위반 시 **제203조 제3항 보정명령 → 제203조 제4항 미보정 시 무효처분** 순서로 정확히 서술했는가(보정명령 단계를 생략하고 곧바로 무효처분처럼 쓰면 감점).
- (+) 설문(2)에서甲의 보정이 **발명의 설명까지 대상**으로 한 것이어서 청구범위만을 대상으로 하는 제19조 보정이 아니라 **제34조 보정**임을 특정하고, 그 번역문을 기준일까지 내지 아니하면 **제출되지 아니한 것으로 본다(\$205③)**는 효과까지 밝혔는가.
- (+) 설문(3) 청구항1: 'a는 A의 하위개념' → 국제출원일까지 제출한 발명의 설명 실시예1에 'A 또는 a'가 이미 기재됨을 지적하여 **적법** 결론.
- (+) 설문(3) 청구항2: 최초 청구항이 대상을 명시하지 아니하였고 특정 동물만을 대상으로 하지 아니함이 자명 → 사람을 덜어내는 한정이므로 새로운 기술적 사항의 도입 없음 → **적법** 결론. 나아가 '동물'이 사람을 포함하는 의미이면 거절이유가 해소되지 아니한다는 점까지 짚으면 가점.
- (+) 설문(3) 실시예3: 발명의 설명에 '**인간의 세포**'만 개시 → 동물 대상 치료방법을 적극적으로 추가 → **부적법** 결론.
- (+) 설문(4): PCT 제17조(3)(a) 근거 + '**속지주의**' 논거로 지정국 불구속을 명확히 결론.
- (+) 설문(4)에서 **추가수수료 이의신청**(단일성 충족 또는 금액 과다를 이유로 한 진술서 첨부, 3인 심사관합의제 심사·결정, 전부 반환 시 이의신청료 반환)을 출원인의 대응수단으로 함께 짚었는가.

- (-) 결론 애매, 조문만 나열하고 사안 포섭 부재.

감점 주의

- 설문(1)에서 제194조 제1항의 인정요건을 열거식(성명·언어·자격·발명의 설명 등)만 나열하고, 조문의 **도달주의 원칙 + 각 호 예외열거 방식**을 정확히 반영하지 않으면 감점.
- 설문(2)에서 제203조 미제출 효과를 곧바로 '무효'로 단정하면 감점 — **보정명령(\$203③) → 미보정 시 무효처분(\$203④)** 2단계 절차를 반드시 명시.
- 설문(3) 신규사항 판단기준을 '번역문'만으로 서술하지 말 것 — **제208조 제3항(원문 기준) + 제208조 제4항(최종 국어번역문 기준)의 이중기준**임을 밝혀야 함.
- 청구항2 보정을 단순한 하위개념 한정으로만 보아 '발명의 설명에 인간의 세포만 개시되어 있다'는 이유로 곧바로 부적법으로 처리하면 감점 — **사람을 떨어내는 제외 클레임 보정의 법리**를 적용하여야 함.
- 설문(2)에서 34조 보정서 번역문 누락은 배점의 상당 부분 손실.
- 설문(4)에서 '청구범위에 가장 먼저 기재된 1군의 발명에 한하여 국제조사보고서 작성'(PCT § 17(3)(a)) 문구를 정확히 쓰지 않으면 감점.
- 서론·일반론 장황, 큰 글씨 줄 띄우기, 문제집 내용 그대로 옮기기는 채점평상 명시적 지양 사항.

(개정 반영: 현행 특허법상 국제특허출원 보정의 신규사항 판단 기준은 § 201 ⑤ 및 § 208 ③ (원문=국제출원일까지 제출한 발명의 설명·청구범위·도면)·§ 208 ④ (최종 국어번역문 또는 국제출원일까지 제출한 도면)의 이중기준임에 유의)

2013년 제2문

사례형

20점

문제

甲은 아래의 [발명의 설명]과 [청구범위]로 특허출원하였다.

[발명의 설명] 본 발명은 폴리에틸렌수지의 표면을 산에 의하여 처리하는 방법에 관한 것이다. 특허 산은 황산(A) 또는 질산(B)으로 구성되는 것이다.

[청구범위]

제1항 폴리에틸렌수지의 표면을 산에 의하여 처리하는 방법

제2항 제1항에 있어서, 산은 황산(A)인 방법

출원인 甲은 지식재산청으로부터 거절이유통지를 받기 전에 제2항을 "제1항에 있어서, 산은 황산(A) 또는 질산(B)인 방법"으로 보정함과 동시에 심사청구를 하였다. 그 후 甲은 심사관으로부터 "산과 질산(B)"은 이견 출원 전에 반포된 선행문헌으로부터 진보성이 없어 특허법 제29조 제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없다는 최후거절이유통지서를 받고, 다음과 같이 청구범위를 보정하였다.

[청구범위]

제1항 폴리에틸렌수지의 표면을 황산(A)에 의하여 처리하는 방법

제2항 제1항에 있어서, 황산(A)에 의하여 처리한 후 염산(C)에 의하여 더 처리하는 방법

상기 보정에 대하여, 심사관으로부터 제1항 및 제2항은 특허법 제47조 제2항의 규정에 위배된다는 취지로 보정각하결정서를 받았고, 동시에 이견 출원은 선행 기술에 의하여 진보성이 없으므로 특허를 받을 수 없다는 거절결정서를 송달 받았다.

위 사례와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (단, 기재요건은 적법하고, 염산(C)은 질산(B)에 비해 신규한 것으로 간주함)

- (1) 甲이 거절이유통지를 받기 전에 한 보정의 적법성에 대하여 설명하시오. (5점)
- (2) 심사관이 판단한 보정각하결정의 적법성에 대하여 설명하시오. (7점)
- (3) 甲이 이견 출원을 특허받기 위하여 취할 수 있는 조치에 대하여 설명하시오. (8점)

모범답안

문제 2 모범답안 (20점)

I. 설문 (1) — 거절이유통지 전 자진보정의 적법성 (5점)

1. 문제의 소재

甲은 거절이유통지를 받기 전에 청구항 2항의 '황산(A)'을 '황산(A) 또는 질산(B)'으로 보정하였다. 자진보정의 시기와 보정범위를 나누어 그 적법성을 검토한다.

2. 자진보정의 시기와 범위

(1) 시기(§47①본문)

특허출원인은 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 자진하여 보정할 수 있다. 다만 거절이유통지를 받은 후에는 제47조 제1항 각 호의 기간에만 보정할 수 있다.

(2) 범위(§47②)

보정은 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 여기서 최초 명세서 등에 기재된 사항이란 명시적으로 기재된 사항이거나, 명시적 기재가 없더라도 통상의 기술자가 출원 시의 기술상식에 비추어 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항을 말한다(2005후3130). 한편 청구범위 보정범위의 제한(§ 47③)은 최후거절이유통지 이후의 보정에만 적용되므로, 자진보정에는 적용되지 아니한다.

3. 사안의 포섭

甲의 보정은 거절이유통지 전에 이루어졌으므로 시기적 요건을 충족한다. 보정으로 추가된 '질산(B)'은 최초 명세서의 발명의 설명에 '산은 황산(A) 또는 질산(B)으로 구성되는 것'이라고 명시적으로 기재되어 있으므로 신규사항 추가가 아니다. 이 보정은 택일적 요소를 부가하는 것이어서 청구범위의 확장에 해당하나, 자진보정에는 제47조 제3항이 적용되지 아니하므로 이는 문제되지 아니한다.

4. 결론

甲의 자진보정은 적법하고, 보정 후의 청구범위(제1항 산에 의한 처리방법, 제2항 황산(A) 또는 질산(B))를 대상으로 심사가 진행된다.

Ⅱ. 설문 (2) — 보정각하결정의 적법성 (7점)

1. 문제의 소재

심사관은 최후거절이유통지에 대응한 보정이 제1항·제2항 모두 제47조 제2항에 위배된다는 이유로 보정각하결정을 하였다. 최후거절이유통지 이후의 보정범위와 보정각하의 요건을 본 후 청구항별 위반 여부와 각하의 단위를 검토한다.

2. 최후거절이유통지 이후의 보정범위와 보정각하

(1) 보정범위(§47②③)

최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간의 보정은 신규사항 추가 금지를 만족하여야 함은 물론, 청구범위에 대한 보정은 i) 청구항을 한정·삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우, ii) 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, iii) 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우, iv) 신규사항을 추가한 보정에 대하여 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 i)~iii)에 따라 보정하는 경우에만 할 수 있다(§ 47③). 이미 진행된 심사 결과를 활용하기 위한 것이다.

(2) 보정각하(§51②)

심사관은 그 보정이 제47조 제2항 또는 제3항을 위반하거나 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 각하의 대상은 문언상 '그 보정', 곧 제출된 보정서이므로 일부 청구항의 보정만을 분리하여 각하할 수 없다. 보정각하를 하면 보정 전 명세서에 의하여 거절이유가 해소되었는지를 판단한다.

3. 사안의 포섭

(1) 청구항 1항 — 위반 아님

'산에 의하여 처리하는 방법'을 '황산(A)에 의하여 처리하는 방법'으로 한 보정은 상위개념을 하위개념으로 변경한 것으로서 청구범위의 감축에 해당한다(§ 47③(1)). 또한 황산(A)은 발명의 설명에 명시적으로 기재되어 있으므로 신규사항 추가도 아니다.

(2) 청구항 2항 — 위반

'염산(C)에 의하여 더 처리하는' 부분은 최초 명세서 어디에도 기재되어 있지 아니하고, 염산(C)은 질산(B)에 비하여 신규한 것으로 간주되므로 기술상식에 비추어 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항도 아니다. 따라서 신규사항 추가로서 제47조 제2항에 위반된다. 구성요소의 직렬적 부가는 감축에 해당하나 그 부가가 신규사항 추가에 저촉되지 아니하여야 하므로 제47조 제3항 제1호도 충족하지 못한다.

4. 결론

심사관이 청구항 1항의 보정까지 제47조 제2항 위반이라고 본 것은 잘못이다. 그러나 청구항 2항의 보정만으로도 각하의 요건이 충족되고 각하는 보정서 단위이므로 청구항 1항의 보정만을 남길 수 없어, 이 사건 보정각하결정 자체는 적법하다. 각하에 따라 심사관은 보정 전 청구범위로 심사하였고, 원 거절이유인 진보성 흠결이 해소되지 아니하여 거절결정이 내려진 것이다.

Ⅲ. 설문 (3) — 甲이 특허받기 위하여 취할 수 있는 조치 (8점)

1. 거절결정의 타당성

보정각하가 적법한 이상 심사는 보정 전의 청구범위, 곧 '산'과 '황산(A) 또는 질산(B)'을 대상으로 한다. 다만 진보성은 선행문헌과 청구항의 발명을 구체적으로 대비하여 판단하는 것이어서 심사관의 판단이 언제나 타당하지는 아니하므로, 甲이 취할 조치는 그 타당성 여부에 따라 달라진다. 흠결이 인정된다면 그 부분을 청구범위에서 덜어내어 거절이유를 해소하여야 하고, 인정되지 아니한다면 보정하지 아니한 채 거절결정을 다투어야 한다.

2. 보정을 수반한 재심사의 청구

흠결이 인정되는 경우이다. 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 보정서에 그 취지를 적어 재심사를 청구할 수 있고, 이때 거절결정은 취소된 것으로 본다(§ 67의2①②). 청구항 1은 '산'을 발명의 설명에 적힌 '황산(A)'으로 한정하고, 청구항 2는 삭제한다. 하위개념화와 청구항의 삭제는 모두 감축에 해당하고(§ 47③ I) 신규사항 추가도 아니므로 적법하며, 이로써 거절이유가 해소된다.

3. 거절결정불복심판과 이후의 조치

(1) 심판의 청구

심사관의 판단이 타당하지 아니하다고 보면 보정 없이 거절결정불복심판으로 그 취소를 구할 수 있고, 재심사 후 다시 거절결정을 받아도 같다. 그 등본 송달일부터 3개월 이내에 청구하며(§ 132의17), 따로 불복할 수 없는 보정각하결정의 당부도 이 심판에서 다툴 수 있다. 다만 심판을 청구하면 재심사를 청구할 수 없어(§ 67의2①Ⅱ) 두 조치는 선택관계이다.

(2) 분리출원

심판청구가 기각되면 심결등본 송달일부터 30일 이내에 최초 명세서 등의 범위에서 분리출원할 수 있다(§ 52의2①). 그 청구범위에는 거절되지 아니한 청구항이나 거절된 청구항에서 거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항만 적을 수 있어, 甲은 청구항 2에서 '질산(B)'을 삭제한 '황산(A)'에

의한 처리방법'을 독립형식으로 분리출원할 수 있다.

(3) 심결취소소송과 상고

기각심결에 불복하면 30일 이내에 특허법원에 심결취소의 소를 제기하고(§ 186), 그 판결에는 대법원에 상고할 수 있다.

4. 분할출원

거절결정등본 송달일부터 3개월 이내에 최초 명세서 등의 범위에서 분할출원할 수 있다(§ 52①Ⅱ). 다만 재심사를 청구하면 거절결정이 취소된 것으로 보므로 그 청구와 동시에 하여야 한다.

5. 그 밖의 조치

이 사건 출원은 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안이 아니어서 실용신안등록출원으로 변경할 수 없고(실용신안법 § 10), 국내우선권주장출원도 선출원일부터 1년이 지나 할 수 없다(§ 55①Ⅰ).

6. 결론

심사관의 판단이 타당하다고 보면 청구항 1을 '황산(A)'으로 한정하고 청구항 2를 삭제하는 보정으로 재심사를 청구하면서 분할출원을 하여 두는 것이 실익이 크고, 그 판단을 다투려면 거절결정불복심판을, 기각되면 분리출원과 심결취소소송으로 다룬다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

설문	쟁점	배점	득점 포인트
(1)	자진보정의 시기적·객관적 적법성	5점	제47조 제1항본문(특허결정등본 송달 전까지)·제47조 제2항 신규사항 추가 금지, 청구항 2항의 '황산(A)→ 황산(A) 또는 질산(B)' 보정이 발명의 설명에 기재된 범위 내이므로 적법. 택일적 요소의 부가는 청구범위의 확장이나 제47조 제3항은 최후거절이유통지 이후의 보정에만 적용되어 문제되지 아니한다는 점까지 밝히면 가점
(2)	최후거절이유통지 대응 보정의 각하 적법성	7점	제47조 제2항 판단을 청구항별로 판단(1항은 최초 명세서 상세한 설명에 '황산(A)'이 기재되어 적법 / 2항은 '염산(C)' 추가로 신규사항 추가 → 위배), 보정각하는 보정서 전체를 대상으로 함(청구항별 각하 불가), 심사관 판단의 취지에는 오류가 있으나 결과적으로 각하 결정 자체는 적법
(3)	거절결정 후 특허받기 위한 조치	8점	◎먼저 거절결정의 타당성을 검토한 뒤 그에 따라 조치가 갈림을 밝힐 것 — 보정각하가 적법하여 심사대상은 보정 전 청구범위('산'·'황산(A) 또는 질산(B)')가 되나, 진보성은 선행문헌과의 구체적 대비로 판단되므로 심사관의 판단이 언제나 타당한 것은 아님. 출결이 인정되면 그 부분을 덜어내는 보정 +재심사, 인정되지 아니하면 보정 없이 거절결정불복심판으로 다름, ①보정을 수반한 재심사청구(§67의2) — '산'을 '황산(A)'으로 감축하고 청구항 2는 삭제('질산(B)'만 덜어내면 '산은 황산(A)인 방법'이 되어 한정된 청구항 1과 실질적으로 같아지므로), 재심사 시 제47조 제3항 위반 여부는 보정각하 전 청구범위와 비교한다는 점, ②거절결정불복심판(§132의17)과 재심사는 선택관계(§67의2①(2)), ③분할출원(§52①(2)) — 재심사를 청구하면 거절결정이 취소된 것으로 보므로 재심사 청구와 동시에 하여야 한다는 점, ③-1 심판청구가 기각된 경우의 분리출원(§52의2①) — 심결등본 송달일부터 30일 이내, 청구범위는 '거절되지 아니한 청구항' 또는 '거절된 청구항에서 거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항'만 기재 가능 → 사안에서는 청구항 2에서 '질산(B)'을 삭제한 '황산(A)인 방법', ③-2 기각심결에 대한 심결취소소송(§186, 30일)과 상고, ④특허출원을 실용신안등록출원으로 변경하는 것은 실용신안법 제10조에 따르는 데 방법발명이라 대상적격 불충족, ⑤국내우선권주장출원은 선출원일부터 1년 도과로 불가(§55①(1)) 등 실익 검토, 각 조치의 요건·시기 명시

배점 합계: 20점

축별 채점 기준

1) 논점 추출(약 40%)

- **득점:** (1) 자진보정 시기·범위 두 축을 모두 지적, (2) 청구항별로 제47조 제2항 위배 여부를 개별 판단하되 보정각하는 보정서 전체에 대해 이루어 짐을 지적, (3) 재심사청구를 중심으로 하되 거절결정불복심판·분할출원 등 '가능한 모든 조치'를 구체적 대응방안과 함께 제시.
- **감점:** 채점평 지적대로 '구체적으로 어떻게 대처해야 하는지'를 쓰지 않고 조치 명칭만 나열, 청구항 1항의 보정이 적법함에도 각하 결과가 적법하다는 결론까지의 논리(청구항별 판단 vs. 각하 단위) 누락, 변경출원을 근거 없이 가능하다고 서술.

2) 목차·구성(약 25%)

- **득점:** 설문별로 목차를 나누고, 각 설문 안에서 (요건 → 사안 포섭 → 결론) 구조. (2)에서 청구항 1·2항을 항별로 나누어 표·목차화, (3)에서 '출원 자체 등록' 조치와 '출원에 포함된 발명 등록' 조치를 구분.
- **감점:** 서론·결론 장황, 보정 일반론만 나열하고 사안 포섭 부실, 배점 대비 (3)에 지면 배분 실패.

3) 답안 작성·논증(약 35%)

- **득점:** 조문(§ 47①·②·③, § 51, § 67의2, § 52) 정확 인용, 판례(신규사항 추가 판단기준 2005후3130)의 취지 적용, '심사관의 취지는 잘못이나 각 하는 보정서 단위이므로 결과적으로 각하 결정 자체는 적법'이라는 결론까지 이르는 일관된 논리, 재심사청구 시 첨부할 보정서(황산(A)로 감축·질 산(B) 삭제)와 의견서 내용까지 구체 제시.
- **감점:** 조문 전사, 신규사항 추가 판단을 최초 명세서 전체(상세한 설명 포함)가 아니라 청구범위와만 비교, 재심사 청구 요건(거절결정등본 송달일 부터 3개월 이내·보정 수반·보정서에 재심사 청구 취지 기재) 누락, 분할출원 시기(거절결정등본 송달일로부터 3개월 이내) 오기.

감점 주의

- 청구항 1항 보정을 제47조 제2항 위반이 아니라고 하면서도 보정각하 결정 전체를 '위법'이라고 결론짓는 논리 비약(→ 보정각하는 보정서 단위임을 놓친 것).
- 재심사청구(§ 67의2①: 거절결정등본 송달일로부터 3개월 이내·보정 수반·보정서에 재심사 청구 취지 기재), 거절결정불복심판(§ 132의17: 결정등본 송달일로부터 3개월 이내), 거절결정 후 분할출원(§ 52①(2): 거절결정등본 송달일로부터 3개월 이내)의 요건·기간을 명시하지 않고 명칭만 열거(※ '30 일'은 2021.10.19. 개정 전 구법 기준으로 오답).
- 변경출원을 방법발명임에도 가능하다고 서술하거나, 특허출원을 실용신안등록출원으로 변경하는 근거를 특허법 제53조로 잘못 인용(실용신안법 제10조가 근거).
- 재심사 청구와 분할출원을 병행할 수 있다고만 쓰고, 재심사 청구로 거절결정이 취소 간주되어 분할출원은 재심사 청구와 동시에 하여야 한다는 제 약을 놓치는 것.

- '산'을 '황산(A)'으로 감축하는 보정이 신규사항 추가라는 심사관의 잘못된 판단에 대응하기 위해 의견서를 함께 제출해야 한다는 실무적 포인트 누락.
- 채점평 지적: 조치 명칭만 나열하고 구체적 대처를 쓰지 않는 것.

2013년 제3문

사례형

30점

문제

이 사건 발명은 "가수분해에 의해 습도를 조절하는 수단"에 관한 것이다. 甲은 이 사건 발명을 특허출원하면서, 청구항 1에 "공기 중 수분을 물방울로 변화시켜 물통으로 배출하는 수단"이라는 기능적 청구항으로 기재하였고, 종속항인 청구항 2 내지 5에 공기 중의 수분을 액체인 물방울로 변화시켜 물통으로 배출하는 수단에 관한 구체적인 구성을 기재하였다. 청구항 1은 발명의 설명 또는 도면에 의해 명료하게 설명되어 있지 않지만, 종속항인 청구항 2 내지 5의 구성요소만으로 보충 한정하여 해석할 때에는 청구항 1의 수단이 명료해져 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 이 사건 발명의 권리범위를 명확하게 특정할 수 있다. 이 사건 발명은 현재 특허등록되어 있다. 이에 대하여, 이 사건 발명을 실시하고자 하는 乙은 이 사건 발명이 기재불비에 해당하여 무효라는 이유로 청구항 1 내지 5에 대해 무효심판을 청구하였다.

(1) 기능적 청구항의 의의, 필요성, 법적 근거 및 권리범위 해석에 관하여 설명하시오. (10점)

(2) 위의 사례와 관련하여 이 사건 발명이 기재불비로서 무효인지의 여부를 판단하시오. (단, 기재불비 외의 특허거절이유는 고려하지 않기로 함) (20점)

모범답안

문제 3 모범답안 (30점)

I. 설문 (1) — 기능적 표현으로 기재된 청구항 (10점)

1. 의의

발명 구성요소의 일부 또는 전부가 통상적인 구조·방법·물질 등이 아니라 기능·효과·성질 등의 기능적 표현으로 기재된 청구항을 말한다.

2. 필요성

통상적인 구조·방법·물질 등으로 구성요소를 구체화함이 불필요하거나 그에 적합한 명칭이 없는 경우에 이용된다. BM발명이나 컴퓨터관련 발명과 같이 구체적 구조만으로 표현하기 어려운 분야에서 그 필요가 크다.

3. 법적 근거

(1) 구법

구 제42조 제4항 제3호는 청구항을 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재할 것을 요구하였는데, '구성'을 물리적 구성으로 새기면 작용이나 동작방법으로 발명을 기재함이 바람직한 경우에도 이를 제한하는 문제가 있었다.

(2) 현행법

이에 2007. 7. 1. 시행된 개정법은 위 규정을 삭제하고 제42조 제6항을 신설하여, 청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다고 규정함으로써 기능적 표현에 의한 기재를 허용하고 있다. 판례도 통상의 기술자가 발명의 설명·도면과 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위의 기재로부터 발명을 명확하게 파악할 수 있다면 적법하다고 한다 (2005후1486).

4. 권리범위 해석

(1) 제한 해석이 허용되는 경우

특허요건을 판단할 때와 달리, 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지고, 발명의 설명이나 도면으로 이를 제한·확장함은 원칙적으로 허용되지 아니한다. 그런데 기능적 표현은 그 기재만으로 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없어, 침해 판단이나 권리범위 확인의 국면에서 문언대로 해석하면 명세서의 다른 기재에 비추어 명백히 불합리할 때가 있다. ① (뒷받침의 흠결) 문언에 포함된다고 해석되는 것 중 일부가 발명에 관한 설명에 의하여 뒷받침되지 아니하는 경우, ② (의식적 제외) 출원인이 그중 일부를 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우가 이에 해당한다. 이때에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사, 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 권리범위를 제한 해석할 수 있다(2023후11340). 공개하지 아니한 부분까지 독점권을 주는 것은 특허법의 목적에 반하기 때문이다.

(2) 자가세정 정수기 사건

'세정수단'이라는 기능적 표현이 문제된 사안이다. 발명의 설명에는 여과된 물에 세정·살균물질을 희석하여 저장탱크를 세정하는 수단만 적혀 있었고, 출원인은 원출원의 심사과정에서 전기분해로 살균물질을 생성하는 수단은 포함되지 아니한다는 의견을 제출하였다. 판례는 원출원의 출원경과도 뒤에 분할출원된 특허발명의 청구범위 해석에 참작할 수 있다고 하면서, 전기분해 방식은 발명의 설명에 뒷받침되지 아니하고 출원인이 의식적으로 제외한 것이어서 제한 해석하였다(2023후11340).

(3) 특허발명의 특징과 대비

기능적 표현으로 기재된 청구항은 그에 상응하는 발명의 설명과 도면의 실시예에 뒷받침되는 범위에서 특허발명을 특정한 후, 확인대상발명과 대비하여 구성요소완비의 원칙과 균등론을 적용한다.

발명의 설명과 도면을 보충하여 문언이 표현하는 기술적 구성을 확정함은, 그 결과 **독립항과 그 종속항의 권리범위가 동일하게 된다고 하여도 마찬가지이다**(2008후57). 독립항의 기능적 표현을 뒷받침하는 실시예가 종속항이 부가·한정한 구성뿐이라면, 두 권리범위가 같아짐은 제한 해석에 따른 당연한 결과이다.

II. 설문 (2) — 이 사건 발명의 기재불비 무효 여부 (20점)

1. 문제의 소재

乙은 등록된 이 사건 발명의 청구항 1 내지 5가 기재불비라는 이유로 무효심판을 청구하였다. 청구항이 기능적 표현으로 기재되어 있으므로 먼저 특허요건을 판단할 때의 방법에 따라 각 청구항의 발명을 특정하고, 이어 명세서의 기재에 관한 규정 가운데 어느 것이 제한적으로 열거된 무효사유에 해당하는지를 살핀 다음, 그 특정된 발명이 그 무효사유에 해당하는지를 청구항별로 검토한다. 무효심판에서는 청구항마다 무효사유의 유무를 판단하여야 하므로 제1항이 무효라고 하여 제2항도 무효라고 할 수 없고(99후2181), 일부 청구항에 대하여만 인용·기각하는 심결이 가능하기 때문이다.

2. 특허요건을 판단할 때의 발명의 특정

청구범위의 기재방법은 대통령령으로 정하는데(§ 42⑧), 그 위임에 따른 시행령 제5조는 다항제를 채택하고 있어 각 청구항은 독립항이든 종속항이든 상호 독립되어 독자적인 권리범위를 가진다. 여기의 종속항이란 독립항의 구성을 모두 포함하면서 이를 부가·한정하여 구체화한 청구항을 말한다.

특허요건을 판단할 때 기능적 표현으로 기재된 청구항은 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 그러한 기능·효과·성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하고, 발명의 설명에 적힌 실시예로 제한하여 해석하지 아니한다(2007후4977). 기재요건을 판단할 때에도 그와 같이 특정된 발명을 대상으로 삼는다. 따라서 청구항 1은 '공기 중 수분을 물방울로 변화시켜 물통으로 배출하는' 기능을 가지는 모든 수단을 포함하는 발명으로, 청구항 2 내지 5는 거기에 그 수단의 구체적인 구성을 부가·한정한 발명으로 각 특정된다.

3. 기재불비와 관련된 무효사유

(1) 사안의 쟁점

특허의 무효사유는 제133조 제1항 각 호에 제한적으로 열거되어 있고, 명세서의 기재에 관하여 같은 항 제1호가 들고 있는 것은 제42조 제3항 제1호와 제42조 제4항뿐이다. 반면 청구범위에 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적을 수 있다고 정한 제42조 제6항은 기재의 형식을 허용하는 규정으로서 거절이유·무효사유의 어느 것에도 해당하지 아니하고, 기재방법을 대통령령에 위임한 제42조 제8항도 같다. 따라서 청구항이 기능적 표현으로 기재되었다는 것만으로는 무효로 되지 아니한다. 사안에서 발명의 설명 자체의 흠은 주장되지 아니하였으므로 쟁점은 제42조 제4항 제1호와 제2호의 위반 여부이다.

(2) 제42조 제4항 제1호 위반의 판단

청구항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다. 공개하지 아니한 사항에까지 특허권을 주는 것을 막으려는 것이므로, 출원 당시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 설명에 개시된 내용을 청구항에 적힌 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 뒷받침된다고 볼 수 없다. 기능적 표현으로 기재된 청구항은 통상의 기술자가 발명의 설명에 개시된 실시예에 근거하여 전체로서 그 청구항에 적힌 발명을 쉽게 유추할 수 있는 경우에만 적절한 기재로 볼 수 있다.

(3) 제42조 제4항 제2호 위반의 판단

청구항은 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있어야 한다. 기재가 불명확하면 특허요건을 판단할 수 없고 보호범위도 정할 수 없기 때문이며, 통상의 기술자가 발명의 설명·도면과 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위의 기재로부터 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단한다(2014후1563).

① **(허용요건)** 판례는 기능적 표현은 그러한 기재에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 인정되는 경우에만 허용된다고 하고(97후1337), 그러한 경우란 i) 종래의 기술적 구성만으로는 발명의 기술적 사상을 명확하게 나타내기 어려운 사정이 있어 청구항을 기능적으로 표현할 필요가 있고, ii) 발명의 설명과 도면의 기재에 의하여 기능적 표현의 의미 내용을 명확하게 확정할 수 있는 경우를 말한다고 한다(2005후7354).

② **(종속항에 의한 보충의 가부)** 나아가 판례는 기능적 표현만으로 되어 불명확한 독립항을 오로지 종속항에서 부가·한정하고 있는 구성요소만으로 이루어진 것으로 보충·한정하여 유 효하게 해석하는 것은 허용될 수 없다고 한다(2005후7354). i) 기능적 표현만 있을 뿐 독자적으로 명확한 구성요소를 갖지 못한 것은 이미 독립항이라 할 수 없고 부가·한정할 대상을 찾을 수 없게 된 종속항 역시 종속항이라 할 수 없으며, ii) 그러한 해석을 허용하면 독립항의 권리범위가 종속항의 그것과 같아지거나 여러 하위 종속항을 가지는 독립항이 오히려 하위 종속항보다 좁아지는 모순이 생겨 다항제의 취지에 어긋나고, iii) 발명의 설명과 도면으로 기능적 표현의 의미를 확정하는 것은 청구범위의 기재방식이 제42조 제4항에 위반되지 아니하는 경우에 한하여 허용되기 때문이다.

4. 청구항별로 무효사유에 해당하는지 검토

(1) 청구항 1의 판단

청구항 1의 '공기 중 수분을 물방울로 변화시켜 물통으로 배출하는 수단'은 기능으로 발명을 특정한 것인데, 발명의 설명이나 도면을 참작하여도 명료하게 설명되어 있지 아니하여 위 허용요건 중 ii)를 충족하지 못한다. 설명 종속항 2 내지 5의 구성만으로 보충하여 한정 해석할 수 있다고 하더라도 그러한 보

충해석은 허용되지 아니하므로, 청구항 1은 발명의 필수적 구성요소가 명확하고 간결하게 기재되었다고 볼 수 없어 제42조 제4항 제2호에 위반된다. 나아가 발명의 설명에 개시된 내용을 위 기능적 표현이 포괄하는 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없으므로 제42조 제4항 제1호 위반도 될 수 있다. 다만 판례는 제42조 제4항 제2호 위반만으로 무효라고 보아 나머지 주장은 나아가 판단하지 아니하였다(2005허7354).

(2) 청구항 2 내지 5의 판단

독립항이 기재불비라고 하여 종속항도 당연히 기재불비가 되는 것은 아니므로 따로 판단하여야 한다. 종속항이 독립항의 불명확한 구성을 그대로 포함하고 있을 뿐이라면 그 불명확은 종속항에서도 필수적 구성요소의 흠으로 남아 기재불비를 면하지 못한다(2005허7354). 그러나 종속항이 바로 그 불명확한 구성을 부가·한정하여 구체화하고 있다면 그 종속항에서는 의미 내용이 명확하게 확정되므로 기재불비가 해소될 수 있다.

사안에서 청구항 2 내지 5는 청구항 1의 위 '수단'에 관한 구체적인 구성을 적고 있고, 그 구성요소로 보충하면 통상의 기술자가 권리범위를 명확하게 특정할 수 있다. 따라서 청구항 2 내지 5는 그 불명확이 해소되어 기재요건을 갖춘 것으로 볼 수 있다. 다만 각 종속항이 구체화하지 아니한 다른 불명확한 구성을 여전히 포함하고 있다면 그 종속항은 기재불비를 면하지 못한다.

5. 결론

청구항 1은 제42조 제4항 제2호의 기재요건을 갖추지 못하여 제133조 제1항 제1호의 무효사유가 있으나, 청구항 2 내지 5는 그 흠이 해소되어 무효사유가 없다. 따라서 乙의 청구는 청구항 1에 대하여만 인용되고 나머지는 기각될 것이며, 그 무효심결이 확정되면 청구항 1의 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다(§ 133③, § 215). 한편 권리범위를 해석하는 국면에서는 실시예로 제한한 결과 독립항과 종속항의 권리범위가 같아지더라도 무방하나, 기재요건을 판단하는 국면에서는 종속항의 구성으로 독립항을 보충하여 유효화할 수 없다는 점에서 두 국면은 구별된다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
(1) 기능적 청구항의 의의	2	means-plus-function 정의, 구조 대신 작용·기능·성질로 특정
(1) 필요성	2	BM·생명공학 등 구조로 특정 곤란, 광범위 권리확보, 이해 편의
(1) 법적 근거	2	현행 특허법 제42조 제6항 신설(구법 §42④(3) 삭제) 경위 명시, 의무규정 문언("적어야 한다") 정확 인용
(1) 권리범위 해석	4	권리범위 판단에서는 제한 해석이 허용되는 두 유형 (문언에 포함되는 것 중 일부가 발명의 설명에 뒷받침되지 아니하는 경우 / 출원인이 의식적으로 제외한 경우)과 참작요소 4가지 (출원된 기술사상의 내용·명세서의 다른 기재·출원인의 의사·제3자에 대한 법적 안정성)를 제시할 것 — 2023후11340(자가세정 가능한 정수기, '세정수단'의 전기분해 방식 제외). 원출원의 출원결과를 분할출원 발명의 청구범위 해석에 참작할 수 있다 는 판시까지 쓰면 가점. 제한 해석의 결과 독립항과 그 종속항의 권리범위가 동일하게 되더라도 마찬가지로 마찬가지로 는 법리(2008후57)를 반드시 적을 것 — 사안은 청구항 1의 기능적 표현이 오로지 종속항 2 내지 5의 구성으로만 뒷받침되는 구조이므로 이 법리가 직접 문제됨
(2) 무효사유 범위와 판단	5	무효사유는 §133① 각 호에 제한 열거되어 있고 명세서 기재에 관하여 같은 항 제1호가 드는 것은 §42③(1)·§42④ 뿐임을 먼저 밝힌 뒤, §42③(1) 실시가능 §42④(1) 뒷받침(발명의 설명에 개시된 내용을 청구항의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없으면 뒷받침 부정)·§42④(2) 명확성(2014후1563)의 일반론을 제시할 것. 이어 판단의 단위 — 등록 전에는 하나의 청구항에라도 거절이유가 있으면 출원 전부 거절이나, 등록 후 무효심판은 청구항마다 무효사유를 판단하므로 제1항이 무효라 하여 제2항도 무효라 할 수 없고 일부인용·일부기각 심결이 가능 (99후2181)함을 반드시 짚을 것. 특허요건 판단에서의 발명의 특정(기능·효과·성질을 가지는 모든 발명, 실제로 제한하지 아니함 — 2007후4977)도 기재요건 판단의 전제로 제시. 제42조 제6항은 기재형식을 허용하는 규정으로 그 자체는 거절이유·무효사유가 아니고(§42⑥도 같음), 청구범위 기재요건(§42④(1)·(2))은 별도 판단. 기능적 표현의 허용 요건 2가지(기능적 표현이 필요한 사정 + 발명의 설명·도면으로 의미 확정 가능 — 2005허7354, 97후1337) 제시
(2) 청구항별 판단 원칙 (다항제)	2	제42조 제8항, 시행령 제5조 — 청구항별 독립 판단
(2) 청구항 1의 기재불비 판단	8	특허법원 2005허7354 판례 취지(종속항 구성만으로 보충해 유효화 불가)와 그 3가지 논거(독립항·종속항 관계 붕괴 / 권리범위 역전 모순 / 설명 참작의 한계), 제42조 제4항 제2호(명확·간결) 위반 결론. 발명의 설명으로부터 확장·일반화되지 아니한다는 점에서 §42④(1) 위반도 될 수 있음 을 덧붙이되, 판례는 §42④(2)만으로 무효라 보고 나머지는 나아가 판단하지 아니하였음을 밝히면 가점
(2) 청구항 2~5의 기재불비 판단	3	독립항 기재불비 = 종속항 당원 기재불비는 아님을 전제로 두 갈래 를 제시할 것 — i) 종속항이 독립항의 불명확한 구성을 그대로 포함하기만 하면 그 흠이 필수구성요소의 흠으로 남아 기재불비(2005허7354는 종속항들이 두 불명확 구성 중 하나씩만 구체화하여 나머지가 남은 사안), ii) 종속항이 바로 그 불명확한 구성을 부가·한정하여 구체화하였다면 의미 내용이 확정되어 기재불비가 해소될 수 있음. 사안의 청구항 2 내지 5는 문제된 '수단'의 구체적 구성을 적고 있으므로 해소된다고 볼 수 있음
(2) 결론(무효 여부)	2	청구항 1은 제42조 제4항 제2호 위반 → 무효사유(§133①(1)) 인정, 청구항 2 내지 5는 흠이 해소 → 일부인용·일부기각 심결 예상. 무효심결 확정 시 그 청구항의 특허권은 처음부터 없었던 것으로 봄(§133③, §215)

총 30점

특별 채점 기준

논점 추출(40%)

- **특점:** ① 기능적 청구항의 4요소(의의·필요성·근거·해석) 균형 서술 ② 제42조 제6항 신설로 기능적 청구항이 입법적 수용되었다는 이력 명시 ③ 사안의 핵심 — "종속항의 구성으로 독립항을 보충해석할 수 있는가"라는 특유 쟁점 포착 ④ 무효사유 조문(§42④(2)를 주된 위반으로, §133①(1)) 정확히 특정.
- **감점:** 기능적 청구항 일반론만 나열하고 사안의 "종속항으로 독립항 보충" 쟁점을 놓친 경우; 진보성·신규성 등 기재불비 외 사유를 서술한 경우(설문 단서 위반); 제42조 제6항과 제42조 제4항의 관계 혼동; 제42조 제5항(삭제된 조항)를 다항제 근거로 인용한 경우.

목차·구성(25%)

- **특점:** (1)과 (2)를 배점(10:20) 비례로 분량 배분. (2)는 **발명의 특정 → 기재불비와 관련된 무효사유(쟁점 확정 → §42④(1)·(2) 각 판단기준) → 청구항별 포섭 → 결론**의 순서로 세우고, 포섭 단계에서 청구항 1과 청구항 2~5를 분리할 것.
- **감점:** (1)에 지면을 과도 배분하여 (2)의 핵심 판단이 얇아진 답안; 청구항별 구분 없이 뭉뚱그린 목차; 조문 나열식 서술.

답안 작성·논증(35%)

- **특점:** 조문(§42③(1), §42④(1)·(2), §42⑥, §42⑧, §97, §133①(1)·③, §215) → 판례(특허법원 2005허7354, 대법원 99후2181·2007후4977·2014후1563·2023후11340·2008후57) → 사안 포섭 → 결론의 논리 흐름. 특히 "기능적 표현만으로 된 텅 빈 독립항을 종속항 구성으로 보충해 유효화하면 독립항·종속항 권리범위 역전 모순이 발생"이라는 판례 논거를 자기 언어로 재구성.
- **감점:** 채점평 지적대로 결론만 맞고 법 논리 구성이 치밀하지 않은 경우; 판례 취지를 부정확하게 인용한 경우; 기능적 청구항이라는 이유만으로 곧바로 기재불비라고 결론지는 경우(§42⑥ 수용 취지 몰이해); 제42조 제6항 문언을 "적을 수 있다"로 오인용한 경우(현행 문언은 "적어야 한다").

감점 주의

- 채점평: "1문(설문1)에서 판례를 정확히 이해하지 못한 답안 다수" → 기능식 청구항 권리범위 한정해석 판례(청구항+상세한 설명·도면으로 명확히 확정되는 구성)를 정확한 문언으로 서술할 것.
- 채점평: "2문(설문2)에서 정답은 쉽게 맞혔으나 결론에 이르는 논리전개가 치밀하지 못함" → "기재불비"라고만 결론짓지 말고, ① 제42조 제6항은 허용규정 ② 명세서 기재요건은 별도 판단 ③ 종속항으로 독립항 보충해석 불허(판례) ④ 그 결과 제42조 제4항 제2호 위반 순서로 단계적 논증 필수.
- 채점평: "답안지 가독성 부족, 양이 아니라 쟁점 부합 간결한 서술이 필요" → 일반론(기능적 청구항 총론) 과다 서술 자제.
- 설문 단서("기재불비 외 거절이유는 고려하지 않음") 위반하여 신규성·진보성·산업상 이용가능성을 논한 경우 감점.
- 종속항 2~5가 독립항 1의 기재불비에 자동 연동된다고 단정한 경우(판례는 자동연동 부정) 논리 감점. 반대로 종속항이 독립항의 불명확한 구성을 그대로 안고 있는 경우까지 일률적으로 해소된다고 본 경우도 감점.
- 다항제의 법적 근거를 제42조 제5항(2014.6.11. 삭제된 조항)로 인용한 경우 감점 → 현행 근거는 제42조 제8항 및 시행령 제5조임에 유의.
- 제42조 제6항을 "적을 수 있다"(임의규정)로 표기한 경우 감점 → 현행 문언은 "적어야 한다"(의무규정)임에 유의(다만 기능적 표현을 허용하는 취지 자체는 유지).

2013년 제4문

사례형

20점

문제

甲은 '비소음형 자동변속기'라는 물건발명(이하 '이 사건 발명'이라 한다)의 특허권자이다. 甲은 자동변속기 생산을 업으로 하는 乙과 이 사건 발명의 전용실시권 설정계약을 체결하면서, "기간: 2011년 1월 1일부터 2012년 1월 1일까지, 지역: 대한민국 전역, 실시내용: 생산·사용·양도·대여·수입·양도 및 대여의 청약"을 내용으로 하는 전용실시권 설정등록을 완료하였다. 반면, 甲이 乙과 체결한 '전용실시권 설정계약서'에는 "乙은 본 특허발명을 실시하고자 하는 경우, 甲에게 실시내용과 수량을 미리 알리고 甲의 승낙을 득한 후에 실시할 수 있다."는 특약이 있으나, 이러한 특약의 제한은 등록되지 아니하였다.

그런데 乙은 甲의 승낙없이 2011년 1월 1일부터 2011년 6월 30일까지 이 사건 발명을 업으로 실시하였다. 뿐만 아니라 乙은 실시사업을 丙에게 이전하지 않은 채, 2011년 7월 1일 甲의 동의없이 丙에게 이 사건 발명의 전용실시권을 이전하는 이전등록을 완료하였다. 아울러, 乙은 2011년 7월 1일 이후에도 지속적으로 甲의 승낙없이 이 사건 발명을 업으로 실시하였다. (단, 이 사건 발명의 특허성, 전용실시권 이전등록신청 시 우리나라 지식재산처를 기망하는 행위가 있는지의 여부, 전용실시권 설정계약의 공정성 문제는 고려하지 말 것)

(1) 乙의 2011년 6월 30일 이전(以前)의 실시행위가 甲의 특허권을 침해하는지 여부를 판단하고, 甲의 구제수단을 설명하시오. (12점)

(2) 乙의 2011년 7월 1일 이후(以後)의 실시행위가 甲의 특허권을 침해하는지 여부를 판단하고, 甲의 구제수단을 설명하시오. (8점)

모범답안

문제 4 모범답안 (20점)

I. 설문 (1) — 2011. 6. 30. 이전 실시행위 (12점)

1. 문제의 소재

乙은 설정등록을 마친 전용실시권자이나, 甲의 사전 승낙을 받도록 한 특약은 등록되지 아니하였다. 등록되지 아니한 제한을 넘어서 실시가 특허권의 침해가 되는지, 침해가 아니라면 甲이 어떤 구제를 받을 수 있는지가 문제된다.

2. 침해의 성립요건

특허권의 침해란 특허권의 존속 중 정당한 권원이 없는 자가 업으로서 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 실시하는 것을 말한다. 곧 i) 특허권의 존속 중일 것, ii) 정당한 권원 없는 자의 실시일 것, iii) 업으로서의 실시일 것, iv) 특허발명의 보호범위에 속하는 발명의 실시일 것을 요한다. 사안에서 이 사건 특허권은 존속 중이고 乙의 실시는 업으로서 하는 보호범위 내의 실시이므로, 乙의 실시가 정당한 권원에 의한 것인지가 다투어진다.

3. 전용실시권과 등록되지 아니한 제한의 효력

(1) 전용실시권의 성질과 발생

전용실시권이란 특허권자 외의 자가 설정행위로 정한 범위에서 독점·배타적으로 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리이다(§100②). 특허권에 부수하는 물권적 권리이므로 시기·지역·실시내용이 중복되는 둘 이상의 전용실시권은 병존할 수 없다. 전용실시권은 특허권자의 의사에 의한 설정계약으로 성립하되 등록하여야만 효력이 발생하고, 그 설정된 범위에서는 특허권자도 특허발명을 실시할 권리를 독점하지 못한다(§94①단서).

(2) 등록의 효력(§101①(2))

전용실시권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외) 또는 처분의 제한은 등록하여야만 효력이 발생한다. 이는 대항요건이 아니라 효력발생요건이다.

(3) 판례

설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니하므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 아니한 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다(2011도4645).

4. 사안의 포섭

乙은 2011. 1. 1.부터 2012. 1. 1.까지, 대한민국 전역에서, 생산·사용·양도·대여·수입과 양도 및 대여의 청약을 내용으로 하는 전용실시권의 설정등록을 마쳤으므로 그 범위에서 정당한 권원을 가진다. 사전 승낙 특약은 전용실시권의 범위에 관한 제한에 해당하나 등록되지 아니하여 효력이 발생하지 아니한다. 따라서 甲의 승낙 없이 이루어진 2011. 1. 1.부터 6. 30.까지의 실시는 전용실시권의 범위 내의 실시로서 甲의 특허권을 침해하지 아니한다.

5. 甲의 구제수단

(1) 채무불이행에 기한 손해배상

특약은 등록되지 아니하여 대세적 효력이 없을 뿐, 甲과 乙 사이에서는 계약으로서 유효하다. 乙이 사전 승낙의무를 위반하였으므로 甲은 민법에 따라 채무불이행으로 인한 손해배상을 청구할 수 있다. 특허권의 침해가 아니므로 제128조의 손해액 추정·산정 규정은 적용되지 아니한다.

(2) 제한의 등록

甲은 乙의 협력을 얻어 그 제한을 등록할 수 있다. 등록에 의하여 제한의 효력이 발생한 뒤에 乙이 이를 넘어 실시하면 그때부터는 전용실시권의 범위를 벗어난 실시가 되어 침해금지청구(§ 126)·손해배상청구(§ 128)와 침해죄(§ 225)의 대상이 된다.

(3) 설정계약의 해제와 말소등록 청구

甲은 채무불이행을 이유로 민법에 따라 설정계약을 해제할 수 있다. 해제에 의한 전용실시권의 소멸도 등록하여야 효력이 발생하므로(§ 101①(2)), 甲은 乙에게 말소등록절차의 이행을 구할 수 있다.

6. 결론

乙은 설정등록을 마친 적법한 전용실시권자이고 사전 승낙 특약은 등록되지 아니하여 효력이 없으므로, 2011. 6. 30. 이전의 실시는 특허권의 침해가 아니다. 다만 乙은 계약상 의무를 위반하였으므로 甲은 채무불이행에 기한 손해배상을 청구할 수 있고, 그 제한을 등록하거나 설정계약을 해제하고 말소등록을 구할 수 있다.

II. 설문 (2) — 2011. 7. 1. 이후 실시행위 (8점)

1. 문제의 소재

乙은 실시사업을 이전하지 아니한 채 甲의 동의 없이 丙에게 이전등록을 하였다. 전용실시권이 乙과 丙 중 누구에게 있는지를 먼저 살피고, 乙의 실시가 침해인지를 검토한 뒤 甲의 구제수단을 본다.

2. 전용실시권이 乙과 丙 중 누구에게 있는지 여부

(1) 전용실시권 이전의 일반론

전용실시권은 재산권이므로 이전할 수 있으나, 실시사업과 함께 이전하는 경우와 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 받아야만 이전할 수 있다(§ 100③). 어떠한 자본과 기술로 실시하는지가 특허권자에게 중대한 이해관계가 있기 때문이며, 두 예외는 설비 가동의 보장과 승계인이 한정되어 불측의 손해가 적다는 데에 근거한다. 그 이전은 일반승계를 제외하고는 등록하여야 효력이 발생한다(§ 101①Ⅱ).

(2) 사안의 포섭

乙은 실시사업을 이전하지 아니하였고 일반승계도 아니며 甲의 동의도 없었으므로 이 사건 이전은 제100조 제3항에 위반된다. 이전등록을 마쳤더라도 이전행위가 무효인 이상 효력이 없어, 전용실시권은 여전히 乙에게 있고 丙은 권원을 취득하지 못한다.

3. 乙의 실시가 甲의 특허권을 침해하는지 여부

(1) 침해의 성립요건과 등록되지 아니한 제한

특허권의 침해란 특허권의 존속 중 정당한 권원 없는 자가 업으로서 보호범위에 속하는 발명을 실시하는 것으로, 요건은 설문 (1)에서 본 바와 같다. 실시란 제2조 제3호의 행위를 말하며 각 실시행위는 독립되어 있다. 한편 전용실시권의 범위에 관한 제한은 등록하여야 효력이 발생하므로, 이를 넘어 실시하더라도 채무불이행 책임은 별론으로 하고 침해가 성립하지 아니한다(2011도4645).

(2) 사안의 포섭

乙은 여전히 전용실시권자로서 정당한 권원이 있고 사전 승낙 특약은 효력이 없으므로, 2011. 7. 1. 이후 乙의 실시도 그 범위 내의 실시로서 침해가 아니다. 이전행위는 권리의 처분일 뿐 실시가 아니어서 그 자체로 침해가 아니다.

4. 甲의 구제수단

전용실시권이 설정된 범위에서는 특허권자도 실시를 독점하지 못하나(§ 94①단서), 소극적 효력은 적극적 효력과 별개이므로 甲도 전용실시권자 외의 자에게는 실시를 배제할 권한을 행사할 수 있다.

(1) 乙에 대하여

침해가 아니므로 특허법에 따른 청구는 할 수 없고, 설문 (1)에서 본 채무불이행 손해배상과 제한의 등록, 설정계약의 해제·말소등록 청구를 할 수 있다.

(2) 丙에 대하여

丙은 권원을 취득하지 못하였으므로 甲은 그 이전등록의 말소를 구할 수 있다. 사안에 丙의 실시는 드러나 있지 아니하나, 丙이 업으로 실시한다면 정당한 권원 없는 자의 실시로서 침해금지·예방청구(§ 126)와 손해배상청구(§ 128) 등의 대상이 된다.

5. 결론

甲의 동의 없이 실시사업과 분리한 이전은 효력이 없어 전용실시권은 여전히 乙에게 있고, 2011. 7. 1. 이후 乙의 실시는 침해가 아니다. 甲은 乙에게는 계약상 구제를, 丙에게는 이전등록의 말소를 구할 수 있다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
(1) 전용실시권 일반론 및 미등록 특약의 효력 (\$100①·\$101①(2))	3	물권적 권리·설정등록의 효력발생요건, 특약 제한 미등록 시 대세적 효력 부정
(1) 2011.6.30 이전 실시의 침해 여부 판단(대법원 2011도4645)	4	판례 법리 정확 인용 + 사안 포섭: 등록되지 아니한 제한을 넘어 실시하여도 특허권 침해 불성립 결론
(1) 甲의 구제수단(민사·계약법적 조치)	5	채무불이행 손해배상(민법), 사후 제한 등록, 계약해제·전용실시권 등록말소청구 등 다각적 제시
(2) 실시사업 없는 전용실시권 이전(\$100③)의 효력	3	특허권자 동의·실시사업 이전 없는 이전등록은 무효 → 乙은 여전히 전용실시권자
(2) 2011.7.1 이후 乙의 실시행위 침해 여부	2	여전히 전용실시권자 지위 유지, 미등록 특약 위반은 침해 아님(설문(1) 논리 원용)
(2) 甲의 乙·丙에 대한 구제수단	3	전용실시권을 설정한 특허권자에게도 침해에 대한 소권이 인정되는지(\$94④단서와 소극적 효력의 관계)를 먼저 정리한 뒤, 乙: 채무불이행 손해배상·제한 등록·계약해제, 丙: 이전이 효력 없음 → 말소등록청구가 주된 구제. ★丙의 실시는 사안에 주어진 사실이 아니므로 침해금지·손해배상은 '실시한다면'의 가정으로 짧게 부기할 것이며, 이를 기정사실로 삼아 길게 논하면 사실관계를 벗어난 서술로 감점

배점 합계: 20점

특별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- **[+]** 대법원 2011도4645 판례(등록되지 않은 특약 위반은 침해 아님)를 정확히 포착하여 결론 도출
- **[+]** 설문(2)를 ① **전용실시권의 귀속(\$100③ — 乙과 丙 중 누구에게 있는가)** → ② **그 지위에 선 乙의 실시가 침해인지** → ③ **구제수단의 순서**로 세워, 귀속 판단이 침해 판단의 전제임을 드러낼 것
- **[+]** 실시행위 독립성 원칙에 따라 이전등록 행위와 실시행위를 별개로 판단
- **[-]** 미등록 특약도 유효하다고 단정하여 침해 긍정 결론에 이른 경우(판례 몰이해)
- **[-]** 채점평 지적: "판례에 대한 정확한 이해 부족"."단순 암기식 접근" — 판례 법리를 사안에 포섭하지 않고 결론만 나열하면 감점

2) 목차·구성(25%)

- **[+]** 침해 성립요건(\$ 94) → 전용실시권자 지위 확인 → 특약 위반의 효력 → 침해 여부 → 구제수단 순의 체계적 목차
- **[+]** 설문 (1)과 (2)의 배점(12:8)에 맞춰 분량 배분, 채점평 지적처럼 "간결한 문체" 유지
- **[-]** 전용실시권 일반론 서술이 지나치게 길고 사안 해결에 지면이 부족한 경우
- **[-]** 구제수단을 나열식으로만 열거하고 실효성·적용 법규정 없이 서술한 경우

3) 답안 작성·논증(35%)

- **[+]** 제100조 제2항·제3항, 제101조 제1항 제2호, 제94조 제1항 단서 등 조문 근거 명시. 제100조 제3항의 두 예외(실시사업과 함께 이전 / 일반승계)의 취지까지 서술
- **[+]** 대법원 2011도4645(미등록 특약)·전용실시권 이전 관련 판례를 인용하고 사안에 포섭
- **[+]** 결론이 명확: (1) 乙 침해 불성립 + 채무불이행 책임, (2) 乙 침해 불성립·이전은 효력 없어 말소청구, 丙이 실시하면 침해 성립
- **[-]** 채점평 지적: "정답은 맞았으나 논리전개가 치밀하지 못함" — 결론만 있고 적용 법규정·판례 부재 시 감점
- **[-]** 침해 판단 시 4요건(유효권리·정당권원 없음·보호범위 내·업으로서) 검토 누락

감점 주의

- 대법원 2011도4645(2013년 최신 판례) 법리를 모른 채 "특약 위반 = 침해"로 결론지음(채점평의 핵심 감점 사유)
- 제100조 제3항(전용실시권 이전 제한)을 단순 조문 인용에 그치고, "실시사업과 함께 이전"."특허권자 동의" 요건을 사안에 포섭하지 않음
- 제101조 제1항의 성격을 '대항요건'으로 오기하는 경우(현행 조문은 '등록하여야만 효력이 발생한다'는 효력발생요건임)
- 제101조 제1항 제2호의 대상('설정·이전·변경·소멸(혼동 제외) 또는 처분의 제한')에서 '설정'을 누락한 서술
- 丙에 대한 조치로 "침해금지청구"만 언급하고 이전등록 무효에 기한 **말소등록청구**를 누락
- 채무불이행 손해배상(민법상 일반 채무불이행 책임)과 특허법상 침해에 따른 손해배상(\$ 128)을 혼동
- 판례·조문 없이 사전면으로 서술하거나, 반대로 조문·판례 전사에 그치고 사안 포섭이 없음

- 채점평 지적: 답안 필체·구성이 산만하여 가독성이 떨어짐, 지나친 분량 나열

PART 5

2014

제1문	제128조 제2항의 성격 · 양도수량의 확정	30점
제2문	甲의 실시태양 3단계 구분 및 침해성립요건 · 제1실시(연구·시험 실시)의 침해 여부	20점
제3문	결합발명의 진보성 판단(구성의 곤란성·효과의 현저성) · 청구범위 해석 법리 및 사안 적용	30점
제4문	진보성 무효사유의 침해소송 내 주장 가부 · 특허권 당연무효 주장 가부	20점

2014년 제1문

약술형

30점

문제

대상 특허권 침해소송에서 파악된 사실관계는 다음과 같다.

- A. 원고는 유동성 및 내구성이 제고된 바퀴에 관한 특허발명의 특허권자이다. 원고는 그 특허발명을 적용한 여행용 가방을 백화점 및 직영 매장에서 평균 30만원의 가격에 판매하여 왔다.
- B. 소외 제3자는 원고의 제품과 비슷한 기능을 가지면서도 원고의 특허권을 침해하지 않는 경쟁제품을 판매하여 왔으며, 피고의 침해행위가 있기 전 특허권자 및 소외 제3자의 시장점유율은 각각 60% 및 40%이었다.
- C. 피고는 원고의 침해소송 제기 전 지난 5년간 15만개의 침해제품을 생산하여 10만개는 판매하였고, 2만개는 홍보품, 사은품 등으로 무상 배포하였고, 나머지 3만개는 판매를 위하여 창고에 보관 중이다.
- D. 피고는 침해제품을 원고의 상권과 구별되는 아웃렛 매장 등에서 평균 20만원의 가격에 판매하여 10만개 전체에 대하여 200억원의 매출을 올렸다.
- E. 원고는 침해행위가 있기 전 매년 6만개의 가방을 판매하여 매년 180억원의 매출을 올렸으나, 침해행위 이후로는 매년 5만개의 가방을 판매하여 매년 150억원의 매출을 올렸다.
- F. 원고의 가방 1개당 판매 이익액은 평균 10만원이었다.

위 사실관계에 기초하여 다음의 질문에 답하시오.

(1) 특허법 제128조 제2항의 성격에 대하여 설명하시오. (10점)

(2) 특허법 제128조 제2항에 따라 손해액을 산정하시오. (20점)

【 원 기출문제 】 이 문제는 2014년 제51회 제2차시험 특허법 문제 1을 현행법에 맞추어 변형한 것이다. 출제 당시의 제128조 제1항은 현행 제128조 제2항에 대응하는데, 현행 제2항은 제1호와 제2호의 합계액 구조여서 문(文)별로 나누어 묻던 원 발문을 그대로 쓸 수 없다. 원 발문은 다음과 같았다.

(1) 특허법 제128조 제1항의 성격에 대하여 설명하시오. (7점)

(2) 특허법 제128조 제1항 제1문에 따른 손해액 산정을 설명하시오. (9점)

(3) 특허법 제128조 제1항 제2문에 따른 손해액의 제한에 대하여 설명하시오. (7점)

(4) 특허법 제128조 제1항 제3문에 따른 손해액의 공제에 대하여 설명하시오. (7점)

모범답안

I. 설문 (1) — 제128조 제2항의 성격 (10점)

1. 문제의 소재

특허권자는 고의나 과실로 특허권을 침해한 자에게 손해배상을 청구할 수 있다(§ 128①). 그러나 특허권은 점유할 수 없는 무체물을 객체로 하므로 그 침해로 인한 손해액의 증명이 유체물에 대한 권리의 침해보다 훨씬 어렵다. 그리하여 특허법은 손해액의 산정에 관한 특칙을 두고 있는바(§ 128 ②부터 § 128㉔까지), 그중 제2항이 어떠한 성격의 규정인지가 문제된다.

2. 관련 법규정

침해자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 다음 각 호의 금액의 합계액을 손해액으로 할 수 있다(§ 128②). i) 그 물건의 양도수량(침해 행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자가 생산할 수 있었던 수량에서 실제 판매한 수량을 뺀 수량을 넘지 아니하는 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액(§ 128②(1))과, ii) 그 수량을 넘는 수량 또는 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 대하여 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액(§ 128②(2))이 그것이다.

3. 성 격

(1) 소극적 손해의 두 유형에 대응하는 산정규정

침해로 인한 소극적 손해에는 매상의 감소로 인한 일실이익과 실시료 수입의 감소가 있다. 제2항은 앞의 것을 제1호에서, 뒤의 것을 제2호에서 각각 산정하도록 하고 그 합계액을 손해액으로 하고 있다. 매상의 감소에 관하여는 침해자가 얻은 이익을 손해액으로 추정하는 규정(§ 128④)이, 실시료 수입의 감소에 관하여는 합리적 실시료액을 손해액으로 하는 규정(§ 128⑤)이 각각 대응한다.

(2) 제1호 — 일실이익 산정에 관한 증명책임의 완화

매출 감소로 인한 일실이익을 청구하려면 본래 특허권자가 자신의 판매 감소량과 그것이 침해로 인한 것이라는 인과관계를 모두 증명하여야 한다. 그런데 판매 감소에는 제3자의 대체품이나 침해자 자신의 노력과 역량이 기여하였을 수도 있어 그 증명이 쉽지 아니하다. 제1호는 침해품이 판매된 만큼 특허권자의 판매가 감소하였으리라는 개연성에 기초하여, 특허권자의 생산능력 범위에서 침해자의 양도수량을 특허권자의 판매 감소량으로 볼 수 있게 한 것이다. 그리하여 특허권자는 자신의 단위수량당 이익액만 증명하면 된다.

(3) 제2호 — 합리적 실시료액에 의한 보완

제2호는 특허권자의 생산능력을 넘는 수량이나 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 대하여 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 더할 수 있게 한 것이다. 이는 매상의 감소가 아니라 실시계약을 체결할 기회를 잃은 데 대한 보상이므로 특허권자가 스스로 실시하고 있을 것을 전제하지 아니한다. 특허권자는 생산하지 아니하더라도 실시계약을 통하여 이익을 얻을 수 있으므로, 침해자가 생산능력을 넘어 취득한 이익도 특허권자가 얻을 수 있었던 이익으로 볼 필요가 있기 때문이다.

(4) 물건의 양도를 전제

침해자가 물건을 양도한 경우에 적용되므로 물건의 발명이나 물건을 생산하는 방법의 발명에 적용되고, 방법의 발명 자체에는 적용되기 어렵다. 다만 여기의 양도는 특허권자의 보호를 강화하려는 입법취지에 비추어 반드시 양도에 한정되지 아니하고 대여나 청약 등도 포함된다고 봄이 타당하다.

(5) 임의규정

합계액을 손해액으로 「할 수 있다」고 정하고 있으므로, 특허권자는 이에 의하지 아니하고 침해자가 얻은 이익액을 손해액으로 추정하는 규정(§ 128④)이나 합리적 실시료액을 손해액으로 하는 규정(§ 128⑤)에 의하여 청구할 수도 있다.

4. 결론

제128조 제2항은 소극적 손해 중 매상의 감소로 인한 일실이익을 제1호에서, 실시료 수입의 감소를 제2호에서 산정하도록 한 손해액 산정의 특칙이다. 제1호는 일실이익의 산정에 관하여 증명책임을 완화한 것이고, 제2호는 그 한계를 합리적 실시료액으로 보완한 것으로서 특허권자의 실시를 전제하지 아니한다. 두 금액은 합계되며, 다른 산정규정과 선택적으로 주장할 수 있는 임의규정이다.

II. 설문 (2) — 제128조 제2항에 따른 손해액의 산정 (20점)

1. 산정의 구조

제128조 제2항에 따른 손해액은 제1호의 금액과 제2호의 금액의 합계액이다. 이를 산정하려면 i) 침해자의 양도수량, ii) 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량, iii) 특허권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량, iv) 단위수량당 이익액을 차례로 확정하여야 한다.

2. 양도수량

(1) 의의

침해자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도한 수량을 말한다. 특허권자의 보호를 강화하려는 입법취지에 비추어 양도는 유상인 경우에 한정되지 아니하고 소유권을 이전하는 일체의 행위를 포함한다. 반면 아직 양도되지 아니한 채 보관 중인 물건은 양도수량에 들어가지 아니한다.

(2) 사안의 포섭

피고는 5년간 15만개를 생산하여 그중 10만개를 판매하고 2만개를 홍보품·사은품으로 무상 배포하였으며 3만개는 창고에 보관 중이다. 무상 배포도 소유권을 이전한 것이므로 양도에 해당하나 보관 중인 3만개는 양도가 없으므로, **양도수량은 12만개**이다.

3. 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량

(1) 의의와 증명책임

특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 수량을 양도수량에서 뺀다(§ 128②(1)). 판례는 이를 침해자의 시장개발 노력이나 판매망, 상표, 광고·선전, 침해제품의 품질의 우수성 등으로 인하여 권리의 침해와 무관하게 판매된 수량이 있는 경우를 말하는 것으로서, 권리를 침해하지 아니하면서 시장에서 경쟁하는 경쟁제품이 있다는 사정도 이에 포함될 수 있다고 한다(2005다36830). 이러한 사정은 배상액을 다투는 침해자가 주장·증명하여야 한다.

(2) 사안의 포섭

소외 제3자는 원고의 특허권을 침해하지 아니하는 경쟁제품을 판매하여 왔고, 침해행위 전 원고와 소외 제3자의 시장점유율은 각각 60퍼센트와 40퍼센트였다. 따라서 피고의 양도수량 전부가 원고의 판매로 이어졌으리라고 볼 수 없고, 경쟁제품의 점유율에 상응하는 40퍼센트인 **4만 8천개**가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이다. 피고가 원고의 상권과 구별되는 아웃렛 매장에서 절반 수준의 가격으로 판매하였다는 사정도 같은 방향의 자료가 된다.

그리하여 제1호의 기준이 되는 수량은 양도수량 12만개에서 4만 8천개를 뺀 **7만 2천개**이다.

4. 특허권자의 실시능력에 따른 한도**(1) 의의**

제1호의 금액은 특허권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘지 아니하는 범위에서만 인정된다. 특허권자가 스스로 생산할 수 없었던 수량까지 판매할 수 있었다고 볼 수는 없기 때문이다.

(2) 사안의 포섭

원고는 침해행위 전 매년 6만개를 판매하여 왔으므로 침해기간 5년 동안 30만개를 생산할 수 있었다고 볼 수 있고, 그 기간에 실제로 판매한 수량은 매년 5만개씩 25만개이다. 따라서 생산할 수 있었던 수량에서 실제 판매수량을 뺀 수량은 **5만개**이다.

5. 단위수량당 이익액

특허권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 말한다. 판례는 이를 그 제품을 판매할 경우의 판매가격에서 재료비·노무비·관리비 등 제경비를 공제한 금액이라고 하여, 매출액에서 변동경비를 뺀 한계이익을 뜻하는 것으로 본다(2005다36830). 침해자의 판매가격이나 이익률이 아니라 특허권자를 기준으로 하므로, 원고의 가방 1개당 판매 이익액인 **10만원**이 기준이 되고 피고의 판매가격이 20만원이라거나 그 매출이 200억원이라는 사정은 고려하지 아니한다.

6. 손해액의 산정**(1) 제1호의 금액**

침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 양도수량 7만 2천개가 실시능력에 따른 한도인 5만개를 넘으므로, 제1호의 수량은 그 한도인 **5만개**가 된다. 여기에 단위수량당 이익액 10만원을 곱하면 **50억원**이다.

(2) 제2호의 금액

제2호의 수량은 양도수량에서 제1호의 수량과 실시권의 설정이나 허락을 할 수 있었다고 인정되지 아니하는 수량을 뺀 수량이다. 사안에는 원고가 전용실시권의 설정이나 통상실시권의 허락을 할 수 없었다고 볼 사정이 없으므로, 양도수량 12만개에서 제1호의 5만개를 뺀 **7만개**가 제2호의 수량이 된다. 여기에는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액, 곧 합리적 실시료액을 곱하여야 하나, 사안에는 실시료율에 관한 자료가 주어져 있지 아니하므로 구체적인 금액을 산정할 수는 없다.

7. 결론

원고는 제128조 제2항 제1호에 따른 50억원과, 같은 항 제2호에 따라 7만개에 대하여 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 더한 합계액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	득점 포인트
설문(1) 제128조 제2항의 성격	10	① 소극적 손해의 두 유형에 대응 — 제1호는 매상감소에 의한 일실이익(\$128④와 대응), 제2호는 실시료 수입의 감소(\$128⑤와 대응), ② 제1호는 일실이익 산정에 관한 증명책임의 완화(생산능력 범위에서 양도수량을 판매 감소량으로 봄), ③ 제2호는 합리적 실시료액에 의한 보완으로서 특허권자의 실시를 전제하지 아니함, ④ 물건의 양도를 전제(방법발명 자체에는 적용 곤란. 양도에 무상양도·대여·청약 포함), ⑤ 「할 수 있다」 — \$128④·\$128⑤와 선택적으로 주장할 수 있는 임의규정
설문(2) 양도수량의 확정	4	판매 10만개 + 무상배포 2만개 = 12만개. 참고 보관 3만개는 양도가 없어 제외. 양도의 개념(유·무상 불문) 명시
설문(2) 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량	5	취지와 증명책임(침해자), 경합제품의 존재도 포함된다는 판례(2005다36830), 경쟁제품 점유율 40%에 상응하는 4만 8천개 산정
설문(2) 실시능력에 따른 한도와 단위수량당 이익액	5	5년간 생산가능 30만개 - 실제 판매 25만개 = 5만개. 단위수량당 이익액은 한계이익이고 특허권자 기준이므로 10만원(피고의 20만원·200억원 아님)
설문(2) 제1호·제2호의 금액 산정	6	공제 후 양도수량 7만 2천개 > 한도 5만개 → 제1호 수량 5만개 × 10만원 = 50억원. 제2호 수량 = 양도수량 12만개 - 제1호 5만개 = 7만개(실시권 설정·허락 불가 사정 없음) → 합리적 실시료액. 두 금액의 합계로 결론

배점 합계 = 30점

특별 채점 기준

1) 논점 추출(약 40%)

- **득점:** 제128조 제2항이 제1호와 제2호의 **합계액** 구조임을 처음에 세우고, 산정에 필요한 네 가지 수량·금액을 차례로 확정하는 순서를 잡은 답안.
- **득점:** 사실관계의 수치(양도수량·생산능력·경합제품 점유율 40%·단위이익 10만원)를 빠짐없이 산정에 반영.
- **감점:** 참고 보관 3만개를 양도수량에 산입하거나 무상배포 2만개를 제외한 답안.
- **감점:** 단위수량당 이익액에 피고의 판매가격 20만원이나 매출 200억원을 사용한 답안.
- **감점:** 제2호를 언급하지 아니하고 제1호의 금액만으로 결론지은 답안.

2) 목차·구성(약 25%)

- **득점:** 설문(1)은 성격을 다섯 갈래로 나누어 제시하고, 설문(2)는 '수량의 확정 → 금액의 산정' 순으로 배점 비례(10 : 20)로 분량을 배분.
- **득점:** 각 수량마다 '의의 → 사안의 포섭'을 짚지어 서술.
- **감점:** 손해배상 일반론이나 제128조 전체의 개관을 장황히 서술하고 정작 산정이 빈약한 답안.

3) 답안 작성·논증(약 35%)

- ★**핵심:** 산정의 순서를 조문대로 밟을 것. 양도수량에서 **침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 먼저 빼고**, 그 결과에 실시능력에 따른 한도를 적용한다. 한도를 먼저 적용한 뒤 그 금액에서 40퍼센트를 공제하는 순서는 조문에 반한다.
- **득점:** 제2호의 수량을 '양도수량 - 제1호의 수량 - 실시권 설정·허락 불가 수량'으로 도출한 답안.
- **득점:** 조문 문언 → 판례(한계이익, 경합제품도 침해 외의 사유에 포함) → 사안 포섭 → 금액의 순으로 논증하고 결론에서 금액을 명시.
- **감점:** 실시료를 자료가 없음에도 제2호의 금액을 임의로 단정한 답안(자료가 없으므로 산정할 수 없다고 밝히는 것이 옳다).
- **감점:** 제2호가 특허권자의 실시를 전제한다고 서술하거나, 「실시료 상당액」과 같이 조문 문언이 아닌 표현을 쓴 답안.
- **감점:** 결론에서 금액을 제시하지 아니하거나 계산 근거가 불명확한 답안.

감점 주의

- 채점평 지적: 배점에 맞게 촘촘히 기재할 것. 배점이 큰 산정 부분에 몇 줄만 쓰거나, 반대로 무관한 총론을 장황히 쓰면 감점.
- 제1호와 제2호를 택일 관계로 오해하는 것. 두 금액은 **합계**된다.
- 판례번호를 논점과 무관하게 붙이는 오인용은 감점. 확실하지 아니하면 사건번호 없이 법리만 정확히 서술할 것.

2014년 제2문

사례형

20점

문제

원고는 전자칠판 발명에 관한 특허권자이다. 동 특허권은 2013년 12월 31일에 만료되었다. 동 전자칠판은 다양한 시청각 기능, 인터넷 기능 등을 가지며, 특히, 학생들의 의견 또는 질문이 실시간으로 칠판 한 쪽에 표시되어 수업을 매우 역동적으로 만드는 것으로 평가된다. 甲은 원고가 판매하고 있는 전자칠판과 유사한 제품을 만들기 위하여 2012년 한 해 동안 연구개발에 매진을 하였고, 그러한 연구개발의 결과로 원고의 제품보다 오히려 더 좋다고 볼 수도 있는 제품을 개발하였다. 甲은 2013년 초반부터 제품을 생산하기 시작하였고, 2014년 1월 1일부터 동 제품을 판매하기 시작하였다. 乙은 개별 전자칠판의 기능에 부합하는 맞춤형 전원공급장치를 판매하는 업체이며, 甲의 연구개발 초기부터 甲 제품에 적용되는 전원공급장치를 개발하였고, 그 후 甲의 제품 생산 시에 그 장치를 납품하였다. 乙은 해당 시장에서 시장점유율 60%를 자랑한다. 위 사실관계에 기초하여 다음의 질문에 답하시오.

(1) 甲의 직접침해 여부에 대하여 설명하시오. (10점)

(2) 乙의 간접침해 여부에 대하여 설명하시오. (10점)

모범답안

문제 2 모범답안 (20점)

I. 설문 (1) — 甲의 직접침해 여부 (10점)

1. 문제의 소재

원고의 특허권은 2013. 12. 31. 존속기간 만료로 소멸하였는데, 甲은 2012년에 연구개발을, 2013년 초부터 생산을, 2014. 1. 1.부터 판매를 하였다. 실시의 각 행위는 독립되어 있어 실시행위마다 침해 여부를 판단하여야 하므로(실시행위의 독립성), 침해의 성립요건과 연구 또는 시험을 위한 실시의 법리를 본 후 행위별로 나누어 판단한다.

2. 직접침해의 성립요건

특허권의 침해란 특허권의 존속 중 정당한 권원이 없는 자가 업으로서 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 실시하는 것을 말한다.

(1) 특허권의 존속 중 실시일 것

존속기간의 만료, 특허료의 불납, 포기 등으로 특허권이 소멸한 후의 실시나 특허출원 중의 실시는 침해가 아니다. 다만 존속 중의 실시이면 족하고 권리행사 당시까지 존속할 필요는 없다.

(2) 정당한 권원 없는 자의 실시일 것

정당한 권원을 가진 자의 실시는 침해가 아니고, 적법하게 판매된 특허제품을 구입한 자의 실시도 권리소진으로 침해가 아니다. 실시란 제2조 제3호의 행위로써, 물건의 발명에서는 그 물건의 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입과 그 양도 또는 대여의 청약이다. 한편 실시의 각 행위는 독립되어 있으므로 하나가 적법하다고 하여 다른 행위까지 적법한 것은 아니다(실시행위의 독립성).

(3) 업으로서의 실시일 것

업으로서란 개인적·가정적 실시를 제외한다는 의미이고, 영리·비영리를 불문하며 1회의 실시도 포함한다.

(4) 특허발명의 보호범위에 속하는 발명의 실시일 것

청구범위를 중심으로 발명의 설명·공지기술·출원경과 등을 참작하여 특허발명을 특정한 후 구성요소완비의 원칙과 균등론으로 판단한다. 다만 그에 해당하더라도 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위(§ 96) 등 법률에 의한 제한에 해당하면 보호범위에 속하지 아니한다.

3. 시험 또는 연구를 위한 실시

(1) 의의 및 취지

연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시에는 특허권의 효력이 미치지 아니한다(§ 96①(1)). 누구든지 특허발명을 연구·시험하여 그 내용을 확인·검증하고 개량할 수 있도록 하여 발명의 보호와 이용의 조화를 꾀하려는 것이다.

(2) 판단기준

특허발명 자체를 대상으로 하는 연구 또는 시험이어야 하고, 다른 연구·시험의 수단으로 이용하는 실시에는 효력이 제한되지 아니한다. 그 목적이 특허성의 확인·기술의 개량인지 상업적 이익인지에 따라 적용을 달리하지 아니한다(2025다202970). 다만 그 결과 제작된 것을 업으로서 다른 용도로 실시하면 그 행위는 침해가 된다.

4. 사안의 포섭

(1) 2012년의 연구개발

특허권의 존속 중이나, 甲의 활동이 원고 발명의 내용 확인이나 개량을 위한 연구 또는 시험에 그친다면 특허권의 효력이 미치지 아니하여 침해가 아니다 (§ 96①(1)). 상업화가 궁극적 목적이었다는 사정만으로 달라지지 아니하나, 이미 판매를 위한 양산 준비에 이르렀다면 이에 해당하지 아니한다.

(2) 2013년 초부터의 생산

이 시기에도 특허권이 존속하였고 생산은 물건발명의 실시이다. 甲의 제품이 원고 청구범위의 구성요소를 모두 포함하거나 그와 균등하다면 직접침해가 성립하며, 개량되어 더 우수하다는 사정은 침해의 성립에 영향이 없다.

(3) 2014. 1. 1. 이후의 판매

특허권은 2013. 12. 31. 소멸하였고, 존속기간 중 생산된 물건을 만료 후 양도하더라도 양도는 생산과 별개의 실시행위이므로 침해가 아니다.

5. 결론

2012년의 연구개발은 연구 또는 시험을 위한 실시 (§ 96①(1))로서, 2014년 이후의 판매는 소멸 후의 실시로서 각 침해가 아니고, 2013년의 생산은 甲의 제품이 보호범위에 속하는 한 직접침해가 된다. 원고는 침해금지청구 (§ 126)는 할 수 없고 손해배상만을 구할 수 있다.

II. 설문 (2) — 乙의 간접침해 여부 (10점)

1. 간접침해의 법규정 및 취지

특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하면 특허권의 침해로 본다 (§ 127(1)). 구성요소완비의 원칙에 따른 직접침해만을 고수하면 부품만을 공급하여 이익을 얻는 자에게 책임을 물을 수 없어 특허권의 효력이 현저히 감소하므로, 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 권리 구제의 실효성을 높이려는 것이다.

2. 성립요건

특허권의 존속 중 정당한 권원 없는 자가 업으로서 간접침해행위를 하여야 한다. 제127조 제1호의 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'에서 '생산에 사용하는'이 공용성을, '…에만'이 전용성을 뜻하며, 대상 물건은 두 요건을 모두 갖추어야 한다.

(1) 공용성

공용성이란 그 물건이 특허발명인 물건의 '생산에 사용하는' 것이어야 한다는 요건이다. 여기의 생산이란 특허발명의 구성요소를 충족하지 아니한 물건을 사용하여 이를 충족하는 물건을 만들어 내는 행위로서, 구성요소완비의 원칙에 의한 생산뿐만 아니라 균등론에 의한 생산도 포함되고, 속지주의상 국내에서의 생산을 의미한다.

(2) 전용성

전용성이란 '…에만'의 요건으로서, 그 물건에 특허발명의 생산 외의 다른 용도가 없어야 한다는 것이다. 따라서 널리 쓰이는 기초상품이나 범용품과 같은 중성적 물건은 특허발명의 구성요소에 속하더라도 간접침해가 성립할 여지가 없다. 판례는 상업적 또는 경제적으로 실용성 있는 용도로서 사회통념상 통용되거나 승인될 수 있는 경우에만 다른 용도로 인정되고, 이론적·실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도로는 다른 용도가 있다고 할 수 없다고 한다(2007후3356). 그 유무는 해당 행위 시를 기준으로 판단한다.

3. 직접침해와의 관계

직접침해가 있어야 간접침해가 인정된다는 종속설과 간접침해의 요건만 갖추면 된다는 독립설이 대립한다. 실시권이나 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위 (§ 96)에서의 실시와 같이 정당한 권원에 의하여 직접침해가 되지 아니하는 자에게 전용품을 공급하는 행위까지 침해로 보는 것은 불법에 가공하지 아니한 행위에 책임을 묻는 것이어서 특허권의 부당한 확장이므로 이를 부정함이 타당하다. 판례도 어느 한 견해를 취하지 아니하고 사안에 따라 판단하는바, 마찰교반용접기 사건에서 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시한 경우, 그 제3자의 생산·양도행위를 간접침해로 보면 실시권에 부당한 제약을 가하고 특허권이 부당하게 확장된다는 이유로 이를 부정하였다(2017다290095).

4. 사안의 포섭

(1) 공용성과 전용성

乙의 전원공급장치는 연구개발 초기부터 甲 제품에 적용되도록 개발되어 그 생산에 사용되었으므로 공용성이 인정된다. 또한 개별 전자칠판의 기능에 부합하는 맞춤형 장치이므로 다른 전자칠판에 사용될 경제적·상업적 내지 실용적인 용도를 인정하기 어려워 전용성도 인정된다. 乙의 시장점유율 60%는 시장에서의 지위를 나타낼 뿐 다른 용도의 존재를 뒷받침하지 않는다.

(2) 시기별 판단

① (2012년 연구개발 단계의 납품) 甲의 실시로 특허권의 효력이 미치지 아니한다면 (§ 96①(1)), 정당한 권원자에게 전용품을 공급한 경우와 마찬가지로 보아야 한다.

② (2013년 생산 시의 납품) 특허권이 존속하고 甲의 생산이 직접침해이므로, 그 생산에만 사용되는 장치를 업으로서 납품한 행위는 간접침해가 된다 (§ 127(1)).

③ (2014년 이후의 납품) 특허권이 소멸하였으므로 간접침해가 성립할 여지가 없다.

5. 결론

乙이 특허권 존속 중 甲의 침해품 생산에만 사용되는 전원공급장치를 업으로서 납품한 행위는 간접침해이다. 다만 연구 또는 시험을 위한 실시에 제공된 부분과 소멸 후의 납품은 간접침해가 아니며, 원고는 乙에 대하여도 손해배상만을 구할 수 있다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점 (총 20점)

쟁점	배점	특점 포인트
甲의 실시태양 3단계 구분 및 침해성립요건	3점	제1실시(연구개발, 2012~2013 초), 제2실시(생산, 2013 초~12.31), 제3실시(2014.1.1~ 생산·판매)로 시기별 구분 명시
제1실시(연구·시험 실시)의 침해 여부	2점	제96조 제1항(1) 연구·시험 예외 적용 검토, 침해 부정. 특허발명 자체를 대상으로 한 연구·시험일 것, 상업적 이익을 목적으로 하여도 적용이 달라지지 아니한다는 점(2025다202970)까지 밝히면 가점
제2실시(생산)의 침해 여부	3점	존속 중 실시+제2조 iii 가목 실시 개념(생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입 등)+구성요건완비/균등론 검토, 원칙적 침해 인정
제3실시(2014.1.1 이후)의 침해 여부	2점	특허권 존속기간 만료(2013.12.31) → 침해 부정. 각 실시행위는 독립하여 평가되므로 존속기간 중 생산한 물건을 소멸 후 양도하여도 그 양도는 침해가 아니며, 존속기간 중 생산에 대하여는 금지청구는 불가하고 손해배상만 가능하다는 점까지 밝혔는지
간접침해(§127) 취지·요건	2점	존속 중 정당한 권원 없는 자·업으로서에 더하여 대상 물건의 공용성(그 물건의 생산에 사용될 것, 균등론에 의한 생산 포함)과 전용성('...에만')을 요건으로 적시(§127①(1), '생산·양도·대여·수출 또는 수입' 포함), 예비적 침해 방지 취지
직접침해 전제 여부(독립설/종속설)	2점	학설 대립 소개 후 자기 견해 명시. 판례가 어느 한 견해만을 취하지 아니하고 사안별로 판단한다는 점과, 마찰교반용접기 사건에서 실시권자에게 전용품을 제작·납품한 행위는 실시권에 부당한 제약을 가하고 특허권을 부당하게 확장하는 결과가 되어 간접침해가 아니라고 한 점(2017다290095)까지 언급하면 가점
타용도(전용성)의 판단기준	2점	판례 — 사회통념상 통용·승인될 수 있는 경제적·상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없을 것, 이론적·실험적·일시적 사용가능성만으로는 다른 용도 부정(2007후3356). 범용품 등 중성적 물건은 전용품이 아니라는 점, 다른 용도의 유무는 해당 행위 시를 기준으로 판단한다는 점
사안 포섭 및 결론(甲의 침해 여부에 따라 경우를 나눈 결론)	4점	甲 제2실시가 직접침해인 경우 乙의 전용성 인정→간접침해 성립, 제1·3실시의 경우 결론 구분, 시장점유율 60%의 의미

특별 채점 기준

1) 논점 추출 (8점)

- 甲의 실시를 시기별로 3단계로 나누어 각각 침해 여부를 검토했는가
- 제96조 제1항(1) 연구·시험 실시 예외를 포착했는가
- 특허권 존속기간 만료일(2013.12.31)의 의미를 포착하여 제3실시를 별도 판단했는가
- 간접침해에서 '전용성(타용도)'과 '직접침해 전제 여부'라는 두 핵심 쟁점을 모두 적시했는가
- 시장점유율 60%라는 사실을 전용성 판단에 활용했는가
- 감점: 甲의 실시를 하나로 묶듯 고려 판단, 존속기간 만료 간과, 전용성 논점 누락, 제96조 제1항(1) 간과

2) 목차·구성 (5점)

- 설문(1)·(2)를 대제목으로 분리, 각각 실시태양별·요건별로 소제목 배치
- 배점 비례(각 10점)에 맞춰 균형 있게 분량 배분
- '판례→학설→사안 포섭' 구분 배치
- 감점: 서론 상황, 일반론 나열, 사안 포섭 소략, 쟁점 편중

3) 답안 작성·논증 (7점)

- 제2조(실시 개념, 물건발명은 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입 및 양도·대여의 청약), 제96조 제1항(1), 제127조 제1항 제1호(생산·양도·대여·수출 또는 수입 및 양도·대여의 청약) 조문을 정확히 인용
- 대법원 판례(전용성 판단 2007후3356, 직접침해와의 관계 — 마찰교반용접기 사건 2017다290095)의 취지 인용
- 독립설/종속설 대립 시 자기 입장·논거 제시
- 사안 사실(연구개발→생산→판매의 시기 이동, 존속기간 만료, 시장점유율 60%)을 조문·법리에 정확히 포섭
- 결론이 각 실시별로 명확하고 본문과 일치할 것
- 감점: 조문 전사, 사안 포섭 없이 일반론만, 결론 애매, 본문↔결론 모순, '수출' 등 실시 개념·간접침해 대상행위의 누락

감점 주의

- 채점평의 "Step by step" 지적: 甲의 실시를 시기별로 촘촘히 나누지 않고 통째로 판단하면 큰 감점
- 특허권 존속기간이 2013.12.31에 만료되었다는 결정적 사실을 놓치는 경우가 다수
- 간접침해에서 '직접침해 전제 여부' 논점을 빠뜨리고 전용성만 논하거나, 반대의 경우
- 제96조 제1항(1) '연구 또는 시험'을 명시하지 않고 곧바로 침해라고 결론

- 제2조 iii 가목·제127조 제1항 제1호 조문 인용 시 '수출'을 누락하는 오기
- 전용성 판단 판례로 상표법 관련 판례를 오인용하는 것
- 시장점유율 60%를 무시하거나, 반대로 60%만으로 타용도가 있다고 성급히 결론
- '관련 없는' 손해배상·무효심판 등을 장황히 서술하는 것

2014년 제3문

사례형

30점

문제

甲은 새로운 서비스 제공이 지속적으로 요구되는 정보통신 분야의 산업계에 종사하면서 선행기술 3개를 합하여 구성된 온라인 서비스 관련 발명을 완성하였고, 기재 자체만으로 그 발명이 명확하게 이해될 수 있도록 청구범위를 작성하여 출원하였다. 하지만, 甲은 “청구범위가 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 제한적으로 해석되어야 특허권을 얻을 수 있다”는 전문가의 자문을 받았다.

- (1) 위의 사례에서 구성·효과 등을 중심으로 진보성을 판단하는 데에 필요한 구체적 기준을 설명하시오. (10점)
- (2) 청구범위의 해석에 관한 법리를 설명하고, 위 사례에 적용하여 기술하시오. (8점)
- (3) 상업적 성공과 진보성 판단의 관계를 설명하시오. (7점)
- (4) 온라인 서비스 분야에 속하지 않는 선행기술을 이용하여 위 출원발명의 진보성을 부정할 수 있는지를 기술하시오. (5점)

모범답안

문제 3 모범답안 (30점)

I. 설문 (1) — 구성·효과를 중심으로 한 진보성 판단기준 (10점)

1. 문제의 소재

甲의 출원발명은 하나의 기술적 과제를 해결하기 위하여 선행기술 3개를 결합한 결합발명이므로, 진보성 판단의 일반적 기준과 함께 결합발명 특유의 판단기준을 검토하여야 한다.

2. 진보성 판단의 일반 기준

(1) 판단의 구조

특허출원 전에 공지된 발명으로부터 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 발명할 수 있으면 특허를 받을 수 없다(§ 29②). 판단은 선행기술의 범위와 내용, 출원발명과 선행기술의 차이, 통상의 기술자의 기술수준을 확정된 다음, 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준에 비하여 그 차이를 극복하고 선행기술로부터 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살피는 방식으로 한다. 실무는 가장 가까운 선행기술을 선택하여 차이점을 파악한 후 그 차이를 메우는 것이 쉬운지를 판단한다.

(2) 구성의 곤란성

구성의 곤란성이란 통상의 기술자가 공지기술로부터 동기 유발에 의하여 또는 통상의 창작능력의 발휘를 통하여 출원발명을 쉽게 생각해낼 수 있는지의 기준이다. 동기 유발의 유형으로는 i) 공지기술에 출원발명에 대한 시사가 있는 경우, ii) 과제가 공통되는 경우, iii) 기능·작용이 공통되는 경우, iv) 기술분야의 관련성이 있는 경우가 있다. 또한 최적의 재료 선택, 수치범위의 최적화, 균등물에 의한 치환, 단순한 설계변경이나 용도변경 등은 통상의 창작능력의 발휘이므로, 차이가 이러한 점에만 있으면 진보성이 부정된다.

(3) 효과의 현저성

효과의 현저성이란 그 발명에서 초래되는 효과가 출원 당시의 기술수준으로 보아 예측할 수 없는 유리한 효과인지의 기준으로서, 선행기술과 성질을 달리 하는 이질적 효과이거나 성질은 같으나 현저하게 우수한 효과를 말한다. 판례는 효과의 현저성은 명세서에 적혀 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 구성의 곤란성을 따져보지 아니한 채 효과의 현저성만으로 진보성을 판단하여서는 아니 된다고 한다(2019후10609).

3. 결합발명 특유의 판단기준

(1) 전체로서의 판단

판례는 결합발명의 진보성을 판단할 때 청구항에 적힌 발명을 전체로서 고려하여야 하고 구성요소 각각이 공지이거나 자명하다는 이유만으로 진보성을 부정할 수 없다고 한다. 즉 과제해결원리를 배제한 채 구성을 하나하나 분해하여 대응 구성으로부터의 도출이 곤란한지만을 따질 것이 아니라, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 구성요소들 사이의 결합관계를 포함한 유기적 전체로서의 구성의 곤란성을 살펴야 하며, 결합된 전체 구성이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다(2013후2620).

(2) 결합의 곤란성과 효과의 증진

여러 공지기술을 결합하면 출원발명에 이를 수 있다는 교시·암시·동기가 선행기술에 제시되어 있거나, 출원 당시의 기술수준·기술상식·그 분야의 기본적인 과제·발전경향·업계의 요구에 비추어 통상의 기술자가 쉽게 그 결합에 이를 수 있다면 진보성이 부정된다. 반대로 결합 전 각 기술이 가지던 작용·효과의 단순한 합을 넘는 증진된 효과가 인정되고 통상의 기술자가 그 결합을 쉽게 도출할 수 없다면 진보성이 인정된다(2006후3052 참조).

(3) 사후적 고찰의 금지

진보성은 출원 시를 기준으로 객관적으로 판단하여야 하고, 출원발명의 내용을 알고 난 뒤의 지식으로 선행기술을 재구성하는 사후적 고찰은 허용되지 아니한다. 인용하는 선행기술의 수가 많을수록 그 위험이 커지므로 결합의 동기를 더 엄격히 요구하여야 한다.

4. 결론

甲 발명의 진보성은 ① 선행기술 3개를 결합할 교시·암시·동기가 제시되어 있는지 또는 그 결합이 통상의 창작능력의 발휘에 지나지 아니하는지(구성의 곤란성), ② 결합된 전체 구성이 각 효과의 단순한 합을 넘는 이질적이거나 현저한 효과를 발휘하는지(효과의 현저성)를 기준으로, 사후적 고찰을 배제하고 유기적 전체로서 판단하여야 한다.

II. 설문 (2) — 청구범위 해석의 법리와 사안에의 적용 (8점)**1. 청구범위 기준의 원칙**

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(§ 97). 발명의 설명에 적혀 있더라도 청구범위에 포함되지 아니한 것은 보호범위에 속하지 아니하고, 부적절하거나 명료하지 아니한 용어 선택으로 생긴 불이익은 출원인이 감수하여야 한다. 또한 보호범위는 청구항별로 개별적으로 판단하므로, 특별한 사정이 없는 한 광범위하게 규정된 독립항의 기술내용을 이를 구체적으로 한정된 종속항으로 제한하여 해석할 수 없다(2008후934).

2. 발명의 설명 참작의 원칙

청구범위는 발명의 설명에 적혀 있는 사항 중 보호받으려는 사항을 적은 것이므로(§ 42④), 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 그 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하려는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다. 다만 이는 문언의 의미를 밝히는 참작일 뿐이므로, 특별한 사정이 없는 한 발명의 설명이나 도면에 의하여 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 아니한다.

3. 판단 국면에 따른 차이**(1) 특허요건 판단 — 제한 해석 불가**

신규성·진보성을 판단할 때 대비의 전제가 되는 발명의 내용은 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 확정하여야 하고, 발명의 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 따라 이를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 아니한다. 이는 청구범위가 기능·효과·성질 등 기능적 표현으로 적힌 경우에도 마찬가지여서, 그러한 기능·효과·성질을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석한다(2007후4977). 제한 해석을 허용하면 출원인이 표시한 의사를 심사하는 측에서 임의로 변경하는 결과가 되고, 기재불비가 있거나 특허요건을 갖추지 못한 발명이 등록되는 불합리가 생기기 때문이다.

(2) 보호범위 판단 — 특별한 사정이 있으면 제한 해석 가능

반면 침해 판단이나 권리범위확인의 국면에서는, 청구범위에 적힌 문언만으로 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없거나 문언 그대로 해석하는 것이 명백히 불합리한 특별한 사정이 있으면 발명의 설명과 도면을 보충하여 보호범위를 제한 해석할 수 있고, 공지기술참작의 원칙과 출원결과참작의 원칙도 적용된다. 청구범위에 적혀 있다는 사정만으로 진실로 발명하지 아니한 부분까지 권리를 인정하면 제3자에게 불측의 손해를 주기 때문이다.

4. 사안에의 적용

甲은 기재 자체만으로 발명이 명확하게 이해될 수 있도록 청구범위를 작성하여 참작 해석의 전제가 되는 문언의 불명확성이 없고, 문제 되는 국면은 특허요건 판단의 국면이다. 따라서 발명의 설명이나 도면에 의하여 청구범위를 제한적으로 축소해석할 수 없고, 출원발명은 청구범위 문언대로 확정되어 선행기술 3개와 대비된다.

5. 결론

"청구범위가 발명의 설명 등에 의하여 제한적으로 해석되어야 특허권을 얻을 수 있다"는 자문은 청구범위 해석의 법리에 부합하지 아니한다. 甲이 선행기술과의 차이를 확보하려면 해석에 기댈 것이 아니라 보정으로 청구범위를 실제로 감축하여야 한다(§ 47).

III. 설문 (3) — 상업적 성공과 진보성 판단의 관계 (7점)**1. 문제의 소재**

상업적 성공이라는 시장에서의 사후적 사실이 출원 시를 기준으로 하는 진보성 판단에 어떠한 지위를 가지는지가 문제된다.

2. 참고적 판단방법으로서의 지위

진보성은 구성의 곤란성과 효과의 현저성을 비교하여 판단함이 원칙이고, 진보성의 유무가 모호한 경우에 한하여 진보성 긍정의 참고자료를 활용할 수 있다. 상업적 성공과 이에 따른 모방품의 출현 외에도 i) 효과가 클어도 오랫동안 해결되지 못하던 과제의 해결, ii) 그 분야의 기술적 편견을 극복한 수단의 채용, iii) 타인이 실패한 기술적 곤란의 극복, iv) 관련 선행기술이 없는 첨단 기술분야에 속하는 경우 등이 이에 해당한다.

3. 판례의 태도

판례는 상업적 성공 또는 이에 준하는 사실은 그 성공이 청구항에 적힌 발명의 기술적 특징에 의한 것으로서 판매기술이나 선전·광고기술 등 기술적 특징 이외의 요인에 의한 것이 아니라는 사실을 출원인이 주장·증명하는 경우에 진보성 인정의 긍정적 근거로 참작할 수 있다고 한다(95후1302). 다만 발명품이

종래품을 누르고 상업적 성공을 거두거나 업계의 호평을 받았다는 사정은 인용의 자료가 될 수 있을 뿐 그 자체로 진보성이 있다고 단정할 수 없고, 진보성은 우선 명세서에 적힌 발명의 목적·구성·효과를 토대로 판단하여야 한다고 한다(2004후3546, 2006후3052).

4. 검토

상업적 성공은 발명의 우수성과 무관하게 시장의 판매여건, 광고 전략, 판매자의 독점적 지위 등에 의하여도 달성될 수 있다. 이를 중시하면 비기술적 요소가 진보성 판단을 좌우하게 되어 기술발전의 촉진이라는 제29조 제2항의 취지에 어긋나므로, 2차적·보조적 자료에 그친다고 보는 판례가 타당하다.

5. 결론

甲의 발명이 상업적으로 성공하더라도 그 자체로 진보성이 인정되지는 아니하고, 그 성공이 결합발명의 기술적 특징에서 비롯된 것임을 甲이 주장·증명하는 경우에 진보성 판단이 모호한 범위에서 긍정의 참고자료로 인용될 수 있을 뿐이다.

IV. 설문 (4) — 다른 기술분야의 선행기술로 진보성을 부정할 수 있는지 (5점)

1. 기술분야의 의미

제29조 제2항은 "그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자"를 기준으로 삼는다. 진보성은 둘 이상의 선행기술을 조합하여 판단할 수 있어 판단의 폭이 넓은 대신 기술분야는 좁게 해석하는 것이 일반적이고, 실무는 국제특허분류를 참고한다. 다만 이는 절대적인 기준이 아니어서 기술분야의 관련성, 과제해결의 동일성, 기능의 동일성 등 인용의 타당성을 검토하여 다른 기술분야의 공지기술도 인용할 수 있다.

2. 판례의 법리

판례는 공지기술의 기술적 구성이 i) 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고(범용성), ii) 그 특허발명의 산업분야에서 통상의 기술자가 특허발명이 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면(채택용이성), 이를 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다고 한다(2006후2059).

3. 사안의 포섭

온라인 서비스 분야에 속하지 아니하는 선행기술이라도 그 구성이 특정 분야에만 적용될 수 있는 것이 아니고, 정보통신 분야의 통상의 기술자가 새로운 서비스의 제공이라는 당면 과제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면 인용할 수 있다. 알려진 과제의 해결을 위하여 다른 기술분야를 참조하는 것은 통상의 창작능력의 발휘에 해당하기도 한다.

4. 결론

범용성과 채택용이성이 인정되는 한 온라인 서비스 분야에 속하지 아니하는 선행기술로도 甲 출원발명의 진보성을 부정할 수 있다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

설문	쟁점	배점	특점 포인트
(1)	결합발명의 진보성 판단(구성의 곤란성·효과의 현저성)	10	진보성 일반기준 + 결합발명 특유의 판단(결합의 암시·동기, 상승효과), 사안 포섭
(2)	청구범위 해석 범위 및 사안 적용	8	원칙(청구범위 기준의 원칙)·발명의 설명 참작의 원칙, 특허요건 판단 국면에서는 제한·확장해석 불가(2007후4977)·보호범위 판단 국면에서는 특별한 사정 시 제한해석 가능이라는 국면 구분, 사안이 특허요건 국면임을 밝혀 자문의 부당성 결론
(3)	상업적 성공과 진보성의 관계	7	보조자료(2차적 고려요소)에 불과, 기술적 특징 유래 요건, 판례 태도와 자기견해
(4)	상이한 기술분야 선행기술의 인용가부	5	원칙적 부정·예외적 긍정 기준(특정분야 한정 아닌 구성+통상의 기술자가 어려움 없이 이용), 사안 포섭
합계		30	

축별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- (1) 단순한 진보성 일반론이 아니라 **결합발명**임을 포착하여 결합의 곤란성·상승효과라는 특유 판단기준을 적시했는가.
- (2) 청구범위 기준의 원칙과 발명의 설명 참작의 원칙을 모두 잡고, 나아가 특허요건 판단 국면과 보호범위 판단 국면에서 제한해석의 가부가 달라진다는 점을 구분했는가. 사안이 특허를 받기 위한 특허요건 판단 국면임을 밝혀 전문가 자문의 당부를 결론지었는가.
- (3) 상업적 성공이 진보성 **인정의 보조자료**에 불과하며, **기술적 특징에서 비롯되어야** 참작 가능하다는 판례 법리를 정확히 적시했는가.
- (4) 제29조 제2항의 '기술분야'에 대한 판례의 예외적 확장 법리(특정분야 한정 구성 아님 + 통상의 기술자의 이용가능성)를 적시했는가.
- 채점평 반영: 문제를 자의적으로 해석하여 묻지 않은 쟁점(예: 신규성·명세서 기재불비 일반론)을 장황히 서술하면 감점.

2) 목차·구성(25%)

- 설문 (1)~(4)를 **분리된 대목차(I~IV)**로 구분하고 각 설문마다 소목차(서설-법리-사안적용-결론)를 갖추었는가.
- 배점(10:8:7:5)에 비례해 분량을 배분했는가. 특히 설문(1)에 결합발명 특유 논점 분량을 충분히 할애했는가.
- 조문 → 판례 → 사안 순의 구성을 유지했는가.
- 채점평 반영: **소제목을 붙여** 논지를 드러냈는가(소제목 부재 시 감점).

3) 답안 작성·논증(35%)

- 조문(§ 29②, § 42④·⑥) 근거 제시 후 판례 법리를 정확히 인용했는가.
- 결합발명 판례(각 구성 간 결합의 암시·동기, 유기적 결합 전체의 구성 곤란성·특유 효과), 청구범위 해석 판례, 상업적 성공 판례, 상이 기술분야 판례를 사안에 포섭했는가.
- 각 설문에 **명확한 결론**과 자기 견해가 있는가.
- 채점평 반영: **읽을 수 있는 글씨**로 작성했는가. 판례의 결론만 나열하고 사안 포섭이 부실하면 감점.

감점 주의

- 결합발명임을 포착하지 못하고 진보성 일반론(목적특이성·구성곤란성·효과현저성)만 나열 → 설문(1) 대폭 감점.
- 청구범위 해석에서 원칙(청구범위 기재 문언)과 발명의 설명 참작을 구분하지 않고 한쪽만 서술하거나, 특허요건 판단과 보호범위 판단의 국면 차이를 언급하지 않은 채 제한해석이 일반적으로 허용된다고 서술.
- 상업적 성공을 진보성 인정의 독립적 근거로 오인하여 서술.
- 상이 기술분야 논점에서 판례의 예외 요건(특정분야 한정 아닌 구성 + 통상의 기술자의 어려움 없는 이용)을 누락한 채 '기술분야 동일해야 한다'로만 결론.
- 사안 포섭 없이 판례·심사기준의 추상적 법리만 반복.
- 소제목 없이 줄글로 서술, 판독 불가능한 필체(채점평 직접 지적).

2014년 제4문

사례형

20점

문제

甲은 자기의 특허발명 내용 중 일부를 바꾸어 물품을 생산·판매하여 수익을 올린 乙에 대하여 더 이상 특허권을 침해하지 못하게 할 목적으로 경고장을 보냈으나, 乙은 이에 대하여 응하지 않고 자기가 생산·판매한 물품은 甲의 특허발명과 무관하다고 주장하였다. 乙은 오히려 자기의 물품은 자유기술을 바탕으로 자기의 아이디어를 덧붙여 만들어낸 것이라는 점에서 甲의 특허발명은 자기의 물품과 관련 없다고 생각하였다. 이에 甲은 乙에 대하여 특허심판원에 권리범위확인심판을 청구하였고, 민사법원에 특허권침해에 대한 금지청구 및 손해배상청구의 소를 제기하였다. 한편 乙은 甲에 대하여 특허의 무효심판을 청구하였다.

(1) 乙은 甲에 대하여 “甲의 특허발명은 선행기술에 의하여 쉽게 아이디어를 얻을 수 있는 것임에도 불구하고 특허권이 허여되었음”을 주장함으로써 甲과의 다툼에서 벗어나고 싶다. 침해소송에서 乙의 항변으로 검토할 수 있는 법적 방안을 제시하시오. (10점)

(2) 甲의 특허출원의 심사과정에서 청구범위가 지나치게 넓다는 지적을 받아 그 청구범위가 축소 보장되었던 사실이 있고, 甲이 乙에 대하여 균등론에 기한 특허권 침해를 주장하는 경우에 乙의 대응방안을 기술하시오. (10점)

모범답안

문제 4 모범답안 (20점)

I. 설문 (1) — 침해소송에서 乙이 검토할 수 있는 항변 (10점)

1. 문제의 소재

乙이 드는 사유는 甲의 특허발명이 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다는 것이다. 특허요건의 흠결에도 착오로 등록된 경우 그 하자를 이유로 침해소송에서 i) 특허권이 당연무효라고 할 수 있는지, ii) 권리범위를 부정할 수 있는지, iii) 권리행사를 제한할 수 있는지를 차례로 검토한다.

2. 권리의 유효성을 부정할 수 있는지

특허권은 하자가 있더라도 특허취소결정이나 무효심결이 확정되어 소멸하기 전까지는 일응 유효한 권리로 보아 법적 안정성을 도모하여야 하므로, 다른 절차에서 특허가 당연무효라고 판단할 수는 없다(97후2095). 특허권은 특허결정과 설정등록이라는 행정처분으로 발생하여 공정력이 있고, 하자 있는 행정처분이 당연무효가 되려면 그 하자가 중대하고 객관적으로 명백하여야 하는데, 진보성의 흠결은 법적 평가의 성격을 가져 판단이 자명하지 아니하므로 중대·명백한 하자가 아니다. 따라서 乙은 당연무효를 주장할 수 없고, 무효를 구하려면 무효심판(§ 133)에 의하여야 한다.

3. 권리범위를 부정할 수 있는지

하자가 있는 특허권이라도 권리가 유효한 이상 원칙적으로 권리범위가 인정된다. 다만 특허발명이 공지기술과 동일하여 신규성이 없는 경우에는 새로운 발명의 공개 없이 착오로 등록된 것이어서 무효심결의 확정 전이라도 권리범위를 인정하지 아니한다(81후56 전원합의체). 그러나 진보성이 부정된다는 이유로는 권리범위를 부정할 수 없고, 이는 권리범위확인심판에서도 마찬가지이다(2012후4162 전원합의체). 사안에서 乙이 드는 사유는 진보성의 흠결이므로, 침해소송에서 甲이 청구한 권리범위확인심판에서도 이를 들어 권리범위의 부정을 구할 수는 없다.

4. 권리행사를 제한할 수 있는지

(1) 판례

판례는 진보성이 없어 공중에게 개방되어야 할 기술을 독점시키는 것은 공공의 이익을 훼손하고 특허법의 입법목적에 배치되며, 보호가치 없는 발명이 형식적으로 등록되어 있음을 기화로 실시자를 상대로 청구하는 것은 실질적 정의와 형평에도 어긋난다고 한다. 그리하여 무효심결의 확정 전이라도 진보성이 부정되어 무효로 될 것이 명백하면 그 특허권에 기초한 침해금지·손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용으로서 허용되지 아니하고, 법원은 그 항변의 당부를 살피기 위한 전제로서 진보성 여부를 심리·판단할 수 있다고 한다(2010다95390 전원합의체).

(2) 특별한 사정

여기의 특별한 사정이란 무효사유가 있더라도 정정심판이나 정정청구로 이를 극복할 수 있는 사정을 말한다. 다만 판결이 확정되거나 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결을 토대로 사실심의 판단을 다투는 것은 허용되지 아니한다(2016후2522 전원합의체).

(3) 사안의 포섭

권리범위는 부정되지 아니하나 권리행사는 제한될 수 있으므로, 이 항변이 乙에게 가장 유력하다. 乙이 선행기술로부터 甲의 특허발명을 쉽게 발명할 수 있었음을 주장·증명하여 무효로 될 것이 명백하다고 인정되면, 甲의 침해금지청구와 손해배상청구는 권리남용으로서 배척된다.

5. 절차적 방안

乙은 무효심판을 청구하고 그 심결이 확정될 때까지 소송절차의 중지를 신청할 수 있다. 중지 여부는 법원의 재량이며, 무효심결이 확정되면 특허권은 처음부터 없었던 것으로 되어 甲의 청구는 받아들여질 수 없다. 甲의 승소판결 확정 후에 무효심결이 확정되면 재심을 청구할 수 있다. 한편 자유기술의 항변은 특허발명의 하자를 다루는 위 항변들과 달리 乙의 물품을 공지기술과 대비하는 것이므로 설문 (2)에서 본다.

6. 결론

乙은 당연무효를 주장할 수 없고 진보성의 흠결로 권리범위의 부정을 구할 수도 없다. 다만 무효로 될 것이 명백함을 주장·증명하여 甲의 권리행사가 권리남용이라는 항변을 할 수 있고, 무효심판의 청구와 소송절차 중지신청을 병행함이 바람직하다.

II. 설문 (2) — 균등침해 주장에 대한 乙의 대응방안 (10점)

1. 균등침해의 요건

판례는 확인대상발명에 변경된 부분이 있더라도 i) 과제의 해결원리가 동일하고, ii) 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, iii) 그 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도이며, iv) 특별한 사정이 없는 한 균등한 것으로서 권리범위에 속한다고 한다(2013다14361). i)~iii)은 특허권자가 증명할 적극적 요건이고, iv)는 실시자가 항변할 소극적 요건이다.

2. 적극적 요건을 다루는 방안

과제해결원리의 동일성은 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인지를 선행기술과 대비하여 실질적으로 탐구해 판단하고(2017후424), 작용효과와 실질적 동일성은 선행기술이 해결하지 못한 과제를 확인대상발명도 해결하는지를 중심으로 본다(2018다267252). 乙은 변경한 부분이 기술사상의 핵심이어서 해결원리가 다르고, 자기 물품은 그 과제를 해결하지 아니하며, 그 변경이 쉽게 생각해 낼 정도가 아니라고 다룰 수 있다.

3. 출원경과참작에 의한 항변

(1) 의의와 적용대상

출원경과참작의 원칙이란 출원 중 감축 등으로 어떤 구성을 보호범위에서 제외하려는 의사가 있었던 경우, 등록 후 그 구성이 균등범위라는 이유로 보호범위에 속한다고 주장함을 금하는 것이다. 스스로 감축하여 특허를 받은 이상 그 부당성을 다룰 절차적 권리는 소멸하였고, 공시된 심사과정을 신뢰한 제3자를 보호하여야 하기 때문이다. 선행기술 회피는 물론 기재불비 등 다른 거절이유 회피를 위한 보정에도 적용된다(2005도4210).

(2) 의식적 제외의 판단기준

의식적으로 제외되었는지는 명세서뿐만 아니라 출원에서 특허될 때까지 심사관이 제시한 견해와 출원인의 보정서·의견서에 나타난 의도와 보정이유를 참작하여 판단한다. 따라서 청구범위의 감축이 있었다는 사실만으로 감축 전후의 모든 구성이 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하려는 의도로 그 구성을 배제하는 감축을 한 경우와 같이 출원과정에 드러난 사정을 종합할 때 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에만 인정된다(2014후638). 감축만으로 균등을 자동 배제하는 엄격한 기준과 달리 우리 판례는 유연한 기준을 취하는바, 의식적 제외를 넓게 인정하면 균등론의 적용 여지가 없어지므로 그 취지가 명확한 경우에만 인정하여야 한다.

(3) 사안의 포섭

甲은 청구범위가 지나치게 넓다는 지적을 받고 축소 보정을 하였으나, 그 사실만으로 감축 전후의 모든 구성이 제외되었다고 볼 수는 없다. 따라서 乙은 심사관의 견해와 甲의 보정서·의견서에 나타난 보정이유를 확보하여 甲이 자기 물품에 해당하는 구성을 제외하려는 의사가 명백히 드러났음을 증명하여야 하고, 그것이 인정되면 甲은 그 구성에 균등을 주장할 수 없다.

4. 자유기술의 항변

확인대상발명이 공지기술만으로 이루어지거나 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있으면 특허발명과 대비할 필요 없이 그 권리범위에 속하지 아니하는데, 실시자가 이를 이유로 항변하는 것이다. 이는 권리범위 자체를 부정하는 것이 아니라 비교의 대상을 공지기술과 확인대상발명으로 바꾸는 것이어서, 특허발명의 하자를 다룰 수 없는 국면에서도 쓸 수 있다. 판단의 대상은 특정된 확인대상발명의 구성 전체이고(2008후64), 대비 이전에 자유기술의 영역에 속함을 이유로 하므로 문언침해인지 균등침해인지를 가리지 아니하고 적용된다(2016후366). 乙은 자기 물품이 자유기술에 아이디어를 더한 것이라고 주장하므로, 그 구성 전체가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있음을 증명하면 甲의 균등침해 주장은 배척된다.

5. 결론

乙은 적극적 요건을 다루는 한편, 출원경과를 확보하여 제외 의사가 드러났음을 주장하고 자유기술의 항변을 할 수 있다. 감축 사실만으로는 의식적 제외가 인정되지 아니하므로, 보정이유가 드러나지 않으면 자유기술의 항변이 더 실효적이다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
(1) 진보성 무효사유의 침해소송 내 주장 가부	2점	무효심결 확정 전이라도 무효사유 명백성 심리 가능(판례) 적시
(1) 특허권 당연무효 주장 가부	1점	등록주의·권한분배 원칙상 다른 절차에서 당연무효 판단 불가
(1) 진보성 하자 있는 특허의 권리범위 부정 주장	2점	공지기술 판례와 대비, 진보성 부정 시 권리범위 부정 여부 논증
(1) 권리남용 항변(대법원 2010다95390 전합)	5점	진보성 부정으로 무효 명백 시 침해금지·손배 청구는 권리남용, 사안 포섭
(2) 균등론 요건 및 균등물 부정 주장	3점	적극적 3요건(과제해결 동일성·치환가능성·치환용이성) 결여 주장
(2) 출원경과금반언(의식적 제외) 항변	5점	축소보정 사실 → 감축된 부분은 균등영역에서 제외, 판례 법리 적용
(2) 자유실시기술 항변	2점	乙 실시가 공지기술로부터 용이 도출 가능하면 균등침해도 부정

합계: 20점

축별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- **특점:** 설문(1)에서 침해소송 내 방어수단을 ① 무효항변 심리가가능성 ② 당연무효 주장 불가 ③ 권리범위 부정 ④ **권리남용 항변(핵심)** 의 4단계로 빠짐없이 적시. 특히 대법원 2012.1.19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결(진보성 흠결로 무효 명백 시 권리남용)을 최우선 논점으로 배치.
- **특점:** 설문(2)에서 출원과정에서 **축소보정 사실**이라는 사안 특정 사실을 잡아 출원경과금반언(의식적 제외설)을 핵심 논점으로 배치.
- **감점:** 설문(1)에서 무효심판 청구 사실만 언급하고 침해소송 내 항변을 논하지 못한 답안. 권리남용 판례를 빠뜨린 답안(가장 큰 감점).
- **감점:** 설문(2)에서 축소보정이라는 사안 사실을 활용하지 못하고 균등론 일반론만 나열한 답안. 채점평이 지적한 "자의적 해석"에 해당.

2) 목차·구성(25%)

- **특점:** 설문(1)·(2)를 로마숫자로 구분하고, 항변사유별 소제목(무효항변/당연무효/권리범위 부정/권리남용, 균등물 부정/의식적 제외/자유실시기술)을 별개 목차로 세분화.
- **특점:** 배점 비례 — 권리남용과 의식적 제외에 지면 집중.
- **감점:** 채점평이 명시적으로 지적한 "소제목 없는 서술", 균등론 일반론 장황 서술.

3) 답안 작성·논증(35%)

- **특점:** 조문(§ 29②, § 1) → 판례(2010다95390 전합, 출원경과금반언 판례) → 사안 포섭(축소보정 사실, 심사관의 넓다는 지적) → 소결 순으로 논증.
- **특점:** 학설 대립(엄격한 기준 vs 유연한 기준) 언급 시 자기 입장 표명.
- **감점:** 판례 결론만 나열하고 사안에 포섭하지 않는 답안. 권리남용의 요건(무효 명백성) 검토 없이 결론만 제시.

감점 주의

- 채점평 지적: **자의적 해석**으로 문제가 요구하지 않은 무효심판 절차·심결취소소송 등을 장황히 서술하는 실수.
- 권리남용 항변의 근거 판례(2010다95390 전합) 미인용 또는 요건(무효 명백성) 누락.
- 설문(2)에서 축소보정 사실을 사안에 포섭하지 못하고 균등론 5요건만 나열.
- **읽을 수 없는 필체·소제목 부재**(채점평 명시).
- 자유실시기술 항변을 균등침해 판단 단계에서 배치하지 못하고 문언침해 단계에서만 언급.

PART 6

2015

제1문	국어번역문·청구범위 법정 제출기간 및 미제출 시 조치·이유 · 영어논문 명세서와 국어번역문의 법적지위	30점
제2문	청구범위해석에 근거한 적극적 권리범위확인심판 청구이유 · 판례에 근거한 제1항 무효 청구이유(PBP청구항)	20점
제3문	조약우선권 주장의 주체적·시기적·객체적 요건 · 조약우선권 주장출원의 실체심사 — 발명의 동일성 판단	30점
제4문	(설문1) 무효심판 청구인 적격 - 이해관계인 개념 · (설문1) 실시권자의 이해관계 인정 여부 - 학설	20점

2015년 제1문

사례형

30점

문제

甲은 한국특허공보 7호에 기재된 “구성요소(A)와 원터치장치(B)로 구성된 스마트폰 구동시스템”의 기술을 인지하고 이를 분석한 결과, 누구나 쉽게 구동시킬 수 있는 보안상의 문제점을 발견하고 이를 해소하고자 지문인식시스템을 연구하였다. 甲은 그 연구물을 다음과 같은 내용으로 전자공학저널에 영문으로 게재하였다.

한국특허공보 7호에 기재된 구성요소(A)와 원터치장치(B)로 구성된 스마트폰 구동시스템은 불특정인이 구동시킬 수 있는 문제점이 있기 때문에 원터치 장치(B) 대신에 지문인식시스템(D)으로 구성되고, 또한 지문인식시스템(D)은 유전자지문인식시스템(d)으로 구성되고, 인지시간이 3~5초 내에서 작동하는 스마트폰 구동시스템

그 후 甲은, 전자공학저널에 게재된 영어논문을 명세서로 하여 외국어특허출원을 하였고, 그 영어논문 명세서에 대하여 다음과 같이 국어번역문을 법정기간 내에 지식재산처에 제출하였다.

구성요소(A)와 원터치장치(B)로 구성된 스마트폰 구동시스템은 불특정인이 구동시킬 수 있는 문제점이 있기 때문에 원터치장치(B) 대신에 지문인식시스템(D)으로 구성되고, 또한 지문인식시스템(D)은 생체지문인식시스템(d)으로 구성되고, 인지시간이 2~5초 내에서 작동하는 스마트폰 구동시스템

그리고 甲은 외국어특허출원에 대하여 다음과 같이 청구범위를 법정기간 내에 지식재산처에 제출하였다.

제1항 구성요소(A)와 지문인식시스템(D)으로 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트폰 구동시스템

제2항 제1항에 있어서, 지문인식시스템(D)은 생체지문인식시스템(d)으로 구성되는 것을 특징으로 하는 스마트폰 구동시스템

위 사실만을 근거로 다음 물음에 답하시오.

- (1) 국어번역문과 청구범위를 제출할 수 있는 법정기간을 설명하고, 만약 그 법정기간 내에 제출하지 않는 경우에 취해지는 조치와 그 이유를 설명하시오. (6점)
- (2) 외국어특허출원 시에 첨부된 영어논문 명세서와 그 국어번역문의 법적지위를 설명하시오. (6점)
- (3) 甲이 제출한 국어번역문에 영어논문의 “인지시간이 3~5초”를 “인지시간이 2~5초”로 잘못 번역한 것을 국어번역문의 제출기간이 경과한 후 인지한 경우, 甲이 취할 수 있는 조치와 그 법적효과를 설명하시오. (5점)
- (4) 甲이 제출한 국어번역문과 청구범위의 흠결을 각각 지적하고 (단, 2~5초로 잘못 번역된 것은 제외한다.), 그 흠결의 해소방안을 설명하시오. (13점)

모범답안

문제 1 모범답안 (30점)

I. 설문 (1) — 국어번역문·청구범위의 제출기간과 미제출 시의 조치 (6점)

1. 외국어특허출원제도

(1) 의의 및 취지

출원인이 명세서 및 도면을 영어로 적겠다는 취지를 출원서에 적으면 영어로 적을 수 있다(§ 42의3①). 영어 논문 등을 그대로 이용해 빠른 출원일을 확보하도록 2015. 1. 1. 시행 개정법이 도입하였고, 출원서와 요약서는 국어로 작성하여야 한다.

(2) 국어번역문의 제출기간

출원일(우선권 주장 시 최우선일)부터 1년 2개월이 되는 날까지 명세서 및 도면의 국어번역문을 제출하여야 하고, 그 전에 제3자의 출원심사청구 취지를 통지받으면 통지일부터 3개월이 되는 날과 위 날 중 빠른 날까지 제출하여야 한다(§ 42의3②). 분할·변경출원이 외국어특허출원이면 위 기한 후에도 그 출원일부터 30일 이내에 제출할 수 있다(§ 52⑦, § 53⑦).

2. 청구범위 제출유예제도

(1) 의의 및 취지

출원인은 청구범위를 적지 아니한 명세서를 출원서에 첨부할 수 있고, 이 경우에도 발명의 설명은 적어야 한다(§ 42의2①). 청구범위 작성에 시간이 걸리더라도 출원일을 먼저 확보하도록 한 것이다.

(2) 청구범위의 제출기간

국어번역문의 제출기간과 같은 기간에 청구범위를 적는 보정을 하여야 한다(§ 42의2②). 출원심사를 청구하려면 그 전에 청구범위가 적혀 있어야 한다 (§ 59②).

3. 미제출 시의 조치와 그 이유**(1) 조치 — 취하 간주**

명세서의 국어번역문을 제출하지 아니하거나(§ 42의3④) 청구범위를 적는 보정을 하지 아니하면(§ 42의2③) 그 기한의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다. 다만 도면 중 설명부분의 국어번역문 미제출은 취하 간주 사유가 아니고 기재요건 위반으로 보정 대상이 될 뿐이다.

(2) 이유

두 제도 모두 출원일을 앞당겨 확보하도록 한 예외이므로, 기간 내에 국어번역문과 청구범위가 갖추어지지 아니하면 심사·공개할 발명을 국어로 확정할 수 없어 절차를 진행할 수 없다. 취하된 출원은 출원공개 대상에서 제외되고 선출원의 지위도 상실하므로 출원인이나 제3자가 같은 발명을 다시 출원할 기회도 확보된다.

4. 결론

甲은 위 각 기간 내에 국어번역문을 제출하고 청구범위를 적는 보정을 하여야 하며, 미이행 시 그 기한의 다음 날에 출원이 취하된 것으로 본다.

II. 설문 (2) — 영어 명세서와 국어번역문의 법적 지위 (6점)**1. 영어 명세서의 법적 지위****(1) 제47조 제2항 전단의 신규사항 판단대상**

외국어특허출원의 영어 명세서는 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면에 해당한다. 보정은 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 적힌 사항의 범위에서 하여야 하므로(§ 47②전단), 국어번역문이나 그 후의 보정이 영어 명세서에 없는 사항을 담으면 신규사항 추가가 되어 거절이유·정보제공사유가 되고 등록 후에는 무효사유가 된다(§ 133①).

(2) 새로운 출원 등의 기초

확대된 선출원의 지위, 분할출원·변경출원의 범위, 국내우선권주장출원의 범위도 영어 명세서에 적힌 사항을 기준으로 판단하므로, 영어 명세서는 그 출원에서 파생되는 새로운 출원의 객체적 범위를 정하는 기초가 된다.

2. 국어번역문의 법적 지위**(1) 보정의 간주**

국어번역문 또는 새로운 국어번역문을 제출하면 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 그 국어번역문에 따라 보정한 것으로 본다(§ 42의3⑤본문). 따라서 심사와 공개는 국어번역문을 기초로 이루어진다.

(2) 제47조 제2항 후단의 신규사항 판단대상

외국어특허출원에 대한 보정은 최종 국어번역문 또는 최초로 첨부한 도면에 적힌 사항의 범위에서 하여야 하고(§ 47②후단), 오역정정이 있으면 정정된 국어번역문이 그 판단대상이 된다.

(3) 최종 국어번역문 이외의 보정의 실효

국어번역문은 제출기한 이전에 새로운 국어번역문으로 갈음할 수 있고, 이 경우 최종 국어번역문 전에 제출한 국어번역문에 따라 보정한 것으로 보는 모든 보정은 처음부터 없었던 것으로 본다(§ 42의3⑤단서). 다만 명세서·도면을 보정하였거나 출원인이 심사청구를 한 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다(§ 42의3③단서).

(4) 절차 진행의 전제

외국어특허출원은 국어번역문을 제출하기 전까지는 명세서의 보정, 분할출원, 변경출원, 출원인의 심사청구를 할 수 없고 출원공개도 되지 아니한다. 국어번역문 제출은 이후 절차 진행의 전제가 된다.

3. 결론

영어 명세서는 최초로 첨부한 명세서로서 제47조 제2항 전단의 신규사항 판단대상이자 새로운 출원의 기초가 되고, 국어번역문은 그 제출로써 보정 간주되어 제47조 제2항 후단의 신규사항 판단대상이자 절차 진행의 전제가 된다.

III. 설문 (3) — 제출기간이 지난 후 오역을 발견한 경우의 조치와 효과 (5점)**1. 문제의 소재**

국어번역문의 제출기간이 지난 이상 새로운 국어번역문으로 갈음할 수 없으므로(§ 42의3③), 오역을 시정할 다른 수단과 그 효과가 문제된다.

2. 甲이 취할 수 있는 조치

(1) 오역의 정정

특허출원인은 제47조 제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 오역을 정정할 수 있다(§ 42의3⑥전단). 오역정정의 내용을 적은 국어번역문 오역 정정서에 정정이유를 적은 설명서를 첨부하여 제출하여야 한다.

(2) 별도의 보정

정정된 국어번역문에는 보정의 효과가 부여되지 아니하므로(§ 42의3⑥후단), 심사의 대상인 명세서와 청구범위를 바로잡으려면 오역정정과 별도로 보정을 하여야 한다.

3. 법적 효과

(1) 신규사항 판단의 기준

정정된 국어번역문이 제47조 제2항 후단에 따른 신규사항 판단의 대상이 된다. 따라서 정정 후에는 '인지시간 3~5초'를 기준으로 보정의 적법 여부를 판단한다.

(2) 종전 정정의 실효

거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 오역정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(§ 42의3㉔).

4. 결론

甲은 보정을 할 수 있는 기간에 오역 정정서를 제출하여 '2~5초'를 '3~5초'로 정정하고, 이와 별도로 명세서와 청구범위에 대한 보정을 하여야 한다. 이는 영어 명세서에 적힌 사항의 범위 내이므로 신규사항의 추가에 해당하지 아니한다.

IV. 설문 (4) — 국어번역문과 청구범위의 흠결 및 해소방안 (13점)

1. 국어번역문의 흠결

(1) 선행기술문헌 정보의 누락

발명의 설명에는 그 발명의 배경이 되는 기술을 적어야 하고, 그 배경이 되는 기술을 나타내는 문헌 정보도 적어야 한다(§ 42③(2)). 영어 명세서에는 종래 기술의 출처로 '한국특허공보 7호'가 적혀 있으나 국어번역문에는 이것이 누락되어 있으므로 위 기재요건을 갖추지 못하였다. 다만 이는 거절이유가 될 뿐이고, 무효사유로 규정된 제42조 제3항 제1호나 제4항의 위반과 달리 등록 후의 무효사유에는 해당하지 아니한다(§ 133①(1) 참조).

(2) 원문과 다른 번역 — 신규사항의 추가

국어번역문의 제출로 최초 명세서를 그 번역문에 따라 보정한 것으로 보므로(§ 42의3⑤본문), 국어번역문에 영어 명세서에 없는 사항이 있으면 신규사항의 추가가 된다(§ 47② 전단). 영어 명세서에는 지문인식시스템(D)이 '유전자지문인식시스템(d)'으로 구성된다고 적혀 있는데 국어번역문에는 '생체지문인식시스템(d)'으로 적혀 있다. 유전자지문과 생체지문은 인식의 대상과 방식이 다른 별개의 구성이어서 자명하게 이해할 수 있는 사항이라고 볼 수 없으므로, 이는 영어 명세서에 없는 사항으로서 신규사항의 추가에 해당한다. 따라서 거절이유·정보제공사유가 되고 등록 후에는 무효사유가 된다(§ 133①). 나아가 국어번역문의 발명의 설명이 개시하지 아니한 구성을 실시하도록 하는 것이어서 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적었다고 보기도 어렵다(§ 42③(1)).

2. 청구범위의 흠결

(1) 제1항

청구항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다(§ 42④(1)). 발명의 설명에는 지문인식시스템(D)이 특정한 하위 구성으로 이루어지고 인지시간이 일정한 범위에서 작동하는 구성만이 개시되어 있는데, 제1항은 구성요소(A)와 지문인식시스템(D)만을 아무런 한정 없이 적고 있다. 이는 발명의 설명이 개시한 범위를 넘어 청구범위를 지나치게 넓게 기재한 것이어서 뒷받침 요건에 위반되고, 이는 등록 후의 무효사유에도 해당한다(§ 133①(1)).

(2) 제2항

제2항은 지문인식시스템(D)이 '생체지문인식시스템(d)'으로 구성된다고 적고 있으나, 이는 영어 명세서에 없는 사항이므로 신규사항의 추가에 해당한다(§ 47② 전단). 국어번역문의 발명의 설명에는 같은 기재가 있으나 그 기재 자체가 신규사항으로서 적법하지 아니하므로 이를 뒷받침의 근거로 삼을 수 없고, 결국 제2항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 할 수 없다(§ 42④(1)).

3. 흠결의 해소방안

(1) 국어번역문 제출기간이 지나지 아니한 경우

새로운 국어번역문을 제출하여 '생체지문인식시스템(d)'을 '유전자지문인식시스템(d)'으로, 누락된 선행기술문헌 정보를 바로잡을 수 있다(§ 42의3③본문). 이 경우 종전 국어번역문에 따라 보정한 것으로 보는 모든 보정은 처음부터 없었던 것으로 보므로 위 흠결이 일괄하여 해소된다(§ 42의3⑤단서). 다만 이미 명세서를 보정하였거나 출원인이 심사청구를 한 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다(§ 42의3③단서).

(2) 국어번역문 제출기간이 지난 경우

보정을 할 수 있는 기간에 오역 정정서를 제출하여 '유전자지문인식시스템(d)'으로 정정하고(§ 42의3⑥전단), 오역정정에는 보정의 효과가 없으므로 별도로 명세서와 청구범위를 같은 내용으로 보정하여야 한다. 이는 영어 명세서에 적힌 사항의 범위 내이므로 신규사항의 추가가 되지 아니한다.

(3) 그 밖의 흠결

선행기술문헌 정보는 영어 명세서에 적혀 있으므로 그 범위에서 보정하여 보충할 수 있고, 제1항은 지문인식시스템의 하위 구성과 인지시간을 부가하는 보정으로 발명의 설명에 의하여 뒷받침되도록 한정할 수 있다. 어느 것이나 영어 명세서와 최종 국어번역문에 적힌 사항의 범위에서 하여야 하고(§ 47②), 최후거절이유통지에 대한 보정에서는 청구범위의 감축 등으로 그 범위가 다시 제한된다(§ 47③).

4. 결론

국어번역문에는 선행기술문헌 정보의 누락과 '생체지문인식시스템'이라는 원문에 없는 기재로 인한 흠결이 있고, 청구범위에는 제1항의 뒷받침 요건 위반과 제2항의 신규사항 추가라는 흠결이 있다. 甲은 국어번역문 제출기간 내에는 새로운 국어번역문으로, 그 기간이 지난 후에는 오역정정과 별도의 보정으로 이를 해소할 수 있다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
(1) 국어번역문·청구범위 법정 제출기간 및 미제출 시 조치·이유	6	최선일 1년2월 원칙, 제60조 제3항 통지 특칙, 분할출원 제52조 제7항·변경출원 제53조 제7항의 30일 특례, 미제출 시 취하간주(\$42의3④, \$42의2③), 공개대상 제외(\$64(2))와 그 이유(선원·확대선원 지위 부존재로 제출원 가능성 확보)
(2) 영어논문 명세서와 국어번역문의 법적지위	6	외국어명세서=최초첨부명세서, 보정범위 판단기준, 확대된 선출원의 기준은 제29조 제3항 본문의 '출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면'(=외국어 원문)이 그대로 적용됨(\$29⑤)는 국제특허출원 특칙이므로 국내 외국어출원에는 부적용), 국어번역문 = 보정 간주(\$42의3⑤), 심사기준·무효사유(\$62(5), \$133①(6)) 이중구조
(3) 오역 인지 시 조치와 법적효과	5	제47조 제1항 기간 내 오역정정(\$42의3⑥) 가능, 정정에 보정효과 부여되지 않음 → 별도 보정서 제출 필요
(4) 번역문·청구범위의 흠결 지적 및 해소방안	13	① 제42조 제3항(2) 배경기술·선행기술문헌정보 미기재 흠결, ② 원문(유전자지문)↔번역문(생체지문) 불일치에 따른 제42조 제3항(1)·제42조 제4항(1)·제47조 제2항 흠결, ③ 해소방안 - 번역문 제출기간 내: 새 국어번역문 제출(\$42의3③), 경과 후: 오역정정(\$42의3⑥) + 별도 보정서 제출

배점 합계: 30점

축별 채점 기준

1) 논점 추출 (약 40%)

- **특점:** 설문별로 묻고 있는 대상(기간·법적지위·조치·흠결)을 정확히 구분하여 각각의 쟁점을 빠짐없이 적시. 특히 (4)에서 배경기술 미기재(\$42③(2)), 실시가능요건(\$42③(1)), 뒷받침요건(\$42④(1)), 신규사항추가금지(\$47②) 4개 흠결을 모두 잡아냈는가.
- **감점:** (1)에서 제60조 제3항 특칙·분할출원 제52조 제7항 특례 누락, (2)에서 국어번역문의 '보정 간주' 효과 누락 또는 제29조 제5항을 국내 외국어출원에 오용, (3)에서 '정정에는 보정효과 없음'을 놓치고 오역정정만 서술, (4)에서 흠결을 1~2개만 지적하고 마무리한 경우. 문제와 무관한 외국어출원 도입 취지·연혁 나열은 배점 없음.

2) 목차·구성 (약 25%)

- **특점:** 설문 (1)~(4)를 로마숫자로 구분하고, (4)와 같이 배점이 큰 설문에는 흠결별 세목차(1. 국어번역문 흠결 / 2. 청구범위 흠결 / 3. 해소방안)로 체계화. 조문·판례·사안포섭·소결 구분.
- **감점:** 6점짜리 (1)(2)에 지면 과다 배분, 13점짜리 (4)에 지면 부족. 서론에 외국어출원제도 취지 상황 서술, 조문 전사식 나열, 목차 없이 서술식 나열.

3) 답안 작성·논증 (약 35%)

- **특점:** 조문(\$42의3, \$42의2, \$47, \$29③ 등) → 사안 포섭 → 소결의 흐름. (4)에서 '원문의 유전자지문인식시스템 ↔ 번역문의 생체지문인식시스템' 불일치라는 사실을 특정하여 제47조 제2항 신규사항 추가 위반으로 포섭. 해소방안을 번역문 제출기간 경과 여부로 나누어 결론 도출.
- **감점:** 조문번호 오기(예: \$52⑤로 잘못 인용, \$29⑤를 국내 외국어출원에 오용), 오역정정과 보정을 혼동하여 오역정정만으로 흠결이 치유된다고 서술, '보정으로 해소하면 된다'는 일반론적 결론, 본문↔결론 모순.

감점 주의

- 채점평 지적대로 **문제와 무관한 일반론(외국어출원제도 도입취지·PCT 국내단계 특칙 등)**을 나열하고 정작 흠결 지적·해소방안을 소략하게 처리한 답안 다수 → 감점.
- (3)·(4)에서 **오역정정(\$42의3⑥)에는 명세서 보정효과가 부여되지 않는다**는 결정적 법리를 놓쳐 '오역정정으로 모두 해결된다'고 결론내면 대폭 감점.
- (4)에서 **제42조 제3항(2) 배경기술·선행기술문헌정보 흠결**을 놓치는 경우 혼합 - 한국특허공보 7호를 사안이 명시했음에 유의.
- (1)에서 제60조 제3항 제3자 심사청구 통지에 따른 **1년2월 vs 통지일로부터 3월 중 빠른 날** 특칙, 분할출원 제52조 제7항·변경출원 제53조 제7항에 따른 30일 특례 누락 시 감점.
- (2)에서 제29조 제5항(국제특허출원 특칙)를 국내 외국어특허출원의 확대된 선출원 판단기준으로 오인용하면 감점. 국내 외국어특허출원은 제29조 제3항 본문의 '출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면'(=외국어 원문 명세서)이 그대로 확대된 선출원 판단기준이 된다.
- 조문 전사식 답안, 세목차 없이 문단으로만 이어지는 답안은 채점평이 명시적으로 지적함.

2015년 제2문

사례형

20점

문제

甲의 특허권의 청구범위는 다음과 같다.

제1항 물질 A로 구성되며 B방법에 의하여 제조되는 제조제 P

제2항 제1항에 있어서, 물질 A는 물질 a로 구성되는 제조제 P

제3항 제조제 P를 D시스템에 의하여 관리하는 보존용기 K

한편 乙은 “물질 a로 구성되며 B방법에 의하여 제조되는 제조제 P”를, 그리고 丙은 “보존용기 K”를 각각 생산·판매하고 있다. 이에 대하여 甲은 乙과 丙을 상대로 적극적 권리범위확인심판을 청구하였으며, 乙과 丙은 甲의 심판청구에 대응하여 무효심판을 청구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 甲이 “乙의 판매제품 제조제 P가 위 특허권의 권리범위에 속한다”는 취지의 주장을 한 경우, 그 청구이유(특허법 제140조제1항제4호)를 청구범위해석에 근거하여 설명하시오. (5점)

(2) 乙이 “물질 A로 구성되며 C방법에 의하여 제조되는 제조제 P”가 기재된 선행문헌만을 근거로, 甲의 제1항에 대하여 무효심판을 청구하는 경우, 그 청구이유를 판례에 근거하여 설명하시오. (단, B방법은 C방법보다 진보성이 있다.) (10점)

(3) 丙이 “제조제 P를 H시스템에 의하여 관리하는 보존용기 K1”이 기재된 선행문헌만을 근거로, 甲의 제3항이 신규성이 없다는 이유로 무효심판을 청구하는 경우, 그 청구이유를 신규성 판단기준에 근거하여 설명하시오. (5점)

모범답안

문제 2 모범답안 (20점)

I. 설문 (1) — 甲의 적극적 권리범위확인심판 청구이유 (5점)

1. 문제의 소재

제1항은 제조방법의 기재를 포함한 물건발명이므로, 그 기재의 취급과 독립항·종속항의 관계가 문제된다.

2. 청구범위의 해석

(1) 해석의 원칙

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적힌 사항으로 정하여지고(§ 97), 확인대상발명이 청구항의 구성요소와 유기적 결합관계를 그대로 포함하면 권리범위에 속한다.

(2) 제조방법이 기재된 물건발명

물건발명의 청구범위에 적힌 제조방법은 최종 생산물의 구조나 성질 등을 특징하는 수단일 뿐이고, 제조방법 B 자체가 아니라 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등이 구성요소가 된다(2011후927 전원합의체). 침해단계에서도 같으나, 권리범위가 명세서 전체의 기재에 비추어 지나치게 넓다는 등 불합리한 사정이 있으면 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다(2013후1726).

(3) 독립항과 종속항

종속항의 권리범위에 속하는 실시는 당연히 독립항의 권리범위에도 속한다. 판례 중에는 선택발명에 현저히 향상된 작용효과가 있으면 다른 발명으로서 권리범위에 속하지 아니한다고 한 것이 있으나(90후960), 보호범위 확정에는 별개 권리의 성립 여부와 무관하므로 기술적 사상을 그대로 이용하여 일체성이 유지되면 침해로 봄이 타당하다.

3. 사안의 포섭

乙의 제품은 물질 a로 구성되고 B방법으로 제조되는 제조제 P로서, 제조방법이 제2항과 같아 그에 의하여 특정되는 구조나 성질 등도 같고 물질도 a로 같으므로 제2항의 권리범위에 속하며, 제2항은 제1항의 종속항이므로 제1항의 권리범위에도 속한다. 물질 a는 甲이 스스로 종속항으로 청구한 것이어서 현저한 효과를 이유로 권리범위를 벗어난다고 볼 사정도 없다.

4. 결론

甲은 乙의 제품이 위와 같이 제2항과 그 독립항인 제1항의 권리범위에 속한다는 취지로 청구이유를 적어야 한다(§ 140①(4)).

II. 설문 (2) — 乙의 제1항에 대한 무효심판 청구이유 (10점)**1. 문제의 소재**

제1항은 제조방법의 기재를 포함한 물건발명이고, 선행문헌에는 같은 물질 A로 구성되나 제조방법이 다른 제조제 P가 개시되어 있다. 제조방법의 기재를 무엇으로 보아 선행기술과 대비할 것인지, 그에 따라 신규성과 진보성 중 어느 무효사유를 주장할 것인지가 문제된다.

2. 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건 판단**(1) 종래의 판례**

종래 판례는 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지에 따라 나누어, 그러한 사정이 있으면 제조방법을 고려하여, 없으면 제조방법을 고려하지 아니하고 물건만으로 특허요건을 판단하였다(2004후3416).

(2) 전원합의체 판례

판례는 물건의 발명에 관한 청구범위는 물건의 구성을 특정하는 방식으로 적어야 하므로 청구범위에 적힌 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 의미를 가질 뿐이라고 하면서, 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단할 때에는 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 선행기술과 비교하여 신규성과 진보성이 있는지를 살펴야 한다고 하여 종래의 판례를 변경하였다(2011후927 전원합의체). 또한 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있더라도 그 본질이 물건의 발명이고 제조방법의 기재가 물건을 특정하는 수단에 불과한 점은 마찬가지이므로 그 의미를 달리 해석할 것은 아니라고 하였다.

(3) 검토

제조방법이 기재된 물건발명의 본질은 물건의 발명이고 제조방법의 기재는 물건의 구조나 성질을 특정하는 수단에 지나지 아니하므로, 특별한 사정의 유무를 묻지 아니하고 물건으로 파악하는 판례가 타당하다. 따라서 제조방법에 신규성이나 진보성이 있다고 하여 그 방법으로 제조된 물건이 당연히 신규성이나 진보성을 가지는 것은 아니고, 제조방법에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가지는 물건으로 특정한 후 신규성과 진보성을 개별적으로 판단하여야 한다.

3. 사안의 포섭**(1) 신규성의 흠결**

제1항은 'B방법의 기재를 포함하여 특정되는 구조나 성질을 가지는 물질 A로 구성된 제조제 P'라는 물건으로 파악된다. B방법이 제조의 효율이나 수율에만 영향을 미칠 뿐 최종 생산물의 구조나 성질에 차이를 가져오지 아니한다면 선행문헌에 개시된 물건과 동일하므로, 제29조 제1항 제2호에 위반되어 무효사유가 있다. B방법이 C방법보다 진보성이 있다는 사정은 방법에 관한 것일 뿐 물건의 신규성 판단에 영향을 미치지 아니한다.

(2) 진보성의 흠결

선행 B방법에 의하여 특정되는 구조나 성질에 어떠한 차이가 있어 신규성이 부정되지 아니하더라도, 그 차이가 선행문헌의 물건으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 정도이고 이질적이거나 현저한 효과를 가져오지 아니한다면 제29조 제2항에 위반되어 무효사유가 있다. 이때에도 판단의 대상은 B방법 자체의 진보성이 아니라 그 방법에 의하여 특정되는 물건의 구성의 곤란성과 효과의 현저성이므로, B방법이 C방법보다 진보성이 있다는 사정만으로 물건의 진보성이 인정되지는 아니한다.

(3) 청구이유의 구성

따라서 乙은 신규성의 흠결을 주위적으로 적고, 물건의 구조나 성질에 차이가 인정될 경우에 대비하여 진보성의 흠결을 예비적으로 함께 적는 것이 타당하다.

4. 결론

乙은 제1항이 제조방법의 기재를 포함하여 특정되는 구조나 성질을 가지는 물건으로 파악되어야 하고 그 물건이 선행문헌에 이미 개시되어 있어 신규성이 없으며, 가사 차이가 있더라도 그로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 없다는 취지로 청구이유를 적어야 한다(§ 133①(1)).

III. 설문 (3) — 丙의 제3항에 대한 무효심판 청구이유 (5점)**1. 신규성의 판단기준****(1) 대비의 방법**

신규성은 청구항에 적힌 발명과 하나의 선행기술을 청구항마다 개별적으로 일대일로 대비하여, 특허발명의 구성이 그 선행기술에 나타나 있는지에 따라 판단한다.

(2) 실질적 동일

판례는 양 발명의 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 아니하는 정도라면 두 발명은 실질적으로 동일하다고 한다(2003후472).

2. 사안의 포섭

제3항의 '제조제 P를 D시스템에 의하여 관리하는 보존용기 K'와 선행문헌의 '제조제 P를 H시스템에 의하여 관리하는 보존용기 KI'을 대비하면, 제조제 P를 일정한 시스템으로 관리하는 보존용기라는 구성이 공통된다. 관리시스템과 보존용기의 차이가 주지·관용기술의 변경에 지나지 아니하여 새로운 작용효과를 낳지 아니한다면 두 발명은 실질적으로 동일하다.

3. 결론

丙은 제3항이 선행문헌에 개시된 발명과 실질적으로 동일하여 신규성이 없으므로 제133조 제1항 제1호의 무효사유가 있다는 취지로 청구이유를 적어야 한다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
설문(1) 청구범위해석에 근거한 적극적 권리범위확인심판 청구이유	5점	① 보호범위는 청구범위에 의함(§97) 및 구성요소완비의 원칙(AER) 적시 ② 제조방법 B 자체가 구성요소가 아니라 제조방법 기재를 포함한 모든 기재로 특정되는 구조·성질 등이 구성요소임을 밝히고, 침해단계 법리(2013후1726)까지 언급 ③ B방법이 동일하므로 그로써 특정되는 구조·성질의 구성요소도 동일함을 도출 ④ 乙 실시품이 제2항(종속항)의 모든 구성 포함하므로 독립항인 제1항 권리범위에도 속함을 포섭 ⑤ 종속항 법리상 당연히 제1항 침해이나, 선택발명에 현저한 효과가 있으면 권리범위에 속하지 않는다고 본 판례(90후960)와 그에 대한 비판을 함께 언급
설문(2) 판례에 근거한 제1항 무효 청구이유 (PBP청구항)	10점	① PBP청구항의 의의·기재 허용여부 정리 ② 신규성·진보성 판단대상 확정 관련 학설(제법한정설·물건동일설) 및 종래 판례 ③ 2015 전원합의체 판결(대법원 2015.1.22. 선고 2011후927 전합)의 법리 정확 인용 ④ B방법은 물건의 구조·성질을 특정하는 수단에 불과, 최종물건으로 대비 ⑤ 선행문헌(A+C방법으로 제조된 P)과 제1항의 물건 동일 → 신규성 상실 ⑥ 단서: B방법이 C방법보다 진보성 있다는 사정은 방법에 관한 것이어서 물건의 신규성 판단에 무관 ⑦ 신규성이 부정되지 않을 경우에 대비하여, 물건의 구성의 곤란성·효과의 현저성을 기준으로 한 진보성 해결(제29조 제2항)을 예비적 무효사유로 병기
설문(3) 신규성 판단기준에 근거한 제3항 무효 청구이유	5점	① 신규성 판단기준(1대1 대비, 청구항별 판단, 실질적 동일성) ② 실질적 동일성 판례(주지관용기술의 부가·삭제·변경으로 새로운 효과 없는 미세한 차이) ③ D시스템↔H시스템, 보존용기 K↔K1의 차이가 주지관용기술의 치환에 불과함을 사안에 포섭 ④ 결론적으로 신규성 해결로 무효사유 구성

배점 합계: 20점

특별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- **[필수]** 설문(2)에서 2015년 전원합의체 판결(2011후927)의 법리를 정확히 포착하여 서술 — 채점평이 "반드시 다루어야 할 사항이 빠져 있다"고 지적한 핵심.
- **[필수]** 설문(1)에서 제조방법 기재의 해석(구성요소 특정 수단)을 전제로 B방법 동일 → 구조·성질 동일을 도출하고, 종속항(제2항) 관계 및 다기재 협범위 원칙으로 제1항 침해까지 연결할 것. 선택발명 판례(90후960)의 반대 취지를 검토한 답안은 가점.
- **[필수]** 설문(3)의 신규성 판단은 실질적 동일성 판례에 근거해 사안에 포섭.
- [감점] PBP 청구항 일반론·명세서 기재불비 논의만 장황히 나열하고 신규성 판단대상 확정으로 연결하지 못한 답안.
- [감점] B방법 자체의 진보성만을 논하여 그로부터 곧바로 물건의 특허성을 도출한 답안(발문 단서를 유인책으로 오해). 다만 물건 자체의 진보성(제29조 제2항)을 예비적 무효사유로 병기한 답안은 가점.

2) 목차·구성(25%)

- 설문별로 (1) 5점 → 간결, (2) 10점 → 판례 중심 상세, (3) 5점 → 실질적 동일성 위주로 배점 비례 배분.
- 각 설문마다 "조문·법리 → 판례 → 사안 포섭 → 결론" 순으로 세목차 구성.
- [감점] 채점평 지적: "두서없고 산만한 서술", 세목차 없이 줄글로 나열.
- [감점] 설문(2)에 지면을 편중시켜 (1)·(3) 부실화하거나 반대로 (2)에서 판례 인용 없이 일반론만 반복.

3) 답안 작성·논증(35%)

- **[핵심 논증]** 설문(2): 전원합의체 판례 인용 → "제조방법 기재는 물건의 구조·성질 특정 수단" → 선행문헌의 "A로 구성된 P"(C방법 무관)와 제1항의 "A로 구성된 P"는 물건으로서 동일 → 신규성 상실이라는 논리 연결.
- 발문 단서 "B방법이 C방법보다 진보성 있다"는 유인책이며, 물건이 동일하면 방법의 진보성 유무와 무관하게 신규성이 상실된다는 점을 명확히 결론. 나아가 B방법으로 특정되는 구조·성질에 차이가 인정되어 신규성이 부정되지 않는 경우에 대비하여, 그 차이가 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 정도라면 진보성도 부정된다는 예비적 논증까지 갖춘 답안을 최상위로 평가.
- 설문(1): 제97조 → 제140조 제1항 제4호 청구이유 형식 → 제조방법 기재의 해석 → AER + 종속항 논리로 결론.
- 설문(3): 1대1 대비, 실질적 동일성 판례(주지관용기술 부가·삭제·변경) 근거 → 사안 포섭.
- [감점] 판례 법리 언급 없이 결론만 제시하거나, 결론이 애매모호한 답안.
- [감점] 조문·판례 전사 후 사안 포섭 누락.

감점 주의

- 채점평 지적: **문제와 무관한 서술 나열, 반드시 다뤄야 할 쟁점 누락** — 특히 설문(2)에서 전원합의체 판례를 모르거나 종래 판례만 인용한 답안 감점.
- PBP 청구항 기재불비 관련 구법(§ 42④(3)) 논의를 장황히 전개하고 신규성 판단으로 이어지지 못한 답안.
- 설문(1)에서 균등론 등 사안과 무관한 이론을 나열하는 실수(선택발명·이용관계 논의는 제1항과의 관계에서 필요한 범위에서만).
- 설문(3)에서 진보성까지 논하는 실수(발문은 신규성만 물음).
- 사안 포섭 없이 일반론만 서술하는 실수.

2015년 제3문

사례형

30점

문제

甲은 발명 A를 2014. 1. 8. 일본 지식재산처에 특허출원(특허출원 1, 우선권 1)하였다. 위의 발명 A는 잡지에 게재되어 동년 1. 15. 반포되었고, 甲은 선 출원발명 A를 개량하여 발명 B를 완성하였다. 또한 甲은 발명의 단일성 요건을 충족하는 발명 A, 발명 B를 제1항(A), 제2항(B)으로 하여 국내우선권을 주장하면서, 2014. 5. 16. 일본 지식재산처에 특허출원(특허출원 2, 우선권 2)하였다. 이후 甲은 특허출원 1과 특허출원 2를 기초로 하여 「공업소유권의 보호를 위한 파리협약」상의 우선권을 주장하면서 2014. 11. 19. 대한민국 지식재산처에 출원하였다.

2014.1.8.	2014.1.15.	2014.5.16.	2014.11.19.
특허출원 1 (우선권 1)	인용문헌	특허출원 2 (우선권 2)	대한민국 특허출원
A	A(개재 · 반포)	제1항(A), 제2항(B)	제1항(A), 제2항(B)

다음 물음에 답하시오.

- (1) 조약우선권 주장의 주체적, 시기적, 객체적 요건에 대하여 논하시오. **(7점)**
- (2) 조약우선권 주장 출원의 실체심사인 발명의 동일성 판단에 대하여 논하시오. **(15점)**
- (3) 인용문헌은 대한민국 출원발명의 신규성을 대비 판단하는 선행문헌에 해당할 수 있는지의 여부에 대하여 논하시오. **(8점)**

모범답안

문제 3 모범답안 (30점)

I. 설문 (1) — 조약우선권 주장의 요건 (7점)

1. 의의 및 취지

조약우선권주장출원이란 당사국 국민 등이 당사국에 특허출원을 한 후 1년 이내에 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하면서 우선권을 주장하는 경우에, 제29조와 제36조를 적용할 때 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 보는 출원을 말한다(§ 54①). 특허독립의 원칙상 각국에 따로 출원하여야 하여 출원 사이에 간격이 생기므로, 그 사이의 사정으로 선출원자가 불이익을 받지 아니하도록 하기 위한 것이다.

2. 주체적 요건

대한민국 국민, 조약 당사국 국민 또는 우리나라와 상호 우선권을 인정하기로 한 준당사국 국민이어야 한다(§ 54①). 우선권을 주장하는 자는 선출원의 출원인이거나 그 정당한 승계인이어야 하며, 우선권은 선출원과 분리되어 독립적이므로 승계인은 우선권을 별도로 승계받아야 한다.

3. 객체적 요건

(1) 최선성

우선권 주장의 기초는 그 발명에 관한 당사국에서의 최초의 출원이어야 한다. 후속출원을 기초로 거듭 우선권을 주장하면 우선기간이 실질적으로 연장되기 때문이다.

(2) 정규성

각국의 국내법령이나 조약에 따라 정규의 국내출원으로 인정되면 족하고, 그 후 출원이 무효·취하·포기되었는지는 묻지 아니한다.

(3) 형식의 무제한

출원의 형식은 제한되지 아니하므로 특허출원과 실용신안등록출원 사이에서도 우선권을 주장할 수 있다.

(4) 발명의 동일

후출원의 청구범위에 적힌 발명이 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 적힌 발명과 동일하여야 하며, 이는 설문 (2)에서 본다.

4. 시기적 요건

선출원의 출원일부터 1년의 우선기간 내에 우선권을 주장하면서 대한민국에 출원하여야 한다(§ 54②). 출원인의 이익과 제3자의 법적 안정성을 조화시키기 위한 기간이다. 아울러 출원과 동시에 그 취지와 선출원의 국명·출원연월일을 출원서에 적고, 최우선일부터 1년 4개월 이내에 증명서류를 제출하여야 한다(§ 54③④).

5. 사안의 포섭

甲은 동맹국인 일본에 한 특허출원 1과 특허출원 2를 기초로 대한민국에 출원하였고, 그 출원은 특허출원 1의 출원일부터 1년 이내이므로 위 요건을 갖추고 있다.

II. 설문 (2) — 조약우선권 주장 출원의 발명의 동일성 판단 (15점)

1. 문제의 소재

우선권 주장이 적법하면 후출원의 청구범위에 적힌 발명 중 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 적힌 발명은 제29조와 제36조를 적용할 때 선출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다(§ 54①). 따라서 어느 발명이 그 소급의 이익을 받는지, 곧 발명의 동일성을 무엇을 대상으로 어떻게 판단하는지가 문제된다.

2. 동일성 판단의 대상

(1) 선출원 측

선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면 전체가 대상이다. 청구범위에 적혀 있을 것을 요하지 아니하므로 발명의 설명이나 도면에만 개시된 발명도 우선권 주장의 기초가 될 수 있고, 그 후 보정으로 삭제된 부분도 최초 명세서에 있었던 이상 기초가 된다.

(2) 후출원 측

후출원의 청구범위에 적힌 발명이 대상이며, 청구항마다 개별적으로 판단한다. 청구범위가 보정되면 최종적으로 확정된 청구범위를 기준으로 우선권 주장의 적법성을 판단한다.

(3) 판단의 주체와 시점

동일성은 우선권 주장일 당시의 기술상식을 가진 통상의 기술자를 기준으로 판단한다. 또한 선출원의 청구범위에 적혀 있지 아니하더라도 출원서류 전체로써 그 발명이 개시되어 있으면 우선권이 인정된다(파리조약 제4조H).

3. 판례에 의한 구체적인 판단법리

(1) 소급하는 발명의 범위를 제한하는 근거

판례는 조약우선권 제도에 의하여 대한민국에 특허를 출원한 날보다 앞서 우선권 주장일에 출원된 것으로 보아 특허요건을 심사하면 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있다고 한다. 이는 명세서 또는 도면의 보정이 받아들여져 그 효과가 출원 시로 소급하는 경우와 다르지 아니하므로, 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 우선권 주장을 수반하여 출원된 발명 가운데 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 한다(2019후10265).

(2) '선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항'의 의미

여기서 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항이란, 그 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나, 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하여 출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항을 말한다(2012후2999, 2019후10265). 곧 동일성의 범위는 제47조 제2항의 신규사항 추가 금지에서 말하는 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위와 같은 기준으로 정하여진다.

(3) 판단의 효과

동일성은 청구항마다 판단하므로, 청구범위에 동일성이 없는 발명이 포함되어 있더라도 그 사유만으로 우선권 주장 전체가 부적법하게 되는 것은 아니다. 동일성이 인정되는 청구항만 우선권의 이익을 누리고, 나머지 청구항은 대한민국 출원일을 기준으로 특허요건을 심사한다. 그 결과 우선권 주장일과 대한민국 출원일 사이에 공지된 기술로 신규성이나 진보성이 부정될 수 있고, 이를 간과하고 등록되면 무효사유가 된다. 다만 심사관이 우선권 주장의 불인정으로 생긴 거절이유를 들어 거절결정을 하려면 우선권 주장이 인정되지 아니한다는 취지와 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하여 의견서 제출과 보정의 기회를 주어야 하고, 이를 누락하면 위법하다(2009후2371).

4. 부분우선권주장·복합우선권주장·누적적 우선권주장의 경우

(1) 부분우선권주장과 복합우선권주장

복합우선권주장이란 하나의 출원에 관하여 복수의 우선권을 주장하는 것을, 부분우선권주장이란 우선권을 주장하는 출원이 그 기초가 된 선출원에 포함되지 아니한 발명을 함께 포함하는 것을 말한다. 어느 동맹국도 이를 이유로 우선권 주장이나 특허출원을 거절할 수 없고, 선출원에 포함되지 아니하였던 구성요소에 대하여는 후출원일을 기준으로 특허요건을 판단한다(파리조약 제4조F). 이는 발명이 계속 개량되어 가는 현실을 고려하여, 출원인이 우선기간 중에 이루어진 개량까지 하나의 출원으로 묶어 보호받을 수 있도록 한 것이다. 다만 발명의 단일성은 국내법에 따라 별도로 요구되므로 이를 갖추지 못하면 거절이유가 된다(§ 45).

(2) 누적적 우선권주장

우선권 주장의 기초가 되는 출원은 최초의 출원이어야 한다. 따라서 제1국 출원이 다시 그 전의 출원을 기초로 우선권을 주장한 것이고 제2국 출원이 그 전 출원일부터 우선기간을 지나 이루어진 경우에는, 전출원과 제1국 출원에 공통으로 포함된 발명에 대하여 우선권이 인정되지 아니한다. 중복하여 우선권을 허용하면 우선기간이 실질적으로 연장되기 때문이다(2004허8749).

5. 사안의 포섭

甲의 대한민국 출원은 특허출원 1과 특허출원 2를 함께 기초로 한 복합우선권주장이고, 제2항의 발명 B는 특허출원 1에 포함되지 아니하므로 부분우선권 주장에 해당한다. 발명 A는 특허출원 1의 최초 명세서에 명시적으로 적혀 있어 동일성이 인정되므로 우선권 1의 이익을 받고, 발명 B는 특허출원 2의 최초 명세서에 처음 적혔으므로 우선권 2의 이익을 받는다. 다만 특허출원 2는 발명 A에 관하여 최초의 출원이 아니라 특허출원 1을 기초로 우선권을 주장한 출원인므로, 발명 A에 대하여는 특허출원 2를 기초로 다시 우선권을 주장할 수 없다.

6. 결론

발명의 동일성은 선출원의 최초 명세서 또는 도면 전체를 대상으로 하되, 그곳에 명시적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 우선권 주장일 당시의 기술 상식에 비추어 그와 마찬가지로 이해할 수 있는 사항의 범위를 기준으로 청구항마다 판단하고, 그 범위를 벗어난 발명은 대한민국 출원일을 기준으로 심사한다.

Ⅲ. 설문 (3) — 인용문헌이 신규성 판단의 선행문헌이 되는지 (8점)

1. 문제의 소재

인용문헌은 2014. 1. 15. 반포되었는데, 이는 특허출원 1 후이면서 특허출원 2와 대한민국 특허출원 전이다. 따라서 각 청구항의 판단시점이 어디로 소급 되는지에 따라 인용문헌이 선행문헌이 되는지가 달라진다.

2. 신규성 판단의 시기적 기준

신규성은 특허출원일이 아니라 특허출원 전에 그 발명이 공지되었거나 반포된 간행물에 게재되었는지를 기준으로 판단한다(§ 29①). 특허출원 전이란 출원한 시점 이전을 뜻하므로 출원일과 공개일이 같은 날이면 시·분·초까지 고려하여야 하고, 출원일의 전날까지를 뜻하는 특허출원일 전과는 구별된다.

3. 우선권 주장의 효과

우선권 주장이 적법하면 후출원의 청구범위에 적힌 발명 중 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 적힌 발명은 제29조와 제36조를 적용할 때 선출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다(§ 54①). 나아가 적법한 우선권 주장 출원은 우선기간 중에 이루어진 제3자의 출원이나 발명의 공개·실시 등에 의하여 불리한 취급을 받지 아니한다(파리조약 제4조B). 다만 이는 특허요건 판단시점의 소급일 뿐 출원일 자체가 소급하는 것은 아니다.

4. 사안의 포섭

(1) 제1항 발명 A

발명 A는 특허출원 1의 최초 명세서에 적혀 있으므로 제29조를 적용할 때 특허출원 1을 한 때인 2014. 1. 8.에 특허출원한 것으로 본다. 인용문헌은 그보다 뒤인 2014. 1. 15. 반포되어 특허출원 후에 반포된 것이므로, 특허출원 전에 반포된 간행물에 해당하지 아니하여 제1항의 신규성을 부정하는 선행문헌이 될 수 없다.

(2) 제2항 발명 B

발명 B는 특허출원 1에 개시되지 아니하고 특허출원 2의 최초 명세서에 처음 적혔으므로 특허출원 2를 한 때인 2014. 5. 16.에 특허출원한 것으로 볼 수 있을 뿐이다. 인용문헌은 그보다 앞선 2014. 1. 15. 반포되어 특허출원 전에 반포된 간행물에 해당하므로 제2항의 신규성을 판단하는 선행문헌이 된다(§ 29①(2)). 다만 인용문헌에는 발명 A만 게재되어 있으므로, 그것이 발명 B의 신규성을 부정하는지는 별도로 대비하여야 한다.

5. 결론

인용문헌은 제1항 발명 A에 대하여는 특허출원 후에 반포된 것이어서 선행문헌이 되지 아니하나, 제2항 발명 B에 대하여는 특허출원 전에 반포된 간행물로서 신규성 판단의 선행문헌이 된다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
설문(1) 조약우선권 주장의 주체적·시기적·객체적 요건	7점	① 주체(동맹국민·정당승계인), ② 객체(최선성·정규성·형식무제한), ③ 시기(특·실 1년, 파리조약 4C(1), §54②) 3요건을 균형있게 기재
설문(2) 조약우선권 주장출원의 실체심사 — 발명의 동일성 판단	15점	① 우선권의 인정근거·효과(파리조약 4B), ② 동일성 판단기준 — 판례 법리(소급하는 발명은 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위로 한정되고, 그 사항이란 명시적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항 — 2012후2999, 2019후10265)와 제47조 제2항의 신규사항 기준과의 동질성, 청구항별 판단으로 일부만 소급한다는 효과, ③ 판단대상(청구범위 아닌 출원서류 전체, 파리조약 4H), ④ 복합우선·부분우선의 개념 및 처리(파리조약 4F) , ⑤ 사안 포섭(우선권 1·2 개별판단, 소급 여부)
설문(3) 인용문헌 (2014.1.15. 반포)이 신규성 판단 선행문헌인지	8점	① 신규성의 시기적 기준은 특허출원일이 아니라 '특허출원 전'이라는 점(§29①, 같은 날이면 사·분·초까지 고려), ② 우선권 주장 효과 (§29 판단시점 소급), ③ A/B 청구항별 개별 판단 — A는 우선권1로 소급되어 인용문헌이 특허출원 후에 반포된 것이므로 선행문헌 X, B는 우선권1에 없어 특허출원 2를 한 때 기준이므로 특허출원 전에 반포된 간행물로서 선행문헌 O

측별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- **[핵심 감점 포인트 — 채점평 반영]** 설문(2)에서 **복합우선·부분우선 개념(파리조약 4F)** 을 언급하지 않으면 대폭 감점. 채점평이 명시적으로 지적한 사항.
- 설문(3)에서 청구항별(A항/B항)로 판단시점을 분리하여 선행문헌 해당 여부를 다르게 결론내야 함. A·B를 몽둥그려 판단하면 감점.
- 발명 A가 2014.1.15. 반포된 사실을 우선권 주장의 효과(파리조약 4B, 우선기간 중 공표에 의한 무효화 방지)와 연결지어야 함.
- 단순히 우선권 일반론만 나열하면 사안형 문제 취지에 맞지 않아 감점.

2) 목차·구성(25%)

- 설문별로 배점 비례(7:15:8) 분량 배분. 설문(2)에 가장 두텁게 서술.
- 설문(1)은 3요건을 소목차로 나누어 명확히 제시(주체/객체/시기).
- 설문(2)는 ① 근거·효과 → ② 동일성 판단기준 → ③ 판단대상 → ④ 복합·부분우선 → ⑤ 사안포섭 순으로 체계화.
- 설문(3)은 반드시 사안(A항/B항)에 포섭한 결론 도출. 일반론 나열형은 감점.

3) 답안 작성·논증(35%)

- 조문(파리조약 4A~4H, § 54, § 29) → 판례(동일성 판단 법리, 2012후2999·2019후10265) → 사안 포섭 순의 논증.
- 판례 원문 그대로 나열(채점평 지적: "판례를 그대로 쓰기보다")보다는 취지·법리를 자신의 언어로 정리.
- 결론 명확: 설문(3)에서 "A항은 선행문헌 X, B항은 선행문헌 O"의 명확한 결론 필수.
- 우선권 주장의 효과 (§ 29 판단시점 소급)와 인용문헌 (§ 29①(2) 반포간행물)의 관계를 논리적으로 연결.

감점 주의

- **[채점평 명시]** 복합우선 개념 누락 — 다수 수험생이 놓친 결정적 감점 포인트.
- 설문(1)에서 시기적 요건을 특허·실용신안(1년)과 디자인·상표(6월)를 구분하지 않고 몽둥그리는 실수.
- 파리조약 4H(청구범위가 아닌 출원서류 전체 기준 판단) 누락.
- 설문(3)에서 A와 B를 구분하지 않고 일괄 판단하여 결론이 모호해지는 경우.
- 우선권 주장의 효과를 "출원일 소급"이라고만 서술하고 "제29조 판단시점 소급"의 실질을 밝히지 않는 경우.
- 설문(3)에서 신규성의 기준을 "특허출원일 전·후"로 적어 "특허출원 전·후"와 구별하지 못하는 경우(같은 날 출원·공개된 사안에서 결론이 달라진다).
- 조문·법전 전사식 나열, 백지답안 제출(채점평 지적).

2015년 제4문

사례형

20점

문제

甲은 자신이 보유하고 있는 냉·난방 시스템에 관한 특허에 대하여, 乙에게 지역적으로는 대한민국 전역, 내용적으로는 생산·사용·양도에 관한 통상실시권을 2010. 12. 31. 허락하여 주고, 乙은 甲에게 특허사용료로 2011. 1. 1.부터 2015. 12. 30. 까지 매출액의 3%를 매년 말에 지급하기로 하는 내용의 계약을 체결하였다. 이처럼 乙이 甲으로부터 유상의 통상실시권을 허락 받았지만, 특허실시계약의 대상인 특허가 무효로 되는 경우에 어떻게 할 것인지에 관한 내용이 계약에 포함되어 있지 않고, 특허의 무효여부에 관하여 甲과 乙이 분쟁(不爭)의 합의를 하였다고까지는 볼 수 없는 상황에서, 乙은 2013. 7. 22. 甲의 특허에 대하여 무효심판을 청구하였다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 실시권자인 乙이 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하는지의 여부에 대하여 학설의 논거와 판례의 태도를 설명하시오. (10점)

(2) 만약 甲의 특허가 무효로 된다면 이미 지급된 특허사용료는 부당이득으로 반환되어야 하는지의 여부에 대하여 학설의 논거와 판례의 태도를 설명하시오. (10점)

모범답안

문제 4 모범답안 (20점)

I. 설문 (1) — 실시권자가 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인인지 (10점)

1. 문제의 소재

이해관계인 또는 심사관은 특허에 무효사유가 있는 경우 무효심판을 청구할 수 있다(§ 133①). 통상실시권을 허락받아 실시계약이 존속하고 있는 乙이 그 이해관계인에 해당하는지가 문제된다.

2. 이해관계인의 의의

이해관계인이란 그 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 자를 말하고, 그 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 자도 이에 포함된다(81후59).

3. 학설의 논거

(1) 부정설

실시권자는 실시권에 의하여 권리의 대항을 받을 염려가 없어 특허의 소멸에 관하여 직접적·현실적 이해관계가 없고, 실시권을 설정받고서 그 특허를 다투는 것은 신의칙에도 어긋난다고 한다.

(2) 긍정설

실시권자는 실시료의 지급이나 실시 범위의 제한 등 제약을 받고 있어 특허가 무효로 되면 그 제약에서 벗어나는 이익이 있고, 실시권을 설정받았다는 사정만으로 특허를 다투지 아니하겠다는 의사를 표시하였다고 볼 수 없다고 한다.

4. 판례의 태도

(1) 종전 판례

종전 판례는 갈리고 있었다. 한편에서는 실시권자에게 특별한 사정이 없는 한 특허를 무효로 할 구체적 이익이 없다거나(77후49), 허락기간에는 권리의 대항을 받을 염려가 없어 업무상 손해를 받거나 받을 우려가 없다는 이유로(80후77) 이해관계인이 아니라고 하였다. 다른 한편에서는 통상실시권에 대가의 지급조건이 붙어 있어 실시료를 지급하여야 한다면 특허가 무효로 됨으로써 그 지급의무를 면하는 이익이 있으므로 이해관계인에 해당한다고 하였다(79후74).

(2) 전원합의체 판례

판례는 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한이 부가되는 것이 일반적이어서 무효심결을 받음으로써 그 제약에서 벗어날 수 있고, 무효심판에 상당한 시간과 비용이 드는 이상 우선 실시권을 설정받아 실시하면서 다툼을 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 무효 여부를 다투지 아니하겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수 없다고 하였다. 그리하여 특별한 사정이 없는 한 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다고 하면서, 이에 배치되는 종전 판결들을 모두 변경하였다(2017후2819 전원합의체).

5. 분쟁의무 조항의 효력

실시계약에 특허의 효력을 다투지 아니하기로 하는 분쟁의무 조항이 있는 경우가 문제된다. 그 효력을 인정하면 실시권자의 무효심판 청구가 사실상 불가능해지고 특허를 받을 수 없는 기술이 그대로 존속하여 시장에 악영향을 미치므로, 그러한 조항은 위법하여 무효이고 특단의 사정이 될 수 없다고 보아야

한다. 공정거래위원회의 심사지침도 무효인 특허의 존속 등을 위하여 실시권자가 특허의 효력을 다투는 것을 부당하게 금지하는 행위를 불공정거래행위의 유형으로 들고 있다.

6. 검토

실시권자는 특허를 무효로 함으로써 실시권의 효력범위에 따른 제한을 벗어나 자유로이 실시할 수 있는 법률상 이익을 가지고, 실시권을 허락받았다는 사실만으로 특허의 유효성을 묵인하였다고 볼 수 없다. 따라서 실시권자가 아무런 제한 없이 실시를 허락받아 특허권 자체를 취득한 것과 마찬가지로 조항관계가 성립하는 등 특허권자와 법률상 이해관계를 같이하는 특단의 사정이 없는 한 무효심판을 청구할 수 있다고 봄이 타당하다.

7. 사안의 포섭 및 결론

乙은 매출액의 3%를 실시료로 지급할 의무를 지고 실시 범위도 제한받고 있어, 특허가 무효로 되면 그 제약을 벗어나는 직접적·현실적 이익이 있다. 甲과 乙 사이에 부쟁의 합의가 있었다고까지 볼 수 없고, 설령 그러한 합의가 있었다더라도 그 효력을 인정하기 어려우므로 결론은 달라지지 아니한다. 따라서 乙은 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다.

II. 설문 (2) — 이미 지급된 특허사용료의 부당이득 반환 여부 (10점)

1. 문제의 소재

특허를 무효로 한다는 심결이 확정되면 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다(§ 133③ 본문). 그렇다면 무효로 확정되기 전에 이미 지급한 실시료가 법률상 원인 없는 급부가 되어 부당이득으로 반환되어야 하는지가 문제된다.

2. 견해의 대립

(1) 부당이득 반환청구권의 요건

① **(반환부정설)** 실시계약의 목적인 급부는 특허발명을 실시할 수 있도록 하는 채무의 이행인데 그 급부가 무효 확정 시까지 계약의 내용대로 이행되었으므로 특허권자가 받은 실시료에는 법률상 원인이 있고, 실시권자는 그때까지 특허를 독점·배타적으로 사용함에 따른 경제적 이익을 누렸으므로 손해가 발생하였다고 볼 수도 없다고 한다.

② **(반환긍정설)** 특허권자는 당초부터 금지권을 행사할 여지가 없어 금지권을 행사하지 아니할 부작위의무를 이행할 수 없었고, 실시권자는 본래 만인의 공유제인 기술을 사용할 권한이 있었으므로 급부의 이행도 사실상의 이익도 인정할 수 없다고 한다.

(2) 무효의 소급효에 대한 해석

① **(반환부정설)** 특허무효의 소급효는 공법상의 효력일 뿐 실시계약이라는 사법상의 법률관계에까지 영향을 미치는 것은 아니고, 당사자들은 특허가 소급하여 무효로 되더라도 실시료의 반환을 구하지 아니하겠다는 취지로 의사가 합치되었다고 해석함이 상당하다고 한다.

② **(반환긍정설)** 소급효에 의하여 특허권이 처음부터 존재하지 아니한 것으로 되는 이상 특허권의 존재를 전제로 한 실시계약도 소급하여 무효로 보아야 하고, 제100조와 제102조가 실시계약의 목적을 유효한 특허권을 전제로 한 급부로 규정하고 있는 점도 근거가 된다고 한다.

(3) 정책적 측면

① **(반환부정설)** 기지급 실시료의 반환을 허용하면 특허 무효의 위험을 전적으로 특허권자에게만 부담시켜 형평에 반하고, 반환을 부정하여야 실시계약의 체결을 장려하는 한편 실시권자로 하여금 무효의 소지가 있는 특허를 조기에 다투도록 유도할 수 있다고 한다.

② **(반환긍정설)** 반환을 부정하면 적법하게 계약을 체결한 실시권자가 무단실시자보다 오히려 불리해지는 불공평이 생기고, 무효심결의 확정 시기에 따라 실시료 지급의무의 범위가 달라져 특허권자가 소송을 지연할 유인이 생긴다고 한다.

3. 판례

판례는 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자가 실시계약에 따라 이미 지급받은 실시료 중 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무는 없다고 한다(2012다42666). 특허권자는 실시계약에 의하여 실시권자의 실시에 대하여 금지나 손해배상을 구할 수 없는 부담을 지고, 실시권자는 무효로 확정되기 전까지 특허권의 독점적·배타적 효력에 의하여 제3자의 실시가 배제되는 이익을 누렸기 때문이다. 나아가 판례는 같은 이유에서 무효로 확정되기 전까지 발생한 미지급 실시료의 지급도 구할 수 있다고 한다(2018다287362).

4. 검토

실시계약 체결 당시 특허권이 유효하게 존재하고 있었던 이상 계약이 원시적으로 이행불능이었다고 할 수 없고, 실시권자는 그 기간 동안 특허권의 배타적 효력에 기대어 사실상 독점적으로 실시할 수 있었다. 따라서 별도의 특약이나 계약 자체의 무효사유가 없는 한 반환의무를 부정하는 판례가 타당하다.

5. 사안의 포섭 및 결론

甲과 乙의 실시계약에는 특허가 무효로 되는 경우의 처리에 관한 내용이 없고 계약 자체에 별도의 무효사유가 있다고 볼 사정도 없으며, 乙은 계약이 유효하게 존재한 기간 동안 특허발명을 실시하면서 그 배타적 효력에 따른 이익을 누렸다. 따라서 甲의 특허가 무효로 확정되었더라도 甲은 이미 지급받은 특허사용료를 乙에게 부당이득으로 반환할 의무가 없다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
(설문1) 무효심판 청구인 적격 - 이해관계인 개념	2점	제133조 제1항 이해관계인 또는 심사관, 판례상 이해관계인 정의(대항받을 염려 있는 자), 심결시 기준
(설문1) 실시권자의 이해관계 인정 여부 - 학설	3점	부정설(신의칙·대항가능성 없음)·긍정설(실시료 면제이익)·절충설의 논거 제시
(설문1) 판례의 태도	3점	① 원칙: 실시권 허용기간 중에는 이해관계 부정, ② 예외: 실시료 지급조건 등 의무이행 부담이 있는 경우 이해관계 긍정
(설문1) 사안포섭 및 결론	2점	부쟁합의 없음+매출액 3% 실시료 지급의무 존재 → 乙의 이해관계 긍정
(설문2) 무효심결 확정 소급효 (§133③)와 문제제기	2점	특허권 처음부터 없었던 것 → 부당이득(민법 §741) 반환 여부 문제됨
(설문2) 학설	3점	반환긍정설(자유기술 실시로 손해 발생)·반환부정설(실시이익 향유로 손해 없음)·절충설(계약에 별도 정함 없으면 부정) 논거
(설문2) 판례의 태도 및 논거 이해	3점	대법원 2012다42666,42673 - 원시적 이행불능·계약 자체 무효사유 없는 한 유효존속기간 상응분 반환의무 없음. 판결이 나오게 된 상황(독점배타적 효력에 의한 반사적 이익, 침해주장 배제이익) 이해
(설문2) 사안포섭 및 결론	2점	계약에 무효시 처리 규정 없음, 원시적 이행불능 아님, 乙은 유효기간 중 배타적 이익 향유 → 甲의 반환의무 없음

배점 합계: 20점

축별 채점 기준

1) 논점 추출 (40%)

- **특점:** (설문1)에서 실시권자의 이해관계인 적격이라는 쟁점을 명확히 인식하고, 판례가 원칙(부정)과 예외(실시료 부담 시 긍정)로 나뉜다는 점을 포착; (설문2)에서 무효의 소급효와 부당이득 반환 문제의 연결, 그리고 대법원 2012다42666,42673 판례의 취지 인식
- **감점:** 무효심판 일반론(청구인·피청구인·요건 등) 나열, 사안의 '매출액 3% 지급조건'을 언급 없이 지나침, 부쟁합의 부존재라는 단서를 놓치고 신의 직만으로 결론냄, 부당이득의 민법 요건(§ 741)만 장황히 나열

2) 목차·구성 (25%)

- **특점:** 설문별로 (i)학설 (ii)판례 (iii)검토·사안포섭 순의 3단 목차, 학설은 견해별로 소재목 부여, 판례는 원칙판례와 예외판례를 구분 배치
- **감점:** 학설과 판례의 뒤섞임, 서문에 무효심판 총론 장황 서술, 배점 10점씩 균등 배분 실패

3) 답안 작성·논증 (35%)

- **특점:** 제133조 제1항(청구인)·제133조 제3항(소급효) 조문 인용, 대법원 판례 취지 정확 인용, 학설 대립 시 자기 입장(절충설) 제시, 사안의 '매출액 3% 실시료' 사실에 판례법리 포섭
- **감점:** 판례를 그대로 옮겨쓰기만 하고 '이 판결이 나오게 된 상황(독점배타적 효력에 따른 반사적 이익 향유)'을 설명하지 않음(채점평 지적사항), 결론 애매, 본문↔결론 모순

감점 주의

- **채점평 직접 지적:** 판례를 단순히 그대로 옮겨쓰기보다 판결이 나오게 된 상황(특허권의 독점배타적 효력에 의해 실시권자가 반사적 이익을 얻어 손해가 없다는 점, 특허권자의 침해주장 배제이익)을 이해하고 서술한 답안에 가점이 부여됨
- 설문(1)에서 판례를 원칙(허여기간 중 이해관계 부정)만 언급하고 예외(실시료 지급조건 등 있는 경우 긍정)를 누락하면 사안포섭이 반대 결론으로 흘러 감점
- 사안 사실관계(부쟁합의 없음, 매출액 3% 실시료, 무효시 처리규정 없음)를 답안에 명시적으로 포섭하지 않고 일반론만 서술
- 설문(2)에서 제133조 제3항 소급효만 언급하고 계약자유원칙·이행불능 여부 검토를 누락
- 학설 대립 시 자기 입장(검토·결론)을 제시하지 않고 병렬 나열로 마무리

PART 7

2016

제1문	) 乙 항변의 성격 — 권리남용의 항변 ·) 침해소송 법원의 진보성 심리·판단 가부 및 청구기각 가부	30점
제2문	[설문(1)] 간접침해의 의의 취지와 제127조 제1호의 요건 · [설문(1)] '특허물건의 생산'의 의미(공용성)	20점
제3문	특허권 공유의 법적 성격 · 제99조 제2항·제4항 취지·공유물분할청구권 인정 여부·민법 규정 적용 여부	30점
제4문	1) A회사 특허권의 유효성 · 2) 乙이 A회사에 취할 조치	20점

2016년 제1문

사례형

30점

문제

甲은 '냉장고 구동시스템'이라는 명칭을 가진 발명(이하 'X발명'이라 한다)의 특허권자이다. 乙은 X발명이 선행기술들과 대비할 때 신규성 또는 진보성이 없어 무효라 생각하고, X발명의 구성요소를 포함하고 있는 자신의 냉장고를 제조·판매하여 왔다. 이로 인하여 甲의 냉장고의 매출액은 절반으로 감소하였다. 결국 甲은 乙을 상대로 그 실시제품이 甲의 특허권을 침해하였다고 주장하면서 그 침해금지 및 손해배상청구의 소(이하 '이 사건의 소'라 한다)를 乙의 주소지의 관할 법원에 제기하였다. 한편 甲의 이 사건의 소에 대응하기 위하여, 乙은 甲을 상대로 특허심판원에 X발명에 대한 특허무효심판 및 소극적 권리범위확인심판을 각각 청구하였다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오.(각 물음은 독립적이다.)

(1) 이 사건의 소에서 피고 乙은 X발명의 진보성이 부정된다고 주장하면서 원고 甲의 청구기각을 구하였다. X발명은 특허무효심판 절차에서 무효심결 확정 전이다.

1. 피고 乙의 항변의 성격을 논하시오.(4점)

2. 법원은 피고 乙의 주장의 당부를 판단하기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부를 심리·판단할 수 있는지 여부 및 이에 근거하여 이 사건 청구를 기각할 수 있는지 여부에 대하여 각각 논하시오.(6점)

(2) X발명에 대한 소극적 권리범위확인심판에서 X발명의 신규성 또는 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정할 수 있는지 여부와 그 심리결과 X발명의 신규성 또는 진보성이 부정된다면 특허심판원은 어떠한 조치를 하여야 하는지에 대하여 각각 논하시오.(단, 신규성이 부정되는 경우와 진보성이 부정되는 경우를 구분하시오.)(10점)

(3) 위 (2)와 별개로, 乙은 특허권자 甲을 상대로 특허심판원에 X발명에 대한 특허무효심판을 청구하였으나 인용되지 않았다. 이에 불복한 乙은 甲을 상대로 특허법원에 위 특허무효심판청구에 대한 심결의 취소소송을 제기하였다. 이 심결취소소송에서 乙은 특허심판원의 심판절차에서 심리·판단된 위법사유에 한하여 주장할 수 있는가, 아니면 그 심결을 위법하게 하는 사유를 심결취소소송절차에서 새로이 주장·입증할 수 있는가에 대하여, 학설과 판례의 태도와 이에 따른 법원의 조치를 각각 논하시오.(10점)

모범답안

문제 1 모범답안 (30점)

I. 설문 (1) — 침해소송에서 진보성 항변의 성격 및 법원의 심리

1. 乙 항변의 성격 (4점)

(1) 문제점

무효심결 확정 전임에도 진보성 부정을 이유로 청구기각을 구하는 乙의 항변이 1) 특허권의 유효성을 부정하는 것인지, 2) 권리범위를 부정하는 것인지, 3) 권리남용으로 권리행사를 제한하는 것인지가 문제된다.

(2) 관련 판례

① (권리의 유효성 부정) 특허는 등록된 이상 무효심결이 확정되지 아니하면 유효하고, 무효사유가 있더라도 다른 절차에서 그 전제로서 당연무효라고 판단할 수 없다(97후2095). 특허결정·설정등록이라는 행정처분으로 발생한 특허권에 공정력이 있기 때문이다. 하자 있는 행정처분이 당연무효가 되려면 그 하자가 중대하고 객관적으로 명백하여야 하는데, 특허결정은 선행기술 조사와 거절이유 통지를 거쳐 이루어지고 특허요건의 흠결은 법적 평가의 성격을 지니 판단이 자명하지 아니하므로, 그 하자는 중대·명백하다고 할 수 없다.

② (권리범위의 부정) 등록특허가 출원 전 공지공용의 기술에 비추어 새로운 것이 아니어서 신규성이 없는 경우에는 무효심결의 유무와 관계없이 권리범위를 인정할 수 없다(91마540). 다만 진보성의 결여는 권리범위 자체를 부정하는 사유는 아니고 권리행사의 제한 문제로 다루어진다.

③ (권리행사의 제한) 진보성이 부정되어 무효로 될 것이 명백한 경우 그 특허권에 기초한 침해금지·손해배상 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용으로 해당하여 허용되지 아니한다(2010다95390 전합).

(3) 사안의 포섭

① 무효심결 확정 전이고 진보성 흠결은 중대·명백한 하자가 아니어서 공정력이 부정되지 않으므로 유효성을 부정할 수 없고, ② 乙은 신규성이 아니라 진보성을 다투므로 권리범위를 부정할 수도 없다. ③ 결국 乙의 항변은 권리행사의 제한을 구하는 취지이다.

2. 진보성의 심리·판단과 청구기각 가부 (6점)

(1) 진보성을 심리·판단할 수 있는지 여부

① **(판례)** 판례는 특허가 무효로 될 것이 명백하면 그 권리행사가 권리남용에 해당하고, **법원도 그 항변의 당부를 판단하기 위한 전제로서 진보성 여부를 심리·판단할 수 있다**고 한다(2010다95390 전합).

② **(검토)** 특허법은 제1조에서 이용자의 이익도 아울러 보호함을 목적으로 하면서 제29조 제2항으로 **진보성 없는 발명을 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 공공영역에 두고 있다**. 본래 공중에게 개방되어야 할 기술이 잘못 등록되었음에도 제한 없이 독점시킨다면 **공공의 이익을 부당하게 훼손**하고 입법목적에도 정면으로 배치되며, 보호가치 없는 발명에 형식적 등록이 되어 있음을 기화로 한 청구를 용인함은 특허권자에게 부당한 이익을, 실시자에게 불합리한 고통과 손해를 줄 뿐이어서 **실질적 정의와 형평**에도 어긋난다. 나아가 이는 대세적 무효선언이 아니라 선결문제에 관한 판단이므로 무효심판의 전속관할과도 모순되지 아니한다.

③ **(사안의 포섭)** 법원은 乙의 항변의 당부를 판단하기 위한 전제로서 X발명의 진보성 유무를 심리·판단할 수 있다.

(2) 청구기각을 할 수 있는지 여부

① **(요건)** 침해금지·손해배상 청구가 권리남용으로 배척되려면 1) **진보성이 부정**되고, 2) 무효로 될 것이 **명백**하며, 3) **특별한 사정이 없을** 것을 요한다.

② **(특별한 사정)** 특허권자는 정정심판청구나 정정청구로 그 무효사유를 이미 해소하였거나 해소할 수 있다는 사정을 **재항변**으로 주장할 수 있고, 이것이 인정되면 권리남용이라 할 수 없다.

③ **(사안의 포섭)** 심리 결과 진보성이 부정되어 무효로 될 것이 명백하고 甲이 정정으로 하자를 해소할 수 있다는 등의 특별한 사정이 없다면, 법원은 甲의 청구를 기각할 수 있다.

3. 결론

乙의 항변은 **권리남용의 항변**이고, 법원은 그 전제로서 진보성 유무를 심리·판단할 수 있으며, 무효로 될 것이 명백하고 특별한 사정이 없다면 甲의 청구를 기각할 수 있다.

II. 설문 (2) — 권리범위확인심판에서 권리범위 부정 가부 및 심판원의 조치 (10점)

1. 권리범위를 부정할 수 있는지 여부

(1) 관련 법리

권리범위확인심판은 특허가 유효함을 전제로 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적 범위에 속하는지를 확인하는 절차이고, 특허는 등록된 이상 무효심결이 확정되지 아니하면 대세적으로 무효로 되지 아니하므로 원칙적으로 그 권리범위를 부정할 수 없다. 다만 판례는 출원 당시 공지공용인 경우까지 청구범위에 적혀 있다는 이유만으로 독점적·배타적 실시권을 부여할 수는 없으므로, 그러한 경우에는 무효심결의 유무와 관계없이 권리범위를 부정할 수 있다고 한다(91마540).

(2) 신규성 위반의 경우

신규성이 없는 발명은 본래 공중의 영역에 있던 것으로서 애당초 보호할 실체가 없어 권리범위를 상정할 수 없다. 따라서 X발명의 신규성이 부정되면 무효심결의 유무와 관계없이 **그 권리범위를 부정할 수 있다**.

(3) 진보성 위반의 경우

판례는 권리범위확인심판이 특허권의 효력이 미치는 객관적 범위를 확인하는 목적의 절차이므로 그 절차에서 진보성까지 판단하는 것은 i) 제도의 목적을 벗어나 본질에 맞지 아니하고, ii) 본래 무효심판의 기능에 속하는 것을 부여하여 그 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다고 하면서, **진보성이 부정된다는 이유로 권리범위를 부정하여서는 아니 된다**고 한다(2012후4162 전합).

판례가 타당하다. 무효사유가 있더라도 무효심결이 확정되지 아니한 이상 대세적으로 무효로 되는 것은 아니어서 아직 무효로 되지 아니한 특허를 무효로 된 특허와 같이 취급할 수 없고, 공지공용의 경우에 관한 위 법리는 애당초 보호할 실체가 없는 경우에 관한 것이어서 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수 없기 때문이다. 침해소송에서 권리남용의 항변을 판단하기 위한 전제로 진보성을 심리할 수 있다고 한 것(2010다95390 전합)은 **권리행사의 제한 여부를 가리기 위한** 판단일 뿐 권리범위 자체를 부정한다는 취지가 아니고 그 효력도 당사자 사이에만 미치므로, 두 판례는 서로 모순되지 아니한다.

2. 심판원의 조치

(1) 심결의 유형

확인대상발명이 권리범위에 속하지 아니한다고 인정되면 **인용심결**을, 그렇지 아니하면 **기각심결**을, 적법요건을 갖추지 못하면 **각하심결**을 한다.

(2) 관련 법리

권리범위확인심판의 심결에는 대세적 효력이 있어 진보성 부정이라는 무효사유는 그 심리대상이 될 수 없으므로, 그러한 사유만을 이유로 한 청구는 주장 자체로 권리범위 확인의 대상이 되지 아니하여 **확인의 이익이 없다**(2010후289 참조).

(3) 신규성 위반의 경우

X발명의 권리범위가 부정되는 이상 확인대상발명은 그 권리범위에 속하지 아니하므로, 심판원은 乙의 청구를 받아들이는 **인용심결**을 하여야 한다.

(4) 진보성 위반의 경우

진보성이 부정되더라도 이를 이유로 권리범위를 부정할 수 없고, 乙은 그 사유만을 이유로 소극적 권리범위확인심판을 청구하였으므로 확인의 이익이 없다. 따라서 심판원은 **각하심결**을 하여야 한다.

3. 결론

신규성이 부정되는 경우에는 무효심결의 유무와 관계없이 권리범위를 부정할 수 있으므로 심판원은 인용심결을 하여야 하고, 진보성이 부정되는 경우에는 권리범위를 부정할 수 없고 그 청구는 확인의 이익이 없으므로 각하심결을 하여야 한다.

Ⅲ. 설문 (3) — 심결취소소송의 심리범위 (10점)

1. 문제점

심결전치주의(§ 186⑥) 아래에서 심판에서 주장·판단되지 아니한 위법사유를 심결취소소송에서 새로이 주장·증명할 수 있는지가 문제된다.

2. 학설

(1) 무제한설

심결취소소송은 항고소송이고 특허법원은 사실심 제1심이므로, 심판에서 판단되지 아니한 어떠한 위법사유도 새로이 주장·증명할 수 있고 법원도 이를 판결의 기초로 삼을 수 있다.

(2) 제한설

심결전치주의를 근거로 특허법원을 사실상 제2심으로 보아 심결에서 현출되지 아니한 위법사유는 주장할 수 없다고 한다. 그렇지 않으면 심판원의 판단을 거치지 아니한 사항을 법원이 먼저 판단하게 되어 심급의 이익을 해한다는 것이다.

(3) 절충설

당사자에게 심판은 대립구조에서 공격·방어가 이루어지므로 무제한설에, 결정계 심판은 출원인의 의견제출 기회를 보장하여야 하므로 제한설에 의한다.

3. 판례의 태도

(1) 당사자계 — 대법원 2007후4410

심판은 행정절차이고 심결은 행정처분이며 그 취소소송은 항고소송으로서 소송물이 심결의 실체적·절차적 위법 여부이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 아니한 위법사유도 새로이 주장·증명할 수 있고, 법원도 **특별한 사정이 없는 한** 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있으며, 그렇게 보더라도 심급의 이익을 해하거나 불측의 손해를 주지 아니한다(**무제한설**).

(2) 결정계 — 대법원 2013후1054

거절결정을 하려면 미리 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 심판절차에서 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 관하여 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(§ 62·§ 63·§ 170). 판례는 이러한 **절차적 권리를 보장하는 규정이 강행규정**이므로 그 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유로 심판청구를 기각한 심결은 위법하고, **그 취소소송에서도 지식재산처장은 새로운 거절이유를 주장할 수 없다**고 한다. 다만 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이를 보충하는 데 지나지 아니하는 사유는 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있다. 정정심판 기각심결의 취소소송에서도 의견서 제출 기회 규정(§ 136⑥)이 강행규정임을 이유로 같은 법리가 적용된다(2018후12004).

4. 검토

소송물이 심결의 실체적·절차적 위법 여부이고 심판절차에는 직권담지주의가 적용되어 당사자가 주장하지 아니한 사실도 심리대상이 되므로 **무제한설이 원칙**이며, 국민의 **법관에 의한 사실심 재판을 받을 권리**(헌법 제27조 제1항)를 보장하기 위하여 특허법원을 설치한 배경에 비추어 보아도 그러하다. 다만 판례도 **'특별한 사정이 없는 한'** 제한 없이 심리·판단할 수 있다고 하는바, 결정계에서는 거절이유의 통지와 의견제출 기회 보장도 **강행규정**이어서 그 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유는 심결의 이유로 삼을 수 없고 취소소송에서도 주장할 수 없으므로, 이것이 심리범위를 제한하는 특별한 사정에 해당한다. 즉 결정계의 제한은 제한설을 취하기 때문이 아니라 출원인의 절차적 권리를 보장하기 위한 강행규정의 효과이다.

5. 결론 — 법원의 조치

乙이 청구한 무효심판은 당사자계 심판이므로 乙은 심판절차에서 주장하지 아니한 새로운 무효사유를 **주장·증명할 수 있다**. 따라서 특허법원은 그 사유가 이유 있으면 심결을 취소하는 **인용판결**을, 이유 없으면 **기각판결**을 하여야 한다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
(1)-1) 乙 항변의 성격 — 권리남용의 항변	4점	무효항변·권리남용항변 구별 후 대법원 2010다95390(전합) 취지에 따라 권리남용 항변으로 성격결정
(1)-2) 침해소송 법원의 진보성 심리·판단 가부 및 청구기각 가부	6점	전합판례에 따른 심리·판단 공정, 무효로 될 것이 명백한 경우 권리남용으로 청구기각 가능
(2) 권리범위확인심판에서 신규성/진보성 부정 시 권리범위 부정 가부와 심판원 조치	10점	신규성(91마540, 98다7209) — 권리범위 부정 → 인용심결 / 진보성(2012후4162 전합) — 권리범위 부정 불가 → 기각심결, 신규성·진보성 구분 서술
(3) 심결취소소송의 심리범위(당사자계)	10점	무제한설·제한설·절충설, 대법원 2007후4410(무제한설), 법원 조치(인용/기각) 명확히 기술

축별 채점 기준

1) 논점 추출(약 12점)

- **특점:** 각 설문이 요구하는 것을 정확히 짚어 (①항변의 성격=권리남용, ②법원의 진보성 심리·판단·청구기각, ③신규성/진보성 구분한 심판원 조치, ④당사자계 심결취소소송 심리범위) 배점 비례로 논점을 추출.
- **특점:** 대법원 2010다95390(침해소송)과 2012후4162(권리범위확인심판) 두 전원합의체 판결의 **대비적 의미**를 정확히 파악(채점평 지적사항).
- **감점:** 두 전합판결의 판시 요지만 단순 나열, 침해소송과 권리범위확인심판의 결론 차이의 이유를 설명하지 못한 경우.
- **감점:** (2)에서 신규성/진보성 구분 없이 서술, (3)에서 결정계·당사자계 구분 없이 일반론만 서술.

2) 목차·구성(약 8점)

- **특점:** 설문 (1)~(3) 별 목차화, 각 소설문별 소재목 부여, 배점(4:6:10:10)에 비례한 분량 배분.
- **특점:** 학설(무제한설·제한설·절충설) → 판례 → 검토 → 사안 포섭의 정형화된 흐름.
- **감점:** 4점 문항에 지면을 과다 할애하거나, 10점 문항을 판례요지 몇 줄로 처리(채점평 지적사항).
- **감점:** 관련 쟁점을 "상품 진열하듯 나열"만 하고 왜 그 논점을 다루는지 설명 없는 서술(채점평 지적).

3) 답안 작성·논증(약 10점)

- **특점:** 조문(§ 128 손해배, § 133 무효, § 135 권리범위확인, § 186 심결취소소송) → 판례 → 사안 포섭 순의 논증.
- **특점:** 권리남용 항변의 근거로 실질적 정의·형평, 소송경제를 제시하고 사안 결론을 명확히 도출.
- **특점:** (3)에서 무제한설이 판례임을 밝히고, 그에 따른 법원의 조치(주장이유 있으면 인용·심결취소, 이유 없으면 기각)를 사안에 포섭.
- **감점:** 결론과 근거의 불일치, 판례 판시만 옮기고 사안 포섭 없음, 학설 대립만 나열하고 자기 입장 부재.
- **감점:** 신규성 부정 시 권리범위 부정(91마540) 결론과 진보성 부정 시 권리범위 부정 불가(2012후4162) 결론을 혼동.

감점 주의

- **두 전합판결(2010다95390 vs 2012후4162)의 대비 의미 미파악:** 침해소송에서는 진보성 심리 가능·권리남용 인정, 권리범위확인심판에서는 진보성 판단 불가 — 이 대비를 명확히 설명해야 함(채점평 명시 지적).
- **판례 요지의 단순 암기·나열:** 논리적 근거 없이 결론만 옮기면 감점.
- **배점 무시한 분량 배분:** 4점 소설문에 2쪽, 10점 소설문에 반쪽 등.
- **소극적 권리범위확인심판의 심결 유형(인용/기각/각하)** 을 부정확하게 서술(신규성 부정 → 인용, 진보성 부정 → 기각 또는 각하).
- **심결취소소송에서 당사자계와 결정계 구분 누락,** 무제한설 판례(2007후4410) 미인용.
- **악필로 채점불능(채점평 명시).**

2016년 제2문

사례형

20점

문제

甲은 반도체 웨이퍼 연마용 패드 및 그 사용방법에 대한 발명 A+B+C에 대하여 특허권을 보유하고 있다. 乙은 A+M+C 발명을 통하여 연마용 패드를 생산하는 회사인데 자사가 생산하는 연마용 패드가 甲의 특허권 권리범위에 속하지 아니한다는 취지로 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 그런데 실제로 乙의 연마용 패드를 구입한 반도체 제조업체가 이를 이용할 때에, 이 연마용 패드는 A+M+b+C로만 나타난다. (단, b는 B로 실시하게 될 개연성이 크다.) 한편, 丙은 甲의 연마용 패드의 반제품을 생산하고 있으며, 이것은 조립을 통하여 완제품이 될 수 있다. 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

(1) 甲이 간접침해를 주장하자, 乙은 자신의 연마용 패드가 기존의 이용공정과 다른 방법으로 사용되는 경우에는 A+M+C로 발현될 수도 있다고 항변하였는데, 실제 시장에서는 기존 이용 공정으로만 사용되고 있었다. 간접침해에서 특허물건의 생산“에만”사용하는 물건에 대하여 설명하고, 乙의 연마용 패드가 이에 해당하는지 여부에 대하여 논하시오. (15점)

(2) 丙이 甲의 연마용 패드 반제품을 생산하여 수출하고, 제3자 丁이 제3국에서 이 반제품을 이용하여 완제품을 생산하자, 甲은 丙의 제품이 자신의 특허권 보호범위에 들어간다고 하면서 특허권침해를 주장한다. 甲의 주장이 타당한지 여부에 대하여 설명하시오. (5점)

모범답안

문제 2 모범답안 (20점)

I. 설문 (1) — '특허물건의 생산에만 사용하는 물건'과 乙 패드의 해당 여부 (15점)

1. 문제의 소재

乙의 연마용 패드(A+M+C)는 甲 특허발명(A+B+C)의 구성요소 B를 결여하므로 구성요소완비의 원칙상 직접침해는 성립하지 아니한다. 따라서 위 패드가 '특허물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하여 간접침해가 성립하는지가 문제된다.

2. 간접침해의 의의 및 관련 법규정

간접침해란 특허발명 자체의 실시가 아니어서 직접침해는 아니나, 그대로 방치하면 직접침해에 이를 개연성이 높은 행위를 침해로 간주하는 것을 말한다. 특허법 제127조 제1호는 특허가 물건의 발명인 경우 "그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위"를 업으로서 하는 경우 특허권을 침해한 것으로 본다고 규정하므로, 정당한 권원 없는 자가 특허권의 존속 중에 전용품에 대하여 위 각 행위를 업으로서 하여야 한다. 판례도 그 전 단계의 행위라도 특허발명을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 이를 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 아니한다고 본 것이라고 한다(2007후3356).

3. '특허물건의 생산에만 사용하는 물건'의 의미

(1) '특허물건의 생산'에 사용될 것 — 공용성

① (생산의 의미) '생산'이란 특허발명의 구성요소를 충족하지 아니한 물건을 사용하여 그 구성요소를 충족하는 물건을 만들어 내는 모든 의식적 행위를 의미하고, 공업적 생산에 한하지 아니하며 가공·조립·수리 등의 행위도 포함된다(2000다27602, 2007후3356).

② (공용성의 판단) 물건의 사용이 구성요소완비의 원칙에 의한 특허물건의 생산에 해당하는 경우뿐만 아니라, 균등론에 의한 생산에 해당하는 경우에도 실질적으로 특허발명을 생산한 것으로 볼 수 있으므로 공용성이 인정된다(2007후3356). 다른 구성이 부가되어 특허발명을 이용하는 관계에 있는 경우에도 같다.

(2) 생산 '에만' 사용될 것 — 전용성

① (의미) '에만'이란 그 물건에 특허발명에 사용되는 외의 다른 용도가 없다는 것을 말한다. 따라서 여러 용도에 널리 쓰이는 범용품과 같은 중성적 물건은 특허발명의 구성요소에 속하더라도 간접침해가 성립할 여지가 없다.

② (타용도의 판단기준) '타용도'의 의미에 관하여는 경제적·상업적·실용적 사용가능성설과 사용사실설이 대립한다. 판례는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적·상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 하고, 단순히 이론적·실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다고 하여(2007후3356, 2017다289903) 사용사실설의 입장에 있다. 단순한 사용가능성만으로 전용성을 부정하면 간접침해 규정이 사문화되므로 판례가 타당하다.

③ (판단시점) 물건의 용도는 시간의 경과에 따라 변할 수 있으므로 타용도의 유무는 해당 행위 시를 기준으로 판단하되, 침해금지청구권을 소송상 행사하는 때에는 사실심 변론종결 시가 기준이 된다.

④ (증명책임) 위 물건에 해당한다는 점은 특허권자가 주장·증명하여야 하나(98후2580), 타용도의 부존재를 증명하기는 곤란하므로 공용성이 증명된 후 실시자가 타용도를 구체적으로 주장하는 때에 전용성의 증명책임이 현실화된다고 봄이 타당하다.

4. 사안의 포섭

乙의 패드를 구입한 반도체 제조업체가 이를 이용하면 $A+M+b+C$ 로 나타나고 b 는 B로 실시될 개연성이 크므로, 그 결과물인 $A+M+B+C$ 는 구성요소완비의 원칙상 甲 특허발명의 구성요소를 모두 포함하고 여기에 M이 부가된 것에 지나지 아니하며, 설령 b 가 B와 동일하지 아니하더라도 균등한 구성에 해당한다. 따라서 乙의 패드는 甲 특허발명의 생산에 사용되는 물건이다.

乙은 기존의 이용공정과 다른 방법으로 사용되면 $A+M+C$ 로 발현될 수도 있다고 항변하나, 실제 시장에서 기존의 이용공정으로만 사용되고 있는 이상 이는 이론적·일시적인 사용가능성에 지나지 아니하고 사회통념상 통용·승인될 수 있는 다른 용도라고 할 수 없다. 판례도 설계변경에 의하여 다른 제품을 만드는 경우 특허발명의 실시물건 이외의 물건에 사용될 가능성이 있다는 것만으로는 권리범위를 벗어날 수 없다고 하였다(98후2580).

5. 결론

乙의 연마용 패드는 특허법 제127조 제1호의 '특허발명의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하므로 乙의 생산·판매는 간접침해에 해당하고, 확인대상발명은 甲 특허발명의 권리범위에 속한다.

II. 설문 (2) — 국내 반제품 생산·수출과 국외 완제품 생산 (5점)

1. 문제의 소재

丙은 국내에서 반제품을 생산·수출할 뿐 완제품은 제3국에서 丁이 생산하므로, 간접침해의 성립 여부와 속지주의에도 불구하고 국내 생산으로 볼 수 있는지가 문제된다.

2. 관련 판례 — 반제품 사건

(1) 1차 판결 — 간접침해의 부정

속지주의 원칙상 특허권은 등록국의 영역 내에서만 효력이 미치므로, 제127조 제1호의 '그 물건의 생산'이란 국내 생산을 의미하고, 생산이 국외에서 일어나면 전 단계 행위가 국내에서 이루어져도 간접침해가 성립할 수 없다(2014다42110). 2025. 1. 21. 개정법이 '수출'을 실시와 간접침해행위에 추가하였으나, 생산을 국내 생산으로 제한해석하는 이상 수출에는 간접침해를 물을 수 없는 문제가 있다.

(2) 2차 판결 — 속지주의의 예외

i) 국내에서 부품·구성 전부가 생산되거나 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, ii) 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 예정되어 있으며, iii) 그 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 iv) 그 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면 예외적으로 국내에서 실시제품이 생산된 것으로 본다(2019다222782). 이에 해당하는지는 속지주의와 구성요소완비의 원칙을 고려하여 엄격히 판단한다(2025다202970).

3. 사안의 포섭

완제품이 제3국에서 생산되어 국내 생산이 없으므로 丙의 반제품 생산·수출은 간접침해가 성립하지 아니한다. 다만 반제품이 주요 구성을 모두 갖추어 丁의 조립이 극히 사소·간단하고 그 생산만으로도 특허발명의 작용효과를 구현할 수 있는 상태면 국내 생산으로 보아 직접침해가 성립한다.

4. 결론

위 예외 요건을 충족하면 甲의 주장은 타당하나, 그에 이르지 아니하면 직접·간접침해가 모두 성립하지 아니하여 타당하지 아니하다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특정 포인트
[설문(1)] 간접침해의 의의·취지와 제127조 제1호의 요건	3점	간접침해 취지(직접침해 전 단계, 침해 개연성이 높은 행위의 침해 의제), 관련 법규정(\$127(1)) 적시
[설문(1)] '특허물건의 생산'의 의미(공용성)	3점	판례(2000다27602, 2007후3356) — 구성요소를 충족하지 아니한 물건으로 이를 충족하는 물건을 만들어 내는 모든 의식적 행위, 가공·조립·수리 포함 / 구성요소완비의 원칙에 의한 생산뿐만 아니라 균등론에 의한 생산도 공용성 인정
[설문(1)] '에만'(전용성)의 의미·타용도 판단	4점	타용도 학설(경제적·상업적·실용적 사용가능성설 ↔ 사용사실설)과 판례가 사용사실설임(2007후3356, 2017다289903), 이론적·실험적·일시적 사용가능성만으로는 타용도 부정, 판단시점(행위 시, 침해금지청구는 사실심 변론종결 시), 증명책임(특허권자, 98후2580)
[설문(1)] 사안 포섭 및 결론	5점	b→B 실시 개연성 큼(공용성 ○), 乙의 막연한 사용가능성 형변 배척(실제 시장에서 기존공정만 사용)→타용도 부정, '에만' 요건 충족, 간접침해 성립
[설문(2)] 반제품 사건 1차 판결 — 간접침해 부정	2점	판례(2014다42110) — 속지주의상 제127조 제1호의 '생산'은 국내에서의 생산 의미, 국외 생산이면 전 단계 행위가 국내라도 간접침해 불성립, 2025. 1. 21. 개정법의 '수출' 추가와 그에 따른 해석 논란 지적
[설문(2)] 반제품 사건 2차 판결 — 속지주의의 예외	3점	판례(2019다222782) — 부품 전부·주요 구성 반제품의 국내 생산, 하나의 주체에게 수출되어 마지막 가공·조립 예정, 그 가공·조립이 극히 사소·간단, 반제품만으로 작용효과 구현 가능한 상태이면 국내에서 실시제품이 생산된 것으로 보아 직접침해 인정 (엄격 판단, 2025다202970), 요건 충족 여부에 따른 조건부 결론 도출

배점 합계: 20점

특별 채점 기준

1) 논점 추출(약 8점)

- **[+]** 설문(1)에서 '에만' 요건(전용성)에 초점을 맞추고, '생산'(공용성)과 구분하여 실시했는가.
- **[+]** 乙의 형변('다른 방법 사용 시 A+M+C로 발현')이 '타용도' 항변임을 파악하고, '실제 시장에서는 기존공정으로만 사용'이라는 사실을 포섭하였는가.
- **[+]** 설문(2)에서 쟁점이 '국외 생산이 제127조 제1호의 생산에 포함되는지'(속지주의)와 '국내 반제품 생산을 실시제품의 생산으로 볼 수 있는지'(속지주의의 예외)임을 모두 포착하였는가.
- **[-]** 직접침해 여부만 장황하게 논한 답안은 감점(구성요소완비의 원칙·균등론은 공용성의 판단 범위를 밝히는 한도에서 간결히 언급하면 족함).
- **[-]** 간접침해 충족설/독립설 논의를 배점과 무관하게 과다하게 서술한 경우 감점(설문(2)에서 간단히 언급하면 족함).

2) 목차·구성(약 5점)

- **[+]** 설문(1) 15점 : 설문(2) 5점의 배점 비율에 맞게 분량을 배분하였는가(설문(1)에 3배 분량).
- **[+]** '공용성·전용성' 또는 '생산·에만'을 별도 소목차로 구분하여 체계화하였는가.
- **[+]** 각 쟁점마다 '법리(관련 법규정·판례) → 사안 포섭 → 결론' 구조를 유지하였는가.
- **[-]** 간접침해 일반론(의의·취지)에 지면을 지나치게 할애하고 사안 포섭이 짧은 경우 감점(채점평 지적).
- **[-]** 배점 5점인 설문(2)에 과도한 분량을 할애하거나 반대로 소홀히 처리한 경우 감점.

3) 답안 작성·논증(약 7점)

- **[+]** 판례(2007후3356, 98후2580, 2014다42110) 법리를 정확히 인용하고 사안에 포섭하였는가.
- **[+]** 乙의 타용도 항변에 대하여 '이론적·일시적·실험적 사용가능성만으로는 타용도 부정'이라는 판례 법리로 반박하고, '실제 시장에서 기존공정만 사용'이라는 사실관계를 근거로 포섭하였는가.
- **[+]** 설문(2)에서 1차 판결로 간접침해를 배제한 다음 2차 판결의 예외 요건을 검토하여 조건부 결론을 논리적으로 도출하였는가.
- **[+]** 각 설문마다 명확한 결론(간접침해 성립/불성립)을 제시하였는가.
- **[-]** 판결요지만 나열하고 사안에 포섭하지 않은 답안(채점평 지적 사항) 감점.
- **[-]** 결론이 애매하거나 본문 논증과 결론이 모순되는 경우 감점.

감점 주의

- **채점평 지적:** 판결요지만 언급하면서 사안 해결을 간략히 적은 답안이 많았음 → 반드시 사안의 구체적 사실(b→B 실시개연성, 실제 시장에서 기존공정만 사용, 제3국에서 완제품 생산)을 포섭할 것.
- 간접침해의 의의·요건을 예상문제처럼 통째로 암기해 나열만 하고 '에만' 요건에 집중하지 않으면 감점.

- 설문(2)에서 1차 판결만 인용하여 간접침해 불성립으로 단정하고 2차 판결의 예외 법리를 검토하지 않으면 대폭 감점(반대로 종속설/독립설을 장황히 논하는 것도 감점).
- 乙의 '타용도' 항변을 판례법리(경제적·상업적·실용적 사용사실 필요)로 반박하지 않고 단순히 결론만 내리는 답안 감점.
- 입증책임 근거 판례를 잘못 인용한 경우 감점 — 특허권자에게 '생산에만 사용하는 물건' 해당성의 입증책임이 있다는 판례는 대법원 98후2580임.
- 배점 비율(15:5)을 무시한 분량 배분 감점(채점평 지적).

2016년 제3문

사례형

30점

문제

乙은 丙과 함께 'X발명'의 특허권(이하 '이 사건 특허권'이라 한다)을 공유하고 있었다. 그런데 丙이 사망하자 丙으로부터 이 사건 특허권의 공유 지분을 상속한 甲은 乙을 상대로 공유물분할청구권에 기한 소를 제기하였다(상속인은甲이 유일한 것으로 가정한다). 한편, 제3자 丁은 이 사건 특허권이 선행기술과 대비할 때 신규성 또는 진보성이 없어서 무효라고 생각하고, 특허심판원에 무효심판을 청구하려고 한다. 위 사실관계에 기초하여 다음의 물음에 답하시오.(각 물음은 독립적이다)

(1) 특허권 공유의 법적 성격에 대하여 논하시오.(5점)

(2) 위 사안에서, 원고 甲이 피고 乙을 상대로 제기한 공유물분할청구의 소와 관련하여 다음 물음에 답하시오.

1. 특허법 제99조제2항 및 제4항 규정의 취지, 공유특허권에 대한 분할청구권 인정여부, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용되는지 여부를 각각 설명하시오.(8점)

2. 특허권의 성질상 현물분할이 허용되는지 여부 및 담당 법원은 이 사건 특허권에 대하여 경매에 의한 대금분할을 명할 수 있는지 여부에 대하여 각각 논하시오.(5점)

(3) 위 (2)와 별개로, 다음 물음에 답하시오.

1. 제3자 丁이 특허심판원에 제기한 무효심판의 피청구인 적격, 제3자 丁을 상대로 한 적극적 권리범위확인심판의 청구인 적격을 각각 설명하시오.(4점)

2. 위 무효심판의 심결이나 적극적 권리범위확인심판의 심결이 이 사건 공유특허권자들에게 불리하게 내려졌다. 이러한 심결에 대한 취소소송을 특허법원에 제기하고자 하는 경우 원고적격을 가진 자에 대하여 논하시오.(8점)

모범답안

문제 3 모범답안 (30점)

I. 설문 (1) — 특허권 공유의 법적 성격 (5점)

1. 문제의 소재

특허법은 지분의 양도·질권 설정과 실시권 설정에 다른 공유자 모두의 동의를 요구하고(§ 99②④) 공유자 모두의 공동심판을 요구하면서도(§ 139②③) 공유의 법적 성격에 관하여는 정하고 있지 아니하므로, 이를 민법상 공유로 볼 것인지 합유로 볼 것인지가 문제된다.

2. 견해의 대립

(1) 합유설

위 각 제한에 의하여 지분의 처분과 권리의 행사가 제약되고 공유자 사이에 합일확정의 필요가 있으므로 민법상 합유에 준한다고 본다.

(2) 공유설

위 제한은 무체재산권의 특수성에서 유래한 것에 불과하므로 그 범위를 벗어난 부분에는 민법상 공유에 관한 규정이 적용된다고 본다.

3. 판례

종전 판례는 특허의 공유관계를 민법 제273조의 합유에 준하는 것이라고 하였다(87후111). 그러나 그 후 판례는 위 각 제한으로 그 범위에서 합유와 유사한 성질을 가지지만 이는 특허권이 무체재산권인 특수성에서 유래한 것으로 보일 뿐이고, 공유자들이 반드시 공동목적이거나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없으며 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하지 아니하는 범위에서는 민법상 공유에 관한 규정이 적용된다고 한다(2002후567, 2013다41578).

4. 검토 및 결론

공유자 사이에 조합체와 같은 인적 결합관계가 당연히 존재한다고 볼 수 없고 합유로 본다는 명문의 규정도 없으므로 판례가 타당하다. 따라서 특허권의 공유는 민법상 공유의 준공유에 해당하고, 다만 제99조 제2항·제4항, 제139조 제2항·제3항의 한도에서 합유와 유사한 성질을 가진다.

II. 설문 (2) — 공유특허권의 분할청구

1. (2)-1) 특허법 제99조 제2항 및 제4항 규정의 취지, 공유특허권에 대한 분할청구권 인정 여부, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용되는지 여부 (8점)

(1) 제99조 제2항·제4항의 취지

공유자는 계약으로 달리 정한 경우를 제외하고 다른 공유자의 동의 없이 지분비율과 관계없이 특허발명 전체를 실시할 수 있으므로(§ 99③), 새로 공유자나 실시권자가 되는 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 그 경제적 효과가 현저하게 달라져 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있다. 판례도 이러한 공유관계의 특수성을 고려하여 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한 데에 그 취지가 있다고 한다(2013다41578).

(2) 공유특허권에 대한 분할청구권의 인정 여부

① **(견해의 대립)** 부정설은 i) 동일한 발명에 대하여 복수의 특허권이 발생하게 되고, ii) 일부 공유자의 일방적인 청구로 다른 공유자가 사실상 특허권의 처분을 강요당하게 된다는 점을 든다. 긍정설은 공유자 사이의 신뢰관계가 깨어진 경우 그 결속관계에서 벗어날 수 있도록 하는 것이 타당하다고 본다.

② **(판례)** 판례는 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 그 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 변동이 발생한다고 보기 어려워 제99조 제2항·제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없다고 한다(2013다41578).

③ **(검토)** 현물분할이 허용되지 아니하는 이상 복수의 특허권이 발생한다는 부정설의 우려는 생기지 아니하고, 분할청구는 이해관계가 대립하는 공유관계를 조기에 해소할 필요에서 부득이하게 인정되는 것이므로 판례가 타당하다.

(3) 민법상 공유물분할 규정의 적용 여부

특허권의 공유에도 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하지 아니하는 범위에서 민법상 공유에 관한 규정이 적용되고(2002후567), 분할청구권을 인정하더라도 제99조 제2항·제4항의 취지에 반하지 아니하므로, 민법 제268조·제269조의 공유물분할에 관한 규정은 특허권의 공유관계에도 적용된다(2013다41578).

2. (2)-2) 현물분할이 허용되는지 여부 및 담당 법원이 경매에 의한 대금분할을 명할 수 있는지 여부 (5점)

(1) 현물분할의 허용 여부

특허권은 발명의 실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라, 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다(2013다41578).

(2) 경매에 의한 대금분할의 가부

현물로 분할할 수 없거나 분할로 인하여 현저히 그 가액이 감소될 염려가 있는 때에는 법원은 물건의 경매를 명할 수 있으므로(민법 제269조 제2항), 담당 법원은 이 사건 특허권에 대하여 경매에 의한 대금분할을 명할 수 있고, 판례도 특허권 등에 대하여 대금분할을 명한 원심을 정당하다고 하였다(2013다41578). 공유자의 1명이 다른 공유자의 지분을 취득하고 그 대가를 지급하는 가격배상에 의한 분할도 가능하다. 한편 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자가 분할청구 이전부터 그 특허발명을 실시하고 있었다면 경매 등으로 특허권이 이전되더라도 통상실시권을 가지며, 이 경우 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(§ 122).

3. 결론

甲은 乙을 상대로 공유물분할을 청구할 수 있고, 담당 법원은 현물분할을 명할 수는 없으나 경매에 의한 대금분할을 명할 수 있다.

III. 설문 (3) — 공동심판의 당사자적격과 심결취소소송의 원고적격

1. 무효심판의 피청구인 적격과 적극적 권리범위확인심판의 청구인 적격 (4점)

(1) 무효심판의 피청구인 적격

공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 하므로(§ 139②), 丁은 甲과 乙 모두를 피청구인으로 하여야 하고, 이에 위반한 심판청구는 부적법하여 심결각하된다(§ 142). 판례도 특허처분은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위이므로 공유자의 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구할 수 없다고 한다(2012후2432).

(2) 적극적 권리범위확인심판의 청구인 적격

특허권의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 하므로(§ 139③), 甲과 乙이 공동으로 청구하여야 한다. 판례는 그 심판절차가 공유자 모두에게 합일적으로 확정되어야 하므로 이를 고유필수적 공동심판으로 본다(87후111). 다만 공유자 중 1명이 단독으로 청구한 후에도 다른 공유자의 동의가 있으면 청구인을 추가하는 보정을 할 수 있다(§ 140②(1)).

2. 심결취소소송의 원고적격 (8점)

(1) 문제의 소재

제139조 제2항·제3항은 심판청구에 관하여만 규정할 뿐 심결취소소송의 제기에 관하여는 아무런 규정을 두고 있지 아니하므로, 공유자에게 불리한 심결에 대한 취소소송을 공유자 모두가 공동으로 제기하여야 하는지 아니면 그중 1명이 단독으로 제기할 수 있는지가 문제된다.

(2) 견해의 대립

① **(고유필수적 공동소송설)** 공유자의 관리처분권이 공동으로 귀속되고 심판절차와의 통일을 기하여야 하므로 공유자 모두가 원고가 되어야 한다고 본다.

② **(유사필수적 공동소송설)** 심결의 취소를 구하는 것은 권리의 소멸을 방지하기 위한 보존행위에 해당하므로 공유자 각자가 단독으로 제기할 수 있다고 본다.

(3) 판례

판례는 공유자 모두가 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자 중 1명이라도 그 등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있으면 그 권리의 소멸을 방지하거나 권리행사방해의 배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다고 한다(2002후567). 최근 판례도 거절결정불복심판에서 패소한 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자에 관하여 같은 취지로 판시하였다(2024후10825).

(4) 검토

i) 공유자 중 1명이 단독으로 제기하여 심결을 취소하는 판결이 확정되면 그 효력이 다른 공유자에게도 미쳐(행정소송법 제29조 제1항) 공유자 모두와의 관계에서 심판절차가 재개되고, 청구를 기각한 판결이 확정되더라도 심결에 불복하지 아니한 다른 공유자의 권리에 영향이 없으므로 합일확정의 요청에 반하지 아니한다. ii) 반면 공유자 모두의 제소를 요구하면 그중 1명이라도 소재불명·파산 등으로 소의 제기에 협력할 수 없거나 이해관계를 달리하여 의도적으로 협력하지 아니하는 경우 나머지 공유자가 출소기간의 만료와 동시에 권리행사에 장애를 받거나 그 의사에 기하지 아니하고 재산권을 침해당하는 부당한 결과에 이른다. 따라서 판례가 타당하다.

(5) 사안의 포섭

무효심판의 심결에 대하여는 적극적 권리범위확인심판의 심결에 대하여든, 甲과 乙은 공동으로 원고가 될 수 있음은 물론 각자 단독으로도 원고적격을 가진다. 이때 피고는 각 심판의 상대방인 丁이 된다(§ 187단서). 다만 공유특허권자를 피고로 하는 경우에는 심판과 마찬가지로 공유자 모두를 피고로 하여야 하는 고유필수적 공동소송이다.

3. 결론

丁의 무효심판은 甲과 乙 모두를 피청구인으로 하여야 하고 甲과 乙의 적극적 권리범위확인심판은 두 사람이 공동으로 청구하여야 하나, 그 각 심결에 대한 취소소송은 甲 또는 乙이 단독으로 제기할 수 있다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특정 포인트
(1) 특허권 공유의 법적 성격	5	합유설/공유설/절충설 대립, 제37조 제3항·제99조 제2항·제4항의 제한, 판례(2002후567)의 준공유설, 자기 결론
(2)-1 제99조 제2항·제4항 취지·공유물분할청구권 인정 여부·민법 규정 적용 여부	8	①제99조 제2항·제4항 취지(공유관계 특수성·경제적 가치 변동 방지), ②분할청구권 인정 여부(2013다41578 긍정), ③민법 공유물분할 규정의 준용 가부
(2)-2 현물분할 가부 및 경매에 의한 대금분할 가부	5	무체재산권 성질상 현물분할 불가, 대금분할 명령 가능(2013다41578)
(3)-1 무효심판 피청구인 적격 / 적극적 권리범위확인심판 청구인 적격	4	제139조 제2항 피청구인 甲·乙 모두(고유필수적), 제139조 제3항 청구인 甲·乙 공동청구(고유필수적)
(3)-2 심결취소소송의 원고적격	8	무제한설 대응이 아닌 당사자적격 논점, 고유필수/유사필수 대립, 판례(2002후567) 유사필수적 공동소송, 공유자 1인 단독제소 적법

합계: 30점

축별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- 문제 (1)이 요구하는 것은 '공유의 법적 성격'(합유·공유·절충의 대립 및 결론)임을 정확히 포착했는가. 채점평이 지정한 대로 '법적 성격'을 충분히 설명하지 못하면 대목 감점.
- 문제 (2)-1은 세 개의 소논점(§ 99②④ 취지 / 분할청구권 인정 여부 / 민법 규정 적용 여부)이 병렬적으로 요구됨을 인식하고 각각 답했는가.
- 문제 (2)-2에서 현물분할 부정 + 대금분할 긍정의 2013다41578 판례 결론을 정확히 제시했는가.
- 문제 (3)-1은 제139조 제2항 vs 제139조 제3항의 조문 구분(피청구인 vs 청구인)을 정확히 대응시켰는가.
- 문제 (3)-2는 '심결취소소송의 심리범위'가 아니라 '원고적격(공유자 1인의 단독 제소 가부)' 문제임을 정확히 파악했는가(논점 오인 시 큰 감점).

2) 목차·구성(25%)

- 로마숫자·아라비아숫자 목차 체계로 5개 설문을 명확히 구분했는가. 채점평이 강조한 '목차 구분 없이 산문식 나열' 회피.
- 배점 비례 분량 배분: (2)-1(8점)과 (3)-2(8점)에 지면을 두텁게, (3)-1(4점)은 간결하게 작성했는가.
- 각 쟁점별로 '조문→학설·판례→사안 포섭→소결' 순서를 유지했는가.

3) 답안 작성·논증(35%)

- 조문(§ 99②④, § 139②③, § 186②) 정확 인용 및 판례 번호(2002후567, 2013다41578) 명시.
- 학설 대립 시 자기 결론 명시(채점평: 결론 없는 나열 감점).
- 사안 포섭: 甲과 乙이 공유자라는 사실을 각 논점에 구체적으로 대입.
- 논리 일관성: (1)에서 공유(준공유)로 결론지었으면 (2)·(3)의 논리(민법 준용, 유사필수적 공동소송)와 정합해야 함.

감점 주의

- (1)에서 조문 나열만 하고 학설 대립·판례 결론을 제시하지 않는 것(채점평 지적).
- (2)-1의 세 소논점 중 제99조 제2항·제4항 취지 또는 민법 준용 여부를 누락하는 것.
- (2)-2에서 현물분할 불가만 쓰고 경매에 의한 대금분할 가능성을 누락하는 것.
- (3)-1에서 제139조 제2항 제139조 제3항의 조문번호 미인용, '고유필수적 공동심판' 성질 결여.
- (3)-2를 '심결취소소송의 심리범위(무제한설·제한설)' 문제로 오인하는 치명적 논점 착오.
- 배점 낮은 (3)-1(4점)에 지면을 과다 배분, 배점 높은 (3)-2(8점)를 요약식으로 처리하는 것(채점평 지적).
- 목차 없이 산문식 나열, 판독 불가능한 글씨(채점평 지적).

2016년 제4문

사례형

20점

문제

각 사례를 읽고 다음 물음에 답하십시오.(각 사례는 독립적이다.)

(1) 乙은 甲에 대한 채권자이며, 甲이 채무이행을 하지 않자 甲을 상대로 하여 위 채무에 관한 이행 판결을 받아 그 판결이 확정되었다. 甲은 위 판결에 기한 강제집행을 면탈할 목적으로 A회사를 설립하였다. 甲은 X발명을 완성한 발명자로서 특허를 받을 권리를 A회사에 양도하고 A회사 명의로 특허출원·등록 받았다.

1. A회사가 등록받은 특허권의 유효성을 논하십시오.(5점)

2. 乙이 A회사에 대하여 취할 수 있는 조치를 논하십시오.(5점)

(2) 甲은 乙에게 자신의 특허를 받을 권리를 양도하고, 단순히 이 사실을 알고 있는 丙에게 위 특허를 받을 권리를 양도하였다. 그 후 丙은 자신의 명의로 특허출원하여 등록을 받았다. 丙의 특허권의 유효성에 대하여 논하십시오.(4점)

(3) 甲은 X발명에 대하여 특허권을 취득한 후 이를 丁에게 양도하였다. 또한 甲은 Y발명에 대하여 특허를 출원한 후, 출원 중인 특허를 받을 수 있는 권리를 丁에게 양도하였다. 그에 따라 X발명에 대해서 丁의 명의로 특허권이전등록이 이루어졌고, Y발명에 대해서는 丁의 명의로 출원인 명의 변경이 이루어져 丁이 특허권 설정등록을 받았다. 만약 甲과 丁 사이의 2개의 양도계약이 각각 무효 또는 취소 등의 사유로 효력을 상실하였다면, 甲이 丁에게 취할 수 있는 조치를 논하십시오.(6점)

모범답안

문제 4 모범답안 (20점)

I. 설문 (1) — A회사 특허권의 유효성과 乙이 취할 수 있는 조치

1. A회사 특허권의 유효성 (5점)

(1) 문제의 소재

특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자의 출원은 제33조 제1항 본문에 위반되어 무효사유가 된다(§ 133①(2)). 甲은 X발명을 완성한 발명자이므로, 甲으로부터 그 권리를 양수한 A회사가 정당한 승계인인지, 즉 강제집행을 면탈할 목적으로 이루어진 양도의 효력이 어떠한지가 문제된다.

(2) 관련 법규정 및 법리

① (권리의 승계) 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있고(§ 37①), 특허출원 전에 이루어진 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(§ 38①). 따라서 발명자로부터 적법하게 권리를 승계한 자가 자기 명의로 출원하여 등록받은 특허는 무권리자의 특허가 아니다.

② (강제집행 면탈 목적 양도의 효력) 채무자가 강제집행을 면탈 목적으로 재산을 처분하였더라도 그 처분행위가 당연히 무효로 되는 것은 아니고, 채권자를 해하는 한도에서 채권자취소권(민법 제406조)의 대상이 될 뿐이다. 다만 양도인과 양수인이 통모하여 양도의 외형만을 갖춘 것이라면 통정허위표시로서 무효이고(민법 제108조), 이 경우 양수인은 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 못한다.

(3) 사안의 포섭 및 결론

甲이 A회사에 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 것이 유효한 이상 A회사는 정당한 승계인으로서 자기 명의로 출원하여 등록받은 것이므로, 강제집행을 면탈할 목적이 있었다는 사정만으로 A회사의 특허권이 무효로 되지는 아니한다. 다만 甲과 A회사가 통모하여 양도의 외형만을 갖춘 허위의 양도라면 A회사는 무권리자에 해당하여 그 특허에는 제133조 제1항 제2호의 무효사유가 있다.

2. 乙이 A회사에 대하여 취할 수 있는 조치 (5점)

(1) 문제의 소재

乙은 甲에 대한 확정판결상의 채권을 가질 뿐 A회사에 대하여는 아무런 채권이 없고, 특허권은 이미 A회사 명의로 되어 있어 甲의 책임재산에서 벗어나 있으므로, 乙이 A회사를 상대로 취할 수 있는 수단이 문제된다.

(2) 甲이 A회사에 대하여 가지는 권리

甲과 A회사 사이의 양도가 통정허위표시 등으로 무효라면 A회사는 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 못한 것이어서 그 특허는 제33조 제1항 본문에 위반되어 제133조 제1항 제2호 본문의 무효사유가 있다. 따라서 정당한 권리자인 甲은 무효심판을 청구한 후 심결 확정일부터 30일 이내에 정당한 권리자로서 특허출원을 하거나(§ 35), 법원에 그 특허권의 이전을 청구하여 이전등록을 받음으로써 제133조 제1항 제2호 단서에 의하여 무효사유를 해소할 수 있다(§ 99의2).

(3) 乙의 대위행사

제133조 제1항 제2호 본문의 무효심판은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 청구할 수 있고 제99조의2의 이전청구권자도 마찬가지이므로, 乙 자신은 특허법상의 구제수단을 행사할 수 없다. 따라서 乙은 甲이 무자력인 이상 확정판결상의 채권을 보전하기 위하여 甲이 A회사에 대하여 가지는 위 이전청구권을 대위행사하여야 한다(민법 제404조). 구법 아래에서는 정당한 권리자가 무권리자에게 직접 이전등록을 청구할 수 없어 순차적인 이전등록을 거쳐야 하였으나, 제99조의2의 신설로 甲이 A회사에 대하여 직접 이전을 청구할 수 있게 되었으므로 그러한 우회는 필요하지 아니하다.

(4) 결론

乙은 甲을 대위하여 A회사를 상대로 특허권의 이전을 청구함으로써 특허권을 甲의 책임재산으로 회복시킨 다음, 이에 대한 강제집행으로 채권의 만족을 얻을 수 있다.

II. 설문 (2) — 丙 특허권의 유효성 (4점)**1. 문제의 소재**

甲은 특허를 받을 수 있는 권리를 乙에게 양도한 후 다시 丙에게 양도하였고 丙이 자기 명의로 출원하여 등록받았으므로, 이러한 이중양도의 효력과 丙이 정당한 승계인인지가 문제된다.

2. 관련 법규정 및 법리**(1) 승계의 대항요건**

특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(§ 38①). 따라서 이중으로 양수한 자 중 먼저 출원한 자가 그 승계로써 다른 양수인에게 대항할 수 있다.

(2) 이중양도의 효력

이중양도라 하더라도 그 자체로 무효가 되는 것은 아니고, 양수인이 양도인의 배임행위에 적극 가담한 경우에 한하여 반사회질서의 법률행위로서 무효가 된다(민법 제103조). 이 경우 그 양수인의 출원은 무권리자의 출원이 되어 제133조 제1항 제2호의 무효사유가 있고, 먼저 양수한 자는 법원에 그 특허권의 이전을 청구할 수 있다(§ 99의2).

3. 사안의 포섭 및 결론

丙은 甲이 이미 乙에게 양도한 사실을 단순히 알고 있었을 뿐 甲의 배임행위에 적극 가담하였다고 볼 사정이 없으므로 甲과 丙 사이의 양도는 유효하고, 丙은 먼저 출원함으로써 乙에게 대항할 수 있다. 따라서 丙은 정당한 승계인으로서 그 특허권은 유효하고, 乙은 甲에 대하여 채무불이행에 따른 책임을 물을 수 있을 뿐이다.

III. 설문 (3) — 양도계약이 실효된 경우 甲이 丁에게 취할 수 있는 조치 (6점)**1. 문제의 소재**

X발명은 설정등록된 특허권이, Y발명은 출원 중인 특허를 받을 수 있는 권리가 각각 丁에게 양도되었는데 그 양도계약이 모두 실효되었으므로, 丁 명의의 각 특허에 무효사유가 있는지와 甲이 취할 수 있는 조치가 문제된다.

2. 丁 명의 특허의 하자

무권리자인지는 형식적으로 발명자 또는 그 승계인으로 기재되어 있는지가 아니라 실질적으로 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는지에 따라 판단한다. 양도계약이 실효된 이상 丁은 X발명의 특허권도 Y발명의 특허를 받을 수 있는 권리도 승계하지 못하였으므로, 丁 명의의 각 특허는 제33조 제1항 본문에 위반되어 제133조 제1항 제2호 본문의 무효사유가 있다.

3. 甲이 취할 수 있는 조치**(1) 무효심판의 청구와 정당한 권리자의 출원**

제33조 제1항 본문을 위반한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 무효심판을 청구할 수 있다(§ 133①(2)본문). 그 심결이 확정되면 甲이 확정일부터 30일 이내에 한 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 보므로(§ 35), 甲은 출원일을 소급받아 다시 특허를 받을 수 있다.

(2) 제99조의2에 의한 특허권의 이전청구

특허가 제133조 제1항 제2호 본문에 해당하는 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전을 청구할 수 있다(§ 99의2①). 이전등록이 되면 특허권과 보상금 지급 청구권은 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 보고(§ 99의2②), 이전등록된 특허권은 제133조 제1항 제2호 단서에 따라 무효심판의 대상에서 제외되어 그 무효사유가 해소된다.

(3) 검토

무효심판과 정당한 권리자의 출원에 의하면 특허권이 소급하여 소멸하고 다시 심사를 받아야 하는 반면, 이전청구에 의하면 기존의 특허권을 그대로 취득하고 무효사유까지 해소되므로 보다 실효적이다. 다만 이전등록 전에 선의로 실시하거나 실시사업을 준비한 자에게는 통상실시권이 인정될 수 있다(§ 103의2).

4. 결론

甲은 X·Y 각 특허에 대하여 무효심판을 청구하고 정당한 권리자로서 특허출원을 하거나, 제99조의2에 따라 법원에 특허권의 이전을 청구하여 제133조 제1항 제2호 단서에 따라 무효사유를 해소할 수 있다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	득점 포인트
설문(1)-1) A회사 특허권의 유효성	5점	특허받을 권리 이중양도 법리, 강제집행면탈 목적 A회사 설립=적극가담, 민법 제103조 반사회질서 무효, 무권리자 특허로 제33조 제1항-제133조 제1항 제2호 무효사유
설문(1)-2) 乙이 A회사에 취할 조치	5점	乙의 A에 대한 직접청구 불가, 甲의 A에 대한 부당이득반환에 기한 특허권이전등록청구권을 채권자대위(민법 §404)로 행사, 무효심판+정당권리자출원(§35) 실익 비교
설문(2) 丙 특허권의 유효성	4점	이중양도의 원칙적 허용, 단순약의로는 제103조 무효사유 아님(적극가담 부정), 출원=제3자 대항요건(§38①), 먼저 출원한 丙 유효
설문(3) 양도계약 실효 시 甲의 조치	6점	대법원 2003다47218: 부당이득반환으로서 특허권이전등록청구 인정(X·Y 모두), 무효심판+정당권리자출원(§35)의 실효성 저하 및 시기적 제한, 두 조치 비교

배점 합계: 20점

축별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- (1)-1)에서 '강제집행 면탈 목적 A회사 설립'을 이중양도 적극가담(민법 § 103)으로 포섭하였는가.
- (1)-2)에서 乙이 A에 대한 직접 청구권이 없다는 점과 채권자대위 구조를 정확히 지적했는가.
- (2)에서 '단순히 알고 있는' 사실이 적극가담이 아님을 포착하여 원칙적 유효로 결론냈는가.
- (3)에서 판례(2003다47218)의 '부당이득반환에 기한 특허권이전등록청구'를 X·Y 모두에 적용했는가.
- 배점이 큰 (3)을 소홀히 하고 (1)에 편중되지 않았는가(채점평: 배점 고려 미흡 지적).

2) 목차·구성(25%)

- 4개 설문을 목차로 명확히 구분하고 각 소설문별 소재목을 두었는가.
- 배점 비례(5:5:4:6)로 분량을 배분했는가.
- 조문→판례→사안포섭→소결의 일관된 구성을 유지했는가.
- 채점평 지적: 산문식 나열, 목차 구분 없음, 배점 불균형 감점.

3) 답안 작성·논증(35%)

- 특허법 제33조 제1항(발명자·승계인), 제38조 제1항(출원=제3자 대항요건), 제35조(정당권리자출원), 제133조 제1항 제2호(무효사유), 민법 제103조, 제404조(채권자대위) 등 적용 법규정을 정확히 인용했는가.
- 판례(2003다47218, 특허법원 2005허9282)의 취지를 정확히 적시했는가.
- 이중양도의 원칙적 유효/예외적 무효 법리를 사안별로 구분 적용했는가.
- 결론이 명확하고 본문과 모순이 없는가.

감점 주의

- (2)에서 '약의=무효'로 잘못 결론내는 실수(적극가담 요건 놓침).
- (1)-2)에서 乙이 A에게 직접 이전등록청구가 가능하다고 서술하거나, 대위행사 구조(甲→A, 乙→甲)를 누락.
- (3)에서 무효심판+정당권리자출원만 서술하고 판례상 특허권이전등록청구를 누락(가장 큰 감점).
- 조문 인용을 구법(§ 33①, § 38①) 그대로만 쓰고 현행법 확인 없이 서술.
- 특허법 제33조 제1항-제133조 제1항 제2호의 무효사유 연결을 빠뜨림.
- 배점 6점인 (3)을 짧게, 배점 4점인 (2)를 길게 쓰는 배분 실패.

PART 8

2017

제1문	전용품에 새로운 구성요소(D)를 부가한 경우 간접침해 성립 여부 · 전용품의 균등물(C')에 대한 간접침해 성립 여부	30점
제2문	표준특허·FRAND 선언의 개념과 침해금지청구권 행사 제한 여부 · FRAND 선언 표준특허권자의 권리행사가 권리남용에 해당하는지	20점
제3문	정정제도의 취지 및 종류(무효심판 중 정정, 취소신청 중 정정, 정정무효심판 중 정정)와 각 요건·절차·효과 · 대법원 계속 중 정정 인용 심결 확정 시 무효심판사건 처리	30점
제4문	공지예외 주장에서 '권리자에 의한 공개'의 의미 및 복수공지의 취급 () 국내우선권주장(\$55)과 공지예외 병행으로 X+X'를 하나의 출원으로 보호	20점

2017년 제1문

사례형

30점

문제

甲은 A+B+C로 구성되는 특허발명의 특허권자이고, 구성 C는 특허발명의 전용품이다. 이 사실에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 乙이 甲의 허락을 받지 않고 C+D를 판매하고 있다. 乙은 C+D는 D의 부가로 인하여 자신의 판매 행위는 특허법 제127조의 침해로 보는 행위에 해당하지 않는다고 주장한다. 乙의 주장이 타당한지에 대하여 논하시오. (8점)

(2) 乙이 C'(C'는 C와 균등의 물건이다.)를 판매하고 있는 경우, 乙의 판매가 특허법 제127조의 침해로 보는 행위에 해당할 수 있는지에 대하여 논하시오. (7점)

(3) 만약, 甲의 특허발명이 방법의 발명인 경우, 그 방법의 실시에만 사용하는 물건 C를 甲이 乙에게 양도했다면, 乙이 그 물건 C를 이용하여 해당 방법 발명을 실시하는 것이 특허침해에 해당하는지에 대하여 논하시오. (8점)

(4) 만약, 甲의 특허발명이 방법의 발명인 경우, 그 방법의 실시에만 사용하는 물건 C와 대비되는 물건을 심판 청구의 대상이 되는 발명으로 특정하여 甲이 권리범위확ixin심판을 청구하는 것에 대한 적법성 여부를 논하시오. (7점)

모범답안

문제 1 모범답안 (30점)

I. 설문 (1) — C+D 판매가 침해로 보는 행위에 해당하는지 (8점)

1. 문제의 소재

乙은 특허발명 A+B+C 중 A·B를 실시하지 아니하므로 구성요소완비의 원칙상 직접침해는 성립하지 아니한다. 다만 전용품인 C에 새로운 구성 D를 부가한 C+D의 판매가 침해로 보는 행위에 해당하는지, 특히 D의 부가로 전용성이 부정되는지가 문제된다.

2. 간접침해의 성립요건

(1) 의의 및 취지

특허법 제127조 제1호는 특허가 물건의 발명인 경우 "그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위"를 업으로서 하는 경우 침해로 본다고 규정한다. 특허발명 그 자체의 실시가 아니어서 직접침해는 아니나 방지하면 침해의 개연성이 높은 행위를 침해로 간주하는 것으로, 판례는 "발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것"이라고 판시하였다(2007후3356).

(2) 요건

간접침해가 성립하려면 1) 유효한 특허권이 존속하고, 2) 정당한 권원 없는 자가, 3) 전용품을 생산·양도·대여·수출·수입하거나 그 양도 또는 대여의 청약을 하며, 4) 이를 업으로서 하여야 한다.

3. 전용성과 다른 구성요소가 부가된 경우

(1) 「...에만」의 의미

판례는 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하려면 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적·상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 하고, 단순히 이론적·실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다고 한다(2007후3356).

(2) 다른 구성요소가 부가된 경우

판례는 확인대상발명의 감광드럼카트리지가 특허발명인 물건의 생산에만 사용되는 이상, 공지의 감광드럼카트리지에 개선된 페토너 회수통을 결합한 것이라 하더라도 간접침해의 성립에는 지장이 없다고 판시하였다(98후2580). 특허요건의 판단과 침해 성립요건의 판단은 별개이고, 다른 구성요소를 임의로 부가하는 것만으로 간접침해를 회피할 수 있게 되면 부당하기 때문이다. 부가로 다른 용도가 창출된 경우에도 그 용도가 위 기준에 이르지 아니하는 한 전용성은 유지된다.

4. 사안의 포섭

C+D도 결국 A·B와 결합하여 특허발명을 생산하는 데 사용될 수밖에 없고, D의 부가로 사회통념상 통용·승인될 수 있는 다른 용도가 창출되었다는 사정도 없다. 따라서 C+D는 여전히 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하므로 乙의 판매는 제127조 제1호의 침해로 보는 행위에 해당한다.

5. 결론

D를 부가하였다는 사정만으로 침해로 보는 행위에서 벗어난다고 볼 수 없으므로 乙의 주장은 타당하지 아니하다.

II. 설문 (2) — C의 균등물 C' 판매가 침해로 보는 행위에 해당하는지 (7점)

1. 문제의 소재

제127조 제1호는 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'이라고만 규정하므로, C와 균등한 물건인 C'가 이에 포함되는지, 즉 침해로 보는 행위의 판단에도 균등론이 적용되는지가 문제된다.

2. 균등물에 대한 간접침해의 성부

(1) 균등침해의 요건

청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 1) 양 발명의 과제의 해결원리가 동일하고, 2) 그 변경에 의하더라도 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 3) 그러한 변경을 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도이면, 4) 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하거나 출원절차에서 의식적으로 제외되는 등 특별한 사정이 없는 한 균등한 것으로서 권리범위에 속한다.

(2) 판례

판례는 특허된 물건의 생산에만 사용하거나 방법의 실시에만 사용하는 물건과 동일한 물건뿐만 아니라 균등한 물건인 경우에도 간접침해가 성립한다고 판시하였다(특허법원 2006허6679).

(3) 검토

전용품을 사용한 생산이 구성요소완비의 원칙에 의한 생산인 경우뿐만 아니라 균등론에 의한 생산인 경우에도 실질적으로 특허발명을 생산한 것으로 볼 수 있다. 또한 균등물에게까지 침해로 보는 행위를 인정하지 아니하면 구성의 사소한 치환만으로 규정을 회피할 수 있게 되어 특허권이 형해화되므로 판례가 타당하다.

3. 사안의 포섭

C'는 C와 균등한 물건이므로 A·B와 결합하면 특허발명과 균등한 물건이 생산되고, 이는 균등론에 의한 특허발명의 생산에 해당한다. 따라서 C'도 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당할 수 있다. 다만 이는 위 균등의 요건이 모두 충족되고, 나아가 C' 자체에 사회통념상 통용·승인될 수 있는 다른 용도가 없어 전용성이 인정될 것을 전제로 한다.

4. 결론

균등의 요건과 전용성이 인정되는 이상 乙의 C' 판매는 제127조 제1호의 침해로 보는 행위에 해당할 수 있다.

III. 설문 (3) — 방법발명의 전용품을 특허권자가 양도한 경우 (8점)

1. 문제의 소재

甲이 자신의 방법발명의 실시에만 사용하는 물건 C를 스스로 乙에게 양도하였다. 乙이 그 C를 이용하여 방법발명을 실시하는 것은 방법의 사용으로서 특허발명의 실시에 해당하나, 특허권 소진에 의하여 침해가 부정되는지, 특히 방법발명에도 소진이 적용되는지가 문제된다.

2. 특허권 소진

(1) 의의 및 근거

권리소진이란 특허권자 등이 특허발명을 실질적으로 구현한 물건을 적법하게 양도한 경우 그 물건에 관한 특허권은 목적을 달성하여 소진되고 그 후의 사용·양도 등에는 특허권의 효력이 미치지 아니하는 것을 말한다. 그 근거는 1) 적법하게 소유권을 취득한 양수인·전득자의 신뢰 보호, 2) 유통 과정의 보호, 3) 특허권자의 이중 이득 금지에 있다.

(2) 방법발명에 대한 소진의 인정 여부

종전 하급심은 단순한 방법의 특허에는 소진이론이 적용될 여지가 없다고 보았으나(서울고등법원 99나59391), 판례는 방법발명에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법의 사용에 쓰이는 물건을 적법하게 양도한 경우로서 그 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것이라면 방법발명의 특허권도 이미 목적을 달성하여 소진되므로 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시하는 행위에 특허권의 효력이 미치지 아니한다고 판시하였다(2017다289903). 특허권자는 제127조 제2호에 의하여 그러한 물건을 양도할 권리를 사실상 독점하고 있어 실시 대가를 확보할 기회가 보장되어 있고, 방법발명을 소진의 대상에서 제외하면 청구항의 작성 형식만으로 소진을 손쉽게 회피할 수 있게 되기 때문이다.

(3) 실질적 구현의 판단기준

어떤 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것인지는 1) 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없는지, 2) 그 물건에 방법발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지, 3) 그 물건을 통하여 이루어지는 공정이

방법발명의 전체 공정에서 차지하는 비중 등을 종합적으로 고려하여 구체적·개별적으로 판단한다(특허법원 2008허13299).

3. 사안의 포섭

C는 甲의 방법발명의 실시에만 사용하는 물건이므로 사회통념상 인정되는 본래의 용도가 그 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도가 없다. 또한 전용품인 이상 방법발명의 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소를 포함하고 그 전체 공정에서 차지하는 비중도 크다고 볼 수 있으므로 C는 방법발명을 실질적으로 구현한 물건에 해당한다. 나아가 그 양도는 특허권자인 甲 자신에 의한 적법한 양도이다.

4. 결론

甲의 특허권은 C의 양도로 소진되었으므로 乙이 C를 이용하여 방법발명을 실시하는 것은 특허침해에 해당하지 아니한다. 다만 특허권이 공유인데 다른 공유자가 양도에 동의하지 아니하였다면 제99조 제4항에 반하여 소진이 인정되지 아니하나, 사안에는 그러한 사정이 없다.

IV. 설문 (4) — 방법발명의 전용품과 대비되는 물건을 확인대상발명으로 한 권리범위확인심판의 적법성 (7점)

1. 의의 및 취지

권리범위확인심판은 확인대상발명에 특허권의 효력이 미치는지를 확인하는 심판으로(§ 135), 분쟁의 조기 해결에 취지가 있다.

2. 적법요건

(1) 주체

적극적 심판은 특허권자·전용실시권자가 청구인이고, 확인대상발명을 실시하였거나 실시하는 이해관계인이 피청구인이다.

(2) 객체

확인대상발명이 대상이며, 청구항이 둘 이상이면 청구항마다 청구할 수 있다(§ 135③).

(3) 시기

현존하는 권리범위의 확정이 목적이므로 특허권 존속 중에 청구하여야 한다.

(4) 절차

심판청구서에 특허발명과 대비할 수 있는 확인대상발명의 설명서·도면을 첨부하여야 하고(§ 140①·③), 확인대상발명은 청구취지의 일부이므로 보정은 요지변경이 아닌 범위에서만 허용된다(§ 140②, 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하는 보정은 예외 — § 140②(3)).

3. 확인대상발명의 특정

(1) 간접침해 물건의 대상적격

특허발명의 보호범위는 제127조에 의하여 그 방법의 실시에만 사용하는 물건에도 미치므로 간접침해 물건도 심판의 대상이 될 수 있고(98후2580), 방법발명의 전용품과 대비되는 물건도 확인대상발명이 될 수 있다.

(2) 청구취지·청구원인으로서의 특정

청구취지로서의 특정은 일사부재리의 객관적 범위를 정하므로 사회통념상 다른 것과 구별되도록 기재하여야 하고, 청구원인으로서의 특정은 대응 부분의 구체적 구성을 차이점 판단에 필요한 정도로 적으면 족하다. 전자가 불명확하면 보정을 명하고 그래도 미흡하면 각하하나, 후자가 다소 불명확하여도 속부판단이 가능하면 본안심결을 할 수 있다.

(3) 실시 제품과 사실적 관점의 일치

적극적 심판에서 특정된 확인대상발명이 피청구인의 실제 실시 발명과 다르면 확인의 이익이 없어 각하된다(2002후2419). 이 동일성은 양 발명이 **사실적 관점에서 같다고 보이는 때에만** 인정되고, 균등관계에 있다는 것만으로는 부족하다. 실시 사실의 증명책임은 심판청구인에게 있다.

4. 사안의 포섭

(1) 주체

甲은 특허권자로서 청구인적격이 있고, 피청구인은 그 물건을 실시하였거나 실시하는 자여야 한다. ② **(객체)** 간접침해 물건이 대상이 되는 이상 방법발명의 전용품 C와 대비되는 물건이어도 문제가 없다. ③ **(시기)** 甲의 특허권이 존속 중이어야 한다. ④ **(절차)** 위 기준에 따라 특정하고 실시 제품과 사실적 관점에서 일치시켜야 한다.

5. 결론

방법발명의 전용품과 대비되는 물건이라는 이유만으로 부적법하지 아니하므로, 위 요건과 특정을 갖추는 한 甲의 청구는 적법하다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

설문	쟁점	배점	특정 포인트
(1)	전용품에 새로운 구성요소(D)를 부가한 경우 간접침해 성립 여부	8	제127조 제1호 요건(전용성·업으로서 실시), 대법원 98후2580(전용품에 개선 부품 결합해도 전용품성 유지), 사안포섭
(2)	전용품의 균등물(C)에 대한 간접침해 성립 여부	7	균등론 5요건(과제해결원리 동일·치환가능성·치환용이성·공지기술 아님·의식적 제외 없음), 특허법원 2006허6679(전용품 균등물도 §127 적용), 사안포섭
(3)	방법발명의 전용품을 특허권자가 양도한 경우 소진 여부	8	소진이론 일반, 방법발명 원칙적 소진 부정 vs 방법의 실시에만 사용하는 물건을 양도한 경우 소진 인정(대법원 2017다289903 등), 사안 결론(비침해)
(4)	방법발명의 전용품을 대상으로 한 권리범위확인심판 청구의 적법성	7	권리범위확인심판 일반·확인 의 이익, 확인대상발명 특정, 대법원 2003후1109(방법발명의 전용품 대비 청구 적법), 사안 결론(적법)
합계		30	

축별 채점 기준

1) 논점 추출(약 12점)

- (1) 직접침해가 아님을 짧게 배제한 뒤 간접침해 성립여부로 논점 좁혔는가. 전용품에 새 구성요소 부가 시 전용품성이 유지되는지 판례 논점을 포착했는가.
- (2) 균등론 요건을 나열하는 데 그치지 않고, 「간접침해에서도 균등론이 적용되는지」라는 핵심 쟁점을 잡았는가.
- (3) 방법발명에서의 소진 부정 원칙과 「방법의 실시에만 사용하는 물건 양도」 예외 법리를 구분했는가.
- (4) 방법발명 전용품을 대상으로 한 권리범위확인심판의 적법성(확인 의 이익·특정)을 정면으로 다뤘는가.
- 감점: 균등론 일반론만 장황히 서술, 제127조 조문 전사 후 사안포섭 누락, 소진 일반론만 서술하고 방법발명 소진 논점 누락.

2) 목차·구성(약 7점)

- 설문 (1)~(4)를 대제목으로 분리하고, 각 설문 내에서 「일반론(요건)→판례→검토→사안의 해결」의 소목차 체계를 유지했는가.
- 배점(8/7/8/7)에 맞춰 분량을 배분했는가. (1)·(3)이 (2)·(4)보다 다소 두텁게.
- 채점평 지적: 소목차 없이 한 페이지에 통으로 쓴 답안 감점. 소제목·문단 구분 필수.

3) 답안 작성·논증(약 11점)

- 조문 (§ 127) 정확 인용(제1호·제2호 표기 정확) → 판례(사건번호·판시취지) → 사안 포섭 → 결론의 4단 구성을 지켰는가.
- (1) 98후2580의 「전용품에 개선된 부품을 결합해도 여전히 특허발명 생산에만 사용되는 물건이면 간접침해」 취지를 사안에 정확히 포섭했는가.
- (2) C'가 C의 균등물이라는 전제에서 전용품의 균등물에도 제127조이 미친다는 결론을 명확히 밝혔는가.
- (3) 방법발명 원칙적 소진 부정 → 예외(전용품을 특허권자가 양도한 경우 목시적 실시허락·소진 인정) → 비침해 결론까지 일관되게 논증했는가.
- (4) 대법원 2003후1109를 근거로 「방법발명의 전용품과 대비되는 물건」을 확인대상발명으로 한 청구를 적법하다고 결론지었는가.
- 감점: 결론이 애매하거나 본문과 모순, 판례 취지를 사안에 연결하지 못한 채 인용만 하는 경우.

감점 주의

- 직접침해와 간접침해 구분 실패:** (1)에서 C+D가 A+B+C+D 전부 실시가 아니므로 직접침해 아님을 먼저 배제하지 않고 바로 간접침해로 뛰어드는 경우 논리 순서 감점.
- 「~에만」 요건 오해:** 전용품에 개량 부품이 부가되어도 궁극적으로 특허발명 생산에만 쓰이면 전용성이 유지된다는 판례 취지를 놓치면 결론이 반대로 나옴.
- 조문 표기 오류:** 현행 제127조은 항 구분 없이 각 호로 구성되므로 물건발명 전용품은 「제127조 제1호」, 방법발명 전용품은 「제127조 제2호」로 표기해야 함. 「제127조 제1항 제1호」, 「제127조 제2항」와 같이 항 번호를 붙이면 감점.
- 간접침해 요건 단정 서술:** 직접침해 존재 여부(독립설/종속설), 침해자 고의 요부 등은 학설 대립이 있으므로 「판례·통설이 독립설을 채택하였다」는 식의 단정은 감점 소지. 학설 대립 소개 수준으로 서술할 것.
- 소진이론에서 방법발명 예외 누락:** 방법발명은 소진되지 않는다고만 쓰고 「전용품 양도 시 예외」를 놓치면 (3)의 결론(비침해)에 도달할 수 없음.
- 권리범위확인심판 각하론으로 흐르는 오류:** (4)에서 간접침해 대상물은 확인 의 이익이 없다고 단정하지 말 것. 대법원 2003후1109가 적법성 인정.
- 글씨·답안지 배치:** 채점평에서 명시적으로 지적된 사항. 소목차·여백·문단 나눔 필수.
- 일반론 과다:** 균등론·소진이론·권리범위확인심판의 의의·법적 성질 등을 지나치게 길게 쓰면 사안 해결 지면이 줄어들어 배점 손실.

2017년 제2문

사례형

20점

문제

甲은 부호분할다중접속(CDMA) 인코딩 및 디코딩과 관련된 특허를 보유하고 있다. 해당 특허는 표준제정기구에 의해 표준으로 채택되었으며, 甲은 해당 특허에 대하여 공정하고, 합리적이며, 비차별적인 라이선스를 허락한다는 프랜드(FRAND) 선언을 하였다. 乙은 甲의 허락을 받지 않고 이 사건 발명을 업으로 실시하였다. 甲은 乙에 대하여 특허침해를 주장하면서, 이 사건 발명의 사용에 대한 금지청구소송을 제기하였다. 이에 대해 乙은 甲이 프랜드 선언을 하였음에도 불구하고 침해금지를 청구하는 것은 권리남용에 해당한다고 주장하였다.

- (1) 甲의 침해금지청구소송에 대한 인용 여부를 논하시오. (8점)
- (2) 乙의 권리남용 주장이 타당한지에 대하여 설명하시오. (5점)
- (3) 甲이 침해금지에 대한 가처분을 신청하는 경우, 가처분의 승인 여부와 그 근거를 설명하시오. (7점)

모범답안

I. 설문 (1) — 침해금지청구소송의 인용 여부 (8점)

1. 침해금지청구권의 발생

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(§ 94①), 권리를 침해하거나 침해할 우려가 있는 자에게 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(§ 126①). 乙은 정당한 권원 없이 업으로서 특허발명을 실시하였으므로 침해가 성립하고, 甲의 금지청구권은 일응 발생한다.

2. 표준필수특허와 FRAND 선언

(1) 의의

표준필수특허란 표준기술의 구현에 반드시 실시되어야 하는 특허이다. 표준으로 선정된 기술은 대체에 상당한 전환비용이 들어 시장에서 장기간 막대한 영향력을 가지므로, 표준화 기구는 표준기술 선정에 앞서 관련 특허 정보를 미리 공개하게 하고(적시 공개 의무), 공정·합리적·비차별적 조건으로 실시허락할 것을 사전에 합의하도록 한다(FRAND 선언 의무).

(2) FRAND 선언의 법적 성격

판례는 FRAND 선언이 'FRAND 조건에 의한 실시권 허락'의 약속 내지 일반 원칙의 선언에 불과하여, 불특정 제3자에게 실시권을 부여하는 구속력 있는 확약의 의사표시로 볼 수 없다고 한다. 실시료 조건의 구체적 정함이 없어 청약으로 볼 수 없고, 실시요구나 실시료 기탁 없는 일방적 실시를 승낙으로 볼 수도 없으므로 라이선스 계약이 성립하지도 아니한다(2011가합39552).

3. FRAND 선언이 금지청구권의 행사를 제한하는지

(1) 학설

FRAND 선언은 성실한 협상의무를 부담시킬 뿐 금지청구권 자체를 포기한 것은 아니라는 견해와, 금지청구를 하지 아니하리라는 신뢰를 부여하였으므로 이후의 금지청구는 금반언·권리남용이라는 견해가 대립한다.

(2) 판례

판례는 FRAND 선언을 한 표준특허권자는 실시요구자와 성실하게 협상할 의무를 부담하고, 여기에는 **상대방이 명시적·묵시적으로 협상거절이나 포기의 의사표시를 하기 전까지는 침해금지청구권을 행사하지 아니할 의무도 포함**된다고 한다. 다만 이 의무는 **정상적으로 실시요구를 하는 잠재적 실시권자, 또는 표준특허의 유효성을 전제로 FRAND 조건에 의한 실시료 부담의사를 표시한 자와 동일시할 수 있는 제3자에 대하여 부담**한다. 따라서 FRAND 선언만으로 무단 실시하는 제3자에 대한 침해금지청구권까지 포기한 것으로 해석할 수 없으므로, 실시권 허락 요청 없이 무단으로 실시하거나 특허의 유효·침해 여부를 부인하면서 실시하는 제3자에게 침해금지 등을 구하더라도 금반언의 원칙에 반하거나 권리남용에 해당하지 아니한다(2011가합39552).

(3) 검토

FRAND 선언의 취지는 성실하게 실시허락을 구하는 잠재적 실시권자의 보호에 있고, 실시허락을 구하지도 아니하는 자에게까지 금지청구를 부정하면 실시료 지급을 지연·회피하는 역 특허역류가 발생하므로 판례가 타당하다.

4. 사안의 포섭

乙이 실시허락을 요청한 사정이 보이지 아니하고 허락 없이 업으로 실시하였으므로 甲의 금지청구는 FRAND 선언으로 제한되지 아니한다. 다만 乙이 실시허락을 구하였음에도 甲이 성실한 협상의무를 이행하지 아니하였다면 결론이 달라질 수 있다.

5. 결론

甲의 침해금지청구는 인용될 것이다.

II. 설문 (2) — 권리남용 주장의 타당성 (5점)

1. 판단 법리

권리의 행사는 신의에 좇아 성실히 하여야 하고 권리를 남용하지 못한다(민 § 2). 일반적으로 권리남용이 되려면 주관적으로 권리행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있고 객관적으로 그 권리행사가 사회질서에 위반되어야 한다. 그러나 특허권의 행사에 관하여 판례는 상대방에 대한 특허권의 행사가 특허제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 거래질서를 어지럽히고 수요자 또는 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는 권리남용으로서 허용될 수 없고, 이때 권리행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주려는 데 있어야 한다는 **주관적 요건이 반드시 필요한 것은 아니라고** 한다(2011가합39552).

2. 표준필수특허권 행사의 남용 여부

표준필수특허권자가 성실하게 협상의무를 이행하지 아니한 채 침해금지를 청구하는 행위는 부당하다고 판단될 가능성이 크다. 그 이행 여부는 1) 잠재적 실시권자에게 공식적으로 협상을 제안하였는지, 2) 협상기간이 적절하였는지, 3) 제시한 실시허락 조건이 합리적·비차별적인지, 4) 합의에 이르지 못할 경우 법원이나 중재기관에 회부하기로 하였는지를 고려하여 판단한다. 반면 실시허락을 받을 의사가 없는 잠재적 실시권자에 대한 금지청구까지 부정하면 역 특허억류가 발생하므로, 그러한 경우에는 부당하다고 보기 어렵다.

3. 사안의 포섭

甲이 비합리적인 실시료를 요구하거나 실시허락을 부당하게 회피하는 등 성실한 협상의무를 위반하였다는 사정은 나타나 있지 아니하고, 오히려 乙이 실시허락을 구하지도 아니한 채 일방적으로 실시하였다.

4. 결론

甲의 권리행사가 신의성실의 원칙에 위배된다고 볼 수 없으므로 乙의 권리남용 주장은 타당하지 아니하다.

III. 설문 (3) — 침해금지가처분의 인용 여부 (7점)

1. 의의 및 요건

침해금지가처분은 다툼이 있는 권리관계에 관하여 임시의 지위를 정하기 위한 가처분으로서, 그 요건은 1) 피보전권리의 존재와 2) 보전의 필요성이다.

2. 피보전권리

앞서 본 바와 같이 甲의 침해금지청구권(§ 126①)이 FRAND 선언에 의하여 제한되지 아니하므로 피보전권리는 인정된다.

3. 보전의 필요성

(1) 판단기준

임시의 지위를 정하는 가처분은 현저한 손해를 피하거나 급박한 위험을 막기 위하여 또는 그 밖의 필요한 이유가 있는 경우에 허용된다(민집 § 300②). 판례는 그 신청이 받아들여지려면 피보전권리가 인정되는 외에 **가처분 인용 여부에 따른 당사자 쌍방의 이해득실관계, 본안소송의 승패 예상, 그 밖의 제반 사정을 법원이 합목적적으로 고려하여** 보전의 필요성이 인정되어야 한다고 한다(상표권 사건에 관한 것이나 같은 취지, 2005마944). 특허권침해금지 가처분에서는 무효심판이 청구되고 그 이유나 증거관계로부터 장래 특허가 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 등의 특별한 사정이 있으면 **당사자 간의 형평을 고려하여 보전의 필요성을 결한 것으로** 본다(92다40563).

(2) FRAND 선언 표준특허의 특수성

FRAND 선언을 한 특허권자는 합리적인 실시료를 받고 실시를 허락하겠다는 의사를 표시하였으므로 손해는 실시료 상당액의 배상으로 전보될 수 있고, 금지가 인용되면 표준기술 시장에서 경쟁사업자가 배제될 수 있다. 따라서 보전의 필요성은 신중하게 판단하여야 한다. 그러나 실시허락을 받을 의사가 없는 실시자에 대하여는 침해금지가 유일한 구제수단이 될 수 있고 이를 부정하면 역 특허억류가 발생하므로, 그러한 경우까지 보전의 필요성이 부정되는 것은 아니다.

4. 사안의 포섭

乙은 실시허락을 구하지 아니한 채 무단으로 실시하는 자이므로 실시허락을 받을 의사가 없는 실시권자에 해당할 여지가 크고, 甲이 성실한 협상의무를 위반하였다거나 이 사건 특허가 무효로 될 개연성이 높다는 사정도 나타나 있지 아니하다. 따라서 FRAND 선언을 하였다는 사정만으로 보전의 필요성이 부

정된다고 볼 수 없다.

5. 결론

피보전권리가 인정되고 보전의 필요성도 부정되지 아니하므로 甲의 가처분 신청은 인용될 수 있다. 다만 乙이 성실하게 실시허락을 구하였음에도 甲이 협상의무를 이행하지 아니한 경우라면, 손해가 실시료 상당액의 배상으로 전보될 수 있어 보전의 필요성이 부정될 것이다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	득점 포인트
(1) 표준특허·FRAND 선언의 개념과 침해금지청구권 행사 제한 여부	8점	특허법 제94조·제126조, 표준특허·FRAND 선언의 의의, 침해금지청구 가부에 관한 학설·판례(서울중앙지법 2011가합39552, 삼성·애플 사건) 적시, '일방적 실시자'인지에 관한 사안 포섭
(2) FRAND 선언 표준특허권자의 권리행사가 권리남용에 해당하는지	5점	권리남용 일반론(민법 §2②), 특허권 남용 판단 기준, FRAND 선언 사안에서의 남용 판단기준(비합리적 실시료 요구·절차 악용·부당한 권리행사 유무), 사안 포섭
(3) 침해금지 가처분(민사집행법상 임시의 지위를 정하는 가처분) 승인 여부	7점	가처분의 의의·요건(피보전권리·보전의 필요성), FRAND 선언 특허의 경우 보전의 필요성 부정(실시료 산정 문제로 귀결), 사안 포섭

축별 채점 기준

1) 논점 추출(약 40%)

- **[+]** 표준특허·FRAND 선언의 개념을 정확히 정의하고, 이로 인해 침해금지청구권 행사가 제한될 수 있음을 문제제기
- **[+]** 설문(1)과 (2)를 구별: (1)은 침해금지청구권 자체의 성립·행사 제한, (2)는 권리남용 항변의 당부로 논점 분리
- **[+]** 설문(3)에서 본안(침해금지청구)과 가처분(보전처분)의 요건 차이(특히 보전의 필요성)를 인식
- **[-]** FRAND 선언·표준특허 개념을 누락하고 일반 침해론만 서술
- **[-]** (1)과 (2)에 동일한 논거를 반복 기재하여 논점 구별 실패
- **[-]** 가처분의 요건을 본안 인용 여부와 동일하게 취급

2) 목차·구성(약 25%)

- **[+]** 설문별 소목차를 분명히 구분하고 배점(8:5:7)에 비례해 분량 배분
- **[+]** 각 쟁점에 대해 '일반론(개념·요건) → 학설·판례 → 사안 포섭 → 소결' 구조 유지
- **[+]** (1)에서 침해요건(§ 94·유·정·보·업·실·제) 일반론을 최소화하고 FRAND 쟁점에 지면 할애
- **[-]** 서론에 표준특허 일반론을 장황하게 나열
- **[-]** 소목차 없이 통으로 서술(채점평이 특히 지적)

3) 답안 작성·논증(약 35%)

- **[+]** 서울중앙지법 2011가합39552(삼성·애플) 판례의 핵심 판시(FRAND 선언자는 원칙적으로 침해금지청구권을 행사하지 않을 의무를 부담하나, 정상적 실시요구 없는 '일방적 실시자'에 대하여는 여전히 행사 가능)를 정확히 인용
- **[+]** 권리남용 판단기준으로 ① 비합리적 실시료 요구, ② 절차 악용, ③ 권리의 부당행사를 제시하고 사안 포섭
- **[+]** 가처분의 보전의 필요성이 FRAND 선언 표준특허에서는 손해배상(실시료 상당액)으로 전보 가능하다는 이유로 부정된다는 논거 제시
- **[+]** 결론이 각 소결과 최종 결론에서 일관되게 명시
- **[-]** 판례 태도만 나열하고 사안에 포섭하지 않음
- **[-]** '乙이 실시요구를 하였는지' 여부에 대한 사안 검토 없이 결론

감점 주의

- FRAND 선언을 하였다는 사정만으로 일률적으로 침해금지청구를 부정하는 결론(판례는 '일방적 실시자'에 대하여는 여전히 인정)
- (1)과 (2)의 논거를 구분하지 않고 모두 '권리남용'으로 처리
- (3) 가처분에서 피보전권리 존재만으로 승인된다고 결론짓고 보전의 필요성 검토를 누락
- 표준특허·FRAND의 개념 정의 누락
- 채점평 지적사항: 소목차·글씨·답안지 배치를 소홀히 하여 가독성 저하

2017년 제3문

사례형

30점

문제

甲은 “A, B 및 C로 구성되는 클러치 구동축 제어장치”에 관한 특허발명의 특허권자이다. 乙은 특허심판원에 특허권자인 甲을 상대로 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1, 2, 3의 조합에 의하여 진보성이 부정된다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 특허발명은 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 乙의 심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 乙은 위 심결에 대해 특허법원에 심결취소소송을 제기하였다. 한편 특허법원은 甲의 특허발명은 비교대상발명 1, 2, 3을 결합하여 용이하게 도출할 수 있으므로 진보성이 부정된다는 이유로 乙의 청구를 인용하였다. 이에 甲은 이 사건 발명은 비교대상발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 주장하며 대법원에 상고하면서, 이 사건 특허발명에 대하여 특허심판원에 별도의 정정심판을 청구하였다.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 정정심판과는 별도로 특허의 정정제도를 두고 있는 취지를 포함하여 특허의 정정제도에 대하여 설명하시오. (10점)
- (2) 乙이 제기한 무효심판 사건이 대법원에 계속 중 甲이 청구한 정정심판의 인용심결이 확정된 경우 무효심판사건은 어떻게 처리되는지에 대하여 설명하시오. (5점)
- (3) 甲은 “자신이 청구한 정정심판청구가 받아들여질 경우에는 그 전의 청구범위를 기초로 한 진보성 판단은 무의미하게 되므로 상고심에서는 위 정정심판의 결과를 기다려 판단하여야 한다.”고 주장한다. 甲 주장의 타당성 여부에 대하여 논하시오. (5점)
- (4) 乙은 “클러치 구동축 제어장치에 관한 특허발명의 구성요소 A는 선행문헌 1에, 구성요소 B는 선행문헌 2에, 구성요소 C는 선행문헌 3에 각각 개시되어 있는바, 甲의 특허발명은 선행문헌과 명세서의 기재내용에 비추어보아 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없다.”고 주장한다. 이에 대해 甲은 어떻게 반박할 수 있을 것인지를 논하시오. (10점)

모범답안

문제 3 모범답안

I. 설문 (1) — 특허의 정정제도 (10점)

1. 정정심판과 별도로 정정제도를 둔 취지

특허법은 하자 있는 특허의 정정수단으로 정정심판(§ 136)을 두면서도, 무효심판·특허취소신청·정정무효심판 계속 중에는 별도의 정정제도(§ 133의2, § 132의3, § 137④)를 둔다. 그 취지는 1) 정정심판과 다른 심판의 병행 계속으로 인한 **모순·저촉된 심결의 방지**, 2) 하나의 절차에서 무효·취소사유의 제거와 특허의 유지를 함께 판단하는 **분쟁의 일회적·경제적 해결**에 있다.

2. 무효심판절차에서의 정정청구(§133의2)

(1) 주체

피청구인인 특허권자이다. 제133조의2 제4항이 준용하는 제136조 제8항에 따라 전용실시권자·질권자, 제100조 제4항·제102조 제1항의 허락실시권자 및 「발명진흥법」 제10조 제1항의 통상실시권자의 **동의를 받아야** 하나, 동의권자가 해당 무효심판을 청구한 경우에는 불요하다(§ 136⑧ 단서).

(2) 객체

제136조 제1항의 정정사유(청구범위 감축, 잘못된 기재의 정정, 분명하지 않은 기재의 석명)로 제한되고, 정정의 범위·실질적 확장변경 금지·정정 후 특허요건(§ 136③~⑤)이 준용된다(§ 133의2④). 다만 무효심판이 청구된 청구항의 정정에는 제136조 제5항은 준용되지 않는다(§ 133의2⑥).

(3) 시기

제133조의2 제1항에 따라 1) 제147조 제1항의 **답변서 제출기간**, 2) 제159조 제1항 후단의 **직권심리 의견서 제출기간**, 3) 청구인의 새로운 증거제출·무효사유 주장으로 심판장이 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하여 정한 기간에 청구할 수 있다.

(4) 절차 및 효과

무효심판절차 내에서 심리되어 별도의 심결 없이 무효심결에 포함되어 판단된다. 적법하면 정정 후 명세서·도면대로 특허출원·설정등록된 것으로 보고(§ 136⑩ 준용), 부적법하면 그 사유가 무효심결의 이유에 기재된다.

3. 특허취소신청절차에서의 정정청구(§132의3) — 무효심판과 다른 규정

정정사유(§ 136① 각 호), 정정의 범위와 실질적 확장·변경 금지(§ 136③④), 실시권자 등의 동의(§ 136⑧), 공유자의 공동청구(§ 139③), 앞선 정정청구의 취하 간주는 무효심판절차에서의 정정청구와 같다(§ 132의3①~③). 조문상 다른 점은 다음과 같다.

(1) 청구시기

무효심판에서는 위와 같이 심판장이 정한 추가 기간에도 정정청구를 할 수 있으나(§ 133의2① 후단), 특허취소신청에서는 **취소이유 통지에 따라 지정된 의견서 제출기간(§132의13②)에만** 청구할 수 있고 추가 기간 규정이 없다(§ 132의3①).

(2) 정정청구서 부분의 송달

무효심판에서는 심판장이 정정청구서 부분을 심판청구인에게 송달하여야 하나(§ 133의2③), 특허취소신청은 결정계 절차이므로 이에 대응하는 규정을 두고 있지 아니하다.

4. 정정무효심판절차에서의 정정청구(§137③·④) — 무효심판과 다른 규정

청구시기는 무효심판과 같고 새로운 증거·무효사유로 인한 추가 기간도 인정되며(§ 137③), 제137조 제4항이 제133조의2 제2항부터 제5항까지를 준용하므로 앞선 정정청구의 취하 간주·부분 송달·준용규정·취하 가능 기간도 같다. 다만 **제133조의2 제6항은 준용에서 제외**되어, 특허취소신청·무효심판과 달리(§ 132의3⑤, § 133의2⑥) 정정 후 청구범위의 사항이 특허출원 시 특허받을 수 있을 것(§ 136⑤)이 그대로 요구된다.

5. 결론

절차 내 정정청구는 주제·객체 요건은 대체로 공통되나 청구시기와 준용 범위에서 위와 같은 차이가 있고, **해당 절차와 일체로 심리·판단되어 정정심판을 별도로 거치지 아니하고도 하자를 치유할 기회를 특허권자에게 부여**하는 데 의의가 있다.

II. 설문 (2) — 정정 인용심결이 확정된 경우 무효심판사건의 처리 (5점)**1. 문제의 소재**

정정 인용심결이 확정되면 정정 후 명세서·도면에 따라 특허출원·설정등록된 것으로 본다(§ 136⑩). 정정 전 명세서로 진보성을 판단한 원심판결을 유지할 수 있는지, 즉 정정심결의 확정이 재심사유인지가 문제된다.

2. 종전 판례와 판례의 변경

종전 판례는 정정심결의 확정이 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 '판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때'에 해당한다고 보았다. 그러나 판례는 **무효심판 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 정정심결이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 위 재심사유가 있다고 볼 수 없다고** 판례를 변경하였다(2016후2522 전합).

3. 판례의 근거

그 근거는 다음과 같다. 1) 위 재심사유는 판결에 법률적 구속력을 미치거나 사실인정의 자료가 된 행정처분이 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는데, 원처분인 특허결정은 심결취소소송의 심리·판단 대상이지 판결의 기초가 된 행정처분이 아니다. 2) 정정은 종전 특허발명과의 실질적 동일성을 전제로 하고, 정정심결이 확정되어도 일사부재리가 적용되지 아니하고 정정무효심판으로 다룰 수 있어 정정 전 명세서가 확정적으로 변경되었다고 단정할 수 없다. 3) 제136조 제10항의 소급효는 이미 진행된 심사·심판절차의 효력을 정정 후 명세서에 승계시키려는 것이지 정정 전 명세서에 따른 모든 법률관계를 소급적으로 변경하려는 취지가 아니다. 4) 사실심 변론종결 후의 정정확정으로 사실심의 판단을 다투게 하면 분쟁 해결이 현저히 지연된다.

4. 사안의 포섭

정정 인용심결은 특허법원 변론종결 후 상고심 계속 중 확정되었으므로, 정정 전 청구범위로 진보성을 부정한 원심판결에 재심사유가 없다.

5. 결론

무효심판사건은 정정 전 청구범위를 기초로 판단되어 원심판결이 유지되고,甲의 상고는 기각된다.

III. 설문 (3) — 상고심이 정정심판의 결과를 기다려야 하는지 (5점)**1. 문제의 소재**

甲은 정정심판이 인용되면 정정 전 청구범위를 기초로 한 진보성 판단이 무의미해진다는 이유로 상고심이 그 결과를 기다려야 한다고 주장한다. 무효심판과 정정심판의 심리 순서, 그리고 정정심결 확정의 효력이 문제된다.

2. 판례

판례는 동일한 특허발명에 대하여 특허무효심판과 정정심판이 동시에 계속 중인 경우, **정정심판을 우선하여 심리·판단하는 것이 바람직하나 반드시 그러하여야 하는 것은 아니고**, 무효심판을 먼저 심리·판단하였다 하여 위법하다고 할 수 없으며, 이 경우 판단의 대상은 **정정심판청구 전의 특허발명**이라고 한다(2001후713). 이 법리는 두 심판의 심결취소소송이 법원에 계속 중인 경우에도 마찬가지이다. 나아가 판례는 사실심 변론종결 이후에 정정심결이 확정되더라도 원심판결에 재심사유가 있다고 볼 수 없다고 한다(2016후2522 전합).

3. 검토

정정심판의 결과를 반드시 기다려야 한다면 특허권자가 정정심판의 청구만으로 무효심판절차를 지연시킬 수 있어 분쟁의 신속한 해결을 해친다. 더욱이 사실심 변론종결 후의 정정확정은 재심사유도 되지 아니하므로, 상고심이 그 결과를 기다려야 할 근거가 없다. 특허권자는 무효심판절차 내의 정정청구(§ 133의2)나 사실심 변론종결 전의 정정심판으로 다룰 기회를 이미 보장받고 있다.

4. 결론

상고심은 정정심판의 결과를 기다릴 필요 없이 정정 전 청구범위를 기초로 진보성을 판단할 수 있으므로, 甲의 주장은 타당하지 아니하다.

IV. 설문 (4) — 진보성 부정 주장에 대한 甲의 반박 (10점)

1. 진보성 판단의 일반 법리

제29조 제2항은 통상의 기술자가 특허출원 시의 기술수준에 비추어 선행기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 발명은 진보성이 부정된다고 규정한다. 판단은 청구항의 목적·구성·효과를 종합하여 이루어지며, 증명책임은 무효를 주장하는 자에게 있다.

2. 반박논거 1) — 결합발명은 유기적 결합 전체로 판단

판례는 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우 각 구성요소가 **유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상**이 진보성 판단의 대상이므로, 구성을 분해하여 개별 구성요소가 공지되었는지만 따질 것이 아니라 **특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성**을 살펴야 하고 이때 결합된 전체 구성이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다고 판시한다(2013후2620). 사안에서 A+B+C의 결합이 각 개별 구성요소의 단순한 집합을 넘어 이질적·현저한 작용효과를 낳는다면, 각 구성요소가 선행문헌 1·2·3에 개별적으로 개시되어 있다는 사실만으로 진보성이 부정되지 않는다.

3. 반박논거 2) — 복수 선행문헌 결합의 요건 미비

판례는 여러 선행기술문헌을 인용하여 진보성을 부정하려면 그 기술을 조합·결합하면 해당 발명에 이를 수 있다는 **암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시**되어 있거나, 그렇지 않더라도 출원 당시의 기술수준·기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 업계의 요구 등에 비추어 통상의 기술자가 용이하게 그러한 결합에 이를 수 있다고 인정되는 경우이어야 한다고 판시한다(2013후2620). 사안에서 선행문헌 1·2·3에 이러한 결합 동기가 제시되어 있지 않다면 그 결합 자체가 허용되지 않으므로 진보성은 부정될 수 없다.

4. 반박논거 3) — 사후적 고찰 금지

판례는 진보성을 판단할 때 선행기술의 범위와 내용, 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준을 기록에 나타난 자료로 파악한 다음 **출원 당시의 기술수준에 비추어** 판단하여야 하고, **그 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로** 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다고 한다(2013후2620). 乙은 "선행문헌과 명세서의 기재내용에 비추어보아 용이하다"고 주장하는데, 이는 甲의 명세서를 이미 알고 있음을 전제로 선행문헌들을 재구성한 **전형적인 사후적 고찰**로서 허용되지 않는다.

5. 결론

甲은 1) 결합발명은 유기적 결합 전체로 판단되어야 하며 A+B+C의 결합이 낳는 현저한 효과, 2) 선행문헌 1·2·3 사이에 결합의 암시·동기가 없음, 3) 명세서의 기재를 참작한 판단은 사후적 고찰로 위법하다는 점을 들어 반박할 수 있다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	득점 포인트
(1) 정정제도의 취지 및 종류 (무효심판 중 정정, 취소신청 중 정정, 정정무효심판 중 정정)와 각 요건·절차·효과	10점	정정심판(§136)과 별도로 정정제도를 둔 취지(모순·저촉 방지, 분쟁의 일회적 해결), 무효심판 중 정정(§133의2), 특허취소신청 중 정정(§132의3), 정정무효심판 중 정정(§137④→§133의2 준용)의 주체·객체·시기 요건과 효과. 특히 무효심판 중 정정청구의 주체는 피청구인인 특허권자이고, 전용실시권자·질권자·제100조 제4항·제102조 제1항·발명진흥법 제10조 제1항의 통상실시권자의 동의를 얻어야 하며(§136⑧ 준용), 다만 동의를 받아야 하는 자가 무효심판을 청구한 경우에는 동의가 불필요함을 정확히 서술
(2) 대법원 계속 중 정정 인용심결 확정 시 무효심판사건 처리	5점	정정 소급효(§136㉔), 정정 전 명세서 기초 원심판결의 재심사유(민소§451①(8))에 해당 → 원칙적 파기환송, 예외 (2007후3394: 무효사유 판단 전제 사실인정에 영향 없으면 파기 불필요), 사안포섭
(3) 상고심에서 정정심판 결과를 기다려야 하는지(甲 주장의 당부)	5점	2001후713 판례 — 정정심판 우선판단 재량, 무효심판 판단대상은 정정 전 발명, 甲 주장 부당
(4) 결합발명의 진보성 판단방법 및 반박논거	10점	결합발명은 유기적 결합 전체로 판단(2009후1897), 복수 인용문헌 결합요건(2008후3377, 2017허4228: 기술분야·과제·작용효과 동일성 및 결합 암시), 사후적 고찰 금지(2007후3660), 명세서 기재를 근거로 한 결합은 사후적 고찰로 위법 → 반박

축별 채점 기준

1) 논점 추출(약 12점)

- 설문 (1)에서 '정정심판과 별도로' 두는 취지를 반드시 언급하고, 현행법상 정정제도 3가지(§ 133의2, § 132의3, § 137④)를 빠짐없이 나열했는가.
- 설문 (1)에서 무효심판 중 정정청구의 주체·객체·시기 요건을 조문에 정확히 근거하여 서술했는가(주체: 특허권자 + 전용실시권자·질권자 등의 동의; 시기: § 147①·§ 159① 후단·심판장 지정기간).
- 설문 (2)에서 정정 소급효 → 원심판결의 사실인정 기초 소멸 → 민소법 제451조 제1항 제8호 재심사유 → 파기환송이라는 논리 흐름을 포착했는가. 예외 판례(2007후3394)까지 언급하면 가점.
- 설문 (3)에서 무효심판/정정심판 병행계속 시 심리순서가 재량이고 판단대상은 정정 전 발명이라는 2001후713 법리를 정확히 포착했는가.
- 설문 (4)에서 ① 결합발명 판단법 ② 복수 인용문헌 결합 요건 ③ 사후적 고찰(특히 '명세서 기재내용에 비추어')이라는 3가지 반박 포인트를 모두 추출했는가.

2) 목차·구성(약 8점)

- 설문별로 로마숫자·아라비아 목차 체계로 구분하고, (1) 10점·(4) 10점에 분량을 더 배분했는가.
- (1)은 취지 → 각 정정제도별 요건·효과를 표·병렬 목차로 정리했는가(무효심판 중 정정 위주 서술 + 나머지는 차이점 위주).
- (4)는 일반론(진보성 판단방법) 최소, 사안 반박 3논점에 지면 집중했는가.

3) 답안 작성·논증(약 10점)

- 조문(§ 136⑧⑨⑩, § 133의2, § 132의3, § 137④, 민소 § 451①(8)) 정확히 인용.
- 판례 사건번호 또는 판시 취지 정확 인용(2007후852, 2007후3394, 2001후713, 2009후1897, 2008후3377, 2017허4228, 2007후3660).
- 각 설문 말미에 명확한 결론(파기환송/甲 주장 부당/반박 가능) 도출.
- 사안 포섭: 특히 (4)에서 "선행문헌과 '명세서의 기재내용에 비추어'" 판단한 부분이 사후적 고찰에 해당함을 사안에 밀착시켜 지적.

감점 주의

- (1)에서 정정심판(§ 136) 자체를 강항히 서술하고 정작 물어본 '정정심판과 별도의 정정제도'(§ 133의2 등)를 빠뜨리는 경우.
- (1)에서 무효심판 중 정정청구 주체를 '이해관계인의 동의'라고 부정확하게 표기하거나, 제136조 제8항 단서(동의 대상자가 무효심판을 청구한 경우 동의 불요)를 누락한 경우.
- (1)에서 시기적 요건을 '심리종결 통지 전 지정기간' 등 부정확한 표현으로 서술하고 제147조 제1항(답변서 제출기간)·제159조 제1항 후단(직권심리 시 의견서 제출기간)·심판장 지정기간을 조문상 정확히 특정하지 못한 경우.
- (2)에서 재심사유 조문(민소 § 451①(8))을 언급하지 않거나, 예외판례를 몰라 무조건 파기환송이라고 단정하는 경우(사안이 예외에 해당하는지 검토 필요).
- (3)에서 판례 인용 없이 '재량이다'만 단답형으로 결론짓는 경우.
- (4)에서 반박 논거를 1개만 제시(예: 사후적 고찰만)하고 결합발명 유기적 판단·결합 요건 미비를 놓치는 경우.
- 판례를 단순 나열하고 사안 포섭 없이 결론을 흐리는 경우(채점평 지적사항: 판례의 사실관계·법리 이해 부족).

2017년 제4문

사례형

20점

문제

甲은 A+B+C로 구성되는 발명 X를 완성한 후, 해당 발명의 사업화에 관심이 있는 乙과의 간담회에서 2015년 3월 2일 발명의 내용을 설명하였고, 乙은 2015년 3월 27일 진행된 자신의 사업설명회에서 발명 X를 공개하고 자세히 설명하였으나 해당 발명의 발명자에 대한 언급은 하지 않았다. 한편 甲은 2015년 8월 3일 발명 X에 대한 특허출원을 하면서 특허출원서에 공지예외의 취지를 기재하였고, 이를 증명할 수 있는 서류로서 2015년 3월 2일 乙과의 간담회 회의록을 제출하였다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (단, 물음 (1)과 (2)는 독립적이다.)

(1) 2015년 3월 27일 乙의 사업설명회에 참석한 丙은 지식재산처에 “甲의 특허출원은 신규성이 없어서 특허를 받을 수 없다.”는 내용의 정보제공을 하면서 그 증거로서 乙이 제공한 사업설명회 자료를 첨부하였다. 丙은 “특허법 제30조 제1항 제1호의 적용을 받기 위해서는 출원인이 해당 발명을 공개 하여야 하는데, 2015년 3월 27일의 공개는 乙이 하였으므로 공지예외를 인정받을 수 없다.”고 주장한다. 丙 주장의 타당성 여부를 검토하시오. (8점)

(2) 甲은 발명 X에 대한 특허출원 후 연구를 계속하여 발명 X에 대한 개량발명 X'를 완성하였다.

1. 甲이 자신의 발명 X와 X'를 하나의 출원으로 보호받기 위한 방법을 설명하시오. (6점)

2. 甲의 2015년 8월 3일 특허출원이 일본지식재산처에 한 출원인 경우 甲이 자신의 발명 X와 X'를 우리나라에서 하나의 출원으로 보호받기 위한 방법을 설명하시오. (6점)

모범답안

I. 설문 (1) — 丙 주장의 타당성 (8점)

1. 문제의 소재

공지예외를 인정받으려면 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 발명을 직접 공개하여야 하는지, 그리고 甲이 출원서에 기재하고 증명서류를 제출한 2015. 3. 2. 공개 외에 乙에 의한 2015. 3. 27. 공개에도 공지예외의 효과가 미치는지가 문제된다.

2. 관련 법규정 및 취지

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 출원 전에 공지 등이 된 경우, 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 제29조 제1항 또는 제2항을 적용할 때 공지되지 아니한 것으로 본다(§ 30①(1)). 이는 신규성·진보성 요건을 지나치게 엄격하게 적용하면 권리자에게 가혹하여 형평을 잃거나 산업발전이라는 특허법의 취지에 맞지 아니하는 경우가 생길 수 있기 때문이다. 적용을 받으려는 자는 출원서에 그 취지를 적어 출원하고 증명서류를 출원일부터 30일 이내에 제출하여야 한다(§ 30②).

3. '권리자에 의한' 공개의 의미

판례는 제30조에 의한 공개는 권리자의 **의사에 의한** 것이면 충분하고 반드시 권리자가 직접 공개하여야 하는 것은 아니며, 권리자가 공개를 의뢰하여 제3자가 공개하거나 제3자가 권리자의 허락(목시적 허락을 포함한다)을 받아 공개하는 경우도 포함된다고 한다(특허법원 2015허7308). 자기 발명의 공개로 특허를 받지 못하게 되는 가혹함을 막고 연구결과와 신속한 공개를 유도하려는 제30조의 취지에 비추어 타당하다.

4. 여러 번 공개한 경우 공지예외의 범위

판례는 권리자가 12개월의 기간 이내에 여러 번의 공개행위를 하고 그중 **가장 먼저 공지된 발명에 대해서만 절차에 따라 공지예외의 주장을 하였더라도, 공지된 나머지 발명들이 가장 먼저 공지된 발명과 동일성이 인정되는 범위에 있다면 나머지 발명들에까지 공지예외의 효과가 미친다**고 판시하였다(2023후10712). 같은 판결은 제30조 제1항이 공지예외의 효과가 미치는 '자기공지된 발명'과 출원의 대상인 '특허출원된 발명'을 구별하고 있으므로, 공지예외가 적용되기 위하여 반드시 자기공지된 발명이 특허출원된 발명과 동일하여야 한다거나 자기공지된 발명 그 자체가 출원되어야 하는 것은 아니라고 한다.

5. 사안의 포섭

乙은 甲과의 사업화 간담회를 통하여 발명 X를 알게 되어 사업설명회에서 공개한 것이므로, 2015. 3. 27. 공개는 甲의 의사에 기초한 공개로서 '권리자에 의한' 공개에 해당한다. 또한 그 공개의 내용은 2015. 3. 2. 공개된 발명 X와 동일성이 인정되는 범위에 있고, 甲은 가장 먼저 공지된 2015. 3. 2. 공개에 관하여 출원서에 취지를 적고 회의록을 증명서류로 제출하였으므로, 별도의 취지 기재나 증명서류 제출이 없더라도 2015. 3. 27. 공개에까지 공지예외의 효과가 미친다.

6. 결론

관리자가 직접 공개하여야만 제30조 제1항 제1호가 적용된다는 丙의 주장은 타당하지 아니하다.

Ⅱ. 설문 (2)-1) — 국내우선권주장출원에 의한 방법 (6점)

1. 문제의 소재

X'는 선출원 명세서에 없는 개량발명이므로 보정으로 추가하면 신규사항 추가로 허용되지 아니한다(§ 47②). 국내우선권주장출원(§ 55)에 의하여야 하는데, 선출원의 공지예외의 주장의 효과가 후출원에 어떻게 미치는지가 함께 문제된다.

2. 국내우선권주장출원

(1) 요건

자신이 특허받을 권리를 가진 선출원을 기초로 선출원일부터 1년 이내에 출원하여야 하고(§ 55①(1)), 선출원이 분할·분리·변경출원이 아니고(§ 55①(2)) 출원 시 포기·무효·취하되지 아니하였으며(§ 55①(3)) 설정등록되거나 거절결정·거절심결이 확정되지 아니하여야 한다(§ 55①(4)). 출원서에 취지와 선출원 표시를 하여야 한다(§ 55②).

(2) 효과

선출원의 최초 명세서·도면에 기재된 발명과 동일한 발명은 제29조, 제30조 제1항, 제36조 등을 적용할 때 선출원 시에 출원한 것으로 본다(§ 55③).

3. 공지예외적용주장을 수반하는 경우

(1) 12개월의 판단시점

후출원의 청구범위에 적힌 발명 중 선출원의 최초 명세서·도면에 기재된 발명과 **동일한 발명**은 제30조 제1항의 12개월의 판단시점이 선출원일로 소급되나(§ 55③), **동일하지 아니한 발명**은 소급되지 아니하므로 공지예외를 받으려면 공지된 날부터 12개월 이내에 국내우선권주장출원을 하여야 한다.

(2) 절차

제30조 제2항의 취지 기재와 증명서류 제출기간은 소급되지 아니하고 국내우선권주장출원일이 기준이므로, 후출원 시 다시 취지를 적고 후출원일부터 30일 이내에 증명서류를 제출하여야 한다.

4. 사안의 포섭 및 결론

X는 선출원 명세서에 기재된 발명과 동일하므로 12개월의 판단시점이 선출원일(2015. 8. 3.)로 소급되어, 선출원일부터 1년 이내인 2016. 8. 3.까지 국내우선권주장출원을 하면 공지예외의 효과가 유지된다. 그러나 X'는 선출원에 기재되지 아니하여 소급되지 아니하므로, X의 공지(2015. 3. 2.)를 선행기술에서 배제받으려면 그 날부터 12개월 이내인 2016. 3. 2.까지 출원하여야 한다. 따라서 甲은 2016. 3. 2.까지 X와 X'를 하나의 명세서에 적어 국내우선권주장출원을 하면서 우선권주장과 공지예외의 취지를 함께 적고 30일 이내에 증명서류를 제출하여야 한다.

Ⅲ. 설문 (2)-2) — 조약우선권주장출원에 의한 방법 (6점)

1. 문제의 소재

제1국 출원이 일본에 한 출원이므로 조약우선권주장출원(§ 54)에 의하여야 하는데, 이 경우에도 공지예외의 12개월이 제1국 출원일로 소급되는지가 문제된다.

2. 조약우선권주장출원

(1) 요건

파리협약 동맹국에 한 제1국 출원을 기초로 하여야 하고, 제1국 출원일부터 1년 이내에 대한민국에 출원하여야 하며(§ 54②), 출원서에 우선권주장의 취지와 최초 출원국명·출원연월일을 적고(§ 54③) 우선권 증명서류를 제출하여야 한다(§ 54④·⑤).

(2) 효과

우선권주장의 기초가 된 발명에 대해서는 제29조 및 제36조를 적용할 때 그 당사국에 출원한 날에 대한민국에 출원한 것으로 본다(§ 54①). 제30조는 그 소급 대상으로 열거되어 있지 아니하다.

3. 공지예외적용주장을 수반하는 경우

제30조 제1항 본문의 '특허출원'은 속지주의 원칙상 **국내의 특허출원**을 의미하므로, 조약우선권주장출원 자체가 공지된 날부터 12개월 이내에 이루어져야 공지예외의 적용을 받을 수 있다. 즉 12개월의 판단시점은 제1국 출원일로 소급되지 아니하며, 그 결과 **공지예외적용주장을 수반하는 조약우선권주장출원은 우선기간이 12개월 이하로 단축**된다. 취지 기재와 증명서류 제출기간도 우선권주장출원일을 기준으로 하므로 국내출원 시에 취지를 적고 그 날부터 30일 이내에 증명서류를 제출하여야 한다.

4. 사안의 포섭 및 결론

조약우선권주장 자체는 제1국 출원일(2015. 8. 3.)부터 1년 이내인 2016. 8. 3.까지 가능하나, X에 관한 공지예외를 받으려면 국내출원이 공지일(2015. 3. 2.)부터 12개월 이내여야 하므로 실제 기한은 2016. 3. 2.까지로 단축된다. 따라서 甲은 2016. 3. 2.까지 X와 X'를 하나의 명세서에 적어 일본 출원을 기초로 한 조약우선권주장과 공지예외적용주장을 함께 하여 출원하여야 한다. 이 경우 X는 제1국 출원일로 소급되어 판단되고, 제1국 출원에 없는 X'는 국내출원일을 기준으로 판단되어 하나의 출원으로 보호받을 수 있다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
(1) 공지의외 주장에서 '권리자에 의한 공개'의 의미 및 복수공지의 취급	8점	제30조 제1항 제1호의 '권리자에 의하여'는 권리자의 의사에 의한 공개이면 족함(2015허7308), 3.2. 甲의 공개→3.27. 乙의 반복공개는 공개행위의 연장선에 있어 공지의외 효과가 미침, 丙 주장 부당 결론
(2)-1) 국내우선권주장(§55)과 공지의외 병행으로 X+X'를 하나의 출원으로 보호	6점	2015.8.3. 선출원(X)을 기초로 1년 이내(2016.8.3.까지) X+X'를 하나의 명세서에 기재한 국내우선권주장출원, 공지의외 주장 병행, X에 대한 제30조 효과 승계
(2)-2) 조약우선권주장(§54)에 의한 X+X'의 국내 하나의 출원 보호	6점	일본 2015.8.3. 제1국출원을 기초로 12개월 이내(2016.8.3.까지) X+X'를 하나의 명세서에 기재한 조약우선권주장출원, 다만 최초공지일(2015.3.2.)로부터 12개월 도과 문제→공지의외를 위해서는 공지일 기준 12개월 내인 2016.3.2.까지 출원 필요, 조약우선권은 제30조 소급효 없음 유의

특별 채점 기준

1) 논점 추출 (약 40%)

- (1)에서 '권리자 직접 공개'가 요건인지에 대한 제30조 제1항 제1호의 해석 쟁점을 정확히 포착했는가.
- 甲의 3.2. 공지와 乙의 3.27. 공지가 밀접·불가분(공개행위 연장선) 관계인지 논점을 잡았는가(2015허7308).
- (2)-1)에서 보정 한계(신규사항 추가금지)로 X' 포섭 불가→국내우선권주장을 도출했는가.
- (2)-2)에서 조약우선권은 제30조 공지의외 소급 안 됨을 지적하여 출원기한(2016.3.2.)을 도출했는가.
- 무관한 일반론(제30조 취지 장황·§ 29 신규성 요건 나열)에 편중되면 감점.

2) 목차·구성 (약 25%)

- 설문 (1)/(2)-1)/(2)-2)로 목차 분리, 배점 비례(8:6:6) 분량 배분.
- 각 소문제 내부: 조문(§ 30, § 54, § 55) → 판례·해석 → 사안포섭 → 소결 구조.
- 공지의외 일반론은 최소화하고 사안 해결에 지면 할애.

3) 답안 작성·논증 (약 35%)

- 제30조 제1항 제1호 문언('권리를 가진 자에 의하여')과 판례(2015허7308) 문언을 정확히 인용.
- 반복공개=공개행위의 연장선 법리를 사안에 포섭하여 丙 주장이 부당함을 명확히 결론.
- 국내우선권(§ 55)과 조약우선권(§ 54)의 요건·기산일 차이를 조문에 근거하여 대비.
- 조약우선권주장출원 시 공지의외 12개월(공지일 기준)이라는 실무적 기한 산정 결론이 사안의 날짜(2015.3.2., 2015.8.3., 2016.3.2., 2016.8.3.)에 정확히 대응.
- 결론이 애매하거나 본문과 모순되지 않을 것.

감점 주의

- (1)에서 제30조 제1항 제2호(의사에 반한 공지)로 오폭섭하는 경우: 사안은 甲의 의사에 의한(자발적) 공개의 연장선이므로 ①1로 해결해야 함.
- 3.27. 乙의 공개에 대해 증명서류를 별도 제출하지 않아 공지의외 못 받는다고 결론짓는 경우(2015허7308 반복공개 법리 몰이해).
- (2)-1)에서 단순 보정(§ 47)만 언급하고 국내우선권(§ 55)을 놓치는 경우.
- (2)-1)에서 국내우선권의 요건 중 제55조 제1항 제2호(선출원이 분할·분리·변경출원이 아닐 것) 또는 제55조 제1항 제3호·4(선출원이 취하·무효·실정등록·거절확정 전) 등 소극적 요건을 완전히 누락한 경우.
- (2)-2)에서 조약우선권 기산일(제1국출원일)과 공지의외 기산일(공지일)을 혼동해 2016.8.3.까지 출원 가능하다고 잘못 결론.
- 조약우선권주장에도 제30조 효과가 소급된다고 오해하는 경우.
- 조문(§ 30, § 54, § 55) 미인용 또는 조문 전사식 나열.

PART 9

2018

제1문	PCT 영어원문과 최종국어번역문의 법적 지위 · 심사관이 국어번역문 기준으로 보정을 인정한 판단의 적법성	30점
제2문	발명의 단일성 요건과 사안 포섭 · 신규성 판단의 실질적 동일성 요건과 제1항 포섭	20점
제3문	조약우선권 인정 요건과 청구항별 판단시점(제54조) 및 각 청구항 거절이유 타당성 · 우선권 기간(1년) 도과 시 청구항 1의 판단시점 및 거절이유 타당성	30점
제4문	검토범위의 한정과 청구항 1·2 · 청구항 3: '청구항 1 및 청구항 2'(중복·비태일적 인용) — 명확성 위반	20점

2018년 제1문

사례형

30점

문제

甲은 영어로 작성된 발명의 설명 및 청구범위로 2016. 5. 1. 한국 지식재산청(수리관청)에 PCT출원을 하였지만, 지식재산청으로부터 “청구범위가 서식에 따라 작성되어 있지 않다”는 방식위반을 이유로 보정을 명받은 후, 2016. 7. 1. 보정한 청구범위를 제출하여 수리되었으며, 그 청구범위는 아래와 같다.

【발명의 설명(영문)】

실시에 1: A와 B로 구성되고, 특히 B는 b인 스마트폰이다.

실시에 2: 실시에 1의 스마트폰을 수단 C에 의해 고정하는 거치대이다.

【청구범위(영문)】

[청구항 1] A와 B로 구성되는 스마트폰.

[청구항 2] 제1항에 있어서, 상기 B는 b로 구성되는 스마트폰.

[청구항 3] 수단 C에 의해 스마트폰을 고정하는 거치대.

甲은 지정국인 한국 지식재산청에 국내절차를 진행하면서 다음과 같은 최종국어 번역문을 제출하였다.

【발명의 설명(국문)】

실시에 1: A와 B로 구성되고, 특히 B는 b 또는 g인 스마트폰이다.

실시에 2: 실시에 1의 스마트폰을 수단 C에 의해 고정하는 거치대이다.

【청구범위(국문)】

[청구항 1] A와 B로 구성되는 스마트폰.

[청구항 2] 제1항에 있어서, 상기 B는 g로 구성되는 스마트폰.

[청구항 3] 수단 C에 의해 스마트폰을 고정하는 거치대.

그 후 甲은 제1항이 진보성이 없다는 심사관의 거절이유를 해소하기 위하여 아래와 같이 청구범위를 보정하였으며, 심사관은 청구범위의 보정을 인정하여 특허결정을 하였고, 2018. 6. 1. 특허등록 제00호로 등록되었다.

【청구범위(등록)】

[청구항 1] A와 g로 구성되는 스마트폰.

[청구항 2] (삭제)

[청구항 3] 수단 C에 의해 스마트폰을 고정하는 거치대.

한편, 특허권자 甲은 “A와 g로 구성되는 스마트폰”을 판매하고 있는 乙 및 “수단 C에 의해 스마트폰을 고정하는 거치대”를 판매하고 있는 丙을 상대로 각각 특허침해금지청구소송을 제기하였다.

위 소송에 대응하여, 乙 및 丙은 甲의 특허권에 대한 무효자료를 조사한 결과, 2016. 4. 1. 반포된 간행물에 게재된 “수단 C1에 의해 스마트폰을 고정하는 거치대(증거자료 1)” 및 2016. 6. 1. 반포된 간행물에 게재된 “수단 C2에 의해 스마트폰을 고정하는 거치대(증거자료 2)”를 확인하였다.

위 지문에 기재된 사항만을 근거로 다음 물음에 답하시오.

(1) PCT출원의 영어원문과 최종국어번역문의 법적지위를 설명하시오. (5점)

(2) 지문에서 영어원문과 최종국어번역문이 차이가 있지만, 심사단계에서 영어원문과 대비하여 판단하지 않고 최종국어번역문을 근거로 보정을 인정한 심사관의 판단에 대한 적법성을 설명하시오. (5점)

(3) 乙은 甲의 특허권에 대해 무효심판을 청구하려고 한다. 무효심판의 청구취지와 그 청구취지에 부합되는 청구이유의 요지를 기술하시오. (10점)

(4) 丙은 법원에 丙의 판매제품이 [청구항 3]의 특허를 침해하지 않는다는 주장을 하려고 한다. 판례를 근거로 그 주장의 논거를 기술하시오. (10점)

모범답안

I. 설문 (1) — 영어원문과 최종국어번역문의 법적 지위 (5점)

1. 영어원문의 지위(§200의2)

대한민국을 지정국으로 한 국제출원은 그 국제출원일에 출원된 특허출원으로 본다(§ 199①). 국제출원일까지 제출된 출원서는 제42조 제1항에 따른 특허출원서로 보고(§ 200의2①), 같은 날까지 제출된 발명의 설명·청구범위·도면은 제42조 제2항에 따라 **특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면으로 본다**(§ 200의2②). 따라서 영어원문은 최초 첨부 명세서로서 번역문·보정의 신규사항 추가 여부(§ 47② 전단)의 판단기준이 된다. 나아가 원문주의에 따라 원문은 신규사항 추가 여부뿐만 아니라 **분할출원·분리출원·변경출원·국내우선권주장출원의 범위, 특허 후 정정의 범위, 확대된 선출원의 대상 발명**의 판단기준이 된다.

2. 최종국어번역문의 지위(§201)

외국어 국제특허출원의 출원인은 국내서면제출기간(우선일부터 2년 7개월) 이내에 발명의 설명·청구범위·도면의 국어번역문을 제출하여야 하고(§ 201①), 제출하지 아니하면 그 출원은 취하한 것으로 본다(§ 201④). 기준일까지 최종 국어번역문을 제출한 경우에는 **국제출원일까지 제출한 발명의 설명·청구범위·도면을 최종 국어번역문에 따라 국제출원일에 제47조 제1항에 따른 보정을 한 것으로 본다**(§ 201⑤). 최종국어번역문은 간주 보정된 명세서로서 국내단계의 심사·보정·특허여부결정과 등록 후 권리범위 해석의 실체적 기준이 된다. 다만 간주 보정도 보정인 이상 원문의 기재 범위를 벗어날 수 없고, 잘못된 번역은 보정 가능 기간에 오역정정으로 바로잡을 수 있다(§ 201⑥).

3. 결론

영어원문은 제200조의2에 의하여 특허출원서에 **최초로 첨부한 명세서**로 간주되어 신규사항 추가 여부와 분할·분리·변경·국내우선권주장출원 범위 등 판단의 기초가 되고, 최종국어번역문은 제201조 제5항의 **간주 보정**에 의하여 심사·특허의 실체적 기준이 되는 이원적 지위를 가진다.

II. 설문 (2) — 최종국어번역문을 근거로 보정을 인정한 심사의 타당성 (5점)

1. 번역문 제출의 입법 취지와 보정의 효과

국어번역문 제출 제도(§ 201)의 취지는 심사관이 원문을 직접 대비하지 아니하고 국어 명세서를 기준으로 심사할 수 있게 하는 **심사의 편의**에 있고, 이는 실체적 제도가 아니라 발명의 내용을 심사관과 공중에게 알리기 위한 절차적 제도이다. 이를 위하여 최종 국어번역문에 따라 국제출원일에 제47조 제1항에 따른 보정을 한 것으로 보는 효과가 부여된다(§ 201⑤). 이 간주 보정은 **제47조 제1항 본문의 시기에 이루어진 보정**이므로 적법하고, 따라서 심사관이 최종국어번역문을 기준으로 심사하는 것이 타당하다.

2. 한계 — 제47조 제2항 전단의 원문 기준 검토

다만 간주 보정도 보정인 이상 그 실체적 범위는 제47조 제2항 전단이 정하는 '최초로 첨부한 명세서 또는 도면'(=원문, § 200의2②)에 기재된 사항의 범위를 벗어날 수 없다. 따라서 **번역문이 제47조 제2항 전단을 만족하는지 의심스러운 경우에는 심사관은 원문을 검토하여야 한다**. 심사기준도 원문과 번역문은 일치할 개연성이 높아 일반적으로 번역문으로 판단하되, 다르다는 의문이 생기면 원문과 대조하도록 하고 있다.

3. 사안의 포섭

심사관이 최종국어번역문을 기준으로 심사하고 그에 근거한 청구범위 보정('A와 g로 구성되는 스마트폰')을 인정한 것 자체는 심사의 효율성 측면에서 타당하다. 그러나 번역문에는 원문에 없던 'g'가 발명의 설명과 청구항 2에 추가되어 제47조 제2항 전단 위반이 의심되었으므로 원문을 검토하였어야 함에도 이를 하지 아니하여, 심사관은 **원문에 없는 신규사항의 추가를 간과**하였다.

4. 결론

번역문을 기준으로 보정을 인정하여 심사한 것은 입법 취지와 심사기준에 부합하여 타당하나, 원문 검토가 필요한 사안에서 이를 누락하여 제47조 제2항 전단 위반을 간과한 하자가 있다.

III. 설문 (3) — 乙의 무효심판 청구취지·청구이유 (10점)

1. 청구취지

"특허등록 제00호의 청구범위 청구항 1, 청구항 3을 무효로 한다. 심판비용은 피청구인이 부담한다." 라는 심결을 구한다.

2. 청구이유

(1) 이해관계

청구인 乙은 피청구인 甲으로부터 이 사건 특허권에 기한 침해금지청구소송을 제기당한 자로서, 이 사건 특허의 무효 여부에 관하여 직접적이고 현실적인 이해관계를 가지는 이해관계인이므로 무효심판의 청구인 적격이 있다(§ 133①).

(2) 청구항 1 — 제47조 제2항 전단 위반

등록 청구항 1의 'g'는 국제출원일까지 제출된 원문(발명의 설명·청구범위)에는 없던 사항으로서, 최종국어번역문과 그에 기초한 보정에 의하여 비로소 도입된 것이다. 원문은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서로 간주되므로(§ 200의2②), 원문에 없는 'g'를 추가한 것은 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 보정으로서 제47조 제2항 전단에 위반되고, 이는 무효사유(§ 133①(6))에 해당한다.

(3) 청구항 3 — 제29조 제2항 위반

이 사건 국제출원은 청구범위의 서식 위반을 이유로 보정명령을 받아 2016. 7. 1. 보정된 청구범위가 수리되었으나, 이는 국제출원일 인정 요건의 흠결이 아닌 방식상 흠결에 불과하므로 방식심사 결과 국제출원일은 최초 제출일인 2016. 5. 1.로 소급하여 인정된다. 따라서 그 후인 2016. 6. 1. 반포된 증거자료 2는 선행기술의 지위에서 배제되고, 출원일 전인 2016. 4. 1. 반포된 증거자료 1만이 선행기술이 된다. 청구항 3(수단 C에 의해 스마트폰을 고정하는 거치대)은 통상의 기술자가 증거자료 1(수단 C1에 의해 스마트폰을 고정하는 거치대)로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 제29조 제2항에 위반되어 무효사유(§ 133①(1))에 해당한다.

(4) 청구항 3 — 제42조 제4항 제1호 위반

발명의 설명에는 실시예 1의 스마트폰(A와 B로 구성)을 수단 C에 의해 고정하는 거치대(실시예 2)만이 기재되어 있을 뿐이다. 그럼에도 청구항 3은 고정 대상을 한정하지 아니한 채 '스마트폰을 고정하는 거치대' 일반으로 기재되어 있는바, 청구항 3은 발명의 설명에서 청구범위까지 일반화 내지 확장이 되지 않으므로 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 아니하고, 제42조 제4항 제1호에 위반되어 무효사유(§ 133①(1))에 해당한다.

3. 결론

청구항 1은 원문 범위를 벗어난 보정(§ 47② 전단), 청구항 3은 진보성 결여(§ 29②)와 발명의 설명에 의한 뒷받침 결여(§ 42④(1))의 무효사유가 있으므로, 청구항 1·3은 무효로 되어야 한다.

IV. 설문 (4) — 丙의 비침해 논거 (10점)**1. 특허발명의 특징****(1) 기능적 표현으로 기재된 경우의 법리**

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지고, 발명의 설명이나 도면 등으로 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 그러나 청구범위에 적혀 있는 사항이 기능·효과·성질 등의 이른바 기능적 표현으로 되어 있어 그 기재만으로 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우, 침해 판단이나 권리범위 확인의 국면에서 문언 그대로 해석하면 명세서의 다른 기재에 비추어 명백히 불합리할 때 — 문언적으로 포함되는 것 중 일부가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않거나 의식적으로 제외된 것으로 보이는 경우 등 — 에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사, 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 권리범위를 제한 해석할 수 있다(대법원 2023후11340, 이른바 자가세정 정수기 사건). 구체적으로 기능적 표현으로 기재된 구성요소는 발명의 설명과 도면에 의하여 뒷받침되는 실시예의 범위 내에서 그 기술적 의미를 파악하여 특허발명을 특정하는 다음, 확인대상발명과 대비하여 구성요소완비의 원칙과 균등론을 적용한다.

(2) 사안의 포섭

청구항 3의 '수단 C에 의해 스마트폰을 고정하는'은 구체적 구조가 아닌 기능적 표현이고, 발명의 설명에는 그에 상응하는 실시예로 실시예 1의 스마트폰(A와 B로 구성)을 수단 C에 의해 고정하는 거치대(실시예 2)만이 기재되어 있다. 따라서 청구항 3의 권리범위는 **실시예 1의 스마트폰을 수단 C로 거치하는 거치대**로 제한 해석된다.

2. 구성요소완비의 원칙과 균등론의 적용 불가

丙이 판매하는 거치대는 실시예 1의 스마트폰이 아닌 다른 스마트폰을 거치하는 것이므로, 제한 해석된 특허발명의 구성과 그 유기적 결합관계를 그대로 포함하지 아니하여 구성요소완비의 원칙상 문언침해가 성립하지 않는다. 나아가 발명의 설명에 개시되지 아니한 기술사상까지 권리범위를 확대할 수 없다는 제한 해석의 취지상, 다른 스마트폰의 거치까지 균등의 범위로 포섭하는 것은 허용될 수 없으므로 균등침해도 성립하지 않는다.

3. 권리남용의 항변

청구항 3은 출원일(2016. 5. 1.) 전에 반포된 증거자료 1(수단 C1에 의해 스마트폰을 고정하는 거치대)로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있어 진보성 결여의 무효사유가 명백하다. 무효심결 확정 전이라도 무효사유가 명백한 특허권에 기초한 침해금지청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니하므로(대법원 2010다95390 전합), 丙은 침해소송에서 권리남용의 항변을 할 수 있다.

4. 자유기술의 항변

丙이 판매하는 거치대는 공지기술인 증거자료 1로부터 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술이므로, 특허발명과 대비할 필요 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다(대법원 2016후366). 증거자료 1은 甲의 공지예외의 주장과 무관한 제3의 공지기술이므로 이 항변에 장애가 없다.

5. 결론

丙은 1) 기능적 표현의 제한 해석에 따라 자신의 거치대가 제한 해석된 권리범위(실시예 1의 스마트폰의 거치)에 속하지 아니하여 문언침해·균등침해가 성립하지 않는다는 비침해 항변을 중심으로, 2) 증거자료 1에 기한 권리남용의 항변과 3) 자유실시기술의 항변을 병행하여 주장할 수 있다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
(1) PCT 영어원문과 최종국어번역문의 법적 지위	5	영어원문=국제출원일 소급의 기초 및 원문(국제출원일 명세서·청구범위·도면) 범위 판단의 기초, 국어번역문=심사·보정·특허결정의 실체적 기준(제201조 제5항의 보정 간주). 국제특허출원에는 제199조 제2항에 의해 제42조의3이 적용되지 아니하며, 원문 범위 판단은 제201조 제5항과 제47조 제2항 전단의 결합에서 도출됨을 정확히 지적
(2) 심사관이 국어번역문 기준으로 보정을 인정한 판단의 적법성	5	최종국어번역문 기준 심사 원칙(제201조 제5항). 국제출원일 원문 범위를 초과하는 보정은 제47조 제2항 전단 위반→제62조 제5호 거절이유가 되나, 국어번역문을 기준으로 심사한 판단 자체는 적법
(3) 청구항 1에 대한 무효심판 청구취지·청구이유 요지	10	청구취지 정형('등록 제00호 청구항 1을 무효로 한다'), 청구이유: ① 원문 범위 초과 보정(제47조 제2항 전단, 제201조 제5항→제133조 제1항 제6호), ② 진보성 흠결(제29조 제2항, 증거자료 1), ③ 뒷받침 요건 위반(제42조 제4항 제1호) 등
(4) 丙의 비침해 논거(청구항 3, 기능적 표현)	10	청구항 3의 '수단 C에 의해 고정하는'은 기능적 표현→권리범위 해석시 발명의 설명 기재 실시예(수단 C)로 제한해석, 丙 제품(C2)은 실시예에 포함되지 않음, 균등침해도 부정(2016마5698). 증거자료 2로 자유실시기술 항변 병행 가능

합계 30점

특별 채점 기준

1) 논점 추출 (12점)

- (1) 영어원문(국제출원일 소급·원문 범위 판단의 기초)과 국어번역문(심사·보정·특허 기준)의 이원적 지위 정확히 포착하고, 국제특허출원은 제199조 제2항에 의해 제42조의3이 적용되지 않으며 원문 범위 판단은 제201조 제5항·제47조 제2항 전단에서 도출됨을 지적: +3
- (2) 심사기준은 국어번역문이라는 원칙(제201조 제5항)과, 원문범위 초과시 별도 거절이유(제47조 제2항 전단 위반→제62조 제5호)라는 예외를 함께 포착: +3
- (3) 진보성 흠결(증거자료 1)뿐 아니라 원문 초과 보정(번역상 신규사항 추가)이라는 PCT 특유 무효사유(제47조 제2항 전단·제201조 제5항→제133조 제1항 제6호)까지 포착: +3
- (4) 청구항 3이 '수단 C에 의해 고정하는'이라는 기능적 표현임을 인식하고, 권리범위 해석시 제한해석 법리를 논점으로 삼음: +3
- 감점: 설문 (1)~(2)에서 국내 외국어특허출원(제42조의3)만 논하고 국제특허출원 특칙(제201조)을 놓친 경우, (4)에서 기능적 표현 논점을 놓치고 문언침해만 논한 경우

2) 목차·구성 (7점)

- 설문별로 목차를 분리하고 배점(5:5:10:10)에 비례한 분량 배분: +3
- (3)에서 청구취지와 청구이유를 명확히 구분 서술: +2
- (4)에서 '조문 → 판례(기능적 표현 제한해석, 균등침해 요건) → 사안 포섭 → 소결' 구조: +2
- 감점: 서론 장황, 일반론 나열, 조문 전사식 나열

3) 답안 작성·논증 (11점)

- (1) 제201조 제5항(보정 간주)과 제47조 제2항 전단(신규사항 추가 금지)의 결합 구조 정확 인용, 국제특허출원에 제42조의3(및 그에 따른 제47조 제2항 후단)이 적용되지 않는다는 점(제199조 제2항) 명시: +2
- (2) 심사관은 국어번역문 기준으로 심사한다는 원칙 인정(제201조 제5항) + 원문 초과 여부는 별도 거절이유(제47조 제2항 전단 위반→제62조 제5호) 지적: +2
- (3) 청구취지 정형 문구 + 청구이유(무효사유별 조문·증거 대응, 특히 원문 초과는 제47조 제2항 전단·제201조 제5항→제133조 제1항 제6호): +4
- (4) 대법원 2007후4977 등 기능적 표현 제한해석 판례 인용 및 사안 포섭(C≠C2): +2, 균등침해 부정(2016마5698 인용 또는 자유실시기술 항변): +1

감점 주의

- 국내 외국어특허출원 규정(제42조의3, 특히 제47조 제2항 후단)만 인용하고 PCT 국제출원의 특칙(제199조 제2항의 제42조의3 부적용, 제201조 제5항의 보정 간주)을 언급하지 않는 실수
- 원문 초과 보정의 적용 법규정을 '제47조 제2항 후단'으로 잘못 인용하는 오류. 국제특허출원의 경우 제199조 제2항에 의해 제42조의3이 적용되지 아니하므로, 원문(국제출원일 명세서·청구범위·도면) 범위 판단의 근거는 제47조 제2항 전단이며(제201조 제5항의 보정 간주와 결합), 그 위반은 제62조 제5호 거절이유·제133조 제1항 제6호 무효사유임
- 신규사항 추가 보정의 거절이유를 '제62조 제1호'로 잘못 인용하는 오류(제62조 제1호는 제25·29·32·36·44조 위반 사유이고, 제47조 제2항 위반은 명문으로 제62조 제5호의 거절이유임)
- 원문 초과와 근거로 제201조 제4항(不제출시 취하 간주 규정)을 인용하는 오류

- (2)에서 '심사관이 원문과 대비했어야 하므로 위법'이라고 단정하는 오류(원칙은 국어번역문 기준 심사가 적법하며, 다만 원문 초과가 있으면 별도 거절이유·무효사유가 됨)
- (3)에서 청구취지를 누락하거나 '특허를 무효로 한다'를 청구항 특정 없이 기재
- (4)에서 청구항 3의 '수단 C'를 기능적 표현으로 파악하지 않고 문언침해만 논해 결론이 흐려지는 오류
- 판례 사건번호를 임의로 부기하거나 존재하지 않는 조문번호를 만들어 인용

2018년 제2문

20점

문제

甲은 “필기볼(1)과 투명잉크관(2)으로 구성되는 볼펜”을 제1항으로, “필기볼(1)과 색변환잉크관(3)에 누름장치(4)가 부착되는 볼펜의 작동장치”를 제2항으로 특허출원을 하였다. 그 후 甲은 심사관으로부터 아래의 거절이유에 의해 특허를 받을 수 없다는 의견제출통지서를 받았다.

【甲의 특허출원전에 반포된 간행물의 인용발명 1은 “필기볼(1)과 잉크관(2')으로 구성되는 볼펜”, 인용발명 2는 “필기볼(1)과 색변환잉크관(3)으로 구성되는 볼펜”, 인용발명 3은 “필기펜촉(5)과 누름장치(4)로 구성되는 만년필”로 기재되어 있음】

1. 제1항과 제2항은 일 군의 발명에 해당되지 않아 단일성이 없으므로 특허법 제45조 제1항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없다.
2. 제1항은 인용발명 1과 실질적으로 동일하여 신규성이 없어 특허법 제29조 제1항 제2호의 규정에 의해 특허를 받을 수 없다.
3. 제2항은 인용발명 2와 비교하여 누름장치(4)의 구성이 없어 차이가 있지만, 그 차이는 인용발명 3의 누름장치(4)를 인용발명 2에 결합하는 경우, 통상의 기술자라면 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 없어 특허법 제29조 제2항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없다.

甲은 거절이유의 부당성을 검토하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 발명의 단일성 요건을 제시하고, 제1항과 제2항은 단일성 요건을 만족하므로 특허를 받을 수 있다는 주장의 논거를 기술하시오. (5점)
- (2) 신규성 판단에서의 실질적 동일성 요건을 제시하고, 제1항은 신규성이 있어서 특허를 받을 수 있다는 주장의 논거를 기술하시오. (5점)
- (3) 복수 구성요소의 진보성 요건을 제시하고, 제2항은 진보성이 있어서 특허를 받을 수 있다는 주장의 논거를 기술하시오. (10점)

모범답안

I. 설문 (1) — 발명의 단일성 요건과 제1항·제2항의 단일성

1. 발명의 단일성 요건

(1) 관련 법규정

특허법 제45조 제1항은 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군의 발명은 하나의 특허출원으로 할 수 있다고 규정하고, 특허법 시행령 제6조는 그 요건으로 1) 청구된 발명 간에 기술적 상호관련성이 있을 것, 2) 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가질 것을 요구하며, 이때의 기술적 특징은 선행기술과 비교하여 개선된 것, 즉 특별한 기술적 특징이어야 한다.

(2) 판단기준

단일성은 독립항을 기준으로 판단하고 각 독립항이 동일하거나 상응하는 특별한 기술적 특징을 공유하면 족하며, 컴비네이션과 서브 컴비네이션의 관계가 그 대표적인 예이다. 단일성 흠결은 절차상 하자에 불과하여 거절이유일 뿐이므로 그 심사는 필요 이상으로 엄격하게 하지 아니한다.

2. 사안의 포섭

(1) 기술적 상호관련성

제1항은 볼펜이고 제2항은 그 볼펜에 장착되어 작동을 담당하는 작동장치로서, 필기볼(1)을 공통 구성으로 하는 컴비네이션과 서브 컴비네이션의 관계에 있다.

(2) 상응하는 특별한 기술적 특징

제1항의 투명잉크관(2)은 인용발명 1에 대하여, 제2항의 색변환잉크관(3)과 누름장치(4)의 결합은 인용발명 2에 대하여 각각 개선된 기술적 특징이고, 양자는 모두 잉크관을 개량하여 사용자가 필기 상태를 인식·제어하게 한다는 공통의 과제를 해결하므로 서로 상응한다. 시행령은 동일할 것까지 요구하지 아니하므로 이 요건도 충족된다.

3. 결론

제1항과 제2항은 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군의 발명에 해당하여 특허법 제45조 제1항 단서의 단일성 요건을 충족하므로, 거절이유 1은 부당하다.

II. 설문 (2) — 신규성 판단에서의 실질적 동일성 요건과 제1항의 신규성

1. 실질적 동일성의 요건

(1) 관련 법규정

특허법 제29조 제1항 제2호는 출원 전 반포된 간행물에 기재된 발명은 특허를 받을 수 없다고 규정하며, 신규성은 청구항에 기재된 발명과 하나의 인용발명을 대비하여 판단한다.

(2) 판례의 법리

판례는 「구성요소에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 서로 동일성이 있다」고 하고(대법원 2003후472), 「두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없다」고 하여(대법원 2014후1181) 동일성의 범위가 진보성 판단과 같은 정도로까지 확대되어서는 아니 됨을 밝히고 있으며, 신규성 판단에서도 같은 취지이다(대법원 2007후2827).

2. 사안의 포섭

제1항과 인용발명 1은 잉크관을 투명한 것으로 한정하였는지에 구성상 차이가 있다.

(1) 새로운 효과의 발생

투명잉크관(2)은 사용자가 잉크의 잔량을 육안으로 확인할 수 있게 하여 인용발명 1의 잉크관(2')이 가지지 못한 새로운 효과를 가져오므로, 주지관용기술을 부가·삭제·변경한 정도의 미세한 차이가 아니다.

(2) 쉽게 도출할 수 있다는 사정만으로는 동일하다고 볼 수 없음

설령 잉크관을 투명하게 하는 것이 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라 하더라도 그러한 사정만으로 양 발명을 동일하다고 할 수 없다. 이는 진보성의 문제일 뿐이기 때문이다.

3. 결론

제1항은 인용발명 1과 사이에 새로운 효과를 수반하는 구성상 차이가 있어 실질적으로 동일하지 아니하므로 신규성이 인정된다. 거절이유 2는 부당하다.

III. 설문 (3) — 복수 구성요소 발명의 진보성 요건과 제2항의 진보성

1. 복수 구성요소 발명의 진보성 요건

(1) 관련 법규정

특허법 제29조 제2항은 통상의 기술자가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 특허를 받을 수 없다고 규정한다.

(2) 진보성의 일반적 판단방법

진보성은 발명의 목적과 구성 및 작용효과를 종합적으로 검토하되 구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성과 효과의 현저성을 참작하여 판단한다. 신규성과 달리 둘 이상의 인용대상을 조합할 수 있으나, 발명의 내용을 알고 난 뒤에 사후적으로 판단하여서는 아니 된다.

(3) 결합발명의 진보성 판단법리

판례는 「결합발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 발명은 전체로서 고려되어야 하며 구성요소 각각이 공지 또는 자명하다고 하여 진보성을 부정할 수 없고, 과제해결원리를 배제한 채 청구항에 기재된 구성을 하나하나 분해한 후 선행기술의 대응 구성요소로부터 도출이 곤란한지만을 따져서는 아니 되며, 특유의 과제해결원리에 기초하여 그 발명에 채용된 특유한 구성요소들과 나머지 구성요소들 사이의 결합관계를 포함하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 살펴보아야 한다」고 하고(대법원 2009후1897), 「결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다」고 한다(대법원 2019후10609). 나아가 여러 공지기술을 결합하여 진보성을 부정하려면 그 결합에 이를 수 있다는 교시·암시·동기가 제시되어 있거나, 출원 당시의 기술수준·기본적 과제·발전경향 등에 비추어 통상의 기술자가 쉽게 그 결합에 이를 수 있다고 인정되어야 한다.

2. 사안의 포섭

(1) 기술분야

인용발명 2는 볼펜이고 인용발명 3은 만년필로서 잉크의 점성과 공급방식 및 필기부의 구조를 달리하는 별개의 기술분야에 속한다. 다른 기술분야의 공지기술을 선행기술로 삼으려면 그 구성이 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 것이 아니고(범용성) 통상의 기술자가 별다른 어려움 없이 이용할 수 있어야 한다(채택용이성)(대법원 2006후2059). 만년필의 누름장치(4)는 필기펜촉(5)에 잉크를 공급하는 구조에 맞추어 설계된 것이어서 범용성이 없고, 이를 색변환잉크관(3)에 적용하려면 구조의 변경이 필요하다.

(2) 구성의 곤란성

두 인용발명 어디에도 누름장치(4)를 볼펜에 결합하라는 교시·암시·동기가 없고 과제나 기능·작용이 공통된다고 볼 사정도 없다. 심사관의 판단은 제2항의 과제해결원리를 배제한 채 구성을 하나하나 분해하여 대응 구성요소를 찾아낸 것에 지나지 아니한다. 제2항은 색변환잉크관(3)에 누름장치(4)가 부착되어 누름 조작에 따라 잉크의 색이 변환되는 유기적 결합관계를 이루므로 그 전체로서 구성의 곤란성을 살펴야 하며, 제2항의 내용을 미리 알고 이를 목표로 두 인용발명을 조합한 것은 허용되지 아니하는 사후적 고찰이다.

(3) 목적의 특이성 및 효과의 현저성

제2항은 하나의 필기구로 필기 도중 색을 전환한다는 두 인용발명이 예정하지 아니한 특유의 과제를 목적으로 한다. 그 효과도 색변환 기능과 누름 기능을 병렬적으로 더한 데 그치지 아니하고 누름 조작으로 색변환을 제어한다는 결합 전체로서의 특유한 효과로서, 각 기술의 작용효과의 단순한 집합을 넘는다.

3. 결론

제2항은 결합에 이를 교시·암시·동기가 없고 유기적으로 결합된 전체로서 구성의 곤란성과 효과의 현저성이 인정되므로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것이 아니다. 거절이유 3은 부당하다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
(1) 발명의 단일성 요건과 사안 포섭	5점	① 특허법 제45조 제1항 단서 및 시행령상 요건(하나의 총괄적 발명개념, 즉 동일·대응하는 특별한 기술적 특징(STF)의 공유) 제시 ② 제1항(불펜)과 제2항(볼펜의 작동장치)이 「필기불(1)」이라는 공통의 특별한 기술적 특징을 공유하고, 물건-그 물건의 특정 부분(작동장치)의 관계로 하나의 총괄적 발명개념을 형성한다는 포섭 ③ 결론 도출
(2) 신규성 판단의 실질적 동일성 요건과 제1항 포섭	5점	① 제29조 제1항 제2호 및 신규성 판단기준(전 구성요소 대비, 청구항 대 인용발명 1:1 대비) ② 실질적 동일성 = 주지·관용기술 부가·삭제·변경 등으로 새로운 효과가 없는 경우에 한정된다는 판례 법리(대법원 2003후472) ③ 제1항의 「투명잉크관(2)」과 인용발명1의 「잉크관(2)」은 색상 특정 유무에서 구성상 차이가 있고, 이는 단순 관용기술 부가·삭제로 볼 수 없는 새로운 효과(투명성)를 가짐 → 실질적 동일 아님
(3) 복수 구성요소 결합발명의 진보성 판단기준과 제2항 포섭	10점	① 제29조 제2항 진보성 판단기준(목적의 특이성, 구성의 곤란성, 효과의 현저성 / 사후적 고찰 금지, 결합의 용이성·동기·시사·암시 존부) ② 인용발명 2(볼펜)+인용발명 3(만년필)의 기술분야 상이성, 결합의 곤란성, 결합에 대한 시사·동기의 부재 ③ 색변환잉크관(3)과 누름장치(4)의 유기적 결합에 의한 상승효과(색 변환 제어 등) ④ 사후적 고찰(hindsight)에 근거한 진보성 부정의 위법성 ⑤ 결론

합계: 20점

특별 채점 기준

1) 논점 추출 (8점)

- (+) 제45조의 「하나의 총괄적 발명개념 = 특별한 기술적 특징(STF)의 공유」라는 실질적 요건을 정확히 제시
- (+) 실질적 동일성의 판단기준(주지·관용기술 부가·삭제·변경 + 새로운 효과의 부존재)을 구체적으로 서술
- (+) 결합발명 진보성 판단에서 「결합의 곤란성·동기·시사」와 「사후적 고찰 금지」를 쟁점으로 포착
- (-) 단일성을 제45조의 조문 나열에 그치고 STF 개념을 언급하지 않음
- (-) 실질적 동일성을 단순히 「전 구성요소 동일」로만 서술하고 판례 법리 누락
- (-) 진보성을 신규성 논리로 혼동하거나, 단순한 구성 대비만 나열

2) 목차·구성 (5점)

- (+) 설문 (1)(2)(3)의 배점(5:5:10)에 비례하여 분량과 논증 강도를 배분
- (+) 각 설문마다 「요건 제시 → 사안 포섭 → 소결」 구조로 정리
- (-) (3)에 지면을 배분하지 못하고 (1)(2)에 편중
- (-) 조문 전사·일반론 나열로 사안 포섭 지면이 부족

3) 답안 작성·논증 (7점)

- (+) 조문(제45조·제29조 제1항 제2호·제29조 제2항) → 판례·심사기준 법리 → 사안 포섭 순의 논증
- (+) 사안의 구체 구성요소(필기불, 투명잉크관, 색변환잉크관, 누름장치)를 인용발명과 대응시켜 대비
- (+) 진보성에서 목적·구성·효과 3요소 및 결합의 시사·동기 존부, 상승효과를 사안에 적용
- (-) 「투명잉크관」과 「잉크관」의 차이를 새로운 효과와 연결하지 못한 채 형식적 표현 차이로만 서술
- (-) 결합발명임에도 인용발명 2·3을 개별적으로만 부정하고 「결합의 곤란성」 논거를 놓침
- (-) 결론이 애매하거나 본문 논증과 모순

감점 주의

- 단일성 요건에서 시행령상 「특별한 기술적 특징(STF)의 공유」를 언급하지 않고 단순히 「기술적으로 관련되면 된다」는 식으로 서술
- 신규성의 실질적 동일성 논의에서 「새로운 효과의 유무」 기준을 놓치고, 단순 표현 차이라고 결론짓는 오류
- 결합발명 진보성에서 인용발명 2와 3의 기술분야(볼펜/만년필) 차이, 결합 시사·동기의 부재, 상승효과를 논하지 않고 단순히 「구성이 다르다」로만 서술
- 사후적 고찰 금지 원칙을 언급하지 않아 진보성 논거 부실
- 각 설문 결론(甲의 주장 인용 가부)을 명시하지 않는 것

2018년 제3문

사례형

30점

문제

甲은 실내 냉난방용 공조로봇을 개발하여 2017. 5. 1. 미국에 “공조부(A)와 이동부(B)를 포함하는 공조로봇”으로 특허출원(‘미국 원출원’이라 함)을 하고, 2017. 8. 1. “공조부(A)와 이동부(B)와 제어부(C)를 포함하는 공조로봇”으로 “일부계속출원”(원출원을 기초로 하여 새로운 구성 C를 추가한 출원)을 하였다.

이후 甲은 “미국 원출원”과 “일부계속출원”에 대해 모두 조약우선권주장을 하면서 2018. 2. 1. 한국에 특허출원을 하였으며, 그 청구범위는 다음과 같다.

[청구항 1] 공조부(A)와 이동부(B)를 포함하는 공조로봇.

[청구항 2] 공조부(A)와 이동부(B)와 제어부(C)를 포함하는 공조로봇.

[청구항 3] 공조부(A)와 이동부(B)와 제어부(C)와 생체인식부(D)를 포함하는 공조로봇.(생체인식부(D)는 한국출원에만 기재됨)

위 한국출원에 대하여 심사관은 의견제출통지서를 발송하였으며, 인용발명 및 거절이유는 다음과 같다.

[인용발명 1] 공조부(A)와 이동부(B)를 구비한 공조로봇(2017. 6. 1. 공개)

[인용발명 2] 청소로봇의 제어부(C)가 개시(2017. 9. 1. 공개)

[인용발명 3] 의학연구소 실험장비의 매뉴얼에 생체인식장치(D)가 개시 (2017. 10. 1. 발간)

[거절이유의 요지]

1. 청구항

제1항은 인용발명 1에 개시되어 있어 특허법 제29조 제1항 제2호의 규정에 의해 특허받을 수 없음.

2. 청구항

제2항은 동일한 공조부(A)와 이동부(B)가 인용발명 1에, 동일한 제어부(C)가 인용발명 2에 개시되어 있어 특허법 제29조 제1항 제2호의 규정에 의해 특허받을 수 없음.

3. 청구항

제3항은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2, 3의 결합에 의해 쉽게 발명 할 수 있으므로 특허법 제29조 제2항에 의해 특허받을 수 없음.

위 사실만을 기초로 하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 한국출원의 각 청구항에 대하여 특허요건 판단시점을 설명하고, 각 청구항에 대한 거절이유의 타당성에 관하여 논하시오. **(12점)**

(2) 위 지문에서 甲이 2018. 7. 1. 한국출원을 하면서 미국 원출원과 일부계속 출원에 대해 모두 조약우선권주장을 하였다고 가정하였을 경우에, 아래의 설문에 답하시오. (거절이유는 위 지문과 동일함) **(12점)**

1. 한국출원 청구항 1에 대한 특허요건 판단시점을 설명하고, 그 거절이유의 타당성에 관하여 논하시오. **(6점)**

2. 한국출원 청구항 2에 대한 특허요건 판단시점을 설명하고, 청구항 2의 신규성 및 진보성이 인정될 수 있는지에 관하여 논하시오. **(6점)**

(3) 재심사 청구와 거절결정불복심판의 차이점과 재심사 청구의 장점에 관하여 설명하시오. **(6점)**

모범답안

I. 문제의 소재

(1) 설문 (1)과 (2)에 공통되는 쟁점은 세 가지이다. 첫째 특허법 제54조 제1항의 우선기간, 즉 선출원일부터 1년 이내에 출원하였는지에 따른 조약우선권 주장의 적법 여부이고, 둘째 우선권주장이 적법한 경우 그 소급효가 어느 청구항에까지 미치는지에 따른 특허요건 판단시점의 결정이며, 셋째 그렇게 정해진 판단시점을 기준으로 각 인용발명이 출원 전에 공지된 것으로서 선행기술의 지위를 가지는지 여부이다. (2) 둘째 판단시점의 소급효와 관련하여, 특허법 제54조 제3항은 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 동일한 발명에 대하여는 특허요건을 적용할 때 그 선출원일에 출원한 것으로 본다 고 규정한다. 판례는 그 소급효가 「우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것」에 한하여 미

치고, 그 기재된 사항에는 명시적 기재뿐 아니라 통상의 기술자가 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이 포함된다고 한다(대법원 2012후2999). 따라서 판단시점은 출원 단위가 아니라 청구항별로 정하여진다. (3) 이하 각 설문에서 이 순서에 따라 검토한다.

II. 설문 (1) — 청구항별 판단시점과 거절이유의 타당성

1. 우선권주장의 적법 여부

특허법 제54조 제1항은 조약당사국에 최초로 출원한 자가 그 출원일부터 1년 이내에 우리나라에 특허출원을 하면서 우선권을 주장할 수 있다고 규정한다. 한국출원일 2018. 2. 1.은 미국 원출원일(2017. 5. 1.)부터 1년 이내이므로, 원출원과 일부계속출원을 기초로 한 두 우선권주장은 모두 적법하다.

2. 판단시점의 결정

(1) 청구항 1

공조부(A)와 이동부(B)는 미국 원출원의 최초 명세서에 기재되어 있으므로 그 출원일인 2017. 5. 1.이 판단시점이다.

(2) 청구항 2

제어부(C)는 미국 원출원에는 없고 일부계속출원에서 새로 추가된 사항이므로 원출원을 기초로 한 소급효가 미치지 아니한다. 일부계속출원의 최초 명세서에는 기재되어 있으므로 그 출원일인 2017. 8. 1.이 판단시점이다.

(3) 청구항 3

생체인식부(D)는 한국출원에만 기재되어 있어 어느 선출원 명세서에도 없으므로 소급효가 미치지 아니한다. 따라서 실제 출원일인 2018. 2. 1.이 판단시점이다.

3. 거절이유의 타당성 검토

(1) 청구항 1

인용발명 1은 2017. 6. 1. 공개된 것으로서 판단시점(2017. 5. 1.) 이후에 공개되었으므로 특허법 제29조 제1항 제2호의 선행기술이 될 수 없다. 거절이유는 부당하다.

(2) 청구항 2

인용발명 1은 판단시점(2017. 8. 1.) 전에 공개되었으나 공조부(A)와 이동부(B)만을 개시할 뿐 제어부(C)가 없고, 인용발명 2는 2017. 9. 1. 공개로서 판단시점 이후여서 선행기술이 될 수 없다. 신규성은 청구항에 기재된 발명과 하나의 인용발명을 대비하여 판단하므로, A와 B와 C 전부를 개시한 인용발명이 없는 이상 신규성이 부정되지 아니한다. 거절이유는 부당하다.

(3) 청구항 3

① **(선행기술 적격)** 인용발명 1(2017. 6. 1.)·2(2017. 9. 1.)·3(2017. 10. 1.)은 모두 판단시점(2018. 2. 1.) 이전에 공개·발간된 것이므로 진보성 판단의 선행기술이 될 수 있다. 이 점에서 거절이유의 전제는 인정된다.

② **(결합의 용이성)** 그러나 진보성 부정은 각 구성요소가 여러 선행기술에 나뉘어 개시되어 있다는 것만으로는 부족하고, 그 결합에 이를 수 있다는 교시·암시·동기가 제시되어 있거나 출원 당시의 기술수준·기본적 과제·발전경향 등에 비추어 통상의 기술자가 쉽게 결합에 이를 수 있다고 인정되어야 하며, 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 사후적 고찰 없이 살펴야 한다. 특히 인용발명 3은 의학연구소 실험장비의 매뉴얼로서 기술분야를 달리하므로, 그 구성이 특정 산업분야에만 적용되는 것이 아니고(범용성) 통상의 기술자가 별다른 어려움 없이 채택할 수 있어야 한다(대법원 2006후2059).

③ **(결론)** 발문의 사실만으로는 생체인식장치(D')가 생체인식부(D)와 같은 것인지, 이를 공조로봇에 결합할 동기가 있는지를 알 수 없다. 세 인용발명이 선행기술이 될 수 있다는 점은 인정되나 결합의 용이성이 증명되지 아니하는 한 진보성이 부정된다고 단정할 수 없으므로, 거절이유가 타당하다고 볼 수 없다.

4. 결론

청구항 1은 판단시점이 2017. 5. 1.이어서 인용발명 1이 선행기술이 될 수 없고, 청구항 2는 판단시점이 2017. 8. 1.이어서 A와 B와 C 전부를 개시한 선행기술이 없으므로 각 거절이유는 부당하다. 청구항 3은 판단시점이 2018. 2. 1.이어서 세 인용발명이 모두 선행기술이 될 수 있으나, 그 결합의 용이성을 인정할 자료가 없으므로 거절이유가 타당하다고 단정할 수 없다.

III. 설문 (2) — 2018. 7. 1. 출원한 경우

1. 우선권주장의 적법 여부

특허법 제54조 제1항은 선출원일부터 1년 이내에 우선권을 주장할 것을 요구한다. 미국 원출원(2017. 5. 1.) 기준 1년은 2018. 5. 1.에 도과하였으므로 원출원을 기초로 한 우선권주장은 부적법하나, 일부계속출원(2017. 8. 1.) 기준 1년은 2018. 8. 1.까지이므로 일부계속출원을 기초로 한 우선권주장은 유효하다.

2. 설문 (2)-1) 청구항 1의 판단시점 및 거절이유의 타당성

(1) 판단시점의 결정

일부계속출원은 원출원의 공조부(A)와 이동부(B)에 제어부(C)를 부가한 것이므로 그 최초 명세서에는 A와 B가 그대로 기재되어 있다. 청구항 1의 발명은 그 기재사항의 범위 안에 있으므로 일부계속출원을 기초로 한 우선권의 효과가 미쳐 판단시점은 2017. 8. 1.이다.

(2) 거절이유의 타당성 검토

인용발명 1은 2017. 6. 1. 공개로서 판단시점 이전에 공개되었고 공조부(A)와 이동부(B)를 그대로 개시하고 있으므로, 청구항 1은 특허법 제29조 제1항 제2호에 의하여 신규성이 부정된다. 거절이유는 타당하다.

3. 설문 (2)-2) 청구항 2의 판단시점 및 거절이유의 타당성

(1) 판단시점의 결정

청구항 2는 일부계속출원의 최초 명세서에 기재된 발명과 동일하므로 일부계속출원을 기초로 한 우선권의 효과가 미쳐 판단시점은 2017. 8. 1.이다.

(2) 거절이유의 타당성 검토

① **(신규성)** 인용발명 1에는 제어부(C)가 개시되어 있지 아니하고, 인용발명 2는 판단시점 이후인 2017. 9. 1. 공개되어 선행기술이 될 수 없다. A와 B와 C 전부를 개시한 인용발명이 없으므로 신규성이 인정된다.

② **(진보성)** 결합의 대상이 될 수 있는 유효한 선행기술은 인용발명 1뿐인데, 인용발명 1에는 제어부(C)에 관한 개시나 시사가 없다. 인용발명 2는 판단시점 이후에 공개된 것이어서 결합의 근거로 삼을 수 없다. 따라서 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 청구항 2의 발명을 쉽게 발명할 수 있다고 볼 수 없어 진보성도 인정된다.

4. 결론

원출원을 기초로 한 우선권주장은 기간 도과로 부적법하나 일부계속출원을 기초로 한 우선권주장은 유효하므로 청구항 1·2의 판단시점은 모두 2017. 8. 1.이다. 청구항 1은 그 이전에 공개된 인용발명 1에 의하여 신규성이 부정되어 거절이유가 타당하나, 청구항 2는 신규성과 진보성이 모두 인정되므로 거절이유는 부당하다.

IV. 설문 (3) — 재심사 청구와 거절결정불복심판의 차이점 및 재심사 청구의 장점

1. 두 제도의 의의

재심사 청구는 출원인이 명세서 또는 도면을 보정하여 심사관에게 다시 심사받는 제도이고(§ 67의2), 거절결정불복심판은 거절결정을 받은 자가 그 취소를 구하는 심판이다(§ 132의17). 이하 요건·절차·효과·불복의 순으로 비교한다.

2. 차이점

(1) 요건 — 주체·객체·시기

주체는 모두 출원인이나 심판청구는 대리인이 밟은 경우 특별수권이 필요하다. 객체는 재심사가 특허결정까지 포함하는 반면 심판은 특허거절결정과 연장등록거절결정에 한정된다. 시기는 재심사가 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 또는 특허결정등본을 송달받은 날부터 설정등록 전까지인 데 비하여, 심판은 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월이다. 다만 이미 재심사에 따른 특허여부결정이 있거나 심판이 청구된 경우 또는 분리출원인 경우에는 재심사를 청구할 수 없다(§ 67의2①단서).

(2) 절차 — 보정의 요부와 판단주체

재심사는 보정을 반드시 동반하여야 하고 원 심사관이 판단하는 심사절차의 연장이어서 그 청구를 취할 수 없다(§ 67의2④). 반면 심판은 보정 없이도 청구할 수 있고, 심판관 합의체가 심리하는 준사법절차로서 별도의 심판청구료가 든다.

(3) 효과

재심사가 청구되면 종전의 특허여부결정은 취소된 것으로 보고(§ 67의2③본문) 심사관이 다시 심사하여 특허여부결정을 새로 한다. 반면 심판에서는 청구가 이유 있으면 심결로써 거절결정을 취소하고(§ 176①), 심사에 부결 것이라는 심결로 환송하거나(§ 176②) 환송하지 아니하고 스스로 특허결정을 할 수 있으며, 취소의 기본이 된 이유는 심사관을 기속한다(§ 176③).

(4) 불복

재심사 후 다시 거절결정되면 그 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 심판을 청구할 수 있으나, 이미 재심사에 따른 특허여부결정이 있으므로 재심사를 다시 청구할 수는 없다. 심판의 기각심결에 대하여는 특허법원에 심결취소소송을 제기하거나(§ 186) 분리출원을 할 수 있다.

3. 재심사 청구의 장점

재심사 청구는 심판청구료를 내지 아니하고 보정만으로 거절이유를 해소할 수 있어 절차가 간이·신속하고, 거절이유를 통지한 원 심사관이 보정된 명세서를 직접 심사하므로 보정으로 해소할 수 있는 사안에서는 등록 가능성이 높다. 또한 재심사에서 다시 거절결정을 받더라도 그때 심판을 청구할 수 있어 다

틀 기회가 한 단계 더 보장된다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	득점 포인트
(1) 조약우선권 인정 요건과 청구항별 판단시점(제54조) 및 각 청구항 거절이유 타당성	12점	① 우선권주장 효력이 미치는 발명의 범위는 선출원 최초 명세서 기재사항으로 한정된다는 법리, ② 청구항 1은 미국 원출원(2017.5.1), 청구항 2는 미국 일부계속출원(2017.8.1), 청구항 3은 한국출원일(2018.2.1)로 판단시점을 각각 특정, ③ 인용발명의 공개일과 각 판단시점 비교, ④ 청구항 1:2는 부당, 청구항 3은 타당(진보성 부정) 결론
(2)-1 우선권 기간(1년) 도과 시 청구항 1의 판단시점 및 거절이유 타당성	6점	① 미국 원출원 기초 우선권주장은 1년 도과로 인정 안 됨, ② 그러나 일부계속출원(2017.8.1)의 명세서에도 A+B가 기재되어 있으므로 이를 기초로 한 우선권주장은 유효 → 판단시점 2017.8.1, ③ 인용발명 1(2017.6.1)은 그 이전 공개이므로 신규성 부정, ④ 거절이유 타당
(2)-2 청구항 2의 판단시점과 신규성·진보성 인정 여부	6점	① 일부계속출원 기초 우선권주장 유효 → 판단시점 2017.8.1, ② 인용발명 2(2017.9.1)는 판단시점 이후 공개로 선행기술 될 수 없음, ③ 인용발명 1만으로는 C를 개시하지 못해 신규성 인정, ④ 결합할 수 있는 유효 선행기술이 없으므로 진보성도 인정, ⑤ 거절이유 부당
(3) 재심사청구와 거절결정불복심판의 차이 및 재심사 장점	6점	① 적용 법규정(제67조의2, 제132조의17), ② 청구주체·판단주체·보정요부·기간·성격 차이, ③ 재심사 장점(간이·신속, 비용 저렴, 심사관과의 소통, 재차 심판청구 가능)

축별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- **득점:** 각 청구항마다 판단시점이 달라진다는 점(조약우선권 효과의 범위가 선출원 최초 명세서 기재사항으로 한정)을 정확히 포착하고, 인용발명 공개일과 판단시점을 대비하여 결론을 도출.
- **득점:** (2)에서 미국 원출원 기초 우선권은 1년 도과로 무효이나, 일부계속출원 기초 우선권은 유효라는 이중구조를 파악.
- **감점:** 청구항 1:2:3의 판단시점을 획일적으로 2018.2.1로 처리, 우선권 효과 범위(제54조)와 확대된 선출원(제29조 제3항)을 혼동, 인용발명 공개일 계산 착오.

2) 목차·구성(25%)

- **득점:** 설문 (1)(2)(3)의 배점 비례에 따라 분량 배분, 청구항별 소제목·표 형식으로 판단시점과 인용발명 대비 결과를 명확히 정리.
- **감점:** 조약우선권 일반론(제54조 요건)만 장황히 서술하고 사안 포섭이 빈약, 재심사·심판 차이를 단순 나열만.

3) 답안 작성·논증(35%)

- **득점:** 조문(제54조 제3항, 제29조 제1·2항, 제67조의2, 제132조의17) → 판례(대법원 2012후2999의 “선출원 최초 명세서 등에 기재된 사항” 법리) → 사안 포섭 → 소결의 순서로 서술.
- **득점:** 각 청구항에 대해 “판단시점 ○○ → 인용발명 ○○은 선행기술 여부 → 신규성/진보성 판단 → 거절이유 타당/부당” 논리 일관.
- **감점:** 결론이 애매하거나 본문과 모순, 대법원 2012후2999 등 법리 인용 없이 결론만 제시, 재심사 청구요건(보정 동반 필요) 누락.

감점 주의

- 조약우선권(제54조)과 국내우선권(제55조)을 혼동해 서술.
- 청구항 1의 판단시점을 무조건 우선일로 소급시키되, 청구항 2의 C가 원출원에 없음을 간과하고 청구항 2도 원출원일(2017.5.1)로 소급 판단.
- 인용발명 2:3의 공개일이 판단시점 이후임에도 진보성 부정근거로 사용.
- (2)에서 우선권 기간 도과 시 자동으로 실제 출원일이 판단시점이 된다고 단정(일부계속출원 기초 우선권이 여전히 유효한 점 누락).
- 청구항 3에 대해 D가 어떤 선출원에도 기재되지 않아 우선권 효과가 미치지 않는다는 점(제54조 제3항 취지, 대법원 2012후2999)의 서술 누락.
- 재심사청구에서 “명세서·도면의 보정과 함께” 청구해야 한다는 요건 누락.

2018년 제4문

사례형

20점

문제

甲은 기술혁신형 중소기업의 대표자로서 도로오염 및 가로수 고사를 방지할 수 있는 친환경 제설제를 개발하여, 2017. 12. 1. 지식재산처에 甲의 명의로 특허출원(‘원출원’이라 함)을 하였다. 그 청구범위는 다음과 같다.

[청구항 1] 성분 A와 성분 B와 성분 C로 이루어지는 제설제.

[청구항 2] 청구항 1에 있어서, 상기 성분 A는 전체 조성물을 기준으로 40~60중량 %, 상기 성분 B는 30~50중량 %, 상기 성분 C는 20~30중량 %인 제설제.

[청구항 3] 청구항 1 및 청구항 2에 있어서, 상기 성분 D는 0.1 중량 % 이상 함유되는 제설제.

[청구항 4] 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서, (a) 상기 성분 A와 상기 성분 B와 상기 성분 C와 상기 성분 D를 특수한 혼합수단으로 혼합 하는 단계(S1)와, (b) 상기 S1 단계 이후에 약 50℃로 예열하여 성형하는 단계(S2)를 포함하는 제설제의 제조방법.

[청구항 5] 청구항 4에 있어서, 상기 특수한 혼합수단은 로터리식 교반기인 제설제의 제조장치.

(1) 심사관이 특허법 제42조에 의해 거절이유를 통지할 수 있는 청구항 및 그 근거를 설명하시오. (12점)

(2) 甲은 원출원에 제설제만 남기고, 각 성분의 함량을 표시하여 “제설제의 제조방법”으로 분할출원을 하려고 한다. 원출원 청구범위를 어떻게 보정해야 하는지를 설명하고, 분할출원의 청구범위를 작성하시오. (단, 기재불비 사항은 고려하지 않고 위 청구범위만으로 작성함) (4점)

(3) 甲은 원출원의 실시를 준비하던 중에 우선심사를 신청하려고 한다. 원출원이 우선심사의 대상이 될 수 있는 요건에 관하여 설명하시오. (4점)

모범답안

I. 설문 (1) — 제42조 위반의 거절이유가 통지될 청구항과 그 근거

1. 검토의 범위

특허법 제62조는 거절결정 사유를 제한적으로 열거하는데, 그중 제42조 관련은 1) 발명의 설명의 기재불비(제42조 제3항 제1호)와 배경기술의 기재 위반(같은 항 제2호), 2) 발명의 설명에 의한 뒷받침(제42조 제4항 제1호)과 명확성(같은 항 제2호), 3) 청구범위의 기재방법 위반(제42조 제8항)이다. 이 중 제42조 제3항 제2호와 제8항 위반은 형식적 요건이어서 거절이유에만 해당한다.

사안에는 청구범위만 제시되어 있어 발명의 설명의 기재불비와 뒷받침 여부(§ 42③(1)·(2), § 42④(1))는 판단할 자료가 없으므로 논외로 하고, **청구범위의 기재만으로 판단할 수 있는 제42조 제4항 제2호와 제42조 제8항 위반**을 청구항별로 검토한다.

2. 관련 법규정 및 판례

(1) 명확성 요건

청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀야 하고(§ 42④(2)) 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항으로 정하여지므로(§ 97), 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니한다. 발명이 명확하게 적혀 있는지는 통상의 기술자가 발명의 설명·도면의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위의 기재로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 사용된 용어만을 기준으로 일률적으로 판단할 것은 아니다(2014후1563). 따라서 청구된 발명의 카테고리나 그 구성이 청구항의 기재 자체로 특정되어야 한다.

(2) 청구범위 기재방법

제42조 제8항은 기재방법을 대통령령에 위임하고, 시행령 제5조는 2 이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 **택일적으로** 기재할 것(제5항), 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 인용된 항은 다시 2 이상의 항을 인용하지 아니할 것(제6항)을 규정한다. 한편 카테고리가 다른 청구항의 인용 형식(‘청구항 ○의 방법으로 제조된 물건’ 등)은 인용형식 독립항으로서 허용된다.

3. 청구항별 검토

(1) 청구항 1·2

청구항 1과 이를 인용하여 함량을 한정한 청구항 2는 불명확한 점이 없고 인용형식도 적법하므로 거절이유가 없다.

(2) 청구항 3

① **(제42조 제8항 위반)** '청구항 1 및 청구항 2에 있어서'는 두 항을 모두 인용하는 표현으로서 택일적 기재가 아니므로 시행령 제5조 제5항에 반한다.

② **(제42조 제4항 제2호 위반)** 청구항 3은 '상기 성분 D'라고 하였으나 인용항 어디에도 성분 D가 없고 인용형식마저 택일적이지 아니하여, '상기'의 오기인지 인용 항번호의 오기인지 가릴 수 없으므로 발명이 명확하다고 할 수 없다. 또한 성분 D의 상한이 없어 청구항 2를 인용하면 100중량%를 초과하는 조성까지 포함되어 조성비도 불명확하다.

(3) 청구항 4

① **(제42조 제8항 위반)** '청구항 2 또는 청구항 3'으로 2 이상의 항을 인용하는데 인용된 청구항 3이 다시 2 이상의 항을 인용하므로 시행령 제5조 제6항에 반한다.

② **(제42조 제4항 제2호 위반)** 물건을 인용하면서 제조방법을 청구하는 것 자체는 인용형식 독립항으로서 허용되나, 청구항 4는 물건인 청구항 2·3을 '...에 있어서'라는 한정·부가의 종속항 형식으로 인용하면서 말미는 '제설제의 제조방법'이어서, 청구된 발명이 물건발명인지 방법발명인지 특정되지 아니하여 카테고리가 불명확하다. 또한 '특수한 혼합수단'은 구성을 특정할 수 없는 추상적·기능적 표현이고, '약 50℃'는 경계가 불명확하여 이 점에서 명확하지 아니하다.

(4) 청구항 5

제42조 제4항 제2호 위반 청구항 5도 방법인 청구항 4를 종속항 형식으로 인용하면서 말미는 '제조장치'이어서 방법발명인지 물건발명인지 특정되지 아니하므로, 같은 이유로 카테고리가 불명확하다. 다만 청구항 4 하나만 인용하므로 시행령 제5조 제6항의 적용대상이 아니어서(특허법원 2001허1433) 제42조 제8항 위반은 아니다.

4. 결론

청구항 3·4는 제42조 제8항(각 시행령 제5조 제5항·제6항)과 제42조 제4항 제2호, 청구항 5는 제42조 제4항 제2호의 거절이유가 통지될 수 있고, 청구항 1·2에는 거절이유가 없다.

II. 설문 (2) — 원출원의 보정과 분할출원의 청구범위**1. 원출원 청구범위의 보정**

원출원에는 제설제만 남겨야 하므로 방법인 청구항 4와 장치인 청구항 5를 삭제한다. 청구항의 삭제는 청구범위의 감축(§ 47③(1))이고 신규사항도 아니어서 허용된다.

[보정 후 원출원 청구범위] 청구항 1·2는 원문대로 유지하고, 청구항 3은 인용형식이 택일적이 되도록 「청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, 성분 D를 0.1중량% 이상 함유하는 제설제」로 고치며('상기' 삭제), 청구항 4·5는 삭제한다.

2. 분할출원의 청구범위

분할출원은 원출원에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 하므로(§ 52①) 청구항 4·5를 기초로 하되, 청구항 4는 독립항 형식으로 각 성분의 함량을 표시하고 청구항 5의 한정에는 방법의 종속항으로 옮긴다. 기재불비는 고려하지 아니하므로 '특수한 혼합수단'과 '약 50℃'는 원문대로 둔다.

[분할출원 청구범위] 청구항 1은 「(a) 성분 A 40~60중량%, 성분 B 30~50중량%, 성분 C 20~30중량% 및 성분 D 0.1중량% 이상을 특수한 혼합수단으로 혼합하는 단계(S1)와, (b) 상기 S1 단계 이후에 약 50℃로 예열하여 성형하는 단계(S2)를 포함하는 제설제의 제조방법」, 청구항 2는 「청구항 1에 있어서, 상기 특수한 혼합수단은 로터리식 교반기인 제설제의 제조방법」으로 한다. 이로써 원출원에는 제설제만, 분할출원에는 그 제조방법만 남는다.

III. 설문 (3) — 우선심사의 대상이 되기 위한 요건**1. 요건**

우선심사란 일정 사유의 출원을 심사청구 순위와 관계없이 우선 심사하는 것이다(§ 61).

(1) 우선심사사유

제61조는 출원공개 후 출원인이 아닌 자가 업으로서 출원발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우(제1호), 대통령령으로 정하는 출원으로서 긴급처리가 필요한 경우(제2호)와 재난의 예방·대응 등에 필요한 경우(제3호)를 규정한다.

(2) 신청의 대상과 시기

신청한 발명은 청구항에 적혀 있어야 하고, 여러 청구항 중 하나가 대상이면 출원 전체가 대상이 되며, 판단은 우선심사결정 시까지 보정된 청구항을 기준으로 한다. 신청에는 **심사청구가 전제**되나(§ 59①) 동시에 할 수 있다.

(3) 신청절차

우선심사신청서에 신청설명서·증빙서류와 **직접 조사한 선행기술의 결과**(검색방법, 근접 문헌 4건 이상, 대비설명)를 제출하여야 한다.

2. 사안의 포섭

甲은 스스로 실시를 준비하므로 제3자의 실시를 요건으로 하는 제1호에는 해당하지 아니하나, 시행령 제9조 제1항이 '출원인이 업으로서 실시 중이거나 실시준비 중인 특허출원'을 대상으로 하므로 제2호의 대상이 된다. 기술혁신형 중소기업의 출원도 대상이나 **출원발명이 그 기업의 업종과 관련성이 있는 경우로 한정**되므로 이를 소명하여야 하고, 친환경 제설제는 녹색기술(자원순환 및 친환경 기술 포함)에 해당할 여지도 있다.

3. 결론

따라서 甲은 심사청구 후 신청서와 선행기술조사 결과를 제출하여 우선심사를 신청할 수 있다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	득점 포인트
(1) 검토범위의 한정과 청구항 1-2	3점	제62조가 거절이유를 제한열거함을 전제로 제42조 관련 조문군을 제시하고, 발명의 설명에 관한 자료가 없어 제42조 제3항 제1호·제2호와 제4항 제1호는 판단할 수 없음을 명시적으로 논외로 선언한 뒤, 청구범위 기재만으로 판단 가능한 제42조 제4항 제2호·제8항으로 검토범위를 좁힌 점(청구항 1-2는 거절이유 없음)
(1) 청구항 3: '청구항 1 및 청구항 2(중복·비태일적 인용) — 명확성 위반	3점	다항 인용시 태일적으로 기재하여야 하는데 '및'으로 기재 → 제42조 제4항 제2호 및 시행령 제5조 제5항 위반. 또한 성분 D의 상한 부재로 명확성 문제도 지적 가능
(1) 청구항 4: 카테고리 불명확 및 기능적/추상적 표현('특수한 혼합수단','약 50°C) — 명확성 위반	3점	물건인 청구항 2-3을 '...에 있어서'라는 종속항 형식으로 인용하면서 말미는 '제조방법'이어서 물건발명인지 방법발명인지 특정되지 않는 점(카테고리 다른 청구항의 인용 자체는 인용형식 독립항으로 적법), '특수한 혼합수단','약 50°C와 같은 불명확 표현 → 제42조 제4항 제2호 위반
(1) 청구항 5: 인용항(방법)과 카테고리 (장치) 불일치 — 명확성 위반	3점	청구항 4(제조방법)를 인용하면서 말미를 '제조장치'로 기재 → 카테고리 불일치로 제42조 제4항 제2호 위반
(2) 원출원 보정 및 분할출원 청구범위 작성	4점	원출원은 제설체(물건)만 남기도록 청구항 4-5 삭제 및 청구항 3의 인용관계 정비, 분할출원은 제조방법(청구항 4의 내용)을 함량과 함께 재구성하여 작성
(3) 우선심사의 대상 요건	4점	제61조 및 시행령상 대상요건을 정확히 구분(제1호는 '출원공개 후 제3자의 업으로서의 실시', 출원인 자신의 실시·실시준비는 제2호+시행령 제9조 제1항 제8호), 중소기업·녹색기술 해당성 검토

합계: 20점

축별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- (+) 청구항별로 각각 다른 기재불비 사유를 구별하여 지정한 답안
- (+) 청구항 3의 '및' 표현(비태일적 다항인용, 시행령 제5조 제5항), 청구항 4의 카테고리 불명확·'특수한 혼합수단'·'약 50°C'의 불명확성, 청구항 5의 인용항·말미 카테고리 불일치를 각각 정확히 포착
- (+) (2)에서 원출원 보정과 분할출원 청구범위 작성 두 가지를 모두 수행
- (+) (3)에서 우선심사 대상요건을 조문 구조에 맞게 구별하여 제시(출원인 자신의 실시준비는 제61조 제2호+시행령 제9조 제1항 제8호, 중소기업 관련은 시행령 제9조 제1항 제5호·제5호의2 등)
- (-) 청구항별 개별 검토 없이 '기재불비'만 나열, 특허법 제29조·제36조 등 무관 조문 논의
- (-) 출원인 자신의 실시준비를 제61조 제1호(제3자 업으로서 실시)로 잘못 포섭

2) 목차·구성(25%)

- (+) 설문 (1)(2)(3)을 별도 목차로 나누고, (1)은 청구항별로 소목차 구성
- (+) 각 청구항 검토시 [기재 → 문제점 → 적용 법규정 → 결론] 순으로 정형화
- (+) (2)에서 보정 후 원출원 청구범위와 분할출원 청구범위를 형식을 갖추어 별도 표기
- (-) 서론에 명세서 일반론을 장황하게 전개, 배점 4점짜리 (2)(3)에 지나치게 많은 지면 소요

3) 답안 작성·논증(35%)

- (+) 제42조 제4항 제1호·제2호, 제3항 제1호를 사안별로 정확히 적용
- (+) 명확성 판단기준 판례(대법원 2014후1563 — 통상의 기술자가 발명의 설명·도면과 기술상식을 고려하여 청구범위 기재로부터 발명을 명확히 파악할 수 있는지로 개별 판단) 인용
- (+) 분할출원 청구범위 작성시 각 성분의 함량을 명시하고 방법발명으로 정확히 기재
- (+) 우선심사 대상요건에서 제61조 제1호(제3자의 업으로서의 실시)와 제2호(대통령령 대상출원)를 정확히 구별하고 사안을 제2호+시행령 제9조 제1항 제8호에 포섭
- (+) '녹색기술' 해당성 판단시 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」상 정의 충족 여부까지 검토
- (-) 조문만 나열하고 사안 포섭 없음, 청구항 3에서 '및'이 '또는'의 취지임을 인식하지 못한 답안
- (-) 사안 유형에 맞지 않는 판례(예: 의약 용도발명의 약리기전 관련 판례)를 명확성 논거로 인용

감점 주의

- 청구항 3의 '및' 표현을 단순 오기오만으로 취급하고 명확성 위반으로 다루지 않는 경우
- 청구항 5의 '제조장치' 말미와 인용항인 청구항 4의 '제조방법' 사이 카테고리 불일치를 놓치는 경우

- (2)에서 원출원의 청구항 4·5만 삭제하면 된다고 답하고 청구항 3의 인용관계 정비('청구항 1 및 청구항 2'→'청구항 1 또는 청구항 2')를 누락하는 경우
- 분할출원 청구범위에 함량을 표시하라는 문제 조건을 지키지 않은 경우
- 우선심사에서 출원인 자신의 실시준비를 제61조 제1호(제3자 실시)로 잘못 분류한 경우
- 단순히 '친환경'이라는 이유만으로 녹색기술 해당성을 단정하고 관련 법률상 정의 검토를 누락한 경우
- 우선심사에서 '중소기업'이라는 사안 사실을 활용하지 못하고 일반론만 기술한 경우

PART 10

2019

제1문	무효사유·자유실시기술 주장을 소극적 권리범위확인심판에서 판단하는 것의 타당성 · 모방 실시자 乙에 대한 선사용권(\$103)·중용권 (\$104) 법리의 유추적용 비교	30점
제2문	분할출원과 우선권 주장의 승계 여부 · 특허 무효 확정과 미지급 실시료 청구	20점
제3문	방법발명 특허권 소진의 이론적 근거·성립요건 · 국외 최초판매 후 국내 수입 — 국제소진(병행수입)	30점
제4문	무효심판 청구의 취지 표준 작성례(무효 대상 청구항 1의 특정 + 심판비용 부담 + '라는 심결을 구합니다') · 청구항 1의 구성요소 분 설(본체부·탐재부·잠금부·두 개의 바퀴·접이식 여행용 캐리어)	20점

2019년 제1문

사례형

30점

문제

甲은 시중에 판매되는 안마기의 내구성과 안마효과가 문제되는 것을 발견하고 그 문제점을 획기적으로 개선한 새로운 방식의 안마기(구성 A+B+C)를 발명하였다. 甲은 위 안마기에 대한 체험행사를 진행하였고, 그 체험행사를 녹화하여 세계적으로 유명한 인터넷 동영상 게시 사이트에 올려 홍보용으로 사용하였다. 뿐만 아니라 체험행사의 참가자들은 甲의 발명을 체험하는 모습을 녹화하고 사진으로 담아 인터넷 포털 사이트의 블로그에 올리기도 하였다.

甲의 발명은 체험행사에 참가한 사람들로부터 호평을 받았다. 안마기에서 나오는 소리가 때마침 영화로 인기를 끌게 된 영국의 유명 락그룹 퀸(Queen)의 노래 보헤미안 랍소디(Bohemian Rhapsody)에서 나오는 음절인 "마마(ma-ma)"와 같다고 하여 그의 발명은 "마마"로 불리며 많은 인기를 끌었다. 甲의 "마마"가 인기를 끌자, 乙은 이를 모방하여 안마기(구성 A+B+C)를 생산·판매하였다.

그 후 甲은 위 안마기가 출원 전 인터넷에 게시되었던 점을 밝히면서 이에 대해 공지예외를 주장하여 특허를 취득하였다. 甲이 특허를 취득하자 乙은 소극적 권리범위확인심판을 제기하였고, 위와 같이 인터넷에 게시된 甲의 발명이 선행발명으로 존재하였으므로 甲의 특허발명이 신규성과 진보성이 없어 무효일뿐더러, 乙이 실시하는 안마기 발명은 이른바 자유실시기술이므로 甲의 특허발명과 대비할 필요 없이 권리범위에 속하지 않는다고 주장하였다. (단, 각 물음은 독립적임)

(1) 위 사안에서 문제되는 쟁점을 소극적 권리범위확인심판에서 판단하는 것이 타당한지 설명하시오. (5점)

(2) 위 사안에서 乙의 실시행위에 선사용권 및 중용권의 법리가 유추적용될 수 있는지 여부를 비교분석하여 설명하시오. (10점)

(3) 위의 사실관계와 달리, 甲이 최초로 출원한 특허의 청구범위로 기재하지 않았지만 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재되어 있던 사항에 대하여 국내우선권을 주장·출원하여 특허 T를 등록받았고, 甲의 선출원일 후 우선권주장출원일 전에 乙이 독자적으로 개발하여 실시하는 발명이 특허 T의 권리범위 내인 경우, 乙의 법적지위를 설명하시오. (5점)

(4) 위의 사실관계와 달리, 甲이 안마기 발명(구성 A+B+C)에 특허를 취득한 후 乙은 자신의 발명 Z(구성 A+B+C)를 완성하였으나, 甲의 특허침해가 염려되어 위 발명 Z는 실시하지 않기로 하였다. 다만 사업을 포기할 수 없어 장차 기술적으로 점차 보완·변경하여 개발하기로 한 발명Y(구성 A+B+C+D)에 대해 사업화 전략을 구상하였다. 乙은 특허침해에 대한 문제 예방을 위해 甲을 상대로 i) 심판 1: 실시하지 않기로 한 발명 Z와 ii) 심판 2: 미래에 완성하여 실시하려는 발명 Y에 대해 소극적 권리범위확인심판을 각각 청구하였다. 이 때 乙이 청구한 각 심판에서 문제되는 쟁점을 설명하시오. (10점)

모범답안

문제 1 모범답안

I. 설문 (1) — 사안의 쟁점을 소극적 권리범위확인심판에서 판단하는 것이 타당성 (5점)

1. 무효 주장(신규성·진보성)의 경우

특허는 행정처분에 의하여 발생한 권리이므로 무효심결 확정 전에는 다른 절차에서 무효라고 판단할 수 없음이 원칙이다. 판례는 권리범위확인심판이 객관적 범위외의 속부를 확인하는 절차라는 전제에서 1) 진보성까지 판단함은 제도의 목적과 본질에 맞지 아니하고, 2) 무효심판의 기능을 약화시키며, 3) 무효는 무효심판으로만 다투도록 한 기본 구조와 상충된다는 이유로 진보성 부정을 이유로 권리범위를 부정할 수 없다고 한다(대법원 2012후4162 전합). 따라서 진보성 쟁점은 무효심판으로 다투어야 한다. 다만 출원 당시 공지공용인 경우까지 권리범위를 인정할 수는 없으므로 신규성 결여가 명백하면 무효심결 확정 전이라도 권리범위를 부정할 수 있어(대법원 81후56 전합) 신규성 쟁점은 이 심판에서 판단할 수 있다.

2. 자유실시기술 주장의 경우

자유실시기술의 항변은 특허발명과 대비할 필요 없이 확인대상발명이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 공공영역에 속함을 이유로 권리범위에 속하지 아니함을 구하는 것으로, 특허의 효력을 부정하는 것이 아니라 권리범위가 공공영역까지 확장되는 것을 제한하는 것이어서 권리범위확인심판의 본질에 부합한다. 따라서 이 쟁점은 이 심판에서 판단할 수 있다(대법원 2016후366).

3. 결론

진보성 결여의 무효 쟁점을 소극적 권리범위확인심판에서 판단하는 것은 타당하지 않고 특허무효심판으로 다투어야 하며, 신규성 결여가 명백한지 여부와 자유실시기술 해당 여부의 쟁점은 이 심판에서 판단하는 것이 타당하다.

II. 설문 (2) — 乙의 실시행위에 대한 선사용권·중용권 법리의 유추적용 비교분석 (10점)

1. 공지에외적용주장과 자유기술의 법리

공지에외(§ 30)의 적용을 받은 공지는 신규성·진보성 적용 시 공지 등이 되지 아니한 것으로 보아 선행기술에서 제외된다. 판례는 1) 자유기술의 항변을 인정하면 공지에외로 등록된 특허가 권리행사를 할 수 없게 되어 제도가 형해화되고, 2) 요건을 갖춘 공지에외주장에 의하여 그 공지는 입법적 결단으로 더 이상 공공영역이 아니며, 3) 창작적 기여가 없는 제3자에게 선사용권(§ 103)을 넘는 무상 실시 권한을 주는 것은 온당치 아니하다는 이유로, 그 공지를 근거로 한 자유기술의 항변은 허용되지 아니한다고 한다(대법원 2022후10012). 따라서 乙은 자유실시기술 주장으로는 보호받을 수 없고 선사용권·중용권 법리의 유추적용 여부가 문제 된다.

2. 선사용권 법리의 유추적용

(1) 법규정 및 취지

특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는, 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 무상의 통상실시권을 가진다(§ 103). 이는 출원된 발명을 알지 못한 채 병행하여 발명을 완성·실시한 자와 특허권자 사이의 공평을 도모하고, 그 실시로 갖추어진 산업설비를 보호하려는 법정실시권이다.

(2) 사안의 포섭

乙의 실시는 甲의 출원 전에 개시되어 시가적 측면은 갖추었으나, 乙은 甲의 인터넷 게시를 보고 발명을 지득하여 모방한 자이므로 발명의 내용을 '알지 못하고 발명한 자'가 아니고, 별개 계통의 발명자로부터 정당하게 지득한 자도 아니어서 제103조를 직접 적용할 수 없다. 유추적용 여부를 1.의 법리와 비교하면, 판례가 '선사용권을 넘어서는 무상의 실시 권한 부여는 온당치 않다'고 한 것은 자유기술 항변을 부정하는 논거일 뿐 모방자에게 선사용권을 인정하는 취지가 아니며, 공지에외적용주장에 의하여 해당 공지가 더 이상 공공영역이 아니게 된 이상 그 공지를 신뢰한 모방 실시에는 제103조가 보호하려는 병행 발명의 공평의 기초 자체가 없다. 따라서 유추적용은 부정된다.

3. 중용권 법리의 유추적용

(1) 법규정 및 취지

무효심판청구의 등록 전에 자기의 특허발명이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 실시사업을 하거나 준비하고 있는 원특허권자 등 법정 열거된 자는, 그 발명 및 사업목적의 범위에서 통상실시권을 가지되 특허권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(§ 104①②). 이는 등록이라는 지식재산처의 행정처분을 선의로 신뢰한 자와 그 실시로 갖추어진 산업설비를 보호하려는 유상의 법정실시권이다.

(2) 사안의 포섭

乙의 기대는 '공지된 기술은 자유로이 실시할 수 있다'는 것인데, 이는 1.의 법리상 공지에외적용주장에 의하여 이미 보호가치를 상실한 기대이고, 등록이라는 공적 외관에 대한 신뢰와는 성질이 다르다. 乙은 자기의 등록을 보유한 바 없어 제104조가 법정 열거한 주체의 어디에도 해당하지 아니한다. 유상의 실시권이라는 점에서 무상인 선사용권보다 특허권자와의 이익조정에 근접한다는 논의는 가능하나, 신뢰의 기초가 없는 모방 실시자에게 명문의 근거 없이 법정실시권을 창설하는 유추적용은 부정된다.

4. 결론

선사용권은 병행 발명자의 공평을, 중용권은 등록에 대한 선의의 신뢰를 각 보호하는 제도인데, 乙은 창작적 기여 없이 甲의 공개를 모방한 자로서 어느 보호의 기초도 갖추지 못하였고, 그 신뢰의 대상인 공지는 공지에외적용주장에 의하여 공공영역에서 제외되었다. 따라서 선사용권·중용권의 법리는 모두 乙의 실시행위에 유추적용될 수 없고, 乙은 甲의 특허권에 대한 침해 책임을 면할 수 없다.

III. 설문 (3) — 국내우선권주장출원과 중간에 독자 실시를 개시한 乙의 법적 지위

1. 문제의 소재

甲의 선출원일 후 우선권주장출원일 전에 독자적으로 개발·실시를 개시한 乙의 발명이 특허 T의 권리범위 내인바, 국내우선권주장출원의 소급효(§ 55③)가 선사용권(§ 103)의 판단시점에 미치는지, 그에 따라 乙에게 선사용권이 성립하는지 문제 된다.

2. 제55조 제3항 소급효의 성격과 범위

국내우선권주장이 적법하면 우선권주장출원의 청구범위에 기재된 발명 중 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 관하여는, 제55조 제3항에 열거된 규정을 적용할 때 그 특허출원을 선출원을 한 때에 출원한 것으로 본다. 이는 출원일 자체의 소급이 아니라 판단시점의 소급이며, 파리조약 제4조 B에 기초하여 예시열거적으로 해석되는 조약우선권(§ 54①)과 달리 제55조 제3항의 열거는 제한열거적이다. 그런데 제55조 제3항의 열거에는 선사용권에 관한 제103조이 포함되어 있으므로, 선사용권의 성립 여부를 판단할 때의 "특허출원 시"는 선출원일로 소급된다.

3. 결론

특허 T의 발명은 최초 출원의 청구범위에는 없었더라도 선출원의 최초 명세서·도면에 기재된 사항이므로 제55조 제3항의 소급 대상이다. 따라서 제103조를 적용할 때 기준시점은 우선권주장출원일이 아니라 선출원일이 된다. 乙은 독자 개발자로서 부지·독자개발의 요건을 갖추었으나, 그 개발과 실시의 개시가 선출원일 후이므로 기준시점인 선출원 시에 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있던 자에 해당하지 아니한다. 결국 **乙의 선사용권은 부정되고, 乙은 특허 T의 권리범위 내 실시에 대하여 침해 책임을 지는 지위에 있다.**

IV. 설문 (4) — 심판1(발명 Z)·심판2(발명 Y)에서 문제되는 쟁점

1. 문제의 소재

乙이 실시하지 않기로 한 발명 Z(A+B+C, 특허발명과 동일)와 장래 완성하여 실시하려는 발명 Y(A+B+C+D)를 각각 확인대상발명으로 하는 소극적 권리 범위확인심판에서, 확인의 이익 등 심판청구의 적법요건과 본안 판단이 문제 된다.

2. 확인의 이익 일반

소극적 권리범위확인심판의 청구인인 이해관계인에는 과거에 확인대상발명을 실시한 자와 현재 실시하는 자뿐 아니라, 분쟁 예방이라는 제도의 기능상 장래에 실시할 예정이 있는 자도 포함된다(97후3241 등). 확인의 이익은 심판청구의 적법요건으로서 직권조사사항이고(2024후10436 참조), 흠결이 있으면 심판청구는 심결각하된다.

3. 심판1(발명 Z)의 쟁점

첫째, **확인 이익**이 문제 된다. 1) 확인대상발명 Z는 특허발명과 동일한 A+B+C이므로, Z가 권리범위에 속하지 아니한다는 심결은 특허발명 자체의 효력을 부정하는 것과 같이 무효 여부의 판단을 무효심판에 전속시킨 특허법의 기본 구조에 반하고, 특허의 무효를 주장하는 것과 다름없는 권리범위확인심판 청구는 확인의 이익이 결여된다(99후2433 참조). 2) 나아가 乙은 Z를 실시하지 않기로 하였으므로, 심결을 받더라도 법적 불안의 해소에 도움이 되지 아니하여 확인의 이익이 없다(2004후1663). 따라서 심판1은 부적법하여 심결각하되어야 한다.

둘째, **설령 본안에 나아가더라도** 乙이 원용할 수 있는 선행기술은 甲의 제형행사 동영상·블로그 게시인데, 이는 공지예외(§ 30) 적용의 근거가 된 공지로서 신규성·진보성 판단의 선행기술에서 제외되므로 이를 근거로 한 신규성 위반의 항변은 허용되지 아니하고, 같은 공지를 근거로 한 자유기술의 항변도 허용되지 아니한다(2022후10012). 결국 Z가 권리범위에 속하지 아니한다는 주장은 받아들여질 수 없다.

4. 심판2(발명 Y)의 쟁점

첫째, **확인 이익**에 관하여, 그 업무의 성질상 장래에 실시하리라고 추측되는 자도 이해관계인에 포함되므로(97후3241 등), 乙은 Y의 사업화 전략을 구상하며 장래 실시하려는 자로서 확인의 이익이 긍정될 수 있다.

둘째, **확인대상발명의 특징**은 청구취지로서의 특징과 청구원인으로서의 특징을 구별하여야 한다. 1) **청구취지로서의 특징**은 사회통념상 다른 것과 구별될 정도로 기재되어야 하는 것으로 일사부재리의 효력범위를 정하는 의미를 가지며, 미흡하면 요지변경이 되지 아니하는 범위에서 보정을 명하고 그대로 특정되지 아니하면 각하한다. 2) **청구원인으로서의 특징**은 특허발명의 구성과 대비하여 차이점을 판단함에 필요할 정도로 대응 구성을 기재하는 것으로, 청구취지로서의 특징이 명확하다면 다소 불명확하더라도 나머지 기재와 도면을 종합하여 속부를 판단할 수 있으면 본안심결을 할 수 있다(2010후3356). 소극적 심판에서는 청구인 스스로 실시자여서 특정 의무가 더 높는데, 발명 Y는 구성 D가 구체화되지 아니하여 양 차원의 특징을 갖추었는지가 선결적으로 문제 된다.

셋째, **본안**에 관하여 Y(A+B+C+D)는 특허발명(A+B+C)의 구성요소 전부와 그 유기적 결합관계를 그대로 포함하면서 구성 D를 부가한 것이므로, 구성요소완비의 원칙상 특허발명의 권리범위에 속하며 이용관계(§ 98)에 해당한다. 구성요소를 부가하였다는 사정만으로 권리범위를 벗어나는 것이 아니다.

5. 결론

심판1은 특허발명과 동일한 데다 乙이 실시를 포기한 발명을 대상으로 하여 확인의 이익이 없어 심결각하되어야 하고, 본안에서도 공지예외 적용의 근거가 된 공지에 기한 신규성·자유기술 항변은 허용되지 아니한다. 심판2는 확인의 이익은 긍정될 수 있으나 확인대상발명의 특징이 선결적으로 문제 되고, 본안에서 Y는 특허발명의 권리범위에 속하므로 심판청구는 기각되어야 한다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

설문	쟁점	배점	특점 포인트
(1)	무효사유·자유실시기술 주장을 소극적 권리범위확인심판에서 판단하는 것의 타당성	5	진보성 판단 불가(대법원 2012후4162 전원합의체)·신규성 명백 시 예외(81후56 전원합의체)를 구분하고, 제30조 공지예외 적용 공지는 선행기술에서 제외되어 자유실시기술 주장도 허용되지 않는다는 판례(2022후10012·2023후11562)로 포섭
(2)	모방 실시자 乙에 대한 선사용권(§103)·중용권(§104) 법리의 유추적용 비교	10	제103조 요건 포섭(부자·독자개발 결여로 직접 적용 부정) → 유추적용 긍정·부정 논거 → 제104조 요건과 등록 신뢰 부재 → 신뢰 대상·대가·주체 비교 후 양자 모두 부정 결론
(3)	국내우선권(§55③) 소급효와 선사용권 성립 기준시점	5	제55조 제3항 판단시점 소급·제한열거성 → 제103조 열거 포함 → 선출원 최초 명세서 기재 발명은 선출원 시 기준 → 선출원일 후 실시 개시한 乙의 선사용권 부정
(4)	심판1(동일 발명·실시 포기)·심판2(장래 실시·미완성 발명)의 쟁점	10	심판1: 특허발명과 동일한 확인대상발명(무효 주장과 같은 결과)+실시 포기로 확인의 이익 부정 → 각하 / 심판2: 장래 실시 예정의 확인의 이익 긍정(97후3241)+확인대상발명 특정(§140③) 문제+이용관계(§98)로 본안 기각
합계		30	

특별 채점 기준

1) 논점 추출(약 12점)

- (1)에서 "무효사유의 심판 내 판단 가부"(진보성/신규성 구분)와 "공지예외 공지에 기한 자유실시기술 항변 가부"를 별개의 논점으로 분리해 추출했는가.
- (2)에서 단순 제103조 요건론에 그치지 않고, 공지예외 주장 출원의 중간 실시자 보호라는 특수성을 포착하여 유추적용 논의로 나아갔는가. 중용권 (§ 104)을 빠뜨리지 않고 대등하게 검토했는가.
- (3)에서 제55조 제3항의 열거 규정에 제103조이 포함된다는 점을 찾아 선사용권 기준시점 소급이라는 핵심 논점을 추출했는가.
- (4)에서 심판1은 "동일 발명"과 "실시 포기" 두 갈래, 심판2는 "장래 실시 확인의 이익"·"미완성 발명의 특정"·"이용관계 본안" 세 갈래를 각각 추출했는가.

2) 목차·구성(약 7점)

- 설문별로 논점 → 법리(조문·판례) → 포섭 → 결론의 목차가 일관되게 유지되는가.
- (2)는 선사용권 → 중용권 → 비교분석 → 결론의 대칭 구조로, "비교분석"이라는 설문 요구가 목차에 드러나는가.
- (4)는 확인의 이익 일반론을 공통 전제로 두고 심판1·심판2를 병렬 배치했는가.
- 배점 비례 분량 배분 — (2)·(4)가 답안의 중심이 되고 (1)·(3)이 간결하게 처리되었는가.

3) 답안 작성·논증(약 11점)

- 판례를 최초 인용 시 완전 표기(선고일자·사건번호·전원합의체 여부)하고 법리 문구를 정확히 재현했는가(특히 2012후4162 전합의 세 가지 논거, 2022후10012의 세 가지 논거).
- 사안의 사실(甲의 자기 공지·공지예외 취득, 乙의 모방, 독자개발, 실시 포기, 장래 실시 구상)을 요건별로 짚어 포섭했는가.
- 각 설문의 결론이 "타당하지 않다 / 부정된다 / 각하되어야 한다 / 기각되어야 한다"로 단정적으로 제시되었는가.
- 조문 표기 (§ 30, § 55③, § 98, § 103, § 104, § 135, § 140③)가 정확하고, 각하(적법요건)와 기각(본안)의 용어 구분이 정확한가.

감점 주의

- 권리범위확인심판에서 진보성 무효사유를 판단할 수 있다고 서술 — 2012후4162 전원합의체 법리의 정면 위반으로 설문 (1) 대부분 실점.
- 甲의 인터넷 게시를 그대로 선행기술로 취급하여 신규성 상실 또는 자유실시기술 해당으로 결론 — 제30조 공지예외의 잠탈 논점(2023후11562) 누락은 본 문항 최대의 함정.
- (2)에서 제103조 요건 포섭 없이 곧바로 유추적용 결론으로 비약하거나, 중용권 검토를 누락하여 "비교분석"이라는 설문 요구를 이행하지 않은 답안.
- (3)에서 국내우선권을 출원일 소급으로 잘못 서술하거나, 제55조 제3항의 제한열거성·제103조 포함 여부를 확인하지 않고 우선권주장출원일 기준으로 선사용권을 긍정한 답안.
- (4) 심판1을 본안 판단(청구 기각)으로 결론 — 확인의 이익 흠결은 심결각하 사유이며, 각하와 기각의 혼동은 감점.
- (4) 심판2에서 장래 실시 예정 발명이라는 이유만으로 확인의 이익을 부정 — 소극적 심판의 분쟁 예방 기능(97후3241)에 반하는 결론.
- 판례 사건번호·선고일자 오기, "~로 볼 여지가 있다"류의 결론 유보.

2019년 제2문

사례형

20점

문제

甲(특허권자)과 乙(실시권자)은 'AMVP 모드에서 영상 부호화 방법'을 명칭으로 하는 특허발명(이하 '이 사건 특허발명'이라 함)에 대하여 실시계약(이하 '이 사건 실시계약'이라 함)을 체결하였다. 그런데 이 사건 실시계약 중 乙이 甲의 이 사건 특허발명에 대하여 무효심판을 청구하였다.

기초적 사실관계에 따르면 甲의 행위는 다음과 같다.

- 2011. 8. 29. 특허출원(이하 '이 사건 선출원'이라 함)을 하였다.
- 2012. 1. 20. 이 사건 선출원을 기초로 우선권을 주장하여 국제출원(PCT)을 하였다.
- 2012. 3. 12. 위의 국제출원(PCT)에 대하여 당시 특허법 제203조가 정한 서면을 제출하여 국내절차를 진행하였다.(이하 '국제특허출원'이라 함)
- 2012. 3. 16. 위의 국제특허출원을 기초로 분할출원(이하 '분할출원 A'라 함)하였다.
- 2014. 4. 25. 위의 분할출원 A를 기초로 분할출원(이하 '분할출원 B'라 함)하여 특허를 받았다.
- 그런데 분할출원 B(이 사건 특허발명)는 물론 분할출원 A의 특허출원서에도 '우선권 주장의 취지 및 이 사건 선출원의 표시'를 기재하지 아니하였다.

이 사건 특허발명은 이 사건 선출원보다 늦게 출원된 선행발명(2011. 11. 7. 출원)으로 인해 진보성이 부정되었다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적임)

(1) '분할출원 B'가 이 사건 선출원의 우선권주장 효력을 인정받을 수 있는지 여부에 대하여 논거를 제시하여 설명하시오. (10점)

(2) 위 사안에서, 특허심판원과 특허법원 모두 甲의 이 사건 특허발명을 무효라고 판단하였다. 대법원도 甲이 패소한 원심 판결을 확정하였다(상고 기각). 한편 특허법원에서 이 사건 특허가 무효라는 취지로 판결이 선고되자, 그 선고일 이후부터 乙은 甲에게 이 사건 실시계약에 따른 실시료를 지급하지 않고 있다.

이러한 사실관계에 따라 때, 이 사건 특허가 무효로 확정되었다고 하더라도 甲이 乙에게 특허발명 실시계약이 유효한 기간 동안의 미지급 실시료를 지급을 청구할 수 있는지 여부에 대하여 논거를 제시하여 설명하시오.(10점)

모범답안

문제 2 모범답안

I. 설문 (1) — 분할출원 B의 우선권 주장 효력

1. 문제의 소재

원출원(국제특허출원)에는 이 사건 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 있었으나, 그로부터 이어진 분할출원 A·B의 특허출원서에는 '우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시'가 기재되지 아니하였다. 분할출원이 원출원의 우선권 주장 효력을 **별도 기재 없이** 승계받을 수 있는지가 문제된다.

2. 법리 — 2017후2819 판결

제55조 제1항 본문·제2항·제3항과 제52조 제1항·제2항 제4호의 취지를 종합하면, **분할출원이 제55조에 의한 우선권 주장의 효력을 인정받기 위해서는 분할출원 시의 특허출원서에 '우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시'를 하여야 하고**, 이것이 기재되지 아니한 분할출원은 제55조에 따른 우선권 주장의 효력을 인정받을 수 없다.

그 근거는 다음과 같다. (1) 분할출원은 원출원과 별개의 **새로운 출원**이므로, 우선권 주장이라는 절차도 분할출원에서 별도로 밟아야 한다. (2) 제52조 제2항 단서 제4호는 분할출원의 출원일 소급 간주에 대한 예외로서 제55조 제2항(국내우선권주장의 취지 기재)을 적용할 경우에는 그 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 보고 있는바, 이는 곧 제55조 제2항의 '특허출원과 동시에 주장' 요건을 분할출원일 기준으로 완화하여 법 스스로 **분할출원서에 우선권 주장을 새로 기재할 것을 예정한** 것이다. (3) 우선권 주장 여부는 출원서 기재에 의해 공시되어 제3자의 신뢰의 기초가 되므로, 기재 없는 우선권 주장의 효력을 인정하면 절차적 안정을 해친다.

3. 사안의 포섭

분할출원 B는 물론 그 원출원인 분할출원 A의 특허출원서에도 '우선권 주장의 취지 및 이 사건 선출원의 표시'가 기재되지 아니하였으므로, **분할출원 B(이 사건 특허발명)는 이 사건 선출원(2011. 8. 29.)을 기초로 한 우선권 주장의 효력을 인정받을 수 없다.**

이 경우 분할출원 B는 제52조 제2항 본문의 출원일 소급에 따라 모출원인 국제특허출원 시에 출원된 것으로 보게 되어, 신규성·진보성 판단의 기준일은 **국제출원일인 2012. 1. 20.** 이 된다. 따라서 그보다 앞서 출원된 선행발명(2011. 11. 7. 출원)이 선행기술이 되고, 이 사건 특허발명은 이로 인해 **진보성이**

부정된다(무효사유, § 133①(1)·§ 29②).

4. 개정법에 따른 입법적 보완

이러한 기재 누락으로 등록이 거절·무효로 되는 문제를 해소하기 위해, 현행법(2021. 10. 19. 개정 법률 제18505호, 2022. 4. 20. 시행)은 **제52조 제4항을 신설**하여 분할의 기초가 된 원출원이 제54조(조약우선권) 또는 제55조(국내우선권)에 따라 우선권을 주장한 출원인 경우 **분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 간주**하고, 원출원에 대해 제출된 우선권 증명서류도 **분할출원에 제출된 것으로 간주**한다. 나아가 제52조 제5항은 간주된 우선권 주장에 관하여 제54조 제7항·제55조 제7항의 기한이 지난 후에도 일정 기간 우선권 주장의 보정·추가를 허용한다. 따라서 현행법 하에 서라면 이 사건과 같은 기재 누락만으로 우선권의 효력이 부정되지는 않으나, 위 개정 규정 시행 전의 출원에는 본 판결(2017후2819)의 법리가 그대로 적용된다.

5. 결론

분할출원 B는 특허출원서에 우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시를 기재하지 아니하여 우선권 주장의 효력을 인정받을 수 없고, 판단 기준일이 국제출원일(2012. 1. 20.)로 되어 선행발명에 의해 **이 사건 특허발명은 진보성이 부정되어 무효사유가 존재한다**. 다만 이는 현행법상 신설된 제52조 제4항·제5항에 의해 입법적으로 해소되었으므로, 위 결론은 그 시행 전 출원에 한하여 타당하다.

II. 설문 (2) — 무효 확정과 미지급 실시료 지급 청구

1. 문제의 소재

특허 무효가 확정되면 특허권은 처음부터 없었던 것으로 간주되는바(§ 133③), 이 소급효가 실시계약에도 관철되어 甲의 미지급 실시료 청구가 부정되는 지 문제된다. 아울러 특허법원의 무효 취지 판결 '선고'와 무효 '확정'의 구별이 필요하다.

2. 법리 — 대법원 2012다42666-2018다287362 판결

(1) 특허발명 실시계약이 체결된 이후 그 대상 특허가 무효로 확정되더라도, **실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단**하여야 한다. (2) 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 실시에 대해 침해로 인한 손해배상·금지를 청구할 수 없고, 무효 확정 전에는 특허권의 **독점적·배타적 효력에 의하여 제3자의 실시가 금지**되므로, 실시권자는 그동안 사실상 독점적 이익을 누린다. (3) 따라서 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한, 무효의 소급효에도 불구하고 실시계약이 **원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수 없고, 무효가 확정된 때부터 이행불능에 빠질** 뿐이다. (4) 그러므로 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 **실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안의 실시료 지급을 원칙적으로 청구할 수 있다**(대법원 2018다287362).

(5) 이미 지급받은 실시료의 반환 여부도 같다. 부당이득(민법 § 741)이 성립하려면 **법률상 원인 없이** 이익을 얻고 그로 인하여 타인에게 손해를 가하였을 것을 요하는데, 실시계약은 무효 확정 전까지 유효하게 존재하였으므로 그 기간에 상응하여 지급받은 실시료는 유효한 실시계약이라는 법률상 원인에 기하여 수령한 것이고, 실시권자도 그 기간 동안 특허권의 독점적·배타적 효력에 의하여 제3자의 실시가 금지되는 이익을 누렸으므로 손해를 입었다고 보기도 어렵다. 따라서 이미 지급받은 실시료 중 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분은 **부당이득의 요건에 해당하지 아니하여** 특허권자가 이를 반환할 의무가 없다(대법원 2012다42666).

3. 사안의 포섭

특허법원에서 무효 취지의 판결이 선고되었더라도 그 확정 전에는 특허권이 유효하게 존속하며, 이 사건 특허는 **대법원의 상고기각으로 비로소 무효가 확정**되었다. 따라서 이 사건 실시계약은 무효 확정 시까지 유효하게 존재하였고 그때부터 장래를 향하여 이행불능이 될 뿐이므로, 乙이 특허법원 판결 선고일 이후 지급을 거절한 실시료 중 **무효 확정 전 기간에 상응하는 부분에 대하여 甲은 그 지급을 청구할 수 있다**(계약 자체의 무효·취소 사유나 실시불능 사정이 없는 한). 무효 확정 이후 기간의 실시료는 이행불능으로 청구할 수 없다.

4. 결론

甲의 미지급 실시료 지급 청구는 실시계약이 유효하게 존재한 기간(무효 확정 전)의 범위에서 **인용**된다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

설문	쟁점	배점	특점 포인트
(1)	분할출원과 우선권 주장의 승계 여부	10	분할출원=새로운 출원 → 분할출원서에 '우선권 주장의 취지·선출원의 표시' 별도 기재 필요(2017후2819, \$52②(4)\$55①~③ 취지 종합), 미기재 시 우선권 효력 부정, 기준일=국제출원일(2012. 1. 20.) → 선행발명(2011. 11. 7.)으로 진보성 부정
(2)	특허 무효 확정과 미지급 실시료 청구	10	무효 소급효(\$133③)에도 실시계약 효력은 별개 판단, 원시적 이행불능 부정·확정 시부터 이행불능(2012다42666), 계약 유효 기간의 미지급 실시료 원칙적 청구 가능(2018다287362), 특허법원 선고≠확정
합계		20	

축별 채점 기준

1) 논점 추출(약 8점)

- (1)에서 '원출원(국제특허출원)에는 우선권 주장이 있었으나 분할출원서에는 없다'는 사실관계의 간극을 포착하여, 분할출원에 원출원의 우선권 주장이 자동 승계되는지를 정면 논점으로 세웠는가.
- (1)에서 우선권 효력 부정 시 판단 기준일이 어디로 귀착되는지(분할출원의 소급효 § 52② → 모출원의 국제출원일)까지 연결했는가.
- (2)에서 '무효 확정'과 '실시계약의 운명'을 분리하는 것이 논점임을 파악했는가(무효 소급효를 계약에 그대로 관찰하면 오답 방향).
- 참고: 실시권자 乙의 무효심판 청구인격적(2017후2819 판시 [1], 이해관계인 인정·판례 변경)을 서두에 언급하면 가점 요소.

2) 목차·구성(약 5점)

- (1)은 '논점 → 법리(요건·근거) → 사안 포섭(A·B 모두 미기재) → 기준일 확정과 진보성 결론' 순서로 체계화했는가.
- (2)는 '무효의 소급효 → 실시계약 효력의 독립 판단 → 이행불능 시점 → 사안 포섭 → 결론' 흐름을 갖추었는가.
- 감점: 판례 문구 전사 후 사안 포섭 생략, 배점 대비 서두 일반론 장황.

3) 답안 작성·논증(약 7점)

- (1)에서 현행법의 입법적 보완 — 2021. 10. 19. 개정(2022. 4. 20. 시행)으로 신설된 제52조 제4항(분할출원 시 우선권 주장·증명서류 제출 자동 간주)·제52조 제5항(기한 경과 후 보정·추가 허용)가 이 판결이 드러낸 출원인 보호 미흡을 해소했음을 부기했는가(가점 요소, 개정 전 출원에는 판례 법리 적용 유지).
- (1)에서 기재 요구의 실질적 근거(분할출원은 새로운 출원이라는 성질, § 52②단서 제4호가 § 55②의 '출원과 동시 주장'을 분할출원일 기준으로 완화된 취지 = 법이 분할출원서 기재를 예정, 출원서 기재에 의한 공시·제3자 신뢰)를 자기 언어로 설명했는가.
- (2)에서 원시적 이행불능이 아닌 실질적 이유(무효 확정 전에는 특허권의 독점·배타적 효력으로 제3자 실시가 금지되고 실시권자는 침해책임 없이 실시 이익을 누림)를 제시했는가.
- (2)에서 무효 '확정' 시점(상고기각 시)과 특허법원 '선고' 시점을 구별하여 미지급 구간을 정확히 포섭했는가.
- 감점: 결론 애매모호, (1)에서 우선권을 인정해 놓고 진보성 부정을 설명하는 등 논리 모순.

감점 주의

- (1)에서 '원출원에 우선권 주장이 있었으므로 분할출원에 당연히 승계된다'고 결론 낸 경우(2017후2819에 정면으로 반함) → 큰 감점.
- (1)에서 우선권 효력을 부정하면서 판단 기준일을 분할출원 B의 현실 출원일(2014. 4. 25.)로 잡은 경우 — 분할출원의 출원일 소급(§ 52②)을 놓친 것.
- (2)에서 무효의 소급효(§ 133③)를 이유로 실시계약도 소급 무효라며 실시료 청구를 전면 부정한 경우(판례 반대) → 큰 감점.
- (2)에서 특허법원 판결 선고일부터 계약이 이행불능이 된다고 본 경우(확정 전에는 특허권 유효 존속).
- 이미 지급한 실시료의 부당이득 반환(2012다42666의 다른 쟁점)과 미지급 실시료 청구를 혼동한 경우.

2019년 제3문

사례형

30점

문제

외국회사 甲(원고)은 '마찰이동 용접방법'에 관한 발명 A(이하 '이 사건 방법발명'이라 함)의 특허권자이다. 甲과 乙 사이에 이 사건 방법발명을 실질적으로 구현한 장비인 '마찰교반 용접기'(이하 '이 사건 용접기'라 함)를 제조·판매해도 좋다는 통상실시권 설정계약을 체결하였다. 그 후 丙(피고)은 乙로부터 乙이 제조한 이 사건 용접기를 구매하여 사용하였다.

甲은 丙을 상대로 정당한 권한 없이 이 사건 용접기를 이용하여 이 사건 방법발명을 업으로 실시함으로써 甲의 특허권을 침해하였다고 주장하며 丙을 상대로 이 사건 손해배상청구의 소를 제기하였다. 丙은 자신의 이 사건 용접기의 구매 및 사용행위에는 甲의 특허권의 효력이 미치지 아니하므로 특허권 침해가 성립되지 않는다고 주장하였다.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적임)

(1) 甲의 특허권의 효력이 미치지 아니한다는 丙의 주장의 타당성에 대하여 그 주장의 이론적 근거, 성립요건을 중심으로 논하시오. (8점)

(2) 위 사안에서, 실시권자 乙은 특허권자 甲의 동의를 얻어 이 사건 용접기를 국내 제조 후 국외에서 최초 판매하였다. 그 후 제3자에 의해 이 사건 용접기가 국내에 수입된 경우 甲의 특허권의 효력이 수입된 이 사건 용접기에 미치는지 여부에 대하여 설명하시오. (6점)

(3) 위 사실관계와 달리, 특허권자 甲은 직접 이 사건 용접기를 제조·판매하고 있다. 甲과 최초 구입자 乙은 재판매 금지조건 합의를 하였다. 그럼에도 불구하고 乙이 그 조건에 반하여 丙에게 전매(재양도)한 경우 甲의 특허권의 효력이 丙의 이 사건 용접기의 구매 및 사용행위에 미치는지 여부에 대하여 설명하시오. (6점)

(4) 위 사실관계와 달리, 특허권자 甲(원고)은 소외 X와 이 사건 방법발명에 대해 통상실시권 설정계약을 체결하였다. 해당 계약에는 이 사건 방법발명의 실시장소를 제한하고 타인에게 재 실시 허락하는 것을 금지하는 내용이 포함되어 있었다. 피고 丁은 소외 X로부터 이 사건 방법발명의 실시에만 사용되는 이 사건 용접기(이하 '이 사건 전용품'이라 함)의 제작을 의뢰받고 20여 대를 제작해 소외 X에게 납품하였다. 그 과정에서 피고 丁은 이 사건 전용품을 검수 시연할 목적으로 이 사건 방법발명을 실시하였다. 甲이 丁을 상대로 간접침해를 주장하며 손해배상청구의 소를 제기한 경우 甲의 주장의 타당성을 논하시오. (10점)

모범답안

문제 3 모범답안

I. 설문 (1) — 丙의 특허권 소진 주장의 타당성 (8점)

1. 문제의 소재

丙은 실시권자 乙로부터 이 사건 용접기를 구매하여 사용할 뿐이므로, 방법발명인 이 사건 특허권이 소진되어 丙의 사용행위에 특허권의 효력이 미치지 않는지 — 방법발명에 대한 권리소진의 인정 여부와 그 성립요건 — 가 문제된다.

2. 권리소진의 의의와 이론적 근거

특허권자 또는 제조·판매권을 가진 실시권자(이하 '특허권자 등')가 특허발명을 실질적으로 구현한 물건을 우리나라에서 적법하게 양도하면, 양도된 당해 물건에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진되고 양수인·전득자의 사용·양도 등 행위에 특허권의 효력이 미치지 않는다(대법원 2017다289903). 명문 규정 없이 판례로 인정되는 법리로서, 그 이론적 근거는 1) 소유권을 적법하게 취득한 양수인·전득자의 기대 보호, 2) 양도 시마다 특허권자의 동의를 요구하면 특허제품의 유통과 거래안전이 현저히 저해되는 점, 3) 특허권자는 최초 양도 시 특허발명의 대가를 확보할 기회를 이미 가지므로 이중이익의 기회를 줄 필요가 없는 점이다.

3. 방법발명에 대한 권리소진 인정 여부

판례는 1) 방법발명을 실질적으로 구현한 물건의 양수인 등이 실시할 때마다 허락을 받아야 한다면 물건의 자유로운 유통과 거래안전을 저해하고, 2) 특허권자는 전용품을 양도할 권리를 사실상 독점하므로(제127조 제2호) 그 양도가액·실시료의 결정으로 실시 대가를 확보할 기회가 있으며, 3) 물건발명과 방법발명은 실질적으로 동일한 경우가 적지 않아 방법발명을 소진 대상에서 제외하면 청구항 기재 방식으로 소진을 손쉽게 회피할 수 있다는 이유로, 방법발명에 대하여도 권리소진을 인정한다(대법원 2017다289903).

4. 성립요건

권리소진이 성립하려면 1) 특허권자 등이, 2) 방법발명을 실질적으로 구현한 물건을, 3) 우리나라에서 적법하게 양도하였을 것을 요한다. 실질적 구현 여부는 사회통념상 그 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도가 없는지, 방법발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소를 모두 포함하는지, 그 물건을 통해 이루어지는 공정이 전체 공정에서 차지하는 비중 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

5. 사안의 포설 및 결론

乙의 판매는 제조·판매를 허락받은 실시권자에 의한 적법한 양도이고, 이 사건 용접기는 본래 용도가 이 사건 방법발명의 실시뿐이며 기술사상의 핵심 구성을 모두 갖추어 방법발명을 실질적으로 구현한 물건이다. 따라서 이 사건 특허권은 소진되어 丙의 구매·사용행위에 효력이 미치지 않으므로, **丙의 주장은 타당하다.**

II. 설문 (2) — 국외 최초판매 후 국내 수입과 소진(국제소진)

1. 문제의 소재

특허권자 등이 국외에서 최초판매한 특허제품이 제3자에 의해 국내에 수입된 경우, 국외 판매로써 **국내 특허권이 소진되는지**(이른바 국제소진·병행수입) 문제된다. 속지주의·특허독립의 원칙과 이중이득 금지라는 소진의 근거가 충돌하는 지점이다.

2. 비교법과 국내 사례

(1) 일본은 BBS 사건에서 각국 특허권은 별개의 권리이므로 이중이득이 아니라고 하여 국제소진 자체는 부정하면서도, 판매 시 일본을 판매지역에서 제외한다는 합의·명기가 없는 한 특허권을 행사할 수 없다는 묵시적 실시허락 구성으로 사실상 병행수입을 허용하였다. (2) 미국은 Lexmark 사건에서 판매 당시 부가된 제한이나 판매지 여하를 불문하고 적법한 판매가 있으면 특허권이 소진된다고 하여 국제소진을 정면으로 인정하였다. (3) 우리나라는 하급심(서울지방법원 동부지원 81가합466)이 국내 특허권자가 수출한 제품이 재수입된 사안에서 소진을 인정한 예가 있으나, **대법원 판례는 아직 확립되어 있지 않다.**

3. 검토

권리자의 이중이득 금지라는 소진의 근거에 비추어 보면 특허제품이 국내에서 판매되었는지 국외에서 판매되었는지는 본질적 차이가 없다. 특허권자 등이 판매의 주체인 이상 그 판매로 특허발명의 대가를 확보할 기회를 가졌기 때문이다. 따라서 소진의 요건으로서 **판매지역은 국내외를 불문**하되, 특허독립의 원칙·속지주의상 그 **효력은 특허권이 부여된 국가(국내 특허권)에 한정**된다고 봄이 타당하다.

4. 결론

실시권자 乙은 특허권자 甲의 동의를 얻어 이 사건 용접기를 국내에서 제조하여 국외에서 최초판매하였으므로, 甲은 그 판매 과정에서 특허발명의 대가를 확보할 기회를 가졌다. 따라서 甲의 국내 특허권은 소진되었고, 제3자가 수입한 이 사건 용접기에 대하여 **甲의 특허권의 효력은 미치지 않는다.**

III. 설문 (3) — 재판매 금지조건 위반 전매와 소진

1. 문제의 소재

특허권자가 특허제품을 판매하면서 재판매 금지조건을 부가한 경우, 그 조건에 위반한 전매에 의해 취득한 자에게 특허권의 효력이 미치는지 — 즉 **조건부 판매로 권리소진을 배제·제한할 수 있는지** 문제된다.

2. 학설·비교법

일본에서는 판매 시 사용·처분에 제한을 두더라도 그 위반은 계약위반이 될 뿐 특허권 침해를 구성하지 않는다고 본다. 미국도 Lexmark 사건에서 판매 시 어떠한 제한을 부가하였는지와 무관하게 적법한 판매로 특허권은 소진되고, 제한조건 위반은 **계약법에 의해 당사자 사이에서만** 다룰 수 있다고 판시하였다. 공정거래위원회의 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」도 판매한 상품의 재판매 관련 조건 부과를 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 행위로 예시한다.

3. 판례

대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결은 계약상 **부수적인 제한조건을 위반하여 판매한 경우** 일률적으로 특허권자의 동의 없는 양도로서 소진이 배제된다고 볼 수는 없고, i) 계약의 구체적 내용, ii) 특허권자가 판매로 보상을 받았음에도 추가 유통을 금지할 이익, iii) 특허제품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 소진 여부를 판단하여야 한다고 하였다.

4. 결론

특허권자 甲이 스스로 이 사건 용접기를 제조·판매하였으므로 甲은 판매 시점에 특허발명의 대가를 확보할 기회를 가졌고, 이로써 당해 용접기에 대한 특허권은 소진되었다. 재판매 금지조건은 甲·乙 사이의 채권적 합의에 불과하여 乙이 이를 위반해 丙에게 전매하였더라도 이미 발생한 소진의 효과를 뒤집을 수 없으며, 추가 유통을 금지할 甲의 이익보다 거래안전·수요자(丙) 보호의 필요성이 크다. 따라서 **甲의 특허권의 효력은 丙의 구매·사용행위에 미치지 않는다.** 甲은 乙에 대하여 계약위반 책임을 물을 수 있을 뿐이다.

IV. 설문 (4) — 丁에 대한 간접침해 주장의 타당성

1. 간접침해 제도(§127(2))

특허가 방법발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건(전용품)을 업으로서 생산·양도·대여·수입하거나 그 양도·대여의 청약을 하는 행위는 특허권을 침해한 것으로 본다. 이는 직접침해의 개연성이 높은 전 단계 행위를 침해로 간주하되, 어디까지나 **특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서** 그 실효성을 확보하려는 제도이다(대법원 2014다42110 판결).

2. 실시권자의 의뢰로 전용품을 제작·납품한 행위

대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결은, 방법발명의 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 공급받아 방법발명을 실시하는 경우 그 제3자의 전용품 생산·양도 행위를 간접침해로 인정하면 i) **실시권자의 실시권에 부당한 제약**을 가하게 되고, ii) **특허권이 부당하게 확장**되는 결과를 초래하며, iii) 특허권자는 실시권 설정 시 제3자로부터 전용품을 공급받아 실시할 것까지 예상하여 **실시료를 책정하는 등의 방법으로 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로** 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기 어렵다는 이유로, 간접침해에 해당하지 않는다고 하였다.

3. 검수 시연 목적의 실시

전용품 제작·납품 행위가 간접침해를 구성하지 않는 이상, 그에 **불가분적으로 수반되는 검수 시연 목적의 방법발명 실시** 역시 별도의 침해를 구성하지 않는다.

4. 사안의 포섭

X는 甲과의 설정계약에 기한 적법한 통상실시권자이다. 계약상 실시장소 제한·재실행허락 금지 특약이 있으나, X가 丁에게 전용품 제작을 의뢰하여 납품받는 것은 자신의 실시를 위한 조달행위일 뿐 丁에게 방법발명의 실시를 허락(재실행허락)한 것이 아니므로 실시권의 범위를 벗어나지 않는다. 따라서 丁이 이 사건 전용품 20여 대를 제작하여 X에게 납품한 행위는 제127조 제2호의 간접침해에 해당하지 않고, 그 과정에서 검수 시연 목적으로 방법발명을 실시한 행위도 제작·납품에 불가분적으로 수반된 것으로서 별도의 침해를 구성하지 않는다.

5. 결론

甲의 간접침해 주장은 타당하지 않다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

설문	쟁점	배점	득점 포인트
(1)	방법발명 특허권 소진의 이론적 근거·성립요건	8	소진의 의의, 근거 3가지(양수인 보호·유통 보호·이종이득 금지), 방법발명 소진 인정 논거 (2017다289903), 요건 3가지 + 실질적 구현 판단기준(㉔용도 ㉕핵심 구성 ㉖공정 비중), 사안 포섭
(2)	국외 최초판매 후 국내 수입 — 국제소진(병행수입)	6	문제 소재(숙지주의-특허독립 vs 이종이득 금지), 일본 BBS-미국 Lexmark-국내 81가합466, 판매지역 불문 소진·효력은 부여국 한정, 대법원 판례 미확립 언급
(3)	재판매 금지조건 위반 전매와 소진	6	조건부 판매의 소진 배제 가부, 조건의 채권적 효력(계약 당사자 간), 2018도14446(부수적 제한조건 위반 시 종합판단), 공정위 심사지침, 甲의 계약책임 추궁 가능성
(4)	실시권자 의의 전용품 제작·납품의 간접침해(§127(2))	10	간접침해 취지(2014다42110), 2017다290095의 3논거(실시권 부당 제약·특허권 부당 확장·실시료 책정으로 이윤 회수), 검수 시연 = 불가분적 수반행위로 별도 침해 불구성
합계		30	

축별 채점 기준

1) 논점 추출(약 12점)

- (1)에서 발문이 '이론적 근거, 성립요건 중심'으로 특정되어 있음에 착안하여 소진의 근거 3가지와 요건 3가지를 정면으로 추출했는가. 특히 이 사건이 **방법발명**임을 포착하여 방법발명 소진 인정 여부(2017다289903)를 별도 논점으로 세웠는가.
- (2)에서 단순 소진이 아니라 **국외 최초판매**라는 점에서 국제소진(병행수입) 논점을 포착했는가.
- (3)에서 특허권자 **직접 판매 + 조건 위반 전매**라는 사안 변형에서 '조건부 판매로 소진을 배제할 수 있는가'라는 논점을 포착했는가.
- (4)에서 丁의 행위를 i) 전용품 제작·납품(간접침해 성부)과 ii) 검수 시연 실시(별도 직접침해 성부)로 나누어 파악했는가.
- 감점: 발문에 없는 쟁점(무효항변, 권리남용 등) 나열, (4)에서 검수 시연 행위 누락.

2) 목차·구성(약 7점)

- (1)은 '의의 → 이론적 근거 → 방법발명 소진 인정 여부 → 성립요건 → 사안 포섭' 흐름으로 체계화했는가.
- (2)(3)은 배점 6점에 맞추어 '문제 소재 → 비교법·판례 → 검토 → 사안' 순으로 간결하게 처리했는가(과도한 일반론 배제).
- (4)는 배점 10점에 상응하여 간접침해 법리와 2017다290095 논거를 충실히 전개했는가.
- 감점: 조문·판례 전사식 나열, 각 물음이 독립적임에도 앞 설문 결론에 기대어 논증 생략.

3) 답안 작성·논증(약 11점)

- 조문(§ 2(3), § 94, § 127(2)) → 판례(2017다289903, 2017다290095, 2018도14446, 2014다42110) → 사안 포섭 → 결론 순의 일관된 논증.
- (1)에서 용접기가 '방법발명을 실질적으로 구현한 물건'임을 판단기준 3요소에 대입하여 포섭했는가(기준만 나열하고 포섭 없으면 감점).
- (2)에서 국제소진에 관한 대법원 판례가 확립되어 있지 않음을 밝히면서도 이종이득 금지 근거로 자기 결론을 논증했는가.
- (3)에서 소진 긍정 결론과 함께 甲·乙 사이의 계약위반 책임(채권적 구제)을 부기했는가(가점 요소).
- (4)에서 간접침해 부정의 실질적 이유(실시료 책정 단계에서 특허권 가치 회수 가능)를 자기 언어로 설명했는가.
- 감점: 결론 애매모호, 판례 문구만 인용하고 사안 포섭 없음, 설문 간 결론 모순.

감점 주의

- (1)에서 소진을 물건발명에 한정된 법리로 서술하거나, 방법발명 소진 인정 여부 논의를 누락한 경우 → 큰 감점.
- '실질적 구현' 판단기준을 간접침해의 전용품 요건과 혼동한 경우.
- (2)에서 국제소진을 대법원 확립 법리인 것처럼 단정하거나, 반대로 숙지주의만을 이유로 논증 없이 침해를 단정한 경우.
- (3)에서 재판매 금지조건 위반을 곧바로 '적법하지 않은 양도'로 보아 소진을 부정한 경우(조건의 채권적 효력 법리에 반함) → 큰 감점.
- (4)에서 실시권자의 전용품 조달(제작 의뢰)을 재설시허락으로 오해하여 X의 실시권 범위 이탈로 구성한 경우.
- (4)에서 간접침해를 긍정하면서 그 근거로 제127조(2)의 문언만 드는 경우(2017다290095 법리 미포착).
- 검수 시연 실시를 독립한 직접침해로 결론 낸 경우.

2019년 제4문

사례형

20점

문제

이에 변리사 丙은 선행문헌의 검색에 의해 비교대상발명 1(첨부자료 3)에 비교대상발명 2(첨부자료 4)를 결합 또는 유기적 결합을 하는 경우, 위 특허권의 청구항 1이 진보성(특허법 제29조 제2항)이 없는 것으로 판단하고 이를 근거로 무효심판을 청구하고자 아래와 같이 『심판청구서』를 작성하였으나, 아직 ‘청구의 취지’와 ‘청구의 이유’의 일부를 작성하지 못하였다.

아래의 『심판청구서』 중 아직 작성하지 못한 다음 사항을 작성하시오.

(1) 청구의 취지 (3점)

(2) 청구의 이유 중에서”5. 무효사유의 판단“ (15점)

(3) 청구의 이유 중에서”6. 결론“ (2점)

심판청구서	
【청구인】	甲
【대리인】	丙
【배청구인】	乙
【사건의 표시】	
【심판의 종류】 무효심판	
【특허번호】 특허 제0012345호	
【청구의 취지】 별지와 같음	
【청구의 이유】 별지와 같음	
【증거방법】 별지와 같음	
위와 같이 특허심판원장에게 제출합니다.	
2019. 07. 28.	
청구인(대리인) 변리사 丙 (서명 또는 인)	
【별지내역】	
【청구의 취지】	
(작성)	
【청구의 이유】	
1. 특허 제0012345호의 개요	
특허 제0012345호(이하 “이건 특허”라 합니다.)는 갑 제1호증(등록특허공보) 및 갑 제2호증(특허등록원부)에 기재된 것과 같이 2017. 02. 01. 출원되었고, 2018. 10. 01. 특허등록되었습니다.	

2. 이진 특허의 제1항 발명의 권리범위

이진 특허의 청구항 1(이하 “제1항 발명”이라 합니다.)은 “본체부(10)와; 상기 본체부(10)의 측면에 회동부(22)로 결합되어 쇼핑백을 포함한 짐이 놓여지는 탑재부(20); 상기 본체부(10)에 설치되어 상기 탑재부(20)를 수납 상태로 고정하는 잠금부(40); 상기 탑재부(20)의 하부면에 형성된 두개의 바퀴(26);를 포함하는 것을 특징으로 하는 짐이식 여행용 캐리어”에 관한 것입니다.

3. 이해관계의 소명

심판청구인(甲)은 사업자등록증상 이진 특허의 제1항 발명과 같은 유형의 제품을 생산·판매하는 업체로서, 특허권자 乙로부터 생산·판매 금지를 요구하는 경고장을 받았으므로 당해 특허권의 존부에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있어 특허법 제133조 제1항의 규정에 의하여 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당합니다.

4. 무효증거

가. 비교대상발명 1(갑 제3호증)의 요지

본 발명은 물품을 수납하는 몸체(10)와, 상기 몸체(10)의 외면에 접철이 가능하도록 회동부(22)에 의해 결합되며 접철 시 상기 몸체(10)의 외면에 맞닿고 펼침 시 상기 몸체(10)의 외면에서 외측으로 연장 형성되는 탑재부(20), 및 상기 몸체(10)에 형성되어 상기 탑재부(20)의 접철 상태를 유지하는 잠금부(40)가 구비되어 있는 여행용 확장형 캐리어에 관한 것입니다.

나. 비교대상발명 2(갑 제4호증)의 요지

본 발명은 물품을 적재할 수 있는 적재부(20), 상기 적재부(20)의 모서리 하단 각각에 장착된 바퀴(50), 그리고 사용하지 않는 경우에는 카트의 상기 적재부(20) 방향으로 손잡이부(24)를 접을 수 있도록 구성된 회동부(23), 및 중심축(25)이 구비되어 있는 휴대용 짐이식 카트에 관한 것입니다.

5. 무효사유의 판단

(작성)

6. 결론

(작성)

【증거방법】

- [1] 갑 제1호증 : 특허 제0012345호의 등록특허공보
- [2] 갑 제2호증 : 특허 제0012345호의 특허등록원부
- [3] 갑 제3호증 : 비교대상발명 1(공개특허공보 10-2016-0000777호)
- [4] 갑 제4호증 : 비교대상발명 2(공개특허공보 10-2016-0000888호)

첨부자료 목록

- 첨부자료 1 : 특허 제0012345호의 등록특허공보
- 첨부자료 2 : 특허 제0012345호의 특허등록원부
- 첨부자료 3 : 비교대상발명 1(공개특허공보 10-2016-0000777호)
- 첨부자료 4 : 비교대상발명 2(공개특허공보 10-2016-0000888호)

작성요령

- 1. 제시된 자료만을 기초로 하고, 그것이 사실임을 전제로 할 것
- 2. 모든 절차 및 양식은 적법한 것으로 간주할 것
- 3. 서술어는 경어를 사용할 것

1 특허 제0012345호의 등록특허공보

(19) 대한민국특허청(KR)	(45) 공고일자 2018년10월10일
(12) 등록특허공보(B1)	(11) 등록번호 10-0012345
	(24) 등록일자 2018년10월01일
(51) 국제특허분류(Int. Cl.) H04N 7/173 (2011.01) G09G 5/00 (2006.01)	(71) 특허권자 乙 (72) 발명자 ○○○ (73) 대리인 丙
(21) 출원번호 : 10-2017-0000123	(25) 심사청구일자 : 2017년02월01일
(22) 출원일자 : 2017년02월01일	(43) 공개일자 : 2018년08월01일
(65) 공개번호 : 10-2018-0000321	
전체 청구항 수 : 총 3 항	
(54) 발명의 명칭 : 접이식 여행용 캐리어	
【명세서】	
【청구범위】	
【청구항 1】 본체부(10)와; 상기 본체부(10)의 측면에 회동부(22)로 결합되어 쇼핑백을 포함한 짐이 놓여지는 탑재부(20); 상기 본체부(10)에 설치되어 상기 탑재부(20)를 수납상태로 고정하는 잠금부(40); 상기 탑재부(20)의 하부면에 형성된 두개의 바퀴(26);를 포함하는 것을 특징으로 하는 접이식 여행용 캐리어	
【청구항 2】 본체부(10)와; 상기 본체부(10)의 측면에 회동부(22)로 결합되어 쇼핑백을 포함한 짐이 놓여지는 탑재부(20); 상기 탑재부(20)와 수직 또는 수평으로 위치할 수 있도록 상기 탑재부(20)의 일단부에 회동결합부(32)에 의하여 결합되는 벽체부(30); 및 상기 본체부(10)에 설치되어 상기 탑재부(20)와 상기 벽체부(30)를 수납상태로 고정하는 잠금부(40);를 포함하는 것을 특징으로 하는 접이식 여행용 캐리어	

【청구항 3】

제2항에 있어서, 상기 탑재부(20)의 하부면에 복수개의 바퀴(26)가 구비된 것을 특징으로 하는 접이식 여행용 캐리어

【발명의 설명】

【기술분야】

본 발명은 여행용 캐리어에 관한 것으로, 특히 캐리어 본체의 측면에 접이식 짐칸을 더 구비하여 가방이나 쇼핑백과 같은 짐들을 올려두고 캐리어와 함께 끌고 다닐 수 있도록 한 접이식 여행용 캐리어에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

일반적으로, 여행용 캐리어는 여행에 필요한 각종 짐을 하나의 공간에 수납하는 데에 이용하는 가방의 하나로서, 여행용 캐리어의 손잡이를 인출하고 본체를 비스듬하게 늘려 손잡이를 잡고 끌게 되면, 바퀴의 회전에 의해 상기 캐리어 내의 짐의 양이 많더라도 이동에 따른 불편함이 없어 많이 이용되고 있다.

하지만, 상기 여행용 캐리어에 수납하는 내용물의 부피와 무게를 항공사의 규정 한도에 맞추다보면, 상기 캐리어에 담지 못한 내용물들을 따로 보조가방에 챙겨서 운반하여야 하므로 상기 보조가방의 휴대가 불편한 문제점이 있다.

【선행기술문헌】

(특허문헌) 공개특허공보 10-2015-0003355호(공개일 : 2015년02월01일)

【발명의 내용】

【해결하려는 과제】

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해소하기 위하여 안출된 것으로서, 캐리어 본체의 측면에 접이식 짐칸을 더 구비하여 가방이나 쇼핑백과 같은 짐들을 올려두고 캐리어와 함께 끌고 다닐 수 있도록 한 접이식 여행용 캐리어를 제공하는 데에 그 목적이 있다.

【과제의 해결수단】

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 일 실시예는 본체부와, 상기 본체부의 측면에 회동부로 결합되어 쇼핑백을 포함한 짐이 놓여지는 탑재부, 상기 본체부에 설치되어 상기 탑재부를 수납상태로 고정하는 잠금부, 및 상기 탑재부의 하부면에 형성된 두개의 바퀴를 포함한다.

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 다른 실시예는 본체부와, 상기 본체부의 측면에 회동부로 결합되어 쇼핑백을 포함한 짐이 놓여지는 탑재부, 상기 탑재부와 수리 또는 수평으로 위치할 수 있도록 상기 탑재부의 일단부에 회동결합부에 의하여 결합되는 벽체부, 및 상기 본체부에 설치되어 상기 탑재부와 상기 벽체부를 수납상태로 고정하는 잠금부를 포함한다.

【발명의 효과】

이상과 같이 본 발명은 적어도 다음의 효과를 포함한다.

첫째, 상기 여행용 캐리어 내의 수납공간이 부족한 경우 상기 탑재부를 수평방향으로 펼쳐서 상기 쇼핑백을 포함한 짐을 올려놓고 운반함으로써 상기 짐의 운반 및 휴대에 따른 편리성이 향상된다.

둘째, 상기 탑재부의 하부면에 복수개의 바퀴를 구비함으로써, 상기 캐리어를 운반함에 있어 손목의 피로감을 줄임과 동시에 상기 캐리어의 동선을 부드럽게 제어할 수 있어 편리성이 향상된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명에 따른 여행용 캐리어의 접힘상태를 도시한 사시도

도 2는 본 발명에 따른 여행용 캐리어의 펼침상태를 도시한 사시도

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하 본 발명에 따른 실시예 1 및 실시예 2를 설명한다.

【실시예 1】

실시예 1에 따른 여행용 캐리어(1)는 본체부(10)와, 상기 본체부(10)의 측면에 회동부(22)로 결합되는 탑재부(20), 및 상기 본체부(10)에 형성되어 상기 탑재부(20)를 수납상태로 고정하는 잠금부(40)를 포함한다.

상기 본체부(10)는 상기 여행용 캐리어(1)의 전체하중을 지지할은 물론 외관을 이루는 것으로써, 상기 여행에 필요한 짐을 수용하는 수용함(16)과, 상기 수용함(16)의 측면에 형성되어 상기 탑재부(20)를 수용하는 오목홈(12), 및 상기 수용함(16)의 하부면에 구비된 복수개의 본체바퀴(14)를 포함한다.

상기 탑재부(20)는 상기 본체부(10)의 측면에 회동부(22)를 통해 결합되어 상기 수용함(16)에 수납되지 못한 여분의 짐이 놓여지고, 상기 오목홈(12)에 수용되어 회동부(22)를 따라 펼쳐지거나 접혀지는 탑재판(24)을 포함하고, 상기 탑재부(20)의 하부면에는 복수개의 바퀴(26)가 구비된다.

상기 잠금부(40)는 상기 수용함(16)의 측면에 형성되어 상기 오목홈(12)에 수용되는 상기 탑재부(20)를 고정하는 기능을 수행한다.

이하, 본 발명에 따른 작용을 실시예 1을 참고로 설명한다.

상기 여행용 캐리어(1)의 상기 수용함(16)에 수납할 짐이 많아 보조가방이 필요한 경우, 상기 잠금부(40)의 걸림을 해제한 후 도 2에서와 같이 상기 탑재부(20)를 반시계방향으로 회전하여 지면에 위치시킨다.

이때 상기 탑재부(20)가 지면에 펼쳐지는 경우, 상기 본체부(10)의 본체바퀴(14)와 상기 탑재부(20)의 바퀴(26)가 동일선상에 위치하므로, 상기 본체부(10) 및 상기 탑재부(20)를 한꺼번에 이동시킬 수 있는 것이다.

상기 탑재부(20)가 더 이상 필요 없는 경우, 상기 탑재판(24)을 회동하여 상기 오목홈(12)에 맞춘 후, 상기 잠금부(40)를 잠금하여 상기 탑재판(24)을 고정하면, 상기 여행용 캐리어(1)의 부피가 최소화된다.

【실시예 2】

실시예 2에 따른 여행용 캐리어(1)는 본체부(10)와, 상기 본체부(10)의 측면에 회동부(22)로 결합되는 탑재부(20), 및 상기 탑재부(20)와 수리 또는 수평으로 위치할 수 있도록 상기 탑재부(20)의 일단부에 회동결합부(32)로 결합되는 벽체부(30), 상기 탑재부(20)에 짐을 올려놓지 않는 경우에는 상기 벽체부(30)를 상기 탑재부(20)와 수평으로 접어서 일체형으로 상기 본체부(10)에 수납상태로 고정하는 잠금부(40)를 포함한다. 또한 상기 탑재부(20)의 하부면에는 복수개의 바퀴(26)가 구비된다.

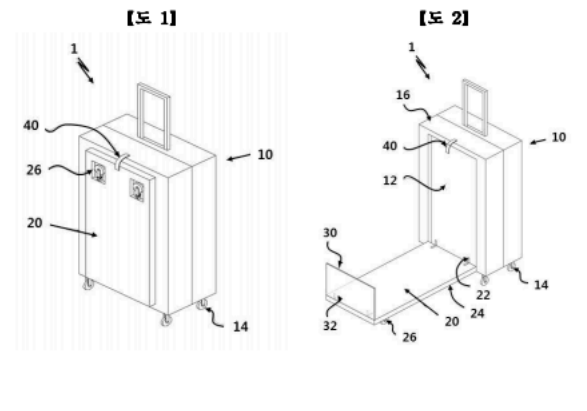
상기 여행용 캐리어(1)의 상기 본체부(10)와, 상기 탑재부(20), 상기 바퀴(26) 및 상기 잠금부(40)는 실시예 1과 기술사상이 동일하므로 자세한 설명은 생략하고, 이하에서는 상기 벽체부(30)에 한정하여 설명하기로 한다.

상기 벽체부(30)는 상기 탑재부(20)의 일단부에 일체형으로 결합되어 회동결합부(32)를 따라 상기 탑재부(20)와 수직으로 펼쳐지거나 수평으로 접혀지는 것으로서, 상기 탑재판(24)에 놓여진 짐이 외부하중에 의해 주변으로 낙하하는 것을 방지하는 기능을 수행한다.

【부호의 설명】

1 : 여행용 캐리어	10 : 본체부	12 : 오목홈
14 : 본체바퀴	16 : 수용함	20 : 탑재부
22 : 외동부	24 : 탑재판	26 : 바퀴
30 : 벽체부	32 : 회동결합부	40 : 잠금부

【도면】



2 특허 제0012345호의 특허등록원부

특허등록원부		
특허번호	제 0012345 호	
권리란		
표시번호	등록사항	
1번	출원연월일	2017년 02월 01일
	출원번호	2017-0000123
	공고연월일	2018년 10월 10일
	특허결정연월일	2018년 09월 10일
	청구범위의 항수	3
	분류기호	H04N 7/173 (2011.01) G09G 5/00 (2006.01)
	발명의 명칭	접이식 여행용 캐리어
	존속기간(예정)만료일	2037년 02월 01일
	2018년 10월 01일 등록	
특허료란		
제01-03년분 (2018. 10. 01.~2021. 10. 01.) 금액 250,000원 2018년 10월 01일 납입		
특허권자란		
	(최종권리자) 乙	
순위번호	등록사항	
1번	(등록권리자) 乙	
2018년 10월 1일 등록		
이하여백		

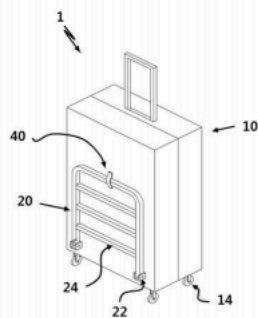
3 비교대상발명 1(공개특허공보 10-2016-0000777호)

(19) 대한민국특허청(KR)	(11) 공개번호 10-2016-0000777
(12) 공개특허공보(A)	(43) 공개일자 2016년07월05일
(51) 국제특허분류(Int. Cl.) H04N 7/173 (2011.01)	(71) 출원인 ○○○
(21) 출원번호 10-2015-0000333	(72) 발명자 ○○○
(22) 출원일자 2015년01월05일	(74) 대리인 ○○○
심사청구일자 없음	
전체 청구항 수 : 총 5 항	
(54) 발명의 명칭 : 여행용 확장형 캐리어	
(57) 요약	

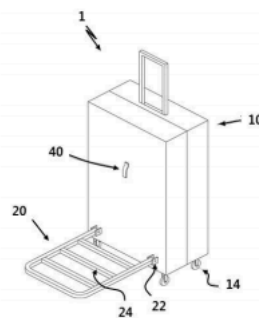
캐리어의 몸체 측면에 추가적인 배낭이나 소용 가방을 안정적으로 고정할 수 있는 것을 목적으로 하는 여행용 확장형 캐리어(1)에 관한 것이다. 상기 여행용 확장형 캐리어(1)는 물품을 수납하는 몸체(10)와, 상기 몸체(10)의 외면에 접착이 가능하도록 외동부(22)에 의해 결합되며 접합 시 상기 몸체(10)의 외면에 맞닿고 펼침 시 상기 몸체(10)의 외면에서 외측으로 연장 형성되는 탑재부(20), 및 상기 몸체(10)에 형성되어 상기 탑재부(20)의 접합 상태를 유지하는 잠금부(40)로 구성된다.

【도면】

【도 1】



【도 2】



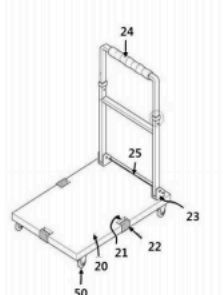
4 비교대상발명 2(공개특허공보 10-2016-0000888호)

(19) 대한민국특허청(KR)	(11) 공개번호 10-2016-0000888
(12) 공개특허공보(A)	(43) 공개일자 2016년08월05일
(51) 국제특허분류(Int. Cl.) G09G 5/00 (2006.01)	(71) 출원인 ○○○
(21) 출원번호 10-2015-0000222	(72) 발명자 ○○○
(22) 출원일자 2015년02월05일	(74) 대리인 ○○○
심사청구일자 없음	
전체 청구항 수 : 총 2 항	
(54) 발명의 명칭 : 휴대용 접이식 카트	
(57) 요약	

본 발명은 간단한 구조를 기반으로 하여 접어 휴대하면서 필요 시 펼쳐서 각종 물품을 편리하게 운반할 수 있는 휴대용 접이식 카트를 제공한다. 상기 접이식 카트에는 물품을 적재할 수 있는 적재부(20), 상기 적재부(20)의 모서리 하단 각각에 장착된 바퀴(50), 그리고 사용하지 않는 경우에는 카트의 적재부(20) 방향으로 손잡이부(24)를 접을 수 있도록 구성된 외동부(23), 및 중심축(25)이 구비되어 있다.

【도면】

【도 1】



문제 4 모범답안

I. 설문 (1) — 청구의 취지

이 사건 특허의 청구항은 3항이 있으나 청구인 甲이 무효를 구하는 대상은 청구항 1에 한정되므로, 청구의 취지에는 **무효 대상을 청구항 1로 특정**하여 기재하여야 한다. 아울러 심판비용을 피청구인이 부담한다는 심결을 청구하는 것이 타당하다. 구체적인 작성에는 다음과 같다.

-작성예-

"1. 특허 제0012345호 발명의 청구범위 청구항 1은 이를 무효로 한다. 2. 심판비용은 피청구인의 부담으로 한다. "

라는 심결을 구합니다.

II. 설문 (2) — 5. 무효사유의 판단

진보성 판단은 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 주선행발명을 선택한 다음 이와 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준에 비추어 그 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다(2015후2341). 사안에서는 비교대상발명 1이 주선행발명임을 전제로 작성하며, 작성에는 다음과 같다.

-작성예-

1. 이견 특허 청구항 1과 비교대상발명 1과의 대비 — 공통점과 차이점

이견 특허 제1항 발명과 비교대상발명 1을 구성요소별로 대비하면, 구성요소 1의 본체부(10)는 비교대상발명 1의 물품을 수납하는 몸체(10)와 동일하고, 구성요소 3의 탑재부(20)를 수납상태로 고정하는 잠금부(40)는 비교대상발명 1의 탑재부(20)의 접힘 상태를 유지하는 잠금부(40)와, 구성요소 5의 접이식 여행용 캐리어는 비교대상발명 1의 탑재부 접철식 여행용 확장형 캐리어와 각각 실질적으로 동일합니다. 반면 구성요소 2는 측면에 회동부(22)로 결합되어 짐이 놓여지는 탑재부(20)인 데 비하여 비교대상발명 1의 탑재부(20)는 외면에 회동부(22)에 의하여 접철 가능하게 결합되어 배낭·소형 가방을 고정하는 것이고, 구성요소 4의 탑재부(20) 하부면에 형성된 두 개의 바퀴(26)는 비교대상발명 1에 대응하는 구성이 없습니다.

따라서 양 발명은 본체부(몸체)의 측면(외면)에 회동부로 접철 가능하게 결합되는 탑재부와 그 수납(접힘) 상태를 고정하는 잠금부를 구비한 접이식(확장형) 여행용 캐리어라는 점에서 구성요소 1, 3, 5가 동일하거나 실질적으로 동일하고, 다만 1) 탑재부(20)의 용도가 짐이 놓여지는 것(이견 특허)인지 배낭·소형 가방의 고정(비교대상발명 1)인지의 점(**구성요소 2**), 2) 탑재부(20) 하부면의 두 개의 바퀴(26) 유무의 점(**구성요소 4**)에서 차이가 있습니다.

2. 차이점에 대한 검토

(1) 구성요소 2의 검토 — 주지관용기술에 의한 변경의 용이성

위 차이점에 관하여 보전대, 접철 가능한 판재를 펼쳐 그 위에 짐을 올려놓아 지지·운반하는 구성은 운반기구 분야에서 널리 사용되어 온 주지관용기술에 지나지 아니합니다. 또한 비교대상발명 1의 탑재부 역시 펼친 판재 위에 배낭 등을 올려 두는 구조여서 짐을 고정하는 용도와 짐을 올려놓는 용도 사이에 기술적 의미의 차이도 크지 아니하므로, 통상의 기술자라면 주지관용기술에 의하여 비교대상발명 1의 탑재부를 짐이 놓여지는 형태로 쉽게 변경할 수 있습니다.

(2) 구성요소 4의 검토 — 비교대상발명 2와의 결합의 용이성

위 차이점에 해당하는 구성은 비교대상발명 2(갑 제4호증, 공개특허공보 10-2016-0000888호)에 그대로 개시되어 있습니다. 비교대상발명 2는 '휴대용 접이식 카트'로서, 물품을 적재할 수 있는 적재부(20)와 **상기 적재부(20)의 모서리 하단 각각에 장착된 바퀴(50)**, 그리고 손잡이부(24)를 적재부(20) 방향으로 접을 수 있는 회동부(23) 및 중심축(25)을 개시하고 있는바, 짐이 적재되는 판재의 하부면에 바퀴를 장착하여 적재된 짐의 하중을 지면에 분산시키고 짐을 굴러서 편리하게 운반하도록 하는 기술사상이 명확히 나타나 있습니다.

나아가 양 비교대상발명의 결합은 통상의 기술자에게 용이합니다.

첫째, **기술분야가 공통**됩니다. 비교대상발명 1은 여행용 캐리어, 비교대상발명 2는 휴대용 접이식 카트로서, 모두 짐을 적재하여 끌고 다니는 접이식 운반기구라는 동일·인접 기술분야에 속합니다.

둘째, **과제와 기능이 공통되어 결합의 동기가 있습니다.** 비교대상발명 1의 탑재부(20)와 비교대상발명 2의 적재부(20)는 모두 펼친 판재 위에 짐을 올려놓아 운반하는 동일 기능의 구성입니다. 그런데 비교대상발명 1과 같이 탑재부에 바퀴가 없으면 탑재부에 올려진 짐의 하중이 몸체와 사용자의 손목에 그대로 전가되므로, 짐의 하중을 지면으로 분산시켜 운반을 편리하게 하려는 것은 운반기구 분야의 자명한 과제이고, 비교대상발명 2는 바로 그 해결수단으로 적재부 하단의 바퀴(50)를 제시하고 있습니다. 따라서 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 탑재부(20) 하부면에 비교대상발명 2의 바퀴 구성을 적용할 동기 내지 암시가 선행문헌 자체에 존재합니다.

셋째, **결합에 기술적 곤란성이 없습니다.** 비교대상발명 1의 탑재부(20) 하부면에 바퀴를 부착하는 것은 주지·관용 수단의 단순 부가에 불과하고, 탑재부의 접철 기능이나 잠금부의 고정 기능이 저해되는 등 결합을 방해하는 사정도 없습니다. 바퀴의 개수를 비교대상발명 2의 모서리 4개에서 두 개로 한 것 역시 탑재부가 일단부에서 몸체와 회동 결합되어 있는 구조를 고려한 단순한 설계변경 사항에 지나지 않습니다.

넷째, **작용효과도 예측 가능한 정도에 불과합니다.** 이견 특허 제1항 발명의 효과, 즉 탑재부를 펼쳐 쇼핑백 등 짐을 올려놓고 운반함으로써 수납공간 부족을 해소하는 효과는 비교대상발명 1로부터, 탑재부 하부면의 바퀴에 의하여 손목의 피로감을 줄이고 캐리어의 동선을 부드럽게 제어하는 효과는 비교대상발명 2의 바퀴 구성으로부터 각각 당연히 예상되는 것으로서, 예측되는 효과의 단순한 합계를 넘는 현저한 효과라고 볼 수 없습니다.

3. 결론

비교대상발명 1(공개일 2016. 07. 05.)과 비교대상발명 2(공개일 2016. 08. 05.)는 모두 이 사건 특허의 출원일(2017. 02. 01.) 전에 반포된 공개특허공보에 게재된 발명이므로 제29조 제1항 제2호의 선행기술에 해당합니다. 그리고 이 사건 특허 제1항 발명은 위에서 본 바와 같이 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 탑재부를 주지관용기술에 의하여 쉽게 변경하고 여기에 비교대상발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 제29조 제2항에 위반하여 진보성이 부정되고, 이는 제133조 제1항 제1호의 무효사유에 해당합니다.

Ⅲ. 설문 (3) — 6. 결론

이 사건 특허의 청구항 1은 비교대상발명 1에 비교대상발명 2를 결합하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 위반하여 등록된 것이라는 취지로 결론을 도출한다. 구체적인 작성에는 다음과 같다.

-작성예-

"이상에서 살핀 바와 같이 이 사건 특허의 청구항 1은 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 비교대상발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 특허법 제29조 제2항에 위반하여 특허된 것이므로, 같은 법 제133조 제1항 제1호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 합니다. 따라서 청구의 취지와 같은 심결을 내려 주십시오."

채점기준

핵심 쟁점과 배점

구분	핵심 쟁점	배점
설문 (1)	무효심판 청구의 취지 표준 작성례(무효 대상 청구항 1의 특정 + 심판비용 부담 + '라는 심결을 구합니다')	3
설문 (2)-가	청구항 1의 구성요소 분설(본체부·탐재부·잠금부·두 개의 바퀴·접이식 여행용 캐리어)	3
설문 (2)-나	비교대상발명 1과의 대비 — 대응 구성(공통점)과 차이점(탐재부 하부면의 바퀴(26))의 특정	4
설문 (2)-다	차이점 검토 — 비교대상발명 2의 개시, 기술분야·과제 공통성, 결합의 동기·용이성, 효과의 예측가능성	6
설문 (2)-라	소결 — 선행기술 적격(출원 전 공개) + 제29조 제2항 진보성 부정 + 제133조 제1항(1) 무효사유	2
설문 (3)	결론 — 제29조 제2항 위반 → 제133조 제1항(1) 무효의 청구서식 결론	2
합계		20

축별 채점 기준

1) 논점 추출(약 8점)

- 이 문제의 본질이 '진보성 부정형 무효심판 청구서의 핵심부(무효사유의 판단) 작성'임을 파악하고, 진보성 판단의 표준 논증 구조(구성 분설 → 주 선행발명과 대비 → 차이점의 극복 용이성 → 소결)를 논점으로 세웠는가 (4점)
- 차이점이 오직 '탐재부(20) 하부면에 형성된 두 개의 바퀴(26)' 하나임을 정확히 추출했는가 — 비교대상발명 1이 본체부·탐재부·회동부·잠금부를 모두 개시하고 있음을 놓치면 대비 전체가 부정확해짐 (2점)
- 비교대상발명 1·2의 공개일(2016. 07. 05. / 2016. 08. 05.)이 이 사건 특허 출원일(2017. 02. 01.) 전이라는 선행기술 적격, 그리고 제29조 제2항 → 제133조 제1항(1)의 조문 연결을 짚었는가 (2점)

2) 목차·구성(약 5점)

- 청구서 별지의 기존 목차(1~4번 항목)에 이어지는 '5. 무효사유의 판단', '6. 결론'의 형식을 지키고, 5. 내부를 가.(분설) 나.(대비) 다.(차이점 검토) 라.(소결)로 단계화했는가 (3점)
- 청구의 취지를 별지 서두 위치에 맞는 독립 문장으로 작성하고, 결론이 5.의 판단을 받아 무효 심결을 구하는 형태로 수미일관하는가 (2점)

3) 답안 작성·논증(약 7점)

- 대비가 구성요소 단위로 이루어지고(대비표 또는 구성별 서술), 각 대응 관계에 도면부호·증거번호(갑 제3호증, 갑 제4호증)를 붙여 사실적 기초를 명확히 했는가 (3점)
- 결합의 동기(양 발명이 짐을 펼친 판재 위에 올려 운반하는 공통 기능, 바퀴 부가로 운반 부담을 줄이려는 자명한 요구)를 선행문헌의 기재로부터 도출하고, 사후적 고찰이 아닌 형태로 서술했는가 (2점)
- 효과(운반 편의·손목 피로 경감·동선 제어)가 결합으로부터 예측 가능한 정도임과 바퀴 개수(2개 vs 4개)가 단순 설계변경임을 처리했는가, 문체가 심판청구서 실무 문체('~합니다')인가 (2점)

감점 주의

- 청구의 취지에서 심판비용 부담 문구 또는 '라는 심결을 구합니다'를 누락하거나, 무효 대상을 '청구항 1'로 특정하지 않고 특허 전체(청구항 3개 전부) 무효로 기재한 경우
- 구성요소 분설 없이 곧바로 '진보성이 부정된다'는 결론으로 직행한 경우(논증 구조 점수 대폭 감점)
- 차이점을 잘못 특정한 경우 — 예: 탐재부·잠금부까지 차이점으로 잡거나, 바퀴가 비교대상발명 1에 있는 것으로 기재(비교대상발명 1의 본체바퀴류 구성과 혼동)
- 비교대상발명 2의 개시 사실만 적시하고 결합의 동기·기술분야 공통성·기술적 곤란성 부존재 논증을 누락한 경우(설문 (2)의 최대 배점 축)
- '이 사건 특허를 알고 보면 결합이 당연하다'는 식의 사후적 고찰 서술 — 결합의 근거를 선행문헌 자체의 기재(과제·기능)에서 끌어내지 않은 경우
- 선행기술 적격(공개일이 출원일 전) 확인이나 제29조 제2항·제133조 제1항(1) 조문 인용을 누락한 경우
- 청구서에 그대로 옮길 수 없는 학술체·강평체로 작성한 경우(작성요령 위반), 또는 제시 자료에 없는 구성·기술내용을 지어낸 경우

PART 11

2020

제1문	乙의 무단 통상실시권 허락의 효력(제99조 제4항) · 丙의 무효심판 청구인 적격과 청구 가능성	30점
제2문	우선권주장 출원인의 동일성 요건(제55조 제1항) · 제38조 제4항(출원인변경신고)의 우선권 절차 적용 여부	20점
제3문	乙의 무권리자(모인)출원에 대한 甲의 조치 · 戊(전용실시권자)의 甲·丙에 대한 조치	30점
제4문	공동발명자의 단독출원 가부 (제33조 제2항, 제44조) · 공동출원의 심사청구 주체 (제59조)	20점

2020년 제1문

사례형

30점

문제

甲과 乙은 "인체의 생리 정보 및 환경 정보를 검출하는 장치"인 사물인터넷(IoT)에 관한 특허발명 A를 공동으로 발명하여 2020. 3. 20. 특허등록을 받은 특허권자이다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 乙은 2020. 5. 20. 甲의 동의 없이 丙과 통상실시권허락계약을 체결하였다. 丙은 乙에게 통상실시료를 지불하고 특허발명 A를 제조하여 판매하던 중 특허발명 A가 신규성이 없음을 발견하고 2020. 7. 10. 특허심판원에 무효심판을 청구하였다. 丙의 특허무효심판청구에 대한 특허심판원의 심결과 관련하여 甲, 乙 및 丙의 상호 법적 조치에 대하여 설명하시오. (14점)

(2) 丁은 국내에서 특허발명 A의 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품을 생산하고 있다. 이들 반제품은 중국으로 수출되어 중국에서 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예상되고 있다. 특허권자 甲은 丁의 실시가 특허발명 A의 보호범위에 포함된다고 주장하면서 丁을 상대로 특허침해소송을 제기하려고 한다. 丁의 행위가 甲의 특허권 보호범위에 속하는지 여부를 설명하고, 丁이 특허법 제130조(과실의 추정)상 과실이 없다고 하기 위하여 입증해야 하는 사항에 대하여 설명하시오. (8점)

(3) 甲과 乙은 특허발명 A의 청구범위를 실질적으로 변경하지 않는다고 판단하는 범위 내에서 청구범위를 정정한 후 정정심판을 청구하였다. 특허심판원은 甲과 乙의 정정청구가 명백한 기각사유에 해당한다고 판단하여 甲과 乙에게 의견서 제출기회 없이 정정기각심결을 하였다. 이에 대하여 공유 특허권자로서 甲과 乙이 취할 수 있는 모든 대응조치에 대하여 설명하시오. (8점)

모범답안

I. 설문 (1) — 丙의 무효심판청구 심결과 관련한 甲·乙·丙의 법적 조치

1. 문제의 소재

乙이 甲의 동의 없이 丙에게 허락한 통상실시권의 효력(§ 99④), 丙의 무효심판 청구인격적(§ 133), 심결(인용·기각)에 대한 심결취소소송에서 공유자의 원고격적과 丙의 피고 지정(§ 186·§ 187), 심결확정 후 丙의 실시료 반환 청구 가부 및 甲의 조치가 문제된다.

2. 乙의 통상실시권 허락의 효력

특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 통상실시권을 허락할 수 있다(§ 99④). 이는 실시권자의 자본력·기술력에 따라 다른 공유자의 이해관계에 미치는 영향이 지대함을 고려한 강행규정이다. 乙은 甲의 동의 없이 통상실시권을 허락하였으므로 그 허락계약은 효력이 없고, 丙은 甲과의 관계에서 무단 실시자에 해당한다.

3. 丙의 무효심판 청구

실시권 허락계약이 무효라 하더라도 丙은 특허발명을 실시하는 자로서 특허권의 존부에 직접적인 이해관계를 가지므로 이해관계인(§ 133①)에 해당하고, 신규성 흠결(§ 29①)은 제133조 제1항 제1호의 무효사유이므로 丙의 무효심판청구는 적법하다.

4. 심결에 대한 불복 — 심결취소소송

(1) 인용심결 — 공유자 중 1인의 소재지 가능

甲·乙은 심결등본 송달일부터 30일 이내에 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있다(§ 186①3)). 심판은 공유자 전원이 공동으로 청구·피청구되어야 하는 고유필수적 공동심판이나(§ 139②3)), 판례는 심결취소소송에 관하여 1) 심결을 취소하는 판결이 확정되면 그 효력이 다른 공유자에게도 미치고 기각 판결의 확정은 불복하지 않은 공유자의 권리에 영향이 없어 합일확정의 요청에 반하지 않는 점, 2) 전원의 공동 제소를 요구하면 1인의 비협력만으로 나머지 공유자의 권리행사에 장애가 생기는 점을 들어 공유자 중 1인의 단독 소제기를 허용한다(대법원 2002후567). 한편 甲·乙은 전원이 공동으로(§ 139③) 청구범위를 감축하는 정정심판(§ 136)을 청구하여 무효사유를 해소하는 방법으로도 대응할 수 있으나, 판례는 심결취소소송의 사실심 변론종결 후 정정 인용심결이 확정되더라도 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유에 해당하지 않는다고 하므로(대법원 2016후2522 전원합의제), 정정에 의한 대응은 사실심 변론종결 전에 하여야 한다.

(2) 기각심결 — 丙은 공유자 모두를 피고로 소재지

기각심결에 대하여는 丙이 30일 이내에 상대방 당사자인 특허권자를 피고로 심결취소소송을 제기할 수 있다(§ 187단서). 심결취소소송의 피고 측은 공유자 모두를 피고로 하여야 하는 고유필수적 공동소송이므로, 丙은 甲·乙 모두를 공동피고로 하여야 한다.

5. 심결확정에 따른 대응조치

(1) 丙의 실시료 반환 청구

판례는 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허무효가 확정되더라도 계약이 유효하게 존재한 기간에 상응하는 기지급 실시료의 반환의무를 부정한다(대법원 2012다42666). 그러나 사안의 실시계약은 제99조 제4항 위반으로 처음부터 효력이 없어 체결 당시부터 원시적으로 이행불능이므로 위 법리는 적용되지 않는다. 따라서 丙은 이미 지급한 실시료를 乙에게 부당이득으로 반환 청구할 수 있고, 이는 계약 자체의 무효에 근거하므로 인용·기각심결의 확정을 불문하고 같다.

(2) 기각심결 확정 시 甲의 조치

기각심결이 확정되면 특허권은 유지된다(동일사실·동일증거에 의한 재청구 금지, § 163). 甲은 무단 실시자 丙에 대하여 권리를 행사할 수 있다. 침해금지 청구는 공유물의 보존행위에 해당하므로 甲은 乙과 공동하지 아니하고도 자기 지분에 기하여 단독으로 특허권 전체에 대한 침해금지를 청구할 수 있고 (§ 126, 대법원 98다41216), 손해배상청구권은 가분채권이므로 甲은 자기의 지분 비율에 따른 손해액의 배상을 청구할 수 있다 (§ 128, 과실은 § 130으로 추정). 乙에 대하여는 제99조 제4항 위반을 제재하는 규정이 없으나, 판례가 특허권의 공유에도 민법상 공유물분할청구 규정의 적용을 긍정하므로(대법원 2013다41578, 현물분할은 불가하고 대금분할·가액배상에 의함) 甲은 분할청구로 공유관계를 해소할 수 있다.

6. 결론

인용심결에는 甲·乙이 각자 단독 제조 및 전권 공동의 정정심판으로, 기각심결에는 丙이 甲·乙 모두를 피고로 한 제조로 대응한다. 丙은 원시적으로 무효인 실시계약에 기하여 지급한 실시료의 반환을 심결 결과와 무관하게 청구할 수 있고, 기각 확정 시 甲은 丙에게 침해책임을 묻는 한편 乙과는 공유물분할 청구로 공유관계를 해소할 수 있다.

II. 설문 (2) — 丁의 행위가 특허권 보호범위에 속하는지 여부 및 과실 부존재 입증사항

1. 丁의 행위가 甲의 특허권 보호범위에 속하는지 여부

(1) 문제의 소재

특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고 (§ 97), 속지주의 원칙상 실시행위는 국내에서 이루어져야 한다. 丁의 최종 가공·조립은 중국에서 예정되어 있으므로, 丁의 행위가 국내에서의 특허발명의 '생산'에 해당하는지와 간접침해 (§ 127 1호)의 해석이 문제된다.

(2) 법리

보호범위 판단은 구성요소완비의 원칙과 균등론에 따른다. 판례는 속지주의 원칙을 전제하면서도, 1) 국내에서 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 2) 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 예정되어 있으며, 3) 그 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여, 4) 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 실시제품이 생산된 것과 같이 본다(2019다222782). 한편 간접침해에서의 '생산'은 국내 생산에 한정되므로, 완제품이 국외에서 생산되는 이상 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해는 성립하지 않는다(2014다42110).

(3) 사안의 포섭

① (작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이른 경우) 위 요건을 갖춘 경우 丁의 반제품 생산·수출은 특허발명의 '생산'에 해당하여 甲의 특허권 보호범위에 속한다.

② (그러한 상태에 이르지 못한 경우) 구성요소완비의 원칙상 보호범위에 속하지 않고, 완제품의 생산이 중국에서 일어나는 이상 간접침해도 성립하지 않는다. 다만 개정법(2025. 1. 21. 개정)이 생산에만 사용하는 물건(전용품)의 '수출'을 침해 간주 행위로 추가함에 따라 이러한 반제품 수출에 간접침해가 성립하는지는 해석의 논란이 있다.

2. 제130조 과실추정을 벗어나기 위한 입증사항

(1) 법규정 및 판례

제130조는 침해자의 과실을 추정하며, 이는 특허공보 등에 의한 공시에 근거한다. 판례에 따르면 추정을 벗어나려면 침해자는 1) 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점 또는 2) 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿었던 점을 정당화할 수 있는 사정을 주장·증명하여야 하고, 침해품이 별도의 산업재산권으로 등록되어 있다는 사정만으로는 부족하다(2003다15006, 2007다65245).

(2) 사안의 포섭

丁은 특허공보 확인·선행기술 조사 등 통상의 주의를 다하였음에도 특허발명 A의 존재를 알기 어려웠던 사정, 또는 변리사의 감정 등을 통해 반제품이 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 데 정당한 사유가 있었다는 사정을 구체적으로 증명하여야 하며, 단순한 부지나 믿음의 주장만으로는 부족하다.

3. 결론

반제품이 작용효과를 구현할 수 있는 상태라면 丁의 행위는 '생산'에 해당하여 보호범위에 속하나, 그렇지 않다면 보호범위에 속하지 아니하고 간접침해도 성립하지 아니한다. 보호범위에 속하는 경우 丁은 위 정당화 사정을 구체적으로 주장·증명하여야 과실추정을 벗어날 수 있다.

Ⅲ. 설문 (3) — 甲·乙의 정정기각심결에 대한 대응조치

1. 문제의 소재

공유특허권자 甲·乙이 공동으로 청구한 정정심판(§ 136)에서 의견서 제출기회 없이 정정기각심결이 내려진 것이 적법한지와 그에 대한 불복수단이 문제된다.

2. 정정기각심결의 위법성

(1) 법 규정 및 관련법리

명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장·변경할 수 없고(§ 136①·④), 공유특허권의 경우 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다(§ 139③). 한편 제136조 제6항은 심판관이 정정심판 청구가 정정요건에 위반된다고 판단할 경우 청구인에게 그 이유를 통지하고 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다고 규정하는데, 판례는 이를 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지한다는 공익상의 요구에 기인하는 강행규정으로 보아, 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판청구를 기각하는 심결은 위법하다고 한다(대법원 2006후2660, 2018후12004).

(2) 사안의 포섭

甲·乙은 공유자 전원이 공동으로 청구하여 청구요건을 갖추었다. 그럼에도 특허심판원은 의견서 제출기회를 부여하지 않은 채 기각심결을 하였는바, '명백한 기각사유'에 해당한다는 이유만으로 강행규정인 제136조 제6항의 절차를 생략할 수 없으므로, 위 심결은 절차상 위법하여 심결취소사유가 된다.

3. 대응조치

(1) 심결취소소송의 제기(§186)

甲·乙은 심결등본 송달일부터 30일 이내에 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있고, 공유자 중 1인이 단독으로도 제기할 수 있으므로(대법원 2002후567) 공동으로 또는 각자 단독으로 제소할 수 있다. 소송에서는 1) 청구범위의 실질적 변경이 없어 정정요건을 갖추었다는 실체상 위법과 2) 의견서 제출 기회 미부여의 절차상 위법(§ 136⑥)을 취소사유로 주장할 수 있다.

(2) 정정심판의 재청구 등

사유·정정사항을 달리하여 정정심판을 다시 청구할 수 있고, 특허발명 A에 관하여 무효심판이 계속 중이라면 그 절차 내에서 정정청구(§ 133의2)를 활용할 수 있다.

4. 결론

甲·乙은 30일 이내에 공동으로 또는 각자 단독으로 심결취소소송을 제기하여 절차상·실체상 위법을 주장할 수 있고, 필요시 정정심판 재청구 또는 무효심판 절차 내 정정청구로 대응할 수 있다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	득점 포인트
(1) 乙의 무단 통상실시권 허락의 효력(제99조 제4항)	3	공유특허권자는 다른 공유자의 동의 없이 실시권을 허락할 수 없음, 위반 시 제3자에 대한 실시권 설정행위는 무효, 다만 공유자 상호간에는 특허법상 직접 제재수단 없음
(1) 丙의 무효심판 청구인 적격과 청구 가능성	2	이해관계인(제133조 제1항), 신규성 흠결(제29조 제1항)의 무효사유
(1) 심결취소소송의 소송수행	5	인용 시 공유자 중 1인의 단독 제소 가능(2002후567 — 취소판결 효력 확산·권리행사 장애 방지) + 甲·乙 전원 공동의 정정심판 대응(\$139③), 사실심 변론종결 후 정정 인용심결 확정은 민소\$451①(8) 재심사유 아님 — 2016후2522 전합), 기각 시 丙이 공유자 모두를 피고로 하는 고유필수적 공동소송(\$187단서), 30일 제소기간
(1) 심결확정 후 조치 — 실시로 반환·권리행사·공유관계 해소	4	丙의 실시로 반환 청구 가능 — \$99④ 위반으로 계약이 원시적 이행불능(2012다42666이 반환의무를 부정하는 '별도 무효사유 없는 경우'의 예외)이므로 인용·기각 확정 불문 동일, 기각 확정 시 甲의 丙에 대한 권리행사(침해금지=보존행위로 지분에 기해 전체에 단독 청구 98다41216 / 손해=가분채권이라 지분 비율 한도), 乙에 대해서는 \$99④ 위반 제재 규정이 없어 공유물분할청구(2013다41578, 대급분할·가격배상)로 공유관계 해소
(2) 丁의 반제품 생산이 특허권 침해에 해당하는지(제2조 제3호, 제94조, 제97조)	4	침해 성립요건 일반론(보호범위=구성요소완비·균등론, 업으로서의 실시·정당한 권원 없음, 속지주의) → 반제품 사건 4요건 (주요 구성 완비 반제품 국내 생산·단일 주체 수출과 최종 조립 예정·조립이 극히 사소·작용효과 구현 상태) 충족 시 국내 생산으로 보아 직접침해(대법원 2019다222782) / 불충족 시 구성요소완비 원칙상 직접침해 부정 + 완제품 생산이 국외여서 간접침해도 부정('생산'=국내 한정, 대법원 2014다42110) + 2025. 1. 21. 개정 \$127(1) 수출 추가에 따른 해석 논란 언급 → 경우 구분 소결
(2) 제130조 과실추정을 벗어나기 위한 입증사항(대법원 2007다65245)	4	① 특허권 존재를 몰랐던 점을 정당화할 사정, ② 자신의 실시가 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 사정
(3) 정정심판 청구요건과 의견제출기회 미부여의 절차 위법(제136조 제6항, 제139조 제3항)	4	공유자 전원 청구, 원칙적 의견서 제출기회 부여 의무, 미부여는 절차위법
(3) 심결취소소송(제186조)·재차 정정심판 청구·무효심판 계속 시 정정청구(제133조의2)의 대응	4	30일 내 특허법원 제소(공유자 1인의 단독 제소도 가능 — 2002후567), 절차위법을 취소사유로 주장

합계: 30점

특별 채점 기준

1) 논점 추출(약 40%)

- (1) '공유특허권자의 통상실시권 허락 제한(제99조 제4항)'과 '심판=고유필수적 공동심판 (§ 139②③) vs 심결취소소송=원고는 1인 가능·피고는 전원'의 구별을 잡아냈는지 확인.
- (2) 반제품 관련 판례(대법원 2019다222782)와 과실추정 판례(대법원 2007다65245)의 2단계 논점을 정확히 분리했는지.
- (3) '공유자 전원 청구' 요건(제139조 제3항)과 '의견제출기회 부여'(제136조 제6항)의 절차위법 문제를 함께 지적했는지.
- 감점: 발문이 '심결과 관련한 상호 법적 조치'를 물었는데 무효사유 판단에만 집중하거나, 반제품 침해 여부만 서술하고 과실 부존재 입증사항을 누락한 경우.

2) 목차·구성(약 25%)

- 설문 (1)(2)(3)을 명확히 구분하고, (1)은 배점이 크므로 상대적으로 넉넉한 분량 배분.
- 각 쟁점 내에서 '조문 → 판례·학설 → 사안 포섭 → 소결' 목차 구조 유지.
- 감점: 서론에 공유특허 일반론을 장황하게 나열, 정정심판 요건을 지나치게 상세히 서술하는 등 배점 불균형.

3) 답안 작성·논증(약 35%)

- 제99조 제4항, 제133조, 제136조, 제139조, 제186조 등 조문 정확 인용.
- 대법원 2019다222782(반제품 속지주의 예외 4요건), 대법원 2007다65245(과실추정)의 요지를 판시 문언에 충실하게 인용하고 사안에 포섭.
- (1)에서 인용/기각 각각의 소송수행 형태(원고 1인 가능 vs 공유자 전원 피고)와 심결확정 후의 조치를 시나리오별로 서술.
- 결론이 사안에 즉응하는 형태(예: '丁의 실시는 특허권 보호범위에 속한다', '甲·乙은 심결취소소송을 제기할 수 있다')로 명확히 제시.
- 감점: 조문 전사식 나열, 판례 결론만 언급하고 사안 포섭 없음, '위법이므로 취소된다'와 같이 논거 없는 단정.

감점 주의

- (1) 乙의 실시권 허락을 유효로 전제하고 논의를 이어가는 오류(제99조 제4항 위반은 무효).
- (1) 심결취소소송의 원고적격을 '공유자 전원이 공동으로 제소하여야 하는 고유필수적 공동소송'으로 서술(판례는 공유자 중 1인의 단독 제소를 허용 — 대법원 2002후567).
- (2) 일체성(작용효과 구현 상태) 검토 없이 일률적으로 침해 성립 또는 불성립이라고 단정하는 결론(대법원 2019다222782·2014다42110의 경우 구분에 반함).
- (2) 과실 부존재 입증사항을 '고의 없음'과 혼동하거나, 두 가지 사정 중 하나만 기재.
- (3) 정정심판 청구인적격에서 공유자 중 1인 단독 청구 가능이라고 서술(제139조 제3항 위반).
- (3) '의견서 제출기회 미부여도 명백한 기각사유이므로 적법'이라고 단정(제136조 제6항 원칙 위반).
- 조문·판례번호를 임의 창작하는 경우.

2020년 제2문

사례형

20점

문제

甲은 인공지능을 활용하여 자율주행으로 운행하는 '무인반송차'에 관한 발명X(구성요소 A+B)를 완성하여 2019. 1. 4. 특허출원하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 乙은 甲이 출원한 발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 양수하였고, 丙은 乙로부터 선출원을 기초로 우선권을 주장하여 특허협력조약이 정한 국제출원(이하 'PCT 국제출원'이라 한다)을 할 수 있는 권리를 이전 받기로 하는 계약을 체결하고, 중국 지식재산처에 PCT 국제출원을 하면서 선출원을 기초로 우선권주장을 하였다. 이후 丁이 후출원에 관한 권리를 양수한 후 특허출원인변경신고를 하였고, 지식재산처에 후출원에 관하여 선출원에 기초한 우선권주장이 포함된 국내서면을 제출하였다. 이에 지식재산처장은 후출원의 출원시점에서 출원인과 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원인이 일치하지 않다는 이유로 우선권주장을 무효로 하는 처분을 하였다. 지식재산처장의 무효처분의 타당성에 관하여 대법원 판례를 중심으로 논하시오. (10점)

(2) 甲은 무인반송차에 관한 발명 X에 대한 개량발명 X'(구성요소 A'+B)를 완성하여 2019. 10. 7. 특허출원하여 2020. 6. 5. 특허등록을 하였다. 한편, 戊는 2019. 8. 5. 무인반송차에 관한 발명 X" (구성요소 A"+B)를 스스로 완성하여 사용하고 있다. 이때, 戊는 甲의 개량발명 X'의 구성요소 중 A'가 진보성 결여가 명백하고, 자신의 발명 X"는 물론 그의 구성요소 A"도 甲의 발명에 비해 진보성이 있다고 판단하고 있다. 甲은 戊를 상대로 특허침해소송을 제기하였다. 甲의 특허침해소송에 대한 戊의 법적 대응 조치에 관하여 설명하시오. (10점)

모범답안

문제 2

I. 설문 (1) — 지식재산처장 무효처분의 타당성

1. 문제의 소재

후출원의 출원인이 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원인과 다름을 이유로 우선권주장을 무효로 한 처분이 적법한지 문제된다. 특허 권리를 승계받은 자가 PCT 자기지정출원을 하면서 출원인변경신고를 마치지 아니한 경우 특허법 제38조 제4항이 우선권주장 절차에도 적용되는지가 쟁점이다(대법원 2017후1274).

2. 관련 법리

(1) 관련 법규정

특허법 제55조 제1항은 특허를 받으려는 자가 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 선출원의 명세서 등에 기재된 발명을 기초로 우선권을 주장할 수 있다고 규정하고, 제38조 제4항은 출원 후 권리의 승계는 일반승계를 제외하고는 출원인변경신고를 하여야 효력이 생긴다고 규정한다. PCT 제8조(2)(b)에 의하면 자기지정출원의 우선권 주장의 조건과 효과는 지정국 법령에 따른다.

(2) 기존의 심사기준

종전 심사실무는 제38조 제4항을 근거로 후출원 전에 선출원에 관하여 출원인변경신고를 마칠 것을 요구하고, 후출원 시점에 양 출원인이 일치하지 아니하면 우선권주장을 무효로 처리하였다. 사안의 무효처분도 이 기준에 따른 것이다.

(3) 대법원 2017후1274 판결

대법원은 1) 제55조 제1항이 우선권주장의 주체를 '특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자'로만 규정하여 출원인의 동일성을 요구하는 분할출원(§52)·변경출원(§53)과 대비되는 점, 2) 제38조 제4항은 출원심사의 편의성·신속성을 위한 규정으로서 **우선권주장 절차에는 적용되지 않는 점**, 3) 국내우선권 제도는 개량과정에서 출원인이 달라질 수 있음을 예정한 점을 들어, **후출원 시 양 출원인이 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았다면 우선권을 주장할 수 있다고** 판시하였다. 또한 PCT 자기지정출원에서 실질적 승계 여부는 국내단계 진입 후 우리나라 법령에 따라 심사하고, 필요하면 시행규칙 제7조 제1항에 따라 승계인 증명서류의 보완을 요구할 수 있다고 하였다.

3. 사안의 포섭

(1) 丙의 우선권주장 적격

甲에서 乙로 특허를 받을 수 있는 권리가 양수되고, 乙에서 丙으로 선출원을 기초로 우선권을 주장하여 PCT 국제출원을 할 수 있는 권리가 이전되었다. 丙은 권리와 우선권을 모두 이전받았으므로 특허법 제55조 제1항의 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 해당한다.

(2) 출원인 불일치를 이유로 한 무효처분의 당부

丙이 PCT 국제출원을 하면서 우선권을 주장한 뒤 丁이 후출원 권리를 양수하여 출원인변경신고를 마치고 국내서면을 제출하였다. 국내단계 심사에서 丙의 실질적 승계가 확인되는 이상, 후출원 시점에 丙과 선출원 출원인 乙이 형식적으로 일치하지 아니한다는 점만으로 우선권주장을 무효로 할 수 없다.

(3) 지식재산처의 조치

기존 심사기준에 따라 제38조 제4항을 근거로 후출원 시점의 출원인 동일성을 요구한 것은 위 판결과 국내우선권 제도의 취지에 반한다. 시행규칙 제7조 제1항에 따라 승계 증명서류의 보완을 요구하는 방식으로 심사하여야 한다.

4. 결론

지식재산처장의 무효처분은 **위법·부당**하다.

II. 설문 (2) — 침해소송에 대한 戊의 법적 대응**1. 사안의 전제와 문제의 소재**

甲은 발명 X(A+B)를 출원하고 그 개량발명 X'(A'+B)를 2019.10.7. 출원하여 등록받았으므로, 戊의 대응은 X와 X' 모두에 관하여 검토할 필요가 있다. X가 등록된 경우에도 戊는 X"(A"+B)의 구성요소 A"가 A와 다름을 들어 아래 (1)과 같은 취지로 문언·균등침해의 불성립을 항변할 수 있다. 이하 X'에 대한 대응을 소송상 항변과 별도 절차로 나누어 본다.

2. 소송상 실제적 항변**(1) 비침해(구성요소완비원칙 위반) 항변**

침해가 성립하려면 실시제품이 청구범위의 각 구성요소와 그 유기적 결합관계를 모두 포함하여야 한다(구성요소완비의 원칙, 2024후11590). X"의 A"는 X'의 A'와 달라 문언침해가 성립하지 아니하고, 과제의 해결원리가 동일하지 아니하며 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내지 아니하고 침해 시를 기준으로 쉽게 변경할 수 있는 정도도 아니므로 균등침해도 성립하지 아니한다고 항변할 수 있다(2013다14361, 2014후2788).

(2) 자유실시기술의 항변

확인대상발명이 특허출원 전 공지기술과 동일하거나 통상의 기술자가 이로부터 쉽게 실시할 수 있으면, 문언침해에 해당하는 경우에도 자유실시기술로서 권리범위에 속하지 아니한다(2016후366). 戊는 X"가 출원 전 공지기술의 범위 안에 있음을 증명하여 항변할 수 있다.

(3) 진보성 결여 명백 → 권리남용 항변

무효사유가 명백한 특허권에 기초한 침해금지·손해배상청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하고, 침해소송 법원은 무효심결 확정 전이라도 그 명백성을 심리할 수 있다(2010다95390 전합). 다만 진보성은 유기적으로 결합된 전체로서 판단하여야 하므로(2009후1897), 구성요소 A'의 진보성 결여가 명백하다는 것만으로는 부족하고 결합된 전체로서의 X'에 무효사유가 명백함을 선행기술로 증명하여야 한다.

(4) 선사용에 의한 통상실시권(§103) 항변

특허출원 시에 그 발명의 내용을 알지 못하고 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 알게 되어 국내에서 실시사업을 하거나 준비하고 있는 자는 그 발명 및 사업목적의 범위에서 통상실시권을 가진다(§ 103). 戊는 甲의 출원일(2019.10.7.) 이전인 2019.8.5. 이미 X"를 **스스로 완성하여 사용하고 있었으므로** 위 법정 통상실시권을 가지며, 권리범위에 속한다고 판단될 경우의 예비적 항변으로서도 실익이 있다.

3. 별도 절차상의 대응**(1) 특허무효심판 청구(§133)**

戊는 이해관계인으로서 진보성 결여를 이유로 무효심판을 청구할 수 있고, 무효심결이 확정되면 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되어(§ 133③) 침해가 성립할 여지가 없다.

(2) 소극적 권리범위확인심판 청구(§135)

戊는 X"가 X'의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있고, 그 심결은 침해소송에서 유력한 증거자료가 된다. 다만 권리범위확인심판에서는 진보성이 부정된다는 이유로 권리범위를 부정할 수 없고(2012후4162 전합), 선사용권과 같은 실시권의 존부는 보호범위 확정과 관련 없는 주관적 사정이므로 이를 이유로 한 소극적 청구는 확인의 이익이 없어 각하된다. 따라서 선사용권은 침해소송에서 항변으로 주장하여야 한다.

(3) 침해소송 절차 중지 신청

심판을 청구한 경우 법원은 필요하면 심결 확정 시까지 소송절차를 중지할 수 있으므로(§ 164②), 戊는 그 중지를 신청할 수 있다.

4. 결론

戊는 소송상 비침해·자유실시기술·권리남용·선사용권 항변을 병행하면서 별도로 무효심판과 소극적 권리범위확인심판을 청구하고 소송절차의 중지를 신청할 수 있다. 발명 완성시점이 X' 출원일 이전임이 명확하므로 **선사용에 의한 통상실시권 항변이 가장 실효적**이고, X' 전체의 진보성 결여가 명백하면 무효심판과 권리남용 항변을 병행하여야 한다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	득점 포인트
(1) 우선권주장 출원인의 동일성 요건(제55조 제1항)	2점	우선권주장 주제는 '특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자'이면 족함을 조문 근거로 적시
(1) 제38조 제4항(출원인변경신고)의 우선권 절차 적용 여부	3점	대법원 2017후1274 판시 — 제38조 제4항은 심사의 편의·신속을 위한 규정으로 우선권 주장 절차에 적용되지 않음
(1) 사안 포섭(丙이 乙로부터 권리를 승계받은 경우·丁의 명의변경)	3점	丙이 특허 받을 권리를 이전받은 이상 후출원 시점 출원인 불일치는 우선권 무효사유 아님, PCT 자기지정 관련 국내단계 실체심사 법리
(1) 지식재산처장 처분의 타당성 결론	2점	무효처분은 부당(위법)하다는 명확한 결론
(2) 침해소송에 대한 절차적·실체적 대응 개관	1점	답변서·소송상 항변 및 별도 심판절차 구조화
(2) 비침해 항변(구성요소완비·균등침해 부정)	2점	A'≠A"의 구성 차이, 진보성 있는 A"는 균등물이 아님
(2) 자유실시기술 항변(대법원 2016후366) / 진보성 결여 명백 → 권리남용 항변	3점	대법원 2010다95390 전합 취지: 진보성 결여가 명백한 경우 권리행사는 권리남용
(2) 선사용에 의한 통상실시권(제103조)	2점	2019.8.5. 완성·사용(2019.10.7. 출원 전) — 요건 포섭
(2) 별도 절차: 무효심판(제133조), 소극적 권리범위확인심판(제135조), 소송절차 정지신청	2점	각 청구인 적격·청구이유·활용 실익

합계 20점.

축별 채점 기준

1) 논점 추출(약 8점)

- (1)에서 '후출원 시 출원인 동일성이 우선권 유효요건인가'라는 핵심 쟁점을 정확히 잡고, 대법원 2017후1274 판결을 인용하였는가.
- (1)에서 특허법 제38조 제4항과 우선권 주장 절차의 관계를 논점화하였는가.
- (2)에서 ① 비침해, ② 무효/권리남용, ③ 선사용권, ④ 별도 심판이라는 4개 축을 빠짐없이 적시하였는가.
- 발문의 사실관계(丙·丁의 지위, 戊의 완성시점 2019.8.5·출원일 2019.10.7·A" 진보성 결여 명백·A" 진보성 있음)를 각 쟁점에 대응시켰는가.
- 감점: 무관한 조약우선권 최선성 논의 장황, 직무발명 등 무관 쟁점 삽입.

2) 목차·구성(약 5점)

- (1)과 (2)의 배점이 동일하므로 분량을 균형 있게 배분하였는가.
- (1)은 '조문 → 판례법리 → 사안포섭 → 결론' 순, (2)는 항변 유형별로 목차를 세분화하였는가.
- 판례요지와 사안적용을 구분 배치하였는가.
- 감점: 서론 장황, 조문 전사, 판례 나열만 하고 사안 포섭 결여.

3) 답안 작성·논증(약 7점)

- (1) 대법원 2017후1274의 핵심 판시(제38조 제4항은 절차편의 규정, 우선권주장은 권리승계만으로 족함, PCT 자기지정출원의 국내단계 실체심사)를 정확히 서술하였는가.
- (1) '丙이 乙로부터 특허받을 수 있는 권리 및 우선권을 이전받았음'을 근거로 처분의 위법성을 도출하였는가.
- (2) 선사용권의 요건(출원 시 국내에서 그 발명의 실시사업 준비/실시 중, 선의)을 조문(제103조)에 근거하여 포섭하였는가.
- (2) 진보성 결여 명백 시 권리남용 항변(대법원 2010다95390 전합 취지) 및 자유실시기술 항변을 구분·병기하였는가.
- 결론이 각 쟁점마다 명확하고, 앞선 논거와 모순이 없는가.

감점 주의

- (1)에서 조약우선권(파리협약 제4조)과 국내우선권(제55조)을 혼동하여 최선출원 요건·기간요건 위주로 서술하면 논점 이탈로 감점.
- (1)에서 특허법 제38조 제4항을 그대로 적용하여 '출원인 불일치는 무효'라고 결론짓는 것은 판례 이탈. 감점.
- (2)에서 선사용권을 언급하지 않거나, 완성 시점(2019.8.5.)과 출원일(2019.10.7.)의 선후관계를 확인하지 않고 결론을 내리면 감점.
- (2)에서 무효심판만 언급하고 소송에서의 권리남용 항변(진보성 결여 명백)을 누락하면 감점.
- 발문이 '설명하시오'임에도 지식재산처장 처분·소송의 결과에 대해 결론을 흐리게 서술하면 감점.

2020년 제3문

사례형

30점

문제

甲은 인간의 건강상태를 확인할 수 있는 체온계의 생산·판매를 업으로 영위하고 있는 회사이다. 최근 COVID-19(이하 '코로나19 바이러스'라 한다)가 세계적으로 확산이 되면서 사람들의 건강상태를 확인하던 기존의 체온계로서는 빠른 시간에 많은 사람들의 발열을 체크하는데 시간이 많이 소요되어 소비자들이 불편을 느끼게 되었다. 그래서 甲은 자사의 연구소 연구원에게 빠른 시간에 많은 사람들이 발열체크를 할 수 있는 열화상 카메라를 개발 하라고 지시하였고, 甲의 지시에 의해 연구소 연구원들이 '열화상 카메라 발명A'(이하 '발명A'라 한다)를 완성하여 우리나라 지식재산처에 출원하여 특허등록이 되었다.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 乙은 甲의 종업원이었던 자로서 코로나19 바이러스가 확산되자 열화상 카메라가 국내뿐만 아니라 전 세계적으로도 필요할 것이라는 인식하에 甲회사에 근무 중, 동 회사의 연구소 연구원들이 연구 중인 열화상 카메라와 관련된 자료를 부정한 방법으로 입수하여 甲의 특허출원보다 먼저 특허출원하였다면 甲이 취할 수 있는 특허법상의 조치에 대하여 설명하시오. (단, 乙의 특허출원등록심사 절차가 진행되고 있다.) (8점)

(2) 甲이 특허등록 받은 발명A를 생산·판매하고 있던 중, 丙도 열화상 카메라에 관한 사업에 관심을 가지고 있어 甲에게 통상실시권 허락을 요청하였다. 마침 코로나19 바이러스로 인하여 자금 사정이 좋지 않던 甲은 국내 시장을 모두 커버하기 어려워하던 시기라, 丙의 요청을 받아들여 발명에 대하여 생산 및 판매에 관한 통상실시권을 허락하였다. 丙은 甲과 통상실시권 계약 체결과 동시에 설정등록을 한 후 甲이 생산한 '발명의 열화상 카메라'를 구매하여 판매도 하고 있다. 그 후에도 코로나19 바이러스가 진정되지 않아 자금조달 등의 사정이 쉽지 않던 甲은 다시 戊와 전용 실시권을 설정하는 계약 체결과 동시에 설정등록하였다. 이 경우 戊가 甲과 丙에게 취할 수 있는 조치에 대하여 설명하시오. (단, 甲과 丙은 발명A를 계속 실시하고 있다.) (13점)

(3) 丁은 서울 시내에서 일반인을 상대로 얼굴로 점을 봐주는 점집을 운영하고 있는 자이다. 丁은 甲의 발명A를 이용하여 [관상(觀相)을 보는 카메라 발명A]를 발명하여 특허를 등록받았다. 丁은 점을 보려고 하는 소비자들에게 [관상(觀相)을 보는 카메라 발명A]를 이용하여 서비스를 제공하려고 한다. 이 경우 丁이 [관상(觀相)을 보는 카메라 발명A]를 실시하기 위한 조치에 대하여 설명하시오. (9점)

모범답안

I. 설문 (1) — 甲이 취할 수 있는 특허법상의 조치 (8점)

1. 乙의 출원이 무권리자 출원인지 판단

발명A는 甲의 지시에 따라 회사 연구소 연구원들이 완성한 직무발명으로, 사용자 甲이 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 보유한다. 乙은 발명자도 그 승계인도 아니면서 연구 중인 자료를 부정한 방법으로 입수하여 甲보다 먼저 출원한 자이므로, 乙의 출원은 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자의 출원, 즉 무권리자(모인) 출원으로서 제33조 제1항 본문 위반에 해당한다.

2. 甲이 취할 수 있는 조치

(1) 정보제공(§63의2)

乙의 출원이 심사 계속 중이므로 甲은 심사관에게 乙이 무권리자임을 밝히는 증거자료(연구자료·개발경위·부정취득 정황 등)를 제출하여 정보를 제공할 수 있다. 제33조 제1항 본문 위반은 거절이유(§ 62(2))이므로 심사관은 이를 이유로 乙의 출원을 거절할 수 있다.

(2) 무효심판의 청구(§133②(2))

심사관이 이를 간과하여 乙에게 특허권이 설정등록되는 경우, 甲은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자로서 제33조 제1항 본문 위반을 이유로 무효심판을 청구할 수 있다. 이 무효사유에 대한 심판청구인은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자로 제한된다(§ 133① 단서). 다만 甲은 이미 발명A에 대하여 자신의 명의로 특허권을 확보하고 있으므로, 정당한 권리자 출원의 출원일 소급(§ 34·§ 35)이나 특허권 이전청구(§ 99의2)에 의한 필요는 없다.

(3) 거짓행위의 죄(§229)

乙이 거짓이나 그 밖의 부정한 행위로서 특허를 받은 때에는 거짓행위의 죄(3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금)에 해당하므로, 甲은 수사기관에 고발하는 등 형사적 제재를 구할 수 있다.

(4) 기타 고려할 수 있는 조치

특허법 외의 조치로서, 乙의 부정취득행위에 대하여 형법상 절도죄, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호법상 영업비밀 침해행위(부정취득행위)의 책임을 물을 수 있다. 또한 甲은 모인에 의하여 노하우로 하여 은닉할 것인지 출원할 것인지의 선택권을 침해받았고 발명자가 자신의 이름이 기재되어야 할 인격권도 침해받았으므로, 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 불법행위(민법 § 750)에 기한 손해배상청구도 고려할 수 있다.

3. 결론

乙의 출원은 무권리자 출원이므로, 심사 계속 중인 현 단계에서 甲은 정보제공으로 거절을 유도하고, 등록되는 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자로서 무효심판을 청구할 수 있다. 아울러 거짓행위의 죄에 의한 형사적 제재와 절도죄·영업비밀 침해·불법행위에 기한 손해배상청구를 병행할 수 있다.

Ⅱ. 설문 (2) — 戊가 甲·丙에게 취할 수 있는 조치 (13점)

1. 전용실시권의 침해인지 판단

(1) 관련 법규정

전용실시권자는 설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점하고(§ 100②), 특허권자도 전용실시권을 설정한 때에는 전용실시권자가 실시할 권리를 독점하는 범위에서는 실시할 수 없다(§ 94① 단서). 전용실시권의 설정은 등록하여야 효력이 발생하는데(§ 101①(2)), 戊는 계약 체결과 동시에 설정등록을 마쳤으므로 유효한 전용실시권자다. 한편 통상실시권을 등록한 때에는 그 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 그 효력이 발생한다(§ 118①).

(2) 甲의 실시가 침해인지 판단

甲의 생산·판매가 戊의 전용실시권 설정행위로 정한 범위 이내라면, 甲은 제94조 제1항 단서에 따라 그 범위에서는 특허권자라도 실시할 수 없으므로 甲의 계속 실시는 전용실시권 침해가 된다. 반면 설정행위로 정한 범위를 벗어난 실시라면 특허권자 자신의 실시로서 침해가 되지 않는다.

(3) 丙의 실시가 침해인지 판단

丙은 통상실시권 계약 체결과 동시에 설정등록을 마쳤고 戊의 전용실시권 등록은 그 후에 이루어졌으므로, 丙은 등록된 통상실시권의 범위 내에서 대항요건을 취득하여(§ 118①) 그 범위 내의 실시는 침해가 되지 않는다. 또한 丙은 甲이 생산한 열화상 카메라를 구매하여 판매하고 있는바, 甲의 판매가 침해가 되지 않는 경우라면 그 판매로써 특허권은 적법하게 소진되므로, 甲이 판매한 것을 丙이 구매하여 판매하는 행위는 권리소진에 의하여 침해가 되지 않는다.

2. 戊가 甲에게 취할 수 있는 조치

(1) 민·형사적 권리행사(침해인 경우)

甲의 실시가 전용실시권 설정 범위 이내인 경우, 戊는 침해금지 및 예방청구(§ 126)와 손해배상청구(§ 128, 과실은 § 130으로 추정)·신용회복청구(§ 131)를 할 수 있고, 고의의 침해에 대하여는 침해죄(§ 225)에 의한 형사적 제재를 구할 수 있다.

(2) 채무불이행에 따른 손해배상

전용실시권 설정계약에서 甲에게 비실시의무가 있거나 제3자에 대한 통상실시권 허락 금지 의무가 있었다면, 甲의 계속 실시와 丙에 대한 통상실시권의 허락은 계약 위반이 되므로 戊는 침해 여부와 별개로 채무불이행에 따른 손해배상을 청구할 수 있다.

3. 戊가 丙에게 취할 수 있는 조치

丙이 등록된 통상실시권의 범위를 벗어나 실시한 경우, 그 부분은 정당한 권원 없는 실시이므로 戊는 침해금지·손해배상 등 민·형사적 권리행사를 할 수 있다. 다만 권리소진이 적용되는 범위(甲이 적법하게 판매한 제품을 구매하여 판매하는 행위) 내에서는 권리가 이미 소진되었으므로 권리행사를 할 수 없다.

4. 결론

甲의 실시는 전용실시권 설정행위로 정한 범위 이내인지에 따라 침해 여부가 갈리며, 침해인 경우 戊는 민·형사적 권리행사를 할 수 있고, 계약상 비실시의무 또는 통상실시권 허락금지의무가 있었다면 채무불이행 책임도 물을 수 있다. 丙에 대하여는 선등록 통상실시권의 대항력(§ 118①)과 권리소진이 미치는 범위에서는 권리행사를 할 수 없고, 그 범위를 벗어난 실시에 대하여만 민·형사적 조치를 취할 수 있다.

Ⅲ. 설문 (3) — 丁이 [관상을 보는 카메라 발명A']를 실시하기 위한 조치 (9점)

1. 이용관계인지에 대한 판단

(1) 관련 법규정

특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명을 이용하는 것인 경우에는 그 특허권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다(§ 98).

(2) 사안의 포섭

丁의 발명A'은 甲의 선출원 등록발명 A를 이용하여 완성한 것으로서 발명A의 구성을 그대로 포함하면서 관상 기능을 부가한 것이므로, 발명A'의 실시는 필연적으로 발명A의 실시를 수반한다. 따라서 丁은 자신이 특허권자라 하더라도 甲의 허락 없이는 발명A'을 업으로서 실시할 수 없고, 허락 없는 실시는 甲의 특허권 침해가 된다.

2. 丁이 취할 수 있는 조치

(1) 실시권 허락(통상실시권·전용실시권)

가장 원칙적인 방법은 甲과 협의하여 발명A에 관한 실시권을 허락받는 것이다. 통상실시권의 허락(§ 102)은 물론, 발명A' 사업의 독점적 실시가 필요한 경우에는 전용실시권의 설정(§ 100)을 받을 수도 있으며, 그 범위·대가 등 조건은 계약으로 자유로이 정할 수 있다.

(2) 통상실시권 허락심판의 청구(§138)

甲이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 허락을 받을 수 없는 경우, 丁은 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다(§ 138①). 다만 丁의 발명A'이 발명A에 비하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권을 허락하여서는 아니 되며(§ 138②), 심판에 의하여 통상실시권이 허락된 경우 甲도 丁의 특허권에 대하여 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다(§ 138③, 크로스 라이선스).

(3) 그 밖의 조치

발명A에 무효사유가 있는 경우 丁은 이해관계인으로서 무효심판(§ 133)을 청구할 수 있고, 무효심결이 확정되면 제98조의 제한 없이 실시할 수 있으며, 甲이 침해소송을 제기하면 심결이 확정될 때까지 소송절차의 중지를 신청할 수 있다(§ 164②). 또한 발명A'이 제98조의 이용관계에 해당하지 않는다고 판단하는 경우에는 자신의 등록발명 A'이 발명A의 권리범위에 속하지 아니한다는 권리 간 소극적 권리범위확인심판(§ 135)을 청구할 수 있다.

3. 결론

丁의 발명A'은 발명A와 이용관계에 있으므로 甲의 허락 없이 실시할 수 없다. 丁은 우선 甲으로부터 통상실시권 또는 전용실시권을 허락받는 방법을 시도하고, 협정이 이루어지지 않으면 통상실시권 허락심판(§ 138)을 청구하여야 한다. 아울러 발명A에 무효사유가 있으면 무효심판과 소송절차 중지신청을, 이용관계 자체를 다투는 경우에는 권리 간 소극적 권리범위확인심판을 활용할 수 있다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	득점 포인트
(1) 乙의 무권리자(모인) 출원에 대한 甲의 조치	8	① 직무발명 승계 → 甲이 정당한 권리자임 확정 ② 심사 중이므로 정보제공(제63조의2)·거절이유(제33조 제1항 본문, 제62조 제2호) 유도 ③ 乙의 거절결정 확정 후 정당한 권리자 출원 시 출원일 소급(제34조·제35조) ④ 만약 등록되면 무효심판(제133조 제1항 제2호)·특허권 이전청구(제99조의2) 언급
(2) 戊(전용실시권자)의 甲·丙에 대한 조치	13	① 전용실시권 설정등록의 효력(제100조 제2항·제101조 제1항 제2호) — 甲의 실시는 원칙적으로 침해 ② 甲에 대한 침해금지(제126조)·손해배상(제128조)·신용회복(제131조)·형사고소(제225조) ③ 丙의 통상실시권 선등록의 대세적 효력(제118조 제1항) — 후발 전용실시권자에게 대항 가능, 따라서 침해 주장 불가 ④ 甲과 戊 간 전용실시권 설정계약의 채무불이행 문제(丙에게 이미 허락된 통상실시권 존재를 담보)
(3) 丁의 이용발명 실시를 위한 조치	9	① 이용관계(제98조) 성립 → 甲의 허락 없이 실시 시 침해 ② 甲과의 협의를 통한 통상실시권 계약(제102조) ③ 협의 불성립 시 통상실시권 허여심판(제138조) 청구 — 요건(상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보) ④ 크로스 라이선스(제138조 제3항) 및 공익적 재정(제107조, 지식재산처장에게 청구) 언급

합계 30점.

축별 채점 기준

1) 논점 추출 (12점)

- (1) 乙이 부정한 방법으로 자료를 입수했다는 사실 → 무권리자 출원임을 정확히 포착했는가 (+3)
- (2) 통상실시권이 **선등록**되었고, 甲·丙이 계속 실시하고 있다는 두 사실을 각각 다른 법적 효과로 연결했는가 (+5)
- (3) 관상 카메라가 발명A를 '이용'한다는 문언에서 이용발명(제98조) 쟁점을 포착했는가 (+3)
- 무관한 조문(진보성, 신규성 등) 나열 시 감점 (-2)

2) 목차·구성 (7점)

- 설문별 목차를 나누고, 배점 비율(8:13:9)에 맞추어 분량을 배분했는가 (+3)
- 각 설문 내에서 「전제 검토 → 조치 열거 → 소결」 순으로 정돈했는가 (+2)
- 설문 (2)에서 甲에 대한 조치와 丙에 대한 조치를 목차 상 분명히 분리했는가 (+2)

3) 답안 작성·논증 (11점)

- 조문 정확 인용: 제34조·제99조의2·제100조·제101조·제118조·제138조 (+5)
- 판례·학설 근거를 사안에 포섭하여 결론을 도출했는가 (+3)
- 丙의 통상실시권이 왜 戊에게 대항 가능한지(제118조 제1항의 등록의 대항력) 논리적으로 설명했는가 (+2)
- 결론이 명확하고 본문 논리와 일치하는가 (+1)

감점 주의

- 설문 (1)에서 특허권 이전청구(제99조의2)만 답하고 심사 중임을 간과한 채 무효심판을 논하는 오류.
- 설문 (2)에서 丙의 통상실시권을 등록의 대항력(제118조 제1항) 근거 없이 그저 '선(先) 계약이므로 유효'라고만 서술하는 것.
- 설문 (2)에서 甲(특허권자)이 전용실시권 설정 후에도 당연히 실시 가능하다고 오해하여 침해가 아니라고 결론짓는 오류(제100조 제2항 위반).
- 설문 (3)에서 이용관계(제98조)를 언급하지 않고 단순히 '甲과 협의하여 실시권 받으면 된다'고만 서술.
- 통상실시권 허여심판(제138조) 요건(상당한 경제적 가치의 중요한 기술적 진보)을 누락한 채 심판만 언급.
- 재정(제107조)의 청구 상대방을 잘못 기재하는 오류(현행법상 지식재산처장).
- 조문 전사식 나열, 학설·판례를 사안에 포섭하지 않는 일반론.

2020년 제4문

사례형

20점

문제

甲과 乙은 COVID-19와 관련된 물질AB로 구성되는 치료제와 그 제조방법을 “공동발명”하였고, 이 중에서 물질AB로 구성되는 치료제에 관하여 특허출원 하였다. 이 특허출원의 특허심사와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (단, 본 특허출원은 우선권주장 출원, 외국어서면 출원, 국제특허출원에 해당되지 않는 것으로 간주하며, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 甲 또는 乙이 단독으로 특허출원할 수 있는지를 근거와 함께 설명하시오. (5점)

(2) 甲과 乙이 공동으로 특허출원한 경우, 甲과 乙이 공동으로 한 특허출원에 대하여 甲 또는 乙이 단독으로 심사청구할 수 있는지와 제3자가 임의로 심사청구할 수 있는지를 근거와 함께 설명하시오. (5점)

(3) 甲과 乙이 공동으로 특허출원한 경우, 심사관으로부터 특허법 제63조(거절이유통지) 제1항 제1호의 거절이유로 의견제출통지서를 받았다. 본 의견제출통지서상의 거절이유를 해소하고 또한 위 공동발명에 대하여 특허를 받기 위하여 공동출원인이 취할 수 있는 특허법상의 모든 수단 및 그 이유를 설명하시오. (10점)

모범답안

I. 문제의 소재

甲·乙은 물질AB 치료제를 공동발명하였으므로 특허를 받을 수 있는 권리는 공유이다(§33②). 설문별로 (1) 공유자 1인의 단독출원 가부, (2) 공동출원 후 심사청구의 주체, (3) 제63조 제1항 제1호의 거절이유통지를 받은 공동출원인이 취할 수 있는 특허법상 수단을 검토한다.

II. 설문 (1) — 甲 또는 乙의 단독출원 가부 (5점)

1. 적용 법규정

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 하고(§33②, §44), 이에 위반한 출원은 거절이유(§62(1))가 되며 등록되더라도 무효사유(§133①(2))가 된다. 한편 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있고, 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다(§37①·③).

2. 판례

대법원 2011다67705는 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만 재산권으로서 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고, 그 이전 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있다고 한다. 나아가 특허법원 2004허5894는 특허출원하고자 하는 발명이 2인 이상 공동으로 이루어진 경우라도 그 출원 전 또는 출원 후에 공동발명자 중 1인이 나머지 공동발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 모두를 이전받아 단독 권리자가 되는 경우에는 공동출원규정의 적용을 받지 않거나 그 규정에 위반하여 출원된 하자가 치유된다고 한다.

3. 결론

甲·乙은 공동발명자로서 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하므로, 원칙적으로 甲 또는 乙은 단독으로 특허출원을 할 수 없고, 단독출원은 제44조 위반으로 거절이유·무효사유가 된다. 다만 甲 또는 乙이 다른 공유자로부터 특허를 받을 수 있는 권리의 지분을 이전받아 단독 권리자가 된다면 단독으로 특허출원을 할 수 있다.

III. 설문 (2) — 심사청구의 주체 (5점)

1. 심사청구의 주체 (§59②)

특허출원에 대하여 심사청구는 “누구든지” 출원일부터 3년 이내에 할 수 있다(§59②). 즉 심사청구권자는 출원인에 한정되지 아니한다.

2. 공동출원인의 단독 심사청구 가부

제11조 제1항 본문은 “2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟을 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 제외하고는 각자가 모두를 대표한다”고 규정한다. 심사청구는 제11조 제1항 각 호(특허출원의 변경·포기·취하, 신청·청구의 취하, 국내우선권주장 또는 그 취하, 거절결정불복심판 청구 등)에 열거되어 있지 않다. 따라서 각자대표 원칙이 그대로 적용되어, 공동출원인인 甲 또는 乙은 각자 단독으로 심사청구를 할 수 있다(§11① 본문의 직접 적용).

3. 제3자의 심사청구

제59조 제2항이 "누구든지"라고 규정하므로, 이해관계 유무를 불문하고 제3자도 임의로 심사청구를 할 수 있다.

4. 결론

甲 또는 乙 단독의 심사청구 및 제3자의 임의 심사청구 모두 가능하다.

IV. 설문 (3) — 거절이유통지를 받은 공동출원인이 취할 수 있는 특허법상 수단 (10점)

1. 거절이유의 타당성 검토

거절이유통지(§ 63①(1))를 받은 출원인은 조치에 앞서 i) 거절이유의 존재 여부, ii) 인용대상의 적법한 존재 여부, iii) 심사관의 법 적용 착오 여부를 검토하고, 그 결과에 따라 대응을 달리한다.

2. 거절이유가 타당하지 아니한 경우

(1) 의견서 제출

타당하지 아니한 이유를 구체적으로 적은 의견서를 제출하고, 필요하면 권리범위 재설계를 위한 보정서를 함께 제출한다.

(2) 특허거절결정에 대한 불복

거절결정을 받으면 3개월 이내에 보정을 수반한 재심사청구(§ 67의2)와 거절결정불복심판청구(§ 132의17) 중 하나를 할 수 있고, 기각심결에는 30일 이내의 분리출원 또는 심결취소소송으로, 기각판결에는 2주 이내의 상고로 다툰다.

3. 거절이유가 타당한 경우

(1) 극복 가능한 경우의 수단

- ① **(공지예외주장(§30))** 신규성·진보성 거절이유의 경우, 공지일부터 12개월 이내의 출원이라면 취지와 증명서류를 제출하며 주장할 수 있다.
- ② **(보정(§47))** 청구범위의 삭제·감축 등으로 극복한다. 최초거절이유통지 대응은 신규사항 추가 금지(§ 47②), 최후거절이유통지 대응은 청구범위 보정 범위 제한(§ 47③)까지 준수하여야 한다.
- ③ **(분할출원(§52))** 일부 청구항에만 거절이유가 있으면 특허받을 수 있는 부분을 분할출원하여 출원 전체가 거절되는 것을 회피한다.
- ④ **(변경출원(§53))** 진보성 거절이유의 경우 실용신안으로의 변경출원을 고려할 수 있으나, 사안의 물질AB 치료제는 물질발명이어서 변경출원을 할 수 없다.
- ⑤ **(국내우선권주장출원(§55))** 기재불비가 신규사항 추가 금지의 한계로 보정으로 치유되지 아니하는 경우, 출원일부터 1년 이내라면 적절한 수단이 된다.

(2) 극복 불가능한 경우

방치하여 거절결정을 유도하거나, 출원공개 전이고 노하우로 보호할 가치가 있으면 출원의 취하·포기를 고려한다.

4. 공동출원인의 절차상 유의점

의견서·보정서의 제출과 재심사청구는 각자대표 원칙(§ 11① 본문)에 따라 甲·乙 각자 할 수 있으나, 출원의 변경·포기·취하(§ 11①(1))와 거절결정불복심판의 청구(§ 11①(6))는 공동으로만 할 수 있고, 분할출원·변경출원은 새로운 출원이므로 전원이 공동으로 하여야 한다(§ 44).

5. 결론

甲·乙은 거절이유가 타당하지 아니하면 의견서 제출과 재심사청구·거절결정불복심판·심결취소소송으로 다투고, 타당하면 공지예외주장·보정·분할출원 등으로 극복하며, 극복이 불가능하면 방치 또는 출원의 취하·포기를 고려할 수 있다. 다만 불복심판 청구·취하·포기와 분할·변경출원은 공동으로 하여야 한다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
(1) 공동발명자의 단독출원 가부 (제33조 제2항, 제44조)	5	공동발명 → 특허받을 권리 공유 → 공유자 전원 공동출원 원칙, 위반 시 제62조 제1호 거절이유-제133조 제1항 제2호 무효사유, 판례 인용(권리의 양도성·지분 전부 이전 시 공동출원 하자 치유)
(2) 공동출원의 심사청구 주체 (제59조)	5	심사청구는 "누구든지" 가능 → 공유자 1인 단독청구 가능, 제3자도 청구 가능, 제11조 제1항 각호 예외 아님
(3) 제63조 제1항 제1호 거절이유 해소 및 특허취득 수단	10	의견서·보정서 제출, 지분 이전에 의한 하자 치유(단독 권리자화), 분할출원, 기간연장(제15조), 거절결정 시 재심사청구(제67조의2)·거절결정불복심판(제132조의17), 실질적 해소방안 논증

합계: 20점

축별 채점 기준

1) 논점 추출 (40%)

- (1): "공동발명"이라는 설문 단서에서 특허받을 권리의 공유(제33조 제2항)를 도출하고 제44조 공동출원 의무 위반을 지적했는가.
- (2): 심사청구의 주체 요건("누구든지", 제59조 제2항·제3항)을 정확히 포착했는가. 제11조 제1항 각호 예외 사항이 아님을 언급했는가.
- (3): 제63조 제1항 제1호가 "제62조에 따라 특허거절결정을 하려는 경우"의 거절이유통지임을 파악하고, 사안에서 상정 가능한 거절이유(예: 진보성, 기재불비 등 일반형) 해소를 위한 절차적·실체적 수단을 망라했는가. 특히 공동출원인이라는 특수성(공동보정·공동절차 문제)을 포착했는가.
- 감점: 무권리자 출원(제34조·제35조) 문제로 오독, 정보제공제도 등 무관한 조문 나열.

2) 목차·구성 (25%)

- 설문 (1)(2)(3)를 명확히 구분 편제. (3)의 배점(10점)에 맞추어 분량을 (1)(2)의 2배로 배분.
- (3)에서 "의견서·보정서 → 분할출원 → 재심사청구 → 거절결정불복심판"을 절차 흐름 순으로 체계화.
- 조문 → 판례·학설 → 사안적용 순서 준수.
- 감점: 서론 장황, (3)에서 특정 수단만 편중 서술.

3) 답안 작성·논증 (35%)

- 조문 정확 인용: 제33조 제2항, 제44조, 제59조, 제62조, 제63조, 제47조, 제52조, 제67조의2, 제132조의17.
- 판례 인용: 특허를 받을 수 있는 권리의 양도성·지분 이전(대법원 판례) 및 지분 전부 이전 시 공동출원 하자 치유(특허법원 판례).
- (3)에서 "공동출원인이 취할 수 있는 모든 수단"이 발문이므로 절차적 수단(의견서·보정·분할·재심사·심판·기간연장)을 빠짐없이 열거하고 각각의 근거·이유를 밝혔는가.
- 공동출원 관련 제11조 제1항 각호 규정과 절차의 공동수행 원칙을 언급했는가.

감점 주의

- 사안은 "공동발명"이므로 제44조 위반은 단독출원 시의 문제이지 공동출원한 경우에는 문제되지 않음에도, (2)(3)에서 제44조 위반을 반복 지적하는 오류.
- 심사청구 주체를 "출원인"으로만 좁게 해석하여 "누구든지"(제59조 제2항)를 놓치는 실수.
- (3)에서 "의견서 제출"만 언급하고 보정, 분할, 재심사청구, 거절결정불복심판을 누락.
- 제63조 제1항 제1호를 "제62조에 따라 특허거절결정을 하려는 경우"의 최초거절이유통지로 파악하지 못하고 최후거절이유통지로 오독.
- 공동출원인의 절차: 특허출원의 취하·포기·거절결정불복심판 청구 등은 공동으로 해야 하지만(제11조 제1항), 의견서·보정서 제출 등 통상절차는 각자대표가 가능함을 혼동.
- 심판단계 보정 근거로 제47조 제1항 제3호를 인용하는 오류(제3호는 재심사청구 시 '청구할 때' 규정임). 현행법상 거절결정불복심판 청구를 이유로 한 별도의 보정기간은 존재하지 않음.

PART 12

2021

제1문	공동발명자 성립요건과 甲·乙·丙 각각의 지위 판단 · Y발명 특허받을 권리의 甲에 대한 이전 가부	30점
제2문	일사부재리(\$163) 적용 여부 · 중복심판금지 적용 여부	20점
제3문	) 丙의 프린터 구입·사용의 직접침해 여부 ·) 丙의 잉크 구입·충전의 간접침해 여부	30점
제4문	제128조 제5항 실시료 상당액 산정 · 제128조 제4항 침해자 이익 추정	20점

2021년 제1문

사례형

30점

문제

甲은 2015. 8. 11. 丁에게 ‘전기 자동차 발전기 세트’를 제작하여 공급하기로 계약하였다(이하 ‘제1계약’이라 한다). 乙은 2015. 8. 25. 甲에게 위 발전기 세트 중 ‘전원분배장치 구성품’ X를 개발하여 공급하기로 계약하였다(이하 ‘제2계약’이라 한다). 甲은 丙에게 위 발전기 세트 중 ‘전원충정장치 구성품’ Y의 기본적인 과제와 아이디어를 제공하고 연구개발과정을 전반적으로 관리하면서 연구를 보조하였다. 丙은 甲과 개발 약정은 하지 않았지만 위 발전기 세트 중 ‘전원충정장치 구성품’ Y를 발명하였다.

제1계약과 제2계약에 따르면, 甲과 乙의 계약을 통해 발생한 모든 지식재산권(등록될 수 있는 권리를 포함한다)은 甲을 거쳐 丁에 귀속하도록 되어 있다.

제2계약의 이행 과정에서 발생한 X 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명을 한 乙에게 귀속되었다가 제1계약과 제2계약에 따라 최종적으로 丁에게 승계된다.

그런데 乙은 2018. 5. 28. 특허발명 X를 출원하여 2018. 12. 17. 특허등록을 받았고, 2019. 7. 30. 戊에게 X발명의 특허권을 이전해 주었다.

(1) 甲, 乙, 丙의 관계에서 ‘전기 자동차 발전기 세트’와 관련하여 공동발명자의 여부와 그 이유를 설명하시오. (5점)

(2) 甲과 丙이 ‘전원충정장치 구성품’ Y 발명과 관련하여 특허를 공동출원을 한 경우 甲이 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받을 수 있는지 설명하시오. (5점)

(3) 만일, 甲과 丙이 ‘전원충정장치 구성품’ Y 발명의 특허를 공유한 경우 甲과 丙의 지분 비율을 설명하시오. (5점)

(4) ‘전원분배장치 구성품’ X의 특허를 받을 수 있는 권리의 승계와 관련한 조치를 설명하시오. (15점)

모범답안

I. 설문 (1) - 공동발명자의 여부와 그 이유(5점)

1. 관련 법리

발명을 한 자는 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고(§ 33①), 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 그 권리를 공유한다(§ 33②). 판례는 **공동발명자가 되려면 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야** 하므로, 단순히 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 **구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자**, 발명의 목적·효과를 달성하기 위한 **구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조연·지도**를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 **기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여**하여야 공동발명자에 해당한다고 한다(2009다75178).

2. 사안의 포섭

(1) Y 발명 — 甲과 丙의 관계

甲은 Y에 관하여 **기본적인 과제와 아이디어를 제공하고 연구개발과정을 전반적으로 관리하면서 연구를 보조**하였을 뿐인바, 이는 판례가 공동발명자성을 부정하는 전형적 사유이고 창작행위에 실질적으로 기여한 사정도 없으므로 **Y는 丙의 단독발명**이다.

(2) X 발명 — 甲과 乙의 관계

X는 乙이 제2계약의 이행 과정에서 발명한 것인데, 계약에 의한 개발의 의뢰·후원·위탁은 창작행위에 대한 기여가 아니므로 **개발·공급 계약의 존재만으로는 甲이 발명자가 될 수 없다**. 결국 甲의 X 발명에 대한 **기술적 사상의 창작에의 실질적 기여**가 있으면 甲·乙의 공동발명, 없으면 乙의 단독발명이 된다.

3. 결론

Y는 丙의 단독발명이고, X는 甲의 실질적 기여 유무에 따라 **乙의 단독발명 또는 甲·乙의 공동발명**이 된다.

II. 설문 (2) - 甲이 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받을 수 있는지 (5점)

1. 관련 법리

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 **발명자에게 원시적으로 귀속**되지만(§ 33①), 이는 **재산권으로서 양도성**을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(§ 37①), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 **명시적으로는 물론 묵시적으로도** 이루어질 수 있으며, 그러한 계약에 따라 특허등록을 **공동출원한 경우에는 그 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가진다**(2011다67705). 묵시적 합의가 있었는지는 출원에 이르기까지의 **역할과 기여도, 당사자 사이의 관계, 출원의 경위** 등을 종합하여 판단한다.

2. 사안의 포섭

Y 발명의 특허를 받을 수 있는 권리는 단독발명자 丙에게 원시적으로 귀속되고, 甲·丙 사이에 개발약정 등 명시적 이전계약은 없다. 그러나 甲은 **과제·아 이디어 제공과 연구개발 관리·보조** 등 출원에 이르기까지 상당한 역할과 기여를 하였고, 丙이 甲과 함께 **공동출원**에 이른 이상, 丙이 甲을 출원인에 포함 시킴으로써 특허를 받을 수 있는 권리의 **일부 지분을 양도하여 장차 취득할 특허권을 공유하기로 하는 묵시적 합의**가 출원 당시 있었다고 볼 여지가 크다.

한편 출원 당시 묵시적 합의가 인정되지 아니하더라도 그 권리는 **출원 후에도 이전할 수 있으므로**(§ 37①), 甲은 丙으로부터 **명시적 또는 묵시적 합의**에 의하여 그 일부 지분을 이전받을 수 있다. 이 경우 상속 기타 일반승계를 제외하고는 **특허출원인변경신고**를 하여야 효력이 발생한다(§ 38④).

3. 결론

甲은 발명자가 아니지만 丙과의 **묵시적 양도 합의**에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 지분을 **이전받을 수 있고**, 출원 후에도 **명시적·묵시적 이전**(§ 38④ 출원인변경신고)에 의하여 지분을 취득할 수 있다.

III. 설문 (3) — 甲과 丙의 지분 비율 (5점)

1. 관련 법리

특허권의 공유는 민법상 공유에 특허법상 특칙(§ 99)이 가미된 것이다. 지분 비율에 관하여 특허법에는 직접적인 규정이 없으나, 특허권 등의 등록령 제26조 제1항은 "등록권리자가 둘 이상인 경우 등록의 원인에 지분에 관한 사항을 정하고 있을 때에는 신청서에 그 지분을 적을 수 있다"라고 규정하여, 공유자 사이의 지분 약정을 특허원부에 등록하여 공시하는 길을 마련하고 있다. 따라서 공유자 사이에 **지분 비율에 관한 약정이 있으면 그에 따르고**, 약정한 지분은 등록령 제26조 제1항에 따라 특허원부에 **등록하여 공시할 수 있다**. 그러나 **약정이 없거나 지분이 등록되어 있지 아니한 경우에는 민법 제262조 제2항에 따라 각 공유자의 지분은 균등한 것으로 추정**된다.

2. 사안의 포섭

甲과 丙 사이에 지분 비율에 관한 약정을 하고 등록령 제26조 제1항에 따라 그 지분을 등록하였다면 甲과 丙은 **그 등록된 비율에 따라** 지분을 가진다. 그러한 약정·등록이 없다면 균등 추정이 적용되며, 다만 이는 '추정'이므로 지분 약정의 존재 등의 입증으로 번복될 수 있다.

3. 결론

甲과 丙이 지분 비율을 약정하고 등록하였다면 그에 따라 지분을 가지나, 그렇지 아니한 경우에는 **각 1/2의 균등한 지분으로 추정**된다.

IV. 설문 (4) — X의 특허를 받을 수 있는 권리의 승계와 관련한 조치 (15점)

1. 관련 법리 — 무권리자의 특허와 정당한 권리자

판례는, 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 **계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로**, 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 **무권리자의 특허**라고 한다(§ 133①(2)본문). 또한 출원 전에 이루어진 권리의 승계는 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있으나(§ 38①), 여기서 '제3자'는 그 권리에 관하여 **승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한하므로**, 무권리자의 특허로서 무효사유가 있는 특허권을 이전받은 **양수인은 제3자에 해당하지 않는다**(대법원 2020후10087 — 분리담채형 발전기 사건).

2. 사안의 전제 — 乙·戊의 지위

X의 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 乙에게 귀속되었다가 제1·제2계약에 따라 최종적으로 **丁에게 승계**되었으므로 정당한 권리자는 丁이다. 권리를 이전한 乙은 무권리자이고 그가 출원·등록받은 특허에는 제133조 제1항 제2호 본문의 무효사유가 있으며, 이를 양수한 戊는 제38조 제1항의 '제3자'에 해당하지 아니하므로 **丁은 특허출원을 하지 않았더라도 戊에게 대항할 수 있다**. 丁은 戊의 특허에 대하여 다음 두 가지 조치를 취할 수 있다.

3. 조치 1) — 무효심판청구와 정당한 권리자 출원

丁은 이해관계인으로서 **제133조 제1항 제2호 본문 위반을 이유로 특허무효심판을 청구**할 수 있다. 무효심결이 확정되면, 확정된 날부터 **30일 이내에 정당한 권리자 출원**을 함으로써 그 출원은 무효로 된 특허의 **출원 시로 소급**한다(§ 35). 이 경우 정당한 권리자가 특허를 받으면, 무효심판청구 등록 전

에 무효사유를 알지 못하고 국내에서 실시사업을 하거나 준비하고 있던 원특허권자 戊에게는 **중용권**(§ 104①(3))이 발생할 수 있고, 戊는 丁에게 상당한 대가를 지급하여야 한다. 이 방법은 새로운 출원을 하는 것이므로, 무권리자 출원의 발명 범위 내에서 명세서·**청구범위를 다시 작성**할 수 있다는 장점이 있다.

4. 조치 2) — 특허권의 이전청구

丁은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자로서 **법원에 해당 특허권의 이전을 청구**할 수 있다(§ 99의2①). 이전등록이 되면 해당 특허권과 보상금 지급 청구권은 **특허권이 설정등록된 날부터** 丁에게 있는 것으로 보며(§ 99의2②), 이전등록된 경우는 **제133조 제1항 제2호 단서에 의하여 무효사유에서 제외**된다. 이 경우 이전등록 전에 무효사유를 알지 못하고 국내에서 실시사업을 하거나 준비하고 있던 원특허권자 戊 등에게는 **법정통상실시권**(§ 103의2)이 발생할 수 있고, 戊는 丁에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(§ 103의2②). 이 방법은 등록된 특허권을 그대로 이전받으므로 **신속하게 권리를 확보**할 수 있다는 장점이 있다.

5. 결론 — 양자의 선택

특허법은 정당한 권리자가 위 두 방법에 드는 비용과 시간 등을 비교하여 **선택**할 수 있도록 하고 있다. 무권리자가 작성한 청구범위가 부실한 경우 등 **권리 범위의 재설계가 필요**하다면 무효심판청구와 정당한 권리자 출원(조치 1))을, 등록특허를 즉시 이전받는 **신속한 권리확보**가 중요하다면 특허권 이전청구(조치 2))를 선택함이 적절하다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
(1) 공동발명자 성립요건과 甲·乙·丙 각각의 지위 판단	5	제33조 제1항·제2항 / 공동발명자 기준 판례(2009다75178 — 과제·아이디어 제공, 일반적 관리, 자금·설비 후원·위탁만으로는 부족, 기술적 사상의 창작행위에 실질적 기여 필요) / Y=丙 단독발명(甲의 행위=소극사유 전형) / X=계약만으로 甲 발명자 불가, 실질적 기여 유무에 따라 乙 단독 또는 甲·乙 공동
(2) Y발명 특허받을 권리의 甲에 대한 이전 가능	5	발명자주의(\$33①) 丙 원시귀속 / 권리의 재산권성·양도성(\$37①), 이전계약은 명시·묵시 불문, 공동출원 시 비발명자도 공유지분 취득(2011다67705) / 甲의 역할·기여도와 공동출원 경위 → 묵시적 양도 합의 인정 여지 / 출원 후에도 명시·묵시 이전 가능(\$38④) 출원인변경신고 → 이전 가능 결론
(3) Y 공유특허 지분비율	5	특허권 공유의 법적 성질(\$99 특칙) / 지분 비율=약정 우선(약정 지분은 등록령 \$26①에 따라 특허원부 등록으로 공시), 약정·등록 없으면 민법 \$262② 균등 추정(반복 가능한 추정) / 사안: 약정·등록 시 그에 따르고, 없으면 각 1/2 추정
(4) X 권리 승계 관련 丁의 조치	15	분리탐재형 발전기 사건(2020후10087) — 양도인 乙=무권리자·특허는 \$133①(2)본문 무효사유, 戊=\$38① '제3자' 불해당(丁 미출원이어도 대항 가능) / 조치① \$133①(2)본문 무효심판→\$35 정당한 권리자 출원(확정일부터 30일·출원일 소급)→선의 戊에 \$104①(3) 중용권 / 조치② \$99의2 이전청구→설정등록일 소급(\$99의2②)·\$133①(2) 단서로 무효사유 제외→선의 실시자에 \$103의2 법정실시권 / 권리범위 재설계 필요성 vs 신속한 권리확보 비교·선택

합계: 30점

특별 채점 기준

1) 논점 추출 (12점)

- (1) 발명자성 판단기준(기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여)과 상호협력요건을 모두 적시 (+)
- (2) 발명자주의 원시귀속 → 제37조 제1항 승계 → 묵시적 지분양도 판례까지 3단 논점 포착 (+)
- (4) 丁의 두 조치 트랙(무효심판+\$35 출원 / \$99의2 이전청구)을 각 부수효과(\$104 중용권 / \$103의2 법정실시권)와 함께 대비 (+)
- (4) 2016년 개정 제99조의2 이전청구·제103조의2 법정실시권 등 현행 조문 반영 (+)
- 발문 단서(제1·제2계약상 丁 귀속, 乙의 무단출원·戊 양도)를 놓치고 일반론만 나열 (-)

2) 목차·구성 (7점)

- 설문 (1)~(4)를 로마숫자로 분리, 각 설문 내 조문→판례→사안포섭→소결 구조 (+)
- 배점 비례 분량 배분: (4)에 지면 절반 이상 할애, (1)~(3)은 간결 (+)
- (4)에서 조치①/조치② 소목차 분할과 선택 기준(재설계 vs 신속 확보) 결론 (+)
- 서론 장황·조문 전사식 나열은 감점 (-)

3) 답안 작성·논증 (11점)

- (1) Y는 甲의 과제·아이디어 제공과 관리·보조가 판례(2009다75178)의 소극사유임을 들어 丙 단독발명으로, X는 계약만으로는 발명자가 될 수 없고 甲의 실질적 기여 유무에 따라 달라진다는 조건부 결론으로 논증 명시 (+)
- (2) 출원 전 명시적 이전 없음, 묵시적 이전 인정 여지 검토 후 출원 후 제37조 제1항 이전 가능 결론 (+)
- (3) 균등 추정 판례 원용 + 특약 부존재 사안포섭 (+)
- (4) 판례(2020후10087) 법리로 乙=무권리자·戊=\$38① 제3자 불해당을 논증하고 두 트랙의 조문 연쇄를 정확히 서술 (+)
- (4) 각 트랙의 선의 실시자 보호를 정확히 짚기 — \$104 중용권=무효심판청구 등록 전 실시 / \$103의2=이전등록 전 실시, 모두 상당한 대가 (+)
- 결론이 애매하거나 본문과 모순되면 감점 (-)

감점 주의

- 甲을 곧바로 공동발명자로 인정하는 오류(관리·보조자 판례 미언급)
- 설문 (2)에서 '공동출원했으므로 당연히 이전' 식 단정 — 원시귀속 주체는 丙임을 놓침
- 설문 (3)에서 기여도 비례 원칙만 서술하고 균등추정 판례 누락
- 설문 (4)에서 구법 조문(구 §36 등)만 인용하고 현행 제99조의2(이전청구)·제103조의2(법정실시권) 미언급
- 戊를 제38조 제1항의 제3자 대항관계에서 대항할 수 있는 자로 오해
- \$35 출원 기간(심결 확정일부터 30일) 누락, 또는 \$104 중용권과 \$103의2 법정실시권의 짝(무효심판 트랙/이전청구 트랙)을 뒤바꿈
- 제99조의2 제2항 소급효를 '처음부터' 소급으로 오기(정확히는 '특허권이 설정등록된 날부터' 소급)
- 존재하지 않는 조문(예: §104의2) 인용
- '제38조 제1항 단서'라는 표현(현행 §38①에는 단서 없음) 사용
- 설문별 배점을 무시하고 (4)를 짧게 처리

2021년 제2문

사례형

20점

문제

甲은 2014. 8. 6. 乙이 가진 특허 발명 통증치료제 X의 청구범위 전부에 대한 특허무효심판을 청구하였다. 甲은 무효심판절차에서 특허발명이 기존 통증치료제 2~3개를 단순 결합한 것이므로 진보성이 부정되어 그 특허등록이 무효로 되어야 한다고 주장하였다. 그러나 특허심판원은 甲의 무효심판청구를 모두 기각하는 심결(이하 '1차 심결'이라 한다)을 하였다.

1차 심결에 대하여 甲은 특허법원에 심결취소의 소를 제기하였다. 특허법원은 2015. 10. 8. 甲의 청구를 모두 기각하는 판결을 하였다. 이에 甲은 대법원에 상고하였으나, 대법원은 2019. 1. 17. 그 상고를 모두 기각하는 판결(이하 '대법원판결'이라 한다)을 선고하였다.

그런데 甲은 1차 심결에 대한 심결취소소송 상고심에서 대법원이 판결을 선고하기 하루 전인 2019. 1. 16. 이 사건 특허 발명 통증치료제 X가 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있도록 기재하지 아니하였으며 미완성 발명에 해당한다고 주장하며, 다시 특허 발명 X의 청구범위 전부에 대한 특허무효심판(이하 '2차 심판 청구'라 한다)를 청구하였다.

(1) 甲의 2차 심판 청구에 관한 조치를 특허법상 일사부재리 원칙과 중복심판금지와 관련하여 설명하시오. (15점)

(2) 甲의 2차 심판 청구는 권리 남용에 해당하는지 설명하시오. (5점)

모범답안

I. 설문 (1) — 일사부재리 및 중복심판금지 관련 조치 [15점]

1. 문제의 소재

甲의 2차 심판청구는 (i) 1차 심결에 관한 상고심 계속 중에 (ii) 1차 심결과 다른 무효사유(기재불비·미완성발명)를 들어 제기되었는데, 각하사유로서 특허법 제163조의 일사부재리 및 제154조 제8항이 준용하는 민사소송법 제259조의 중복심판(중복제소)금지에 저촉되는지가 문제된다.

2. 일사부재리 원칙 저촉 여부

(1) 적용 법규정 — 특허법 제163조

특허법 제163조 본문은 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다”고 규정하며, 다만 확정된 심결이 **각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다**(§ 163 단서). 즉 제163조는 무효심판에 한정되지 않고 특허법상 모든 심판의 확정심결에 적용된다.

(2) 판단시점 — 판례

2009후2234 전원합의체 판결은 종전 판례(심결시 기준)를 변경하여, 일사부재리 원칙의 적용을 위한 선행 확정심결의 존재 여부는 ‘**심판청구시**’를 기준으로 판단하여야 한다고 판시하였다. 이는 일사부재리의 대세효(‘누구든지’)로 인한 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 선행 심결의 확정에 관해서만 기준 시점을 변경한 것이다(2018후11360 참조).

(3) 동일사실·동일증거

판례는 ‘동일사실’이란 청구원인이 되는 특정한 무효사유를 의미하고, ‘동일증거’는 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 실질적으로 동일한 증거를 뜻한다(2012후1057)고 본다. 무효사유가 서로 다른 경우에는 동일사실이라 할 수 없다(특허법원 2007허1787 참조).

(4) 사안 포섭

① 2차 심판청구시(2019. 1. 16.)에는 1차 심결에 대한 대법원의 상고기각 판결(2019. 1. 17.)이 아직 선고되지 않아 **1차 심결이 확정되지 않은 상태**였으므로, 청구시 기준으로 확정심결이 존재하지 아니한다. ② 나아가 1차 심판의 무효사유는 진보성 흠결이고 2차 심판의 무효사유는 기재불비·미완성발명이어서 **동일사실이라고 볼 수도 없다**.

(5) 결론

일사부재리(§ 163)에 저촉되지 아니한다.

3. 중복심판금지 저촉 여부

(1) 근거 — 특허법 제154조 제8항에 의한 민사소송법 제259조 준용

특허법 제154조 제8항은 심판에 관하여 **민사소송법 제259조(중복된 소제기의 금지)를 명문으로 준용**한다. 따라서 “법원(특허심판원)에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 (심판)을 제기하지 못한다”는 중복심판금지 법리가 심판절차에도 그대로 적용된다.

(2) 심결취소소송 계속 중 ‘심판 계속’ 인정 여부

‘전 심판의 계속 중’이란 전 심판에서 내려진 심결이 확정되지 아니한 경우를 의미하므로, 특허심판원에 계속 중인 경우뿐만 아니라 특허법원·대법원에 계속 중인 경우도 포함한다. 이를 좁게 해석할 경우 심결취소소송 제기 후 확정 전에 동일심판을 다시 청구하여도 일사부재리에 저촉되지 아니하여(2009후 2234 참조) 무용한 절차반복 방지라는 중복심판금지 규정의 입법취지에 반하기 때문이다.

(3) 사건의 동일성

중복심판금지에서 사건의 동일성은 **당사자와 청구(심판대상)**를 기준으로 하고, 등록무효심판에서 무효사유는 공격방법에 불과하므로 무효사유가 다르다는 것만으로 동일성이 부정되지 아니한다.

(4) 판단 기준시 — 후심판의 ‘심결 시’

중복심판청구 금지는 심판청구의 적법요건이므로, 민사소송의 중복제소금지가 사실심 변론종결시를 기준으로 판단되는 것과 마찬가지로 **후심판의 ‘심결 시’를 기준으로** 전심판의 계속 여부를 판단하여야 한다(2016후2317). 위 2009후2234 전원합의체가 채택한 심판청구시 기준은 일사부재리의 선행 심결 확정 판단에 한정된 것이므로 중복심판청구에 그대로 적용할 것은 아니다.

(5) 사안 포섭

① 2차 심판청구 시(2019. 1. 16.) 1차 심판은 상고심에 계속 중이었으므로 ‘전 심판 계속 중’이었다. ② 1차·2차 심판은 모두 甲이 특허발명 X의 청구범위 전부에 대하여 등록무효를 구하는 것으로서 당사자와 청구가 동일하고, 무효사유(진보성 ↔ 기재불비·미완성)의 차이만으로 동일성이 부정되지 아니한다. ③ 그러나 판단 기준시인 2차 심판의 **심결 시에는 대법원판결(2019. 1. 17.) 선고로 1차 심결이 확정되어 전심판의 계속이 소멸**하므로, 중복심판청구에 해당하지 아니한다.

(6) 결론

중복심판금지(§ 154⑧, 민소 § 259 준용)에도 저촉되지 아니한다.

4. 판단 기준시의 논거 — 심판청구권 보장과 모순·저촉 방지의 이익형량

일사부재리의 기준시가 심판청구 시로 변경된 결과, 사안과 같이 전심판 계속 중 청구된 후심판이 그 심결 시에 전심판의 확정으로 중복상태가 해소되면 중복심판청구에도, 일사부재리에도 해당하지 아니하여 **심결의 모순·저촉이 발생할 여지**(공백)가 생긴다. 그러나 대법원은 이를 일사부재리 기준시 변경에 따른 **불가피한 공백**으로 보고, 이 공백을 메우기 위하여 중복심판청구의 판단 기준시까지 심판청구 시로 앞당겨 얻는 이익(심결의 모순·저촉 방지)이, 전심판 계속 중이라는 이유만으로 — 심결 전에 전심판의 계속이 소멸될 여지가 있음에도 — 후심판 청구가 전면적으로 제한되는 문제보다 크다고 할 수 없다고 하였다(2016후2317 판시이유). 즉 당사자의 **심판청구권(재판청구권) 보장**의 이익이 **심결의 모순·저촉 방지의 취지보다 크다는** 이익형량에 기초하여 심결 시 기준을 채택한 것이다.

5. 결론

2차 심판청구는 청구 시를 기준으로 1차 심결이 확정되지 아니하였고 무효사유도 동일하지 아니하여 **일사부재리에 저촉되지 아니하고**, 심결 시를 기준으로 전심판의 계속이 소멸하여 **중복심판금지에 저촉되지 아니한다**. 따라서 특허심판원은 甲의 청구를 각하하지 아니하고 **본안심리를 진행**하여야 한다.

II. 설문 (2) — 권리남용 해당 여부 [5점]**1. 문제의 소재**

일사부재리·중복심판금지에 형식적으로 저촉되지 않더라도, 반복적 무효심판 청구가 권리남용(민법 § 2②)에 해당하여 부적법 각하되어야 하는지가 문제된다.

2. 관련 법리

중복심판금지는 그 자체가 **동일 당사자에 의한 심판청구권의 남용을 방지**함으로써 심결의 모순·저촉을 방지하고 심판절차의 경제를 꾀하기 위한 제도이다(대법원 2016후2317). 나아가 대법원은 그 적용에서도 심판청구권 보장을 중시하여, 전심판 계속 중의 후심판 청구를 전면적으로 제한하지 아니하고 그로 인한 심결의 모순·저촉의 여지는 불가피한 공백으로 수용하였다. 따라서 일사부재리·중복심판금지라는 제도적 한계에 저촉되지 아니하는 반복 청구를 곧바로 권리남용이라 할 수는 없고, **동일한 무효사유**를 반복 주장하거나 소송지연·상대방 괴롭힘의 부당한 목적이 명백한 경우 등에 한하여 남용이 인정될 수 있다.

3. 사안 포섭

甲의 2차 심판청구는 1차 심판과 무효사유(진보성 vs. 기재불비·미완성)가 **명백히 상이하여** 이를 청구할 정당한 이익이 인정되고, 전심판 확정 직전의 후심판 청구는 판례가 심판청구권 보장의 관점에서 제도상 허용되는 것으로 본 행위 태양이다. 대법원판결 하루 전에 청구한 점만으로 소송지연·상대방 괴롭힘의 부당한 목적이 있다고 단정하기 어렵다.

4. 결론

甲의 2차 심판청구는 **권리남용에 해당하지 아니한다**.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특정 포인트
일사부재리(\$163) 적용 여부	6점	조문(\$163 본문·단서)·판단시점 판례(대법원 2009후2234 전합)·동일사실 여부(진보성↔기재불비·미완성)·소결
중복심판금지 적용 여부	6점	적용 법규정(\$154⑧)에 의한 민소\$259의 직접 준용·심결취소소송 계속 중 심판 계속 여부·사건의 동일성(무효사유=공격방법)·판단 기준시(후심판 심결 시, 2016후2317)와 이익형량(심판청구권 보장>모순·저촉 방지)·소결
2차 심판청구에 대한 조치(본안심리 진행)	3점	각하 사유 부존재 → 본안심리 진행 결론
권리남용 해당 여부	5점	중복심판금지의 취지(심판청구권 남용 방지, 2016후2317)와 심판청구권 보장 중시의 판례 태도 제시·무효사유 상이+부당 목적 불인정 → 권리남용 부정
합계	20점	

축별 채점 기준

1) 논점 추출 (약 40%)

- 2차 심판청구 시점(2019.1.16.)이 대법원판결 선고 전달일을 포착하여 청구시 1차 심결이 확정되지 않았다는 사실을 논거로 사용했는가.
- 무효사유가 1차(진보성)와 2차(기재불비·미완성)로 **다르다**는 사실을 포착하여 '동일사실' 요건 및 권리남용 판단에 연결했는가.
- 일사부재리·중복심판금지를 **별도의 요건**으로 분리 검토했는가(몽둥이로만 감점).
- (2)에서 중복심판금지의 취지(심판청구권 남용 방지)와 심판청구권 보장 중시의 판례 태도(2016후2317)를 권리남용 판단에 연결했는가.

2) 목차·구성 (약 25%)

- 설문 (1)을 '일사부재리 / 중복심판금지 / 판단 기준시의 이익형량 / 결론'으로 목차화했는가.
- 각 쟁점마다 조문 → 요건(판단시점·동일사실 등) → 사안포섭 → 소결의 순서로 통일된 구조를 유지했는가.
- 배점(15:5)에 맞게 (1)에 지면을 두텁게, (2)는 간결하게 배분했는가.

3) 답안 작성·논증 (약 35%)

- 제163조 조문을 정확히 인용하고('이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때', 각하심결 제외 단서 포함), 판단시점에 관한 **대법원 2009후2234 전 원합의체** 판결(심결시→심판청구시로 변경, 대세효로 인한 제3자 권리 제한 최소화)을 명시했는가.
- 중복심판금지의 근거로 **특허법 제154조 제8항이 민사소송법 제259조(중복된 소제기의 금지)를 직접 준용**한다는 점을 정확히 적시했는가.
- 청구시 기준 1차 심결이 미확정이었다는 점 + 무효사유가 상이하여 '동일사실'이 아니라는 점을 **이중으로** 논증했는가.
- 중복심판금지에서 심결취소소송 계속 중이 '심판 계속 중'에 포함되는지와 판단 기준시(후심판 심결 시)의 논거인 이익형량(심판청구권 보장 > 모순·저촉 방지, 2016후2317 판시이유)을 논증했는가.
- 결론(본안심리 진행 / 권리남용 부정)이 명확하고 본문 논거와 일치하는가.

감점 주의

- 일사부재리와 중복심판금지를 구분하지 않고 몽쳐서 서술.
- 제163조를 '무효심판에 한정된 규정'으로 오독하거나 각하심결 단서를 누락한 채 인용.
- 중복심판금지의 근거로 제154조 제8항에 의한 제259조 준용을 명시하지 않고 '명문 규정 없음'이라고만 서술.
- 판단시점 판례(전원합의체 변경 판례)를 언급하지 않고 결론만 기재.
- 무효사유가 진보성↔기재불비·미완성으로 다르다는 사실 자체를 놓치고 '동일사실 여부' 검토 누락.
- 권리남용을 상표법·특허권 행사 국면의 권리남용과 혼동하여 서술.
- 사안 특유의 시점(2019.1.16. vs 2019.1.17.)을 포섭하지 않은 채 일반론 나열.
- 중복심판의 사건 동일성을 무효사유의 차이만으로 부정하는 오류(무효사유는 공격방법).

2021년 제3문

사례형

30점

문제

甲은 잉크젯프린터에서 잉크카트리지와 잉크젯프린터 본체의 결합에 특징이 있는 발명에 대한 특허권자이다.

乙은 상기의 특허된 잉크젯프린터를 판매하고 있으며, 이러한 잉크젯프린터에 사용되는 소모품으로 甲의 특허된 잉크젯프린터에만 사용할 수 있는 잉크카트리지도 甲과 무관한 외국의 제조업자로부터 수입하여 판매하고 있다.

丙은 乙로부터 잉크젯프린터를 구입하여 가정용으로 사용하고 있고, 잉크카트리지가 다 소모된 경우에는 시장에서 다양한 잉크젯프린터에 사용할 수 있는 잉크를 구입하여 이를 직접 충전하여 사용하고 있다.

丁은 乙로부터 잉크젯프린터를 구입하여 인쇄소에서 업무용으로 사용하고 있는데, 잉크카트리지가 모두 소모된 경우에는 乙이 판매하는 잉크카트리지를 구입하여 기존의 잉크카트리지를 제거하고 이를 삽입하여 사용하고 있다.

(1) 다음 물음에 답하시오. (10점)

1. 丙이 乙로부터 잉크젯프린터를 구입하여 사용하는 행위가 甲의 특허권을 직접침해하는 행위인지 설명하시오. (4점)
2. 丙이 乙로부터 구입한 잉크젯프린터의 잉크카트리지가 다 소모된 이후에 시장에서 다양한 종류의 잉크젯프린터의 잉크카트리지에 사용될 수 있는 잉크를 구입 및 충전하여 사용하는 행위가 甲의 특허권을 간접침해하는 행위인지 설명하시오. (6점)

(2) 丁의 행위는 甲의 특허권을 직접침해하는지에 대하여 설명하시오. (10점)

(3) 乙의 잉크카트리지 수입·판매 행위가 甲의 특허권을 직접침해, 간접침해 하는지 여부에 대하여 모두 설명하시오. (10점)

모범답안

문제 3 모범답안

I. 설문 (1)

1. 소문 1) 丙의 프린터 구입·사용의 직접침해 여부

(1) 문제의 소재

직접침해가 성립하기 위해서는 특허권의 존속 중에 정당한 권원이 없는 자가 **업으로서 특허발명을 실시**하여야 한다(§ 94①). 물건의 발명에서 실시란 그 물건을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말하므로(§ 2(3) 가목), 丙이 잉크젯프린터를 사용하는 행위는 '사용'으로서 특허발명의 실시에 해당한다. 다만 '**업으로서**'의 **실시인지**, **특허권이 소진되어 丙이 정당한 권원을 취득하는지**가 문제된다.

(2) '업으로서'의 실시인지

'업으로서'란 널리 사업으로서 실시하는 것을 의미하고, 개인적·가정적 실시는 이에 포함되지 아니한다. 특허권의 효력을 산업상 실시에 한정하여 개인의 사적 영역에까지 미치지 않도록 하려는 취지이다. 丙은 프린터를 **가정용**으로 사용하고 있으므로 그 사용은 업으로서의 실시에 해당하지 아니한다.

(3) 권리소진 여부

특허권자 또는 그로부터 허락을 받은 자가 국내에서 특허물건을 적법하게 양도한 경우, 그 물건에 관한 특허권은 이미 목적을 달성하여 **소진**되고, 양수인이나 전득자가 그 물건을 사용·양도하는 행위에는 특허권의 효력이 미치지 아니한다(대법원 2017다289903 참조). 사안에서 乙이 판매하는 잉크젯프린터가 甲 또는 그로부터 허락을 받은 자에 의하여 적법하게 양도된 것이라면, 丙의 구입으로 그 프린터에 관한 특허권은 소진되어 丙은 정당한 권원을 가진다.

(4) 결론

丙의 프린터 사용은 가정용으로서 '업으로서'의 실시가 아니므로 **권리소진 여부와 관계없이 직접침해가 성립하지 아니하고**, 권리소진이 인정되는 경우에는 丙이 정당한 권원까지 가지게 되어 더욱 그러하다.

2. 소문 2) 丙의 잉크 구입·충전의 간접침해 여부

(1) 적용 법규정과 문제의 소재 — 제127조 제1호

특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 **생산에만 사용하는 물건**을 업으로서 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위는 특허권을 침해한 것으로 본다. 丙은 잉크를 **구입하여 충전**하였을 뿐 잉크를 생산·양도·대여·수출·수입하거나 그 청약을 한 것이 아니므로, 잉크 자체를 기준으로 위 행위 태양에 해당할 여지가 없다. 결국 사안에서는 甲의 특허된 잉크젯프린터의 생산에만 사용하는 물건인 **잉크카트리지를** 기준으로, 소모된 카트리지에 잉크를 충전하는 행위가 그 **잉크카트리지의 '생산'**에 해당하는지, 나아가 '**업으로서**'의 행위인지가 문제된다.

(2) 잉크카트리지의 '생산'에 해당하는지 — 제품의 동일성 관점

사용 중인 물건에 대한 가공·부품 교체가 **제품의 동일성을 유지**하는 범위 내의 **단순한 수리·개조**에 그치는 경우에는 '생산'에 해당하지 아니하나, 제품의 동일성을 상실시켜 새로운 물건을 만들어 내는 것으로 평가되는 경우에는 **재생산**으로서 '생산'에 해당한다. 사안에서 소모된 잉크를 다시 채워 넣는 행위는 카트리지 본래의 형상·구조에 변경을 가하지 아니하는 단순한 수리·개조로 볼 여지가 있으나, 잉크가 다 소모되어 사용이 끝난 카트리지를 다시 사용 가능한 상태로 만드는 재생산으로 볼 여지도 있어, 어느 관점을 취하느냐에 따라 '생산' 해당 여부가 달라진다.

(3) '업으로서'인지

그러나 丙의 잉크 구입·충전·사용은 **가정용**에 그치므로 어느 경우에도 '업으로서'의 행위에는 해당하지 아니한다. 간접침해는 직접침해의 개연성이 높은 예비적 행위를 침해로 의제하는 제도인 점에 비추어 보더라도, 가정 내 사적 실시에 대하여는 그 개연성을 인정하기 어렵다.

(4) 결론

잉크의 충전이 잉크카트리지의 재생산에 해당하는지는 제품의 동일성 관점에 따라 달라질 수 있으나, 丙의 행위는 업으로서의 행위가 아니므로 **간접침해는 성립하지 아니한다**.

II. 설문 (2) — 丁의 행위의 직접침해 여부**1. 문제의 소재**

직접침해가 성립하려면 정당한 권원이 없는 자가 **업으로서** 특허발명을 실시하여야 하는데 (§ 94①), 丁의 구입은 실시가 아니나 사용은 실시에 해당하고 **인쇄소 업무용**이므로 '**업으로서**'의 요건을 충족한다. 丁의 행위는 1) 구입 후 프린터의 **사용**, 2) 소모된 카트리지의 **제거·삽입**, 3) **그 후의 사용**으로 나뉘는바, 권리소진 여부와 재생산('생산') 해당 여부에 따라 행위별로 침해 여부가 문제된다.

2. 실시행위의 독립성**(1) 일반론**

실시행위는 행위 태양마다 **독립하여** 침해 여부를 판단한다(실시행위 독립의 원칙). 어느 실시행위가 침해가 아니라고 하여 다른 실시행위까지 당연히 침해가 부정되는 것은 아니다.

(2) 사안

丁의 처음 사용, 카트리지의 제거·삽입(생산 여부), 그 후의 사용은 각각 나누어 침해 여부를 판단하여야 한다.

3. 권리소진 여부**(1) 일반론**

특허권자 또는 그로부터 허락을 받은 자가 국내에서 특허물건을 적법하게 양도한 경우 그 물건에 관한 특허권은 목적을 달성하여 소진되고, 양수인은 소진의 범위 내에서 이를 사용할 수 있다.

(2) 사안

乙이 판매하는 프린터가 甲 또는 그로부터 허락을 받은 자에 의하여 적법하게 양도된 것이라면 그 프린터에 관한 특허권은 소진되나, 그렇지 않다면 丁은 정당한 권원을 갖지 못한다.

4. 카트리지 제거·삽입이 재생산('생산')에 해당하는지 — 제품의 동일성 관점**(1) 판단기준**

종래 판례는 소모품의 교체에 관하여, 완제품 특허권자가 소모품 유통시장(after market)에서 과도한 독점권을 갖는 것을 방지하기 위하여 1) 본질적 구성요소 2) 입수 곤란 3) 교체 예정 4) 특허권자 측의 별도 제조·판매를 요구하여 '생산'을 엄격하게 인정하였다(대법원 98후2580). 그러나 **최근 판례는 판단기준을 달리하여**, 수리나 부품 교체가 원래 제품과의 **동일성을 해할 정도**에 이르면 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지로 **재생산**으로서 특허권을 침해하나, 교체 이후에도 **동일성이 유지**되면 제품 사용의 일환으로 허용되는 **수리**에 해당한다고 보고, 이는 당해 제품의 **객관적 성질, 이용형태 및 특허법의 규정취지** 등을 종합하여 판단한다(대법원 2017다289903). 본질적 부분의 교체라면 곧 생산이 된다는 종래 판례보다 **수리의 범위를 넓게 인정**하려는 경향이다.

(2) 사안 포섭

甲의 특허발명은 카트리지와 본체의 **결합** 자체에 특징이 있으므로, 기존 카트리지를 제거하고 甲과 무관한 비정품을 삽입하는 행위는 특징적 구성인 결합을 새로 만들어 내는 것이어서, 제품의 객관적 성질과 이용형태에 비추어 원래 제품과의 **동일성을 해하는 실질적 재생산**으로서 '생산'에 해당한다고 볼 여지가 크다.

5. 결론 — 실시행위별 판단**(1) 권리소진이 적용되지 않는 경우**

丁은 정당한 권원 없이 업으로서 실시하는 것이므로, 1) 처음의 사용은 직접침해이고, 2) 카트리지의 제거·삽입은 재생산으로 평가되면 '생산'으로서 직접침해이며, 3) 그 후의 사용 역시 직접침해이다.

(2) 권리소진이 적용되는 경우

① 처음의 사용은 소진의 범위 내로서 직접침해가 아니다. ② 카트리지의 제거·삽입은 원래 제품과의 동일성을 해하는 **재생산으로 평가되면** '생산'으로서 직접침해가 되나, 동일성이 유지되는 **수리·개조에 그치면** 직접침해가 아니다. ③ 그 후의 사용은 재생산이라면 재생산된 물건에 소진의 효력이 미치지 아니하여 직접침해가 되고, 수리에 그친다면 소진 범위 내의 사용으로서 직접침해가 아니다.

(3) 사안

재생산으로 평가될 여지가 큰 이상, 丁의 카트리지 제거·삽입과 그 후의 사용은 甲의 특허권을 **직접침해할 가능성이 크다**.

Ⅲ. 설문 (3) — 乙의 카트리지 수입·판매의 침해 여부**1. 직접침해 여부****(1) 직접침해의 성립요건**

직접침해는 특허권의 존속 중에 정당한 권원이 없는 자가 **업으로서** 특허발명을 실시하는 것으로서, 실시의 대상이 특허발명의 **보호범위에 속하여야** 한다. 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고(§ 97), 보호범위에 속하는지는 청구범위에 기재된 **구성요소 전부**를 그대로 실시하여야 한다는 **구성요소완비의 원칙**에 의하되, 일부 구성을 변경한 경우에도 과제해결원리가 동일하고 실질적으로 동일한 작용효과를 가지며 그 변경이 용이한 때에는 보호범위에 속한다는 **균등론**이 예외적으로 적용된다(대법원 2013다14361·2014후2788).

(2) 사안

甲의 특허발명은 카트리지와 본체의 결합체인 잉크젯프린터인데, 乙이 수입·판매하는 것은 **카트리지 단독**으로서 본체 등 나머지 **구성요소를 생략한** 실시이고, 구성의 변경이 아니라 결여이므로 균등론이 적용될 여지도 없다. 구성요소완비의 원칙상 특허발명의 보호범위에 속하지 아니하므로 乙의 **수입·판매는 모두 직접침해에 해당하지 아니하고**, 직접침해가 부정되는 이상 수입에 따른 국제소진 여부는 논할 실익이 없다.

2. 간접침해 여부**(1) 간접침해의 성립요건**

특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 **생산에만 사용하는 물건을 업으로서** 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 양도·대여의 청약을 하는 행위는 특허권을 침해한 것으로 본다(§ 127(1)). 이는 장래 특허권 침해의 개연성이 높은 예비적 행위를 침해로 의제하여 특허권 구제의 실효성을 높이려는 것이다(대법원 2007후3356 참조). 한편 간접침해의 성립에 직접침해의 성립이 전제되어야 하는지에 관하여 **독립설과 종속설**이 대립하나, 사안에서는 丁과 같이 업으로서 사용하는 구매자가 존재하므로 어느 견해에 의하더라도 결론에 차이가 없다.

(2) 사안

'생산에만' 사용하는 물건이란 다른 용도가 사회통념상 통용·승인되지 아니하는 것을 말하는바(대법원 2007후3356 참조), 乙이 수입·판매하는 카트리지는 甲의 특허된 잉크젯프린터**에만** 사용할 수 있는 것이고, 乙은 이를 **업으로서** 수입·판매하고 있으므로, '에만'과 '업으로서' 요건은 사안에서 전제되어 있다. 실제로 乙의 카트리지 구매자 중에는 丁과 같이 소모된 카트리지를 제거하고 이를 삽입하여 업무용으로 사용하는 자가 존재한다. 결국 카트리가 특허 프린터의 **'생산'**에 사용하는 물건인지, 즉 구매자가 소모된 카트리지를 제거하고 이를 삽입하는 행위가 프린터의 재생산('생산')에 해당하는지가 관건인바, 앞서 본 바와 같이(설문 (2)) 결합에 특징이 있는 발명에서 이는 원래 제품과의 동일성을 해하는 **재생산으로 평가될 여지가 크다**. 재생산('생산')에 해당한다면 乙의 **수입·판매는 모두 간접침해에 해당한다**.

3. 결론

乙의 카트리지 수입·판매는 구성요소를 생략한 실시로서 **직접침해에 해당하지 아니하나**, 구매자의 카트리지 교체가 프린터의 재생산으로 평가될 여지가 큰 이상 **간접침해에 해당할 가능성이 크다**.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	득점 포인트
(1)-1) 丙의 프린터 구입·사용의 직접침해 여부	4	① 직접침해 요건 제시 후 사용=실시(제2조 제3호 가목)임을 전제로 '업으로서'·권리소진 2쟁점 추출 ② 가정용 사용은 '업으로서' 결여 ③ 권리소진 일반론(적법 양도 시 소진·소진 범위 내 사용, 2017다289903) 검토 ④ 업 요건 결여로 권리소진 여부와 관계없이 직접침해 불성립 결론
(1)-2) 丙의 잉크 구입·충전의 간접침해 여부	6	① 제127조 제1호 요건 제시 ② 丙은 잉크를 생산·양도 등 한 바 없어 잉크 기준으로는 행위 태양 불해당 → 전용품=잉크카트리지의 '생산'·인지로 쟁점 전환 ③ 제품의 동일성 관점 — 단순한 수리·개조 vs 재생산에 따라 갈림 ④ 가정용은 '업으로서' 결여(직접침해 개연성 관점 간단히) → 간접침해 부정
(2) 丁의 카트리지 교체 사용의 직접침해 여부	10	① 직접침해 요건 — 사용=실시, 인쇄소 업무용=업으로서 ○ ② 실시행위의 독립성을 독립 논점으로 기술하고 행위별(처음 사용/제거·삽입/그 후 사용) 판단 구조화 ③ '생산' 판단기준의 변화 — 종래 소모품 4요건(98후2580) → 최근 동일성 기준(객관적 성질·이용형태·규정취지 종합, 대법원 2017다289903, 수리 범위 확대 경향) ④ 결합에 특징+비정품 → 동일성을 해하는 실질적 재생산 포섭 ⑤ 실시행위별 결론 — 소진 부적용 시 사용·재생산·그 후 사용 모두 직접침해 / 소진 적용 시 처음 사용 비침해, 제거·삽입과 그 후 사용은 재생산 여부에 따라 갈림
(3) 乙의 카트리지 수입·판매의 직·간접침해 여부	10	① 직접침해 요건 — 보호범위 속부는 구성요소완비의 원칙·균등론으로 판단 ② 카트리지 단독=구성요소 생략 실시 → 수입·판매 모두 직접침해 부정 ③ 간접침해(\$127(1)) 요건 — '에만'·'업으로서'는 사안상 전제 ④ 카트리지 교체가 프린터의 재생산('생산')·인지로 쟁점 수렴 — 재생산 평가 여지 크면 수입·판매 모두 간접침해

배점 합계: 30점

특별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- (1)-1)에서 '업으로서' 요건과 권리소진을 모두 쟁점으로 추출하고, 가정용 사용의 업 요건 결여로 권리소진 여부와 관계없이 직접침해가 부정됨을 논증했는가.
- (1)-2)에서 전용품인 잉크카트리지의 '생산' 해당성(제품의 동일성 관점 — 수리·개조 vs 재생산)과 '업으로서' 요건을 짚고, 업 요건 결여를 결정적 근거로 간접침해를 부정했는가.
- (2)에서 실시행위 독립의 원칙에 따라 권리소진 여부·재생산 여부의 경우의 수를 구조화하고, 소모품 교체의 '생산' 해당성(대법원 판례 법리)을 핵심 쟁점으로 파악했는가.
- (3)에서 구성요소완비의 원칙으로 직접침해를 부정하고, '에만'·'업'이 전제된 사안에서 '생산' 해당성으로 간접침해 쟁점을 수렴시켰는가.
- 배점(4/6/10/10)에 맞추어 쟁점의 두께가 조절되었는가.

2) 목차·구성(25%)

- 소문별 목차를 명확히 구분하고, 각 소문 내에서 '조문 → 판례 → 사안 포섭 → 소결' 흐름을 유지했는가.
- (2)는 일반론/사안 세부 목차와 실시행위별 결론 구조를, (3)은 직접침해·간접침해의 병렬 항목화를 갖췄는가.
- 일반론(실시행위 독립원칙·소진론)은 최소로 하고 사안 포섭에 지면을 배분했는가.

3) 답안 작성·논증(35%)

- 제2조 제3호(실시 — 수출 포함 현행 문언), 제94조, 제97조, 제127조 제1호 등 조문을 정확히 인용했는가.
- '생산' 판단기준의 변화(종래 소모품 4요건 98후2580 → 제품의 동일성 기준·객관적 성질·이용형태·규정취지 종합, 대법원 2017다289903)를 제시하고 동일성 관점에서 사안에 포섭했는가.
- 결합발명에서 카트리지가 특징적 구성이라는 사안 특유의 사실을 결론 도출에 활용했는가.
- (1)-2)에서 가정 내 사적 실시와 간접침해 제도 취지의 관계를 간단히 짚고, (3)에서 독립설·종속설 대립이 丁(업무용 사용자)의 존재로 결론에 차이가 없음을 논증했는가.
- 결론이 논증과 일관되며 명확한가.

감점 주의

- 丙의 프린터 '구입' 자체를 실시로 보아 침해 판단하는 오류.
- '업으로서' 요건을 검토하지 않고 가정용 사용을 침해로 판단.
- (1)-2)에서 쟁점을 잉크 자체의 전용품성으로만 파악하여 카트리지의 '생산' 해당성(수리·개조 vs 재생산) 논의를 누락.
- (2)에서 소진론만 언급하고 카트리지 교체의 '생산' 해당성 판단기준을 누락.
- (3)에서 카트리지만의 수입·판매를 특허품(프린터)의 직접침해로 오인.
- 조문 전사·일반론(간접침해 취지) 장황 서술, 결합발명 사실 미활용.

2021년 제4문

사례형

20점

문제

甲은 스마트폰에 대한 특허권자로 매월 10,000 대씩 연간 120,000 대의 생산능력을 가지고 있는 공장 설비를 2019년에 구축하였는데 2020년 5월과 6월의 2개월 동안에는 신규 설비로 교체하는 공사관계로 스마트폰을 생산할 수 없었다. 甲은 2020년에 스마트폰 1대당 1,000,000 원에 70,000 대를 판매하였으며 1대당 200,000 원의 이익을 얻었다.

乙은 甲의 특허권을 침해하는 스마트폰을 매년 80,000 대를 생산할 수 있는 공장설비를 갖추고 있다. 乙은 2020년에 스마트폰을 1대당 800,000 원에 50,000 대를 판매하여 1대당 150,000 원의 이익을 얻었다. 한편 스마트폰과 같은 통신기기 시장에서 합리적 실시료율은 판매액의 5 %이다.

甲이 乙의 침해행위 이외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 없다면, 甲이 乙의 2020년 한 해 동안의 특허권 침해에 따른 손해액으로, 특허법 제128조(손해배상청구권 등) 각 항의 규정에 근거하여 주장할 수 있는 손해배상액에 대한 다음 물음에 답하시오. (단, 계산과정을 포함한다.)

- (1) 특허법 제128조 제5항에 따른 손해액을 구하시오. (5점)
- (2) 특허법 제128조 제4항에 따라 손해액으로 추정되는 액수를 구하시오. (5점)
- (3) 특허법 제128조 제2항 제1호 및 제2호에 따른 손해액의 합을 구하시오. (10점)

모범답안

I. 설문 (1) — 특허법 제128조 제5항에 따른 손해액 (5점)

1. 적용 법규정

특허법 제128조 제5항은 특허권자가 특허발명의 실시에 대하여 "합리적으로 받을 수 있는 금액"을 손해액으로 청구할 수 있도록 한다. 침해자의 이익이나 특허권자의 판매감소 입증이 어려운 경우의 최소한의 손해 보전 규정이다.

2. 사안 적용

합리적 실시료율은 판매액의 5%이고, 乙의 2020년 판매액은 50,000대 × 800,000원 = 40,000,000,000원(400억 원)이다.

3. 결론

손해액 = 50,000 × 800,000 × 0.05 = **2,000,000,000원**(20억 원)이다.

II. 설문 (2) — 특허법 제128조 제4항에 따른 추정 손해액 (5점)

1. 적용 법규정

제128조 제4항은 침해자가 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자의 손해액으로 추정한다.

2. 사안 적용

乙은 스마트폰 50,000대를 판매하여 1대당 150,000원의 이익을 얻었으므로, 침해로 인한 이익액은

50,000대 × 150,000원 = **7,500,000,000원**(75억 원)이다.

3. 결론

손해액은 75억 원으로 추정된다. 다만 甲의 생산가능수량이 100,000대에 그쳐 침해수량 전부를 甲이 판매할 수 있었다고 보기 어려운 사정 등 실손해액이 추정액에 미치지 못함을 乙이 입증하면, 제128조 제4항 추정의 일부 복명이 가능하다.

III. 설문 (3) — 특허법 제128조 제2항 제1호·제2호의 합계 (10점)

1. 적용 법규정 및 구조

제128조 제2항은 침해자가 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때, 다음 각 호에 해당하는 금액의 **합계액**을 손해액으로 할 수 있도록 한다. 제1호는 「그 물건의 양도수량(침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 수량을 뺀 수량) 중 특허권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에

서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘지 아니하는 수량」에 「침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액」을 곱한 금액이고, 제2호는 「양도수량 중 위 수량을 넘는 수량」(특허권자가 실시권의 설정·허락을 할 수 있었다고 인정되지 아니하는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대한 「특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액」이다.

2. 법문의 요소별 수치 확정

그 물건의 양도수량은 50,000대이고, 발문상 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 없으므로 뺀 수량은 없다. 생산할 수 있었던 물건의 수량은 월 10,000대 $\times$ 12개월 = 120,000대에서 2020년 5·6월 조업불능분 20,000대를 뺀 100,000대이고, 실제 판매한 물건의 수량은 70,000대이므로, 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량은 $100,000 - 70,000 = 30,000$ 대이다. 단위수량당 이익액은 200,000원이고, 합리적으로 받을 수 있는 금액은 판매가 $800,000\text{원} \times 5\% =$ 대당 40,000원이다.

3. 제128조 제2항 제1호

양도수량 50,000대 중 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량(30,000대)을 넘지 아니하는 수량 = 30,000대이다.

제1호 금액 = 30,000대 $\times$ 단위수량당 이익액 200,000원 = 6,000,000,000원(60억 원)이다.

4. 제128조 제2항 제2호

양도수량 중 위 수량을 넘는 수량 = $50,000 - 30,000 = 20,000$ 대이다. 甲이 이 수량에 대하여 실시권의 설정·허락을 할 수 있었다고 인정되므로 뺀 수량은 없다.

제2호 금액 = 20,000대 $\times$ 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액 40,000원 = 800,000,000원(8억 원)이다.

5. 결론

제1호 금액과 제2호 금액의 합계액 = 60억 원 + 8억 원 = 6,800,000,000원(68억 원)이다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	득점 포인트
설문(1) 제128조 제5항 실시료 상당액 산정	5	침해자 판매액(50,000×800,000) × 5% = 20억 원 도출
설문(2) 제128조 제4항 침해자 이익 추정	5	50,000대 × 단위이익 150,000원 = 75억 원 산출. 甲의 생산능력(100,000대) 언급으로 일부 복멸 가능성 부기
설문(3)-① 제128조 제2항 제1호	5	생산할 수 있었던 물건의 수량 산정에서 5·6월 조업불능 반영(120,000-20,000=100,000), 양도수량 50,000대 중 '생산할 수 있었던 물건의 수량'에서 실제 판매한 물건의 수량(70,000)을 뺀 수량(30,000)을 넘지 아니하는 수량' 30,000대 × 단위수량당 이익액 200,000원 = 60억 원
설문(3)-② 제128조 제2항 제2호	5	양도수량 중 위 수량을 '넘는 수량' 20,000대(실시권 설정·허락 가능 인정 → 뺄 수량 없음) × 합리적으로 받을 수 있는 금액 (800,000×5%=40,000) = 8억 원 . 제1호·제2호 합계액 68억 원

합계 20점

축별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- (+) 5·6월 조업불능이 제128조 제2항 제1호의 "생산할 수 있었던 물건의 수량"에 반영되는 사정임을 포착
- (+) 발문의 "침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 없다"는 단서를 정확히 해석(양도수량 감산 없음)
- (+) 제128조 제2항 제1호와 제2호의 병용 구조('넘는 수량'에 대한 합리적 실시료) 파악
- (-) 제128조 제5항·④·② 각 조항의 산정기초(양도수량·이익·실시료율)를 뒤섞어 계산
- (-) 甲의 단위이익과 乙의 단위이익을 혼동

2) 목차·구성(25%)

- (+) 설문 (1)/(2)/(3) 각각을 "조문 → 요건 → 사안 대입 → 계산 → 결론" 4단 구성으로 정리
- (+) (3)에서 1호·2호를 소목차로 분리 서술
- (-) 일반론(손해배상 취지, 개정 연혁 등)에 과다한 지면 할애
- (-) 계산과정 없이 결과만 기재

3) 답안 작성·논증(35%)

- (+) 각 항 계산식·단위·최종 금액을 명시(발문 단서 "계산과정 포함" 준수)
- (+) 제128조 제2항 제1호의 법문 구조(양도수량 중 '생산할 수 있었던 물건의 수량'에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘지 아니하는 수량')를 그대로 사용해 계산
- (+) 제128조 제2항 제2호의 실시료 산정기초를 침해자 판매가격(800,000원)에 5% 적용한 근거 제시
- (-) 생산능력을 120,000대로 그대로 두어 미판매수량을 50,000대로 계산
- (-) 제128조 제5항에서 甲의 판매가(1,000,000원) 기준으로 계산

감점 주의

- 5·6월 조업불능을 제128조 제2항 제1호의 "침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정"으로 오해하여 양도수량에서 감산하는 실수(→ 문제는 이를 명시적으로 배제함; 생산능력 감소 사정으로만 반영)
- 제128조 제5항·④의 산정기초를 침해자 매출·이익이 아닌 甲의 것으로 오인
- 제128조 제2항 제2호에서 실시료 기준가격을 甲의 판매가로 계산
- "계산과정 포함" 단서 미준수(수식·단위 누락)

PART 13

2022

제1문	이 사건 발명에 대한 권리귀속(§33①·§37①, 2011다67705 — 재산권·양도성, 명시·묵시 이전) · 甲 출원의 적법성(§38①·대법원 2020후 10087)	30점
제2문	일사부재리 판단시점 판례 태도 · §163 단서 의의 및 각하심결 적용범위	20점
제3문	의약용도발명에서 약리기전의 지위 · 의약용도발명 진보성 판단기준 및 임상시험 확인 요부	30점
제4문	심결취소소송의 성격과 변론주의 적용 · 자백의 대상 — 사실 vs 법적 판단 구분	20점

2022년 제1문

사례형

30점

문제

甲은 자동차 전력공급장치를 개발·제조하여 판매하는 것을 업으로 하는 회사이고, 乙은 시판되는 차량에 적합한 자동차 전자장비 일체를 개발·제조하여 판매하는 것을 업으로 하는 회사이다.

甲은 ‘자동차 전력공급장치의 방수배선방식’(이하 ‘이 사건 특허’라 한다)에 관한 특허권자이자, ‘자동차 전력공급장치의 방수배선을 위한 회로덮개’(이하 ‘이 사건발명’이라 한다)의 발명자인 甲의 종업원으로부터 특허를 받을 권리를 승계받은자인데 甲은 아직까지 이 사건 발명을 출원하지 아니하였다. 甲은 乙에게 자신의 영업 일부를 양도하기로 하는 계약(이하 ‘이 사건 계약’이라 한다)을 체결하면서, 양도의 대상으로 이 사건 특허 및 이 사건 발명 관련 특허법상의 권리를 포함하였다. 위 사례를 토대로 다음 물음에 답하시오.

(1) 이 사건 계약의 이행이 완료된 후, 甲은 이 사건 발명을 지식재산처에 출원하였다. 이 사건 발명에 관한 권리귀속을 토대로 甲의 이 사건 발명의 출원이 적법한지를 판단하시오. (10점)

(2) 이 사건 계약의 이행이 완료된 후, 乙은 특허권 이전의 등록 없이 이 사건 특허를 실시하고 있다. 이에 甲은 乙의 이 사건 특허의 실시가 자신의 특허권을 침해하는 것이라고 주장한다. 이 사건 특허에 관한 권리귀속을 토대로 특허권 침해 여부에 대해 판단하시오. (10점)

(3) 특허심사관이 위 (1)에서 수험생이 제시한 결론과 달리 판단하여 특허결정하거나 거절결정하였다면 어떠한 특허심판을 청구해야 하는지에 대해 설명하고, 청구된 심판이 특허심판원에 계속 중 심판청구인이 동일한 심판을 다시 청구하였다면 특허심판원은 어떠한 판단 또는 조치를 취해야 하는지 설명하시오. (10점)

모범답안

문제 1 모범답안

I. 설문 (1) — 甲의 이 사건 발명 출원의 적법 여부

1. 문제의 소재

이 사건 계약의 이행 완료로 이 사건 발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리가 乙에게 이전되었는지(권리귀속), 그렇다면 권리를 양도한 甲이 한 출원이 적법한지(무권리자 출원)가 문제된다.

2. 이 사건 발명에 대한 권리귀속

(1) 관련 법리

발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(§ 33① 본문). 이 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만 **재산권으로서 양도성**을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(§ 37①), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 **명시적으로는 물론 묵시적으로도** 이루어질 수 있다(대법원 2011다67705).

(2) 사안의 포섭

이 사건 발명의 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자인 甲의 종업원에게 원시적으로 귀속되었다가 甲에게 승계되었고, 甲·乙은 이 사건 계약에서 이 사건 발명 관련 특허법상의 권리를 양도 대상에 **명시**하였으므로, 계약의 이행 완료로 그 권리는 **乙에게 이전**되었다. 따라서 현재의 권리귀속주체는 乙이다.

3. 甲 출원의 적법성

(1) 관련 법리

특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(§ 38①). 그러나 판례는, 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 **계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로** 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 **무권리자의 특허**이고, 제38조 제1항의 '제3자'는 그 권리에 관하여 **승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다**고 한다(대법원 2020후10087).

(2) 사안의 포섭

甲은 이 사건 계약으로 권리를 이전한 **양도인으로서 더 이상 권리귀속주체가 아니고**, 승계인 乙과 양립할 수 없는 법률상 지위를 새로 취득한 바도 없으므로 제38조 제1항의 '제3자'에 해당하지 아니한다. 따라서 乙이 아직 출원하지 않았다는 사정을 들어 甲이 자신의 출원을 정당화할 수 없고, 甲의 출원은 제33조 제1항 본문 위반의 **무권리자 출원**으로서 거절이유(§ 62(2))가 있으며, 착오로 설정등록되더라도 무효사유(§ 133①(2) 본문)에 해당한다.

4. 결론

이 사건 발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 乙에게 귀속되므로, 무권리자인 甲의 이 사건 발명 출원은 **부적법하다**.

Ⅱ. 설문 (2) — 乙의 실시가 甲의 특허권을 침해하는지

1. 문제의 소재

乙은 이 사건 특허에 관한 이전등록 없이 이를 실시하고 있으므로, 이 사건 특허권의 귀속을 먼저 확정된 뒤 乙의 실시가 침해에 해당하는지를 검토한다.

2. 이 사건 특허에 대한 권리귀속

(1) 일반 법리

특허권은 이전할 수 있으나(§ 99①), 특허권의 이전은 상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우를 제외하고는 **등록하여야만 효력이 발생한다**(§ 101①(1) — 효력발생요건). 판례도 영업양도는 채권계약이므로 재산의 이전에 포괄승계가 인정되지 아니하고 **재산의 종류에 따라 개별적으로 이전행위**를 하여야 한다고 한다(대법원 2019다225255).

(2) 사안의 포섭

이 사건 계약으로 甲은 乙에게 이 사건 특허권을 이전하여 줄 채권적 의무를 부담하게 되었으나, **이전등록이 마치지지 아니한 이상** 특허권 이전의 효력은 발생하지 아니한다. 따라서 이 사건 특허권의 귀속주체는 **여전히 甲**이다.

3. 특허권 침해 여부

(1) 일반 법리

특허권 침해가 성립하려면 특허권의 존속 중에 **정당한 권원이 없는 자가** 업으로서 특허발명을 실시하여야 한다. 정당한 권원은 물권적 실시권에 한정되지 아니하고, 허락에 의한 **통상실시권은 당사자 사이의 합의만으로 효력이 발생하며 등록은 대항요건**에 불과하다(§ 118). 나아가 특허권 양도계약의 양도인은 양수인에게 특허권을 이전하여 줄 의무와 함께 그때까지 양수인의 실시를 용인할 의무를 부담하므로, 양도계약에는 **이전등록 전 양수인의 실시**에 대한 **묵시적 허락**이 포함되어 있다고 해석함이 타당하다. 또한 양도인이 스스로 이전등록에 협력하지 아니한 채 양수인의 실시를 침해라고 주장하는 것은 **신의성실의 원칙에 반하여** 허용되지 아니한다.

(2) 사안의 포섭

乙은 이 사건 계약에 따라 이 사건 특허를 포함한 영업재산을 양수하였고 그 **이행이 완료**되었다. 따라서 乙의 실시는 이 사건 계약에 내재된 묵시적 실시 허락에 기한 것으로서 **정당한 권원**이 인정되고, 특허권을 양도해 놓고 이전등록의 형식만을 들어 침해를 주장하는 甲의 주장은 신의칙에도 반한다.

4. 결론

이 사건 특허권 자체는 이전등록이 없어 甲에게 남아 있으나, 乙은 계약의 효력에 따른 정당한 권원을 가지므로 乙의 실시는 甲의 특허권을 **침해하지 아니한다**.

Ⅲ. 설문 (3) — 청구할 심판과 중복 청구에 대한 심판원의 조치

1. 문제의 소재

설문 (1)의 결론은 甲의 출원이 무권리자 출원으로서 부적법하다는 것이다. 심사관이 이와 달리 판단하여 특허결정한 경우와 거절결정한 경우를 나누어 청구할 심판을 특정하고, 그 심판의 계속 중 동일한 심판을 다시 청구한 경우의 처리를 검토한다.

2. 청구하여야 할 심판

(1) 일반 법리 — 무효심판과 거절결정불복심판

특허에 무효사유가 있는 경우 이해관계인 또는 심사관은 특허무효심판을 청구할 수 있는데, 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자가 받은 특허 (§ 133①(2)본문)의 경우에는 **특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만** 청구할 수 있다(§ 133① 괄호). 한편 거절결정을 받은 자가 결정에 불복할 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 **3개월 이내**에 거절결정불복심판을 청구할 수 있다(§ 132의17).

(2) 사안의 포섭

① (**특허결정한 경우**) — 甲의 특허에는 제33조 제1항 본문 위반(무권리자)의 무효사유가 있으므로, 이 사건 발명에 관한 **특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자인 乙**이 무효심판을 청구하여야 한다(§ 133①(2)본문). 무효심결이 확정되면 乙은 확정일부 30일 이내에 정당한 권리자 출원을 하여 무효로 된 특허의 출원 시로 소급받는 **제35조의 구제**를 받을 수 있다. ② (**거절결정한 경우**) — 출원인 甲이 거절결정등본을 송달받은 날부터 **3개월 이내**에 거절결정 불복심판을 청구할 수 있다(§ 132의17). 다만 甲의 출원은 무권리자 출원이어서 심판청구는 **기각되어 거절결정이 확정**될 것이고, 이 경우 乙은 거절이 확정된 날부터 30일 이내에 출원하면 무권리자의 출원 시로 소급받는 **제34조의 보호**를 받을 수 있다.

3. 심판 계속 중 동일 심판을 다시 청구한 경우의 판단·조치

(1) 일반 법리 — 중복심판금지의 원칙

특허법 제154조 제8항은 심판에 관하여 민사소송법 제259조(중복된 소제기의 금지)를 준용하므로, 특허심판원에 **전심판이 계속 중인 사건에 대하여 동일한 당사자가 동일한 심판**을 다시 청구하는 것은 허용되지 아니한다. 중복심판청구 금지는 심판청구의 적법요건으로서 직권조사사항이고, 그 위반 여부는 **후심판의 '심결 시'를 기준**으로 전심판의 계속 여부를 판단한다(대법원 2016후2317).

(2) 사안의 포섭

심판청구인이 자신이 청구하여 계속 중인 심판과 당사자·심판물이 동일한 심판을 다시 청구하였으므로, 후심판의 심결 시까지 전심판의 계속이 유지되는 한 후심판은 중복심판청구로서 부적법하고, 특허심판원은 이를 **심결로써 각하**하여야 한다(§ 142). 다만 후심판의 심결 시에 전심판이 취하·각하 등으로 계속이 소멸한 때에는 중복심판에 해당하지 아니하므로 본안심리를 진행하여야 한다.

4. 결론

특허결정한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 乙이 **무효심판**(§ 133①(2)본문)을 청구하고 무효 확정 후 제35조로 구제받을 수 있으며, 거절결정한 경우에는 甲이 등본 송달일부터 3개월 이내에 **거절결정불복심판**(§ 132의17)을 청구할 수 있으나 기각·확정될 것이므로 乙은 제34조로 보호받는다. 심판 계속 중 동일 심판이 다시 청구되면 특허심판원은 심결 시를 기준으로 중복심판 여부를 판단하여 **후심판을 각하**하여야 한다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

설문	쟁점
(1)	이 사건 발명에 대한 권리귀속(\$33①·\$37①, 2011다67705 — 재산권·양도성, 명시·묵시 이전)
(1)	甲 출원의 적법성(\$38①·대법원 2020후10087)
(1)	결론 — 제62조 2호 거절이유, 설정등록 시 제133조 제1항 제2호 무효사유
(2)	특허권 이전의 효력발생요건(\$99①, \$101①(1)) — 이전등록 없어 특허권 자체는 甲에게 잔존
(2)	乙의 정당한 권원 — 통상실시권은 합의만으로 효력·등록은 대항요건(\$118), 양도계약 해석상 이전등록 전 실시의 목
(2)	결론(침해 부정) + 신의칙 위반 부가
(3)	심판 특정 — 특허결정 시 乙의 무효심판(\$133①(2)본문, 청구인=특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자 한정)+무효 확정 후 \$35 구제 / 거절결정 시 甲의 거절결정불!
(3)	중복심판(\$154⑥, 민소\$259 준용) 요건(당사자·심판물 동일, 선행심판 계속 중) 및 판단시점(심결
(3)	후행심판 각하심결(\$142)

합계: 30점

축별 채점 기준

1) 논점 추출 (12점)

- (1)에서 '권리귀속(\$33①·\$37①·2011다67705) → 甲 출원의 적법성(\$38①·2020후10087)'의 이중 논점을 관련법리/사안 포섭으로 나누어 모두 포착했는가.
- (2)에서 '특허권 이전은 등록이 효력요건(\$101①(1)) → 권리귀속은 여전히 甲, 그러나 계약상 실시권원 발생 → 침해 부정'이라는 흐름을 잡았는가.
- (3)에서 '심판 종류(무효심판/거절결정불복심판)'와 '중복심판 처리'를 모두 다루었는가. 일방만 서술 시 대폭 감점.
- 무관한 직무발명·공동출원 위반 등을 장황히 다루면 감점. (3)에서 \$34·\$35 구제는 각 경우의 귀결로 간결히 연결.

2) 목차·구성 (7.5점)

- 설문별로 목차를 분리(I/II/III)하고, 각 설문 내에서 '규정→판례→사안 포섭→결론' 구조를 취했는가.

- 배점 비례로 분량 배분(각 10점 균등)했는가.
- 특발권 이전(대항요건)과 특허권 이전(효력요건)을 명확히 대비하는 소목차가 있는가.

3) 답안 작성·논증 (10.5점)

- 조문 인용의 정확성: 제33조 제1항, 제37조 제1항, 제38조 제1항(대항요건), 제99조 제1항, 제101조 제1항 제1호(효력요건), 제62조 2호, 제133조 제1항 제2호, 제132조의17, 제154조 제8항, 제142조.
- 판례 인용: 대법원 2020. 5. 14. 2020후10087(무권리자), 대법원 2020. 8. 27. 2019다225255(영업양도·실시권원).
- 사안 포섭이 구체적인가(甲=양도인, 乙=양수인, 이전등록 유무 등).
- 결론과 논증의 일관성(설문 (1) 무권리자 출원 부적법 / (2) 침해 부정 / (3) 무효심판·중복심판 각하).

감점 주의

- 특발권 이전은 대항요건, 특허권 이전은 효력요건임을 혼동하는 서술.
- (1)에서 영업양도가 포괄승계라는 이유로 특발권 이전 효력을 부정하는 잘못된 결론(사안은 특정승계로 봄이 타당).
- (2)에서 이전등록이 없다는 이유만으로 곧바로 침해 성립을 인정하고 실시권원 논의를 누락.
- (3)에서 심사관이 '특허결정한 경우'와 '거절결정한 경우'를 구분하지 않고 무효심판만 서술.
- 중복심판을 언급하면서 조문(§ 154⑧, 민소 § 259) 및 각하조문(§ 142)을 누락.
- 정당권리자 甲/乙 관계를 반대로 파악(발명자·특발권자를 혼동).

2022년 제2문

약술형

20점

문제

특허법 제163조(일사부재리)와 관련하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 일사부재리에 해당하는지 여부의 판단시점에 관한 대법원 판결로는 「대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결」과 「대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결 등」이 있다. 이들 대법원 판결 중 전자는 일사부재리 판단시점을 '심판청구시'로 보았고, 후자는 2009후2234 전원합의체 판결을 유지하면서도 또 다른 이유로 일사부재리 판단시점을 '심결시'로 보았다. 이들 판례는 모두 유효하다. 이들 판례를 토대로 일사부재리에 해당하는지 여부의 판단시점을 결정하는 판례의 태도를 설명하시오. **(10점)**

(2) 특허법 제163조 단서규정("다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.")의 의의와 본 규정에서 '각하심결'로 볼 수 있는 적용범위에 관한 판례의 태도를 설명하시오. **(10점)**

모범답안

I. 설문(1) — 일사부재리 판단시점에 관한 판례의 태도

1. 문제의 소재

일사부재리 원칙(§ 163)의 위반 여부 판단시점과 관련하여 2009후2234 전원합의체 판결은 '심판청구시'로, 2018후11360 판결은 '심결시'로 판시하였는바, 양 판결의 조화적 해석이 문제된다.

2. 일사부재리 원칙의 일반론

(1) 의의·취지

일사부재리란 특허심판의 본안심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없는 것을 말한다(§ 163). 심판청구의 반복으로 인한 절차의 번거로움과 심판상 불경제를 방지하고, 모순·저촉되는 심결의 발생을 막아 법적 안정성을 도모하기 위함이다.

(2) 요건 및 효과

① 본안심결이 확정되었을 것(각하심결 제외), ② 동일사실 및 동일증거에 의한 청구일 것, ③ 동일한 심판청구일 것을 요한다. '누구든지'라는 문언상 그 효력은 당사자뿐 아니라 제3자에게도 미치며(대세효), 이에 위반한 심판청구는 부적법하여 심결각하의 대상이 된다(§ 142).

3. 2009후2234 전원합의체 판결의 검토 — 심판청구시

(1) 판시

일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.

(2) 논거

① 심결시 기준에 따르면, 제1차 심결에 대한 심결취소소송 계속 중 동일사실·동일증거에 의한 다른 심판의 심결이 확정 등록되면, 법원이 제1차 심결을 취소하더라도 특허심판원은 그 심판청구를 각하할 수밖에 없다. 이는 관련 확정심결의 등록이라는 우연한 사정으로 진행 중이던 절차가 소급하여 부적법하게 되어 헌법상 재판청구권을 과도하게 침해할 우려가 있고, 심결을 취소한 법원의 판결을 무의미하게 만든다. ② 제163조는 '누구든지' 다시 심판을 청구할 수 없다고 규정하여 대세효를 인정하므로, 함부로 그 적용범위를 넓히는 것은 재판청구권의 행사를 제한하는 결과가 된다. ③ '그 심판을 청구할 수 없다'는 문언상 심결 확정 등록 후의 새로운 심판청구가 허용되지 않는다고 해석될 뿐, 청구 당시 확정되지 아니한 심결이 그 후 확정되었다 하여 심판청구가 소급하여 부적법하게 된다고 해석할 수 없다.

4. 2018후11360 판결의 검토 — 심결시

(1) 판시

특허심판원은 심판청구 후 심결시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결시를 기준으로 심판청구가 선행 확정심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이어서 일사부재리 원칙에 위반되는지를 판단하여야 한다.

(2) 논거

심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구이유의 보정은 요지변경이 되더라도 허용된다(§ 140②(2)). 따라서 동일사실·동일증거 해당 여부는 심결시까지 보정된 사실과 증거를 기준으로 판단함이 타당하다. 이에 따라 신규성 위반 기각심결 확정 후 다시 신규성 위반만을 주장하

여 무효심판을 청구한 경우, 심결취소소송 단계에서 비로소 진보성 위반을 추가 주장하는 것은 허용되지 않는다.

5. 양자의 관계 — 본안심결의 확정만 심판청구시, 나머지 요건은 심결시

2018후11360 판결은 2009후2234 전원합의체 판결을 유지하면서, 이를 선행심결의 확정 시점이 쟁점이 된 사안에서 일사부재리의 대세효로 인한 제3자의 심판청구권 제한을 최소화하기 위하여 선행 본안심결의 확정 여부에 한정하여 심판청구시를 기준으로 삼은 것으로 해석하였다. 즉 1) 선행 본안심결의 확정 여부는 심판청구시를 기준으로 판단하고(2009후2234 전원합의체), 2) 동일사실·동일증거 등 나머지 요건은 심결시까지 보정된 자료를 기준으로 심결시에 판단한다(2018후11360). 양 판결은 판단 대상 요건을 달리하므로 상호 모순·저촉 없이 병존한다.

6. 결론

판례에 의하면 일사부재리 위반 여부는 원칙적으로 심결시를 기준으로 판단하되, 선행 본안심결의 확정 여부만은 예외적으로 심판청구시를 기준으로 판단한다.

II. 설문(2) — 제163조 단서의 의의 및 '각하심결'의 적용범위

1. 문제의 소재

제163조 단서는 확정된 심결이 각하심결인 경우 일사부재리 효력을 배제하는데, 실체판단이 이루어진 일사부재리 위반 각하심결도 이 '각하심결'에 포함되는지 문제된다.

2. 제163조 단서의 의의

(1) 연혁

종래 심판청구 적법요건 흠결로 각하된 확정심결에 일사부재리 효력이 미치는지에 관하여 견해대립이 있었으나, 2001. 2. 3. 개정 특허법에서 단서 규정을 신설하여 각하심결에 대하여는 일사부재리의 효력이 없음을 입법적으로 명확히 하였다.

(2) 의의

각하심결은 본안에 관한 실체판단 없이 부적법 각하된 것이므로, 이에 대해 대세적 실권효를 인정할 근거가 없다는 취지를 명확히 한 규정이다.

3. '각하심결'의 적용범위 — 대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결

(1) 쟁점

일사부재리 위반을 이유로 한 각하심결은 그 심리 과정에서 새로 제출된 증거가 선행 확정심결을 번복할 수 있을 만큼 유력한지에 관한 실체적 판단이 선행된다. 이러한 실체판단이 개재된 각하심결이 단서의 '각하심결'에 포함되는지가 쟁점이다.

(2) 원심(특허법원)의 태도

선행 각하심결이 동일증거 해당 여부를 실체적으로 판단한 이상 단서 규정이 적용되지 않아 일사부재리 효력이 있다고 보았다.

(3) 대법원의 판시 및 논거

대법원은 단서 규정이 새로 제출된 증거가 선행 확정심결을 번복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리·판단이 이루어진 후의 각하심결에도 **동일하게 적용된다고** 판시하였다. 그 논거는 다음과 같다.

① **(문언해석의 한계)** — 일사부재리 원칙은 심판청구의 적법요건일 뿐이어서, 실체판단이 선행되었더라도 각하심결을 본안 기각심결과 동일하게 취급하는 것은 문언의 가능한 해석범위를 넘어선다. ② **(심판청구권 보장)** — 심판청구 남용 방지와 심결 모순·저촉 방지라는 일사부재리 취지를 고려하더라도, 헌법상 심판청구권 보장 역시 중요한 가치이다. ③ **(대세효 고려)** — 현행 제163조는 일사부재리 효력이 제3자에게까지 미치도록 하는 대세효를 인정하므로, 단서의 예외를 인정하여 그 적용범위를 축소·확대 해석하는 것은 정당화되기 어렵다.

(4) 검토

일사부재리의 대세효라는 강력한 효과에 비추어 그 예외인 단서 규정은 문언 그대로 넓게 해석하는 것이 타당하며, 실체판단의 개재 여부와 무관하게 형식적으로 각하심결에 해당하면 단서가 적용된다고 봄이 옳다.

4. 결론

제163조 단서의 '각하심결'에는 1) 형식적 각하심결뿐 아니라, 2) 일사부재리 위반을 이유로 실체적 판단이 선행된 후 내려진 각하심결도 포함된다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특정 포인트
설문(1) 일사부재리 판단시점 판례 태도	10	① §163 일사부재리 의의·요건, ② 2009후2234 전원합의체 판결의 논거(선행심결의 확정 여부는 심판청구시를 기준으로 한다 — 재판청구권 침해, 심결취소판결 무의미화, 문언해석), ③ 2018후11360 판결의 논거(§140②의 청구이유 보정 허용→심결시), ④ 두 판결의 조화적 해석(원칙 심결시 + 선행심결 확정 여부만 심판청구시)
설문(2) §163 단서 의의 및 각하심결 적용범위	10	① 단서 규정(2001년 개정 신설)의 의의 = 각하심결에 일사부재리 효력 부정 명확화, ② 적용범위 쟁점(일사부재리 위반 각하심결도 단서에 포함되는지), ③ 대법원 2021후10077 판결의 논거(문언해석 초과 불가, 심판청구권 보장, 대세효 고려 확대해석 부담), ④ 결론: 실체판단이 이루어진 각하심결에도 단서 적용

합계: 20점

축별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- (+) 설문(1)에서 두 판결이 모순되지 않고 조화롭게 해석됨을 정확히 포착 — 즉 '동일사실·동일증거 판단은 심결시', '선행심결 확정 여부만 심판청구시'라는 이원적 구조 적시
- (+) 설문(2)에서 단서의 신설 취지(구법하 견해대립 해소)와 적용범위 확대 여부(2021후10077의 쟁점)를 정확히 구분
- (-) 두 판결을 모순관계로 오해하거나 어느 하나만 유효하다고 서술
- (-) 각하심결의 적용범위에서 일사부재리 위반 각하심결 논점 누락

2) 목차·구성(25%)

- (+) 설문별로 (의의·요건)→(판례1)→(판례2)→(양 판결 관계)→(결론) 순으로 체계화
- (+) 배점 비례(각 10점)로 분량 균등 배분
- (-) 일사부재리 일반론(요건·효과)을 지나치게 장황히 서술하고 판례 태도 서술 빈약
- (-) 판례 논거를 나열식·조문 전사식으로만 나열

3) 답안 작성·논증(35%)

- (+) § 163· § 140② 조문 근거를 명시하고, 판례 법리→논거→결론 순으로 논증
- (+) 2009후2234 전합의 취지(대세효로 인한 제3자 권리 제한 최소화)를 2018후11360의 심결시 원칙과 연결
- (+) 2021후10077의 세 가지 논거(문언해석 한계, 심판청구권 보장, 대세효 확대해석 부담)를 구체적으로 제시
- (-) 판례 결론만 적고 논거 누락
- (-) 두 판결의 기준시를 학설의 대립인 것처럼 세워 어느 하나가 옳다는 식으로 서술

감점 주의

- 두 판결을 대립·모순 관계로 서술하는 것: 발문 자체가 '모두 유효'라고 명시했으므로 조화적 해석이 핵심
- 설문(2)에서 단서 신설 연혁(2001년 개정)만 쓰고 대법원 2021후10077의 확대해석 부정 법리를 누락하는 것
- 일사부재리 일반론(요건 3가지: 동일당사자 요건은 삭제됨에 유의, 동일사실·동일증거, 확정심결)에 지면을 낭비하는 것
- '각하심결에는 일사부재리 효력이 없다'만 쓰고 '실체판단한 각하심결도 마찬가지'라는 핵심 결론 누락

2022년 제3문

사례형

30점

문제

ㅁ은 백혈병 치료제로 억제학적 조성물인 발명 X를 하였다. ㅁ은 발명 X가 위장질환(이하 ‘위장병’이라 한다)의 치료에 쓰일 수 있다는 사실을 알았다. ㅁ은 위장병 치료 용도를 청구범위로 하여 특허 출원하고자 한다. 발명 X의 선행발명1에는 ‘위장병에 선택적 억제제인 X의 시험이 A 연구소에서 다른 세계적인 연구 센터 B와 협력 하에 막 시작되었고 초기 결과는 매우 흥미로워 보인다(very early results look exciting)’는 연구결과가 있다. 발명 X의 선행발명 2에는 ‘X가 위장병 종양의 비정상적 활성의 강력한 억제제이고, 부분적으로 또는 완전히 종양의 치료에 유용할 수도 있다’는 연구결과가 있다.

또한, ㅁ은 백혈병 치료제인 발명 Y가 백혈병 치료에서 경피투여를 했을 때 뛰어난 피부 침투성이 있다는 것을 알았다. ㅁ은 전신 경피투여 용법을 사용하면 치료 효과가 오랜 시간 일정하게 지속되고, 간편하게 투약할 수 있다는 것을 알았다. ㅁ은 백혈병 치료에서 발명 Y의 경피투여 용법이 약효 증대 및 효율적인 투여 방법이라는 취지로 특허 출원하고자 한다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 의약품도발명의 ‘약리기전’이 발명의 구성요소로 의미를 가지는 경우를 설명하시오. (5점)
- (2) 발명 X가 위장병 치료 용도로 특허를 받기 위한 진보성 판단 기준을 설명하고, 만일 발명 X의 진보성을 부정하는 경우 선행발명에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것이 필요한지 설명하시오. (10점)
- (3) 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우, 투여용법과 투여용량이 발명의 구성요소인지 설명하고 새로운 의약품도가 부가되면 특허가 될 수 있는지 설명하시오. (8점)
- (4) 발명 Y가 의약품도발명의 특정한 투여용법에 관한 진보성을 인정받기 위한 요건을 설명하시오. (7점)

모범답안

문제 3 모범답안

I. 설문 (1) — 약리기전이 구성요소로 의미를 갖는 경우

1. 의약품도발명의 의의 및 구성

의약품도발명이란 특정 물질의 미지의 약리효과 발견에 기초하여 새로운 의약용도를 제공하는 발명을 말하며, 판례는 '의약물질 + 의약용도'를 그 구성요소로 본다(2006후3564).

2. 관련 법리 및 판례

(1) 약리기전의 법적 지위

대법원은 1) 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약용도의 결합을 도출해내는 계기에 불과하므로, 2) 청구범위에 기재된 약리기전은 **특정 물질의 의약용도를 특정하는 한도 내에서만** 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐, 약리기전 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소로 볼 수 없다고 판시하였다(2012후3664). 같은 취지에서 물질·약리기전·용도로 기재된 청구항은 물질과 용도를 구성요소로 하는 발명으로 이해하고(2012후238), 물질·용도로 기재된 청구항에 약리기전을 부가하는 정정은 용도의 중복 기재에 불과하여 청구범위의 감축이 아니라고 한다(2012후3664).

(2) 물질과 약리기전만으로 기재된 경우 — 제42조 제4항 제2호의 명확성 요건

청구범위에는 발명이 **명확하고 간결하게** 적혀 있어야 한다(§ 42④(2)). 의약품도발명의 청구범위에는 의약용도를 **대상 질병 또는 약효로 명확히 기재**함이 원칙이나, 의약용도가 **약리기전만으로** 기재되어 있더라도 발명의 설명의 다른 기재나 기술상식에 의하여 **의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우**에는 제42조 제4항 제2호가 정한 청구항의 명확성 요건을 충족한 것으로 볼 수 있다(2007후5215).

3. 결론

약리기전만으로 기재된 경우라도 발명의 설명·기술상식에 의하여 구체적 의약용도를 명확히 파악할 수 있다면 **제42조 제4항 제2호의 명확성 요건을 충족**하고, 그 약리기전은 **의약용도를 특정하는 한도**에서 구성요소로서 의미를 가진다.

II. 설문 (2) — 발명 X의 진보성 판단기준 및 임상시험 여부

1. 발명 X의 진보성 판단기준

(1) 문제의 소재

발명 X는 공지된 약제학적 조성물에 위장병 치료라는 새로운 용도를 부가한 **의약용도발명**이고 선행발명 1·2라는 **복수의 선행발명**이 존재하므로, 일반 법리에 이어 의약용도발명과 결합발명의 진보성 판단기준을 차례로 검토한다.

(2) 진보성 판단의 일반 법리

특허출원 전에 공지된 선행기술에 의하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있으면 진보성이 부정된다(§ 29②). 판례는 1) **선행기술의 범위와 내용**, 2) **대상 발명과 선행기술의 차이**, 3) **통상의 기술자의 기술수준**을 파악한 다음, 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준에 비추어 그러한 **차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지**를 살펴보아야 하고, 이때 대상 발명의 명세서에 개시된 기술을 알고 있음을 전제로 **사후적으로 판단하여서는 안 된다**고 한다(2022후10524).

(3) 의약용도발명의 진보성 판단

의약용도발명에서는 통상의 기술자가 선행발명들로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 **치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면** 진보성이 부정된다(2016후502). 다만 선행발명들이 단순한 선언적 진술이나 막연한 기대·가능성의 제시에 그쳐서는 부족하고, 질병의 발생 기전과 치료 원리, 특정 물질의 과학적·기술적·기능적 특성 및 그 특성과 치료 원리의 관련성 등이 포함되어 있어 치료효과를 **합리적으로 예측할 수 있을 정도에 이르러야** 한다(특허법원 2024허14162).

(4) 결합발명의 진보성 판단

복수의 선행문헌을 결합하는 경우에는 **결합의 암시·동기**가 선행문헌에 제시되어 있거나, 출원 당시의 기술수준·기술상식·해당 기술분야의 기본적 과제·발전 경향 등에 비추어 통상의 기술자가 **쉽게 결합에 이를 수 있으면** 진보성이 부정된다(2005후3284).

(5) 사안의 포섭

선행발명 1은 X의 위장병에 대한 시험 개시와 '초기 결과가 매우 흥미롭다'는 기재로 위장병 치료 용도에 대한 **암시·동기**를 제공하고, 선행발명 2는 X가 위장병 증양의 비정상적 활성의 강력한 억제제로서 중앙 치료에 유용할 수 있다는 **구체적 기재**를 담고 있다. 양 문헌은 기술분야와 기술적 과제가 동일하여 결합이 쉽고, 통상의 기술자는 그 결합으로부터 X의 위장병 치료효과를 합리적으로 예측할 수 있으므로, 발명 X의 진보성은 **부정될 수 있다**.

2. 임상시험 여부

(1) 관련 법리

대법원은 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 경우 "선행발명들에서 **임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다**"고 한다(2016후502). 의약용도발명의 진보성은 치료효과의 **합리적 예측가능성**을 기준으로 하기 때문이다. 이는 투입한 노력과 비용 자체에 보상을 주어야 한다는 '**이마의 땀(sweat of the brow)**' 이론을 특허법이 취하지 않는 것과 맥을 같이한다. 특허법이 보호하는 것은 **기술적 사상의 창작**이므로 출원인이 임상시험에 들인 상당한 노력·비용 자체가 진보성의 근거가 될 수 없고, 반대로 선행발명 단계에서 임상시험에 의한 확인이 없다는 사정도 진보성 부정에 장애가 되지 아니한다.

(2) 사안의 포섭

선행발명 1·2의 기재가 치료효과의 합리적 예측 수준에 이르는 이상, 선행발명에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인되지 않았더라도 발명 X의 진보성 부정에는 지장이 없다.

3. 결론

발명 X의 진보성은 일반 법리 위에 의약용도발명(치료효과의 합리적 예측가능성)과 결합발명(암시·동기·결합의 용이성)의 기준으로 판단하고, 사안에서는 선행발명 1·2의 결합으로부터 위장병 치료효과를 쉽게 예측할 수 있어 **진보성이 부정될 수 있으며**, 이 경우 선행발명에서 **임상시험 등에 의한 치료효과의 확인까지 요구되지 아니한다**.

III. 설문 (3) — 투여용법·투여용량의 구성요소성 및 특허 가부

1. 투여용법·투여용량이 발명의 구성요소인지

(1) 종래 판결

종래 판례는 투여용법·투여용량은 의약을 인간 등에게 투여하는 방법이어서 특허를 받을 수 없는 **의료행위**이거나, 청구범위 기재에 의하여 얻어진 **최종적인 물건 자체에 관한 것이 아니라는** 이유로 의약발명의 구성요소로 인정하지 아니하였다(대법원 2007후2926). 그 후 전원합의체가 이를 변경하여 투여용법·투여용량도 발명의 구성요소가 된다고 하였다(2014후768).

(2) 전원합의체 판결 (대법원 2014후768 전합)

대법원은 1) 투여용법·투여용량은 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 **의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소**가 될 수 있고, 2) 최적의 투여용법·투여용량을 찾아내는 데에는 상당한 노력·비용·투자가 소요되고 창작적 요소가 있어 특허법상 보호가치가 있으며, 3) 의료산업의 기술발전을 촉진하여 환자의 생명·건강과 관련된 보편적 인권을 보호할 필요가 있다는 점을 근거로 종래 판결을 변경하였다.

(3) 별개의견

투여방법은 방법의 성격을 가져 '의약품'을 한정하는 것이 아니고, 특허를 부여하면 의사의 자유로운 의료행위가 제한될 수 있다는 이유로 구성요소성을 부정한다.

(4) 검토

의약품발명의 본질은 의약이 효능을 발휘하는 '쓰임새'의 창작에 특허를 부여하는 것이므로, 투여용법·투여용량 역시 그 쓰임새의 일부로 포섭하는 다수의 의견이 타당하다. 따라서 투여용법·투여용량은 **새로운 의약품으로서 발명의 구성요소 중 하나**가 된다.

2. 새로운 의약품도 부가 시 특허 가부

투여용법·투여용량이 발명의 구성요소인 이상, 이러한 **새로운 의약품도가 부가되어 신규성·진보성 등의 특허요건을 갖춘 의약에 대해서는 새롭게 특허권이 부여될 수 있다**. 다만 새로운 투여방법을 개발하기만 하면 곧바로 특허가 부여되는 것은 아니고, 부가된 의약품도를 포함한 발명 전체에 대하여 별도의 특허요건 심사를 거쳐야 한다.

3. 결론

투여용법·투여용량은 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 **새로운 의약품으로서 발명의 구성요소 중 하나**이고(다수의견), 그것이 부가되어 신규성·진보성 등 특허요건을 갖춘 의약은 별도의 심사를 거쳐 **새롭게 특허를 받을 수 있다**.

IV. 설문 (4) — 발명 Y의 투여용법 관련 진보성 요건**1. 발명 Y의 성격**

발명 Y는 백혈병 치료제에 경피투여라는 새로운 투여용법을 부가한 의약품발명이다.

2. 진보성 인정 요건 — 효과 중심의 판단 (대법원 2014후2702)

의약개발 과정에서는 약효 증대 및 효율적 투여방법 등의 기술적 과제 해결을 위하여 적절한 투여용법·투여용량을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지고 있다. 따라서 투여용법·투여용량의 부가는 그 자체로 **구성의 곤란성을 인정하기 어렵거나 그 판단이 모호하므로**, 이러한 발명의 진보성 판단에서는 **효과의 현저성이 중심적 요소**가 된다. 즉 출원 당시의 기술수준·공지기술에 비추어 통상의 기술자가 **예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과**가 인정되어야 진보성이 부정되지 아니한다(대법원 2014후2702).

3. 효과의 현저성이 인정되는 경우 (특허법원 2016허830)

특정한 투여용법·투여용량으로 인하여 나타난 유리한 효과가 통상의 기술자의 기술수준에서 예측되는 범위를 넘는 **현저한** 경우이거나, 당해 의약품발명의 약리효과가 온전히 유지되면서 독성·부작용이 최소화되는 특정한 투여용법·투여용량을 선행발명 또는 공지의 발명으로부터 **예측할 수 없었던** 경우에 진보성이 인정된다(특허법원 2016허830). 예측할 수 없는 약효의 향상, 부작용의 감소, 복약 편의성의 증진 등이 이에 해당한다.

4. 사안 포섭

발명 Y는 백혈병 치료에서 경피투여시 1) 뛰어난 피부 침투성, 2) 치료효과의 장시간 일정한 지속(약효 향상), 3) 간편한 투약(복약 편의성 증진)이라는 효과를 갖는다. 이러한 효과가 출원 당시 기술수준·공지기술에 비추어 통상의 기술자가 예측할 수 없는 이질적 효과로 인정된다면 진보성이 긍정된다.

5. 결론

투여용법 부가 발명은 구성의 곤란성 판단이 모호하여 **효과의 현저성이 진보성 판단의 중심**이 되므로, 발명 Y는 경피투여 용법이 가져오는 뛰어난 피부 침투성, 치료효과의 장시간 지속(약효 향상), 간편한 투약(복약 편의성 증진)이 통상의 기술자가 예측할 수 없는 **현저하거나 이질적인 효과**임을 입증하여야 진보성을 인정받을 수 있다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

설문	핵심 쟁점	배점	특정 포인트
(1)	의약품도발명에서 약리기전의 지위	5	의약품도발명 개념·구성(물질+의약품도), 약리기전 판례(대법원 2014후768 취지) 정확 인용, '의약품도 특정 한도 내에서만 구성요소'라는 결론
(2)	의약품도발명 진보성 판단기준 및 임상시험 확인 여부	10	제29조 제2항, 선행문헌 결합요건(대법원 2005후3284), 의약품도발명 진보성 판단법리(대법원 2016후502), 임상시험까지 요구되지 않음, 선행발명 1-2 결합에 의한 사안 포섭, 진보성 부정 결론
(3)	투여용법·용량의 구성요소성 및 특허가부	8	전합판결(대법원 2014후768) 다수의견 3가지 논거(쓰임새 동일, 투자보호, 물건에 새 의미), 별개의견 대비, 신규성·진보성 등 특허요건 별도 심사 필요
(4)	투여용법 관련 진보성 요건	7	의약개발과정상 적절한 용법·용량 탐색이 통상적 노력 → 구성의 곤란성 판단이 모호하여 효과의 현저성이 중심(대법원 2014후2702), 현저성 인정 유형(특허법원 2016허830 — 약효 향상·부작용 감소·복약 편의성 증진), 사안 포섭(경피투여의 약효 지속·복약 편의성)

배점 합계: 30점

측별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- (1) 약리기전이 '의약품도를 특정하는 한도 내'에서만 구성요소가 된다는 제한적 지위 포착 여부
- (2) '진보성 판단기준'과 '임상시험 확인 여부' 두 요구사항을 분리하여 각각 답변했는가
- (2) 선행문헌 결합요건 법리(암시·동기·기술상식)와 의약품도발명 특유의 진보성 법리를 모두 제시
- (3) '구성요소 여부'와 '새로운 의약품도 부가시 특허 가부' 두 논점을 각각 답변
- (4) 투여용법 부가 발명의 진보성은 일반 진보성보다 강화된 '현저·이질적 효과' 요건임을 파악
- 감점: 의약품도발명 일반론만 나열, 사안(선행발명 1-2, 발명 Y의 효과) 포섭 누락

2) 목차·구성(25%)

- 설문 (1)~(4)를 각 항목별로 구분하여 목차화
- 각 설문 내 '판례 법리 → 사안 포섭 → 결론' 구조
- 배점 비례 분량(5:10:8:7) 배분, (2)에 지면 집중
- 감점: 판례 원문 장황 인용, 사안 포섭 부재

3) 답안 작성·논증(35%)

- 조문(§ 29②, § 42④) → 판례(2016후502, 2014후768 전합, 2014후2702) → 사안 포섭 순 논증
- 선행발명 1의 'very early results look exciting'과 선행발명 2의 '강력한 억제제·종양 치료 유용성' 기재를 결합 근거로 구체적 포섭
- 발명 Y의 '약효 오래 지속·복약 편의성 증진'을 이질적 효과로 포섭
- 결론의 명확성(X는 진보성 부정, Y는 이질적 효과 인정시 진보성 긍정)
- 감점: 판례 결론만 나열하고 사안 대입 없음, 결론이 애매한 경우

감점 주의

- 의약품도발명 개념·성립요건만 장황히 서술하고 정작 약리기전·투여용법의 지위 판례를 놓치는 경우
- (2)에서 '임상시험 확인 불요'라는 대법원 2016후502 판시를 누락한 경우
- (3)에서 종래 판례(투여방법=의료행위/물건 아님)와 전합판결 다수의견의 변경 취지를 대비하지 못한 경우
- (4)에서 '현저성 또는 이질성' 대신 통상적 진보성 기준만 제시한 경우
- 사안의 구체적 사실(선행문헌 표현, 발명 Y의 효과)을 인용하지 않고 일반론으로만 결론 도출한 경우

2022년 제4문

사례형

20점

문제

甲은 '안마기' (구성 A+B+C) 특허발명 X를 하였다. 乙은 甲의 특허발명 X와 유사한 구성을 가진 안마기 제품 Y를 생산·판매하고 있다. 이에 甲은 乙에게 특허침해소송을 제기하였다. 그러자 乙은 甲을 상대로 특허발명 X의 기재불비, 신규성 및 진보성 부정 등을 주장하며 등록무효 심판청구를 제기하였다.

특허침해소송중 乙은 판매 제품 Y는 X의 특허권을 침해하지 않는다고 주장하였다. 乙은 특허침해소송 제1심 제1회 변론기일에서 제품 Y는 특허발명 X의 구성요소 B를 제외한 나머지 구성요소를 모두 구비하고 있다고 진술하였다. 甲이 제품 Y에 대하여 X의 구성요소 C를 구비하고 있는지 감정신청을 하자 乙은 '이 부분에 관하여 다투지 않아 감정이 필요하지 않다'는 의견을 제출하여 甲의 감정신청이 철회되었다.

이후 乙이 제기한 특허발명 X의 등록무효 심판청구 기각심결에 대한 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유가 인정되지 않는다는 이유로 청구기각 판결이 내려졌다. 그러자 乙은 침해소송 제1심 제9회 변론기일에서 구성요소 C에 관한 종전 진술을 반복하였다. 乙은 제품 Y의 구성요소 C 포함 여부에 관한 감정신청을 하였으나, 제10회 변론기일에서 쌍방 모두 감정신청을 하지 않아 변론이 종결되었다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 심결취소소송에서 자백이 가능한 경우를 설명하시오. (6점)

(2) 乙이 특허침해소송중 '어떤 구성요소를 구비하고 있다'라고 한 표현은 재판상 자백인지 설명하고 취소가능인지 설명하시오. (14점)

모범답안

I. 설문(1) — 심결취소소송에서 자백이 가능한 경우

1. 심결취소소송의 성격과 적용 법규정

심결취소소송은 특허법 제186조에 근거한 특허법원 전속관할의 행정소송이다. 행정소송법 제8조 제2항에 따라 민사소송법 규정이 준용되며, 행정소송법 제26조는 행정소송의 특수성에서 연유하는 변론주의에 대한 일부 예외규정에 불과하다.

2. 변론주의와 자백의 인정

판례는 심결취소소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용되므로 재판상 자백 또는 자백간주(민소 § 288, § 150)가 인정된다고 한다.

3. 자백의 대상 — 사실에 한정

판례는 자백의 대상은 '사실'이고, 그 사실에 대한 법적 판단 내지 평가는 자백의 대상이 되지 않는다고 한다. (1) 자백 대상이 되는 사실(주요사실)의 예: 1) 선행발명이 어떤 구성요소를 가지고 있는지, 2) 선행발명의 공지시기, 3) 침해대상제품이 어떤 구성요소를 가지고 있는지 등이다. (2) 자백 대상이 되지 않는 법적 평가의 예: 발명의 신규성·진보성 유무, 청구범위의 해석, 권리범위 확정, 구성요소의 동일·균등 여부 판단 등이다.

4. 결론

심결취소소송에서는 민사소송법상 자백 규정이 준용되므로, 당사자가 변론기일 또는 변론준비기일에서 상대방의 주장과 일치하는, 자기에 불리한 '사실'을 진술한 경우 재판상 자백이 성립하여 자백이 가능하다. 다만 법적 판단·평가에 해당하는 사항은 자백의 대상이 되지 아니한다.

II. 설문(2) — 乙의 진술의 재판상 자백 해당 여부 및 취소가능성

1. 재판상 자백의 요건과 효과

(1) 요건 (민소 § 288)

① 변론기일 또는 변론준비기일에서, ② 상대방의 주장과 일치하는, ③ 자기에 불리한, ④ 사실에 관한 진술이어야 한다.

(2) 효과

① 상대방의 증명책임이 면제되고(민소 § 288 본문), ② 당사자의 임의철회가 제한되며(민소 § 288 단서), ③ 법원에 구속력이 발생한다 — 판례는 "일단 재판상 자백이 성립하면 그것이 적법하게 취소되지 않는 한 법원은 이에 구속되므로 자백과 배치되는 사실을 증거에 의하여 인정할 수 없다"고 한다(대법원 2019다277751).

2. '어떤 구성요소를 구비하고 있다'는 표현이 자백인지

(1) 판례 법리 (대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결)

① 특허침해소송에서 침해대상제품이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 **침해판단의 전제가 되는 주요사실**로서 재판상 자백의 대상이 될 수 있다. ② 다만 "침해대상제품 등이 어떤 구성요소를 가지고 있다"는 표현이 **사실에 대한 진술인지**, 아니면 **그 구성요소가 특허발명의 구성요소와 동일 또는 균등하다는 법적 판단·평가에 관한 진술인지**는, 당사자 진술의 구체적 내용과 경위, 변론의 진행 경과 등을 **종합적으로 고려**하여 판단하여야 한다.

(2) 사안 포섭

① 乙은 침해소송 제1심 **제1회 변론기일**에서 제품 Y가 특허발명 X의 구성요소 B를 제외한 **나머지 구성요소(A, C)를 모두 구비**하고 있다고 진술하였다. 이는 침해판단의 전제가 되는 주요사실에 관한, 자기에겐 불리한 진술이다. ② 甲이 구성요소 C 구비 여부에 관한 감정신청을 하자 乙은 **"이 부분에 관하여 다루지 않아 감정이 필요하지 않다"**는 의견을 제출하여 甲의 감정신청을 철회시켰다. 이는 구성요소 C의 구비 사실 자체를 다루지 않겠다는 명시적 표시이다. ③ 乙이 종전 진술을 번복한 것은 별도로 제기한 등록무효 심결취소소송에서 청구기각 판결이 내려진 **이후 제9회 변론기일**에 이르러서였다. 이러한 번복 시점과 경위는 종전 진술이 법적 평가가 아니라 사실 진술이었음을 뒷받침한다.

(3) 결론

乙의 진술 내용, 감정신청 철회 유도의 경위, 변론 진행 경과를 종합하면, 乙의 진술은 제품 Y의 대응구성이 특허발명 X의 구성요소 C와 동일·균등한지에 관한 법적 판단·평가가 아니라, **구성요소 C 자체를 구비하였다는 사실에 대한 진술**로서 **재판상 자백이 성립**하였다고 봄이 타당하다.

3. 자백을 취소할 수 있는지

(1) 자백 취소의 요건

민사소송법 제288조 단서 및 판례에 따르면, 재판상 자백은 1) 상대방의 동의가 있거나, 2) 자백이 **진실에 반하고(반진실) 착오에 기인**한다는 점을 자백한 당사자가 증명한 경우, 3) 형사상 처벌받을 행위로 인한 경우(재심사유), 4) 경정의 경우에 한하여 취소할 수 있다. 반진실과 착오는 **모두 자백한 당사자가 증명책임**을 부담한다.

(2) 사안 포섭

① 甲이 乙의 자백 취소에 동의한 사정은 없다. ② 乙은 제9회 변론기일에서 감정신청을 하였으나 제10회 변론기일에서 쌍방 모두 감정신청을 하지 않아 변론이 종결되었으므로, **제품 Y가 구성요소 C를 구비하지 않았다는 점(반진실)에 관한 증거가 이루어지지 않았다**. ③ 乙의 진술이 착오에 기인하였다는 사정도 나타나지 않고, 오히려 무효심판 결과를 본 후 전략적으로 진술을 번복한 것에 가까우므로 착오도 인정되기 어렵다.

(3) 결론

반진실 및 착오의 증거가 없는 이상, 乙은 종전 자백을 **적법하게 취소할 수 없다**. 따라서 법원은 자백된 사실(구성요소 C 구비)에 구속되며, 이에 배치되는 사실을 증거에 의하여 인정할 수 없다.

4. 결론

乙이 제1심 제1회 변론기일에서 제품 Y가 구성요소 C를 구비하고 있다고 진술하고 甲의 감정신청을 철회시킨 것은 법적 평가가 아닌 사실 진술로서 **재판상 자백이 성립**한다. 甲의 동의가 없고 반진실·착오에 대한 증명도 이루어지지 않았으므로 乙은 이후 제9회 변론기일에서 한 번복 진술로써 위 자백을 적법하게 취소할 수 없다. 따라서 법원은 구성요소 C 구비라는 자백된 사실에 구속되어 이에 배치되는 사실을 인정할 수 없다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
(1) 심결취소소송의 성격과 변론주의 적용	2점	심결취소소송이 행정소송이나 민사소송법 준용(민소§8②)으로 변론주의가 원칙적으로 적용된다는 점 적시
(1) 자백의 대상 — 사실 vs 법적 판단 구분	4점	자백의 대상은 '사실'이며 법적 판단·평가(신규성·진보성, 청구범위 해석 등)는 자백 대상 아니라는 판례법리, 선행발명 구성·공지시기 등 주요사실은 자백 대상이라는 점
(2) 재판상 자백의 요건 및 효과	3점	민사소송법 제288조 요건(변론기일에서 상대방 주장과 일치하는 자에게 불리한 사실 진술), 법원 구속력·증명 불요·임의철회 제한
(2) '어떤 구성요소를 구비하고 있다'의 성격 판단기준	4점	대법원 2019다277751 판결 — 침해대상제품의 구성 구비 여부는 주요사실로 자백 대상. 다만 사실 진술인지 법적 판단(동일균등 평가)인지는 진술 내용·경위·변론 진행 종합 판단
(2) 사안 포섭 — 재판상 자백 성립 인정	4점	제1회 변론기일 진술, 감정신청 철회 유도, 무효심판 청구기각 후 번복 등 종합하면 사실 진술로서 자백 성립 결론
(2) 자백 취소가능성	3점	취소요건(상대방 동의, 반진실+착오, 형사상 처벌행위, 경정 등) 제시 후 사안에서 반진실·착오 증명 없어 취소 불가 결론

배점 합계: 20점 (설문(1) 6점 + 설문(2) 14점)

축별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- **특점 포인트**
 - 설문(1): 심결취소소송에도 변론주의·자백이 적용된다는 원칙과, 자백은 '사실'에 한한다는 한계를 모두 짚었는가.
 - 설문(2): 대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결(침해대상제품 구성 자백 사안)을 정확히 포착하고, ① 자백 성립 여부, ② 취소 가능 여부의 두 논점을 분리하여 답했는가.
 - 신규성·진보성·청구범위 해석은 법적 평가로 자백 대상이 아님을 언급했는가.
- **감점 포인트**
 - 자백의 대상을 '사실'로 한정하지 않고 무분별하게 인정한 서술
 - 대법원 2019다277751 판례를 언급하지 않고 일반 민소법 자백론만 나열
 - 설문(2)에서 취소가능성 논점을 아예 놓친 경우

2) 목차·구성(25%)

- **특점 포인트**
 - 설문(1)과 설문(2)를 로마숫자로 분리, 설문(2)는 '자백 성립 여부'와 '취소 가능성'을 소목차로 구분
 - 조문(민소 § 288, § 186) → 판례(2019다277751) → 사안 포섭 → 소결 흐름
 - 배점 비례(6:14) 분량 배분
- **감점 포인트**
 - 사실관계 나열만 하고 요건 분석 목차가 없는 답안
 - 설문(2)에서 취소 요건을 목차 없이 결론만 서술

3) 답안 작성·논증(35%)

- **특점 포인트**
 - 조문(민소 § 288 본문·단서) 정확 인용, 특허법 제186조과 민소법 준용관계 명시
 - 대법원 2019다277751의 '종합적 판단' 법리(진술 내용·경위·변론 진행)를 사안에 구체적으로 포섭 — 특히 감정신청 철회 유도 사실이 자백 인정의 결정적 상황이라는 점
 - 자백 취소요건(반진실 + 착오)의 증명책임이 취소를 구하는 자에게 있다는 점, 사안에서 이러한 증명 없음을 논증
 - 명확한 결론(자백 성립 O, 취소 불가)
- **감점 포인트**
 - 조문 전사·판례 요지만 나열하고 사안 포섭 부재
 - 반대 결론(자백 부정)을 논리 없이 결론지음
 - 자백 취소요건과 재심사유(민소 § 451①⑤)를 혼동

감점 주의

1. 설문(1)에서 심결취소소송의 성격(행정소송+민사소송법 준용)을 언급하지 않고 곧바로 자백론만 서술하면 감점.
2. 자백의 대상을 '사실'로 한정하는 판례 법리(신규성·진보성·권리범위확정 등은 법적 평가로 자백 대상 아님)를 누락하면 큰 감점.
3. 설문(2)에서 대법원 2019다277751 판결의 핵심 — '구성요소를 가지고 있다'는 표현이 사실 진술인지 법적 평가인지 종합적으로 판단해야 한다는 법리 — 를 놓치면 감점.
4. 사안 포섭 시 '감정신청 철회 유도', '무효심판 기각 후 번복 시점' 등 구체적 사실을 원용하지 않고 추상적 결론만 내리면 감점.
5. 자백 취소요건에서 '반진실+착오'가 모두 필요하다는 점, 사안에서 이 증명이 없다는 점을 논증하지 않으면 감점.
6. 결론에서 취소 가부에 대한 답을 내리지 않고 유보하면 감점.

PART 14

2023

제1문	권리범위확인심판제도 취지 및 침해소송과의 차이 ·) 소진 주장 권리범위확인심판	30점
제2문	-① 공지에외주장의 의의·요건(§30①(1))과 사안 포섭 · -② 보정기간 등 제30조 제3항 사후 보완 가부	20점
제3문	乙에 대한 침해 주장 - 간접침해 성립 · 丙에 대한 침해 주장 - 직접침해	30점
제4문	선택발명 의의 및 진보성 요건 · 상하위개념 발명 간 침해 판단	20점

2023년 제1문

사례형

30점

문제

甲은 발명 X를 완성하여 2021. 7. 20. 특허출원하였고, 2022. 12. 20. 특허등록을 받았다. 甲은 2023. 3. 20. 특허발명 X에 대하여 丙과 독점적 통상실시권 계약을 체결하였다. 한편 乙은 발명 X'를 2023. 4. 10.부터 실시하고 있다. 甲과 乙은 각각 상대방을 상대로 특허심판원에 권리범위 확인심판을 청구하려고 하고, 甲은 이와 별도로 乙을 상대로 법원에 특허권 침해소송을 제기하려고 한다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 특허법상 권리범위확인심판제도의 취지를 고려하여 권리범위확인심판제도와 특허권 침해소송과의 차이점을 설명하시오. (2점)

(2) 다음과 같은 이유로 청구된 권리범위확인심판의 타당성에 관하여 설명하시오. (12점)

1. 乙의 발명 X'에 관련된 물건과의 관계에서 甲의 특허권이 소진되었음을 이유로 乙이 권리범위확인심판을 청구하는 경우
2. 甲의 특허발명 X에 진보성이 없음을 이유로 乙이 권리범위확인심판을 청구하는 경우
3. 乙의 발명 X'가 甲의 특허발명 X의 구성요소 중 일부를 변경하였음을 이유로 甲이 권리범위확인심판을 청구하는 경우
4. 乙이 장래 실시할 수도 있음을 이유로 乙이 권리범위확인심판을 청구하는 경우

(3) 甲의 발명 X의 청구범위가 전제적으로 물건으로 기재되어 있으면서 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명인 경우에 乙의 발명 X'의 실시가 甲의 권리범위에 포함되는지 여부를 판단할 때 확인대상 발명 X'와 대비해야 할 사항을 설명하시오. (4점)

(4) 甲은 2023. 5. 10. 법원에 특허권 침해소송을 제기하였고, 이에 乙은 권리범위확인심판 대신에 특허무효심판을 청구하였다. 특허무효심판의 심결과 관련하여 甲이 취할 수 있는 조치에 관하여 설명하시오. (12점)

모범답안

I. 설문 (1) — 권리범위확인심판과 침해소송의 차이 (2점)

1. 제도의 취지

권리범위확인심판(§ 135)은 확인대상발명이 특허권의 객관적 효력범위에 속하는지를 특허심판원이 간이·신속하게 판단하여 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데 그 취지가 있다.

2. 양자의 차이 (대법원 2016후328)

권리범위확인심판은 침해금지·손해배상청구권 등 당사자 사이의 권리관계를 **최종적으로 확정**하는 절차가 아니고 그 심결이 침해소송에 **기속력**을 미치지 않으나, 특허권의 객관적 효력범위를 확인하는 **고유한 기능**을 가진다. 절차적으로도 심리기관(특허심판원/법원)·심리범위·집행력 유무에서 구별된다.

II. 설문 (2) — 권리범위확인심판의 타당성 (12점)

1. -1) 소진을 이유로 한 소극적 권리범위확인심판

(1) 판례(2010후289)

권리범위확인심판은 확인대상발명에 특허권의 효력이 미치는지를 확인하는 **권리확정을 목적으로** 하는 절차이다. 그런데 소진이나 실시권의 존재는 실시가 침해로 인정되지 아니하는 **주관적인 측면, 즉 정당한 권원에 관한 것**일 뿐, 침해의 객관적 측면인 **보호범위의 확정에서 문제되는 법률에 의한 제한에 해당하지 않는다**. 따라서 특허권이 소진되었다 하더라도 그러한 사정은 침해소송에서 **항변**으로 주장함은 별론으로 하고, 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과는 **아무런 관련이 없다**.

(2) 사안

권리범위확인심판에서는 소진 여부를 심리·판단할 수 없으므로, 소진을 이유로 한 乙의 심판청구는 **타당하지 않으며, 확인의 이익이 없어 각하**되어야 한다.

2. -2) 진보성 흠결을 이유로 한 소극적 권리범위확인심판

(1) 판례(2012후4162 전합)

등록된 특허는 진보성이 없어 무효로 할 사유가 있더라도 **무효심결이 확정되지 아니하는 한** 다른 절차에서 무효임을 전제로 판단할 수 없다. 권리범위확인심판에서 진보성까지 판단하는 것은 **제도의 목적과 본질에 맞지 아니하고 무효심판의 기능을 약화시킬 우려가 있다**. 침해소송에서 권리남용 항변으로 진보성 결여를 심리하는 것(2010다95390 전합)은 그 효력이 **당사자 사이에만** 미쳐 무효심판에 의해서만 대세적 효력을 부정하도록 한 기본 구조와 상충되지 아니하나, 권리범위확인심판의 심결은 제3자에게도 일사부재리의 **대세적 효력**이 미치므로 진보성 결여 주장을 인정하면 **기본 구조와 상충**된다. 따라서 권리범위확인심판에서 진보성 부정을 이유로 권리범위를 부정할 수 없다. 다만 **공지공용의 것**(신규성 결여)인 경우에는 무효심결과 관계없이 권리범위를 부정할 수 있으나(81후56 전합), 이를 진보성까지 확장할 수는 없다.

(2) 사안

乙이 진보성 흠결을 이유로 소극적 권리범위확인심판을 청구하는 것은 **타당하지 않으며, 확인의 이익이 없어 각하**되어야 한다. 다만 침해소송에서는 권리남용의 항변으로 이를 주장할 수 있다.

3. -3) 구성 일부 변경을 이유로 한 적극적 권리범위확인심판

(1) 균등론(2013다14361, 2014후2788 등)

청구범위에 기재된 구성 중 일부를 변경하였더라도 1) 과제의 해결원리가 동일하고, 2) 그 변경에 의하더라도 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 3) 그러한 변경을 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도이면, 4) **특별한 사정이 없는 한** 균등한 것으로서 권리범위에 속한다. 앞의 세 요건은 특허권자가 증명할 **적극적 요건**이고, 자유기술에 해당하거나 출원절차에서 의식적으로 제외된 경우 등 특별한 사정은 제3자가 항변할 **소극적 요건**이다.

(2) 사안

甲의 심판청구는 乙이 현재 실시 중인 발명 X'를 확인대상발명으로 하므로 **확인 이익이 인정되어 적법**하다. 다만 구성요소 중 일부가 변경된 이상 구성요소완비의 원칙에 의한 문언상 속부는 인정되지 않으므로, 본안심리에서 균등의 적극적 요건(1)~3)) 충족 여부와 소극적 요건(4)) 항변 성립 여부를 판단하여, 균등관계가 인정되면 **인용심결**, 부정되면 **기각심결**이 내려진다.

4. -4) 장래 실시 예정을 이유로 한 소극적 권리범위확인심판

(1) 청구인 적격 및 확인대상발명 적격

소극적 권리범위확인심판은 이해관계인이 청구할 수 있는데(§ 135②), 판례는 **장래 실시 예정자도** 이해관계인에 포함되고 그가 특정한 **장래 실시 예정인 발명**도 심판대상이 된다고 하여 양 적격을 모두 인정한다(97후3241, 2014후2849).

(2) 확인의 이익의 폭넓은 인정

판례는 그 **분쟁 예방적 기능**을 고려하여 장래 실시 계획이 주장되는 확인대상발명에 대한 확인의 이익을 **폭넓게 인정**한다(85후48, 49). 실시 가능성이 없다는 점은 특허권자가 증명하여야 하는데 청구인이 자인하지 아니하는 한 증명이 쉽지 아니하므로(2020후11813), 청구인이 장래에도 실시할 계획이 없음을 스스로 자인하지 아니하면 **확인 이익이 긍정**된다. 확인의 이익이 부정된 사안은 청구인이 변론준비절차에서 이를 자인한 경우였다(2004후1663).

(3) 사안

乙이 장래 실시할 수도 있음을 이유로 소극적 권리범위확인심판을 청구하는 것은 원칙적으로 **타당**하며, 실시하지 않을 것임을 스스로 자인하지 않는 한 확인의 이익이 긍정된다(단, 甲이 권리범위 불속을 다투지 않는 경우에는 확인의 이익이 부정될 수 있다).

Ⅲ. 설문 (3) — PbP 청구항의 대비 방법 (4점)

1. 제조방법이 기재된 물건 청구항(PbP)

甲의 발명 X는 청구범위가 전체적으로 물건이면서 제조방법 기재를 포함하고 있으므로 PbP 청구항에 해당한다.

2. 판례(대법원 2013후1726, 2020후11059)

(1) 원칙 — **특허요건 판단 국면과 동일**: 권리범위를 판단할 때에도 특허요건을 판단할 때와 **마찬가지로**, 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 **모든 기재에 의하여 특정되는 구조·성질 등을 가지는 물건**으로 특허발명을 파악하여 확인대상발명과 대비한다. (2) 예외 — **특허요건 판단 국면과 달리 제한 해석 허용**: 다만 특허요건을 판단할 때와는 **달리**, 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등 **명백히 불합리한 사정**이 있는 경우에는 권리범위를 청구범위에 기재된 **제조방법의 범위 내로 한정**하여 해석할 수 있다.

3. 사안 및 결론

甲의 발명 X는 PbP 청구항이므로, 원칙적으로 특허요건 판단 국면과 마찬가지로 제조방법 기재를 포함한 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 **구조·성질 등을 가지는 물건**으로 파악하여 乙의 발명 X'와 대비하여야 하고, 그 권리범위가 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓어지는 등 명백히 불합리한 사정

이 있는 경우에는 예외적으로 **제조방법의 범위 내로 한정**하여 대비하여야 한다.

IV. 설문 (4) — 무효심판 관련 甲의 조치 (12점)

1. 무효심판 청구가 타당한 경우(무효사유가 있는 경우)의 조치

(1) 심판원 단계 — 정정청구(§133의2)

무효심판 계속 중에는 지정된 기간 내에 정정청구를 하여 청구범위의 감축 등으로 무효사유를 해소할 수 있다. 정정청구를 할 때에는 독점적 통상실시권자 丙의 **동의**를 얻어야 한다(§136⑤ 준용).

(2) 특허법원·대법원 단계 — 정정심판 청구(§136)

무효심결에 대한 심결취소소송이 특허법원·대법원에 계속 중인 때에는 별도로 정정심판을 청구하여 무효사유의 해소를 도모할 수 있다(이때에도 丙의 동의가 필요하다). 다만 판례는 **사실심 변론종결 후에 정정을 인용하는 심결이 확정되더라도** 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 재심사유가 있다고 볼 수 없다고 하므로(대법원 2016후2522 전합), 사실심 변론종결 후에는 정정인용심결의 확정으로 대응할 수 없음에 유의하여야 한다.

2. 무효심판 청구가 타당하지 않은 경우(무효사유가 없는 경우)의 조치

(1) 심판원 단계 — 적극 대응

답변서 제출·구술심리 등을 통해 무효사유의 부존재를 적극 주장·입증하여 **기각심결**(청구가 부적법한 경우 각하심결)을 유도한다. 침해소송과 병행되므로 심리 지연 방지를 위한 신속심판 신청도 고려할 수 있다.

(2) 인용심결이 내려진 경우 — 불복

심결등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 특허법원에 **심결취소의 소**를 제기하고(§186), 패소 시 대법원에 **상고**하여 다툴 수 있다. 당사자제 심판이므로 심결에서 판단되지 않은 위법사유도 소송단계에서 주장·입증할 수 있다.

3. 병행 침해소송 관련 조치

(1) 침해소송의 수행과 가처분의 한계

특허에 무효사유라는 하자가 있더라도 무효심결이 확정되기 전까지 특허권은 유효하므로 침해소송의 제기·수행 자체는 가능하다. 다만 하자가 **명백**한 경우에는 침해금지가처분에서 **보전의 필요성을 결한 것**으로 판단될 수 있다.

(2) 乙의 무효 항변에 대한 대응

乙이 침해소송에서 무효사유가 명백함을 이유로 권리남용의 항변(대법원 2010다95390 전합)을 하는 경우, 甲은 정정청구·정정심판 청구를 통해 무효사유를 해소하였거나 해소할 수 있다는 사정을 **정정의 재항변**으로 주장할 수 있고(대법원 2016후2522 전합), 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 **소송절차의 중지**를 신청할 수도 있다(§164②).

(3) 무효심결이 확정된 경우

무효심결이 확정되면 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 이미 확정된 침해소송 판결은 **재심**의 대상이 될 수 있고, 지급받은 손해배상금 등의 **사후처리** 문제가 발생할 수 있다.

4. 독점적 통상실시권자 丙 관련 조치

(1) 보조참가 요청(§155③)

丙은 심판 결과에 이해관계를 가지는 자로서 심리종결 시까지 甲을 보조하기 위하여 심판에 참가할 수 있으므로, 甲은 丙에게 **보조참가를 요청**하여 함께 다툴 수 있다.

(2) 실시료 관계 — 무효심결 확정 지연의 이익

판례는 특허가 무효로 확정되더라도 특별한 사정이 없는 한 **이미 지급된 실시료의 반환을 청구할 수 없다**고 하므로(대법원 2012다42666), 설령 무효심판 청구가 타당하더라도 甲으로서는 정정·불복 등을 통해 **무효심결의 확정을 최대한 늦추는 것**이 그때까지 丙으로부터 실시료를 지급받을 수 있어 유리하다.

5. 결론

甲은 무효사유가 있는 경우에는 정정청구(심판원 단계)·정정심판(법원 단계, 사실심 변론종결 전까지)으로 무효사유를 해소하고, 무효사유가 없는 경우에는 심판원 단계에서 적극 대응하여 기각을 유도하며 인용 시 심결취소의 소·상고로 다툰다. 병행 침해소송에서는 정정의 재항변·소송절차 중지 신청으로 대응하고, 丙에게 보조참가를 요청하여 함께 다투는 한편 무효심결의 확정을 최대한 늦춰 실시료 수취의 이익을 확보하여야 한다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
(1) 권리범위확인심판제도 취지 및 침해소송과의 차이	2점	① 취지(객관적 숙부판단·간이신속 분쟁 예방/종결), ② 판례(2016후328) — 최종적 권리관계 확정절차 아님, 침해소송에 기속력 없음, 그러나 고유한 기능
(2)-1) 소진 주장 권리범위확인심판	3점	판례(2010후289) — 권리소진은 침해소송 항변사항일 뿐 권리범위확인심판에서 심리 불가 → 타당하지 않음·확인 이익이 없어 각하
(2)-2) 진보성 주장 권리범위확인심판	3점	전합판례(2012후4162) — 권리범위확인심판에서 특허발명 진보성 심리 불가 → 타당하지 않음·확인 이익이 없어 각하
(2)-3) 균등론 근거 적극적 권리범위확인심판	3점	균등론 4요건(적극 3요건+소극 1요건 '특별한 사정', 2013다14361·2014후2788) — 확인 이익 있어 적법, 본안에서 균등 요건 충족 여부에 따라 인용/기각
(2)-4) 장래 실시 예정 소극적 권리범위확인심판	3점	이해관계인(§135②), 판례(97후3241, 2014후2849) — 장래 실시예정도 심판대상, 확인 이익 폭넓게 인정(85후48,49)·실시하지 않을 것임을 스스로 자인하지 않는 한 긍정(2004후1663) → 타당
(3) PbP청구항 대비 방법	4점	판례(2013후1726, 2020후11059) — 원칙: 특허요건 판단과 마찬가지로 제조방법 포함 청구범위 모든 기재로 특정되는 구조·성질을 갖는 물건으로 대비 / 예외: 특허요건 판단과 달리 명백히 불합리한 사정 시 제조방법의 범위 내로 제한해석
(4) 무효심판 관련 甲의 조치	12점	① 무효사유 有: 정정청구(§133의2, 심판원)·정정심판(§136, 법원 단계 — 사실심 변론종결 후 정정심결 확정으로 대응 불가, 2016후2522 전합), ② 무효사유 無: 적극 대응 기각·각하 유도, 인용 시 심결취소의 소(§186)·상고, ③ 침해소송: 하자 있어도 수행 가능(명백 시 가치분 보전필요성 결여)·정정의 재항변·소송중지(§164②)·무효 확정 시 재심·사후처리, ④ 丙: 보조참가(§155③)·기지급 실시로 반환 불요(2012다42666)에 따른 확정 지연의 이익

합계: 30점

출별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- (2) 설문별로 서로 다른 판례법리(소진/진보성/균등/장래실시)를 정확히 매칭하였는가.
- (3) PbP청구항임을 인식하고 원칙(특허요건 판단 국면과 동일)·예외(특허요건 판단과 달리 권리범위 국면의 제한해석) 구조를 포착하였는가(2013후1726).
- (4) 무효사유 준비에 따른 조치 구분(정정청구·정정심판 vs 적극 대응·심결취소의 소·상고), 병행 침해소송상 조치(가처분의 한계·정정의 재항변·소송중지·무효 확정 시 재심), 丙 관련 조치(보조참가·실시료 확정 지연의 이익)까지 모두 포착하였는가.
- 감점: 소진과 자유실시기술 혼동, 진보성 판단 가부에서 신규성·명확성 판단 가부(2012후4162 방론)만 서술, PbP 원칙만 쓰고 예외 누락, (4)에서 丙(독점적 통상실시권자) 논점 누락.

2) 목차·구성(25%)

- 설문별로 소제목을 두어 (2)의 4개 사안을 병렬 배치하였는가.
- 배점 대비 분량 배분: (1) 2점·(3) 4점은 압축, (2)·(4) 12점은 충분히 서술.
- (4)는 무효사유의 준비(무효심판 청구의 타당/부당)에 따른 대응 구분 → 병행 침해소송상 조치 → 丙 관련 조치의 프레임으로 체계화.
- 감점: (1)에서 장황한 서론, (2) 4설문 배점 균형 실패, (4)에서 정정청구·정정심판·정정 재항변 3자 관계 혼용.

3) 답안 작성·논증(35%)

- 조문(§ 133의2, § 136, § 164②, § 186 등) → 판례 → 사안 포섭 → 소결 구조 유지.
- 판례번호(2010후289, 2012후4162, 2014후2849, 2013후1726, 2020후11059) 정확히 인용.
- (2)·(3)에서 균등론 4요건(적극 3요건+소극 1요건)을 제시하고, 청구는 적법하며 본안심리에서 균등론 적용 여부에 따라 인용/기각이 갈린다는 결론.
- (4)에서 제136조 제8항 통상실시권자 동의요건을 정정청구/정정심판 양쪽에 적시.
- 감점: 법조문 인용 없이 결론만, 판례 취지 부정확 인용, 정정 재항변에서 동의요건 누락.

감점 주의

- (2)·(1)을 자유실시기술 항변과 혼동하여 서술하는 실수(소진은 침해소송 항변, 자유실시는 별개).
- (2)·(2)에서 신규성은 심리 가능·진보성은 심리 불가라는 판례 태도를 뒤바꾸어 서술.
- (2)·(3)에서 균등요건을 나열하지 않고 "변경만으로 침해"라는 결론에 동조하는 실수.
- (2)·(4)에서 "장래 실시"를 이유로 무조건 부적법 각하로 결론짓는 실수(97후3241·2014후2849는 원칙 허용).
- (3)에서 2015년 전합 이전의 제법한정설적 이론론을 답습하고 현행 판례의 원칙·예외 이론법을 놓치는 실수.
- (4)에서 정정청구(§ 133의2)와 정정심판(§ 136)의 시기적 사용·국면을 혼동(무효심판 계속 중은 정정청구, 심결취소소송 계속 중은 정정심판).

- (4)에서 독점적 통상실시권자 丙에 대한 제136조 제8항 동의 요건 및 기지급 실시료 반환 불가 판례(2012다42666 등) 누락.

2023년 제2문

사례형

20점

문제

甲은 해양 환경문제에 관심이 많아 해양 환경오염을 처리할 수 있는 장치에 관한 연구를 진행하였다. 그 결과, 발명 a와 b로 구성된 발명 A를 완성하였고, 2022. 7. 22. 지식재산처에 발명 A를 특허출원(이하 “특허출원 X”라 한다)하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 甲은 2022. 2. 10. 발명 A에 대하여 학위논문을 작성하여 발표하였는데, 발명 A에 대하여 특허출원 X를 할 때 특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)에 의한 공지예외주장을 하지는 않았다. 심사관은 공개된 甲의 논문에 의해 신규성 상실을 이유로 甲의 특허출원 X에 대하여 거절이유를 통지하였고, 甲은 특허출원 X의 보정기간 내에 보정을 하거나 분할출원을 통해 특허법 제30조에 의한 공지예외주장을 하여 거절이유를 극복하려고 한다. 甲의 주장이 타당한지에 관하여 설명하시오. (9점)

(2) 심사관은 출원단계에서 선행발명 Y에 의거하여 甲의 특허출원 X가 진보성이 없다는 이유로 거절결정하였다. 甲은 거절결정에 불복하는 심판을 청구하였지만 특허심판원은 기각심결을 하였다. 이에 甲은 심결취소소송을 제기하였고, 심결취소소송단계에서 지식재산처는 甲의 특허출원 X가 선행발명 Z에 의거하여 진보성이 없다고 주장하였다. 지식재산처의 주장이 타당한지에 관하여 설명하시오. (6점)

(3) 甲은 2022. 10. 20. 乙에게 발명 A에 대한 특허출원 X 및 그에 관한 분할출원으로 특허받을 수 있는 권리를 양도하였는데, 乙은 특허출원인 변경신고를 하지 않았다. 甲은 특허출원 X를 원출원으로 하여 분할출원을 하였고, 심사관은 이 분할출원에 대하여 진보성 위반으로 거절결정하였다. 甲은 거절결정에 불복하는 심판을 청구하였으나 기각심결되었고, 특허심판원으로부터 심결등본을 송달받았다. 甲으로부터 심결등본을 전달받은 乙이 심결취소소송을 제기하려고 한다. 乙이 심결취소소송을 제기할 수 있는 당사자로서 적합한지에 관하여 설명하시오. (5점)

모범답안

I. 설문 (1) — 보정 또는 분할출원을 통한 공지예외주장 가부 (9점)

1. 문제의 소재

甲이 원출원 시 제30조에 의한 공지예외주장을 하지 않았음에도, 1) 보정기간 내 보완을 통해, 또는 2) 분할출원을 통해 공지예외주장을 하여 신규성 상실의 거절이유를 극복할 수 있는지가 문제된다.

2. 공지예외주장 제도의 의의 및 요건 (§30)

(1) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 제29조 제1항에 해당하게 된 날부터 12개월 이내에 출원하면, 신규성·진보성 판단 시 공지되지 않은 것으로 본다 (§ 30①(1)). 절차적으로는 특허출원서에 그 취지를 적고, 증명서류를 출원일부터 30일 이내에 지식재산처장에게 제출하여야 한다 (§ 30②). (2) 사안: 甲은 2022. 2. 10. 학위논문 발표(자기공지) 후 12개월 이내인 2022. 7. 22. 출원하였으므로 실체적 요건은 충족하나, 출원 시 취지 기재·증명서류 제출을 누락한 절차상 하자가 있다.

3. 보정기간 내 사후 보완 가부 (§30③)

(1) 2015년 개정으로 신설된 제30조 제3항은 출원인의 이익을 두텁게 보호하기 위하여, 보완수수료를 납부하면 1) 제47조 제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간 또는 2) 특허결정·특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정) 등본 송달일부터 3개월 이내(설정등록을 받으려는 날이 그보다 짧으면 그 날까지)에 취지를 적은 서류·증명서류를 사후 제출할 수 있도록 하였다. (2) 사안: 심사관의 거절이유통지에 따른 제47조 제1항의 보정기간이 진행 중이므로, 甲은 보완수수료를 납부하고 취지·증명서류를 제출하여 공지예외의 효과를 받을 수 있다. 이 방법에 의한 甲의 주장은 타당하다.

4. 분할출원을 통한 공지예외주장 가부

(1) 판례(대법원 2020후11479)는 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차 (§ 52②(2) — 분할출원을 한 때 제출한 것으로 간주)를 준수하면 공지예외주장을 할 수 있다고 하며, 그 근거는 다음과 같다. i) 제52조 제2항 제2호는 원출원에서 공지예외주장을 하였을 것을 전제로 규정하고 있지 않다(문언). ii) 원출원의 청구범위에 기재된 발명은 공지기술과 달라 공지예외주장이 필요 없었더라도, 분할출원에서 권리범위를 재설계하는 과정에서 청구범위에 기재된 발명이 공지기술과 동일하거나 그로부터 쉽게 도출될 수 있으므로 공지예외주장을 통해 이를 보호할 필요가 있다. iii) 분할출원은 원출원과 별개의 독립된 출원이다. iv) 공지예외제도 (§ 30)는 출원인의 권리를 실질적으로 보호하기 위한 제도이다. (2) 사안: 원출원이 자기 공지일(2022. 2. 10.)부터 12개월 이내에 이루어졌으므로, 甲은 분할출원을 하면서 취지·증명서류를 제출하여 공지예외의 효과를 받을 수 있다. 이 방법에 의한 甲의 주장도 타당하다.

5. 결론

甲은 보정기간 내 제30조 제3항에 따른 사후 보완 또는 분할출원에서의 공지예외주장 어느 방법으로도 신규성 상실의 거절이유를 극복할 수 있으므로, 甲의 주장은 모두 타당하다.

II. 설문 (2) — 심결취소소송에서 선행발명 변경 주장의 타당성 (6점)

1. 문제의 소재

거절결정불복심판의 심결취소소송단계에서 지식재산처가 주선행발명을 Y에서 Z로 변경하여 진보성 흠결을 주장할 수 있는지가 문제된다.

2. 판례의 법리

(1) 새로운 거절이유 주장의 금지(대법원 2013후1054): 심사단계에서 거절결정을 하려면 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고 심판단계에서 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야 하는데(§ 62·§ 63·§ 170), 이러한 절차적 권리를 보장하는 규정은 **강행규정**이다. 따라서 의견제출의 기회를 부여받지 못한 **새로운 거절이유**를 들어 심판청구를 기각하는 것은 위법하고, 심결취소소송단계에서도 지식재산처장은 이를 새로 주장할 수 없다. 다만 이미 통지된 거절이유와 **주요한 취지가 부합하여** 이를 **보충하는 데 지나지 않는** 주장은 허용된다. (2) 주선행발명의 변경(대법원 2015후2341): 진보성 판단에서 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하면 출원발명과 **공통점·차이점의 인정과 그 차이점을 극복하여 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로**, 출원인에게 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다.

3. 사안 포섭 및 결론

심사·심판단계에서는 선행발명 Y에 기초하여 진보성이 판단되었는데, 지식재산처는 소송단계에서 비로소 주선행발명을 Z로 변경하여 주장하고 있고, 甲에게 Z에 관한 의견제출 기회가 부여된 사정도 보이지 않는다. 이는 새로운 거절이유의 주장에 해당하므로 지식재산처의 주장은 **부당하다**.

III. 설문 (3) — 특허출원인변경신고 없는 승계인의 원고적격 (5점)

1. 문제의 소재

특허를 받을 수 있는 권리를 양수하였으나 특허출원인변경신고를 하지 않은 乙이 심결취소소송을 제기할 수 있는 당사자에 해당하는지가 문제된다.

2. 판례의 법리 (대법원 2015후321)

(1) 심결취소소송은 당사자·참가인 또는 참가신청이 거부된 자만이 심결등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기할 수 있고(§ 186②3), 출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 등 일반승계를 제외하고는 **특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다**(§ 38④). 변경신고를 효력발생요건으로 한 것은 특허에 관한 절차의 참여자와 특허를 받을 자를 쉽게 확정함으로써 심사의 편의성·신속성을 추구하기 위한 것이다(대법원 2017후1274). (2) 이러한 규정들에 의하면 변경신고를 하지 않은 특정승계인은 양수의 효력이 발생하지 않아 심결취소의 소를 제기할 수 있는 당사자에 해당하지 아니하므로 그가 제기한 소는 부적법하고, 소 제기 후 변경신고를 하였더라도 그 시기가 **제소기간 경과 후라면 제소기간 내에 적법한 소 제기가 없었던 것이어서** 여전히 부적법하다.

3. 사안 포섭 및 결론

乙은 2022. 10. 20. 특허를 받을 수 있는 권리를 양수하였으나 특허출원인변경신고를 하지 않아 승계의 효력이 발생하지 않았으므로, 현재 상태로는 심결취소소송을 제기할 수 있는 당사자로 **부적합하다**. 乙이 소를 제기하려면 심결등본 송달일부터 30일의 제소기간 내에 특허출원인변경신고를 마쳐 승계의 효력을 발생시킨 후 원고로서 제소하여야 한다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
(1)-① 공지예외주장의 의의·요건(§30①(1))과 사안 포섭	2	甲의 학위논문 발표는 자기공지, 12개월 이내 출원(2022.2.10.→2022.7.22.) 요건 충족, 다만 출원 시 취지 기재·증명서류 미제출의 절차상 문제 지적
(1)-② 보정기간 등 제30조 제3항 사후 보완 가부	3	2015년 개정으로 신설된 공지예외 보완제도(§30③)를 적시하되, 보완수수료 납부 시 ① 제47조 제1항의 보정기간(§30③(1)) 또는 ② 특허결정·특허거절결정 취소심결(특허등록결정 심결) 등본 송달일부터 3개월 이내(설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧으면 그 날까지, §30③(2))의 기간에 취지·증명서류를 제출할 수 있음을 밝히고, 甲의 보정기간 내 주장이 타당함을 결론
(1)-③ 분할출원 시 공지예외주장 가부	3	대법원 2020후11479 판례(원출원에서 공지예외주장 없이 자기공지일로부터 12개월 이내 출원한 경우, 분할출원에서 적법절차 준수하여 공지예외주장하면 그 효과 인정) 인용, 甲의 분할출원 주장도 타당
(1)-④ 결론	1	두 방법 모두 타당하다는 명확한 결론
(2)-① 심결취소소송의 심리범위 일반론(무제한설·판례)	1.5	거절결정불복심판의 심결취소소송에서 심리대상은 심결의 위법성, 다만 심판단계에서 통지·의견제출기회 부여되지 않은 새로운 거절이유는 주장 불가
(2)-② 주선행발명 변경 = 새로운 거절이유(2015후2341)	3	주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유에 해당한다는 판례 명시
(2)-③ 사안 포섭·결론	1.5	Y→Z 변경, 甲에게 Z에 대한 의견제출기회 부여 사정 없음 → 지식재산처 주장 부당
(3)-① 심결취소소송 원고적격 (§186②)과 출원 후 승계 효력요건(§38④)	2	특허출원인변경신고를 하지 않은 특정승계인은 승계 효력 미발생
(3)-② 관련 판례(2015후321)	2	특정승계인이 변경신고 없이 심결취소의 소를 제기하면 원고적격 없고, 소 제기 후 제소기간 도과 후 변경신고해도 부적법
(3)-③ 사안 포섭·결론	1	乙은 변경신고 없이 제기하면 부적합, 제소기간 내 변경신고 시에는 가능하다는 취지 결론
합계	20	

축별 채점 기준

1) 논점 추출(약 40%)

• 특점 포인트

- 설문(1)에서 ④ 제30조 제3항에 따른 원출원에서의 사후 보완(보정기간뿐 아니라 특허결정 등본 송달일부터 3개월 내 기간도 포함), ① 분할출원에서의 공지예외주장 가부(2020후11479)라는 두 축을 분리해 논점화
- 설문(2)에서 '주선행발명의 변경'이 새로운 거절이유인지가 핵심 논점임을 포착(단순한 심리범위 일반론에 그치지 않음)
- 설문(3)에서 '특허출원인변경신고 흠결'과 '심결취소소송 원고적격'을 제38조 제4항 + 제186조 제2항 + 2015후321로 연결

• 감점 포인트

- (1)에서 제30조 제3항 개정(공지예외 보완제도) 자체를 언급하지 않고 구법 논의로 처리
- (1)에서 제30조 제3항의 보완 가능 시기를 제47조 제1항의 보정기간만으로 축소하여 서술하고 제30조 제3항 제2호(특허결정등본·특허거절결정 취소심결 등본 송달일부터 3개월 이내)를 누락
- (2)에서 심결취소소송 심리범위 일반론(무제한설·제한설 학설대립)만 장황히 쓰고 주선행발명 변경 판례로 포섭하지 못함
- (3)에서 제38조 제4항(특허출원인변경신고의 효력발생요건)를 누락하고 원고적격 일반론만 서술

2) 목차·구성(약 25%)

• 특점 포인트

- 배점(9/6/5)에 비례한 분량 배분. 특히 (1) 9점 문제에 보정·분할 두 축을 병렬 목차로 배치
- 각 소문제마다 '의의·조문 → 판례 → 사안 포섭 → 소결' 순의 정돈된 목차
- (1)에서 공지예외 요건·절차 → 제30조 제3항 보완(§30③(1)·§30③(2)) → 분할출원 판례로 이어지는 흐름

• 감점 포인트

- 9점 문제인 (1)을 5~6줄로 축약하거나, 5점 문제인 (3)에 지나치게 많은 분량 할애
- 조문 전사에 지면 낭비, 사안 포섭 부분 부실

3) 답안 작성·논증(약 35%)

• 특점 포인트

- 제30조 제1항·②·③(§30③(1) 및 §30③(2) 모두) 조문 번호를 정확히 인용하고, 2015년 개정으로 제30조 제3항(보완제도) 신설된 점을 반영

- 대법원 2020후11479(분할출원에서의 공지예외주장), 2015후2341(주선행발명 변경=새로운 거절이유), 2015후321(특허출원인변경신고 없는 소 제기 부적법) 3개 판례를 정확히 매칭
- 사안 사실관계(2022.2.10. 논문 발표 → 2022.7.22. 출원, 12개월 이내 요건 충족)를 명시적으로 포섭
- 각 설문마다 '타당/부당' 결론을 명확히 표시
- **감점 포인트**
- 판례 법리만 나열하고 사안 포섭 없음
- '주선행발명 변경' 법리를 몰라 (2)를 단순히 '새로운 거절이유는 주장 불가'로 얼버무림
- (1)에서 분할출원의 종속성만 언급하고 2020후11479 취지 미인용

감점 주의

- **제30조 제3항(공지예외 보완제도) 누락 또는 축소 서술:** 2015년 개정으로 신설된 조항으로, 이를 모르면 (1) 전반부에서 결정적 감점. 특히 보완 가능 시기를 제47조 제1항의 보정기간(§ 30③(1))만으로 좁게 서술하고, 특허결정 또는 특허거절결정 취소심결(특허등록결정 심결) 등본 송달일부 터 3개월 이내(설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧으면 그 날까지, § 30③(2))의 기간을 함께 적시하지 못하면 감점.
- **주선행발명 변경 판례(2015후2341) 누락:** (2)에서 이 판례를 인용하지 않으면 '심결취소소송 심리범위 일반론'만 서술한 답안이 되어 감점.
- **제38조 제4항와 2015후321 연결 실패:** (3)에서 특허출원인변경신고의 효력발생요건을 조문으로 명시하지 않고 판례만 인용하거나, 그 반대의 경우 감점.
- **사안 포섭 소홀:** 甲이 2022.2.10.에 자기공지, 2022.7.22.에 출원한 사실을 12개월 이내라는 요건과 명시적으로 연결하지 않으면 감점.
- **결론의 애매함:** 각 설문의 결론(타당/부당, 적합/부적합)을 명확히 밝히지 않으면 본문↔결론 모순으로 감점.
- **분할출원 시 공지예외 주장을 무조건 부정:** 원출원 미주장 시 분할출원에서 주장 불가라는 구법적 사고로 답하면 최신 판례(2020후11479)와 제30조 제3항 취지에 반해 감점.

2023년 제3문

사례형

30점

문제

甲은 “대형유동채널(A) + 소형유동채널(B) + 균일한 고체 중합체시트(C)를 구성요소로 하는 반도체 웨이퍼 연마용 패드 및 그 사용방법”에 관한 발명을 완성하여 2018. 6. 20. 특허출원한 후 2022. 3. 21. 특허등록을 받았다.

乙은 甲의 특허발명의 구성요소 중 대형유동채널(A)과 균일한 고체 중합체시트(C)와 동일한 구성을 가지면서 소형유동채널(B)이 결여되어 있고 마이크로 홀(M)이 부가되어 있는 연마용 패드에 관한 발명(A + C + M)을 완성하여 이 발명을 2022. 4. 20.부터 업으로서 실시하고 있다. 乙의 발명은 甲의 특허발명의 구성요건을 충족하지는 않지만, 乙이 자신의 발명인 연마용 패드를 사용하게 되면 甲의 특허발명의 구성요건을 충족하게 되어 특허권 침해에 이르게 할 개연성이 있다. 다만, 乙의 발명은 마이크로 홀(M)이라는 기술수단에 의하여 甲의 특허발명보다 더 우수한 작용효과를 기대할 수 있다.

乙은 자신의 발명(A + C + M)을 丙에게 공급하는 계약을 체결하였다. 丙은 乙의 연마용 패드를 사용하여 화학적·기계적 평탄화 공정을 수행하고 있고, 이 과정에서 다수의 다이아몬드입자가 부착된 컨디셔너로 연마용 패드의 표면을 압착하여 문지르는 브레이크 인(break-in) 및 컨디셔닝(conditioning) 공정이 필수적으로 부가됨을 확인하였고, 이러한 컨디셔닝 공정을 수행하는 경우에 乙의 발명의 연마용 패드에는 甲의 특허발명의 구성요소 중 소형유동채널(B)의 수치범위 내에 있는 폭과 길이 및 밀도를 가지고 연마슬러리를 이동시키는 통로가 포함되어 있어서 甲의 특허발명의 구성요소 중 소형유동채널(B)과 동일한 구조와 기능을 하는 줄무늬 홈이 반드시 형성된다는 사실을 알면서도 이를 계속 업으로서 실시하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 甲은 乙과 丙을 상대로 특허권 침해 주장을 하려고 한다. 甲의 특허권 침해주장이 타당한지 여부에 대하여 설명하시오. (12점)

(2) 丁은 甲의 연마용 패드의 반제품을 생산하고 있으며, 丁이 생산한 반제품은 조립하여 완제품으로 제작될 수 있다. 丁은 甲의 연마용 패드 반제품을 생산하여 제3국에 수출하였고, 戊는 제3국에서 이 반제품을 이용하여 완제품을 생산하고 있다. 甲은 丁과 戊를 상대로 특허권 침해를 주장하려고 한다. 甲의 주장이 타당한지 여부에 대하여 설명하시오. (8점)

(3) 특허권자 甲은 자신의 특허발명을 실시하는 데 적합한 장비를 제조·판매할 수 있도록 X와 통상실시권을 허락하는 계약을 체결하였다. 그 후 통상실시권자 X는 甲의 특허발명 중에서 반도체 웨이퍼 연마용 패드의 전용품인 대형유동채널(A)을 제작 및 납품하는 계약을 Y와 체결하였고, Y는 대형유동채널(A)을 제작하여 X에게 납품하고 있다. 甲이 Y에 대하여 특허법상 취할 수 있는 조치에 관하여 설명하시오. (10점)

모범답안

문제 3 모범답안

I. 설문 (1) - 乙과 丙에 대한 침해 주장의 타당성

1. 쟁점의 정리

乙의 실시제품(A+C+M)은 구성요소 B가 결여되어 있으므로 직접침해가 부정될 때 간접침해(§ 127)의 성립 여부가, 丙의 실시제품(A+b+C+M)은 특허발명의 구성을 모두 포함하므로 직접침해의 성립 여부가 문제된다.

2. 침해 판단의 법리

(1) 직접침해 — 구성요소완비의 원칙과 균등론

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(§ 97). 확인대상발명이 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으면 침해가 성립하고(구성요소완비의 원칙, 대법원 2017후424), 구성요소 중 일부가 결여된 경우에는 원칙적으로 보호범위에 속하지 않는다. 구성 중 일부가 변경된 경우에도 1) 과제의 해결원리가 동일하고, 2) 변경에 의하더라도 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 3) 그 변경이 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도인 때에는, 4) 특별한 사정(자유기술 해당·의식적 제외)이 없는 한 균등한 것으로서 여전히 보호범위에 속한다(대법원 2013다14361, 2014후2788). 한편 확인대상발명이 특허발명의 구성 전부를 포함하면서 새로운 구성을 부가한 경우에도 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 한 보호범위에 속한다(이용관계).

(2) 간접침해 (§127(1))

특허가 물건의 발명인 경우, 그 물건의 '생산에만 사용하는 물건'을 업으로서 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위는 특허권을 침해한 것으로 본다(2025.1.21. 개정으로 현행 § 127은 '다음 각 호의 구분'에 따른 제1호(물건발명)·제2호(방법발명) 구조로 규정된다). 판례에 따르면 '생산에만 사용'이라 함은 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적·상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 한다는 의미이고, 확인대상발명이 특허발명보다 더 우수한 작용효과를 기대할 수 있다는 사정은 결론에 영향이 없다(대법원 2007후3356).

3. 乙의 실시에 대한 판단

(1) 직접침해 여부

乙의 실시제품(A+C+M)은 구성요소 B가 포함되어 있으므로 구성요소완비의 원칙상 문언침해가 성립하지 않고, 구성의 변경이 아닌 결여이므로 균등론에 의하더라도 보호범위에 속한다고 볼 수 없다.

(2) 간접침해 여부

乙의 발명(A+C+M)은 甲의 특허발명(A+B+C)과 A, C 구성이 동일하고, 乙 제품을 사용하여 화학적·기계적 평탄화 공정을 수행하면 컨디셔닝 공정이 필수적으로 부가되어 특허발명의 B와 동일한 구조·기능을 갖는 줄무늬 홈(b)이 반드시 형성된다. 따라서 乙의 실시제품은 甲의 특허발명 물건의 생산에만 사용되는 물건에 해당하고, 마이크로 홈(M)의 부가로 더 우수한 효과를 기대할 수 있다는 사정은 결론에 영향이 없다.

(3) 결론

직접침해는 성립하지 않으나 乙의 실시행위는 간접침해(§ 127(1))에 해당하므로, 甲의 침해 주장은 **타당**하다.

4. 丙의 실시에 대한 판단

(1) 실시제품의 확정

丙은 乙로부터 공급받은 A+C+M을 사용하여 컨디셔닝 공정을 수행하고 있고, 이 과정에서 B와 동일한 구조·기능의 줄무늬 홈(b)이 반드시 형성되므로, 丙의 실시제품은 A+b+C+M이다.

(2) 직접침해 여부

丙의 실시제품에서 b는 특허발명의 B의 수치범위 내에 있는 폭·길이·밀도를 가지고 동일한 구조와 기능을 하므로, 丙의 실시제품은 특허발명의 구성요소 전부와 그 유기적 결합관계를 그대로 포함한다(구성요소완비의 원칙). 설령 b를 B와 문언상 동일하다고 보기 어렵더라도 과제의 해결원리와 작용효과가 동일하고 그 변경이 용이한 균등한 구성에 해당한다. 마이크로 홈(M)의 부가로 더 우수한 작용효과를 기대할 수 있더라도 특허발명이 일체성을 유지한 채 그대로 이용되고 있으므로 침해의 성립에 영향이 없다(이용관계). 나아가 丙은 연마용 패드의 사용방법 발명도 함께 실시하고 있고, 줄무늬 홈이 형성된다는 사실을 알면서도 계속 업으로서 실시하고 있으므로 고의도 인정된다.

(3) 결론

丙의 실시는 특허발명에 대한 직접침해에 해당하므로, 甲의 침해 주장은 **타당**하다.

5. 결론

乙에 대하여는 간접침해가, 丙에 대하여는 직접침해가 성립하므로, 甲의 乙과 丙에 대한 침해 주장은 모두 타당하다.

II. 설문 (2) - 丁과 戊에 대한 침해 주장의 타당성

1. 문제의 소재

丁은 국내에서 특허물건의 반제품을 생산하여 제3국에 수출하고, 戊는 제3국에서 그 반제품으로 완제품을 생산하고 있으므로, 각 행위에 甲의 특허권의 효력이 미치는지가 문제된다.

2. 판단의 법리

(1) 구성요소완비의 원칙

확인대상제품이 청구범위에 기재된 구성요소 전부와 그 유기적 결합관계를 그대로 포함하여야 침해가 성립하므로, 완제품 구성의 일부가 결여된 반제품의 생산은 원칙적으로 특허발명의 직접침해가 되지 않는다.

(2) 속지주의 원칙

특허권은 등록국의 영역 내에서만 효력이 미치므로, 국외에서의 생산·사용 등 실시행위에는 국내 특허권의 효력이 미치지 않는다.

(3) 반제품 사건에 대한 판례의 일반론

① 간접침해 제도는 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범위에서 그 실효성을 확보하기 위한 것이고 속지주의 원칙상 특허권의 효력은 등록국 영역 내에 한정되므로, 특허법 제127조 제1호의 '생산'이란 **국내에서의 생산**을 의미하고, 완제품 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립하지 않는다(대법원 2014다42110). ② 다만 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되고, 하나의 주체에 수출되어 마지막 단계의 가공만 예정되어 있으며 그 가공이 극히 사소한 경우에는 국내에서의 생산으로 보아 직접침해가 인정될 수 있다(대법원 2025다202970 참조). ③ 한편 2025. 1. 21. 개정 특허법 제127조 제1호는 전용품의 '수출'을 침해 간주 행위로 추가하였으나, '물건의 생산'을 국내생산으로 제한해석하는 판례 법리가 유지된다면 수출에 대해서는 여전히 간접침해를 물을 수 없다는 해석의 논란이 있다.

3. 戊에 대한 판단

戊는 제3국에서 반제품을 이용하여 완제품을 생산하고 있으므로, 속지주의 원칙상 甲의 국내 특허권의 효력이 미치지 않는다. 따라서 甲의 戊에 대한 침해 주장은 **부당**하다.

4. 丁에 대한 판단

(1) 丁의 반제품은 완제품 구성의 일부가 결합된 것이므로 구성요소완비의 원칙상 그 자체로 직접침해가 성립하지 않고, 완제품 생산이 제3국에서 이루어지는 이상 '생산'을 국내생산으로 해석하는 판례 법리상 간접침해도 성립하지 않는다(수출을 간주 행위로 추가한 개정법 하에서의 해석 논란은 앞서 본 바와 같다). (2) 다만 丁이 국내에서 특허발명의 부품 또는 구성 전부를 생산하였고, 戊에 의한 마지막 단계의 조립·가공이 극히 사소한 경우라면 국내에서의 생산으로 보아 **직접침해**가 성립할 수 있다.

5. 결론

戊에 대한 침해 주장은 부당하고, 丁에 대한 침해 주장은 반제품 국내생산 예외 요건(부품 전부 국내생산·극히 사소한 가공)을 충족하는 경우에 한하여 타당할 수 있다.

Ⅲ. 설문 (3) - Y에 대하여 甲이 취할 수 있는 조치

1. 문제의 소재

Y는 특허발명의 전용품인 대형유동채널(A)만을 제작·납품하고 있으므로 직접침해는 성립하지 않는다. 통상실시권자 X에게 전용품을 공급하는 Y의 행위가 간접침해에 해당하여 甲이 특허법상 조치를 취할 수 있는지가 문제된다.

2. 판례의 법리 — 마찰교반용접방법 사건(대법원 2017다290095)

판례는 방법발명의 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 공급받아 방법발명을 실시하는 경우, 1) 제3자의 전용품 생산·양도를 간접침해로 보면 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고 특허권이 부당하게 확장되며, 2) 특허권자는 실시권 설정 시 제3자로부터 전용품을 공급받아 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정함으로써 특허권 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있어 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기 어렵다는 이유로, 제3자의 전용품 생산·양도 행위는 간접침해에 해당하지 않는다고 하였다. 다만 이 법리는 실시권자가 **허락받은 범위 내에서 특허발명을 실시하기 위하여** 전용품을 공급받는 경우에 관한 것이다.

3. 사안의 포섭

(1) X는 '甲의 특허발명을 실시하는 데 적합한 장비의 제조·판매'에 대한 통상실시권만을 허락받았을 뿐, 특허발명 자체(연마용 패드 및 그 사용방법)의 실시를 허락받은 것이 아니다. (2) 그런데 X는 이러한 **실시권의 범위를 벗어나** 특허발명을 실시하기 위하여 Y에게 전용품인 대형유동채널(A)의 제작·납품을 의뢰한 것이므로, 실시권 범위 내의 실시를 전제로 간접침해를 부정한 위 판례의 법리는 사안에 적용될 수 없다. 따라서 Y가 제작·납품하는 대형유동채널(A)이 특허발명의 생산에만 사용하는 물건(전용품)에 해당하는 한, Y의 생산·양도 행위는 간접침해(§ 127(1))에 해당하고 甲은 Y에 대하여 특허법상 조치를 취할 수 있다.

4. 甲이 취할 수 있는 조치

(1) 민사적 조치

침해금지 및 예방청구(§ 126), 손해배상청구(§ 128), 신용회복청구(§ 131), 부당이득반환청구 등을 제기할 수 있다.

(2) 심판 절차

Y를 피심판인으로 하여 적극적 권리범위확인심판(§ 135)을 청구할 수 있다.

(3) 형사적 조치

판례에 따르면 간접침해는 특허권 침해로 '보는' 것에 불과하여 형사처벌 대상인 침해죄(§ 225)에는 해당하지 않으므로, 甲은 Y에 대해 형사고소 등 형사적 조치는 취할 수 없다.

5. 결론

X가 실시권의 범위를 벗어나 특허발명을 실시하기 위하여 Y에게 납품을 의뢰한 이상 Y의 전용품 공급행위는 간접침해에 해당하므로, 甲은 Y에 대하여 침해금지 및 예방청구·손해배상청구 등 민사적 조치와 적극적 권리범위확인심판 청구를 할 수 있다. 다만 형사적 조치는 취할 수 없다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
(1) 乙에 대한 침해 주장 - 간접침해 성립	6점	제127조 제1호(물건발명), 직접침해 부정($A+C+M \neq A+B+C$) → 간접침해 검토, '∼에만 사용'의 의미(2007후3356), 컨디셔닝 공정으로 B와 동일한 줄무늬홈(b) 필연 형성 → 전용품성 인정, 더 우수한 효과라도 결론 무관 → 침해 주장 타당
(1) 丙에 대한 침해 주장 - 직접침해	6점	실시제품 확정($A+b+C+M$), 구성요소완비의 원칙(B와 동일 구조·기능의 b 포함)·문언 비동일 시 균등 구성, 부가구성 M은 일체성 유지 시 침해에 영향 없음(이용관계), 사용방법 발명도 실시 → 침해 주장 타당
(2) 戊에 대한 침해 주장 - 속지주의	3점	속지주의 원칙, 제3국에서의 완제품 생산은 국내 특허권 효력 밖 → 침해 주장 부당
(2) 丁에 대한 침해 주장 - 반제품 국외수출	5점	구성요소완비·속지주의·반제품 판례 일반론(2014다42110 국내생산 원칙, 2025다202970 예외법리, 2025년 개정 제127조 수출 추가 해석 논란) 선제시 → 간접침해 불성립, 예외 요건(부품 전부 국내생산 + 극히 사소한 가공) 충족 시 직접침해 성립 가능
(3) Y에 대한 조치 - 실시권자 공급형 간접침해	10점	마찰교반용접방법 판례(2017다290095)의 간접침해 부정 법리와 그 사정거리(허락 범위 내 실시 전제) 제시, X의 통상실시권 범위 (장비 제조판매만 허락) 이탈 → Y의 전용품 공급은 간접침해 성립, 취할 수 있는 조치(민사적 침해금지·손해배상·권리범위확인심판, 형사조치 불가)

배점 합계: 30점

특별 채점 기준

1) 논점 추출 (12점)

- **특점:** (1)에서 乙은 간접침해, 丙은 직접침해(이용침해)로 분리 접근했는가 / (2)에서 속지주의와 반제품 수출 판례(녹다운 방식)를 모두 짚었는가 / (3)에서 실시권자 공급 시 간접침해 성립 여부(2017다290095)를 핵심 쟁점으로 포착했는가.
- **감점:** 乙의 실시제품을 그대로 문언침해 대상으로 논한 답안, 丙을 간접침해로만 처리한 답안, (3)에서 X의 통상실시권 범위(장비 제조판매만 허락)에 대한 해석 논점을 놓친 답안.

2) 목차·구성 (7.5점)

- **특점:** 각 물음을 물음별로 목차화하고, 침해 주체별(乙/丙, 丁/戊)로 분리 서술. 배점 비례로 (1) 12점에 가장 큰 분량, (2) 8점, (3) 10점 안배.
- **감점:** 간접침해 일반론 상황, 사안 포섭 부족, 판례 사실관계와 본 사안 사실관계 대응관계를 명시하지 않음.

3) 답안 작성·논증 (10.5점)

- **특점:** 직접침해 법리(구성요소완비·균등론)와 간접침해 법리를 먼저 제시한 후 주체별 판단, 조문(§ 97·§ 127) → 판례(2007후3356, 반제품 수출 판례, 2017다290095) → 사안 포섭 → 결론의 흐름. 학설 대립(간접침해 독립설·종속설) 시 자기 입장 명시. (3)에서 마찰교반용접방법 판례의 사정 거리를 짚고 X의 실시권 범위 이탈을 근거로 간접침해 성립 결론 도출.
- **감점:** '∼에만 사용'의 판단기준(사회통념상 다른 용도) 미제시, 균등 구성 포함 시에도 직접침해가 성립한다는 법리 누락, 반제품 판례의 예외법리(극히 사소한 가공) 누락, (3)에서 형사조치 가부에 대한 검토 누락.

감점 주의

- 乙의 발명이 더 우수한 효과를 갖는다는 사정만으로 간접침해·이용침해가 부정된다고 결론지음(2007후3356 반대).
- 丙에 대해 乙과 동일하게 간접침해로 처리 → 丙은 직접 실시자($A+b+C+M$)로서 직접침해임을 놓침.
- 戊의 국외 완제품 생산에 대해 속지주의 언급 없이 침해 성립 여부만 판단.
- 丁의 반제품 수출을 무조건 간접침해 성립 또는 무조건 불성립으로 단정(예외 법리 언급 필요).
- (3)에서 통상실시권자 X의 실시허락 범위를 '특허발명 실시 자체'로 오해하여 간접침해를 곧바로 부정.
- (3)에서 조치를 묻는 문제임에도 침해 성립 여부만 서술하고 구체적 조치(권리범위확인심판, 침해금지청구, 형사조치 불가 등)를 누락.
- 간접침해 적용 법규정을 '제127조 제1항'으로 표기(2025.1.21. 개정 전 구법 표기) → 현행법상 '제127조 제1호'(물건발명)·'제2호'(방법발명)로 표기해야 함.

2023년 제4문

사례형

20점

문제

甲은 심혈관 치료물질에 관하여 A + B + C로 구성된 발명 X를 완성하여 특허출원을 하였다. 이때 발명 X의 구성요소 중에서 C는 C1과 C2로 구성되어 있다.(단, 이때 C1과 C2는 C의 하위구성요소이다.) 乙은 심혈관 치료물질에 관하여 A + B + C2로 구성된 발명 Y를 완성하여 특허출원을 하였다. 甲의 발명 X가 특허등록된 후에 丙은 A + B + M으로 구성된 심혈관 치료물질에 관한 발명 Z를 완성하여 실시하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 선택발명에 대해 설명하고, 乙의 선택발명이 진보성을 인정받기 위한 요건에 관하여 설명하시오. (5점)

(2) 다음의 경우에 甲과 乙의 출원 중에서 후출원을 실시하는 것이 선출원의 특허권을 침해하는지 여부에 대하여 설명하시오. (단, 후출원은 등록되지 않은 것으로 가정한다.) (5점)

1. 甲의 특허출원이 선출원인 경우
2. 乙의 특허출원이 선출원인 경우
3. 甲과 乙의 출원이 동일자 출원인 경우

(3) 심혈관 치료물질에 관한 발명 X에 대하여 특허를 받은 甲은 특허발명 X의 구성요소 중 C가 丙의 발명의 구성요소 M과 과제해결원리가 동일하다고 판단하고 있다. 이에 甲은 丙을 상대로 특허권 침해를 주장하려고 한다. 丙은 甲의 특허권 침해 주장이 부당하다고 판단하고 있다. 丙이 甲의 특허권 침해주장에 대하여 취할 수 있는 대응조치에 대하여 설명하시오. (10점)

모범답안

I. 설문 (1) — 선택발명과 진보성 인정요건 (5점)

1. 선택발명의 의의

선택발명이란 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 그 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건의 전부 또는 일부로 하는 발명을 말한다.

2. 진보성 인정요건 (§29②)

(1) 판례 법리

판례는 선택발명에도 일반적인 진보성 판단방법이 적용되므로 선행발명에 상위개념이 기재되어 있다는 사정만으로 곧바로 구성의 곤란성이 부정되지 아니한다고 한다(2019후10609, 2020후11738). **구성**의 곤란성은 1) 상위개념에 포함되는 하위개념의 개수, 2) 특정 하위개념을 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기·암시의 유무, 3) 선행발명에 구체적으로 개시된 하위개념과의 구조적 유사성을 종합하여 판단한다. 효과가 현저하면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 되고, 구성의 곤란성이 불분명하더라도 **이질적이거나 양적으로 현저한 효과**가 있으면 진보성이 부정되지 아니한다. 효과의 현저성은 **명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과**를 중심으로 판단하고, 의심스러운 때에는 그 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후의 실험자료로 증명할 수 있다.

(2) 사안 포섭

상위개념 C에 포함되는 하위개념은 C1과 C2 **둘뿐**이어서 선택의 폭이 매우 좁고 C2는 선행발명 X에 이미 **구체적으로 개시**되어 있으므로, 통상의 기술자가 C2를 쉽게 선택할 수 있어 구성의 곤란성을 인정받기 어렵다. 따라서 Y(A+B+C2)가 진보성을 인정받으려면 C2 선택에 따른 심혈관 치료 효과가 **이질적이거나 양적으로 현저**하고 그 효과가 명세서에 기재되어 인식·추론될 수 있어야 한다.

3. 결론

Y는 구성의 곤란성을 인정받기 어려우므로, 진보성이 인정되려면 C2 선택에 따른 **이질적이거나 양적으로 현저한 효과**가 명세서의 기재로부터 인식·추론될 수 있어야 한다.

II. 설문 (2) — 상하위개념 출원의 실시와 침해 여부 (5점)

1. 甲의 출원이 선출원인 경우(상위개념→하위개념 실시)

(1) 선택침해 법리와 그 비판

판례는 선택발명에 현저히 향상된 작용효과가 있으면 특허발명과 **다른 발명**으로서 그 권리범위에 속하지 아니한다고 한다(90후960). 그러나 특허요건의 판단과 침해의 판단을 혼동한 것이라는 비판이 있고, 이에 따르면 선행발명의 기술적 사상을 그대로 이용하여 **일체성이 상실되지 아니한 이상** 침해로 보아야 한다.

(2) 사안

판례에 의하면 Y의 현저한 효과 유무에 따라 침해 여부가 갈린다. 그러나 Y가 X의 기술적 사상을 그대로 이용하여 일체성을 유지하는 이상 현저한 효과의 유무와 관계없이 甲의 특허권을 **침해**한다고 봄이 타당하다.

2. 乙의 출원이 선출원인 경우(하위개념→상위개념 실시)

甲의 A+B+C 실시가 A+B+C2의 실시에 해당하는 때를 제외하고는 선출원 발명의 기술적 사상을 이용한 것이 아니어서 구성요소완비의 원칙이나 균등론이 적용될 여지가 없으므로 침해가 성립하지 아니한다.

3. 동일자 출원인 경우

(1) 협의제와 발명의 동일성 판단 (§36②)

동일자 출원 사이에는 협의제가 적용되므로 두 발명의 동일 여부가 문제되고, 동일성은 **실질에 의하여** 판단한다. X와 Y가 동일하지 아니하다면 양자 모두 등록될 수 있다.

(2) 제98조의 해석

제98조는 **특허출원일 전에 출원된** 타인의 특허발명을 이용하거나 그 권리와 저촉되는 경우만을 규정할 뿐 출원일이 같은 경우는 규정하지 아니한다. 따라서 동일자 출원 상호 간에는 이용·저촉관계라도 **양자 모두 자유롭게 실시**할 수 있으므로, 乙의 침해는 성립하지 아니한다.

4. 결론

甲의 출원이 선출원이면 침해로 봄이 타당하고, 乙의 출원이 선출원이면 원칙적으로 비침해이며, 동일자 출원이면 양자 모두 자유롭게 실시할 수 있다.

III. 설문 (3) — 균등침해 주장에 대한 丙의 대응조치 (10점)

1. 문제의 소재

침해 주장이 부당한 경우는 침해가 **성립하지 아니하는** 경우와 침해가 성립하더라도 **권리행사가 적절하지 아니한** 경우로 나뉜다. Z(A+B+M)는 X(A+B+C)와 C:M의 차이가 있어 문언침해가 성립하지 아니하고 甲도 과제해결원리의 동일성을 내세우므로, **균등론**의 성부가 주요 쟁점이다.

2. 균등론의 요건 (대법원 2013다14361, 2014후2788)

청구범위에 기재된 구성 중 일부를 변경한 경우에도 1) 과제의 해결원리가 동일하고, 2) 그 변경에 의하더라도 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 3) 그러한 변경을 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도이면, 4) 확인대상발명이 자유기술에 해당하거나 출원절차에서 의식적으로 제외되는 등 특별한 사정이 없는 한 균등침해가 성립한다. 앞의 세 요건은 특허권자가 증명할 적극적 요건, 특별한 사정은 상대방이 항변할 소극적 요건이다.

3. 침해소송에서의 항변 — 균등 요건의 다툼

(1) 제1요건(과제해결원리의 동일성) 불충족 주장

과제해결원리의 동일 여부는 **발명의 설명과 출원 당시의 공지기술을 참작하여 특허발명에 특유한 기술사상의 핵심**을 실질적으로 탐구하여 판단한다(대법원 2016마5698). 그 핵심이 이미 공지되었다면 균등의 폭이 좁아지므로, 丙은 출원 전 공지기술을 제시하여 그 핵심이 공지되었음을 밝히거나 C와 M의 과제해결원리가 다름을 주장할 수 있다.

(2) 제2요건·제3요건 불충족 주장

丙은 M이 C와 실질적으로 다른 작용효과(새로운 약리기전·부작용 감소 등)를 나타냄을, 또는 통상의 기술자가 C를 M으로 변경하는 것이 용이하지 아니함을 기술수준 자료로 증명하여 다룰 수 있다.

(3) 제4요건(특별한 사정) 해당 주장

丙은 Z가 출원 전 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 **자유기술**에 해당한다고 항변하거나, 甲의 출원경과를 조사하여 M 또는 그에 상응하는 구성이 청구 범위로부터 **의식적으로 제외**되었음을 주장할 수 있다.

4. 소극적 권리범위확인심판의 청구 (§135②)

丙은 침해소송과 별도로 같은 이유를 들어 Z가 甲의 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 **소극적 권리범위확인심판**을 청구할 수 있고, 침해소송이 제기된 뒤에 청구하여도 확인의 이익이 인정된다(대법원 2016후328). 다만 그 심결은 유력한 증거로 활용될 뿐 법원을 기속하지 못한다(대법원 99다59320).

5. 무효사유가 있는 경우의 조치

X에 무효사유가 있는 경우 丙은 이해관계인으로서 **무효심판**(§133①)을 청구하여 특허권을 소급적으로 소멸시키고, 심결 확정 시까지 침해소송 절차의 **중지를 신청**할 수 있다(§164②). 무효심결 확정 전이라도 신규성·선출원 위반이면 **권리범위가 인정되지 아니하여** 침해가 아님을(81후56 전합), 진보성 위반이 명백하면 특별한 사정이 없는 한 **권리남용**임을 항변할 수 있다(2010다95390 전합).

6. 결론

丙은 침해소송에서 균등의 적극적 요건 불충족 또는 특별한 사정의 존재를 이유로 항변하고 같은 이유로 소극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있으며, X에 무효사유가 있으면 무효심판을 청구하면서 소송절차의 중지를 신청하고 권리범위 불인정·권리남용의 항변을 함께 제기할 수 있다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특정 포인트
설문(1) 선택발명 의의 및 진보성 요건	5점	선택발명 개념(상위개념→하위개념) 정확 서술, 판례(2019후10609 등) 법리에 따른 구성의 곤란성·효과의 현저성 요건, 사안 포섭(C→C2, 하위개념 2개인 사정 반영)
설문(2) 상하위개념 발명 간 침해 판단	5점	1) 甲 선출원 시 선택침해 법리(90후960)와 그 비판(보호범위 문제≠특허요건 문제, 일체성 유지 시 침해), 2) 乙 선출원 시 상하위개념 실시는 A+B+C가 A+B+C2의 실시인 경우를 제외하면 선출원 발명의 기술적 사상 이용이 아니어서 침해 불성립, 3) 동일자 출원 시 협의제(\$36②)의 실질적 동일성 판단(선택발명 관계라 부적용)과 §98 '특허출원일 전' 해석상 양자 자유 실시 → 침해 불성립
설문(3) 균등침해에 대한 丙의 대응조치	10점	침해주장 부당=불성립/권리행사 부적절 구분, 균등론 4요건(적극 3+소극 1) 요건별 다툼(제1요건 과제해결원리, 제2·3요건 작용효과·변경 용이성, 제4요건 자유기술·의식적 제외), 소극적 권리범위확인심판(\$135②), 무효사유 시 무효심판(\$133①)+소송중지 신청(\$164②)·권리남용 항변(2010다95390)

합계: 20점

축별 채점 기준

1) 논점 추출 (약 8점)

- **특점:** (1) 선택발명 정의와 진보성 판단기준(2019후10609 이후 판례)을 정확히 포착, (2) 상하위개념 출원경합의 3유형별 침해 판단 논점 구별, (3) 균등침해 주장에 대한 대응조치가 주논점임을 인식하고 균등요건 각 항목별 다툼 방안을 구체적으로 적시
- **감점:** 선택발명 진보성 법리의 최신 판례 흐름(구성의 곤란성 우선 검토) 누락, (2)에서 선택침해·이용침해·자유실시 관계 미검토, (3)에서 균등요건만 나열하고 대응조치를 구체적으로 제시하지 못한 경우

2) 목차·구성 (약 5점)

- **특점:** 설문별 5:5:10 배점 비례 분량 배분, 균등론 요건을 소제목으로 분설, 문언침해/균등침해/기타 조치(권리남용, 무효심판, 소극적 권리범위확인심판)를 위계 있게 구성
- **감점:** (3)에서 균등침해 요건 일반론만 장황하게 서술하고 사안 포섭 부실, 배점 5점 문제에 지나치게 긴 답안, 서론·결론의 형식적 반복

3) 답안 작성·논증 (약 7점)

- **특점:** 조문(\$ 29②, § 36②, § 98, § 127, § 133, § 135) → 판례 → 사안 포섭 순의 논증, 90후960·2019후10609·균등론 4요건 판례의 정확한 인용, 결론 명확성
- **감점:** 판례 법리 부정확 인용, 사안 사실관계(C가 C1·C2 2개로만 구성됨)의 특수성 무시, 조문 전사식 나열, 결론 모호

감점 주의

- **설문(1):** 종래 판례(2001후2740 등)만 인용하고 최신 대법원 판례(2019후10609, 2020후11738)의 '구성의 곤란성 우선 검토' 태도를 반영하지 않으면 감점. 하위개념이 2개뿐이라는 사안의 특수성(구성의 곤란성 인정 곤란)을 지적하지 않으면 감점.
- **설문(2):** 甲 선출원 시 90후960 법리와 그 비판(일체성 유지 시 침해)을 함께 서술하지 않으면 감점. 동일자 출원의 경우 협의제의 실질적 동일성 판단과 §98 '특허출원일 전' 문언 해석(양자 자유 실시)을 누락하면 감점.
- **설문(3):** 균등요건을 단순히 나열하기만 하고 '丙이 어떤 자료로 어떤 요건을 다룰 것인지'를 구체적으로 제시하지 못하면 감점. 특히 ① 출원 전 공지기술 조사를 통한 과제해결원리·작용효과 다툼, ② 출원경과 참작에 의한 의식적 제외 항변, ③ 자유실시기술 항변을 구분해서 쓰는 것이 중요. 권리남용 항변, 무효심판, 소극적 권리범위확인심판 등 부수적 조치 누락 시 감점.

PART 15

2024

제1문	보정요구서의 내용·취지 (§46 절차보정+§6 특별수권) · 국내우선권주장 취지(장점)+개량발명 예시	30점
제2문	확인대상발명의 특정 3측면 · 1) 청구인용판결의 이유·효과·문제점	20점
제3문	무효심판 내 정정청구 취지 · 정정 허용범위(정정사유·신규사항추가금지·실질적 확장변경 금지·정정 후 특허요건)	30점
제4문	판단의 구조(특허발명의 특정 → 확인대상발명의 특정 → 구성요소완비·균등론 → 법률의 제한·확장) · 균등론(2016마5698)·법률의 제한·확장	20점

2024년 제1문

사례형

30점

문제

주식회사 甲은 2021. 5. 1. 자신의 발명을 대리인 없이 스스로 다음과 같이 특허출원하였다. [이하 ‘선출원’이라 한다.]

[발명의 설명]

A

[청구범위]

[청구항 1] A

이후 주식회사 甲은 A 발명을 개량하였고, A 발명 및 개량 발명에 대하여 주식회사 乙에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였으며(다만 우선권의 승계는 별도로 하지 않음), 주식회사 乙은 변리사 김특허를 대리인으로 선임하였다.

변리사 김특허는 2022. 4. 1. ‘주식회사 乙’을 출원인으로 기재하고, 대리인 란에 자신과 자신이 선임한 복대리인 변리사 이실용을 기재하면서 위임사항 란에 “특허의 출원 및 등록에 관한 모든 절차”라고만 기재된 위임장을 각각 첨부하였고, 위 선출원을 기초로 특허법 제55조의 우선권을 주장하면서(출원시 그 취지를 기재하고 선출원을 표시하였으며, 다만 우선권주장서류는 별도로 제출하지는 않음) 다음과 같이 특허출원하였다.

[발명의 설명]

A, A+B

[청구범위]

[청구항 1] A

[청구항 2] A+B

주식회사 乙은 특허출원시부터, A 발명의 실시에 대하여 제3자인 주식회사 丙에게 월 2,000,000원의 로열티를 지급받고 있고, A+B 발명의 실시에 대하여 제3자인 주식회사 丁에게 월 3,000,000원의 로열티를 지급받고 있다.

한편, 주식회사 戊는 A 발명을 2022. 2. 1.부터 주식회사 乙의 허락 없이 지역사회의 발전을 위하여 비영리로 실시 중이다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다)

(1) 주식회사 乙의 특허출원에 대하여 지식재산청은 2022. 6. 1.자 보정 요구서를 발송하였다. 이에 대한 구체적인 내용 및 취지를 설명하시오.

(5점)

(2) 일반적으로 출원인이 특허법 제55조의 우선권을 주장하는 취지(장점)를 설명하고, 개량 발명의 예를 제시하시오. **(7점)**

(3) 2024. 7. 1. 현재, 주식회사 戊에 대한 주식회사 乙의 권리 성립 요건과 권리행사에 필요한 절차를 설명하시오. **(8점)**

(4) 만약, 주식회사 乙의 특허출원이 2022. 12. 1. 공개되었고, 이후 주식회사 乙이 자신의 발명을 전부 침해하였다는 이유로 주식회사 戊에게 2023. 1. 1. 경고장을 발송하여 주식회사 戊가 2023. 2. 1. 송달받았으며, 이후 2023. 10. 1. 주식회사 乙의 특허출원이 등록되었다고 한다면, 다음 물음에 답하시오. **(10점)**

1. 주식회사 乙이 주식회사 戊에게 특허법상 보상금 지급 청구를 할 수 있는 기한을 설명하시오.

2. 2024. 7. 1. 현재 주식회사 乙이 특허법상 보상금 지급 청구를 하였을 경우 주식회사 戊에게 받을 수 있는 예상 금액을 설명하시오.

3. A 발명에 대한 특허권 존속기간만료일은 언제인지 설명하시오.

모범답안

문제 1 모범답안

I. 설문(1) — 보정 요구서의 구체적 내용 및 취지 (5점)

1. 절차보정명령(\$46)

지식재산처장은 특허에 관한 절차가 1) 제3조제1항(미성년자 등의 행위능력)·제6조(대리권 범위)을 위반한 경우, 2) 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우, 3) 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다(\$46).

2. 대리인의 특별수권사항(\$6)

특허법 제6조는 국내에 주소나 영업소가 있는 자로부터 절차를 위임받은 대리인은 특별한 수권 없이 **국내우선권주장 및 그 취하**(\$6(6))와 **복대리인의 선임**(\$6(8)) 등을 할 수 없다고 규정한다. 본인에게 중대한 결과를 초래하는 절차에 본인의 명시적 의사를 확인하여 **본인을 보호**하려는 취지이다.

3. 사안 — 보정요구서의 구체적 내용

(1) **국내우선권주장(\$55)에 대한 특별수권 흠결** → 위임장에 "특허의 출원 및 등록에 관한 모든 절차"라는 포괄위임 문언만 있고 제55조 우선권주장에 대한 특별수권 표시가 없으므로, 이에 관한 대리권 증명서류 보정을 요구한다. (2) **복대리인 선임에 대한 특별수권 흠결** → 이실용의 복대리인 선임에 대한 특별수권 표시가 없으므로, 복대리 특별수권을 증명하는 서류 보정을 요구한다.

4. 관련문제 — 보정요구 대상이 아닌 사항

조약우선권과 달리 **국내우선권주장에는 우선권증명서류가 요구되지 아니하고**(\$55②), **승계를 통해 특허를 받으려는 자이면** 주장할 수 있어 별도의 우선권 승계는 요건이 아니며, 甲에서 乙로의 **권리승계 증명서류도 필수 제출서류가 아니어서** 주된 보정요구 대상이 아니다.

5. 결론

지식재산처장은 특허법 제46조의 절차보정명령으로 국내우선권주장(\$6(6))과 복대리인 선임(\$6(8))에 관한 특별수권 흠결의 보정을 요구하여야 한다.

II. 설문(2) — 국내우선권주장의 취지와 개량발명의 예 (7점)

1. 국내우선권주장의 의의(\$55)

특허출원인이 자신의 선출원에 최초 첨부된 명세서·도면에 기재된 발명을 기초로, 선출원일부터 1년 이내에 우선권을 주장하여 후출원할 수 있는 제도이다.

2. 취지(장점)

(1) 기본발명과 개량발명의 일체 보호

선출원의 기본발명을 구체화·개량한 발명을 하나의 출원으로 누락 없이 보호하고, 절차와 비용을 절감하며, 기본발명의 심사청구기간·존속기간을 우선기간만큼 연장할 수 있다(새로 추가된 개량발명에는 소급효가 인정되지 아니한다). 통상의 절차로 출원하면 자기 선출원과의 동일발명 거절, 선출원을 보정하면 신규사항 추가 거절의 위험이 있는데 이를 회피할 수 있다.

(2) 내·외국인 간의 형평성 도모

외국출원에 대해서만 인정되는 조약우선권주장과 달리 국내출원에 대하여 우선권을 인정함으로써 내·외국인의 불평등을 해소한다.

(3) PCT 이용의 활성화

PCT 제8조(2)(b)는 자기지정의 경우 우선권주장의 효과를 지정국의 국내법령에 위임하고 있으므로, 국내법에 적용 법규정을 둬으로써 대한민국을 지정하는 자기지정 우선권주장을 이용할 수 있게 되어 PCT 이용의 활성화에 기여한다.

판례도 제55조 제1항이 선·후출원인의 동일성을 요구하지 아니하고 제38조 제4항은 우선권주장 절차에 적용되지 아니하므로, 권리를 승계받았다면 후출원 시 출원인변경신고를 마치지 아니하였더라도 우선권을 주장할 수 있다고 하여 누락된 개량 성과를 폭넓게 보호하려는 취지를 확인하였다(2017후1274).

3. 개량발명의 예 — 국내우선권주장의 이용형태

1) 실시예 보충형 — 판명된 실시예를 우선 기재하여 출원하고 이후 실증을 통하여 갖추어지는 대로 실시예를 추가해 나가는 유형이다(특히 화학발명에서 실시예 추가가 부적절한 보정으로 취급될 위험을 예방). **2) 상위개념 추출형** — 실증된 발명적 아이디어를 그때마다 개별출원하여 두었다가 이들을 기초로 상위개념이 얻어졌을 때 하나로 묶어 보다 넓은 범위의 권리를 취득해 나가는 유형이다. **3) 출원의 단일성 이용형(일 군의 발명)** — 기술적 사항은 상이하나 산업상 이용분야가 극히 밀접하여 출원의 단일성(\$45)을 충족하는 발명들을 하나의 출원으로 하여 우선권주장을 하는 유형이다(예: 물건과 그 물건을 생산하는 방법).

4. 결론

제도의 취지는 위 세 가지에 있고, 판례도 선·후출원인이 달라도 권리승계가 있으면 우선권주장을 허용한다(2017후1274). 사안의 **A에서 A+B로의 변경은 기본발명에 B를 부가한 개량발명을 하나의 출원으로 묶은 예**이다.

Ⅲ. 설문(3) — 2024.7.1. 현재 乙의 戊에 대한 권리 성립요건과 행사절차 (8점)

1. 문제의 소재

2024.7.1. 현재 乙의 특허출원은 설정등록 전이므로, 戊의 **등록 전 실시에 대하여는 보상금청구권**(§ 65)이, **설정등록 후의 실시에 대하여는 특허권이** 문제된다. 이하 보상금청구권을 중심으로 검토한다.

2. 보상금청구권(§65)의 성립요건

(1) 의의·법적 성질

출원인은 출원공개 후 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고 업으로 실시한 자에게 그때부터 설정등록 시까지의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액의 보상금을 청구할 수 있다(§ 65②). 특허권과 독립된 채권적 권리이고(§ 65④), 출원의 포기·무효·취하나 거절결정·취소결정·무효심결(후발적 무효사유 제외) 확정 시 처음부터 발생하지 아니하는 해제조건부 권리이다(§ 65⑥).

(2) 요건 1) — 출원공개될 것

乙의 후출원은 국내우선권주장을 수반하므로 제64조에 따라 선출원일(2021.5.1.)부터 1년 6개월이 경과한 2022.11.1.경 **출원공개**되었다.

(3) 요건 2) — 경고하였거나 출원공개된 발명임을 알고 있을 것

戊가 출원공개된 발명임을 알았다는 사정이 사실관계상 나타나지 않으므로, 乙의 **서면경고**가 필요하다.

(4) 요건 3) — 정당한 권원 없는 자가 출원발명을 업으로서 실시할 것

① 戊는 청구항 1의 A 발명을 실시하고 있고, '지역사회 발전을 위한 비영리' 실시라 하더라도 계속적·반복적 실시는 '**업으로서**'의 실시에 해당한다. ② 정당한 권원과 관련하여 설정등록 전이므로 **선사용권자(§103)가 될 기대의 위치에 있는 자**인가 문제되는데, 제55조 제3항이 제103조를 열거하여 기준시점이 **우선일(2021.5.1.)**로 소급되므로, 실시개시일(2022.2.1.)이 그 이후인 戊는 **그 지위에 있지 아니하고** 달리 정당한 권원도 없다.

(5) 결론

乙이 서면경고를 하면 경고 도달 후의 실시분에 대하여 보상금청구권이 성립한다.

3. 권리행사에 필요한 절차

(1) 보상금청구권의 행사 — 서면경고와 조기권리화

보상금청구권은 설정등록 후에만 행사할 수 있으므로(§ 65③), 乙은 **서면경고**로 청구권을 성립시키고 **심사청구**(§ 59)와 **우선심사신청**(§ 61(1))으로 **조기권리화**를 도모한 후 **설정등록일부터 3년 이내에** 행사하여야 한다(§ 65⑤, 민 § 766 준용).

(2) 특허권의 행사

보상금청구권은 **등록 전 실시분**을, 특허권은 **등록 후 실시분**을 대상으로 하는 **독립된 권리**이다(§ 65④). 戊가 실시하는 것은 청구항 1의 A 발명이므로 乙은 **청구범위에 A 발명을 유지한 채** 등록받아야 하고, 등록 후 침해금지청구(§ 126)·손해배상청구(§ 128)와 침해죄 고소(§ 225)를 할 수 있다.

4. 결론

乙은 **서면경고 후 조기 등록**을 받아 **경고 시부터 등록 전까지의 실시분에 대한 보상금**을 청구할 수 있고, 등록 후의 실시에 대하여는 청구범위에 A 발명을 유지하여 등록받은 특허권으로 민·형사적 조치를 취할 수 있다.

Ⅳ. 설문(4)-1) — 보상금 지급 청구를 할 수 있는 기한 (3점)

1. 소멸시효 — 제65조 제5항·민법 제766조 준용

보상금청구권은 설정등록일부터 행사할 수 있으므로 **설정등록일이 단기소멸시효의 기산점**이 되고, 민법 제766조 준용에 따라 **3년**의 단기소멸시효에 걸린다(§ 65⑤).

2. 결론

乙의 특허출원은 2023.10.1.에 설정등록되었으므로, 청구 기한은 설정등록일로부터 3년이 되는 2026. 10. 1.까지이다.

Ⅴ. 설문(4)-2) — 예상 청구금액 (4점)

1. 청구가능 금액(§65②)

보상금은 위 기간의 실시에 대하여 **합리적으로 받을 수 있는 금액**이다(§ 65②). 2019년 개정으로 '통상'이 '합리적으로'로 변경되었으나, 이는 실시료 상당액이 사실상 상한으로 기능하여 무단실시자가 정당한 실시권자보다 유리해지는 문제를 개선하여 **실시료를 상회하는 금액을 산정할 수 있도록** 한 취지이다.

2. 합리적 실시료의 산정 방법

제3자와의 기존 실시료를 그대로 **유추 적용할 수는 없고**, 이를 산정의 기초자료로 삼되 허락 없는 실시라는 사정 등을 고려하여 **그보다 높은 금액**으로 산정하여야 한다.

3. 사안 포섭

(1) **실시 기간**: 경고 송달일(2023.2.1.)부터 설정등록일(2023.10.1.) 전일까지 = **8개월** (2) **실시료 기준**: 戊가 실시하는 발명은 청구항 1 A이며, 丙이 A 실시시에 대해 월 2,000,000원의 로열티를 지급하고 있으므로 이를 산정의 기초자료로 삼는다. 반면 丁의 3,000,000원은 A+B(청구항 2)에 대한 것으로 발명의 기여도가 달라 기초로 삼기에 부적절하다. (3) **계산**: 기초금액은 2,000,000원/월 × 8개월 = 16,000,000원이고, '합리적으로 받을 수 있는 금액'은 이를 **상회하는 금액**으로 산정된다

4. 결론

乙은 戊에게 丙의 실시료를 기초로 산정한 **1,600만원을 상회하는** 합리적 실시료 상당의 보상금을 청구할 수 있다.

VI. 설문(4)-3) — A 발명 특허권 존속기간만료일 (3점)

1. 원칙(§88①)

특허권의 존속기간은 설정등록한 날부터 **특허출원일 후 20년이 되는 날까지**이다.

2. 국내우선권주장의 취급

제55조 제3항은 신규성·진보성·제103조 선사용권 등 열거된 규정 적용시에만 선출원 시로 소급될 뿐, 제88조 존속기간 규정은 열거대상이 아니므로 **존속기간 기산일은 실제 후출원일 기준**이며 우선일로 소급되지 않는다.

3. 결론

乙의 후출원일은 2022.4.1.이므로, A 발명(청구항 1) 특허권의 존속기간만료일은 2042. 4. 1.이다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
설문(1) 보정요구서의 내용·취지 (§46 절차보정+§6 특별수권)	5점	국내우선권주장·복대리인 선임에 대한 특별수권 흠결 지적, 제6조 특별수권의 취지(본인 보호) 서술, 관련문제(우선권주장서류·우선권 승계·승계증명서류 불요) 정리
설문(2) 국내우선권주장 취지(장점)+개발발명 예시	7점	취지 3가지(기본·개발발명의 일체 보호에 의한 출원인 이익 극대화, 내·외국인 형평, PCT 활성화[8(2)(b) 국내법 위임→자기지정])+판례 취지(2017후1274) 보충, 개발발명의 예=이용형태 3유형(실시에 보충형·상위개념 추출형·출원의 단일성 이용형)
설문(3) 보상금청구권 성립요건·행사절차	8점	등록 전 실시=보상금청구권/등록 후 실시=특허권 행사 구분, 성립요건 3(출원공개 2022.11.1.·경고 또는 약의·정당한 권원 없는 업으로서의 실시 — 등록 전이므로 '선사용권자가 될 기대의 위치' (§103)가 정당한 권원, §55③ 소급으로 부정), 행사절차=서면경고+조기권리화(심사청구·우선심사신청) 중심, 청구범위 A 유지 노력·등록 후 민·형사적 조치, 양 권리의 기간 구분(보상금=경고/약의 시~등록 전, 등록일부터 3년 내 행사·특허권=등록 후)과 독립성 (§65④)
설문(4)-1) 청구가능 기한 (민§766 준용)	3점	§65⑤·민§766 준용, 설정등록일 기산 3년(단기시효), 2026.10.1.
설문(4)-2) 예상 금액	4점	제65조 제2항 '합리적으로 받을 수 있는 금액'(2019.1.8. 개정 — 실시로 상회 산정 가능), 경고송달일(2023.2.1.)~설정등록일(2023.10.1.) 8개월, 丙 로열티는 기초자료(丁은 기여도 차이로 부적절), 제3자 실시료를 그대로 유추할 수 없고 1,600만원을 상회하는 금액으로 산정
설문(4)-3) 존속기간만료일	3점	제88조 제1항 출원일(우선일X) 기준, 2042.4.1.
합계	30점	

축별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- **특점:** (1) '보정 요구서'가 제46조 방식심사상 절차보정명령임을 포착. 국내우선권주장 (§ 6(6))·복대리인 선임 (§ 6(8))이 특별수권사항임을 특정하고 특별수권 제도의 취지(본인 보호)를 서술. (2) 기본서상 취지 3가지(일체 보호에 의한 이익 극대화·내외국인 형평·PCT 활성화)+판례 취지 보충+이용형태 3유형 제시. (3) 등록 전 실시(보상금청구권)와 등록 후 실시(특허권 행사)를 구분하고, 戊의 '비영리 지역사회' 문언에 낱이지 않고 '業으로서' 실시 인정. 정당한 권원 논점에서 등록 전이므로 '선사용권자가 될 기대의 위치에 있는 자'인지가 문제됨을 짚고, **제55조 제3항이 제103조를 명시적으로 열거하고 있으므로 판단 기준시점인 '특허출원 시'는 우선일(2021.5.1.)로 소급**되어 戊의 실시개시일(2022.2.1.)로는 그 지위가 인정되지 않음을 논증. (4)-1) 단기시효 기산점을 설정등록일로 특정. (4)-2) '통상'→'합리적' 개정(2019.1.8.) 취지(실시로 상회 산정)를 반영하여 丙 로열티를 기초자료로만 삼고(丁은 기여도 차이로 배제) 이를 상회하는 금액으로 산정. (4)-3) 존속기간은 우선일이 아닌 출원일 기산.
- **감점:** 우선권주장서류 제출 필요로 오답, 우선권 승계 필요로 오답, 존속기간을 우선일(2021.5.1.)로 기산, 시효 기산을 공개일/경고일로 잘못 기산, 戊 실시가 '業' 아니라고 오판, 제65조에 존재하지 않는 특칙(선사용권 효력제한 조항 등)을 창설하여 원용, **제55조 제3항 열거조항에서 제103조를 누락하고 선사용권 기준시점을 후출원일(2022.4.1.)로 오판.**

2) 목차·구성(25%)

- **특점:** 설문별 로마숫자 목차와 설문별 '결론' 마무리. 설문(1)은 '보정명령 근거→특별수권과 취지→사안→관련문제→결론', 설문(3)은 '문제의 소재(등록 전/후 이원 구분)→성립요건 3→행사절차→결론' 구성. (4)-3)은 짧게, (3)·(4)-1)·2)는 사안 포섭 위주로 분량 배분. 표·번호로 요건 도해.
- **감점:** 배점 낮은 (4)-3)에 우선권 일반론 장황 서술, (1)에서 우선권 취지 재론(설문2 침범), 서론 남발.

3) 답안 작성·논증(35%)

- **특점:** 조문 (§ 46·§ 6·§ 55·§ 59·§ 61·§ 65·§ 88·§ 103·§ 126·§ 128·§ 225·민 § 766) 정확 인용, 판례(2017후1274 국내우선권 취지) 근거 제시, 사실관계 낱짜를 계산해 결론 도출(경고송달~등록=8개월, 등록일+3년=2026.10.1., 출원일+20년=2042.4.1.).
- **감점:** 판례·조문 없는 일반론, 계산 오류, 결론 애매("일 수 있다" 남발), 본문↔결론 모순, 폐지된 구법 법리(구 § 56 선출원 취하간주 등) 원용.

감점 주의

- 국내우선권주장에 **우선권주장서류·우선권 승계**가 필요하다고 서술(조약우선권과 혼동): 대감점
- 존속기간 기산일을 **우선일**로 계산(2041.5.1.): 대감점
- 보상금청구권 단기소멸시효 기산점을 **경고일·공개일**로 오기: 감점
- 戊의 '비영리·지역사회 발전' 문언에 낱여 '業으로서 실시' 부정: 대감점
- 특별수권사항 조문 (§ 6)을 제시하지 못하고 일반론만 서술: 감점
- 설문(1)에서 승계증명서류 제출을 주된 보정요구 사항으로 서술(필수 제출서류 아님): 감점
- 설문(4)-2)에서 **8개월** 산정 근거를 밝히지 않거나 로열티 금액 계산 오류: 감점
- 제46조 각 호 인용 오류 (§ 82 수수료를 § 28②로 오기, '산업통상자원부령 방식'으로 오기): 감점

- 선출원 취하간주(폐지된 구 § 56 법리)를 현행 법리로 원용: 감점
- 선사용권 항변 배제 근거로 존재하지 않는 제65조 특칙을 원용: 대감점
- 제55조 제3항 열거조항에 제103조가 포함됨을 놓치고 후출원일(2022.4.1.)을 제103조 '특허출원 시'로 파악: 감점

2024년 제2문

사례형

20점

문제

甲은 다음 특허 제10-0000000호의 특허권자이다.

[청구범위]

[청구항 1] A, B를 포함하는 기계장치.

[청구항 2] 제1항에 있어서, C를 더 포함하는 기계장치.

[청구항 3] 제2항에 있어서, D를 더 포함하는 기계장치.

甲은 乙에게 특허권 침해를 이유로 경고장을 발송하였고, 특별한 답변이 없자 乙을 상대로 특허심판원에 청구취지 및 확인대상발명을 다음과 같이 기재하여 권리범위확인심판을 청구하였다.

[청구취지]

1. 확인대상발명은 특허 제10-0000000호 제2항의 권리범위에 속한다.
2. 심판 비용은 피청구인이 부담한다.

[확인대상발명]

A', B, C를 포함하는 기계장치.

위 심판에서 乙은 구체적인 증거를 제시하지 않으면서, 甲이 특정한 확인대상발명 중 구성 C는 자신이 실시하는 발명 C'과는 사실적 관점에서 동일성이 없다고 주장하였고(다만 구성 C 및 C'은 균등관계라고 판단될 수는 있음), 특허심판원은 심리를 통하여 甲이 특정한 확인대상발명의 구성 중 A' 및 B는 乙이 실시하고 있다고 인정하였으나, 확인대상발명의 구성 중 C는 乙이 주장하는 C'과는 상이하다는 심증을 얻었으며, 이를 이유로 甲에게 확인대상발명에 대한 보정의 기회를 부여하였다. 그러나 甲은 특허심판원의 판단이 옳지 않다고 적극적으로 주장하면서 확인대상발명을 보정하지 않았다. 이후 특허심판원은 甲의 심판청구를 각하하는 심결을 하였다. 이에 甲은 특허법원에 심결취소소송을 제기하였다. (단, 다음 각 물음은 독립적이다)

(1) 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 기재 정도에 관하여, 다음 측면에서 각각 설명하시오. (5점)

1. 청구취지의 특정
2. 청구원인의 특정
3. 확인의 이익

(2) 이 사건 심결취소소송에서, 특허법원은 특허심판원의 판단이 위법하다는 원고 甲의 주장은 심리하지 않으면서, 독자적으로 확인대상발명 중 구성 A'의 정의가 모호하여 사회통념상 다른 물건과 구별될 수 있을 정도로 특정되지 않았다고 판단하였다. 이 경우 다음 물음에 대하여 설명하시오. (8점)

1. 다음과 같이 청구인용판결을 한 경우, 판결의 이유, 효과 및 문제점
 1. 특허심판원이 ... 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
 2. 소송 비용은 원고가 부담한다.
2. 다음과 같이 청구기각판결을 한 경우, 판결의 이유, 효과 및 문제점
 1. 원고의 청구를 기각한다.
 2. 소송 비용은 원고가 부담한다.

(3) 이 사건 심결취소소송에서, 특허법원의 심리 범위를 특허법 제186조 제6항을 고려하여 설명하고, 만약 재판부가 확인대상발명이 적법하게 특정되었다고 판단하는 경우 본안 심리를 할 수 있는지 여부에 대하여 설명하시오. (3점)

(4) 甲은 이 사건 권리범위확인심판에서 최종 패소하였고, 특허권 침해소송을 제기하려고 한다. 승소하기 위하여 활용해야 하는 특허법상 규정을 설명하시오. (4점)

문제 2 모범답안

I. 설문(1) — 확인대상발명의 기재 정도

1. 청구취지의 특정

확인대상발명은 청구취지의 일부를 구성하므로 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐 아니라, 그에 앞서 **사회통념상 다른 것과 구별될 수 있을 정도로 구체적으로 특정**되어야 한다(대법원 2010후3356·2022후10746). 심판의 대상을 명확히 하여 심결의 효력이 미치는 범위를 확정하기 위함이다.

2. 청구원인의 특정

확인대상발명의 설명서에는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없으나, **특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로** 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적 구성이 기재되어야 한다(대법원 99후2372·2011후1494).

3. 확인의 이익

적극적 권리범위확인심판은 피심판청구인이 현재 실시하는 발명을 대상으로 하므로 확인대상발명은 **실시 발명과 사실적 관점에서 동일**하여야 한다. 실시하지 아니한 발명에 관한 심결은 실제 실시 발명에 아무런 효력이 없으므로 확인의 이익이 없어 각하된다(대법원 2002후2419). 실시 사실의 증명책임은 심판청구인에게 있고 확인의 이익은 직권조사사항이다(특허법원 2006허8705). 사실적 동일성은 균등관계와 구별되므로 균등관계에 있더라도 사실적 동일성이 없으면 확인의 이익이 없다.

4. 결론

확인대상발명은 청구취지 측면에서 사회통념상 다른 물건과 구별될 정도로 특정되어야 하고, 청구원인 측면에서는 차이점 판단에 필요한 정도로 대응 구성이 기재되면 충분하다. 다만 실시 발명과 **사실적 관점에서 동일**하여야 하며, 이를 결하면 확인의 이익이 부정되어 각하된다.

II. 설문(2) — 특허법원의 판결

1. 사안의 전제

특허법원은 확인대상발명 중 A'이 사회통념상 다른 물건과 구별될 정도로 특정되지 아니하였다고 판단하였다. 이는 청구취지 자체의 특정 흠결이어서 심판청구는 부적법하므로, 원심결은 이유(확인의 이익 부정)는 부당하나 **결론(각하)은 정당**하다. 한편 확인대상발명의 특정 여부와 확인의 이익은 **적법요건으로서 직권조사사항**이므로, 법원은 직권탐지의무까지는 없더라도 이미 제출된 자료에 의심할 만한 사정이 보이면 당사자가 다투지 아니하여도 심리·조사할 의무가 있다(대법원 2024후10436). 따라서 특허법원이 **독자적으로 A'의 특정 여부를 판단한 것 자체는 허용**된다(대법원 2021후10725).

2. 청구인용판결의 경우

(1) 판결의 이유

특허심판원은 확인대상발명의 적법특정 여부를 먼저 판단하고 그 특정을 전제로 확인의 이익을 판단하였어야 함에도, 특정 흠결을 간과하고 확인의 이익 부정을 이유로 각하하였으므로 심결이유가 위법하다는 취지이다.

(2) 효과

판결확정 시 각하심결이 취소되고, 취소의 기본이 된 이유는 특허심판원을 기속한다(§ 189③). 특허심판원은 확인대상발명의 특정을 다시 판단하여 심결하여야 한다(§ 189②).

(3) 문제점

① (**소송비용 부담의 모순**) 원고가 승소하면 소송비용은 패소자인 피고가 부담하여야 하는데(행정소송법 § 8② 준용, 민소 § 98) 판결문은 원고 부담으로 하고 있어 주문에 모순이 있다. ② (**본질적 부당성**) 특정 흠결은 어차피 각하사유여서 각하심결의 결론이 정당함에도 이를 취소하는 것은 소송경제에 반하므로, 청구기각이 타당하다.

3. 청구기각판결의 경우

(1) 판결의 이유

확인대상발명이 청구취지로서 특정되지 아니하여 심판청구가 부적법하므로, 이를 각하한 원심결은 이유는 달라도 **결론에 있어서 정당**하다는 취지이다.

(2) 효과

판결이 확정되면 각하심결이 그대로 확정되나, 각하심결이므로 **일사부재리의 효력은 발생하지 아니한다**(§ 163단서). 따라서 甲은 확인대상발명을 적법하게 특정하여 다시 청구할 수 있다.

(3) 문제점

① (**판단누락의 소지**) 특정 여부는 직권조사사항이어서 법원이 스스로 심리·판단할 수 있으므로 이를 곧바로 위법이라 할 수는 없으나(대법원 2024후10436·2021후10725), 원고가 내세운 주장에 아무런 판단을 하지 아니한 점에서는 판단누락의 위법 소지가 남는다(민소 § 451①(9)). ② (**절차적 방어권 침해**) A'의 특정 흠결은 심판단계에서 지적되지 아니하여 甲에게 보정 기회가 없었는데, 소송단계에서 새로 지적된 흠결로 보정 기회 없이 기각되므로 절차적 방어권이 박탈된다.

4. 결론

원심결의 각하 결론 자체는 정당하므로 이유를 달리하여 청구를 인용하기보다 **청구기각판결**을 하는 것이 소송경제와 결론의 정당성에 부합한다. 다만 인용판결에는 소송비용 부담의 모순이, 기각판결에는 원고 주장에 대한 판단누락과 보정기회 미부여에 따른 절차적 방어권 침해의 문제가 남는다.

Ⅲ. 설문(3) — 심리범위 및 본안심리 가부

1. 심결전치주의(§186⑥)

특허법원의 심결취소소송은 심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없다(심판전치).

2. 심리범위 — 무제한설

판례는 무제한설을 취하여, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 위법사유도 주장·입증할 수 있고 특허법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 심리·판단할 수 있다(2018후11360).

3. 본안심리 가부

다만 소송물은 **당해 심결의 위법성**이므로 원심결이 각하심결인 경우 심리범위는 **각하사유의 존부**에 국한된다(특허법원 2006허1513). 확인대상발명이 적법하게 특정되었다고 판단되면 각하심결을 취소하고 사건을 특허심판원에 환송하여야 하며(§ 189②), 곧바로 **권리범위 속부라는 본안**에 나아갈 수 없다. 이는 심결전치주의(§ 186⑥)와 특허심판원의 전문적 판단권한 보장에 부합한다.

4. 결론

심리범위는 무제한설에 의하나 원심결이 각하심결인 이 사건에서는 각하사유의 존부에 국한되므로, 특정이 적법하다고 판단되면 특허법원은 **각하심결을 취소·환송하여야 할 뿐** 본안에 나아갈 수 없다.

Ⅳ. 설문(4) — 침해소송에서 활용할 특허법상 규정

1. 사안의 전제 — 적극적 권리범위확인심판에서의 입증 곤란

적극적 권리범위확인심판의 심판절차에는 아래 **증명 보조 규정이 적용되지 아니하여 실시 증명이 곤란**하다는 비판이 있다. 甲은 침해소송에서 이들 규정을 활용할 수 있다.

2. 구체적 행위태양 제시의무(§126의2)

특허권자가 침해행위의 구체적 태양을 주장하면 상대방은 자신의 행위태양을 구체적으로 제시하여야 하고, 정당한 이유 없이 불응하면 법원은 특허권자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. 甲은 심판에서 증거 없이 상이하다고만 주장한 乙에게 실시태양(특히 C' 구성)의 제시를 요구할 수 있다.

3. 자료제출명령(§132)

법원은 신청에 의하여 침해 증명 또는 손해액 산정에 필요한 자료 제출을 명할 수 있고, 영업비밀이라도 반드시 필요한 때에는 거부의 정당한 이유가 되지 아니하며, 정당한 이유 없이 불응하면 자료의 기재에 관한 상대방 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. 甲은 이로써 실시태양과 손해액 증명을 보완할 수 있다.

4. 그 밖의 보조규정

과실 추정(§ 130)·손해액 산정 특칙(§ 128)을 병용할 수 있다. 다만 **생산방법의 추정(§129)은 '물건을 생산하는 방법의 발명' 특허에 적용되므로, 물건 발명(기계장치)인 이 사건 특허에는 적용되지 않는다.**

5. 결론

甲은 구체적 행위태양 제시의무와 자료제출명령으로 증거편재의 불리함을 극복하고, 과실 추정·손해액 산정 특칙을 병용하여 승소 가능성을 높일 수 있다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특정 포인트
설문(1) 확인대상발명의 특정 3측면	5점	①청구취지 특정(사회통념상 구별 — 2010후3356·2022후10746) ②청구원인 특정(대비가능성 — 99후2372·2011후1494) ③확인의 이익(적극적 심판=실시 발명 대상 → 사실적 동일성 — 2002후2419, 입증책임·직권조사 — 2006허8705)
설문(2)-1) 청구인용판결의 이유·효과·문제점	4점	확인대상발명 특정 흠결 간과·선순위성 위반, 기속력(\$189③), 소송비용 원고부담 모순
설문(2)-2) 청구기각판결의 이유·효과·문제점	4점	심결결론 정당→기각, 각하심결 확정 및 일사부재리 배제(\$163단서), 판단누락 소지(직권조사 전제)·보정기회 박탈 문제
설문(3) 심리범위·본안심리 가부	3점	제186조 제6항 심결전치주의, 무제한설 판례(2018후11360), 각하심결 취소소송의 심리범위는 각하사유에 국한→본안심리 불가(2006허1513)
설문(4) 침해소송 승소를 위한 활용규정	4점	심판절차 입증 곤란 비판(\$126의2·\$132 부적용) 전제, 제126조의2 구체적 행위태양 제시의무, 제132조 자료제출명령(+ \$130 과실추정·\$128 손해액 특칙 — \$129 생산방법 추정은 물건발명이라 부적용)

특별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- 설문(1): 3측면을 각각 구분해 판례법리로 정리했는가. '확인의 이익'에서 적극적 권리범위확인심판은 피심판청구인이 실시하고 있는 발명을 대상으로 하는 것이므로 확인대상발명이 실시발명과 사실적 관점에서 동일하여야 함(2002후2419)을 적시했는가.
- 설문(2): 각하심결의 결론이 정당한 사안임을 파악하고, 청구인용·청구기각 각각의 논리 모순·문제점을 짚었는가. 특히 (2)-1)에서 소송비용을 원고 부담으로 기재한 판결문 자체의 모순, (2)-2)에서 원고 주장 미심리로 인한 판단누락·보정기회 박탈을 지적했는가. 확인대상발명의 특정 여부·확인의 이익은 직권조사사항이어서 법원의 독자 판단 자체는 허용됨(2024후10436·2021후10725)을 전제로 논지를 전개했는가.
- 설문(3): 심결전치주의(\$ 186⑥)와 무제한설의 관계, 각하심결 취소소송에서 본안심리 불가 법리(2006허1513)를 포착했는가.
- 설문(4): 심판절차의 입증 곤란 비판을 전제로, 乙의 불성실한 부인태도에서 제126조의2를 곧바로 도출했는가.
- 감점: 판례 사안(2021후10725)의 결론만 나열하고 설문의 구체적 사실관계에 포섭하지 않은 경우.
- 감점: 설문(4)에서 생산방법의 추정(\$ 129)을 물건발명인 이 사건 특허의 활용 규정으로 나열한 경우.

2) 목차·구성(25%)

- 설문별로 배점에 비례한 분량 배분(설문2 8점>설문1 5점>설문4 4점>설문3 3점).
- 소설문 1)·2)를 대칭적으로 "이유·효과·문제점" 3단으로 구성.
- 판례·조문·사안포섭이 구분되어 배치.
- 감점: 확인대상발명 특정법리를 서론에 장황히 나열, 설문(2)에서 이유·효과·문제점 구분 없이 뭉뚱그린 서술.

3) 답안 작성·논증(35%)

- 조문(\$ 186⑥, \$ 189②·③, \$ 163단서, \$ 126의2, \$ 132, \$ 130·\$ 128) 정확히 인용.
- 판례법리(2002후2419·2010후3356·99후2372 등)를 인용하되 사안에 포섭.
- (2)에서 각하심결이 결론상 정당하므로 원래는 청구기각이 타당하다는 전제 하에, 청구인용판결의 논리적 무리 및 소송비용 원고부담의 모순을 명확히 지적.
- (3)에서 무제한설 원칙에도 불구하고 심판대상(심결의 위법성)이 각하사유에 국한되므로 본안(권리범위 속부)까지 나아갈 수 없다는 결론.
- 감점: 판례 법리만 옮겨쓰고 결론이 애매한 경우, (2)-1) 청구인용의 문제점을 소송비용 하나로만 처리하고 본질적 모순(각하가 정당)을 놓친 경우.

감점 주의

- 확인대상발명 특정의 3측면을 하나로 뭉쳐 서술하는 경우.
- 설문(2)에서 "청구인용판결이 타당하다"고 결론지어 사안의 전제(각하심결이 결론상 정당)를 놓치는 경우.
- 각하심결 취소소송에서 특허법원이 곧바로 권리범위 속부(본안)를 판단할 수 있다고 서술하는 경우.
- 설문(4)에서 제126조의2를 누락하고 일반 침해론(\$ 127, \$ 128)만 나열하는 경우.
- 자료제출명령의 조문번호를 존재하지 않는 제132조의2로 잘못 인용하는 경우(정확히 \$ 132).
- 조문번호를 구법(\$ 164 등)으로 인용하거나, 제189조 제3항 기속력 조문을 누락하는 경우.

2024년 제3문

사례형

30점

문제

I. 특허권자인 甲의 특허발명(X)는 ‘열 저장 틱을 구비한 디스펜서’에 관한 것이고 乙의 비교대상발명(Y)는 ‘튜브형 화장품 용기의 노즐팁’에 관한 것이다.

II. 乙은 甲을 상대로 X는 기재불비사유가 있고 진보성이 부정되어 무효가 되어야 한다고 주장하며 무효심판청구를 제기하였다. 위 심판절차가 진행되던 중 甲은 X의 발명의 설명 부분을 정정하는 정정청구를 다음과 같이 하였다.

“X의 청구범위에는 열 저장 틱의 재질로서 금속 또는 세라믹이 기재되어 있는데, 발명의 설명에는 열 저장 틱의 재질로서 금속 또는 세라믹 뿐만 아니라, 고밀도 플라스틱, 복합물 등도 포함되는 것으로 기재되어 있다. 정정청구는 열 저장 틱의 재질로서 청구범위에 기재되어 있지 아니한 고밀도 플라스틱, 복합물 등을 발명의 설명에서 삭제하는 것을 내용으로 한다.”

III.

1. X 중 ‘하우징에 결합되고, 금속 또는 세라믹을 포함하고, 제품을 표면에 인가(印加, 전원을 공급·연결하는 일)하기 위한 인가면을 구비하는 열 저장 틱’은 Y의 ‘튜브용기에 결합되고, 제품을 표면에 인가하기 위한 경사면을 구비하는 실리콘팁’에 대응하는데, 이들 구성은 열 저장 틱과 실리콘팁이 모두 하우징이나 튜브용기에 결합되고, 제품을 표면에 인가하기 위한 인가면을 구비하고 있다는 점에서는 동일하다. 그러나 X의 열 저장 틱은 금속 또는 세라믹을 포함하는 것임에 비하여, Y의 실리콘팁은 실리콘을 재질로 하는 것이라는 점에서 차이가 있다.
2. X는 피부에 온기 또는 냉기를 인가하여 통증이나 불편한 느낌을 완화할 수 있는 디스펜서를 제공하고자 하는 기술적 과제를 해결하기 위하여 열을 저장 및 전달할 수 있는 특성을 가진 금속 또는 세라믹 재질의 열 저장 틱을 그 해결수단으로 채택한 것이다. Y에는 이러한 기술적 과제 및 그 해결원리에 관한 기재나 암시가 없다.
3. Y는 입술에 립글로스를 바를 때 손가락으로 바르는 듯한 부드러운 느낌을 느낄 수 있도록 하는 것을 기술적 과제의 하나로 삼고 있는데, Y에서 실리콘팁의 재질을 피부에 이질감을 제공하는 금속 또는 세라믹으로 변경하는 시도는 Y의 기술적 과제에 반하는 것이거나 Y 본래의 기술적 의미를 잃게 하는 것이 되어 쉽게 생각해내기 어렵다.
4. X는 금속 또는 세라믹 재질의 열 저장 틱에 관한 구성이 나머지 구성들과 유기적으로 결합함으로써 피부에 온기 또는 냉기를 인가하여 통증이나 불편한 느낌을 완화할 수 있게 되는 특유한 효과를 가지게 되는데, 이러한 효과는 Y로부터 예측하기 어렵다.

(1) ‘특허무효심판절차’에서 특허정정을 할 수 있게 하는 취지 및 허용범위에 관하여 설명하시오. (9점)

(2) 특허 오류 정정 범위에 포함되는 사항에 대해서 설명하시오. (5점)

(3) 청구범위와 발명의 설명과의 관계를 설명하고 위의 II에 대해서 판단하시오. (8점)

(4) 본 사례와 관련된 진보성 유무 판단 방법에 관하여 설명하고 위의 III에 대해서 판단하시오. (8점)

모범답안

모범답안 — 문제 3

I. 설문 (1) — 무효심판절차 내 정정청구의 취지 및 허용범위 (9점)

1. 의의 (§133의2)

특허무효심판의 피청구인(특허권자)은 답변서 제출기간(§ 147①), 직권심리에 따른 의견서 제출기간(§ 159① 후단) 등 제133조의2 제1항 각호의 기간 내에 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다.

2. 취지

그 취지는 ① 청구인의 무효주장에 대한 **특허권자의 방어권을 보장함**으로써 별도의 정정심판을 청구할 부담을 덜어주고, ② 무효심판절차 내에서 정정을 함께 처리하여 **심판경제**를 도모하며, ③ 무효심판과 정정심판을 별도로 진행할 경우 발생할 수 있는 **심결의 모순저촉을 방지**하려는 데 있다.

3. 허용범위

(1) 정정사유의 한정(§133의2①이 §136① 각호를 원용)

정정은 1) 청구범위의 감축, 2) 잘못 기재된 사항의 정정, 3) 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 한하여 허용된다. 특히 3)에는 기재 자체가 불명료한 것을 명확히 하는 경우뿐만 아니라, 발명의 설명과 청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 것을 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 경우도 포함된다.

(2) 신규사항 추가 금지(§133의2④에 의한 §136③ 준용)

정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 다만 잘못 기재된 사항의 정정은 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다.

(3) 청구범위의 실질적 확장·변경 금지(§133의2④에 의한 §136④ 준용)

청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다. 이는 정정 후의 청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하며, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 줄 염려가 없어야 한다.

(4) 정정 후 청구범위의 특허요건(§133의2④에 의한 §136⑤ 준용)

청구범위의 감축 또는 잘못 기재된 사항의 정정의 경우, 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다. 다만 무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 이를 준용하지 아니하는데(§ 133의2⑥), 그 청구항의 특허요건은 무효심판에서 판단되어 중복되기 때문이다.

4. 결론

무효심판절차 내 정정청구는 특허권자의 방어권 보장과 심판경제·모순저축 방지를 위하여 인정되는 제도로서, 제133조의2 제1항 각호의 기간 내에만 청구할 수 있다. 그 허용범위는 청구범위의 감축·잘못 기재된 사항의 정정·분명하지 아니하게 기재된 사항의 명확화(발명의 설명과 청구범위의 불일치·모순을 통일하는 경우 포함)라는 정정사유에 해당하여야 하고, 신규사항 추가와 청구범위의 실질적 확장·변경이 금지되며, 청구범위의 감축·잘못 기재된 사항의 정정의 경우 원칙적으로 정정 후의 청구범위가 특허출원 시 특허를 받을 수 있는 것이어야 하는 한도로 제한된다. 다만 무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조 제5항이 준용되지 아니한다.

II. 설문 (2) — 오류 정정 범위에 포함되는 사항 (5점)

1. 근거 (§136①(2)·(3))

'오류의 정정'은 법문상의 용어가 아니라, 정정사유 중 제136조 제1항 제2호(잘못 기재된 사항의 정정)와 제3호(분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우)를 아우르는 판례상의 개념이다.

2. 잘못 기재된 사항의 정정 (§136①(2))

특허발명의 명세서 또는 도면 중 오기(誤記)를 명확한 내용의 자구(字句)나 어구(語句)로 고치는 것을 말한다(2004후2451). 정정 전후의 기재내용이 동일한 의미를 표시하는 것이라고 객관적으로 인정될 수 있어야 하며, 그 정정은 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다(§ 136③ 단서).

3. 분명하지 아니하게 기재된 사항의 명확화 (§136①(3))

이에 해당하는 경우로는 i) 문리(文理)상 의미가 명확하지 아니한 기재를 바로잡는 경우, ii) 그 자체의 기재내용이 다른 부분의 기재와 관련하여 불합리한 관계를 바로잡는 경우, iii) 발명의 신규성·진보성을 명확히 하기에 불충분한 기재를 특허결정 시의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 명확히 하는 경우, iv) 청구범위의 기재 내용 자체의 의미는 명백하더라도 발명의 카테고리가 분명하지 아니하여 발명의 내용을 명백히 확정할 수 없는 경우, v) 발명의 설명과 청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없게 하는 경우(2014후2184)가 있다.

4. 결론

오류 정정의 범위에는 잘못 기재된 사항의 정정(제2호)과 분명하지 아니하게 기재된 사항의 명확화(제3호 — 발명의 설명과 청구범위 간 불일치·모순의 통일 포함)가 포함된다. 어느 경우에도 신규사항 추가는 허용되지 아니하고(§ 136③), 청구범위의 실질적 확장·변경은 금지된다(§ 136④).

III. 설문 (3) — 청구범위와 발명의 설명의 관계 및 사안 II 판단 (8점)

1. 적용 법규정

(1) 발명의 설명(§42③): 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세히 적어야 한다. (2) 청구범위(§42④): 보호받으려는 사항을 적은 청구항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고(1호), 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있어야 한다(2호). (3) 보호범위(§97): 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다.

2. 양자의 관계 — 청구항의 기재원칙(§42④(1) 뒷받침 요건)

(1) 기능적 관계

발명의 설명은 청구범위의 **해설서** 역할을 수행하므로 발명의 설명과 청구항의 기재가 상호 모순되어서는 안 되고, 또한 발명의 설명은 **기술 공개서** 역할을 하므로 공개하지 아니한 사항을 청구항에 적으면 공개하지 아니한 발명에 특허권이 부여되는 결과가 된다. 이에 청구항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다(§ 42④(1)).

(2) 뒷받침 여부의 판단

특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 통상의 기술자의 입장에서 **청구항에 적혀 있는 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 적혀 있는지에** 의하여 판단하고(2010후2582), 출원 시의 기술상식에 비추어 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 **확장 내지 일반화할 수 없는 경우**에는 뒷받침되지 않는다(2004후1120).

(3) 포함관계(2014후2184)

청구범위는 발명의 설명에 기재된 기술적 사상의 **전부 또는 일부를** 특허발명의 보호범위로 특정한 것이고, 발명의 설명에 기재된 모든 기술적 사상이 반드시 청구범위에 포함되어야 하는 것은 아니다. 따라서 **특별한 사정이 없는 한 청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항이 발명의 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 설명과 청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기는 어렵다.** 다만 청구항에는 기재되지 아니하고 발명의 설명에만 기재된 발명은 원칙적으로 보호받지 못하며, 이 경우 출원인은 보정(§ 47)·분할출원(§ 52)·국내우선권주장출원(§ 55)·별도의 신규출원 등을 통하여 보호받을 수 있다.

3. 사안 II의 포섭

(1) X의 청구범위에는 열 저장 팁의 재질로서 '금속 또는 세라믹'만 기재되어 있고, 발명의 설명에는 이에 더하여 '고밀도 플라스틱, 복합물' 등도 열 저장 팁 재질로 기재되어 있다. (2) 그러나 위 판례에 따르면, 청구범위는 발명의 설명에 기재된 기술적 사상의 일부분만을 보호범위로 특정할 수 있으므로, 청구범위에 기재되지 아니한 사항(고밀도 플라스틱·복합물)이 발명의 설명에 포함되어 있다는 사정만으로 청구범위와 발명의 설명이 서로 일치하지 아니하거나 모순이 있다고 볼 수 없다. (3) 따라서 甲의 정정청구(발명의 설명에서 '고밀도 플라스틱, 복합물' 등을 삭제)는 제136조 제1항 제2호의 '잘못 기재된 사항의 정정'이나 제3호의 '분명하지 아니한 기재의 명확화'에 해당하지 아니한다.

4. 결론

甲의 정정청구는 제136조 제1항 각호 어디에도 해당하지 않으므로 **부적법하여 인정될 수 없다.**

IV. 설문 (4) — 진보성 판단방법 및 사안 III 판단 (8점)

1. 판례에 의한 진보성 판단의 일반법리

판례는 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서, 1) **선행기술의 범위와 내용**, 2) **진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이**, 3) **통상의 기술자의 기술수준**을 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 그 차이를 극복하고 선행기술로부터 대상 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다고 한다(대법원 2014후2184, 2024후10641 등). 그 판단은 **구성의 곤란성**(선행기술로부터 구성의 변경·결합에 이르는 것이 통상의 기술자에게 어려운지)을 중심으로 하되, **효과의 현저성(목적의 특이성)**(선행기술로부터 예측하기 어려운 현저한 효과나 특이한 기술적 과제의 존재)을 함께 고려하여 이루어진다. 이때 대상 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 **사후적으로** 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다(사후적 고찰 금지).

2. 사안 III의 포섭

(1) 구성의 곤란성

① X의 열 저장 팁은 '금속 또는 세라믹'을 재질로 하고, Y의 실리콘팁은 '실리콘'을 재질로 한다는 점에서 차이가 있다. ② Y는 '손가락으로 바르는 듯한 부드러운 느낌'을 기술적 과제로 삼으므로, 실리콘팁의 재질을 피부에 이질감을 주는 금속·세라믹으로 변경하는 시도는 **Y의 기술적 과제에 반하거나 Y 본래의 기술적 의미를 잃게 하는 것**이 되어 통상의 기술자가 쉽게 생각해내기 어렵다. 나아가 Y에는 X의 기술적 과제(피부에 온기·냉기를 인가하여 통증·불편을 완화)와 그 해결원리에 관한 기재나 암시도 없다. 따라서 구성의 곤란성이 인정된다.

(2) 효과의 현저성(목적의 특이성)

① X는 금속·세라믹 재질의 열 저장 팁이 나머지 구성들과 유기적으로 결합함으로써 피부에 온기 또는 냉기를 인가하여 통증이나 불편한 느낌을 완화하는 **특유한 효과**를 가지는데, 이러한 효과는 Y로부터 **예측하기 어렵다.** 따라서 효과의 현저성도 인정된다.

3. 결론

X의 명세서에 개시된 기술을 알고 있음을 전제로 **사후적으로** 판단하지 아니하는 한, 구성의 곤란성과 효과의 현저성이 모두 인정되어 통상의 기술자가 Y로부터 X를 쉽게 발명할 수 없다. 따라서 **X의 진보성이 부정된다고 할 수 없다.**

채점기준

핵심 쟁점과 배점

설문	쟁점	배점	특점 포인트
(1)	무효심판 내 정정청구 취지	3	별도 정정심판 없이 방어권 보장, 심판경제·모순저축 방지
(1)	정정 허용범위(정정사유·신규사항추가금지·실질적 확장변경 금지·정정 후 특허요건)	6	제133조의2①이 제136조 제1항 각호를 원용, 제133조의2④에 의한 제136조 제3항·④·⑤ 준용, 무효심판 청구된 청구항의 정정 후 특허요건 배제(§133의2⑥)
(2)	오류정정 범위(§136③(2)·(3)) 판례 법리	5	2호=오기를 자구·어구로 고침(2004후2451, 전후 동일 의미의 객관적 인정), 3호=기본서 5유형(문리상 불명확·타 기재와 불합리 관계·신규성진보성 명확화 불충분·카테고리 불분명·발명의 설명↔ 청구범위 모순 통일)(대법원 2014후2184; 그 인용판례 2004후3096, 2011후3193)
(3)	청구범위와 발명의 설명의 관계(§42③·④, §97)	4	해설서·기술 공개서 기능, 뒷받침 요건(§42④(1))의 판단 (2010후2582·2004후1120), 발명의 설명에만 기재된 발명의 구체수단
(3)	사안 II 판단(2014후2184 법리 포섭)	4	청구범위 미기재 사항이 발명의 설명에만 있어도 모순 아님 → 정정 부적법
(4)	진보성 판단법리(§29②, 사후적 고찰 금지)	4	구성곤란성·목적특이성·효과현저성, 명세서 알고 있음 전제 사후판단 금지
(4)	사안 III 포섭(재질 차이·과제 상반·효과 예측 곤란)	4	기술적 과제·해결원리 상이, Y의 기술적 의의 상실, 특유한 효과, 진보성 부정 안 됨
합계		30	

측별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- (1) 취지는 '별도 정정심판 불요·특허권자 방어권 보장'을 명시했는가.
- (1) 허용범위에서 제133조의2①이 제136조 제1항 각호를 원용하는 구조(정정사유)와, 제133조의2④에 따른 제136조 제3항(신규사항추가금지), 제136조 제4항(실질적 확장변경 금지), 제136조 제5항(정정 후 특허요건)의 준용을 빠짐없이 적시하고, 무효심판 청구된 청구항에 대해서는 정정 후 특허요건 판단이 배제됨(§133의2⑥)을 지적했는가.
- (2) 대법원 2014후2184 판결 취지에 따른 오류정정 범위(오기 정정/불분명 기재 명확화/발명의 설명과 청구범위 모순 통일)를 적시했는가.
- (3) 발명의 설명의 해설서·기술 공개서 기능과 뒷받침 요건(§42④(1))을 중심으로 청구범위(§42④, §97)와 발명의 설명(§42③)의 관계를 서술하고, 2014후2184 판례(청구범위 미기재 사항이 발명의 설명에 있다고 모순 아님)를 사안에 정확히 포섭했는가.
- (4) 판례의 진보성 판단 일반법리와 사후적 고찰 금지를 실시하고, 구성의 곤란성(재질 차이·과제 상반)과 효과의 현저성(예측 곤란한 특유 효과)을 기준으로 포섭하여 진보성이 부정되지 않는다고 결론지었는가.
- 감점: 정정심판(§136)과 정정청구(§133의2)의 조문 혼용, 제136조 제1항을 제133조의2④의 '준용' 대상으로 오기(§133의2④)의 준용대상은 §136③~⑥, ⑧, ⑩~⑬임), 무효심판 청구항의 정정 후 특허요건 배제 누락, 사안 II를 '기재불비 해소' 정정으로 잘못 인정하는 결론.

2) 목차·구성(25%)

- 설문별 배점(9/5/8/8)에 비례하여 분량을 배분했는가.
- 각 설문을 '법리(조문·판례) → 사안 포섭 → 결론' 흐름으로 체계화했는가(설문(4)는 진보성 의의 없이 판례 일반법리 → 기준별 포섭 → 결론 구성).
- 설문(1)에서 취지와 허용범위를 소재목으로 분리했는가.
- 설문(3)·(4)에서 일반론과 사안 판단을 분리 배치했는가.
- 감점: 판례 전문 통째 옮기기, 사안 포섭 없이 일반론만 서술, 설문 순서·번호 혼동.

3) 답안 작성·논증(35%)

- 조문 인용의 정확성(§133의2, §136, §42③·④, §97, §29②).
- 대법원 2014후2184(오류정정 범위 및 청구범위·발명의 설명 모순 판단 법리)의 판시 취지를 정확히 옮기고 사안에 대응시켰으며, 뒷받침 요건 판례(2010후2582 — 대응 사항 존재 기준, 2004후1120 — 확장·일반화 불가 시 위반)를 인용했는가.
- 설문(3) 결론에서 甲의 정정은 제136조 제1항의 어느 사유에도 해당하지 않아 부적법하다는 결론이 명확한가.
- 설문(4) 결론에서 구성의 곤란성(재질 차이 + 과제 상반·기술적 의미 상실)과 효과의 현저성(예측 곤란한 특유 효과)을 근거로 사후적 고찰이 아닌 이상 진보성이 부정되지 않는다고 결론지었는가.

- 감점: 결론 애매, 논리 비약, 사안 사실관계(재질/과제/효과)의 단순 나열, 판례 법리와 사안 사이 포섭 연결 부재, 정정 관련 판례들의 판시 취지를 뒤바꿔 인용.

감점 주의

- 설문(1)에서 '취지'만 쓰고 '허용범위'를 빠뜨리거나, 반대로 정정요건만 나열하는 실수.
- 설문(1) 허용범위 서술에서 제136조 제1항을 제133조의2④의 준용 대상이라 오기하는 실수(§ 136①은 § 133의2①이 직접 원용하는 조문이며, § 133의2④의 준용대상은 § 136③ 이하임).
- 제133조의2⑥(무효심판 청구된 청구항의 정정 후 특허요건 판단 배제) 누락.
- 설문(2)에서 '오기의 정정'만 언급하고 '불분명 기재의 명확화·모순 통일'을 빠뜨리는 실수, 또는 대법원 2014후2184의 판시 취지를 다른 판례의 판시로 오기하는 실수.
- 설문(3)에서 발명의 설명에만 기재된 사항 삭제를 '기재불비 해소'로 오인하여 정정 인정하는 결론(2014후2184 판시에 반함).
- 설문(4)에서 판례 사실관계를 단순 복사만 하고 '사후적 고찰 금지' 법리 적용을 누락하는 실수.
- 판례 인용 시 구법 기준 판시(2014후2184는 2009. 1. 30. 개정 전 구 특허법 기준)와 현행 조문(§ 133의2·§ 136)의 대응을 애매하게 처리.

2024년 제4문

사례형

20점

문제

ㅁ은 乙을 상대로 ‘롤방충망의 록킹구조’에 관하여 다음 표와 같은 내용으로 소극적권리범위확인심판을 청구하였다.

구분	확인대상발명	특허발명	공지기술
공통점	구성요소1(프레임), 구성요소3(스프링), 구성요소4(걸림부)	구성요소1(프레임), 구성요소3(스프링), 구성요소4(걸림부)	
세부작동 및 구조 (구성요소2)	버튼부재가 고정판의 버튼삽입홈에 힌지(hinge)를 통해 회전 가능하게 장착	슬라이딩 가능하게 장착되어 전후 방향으로 이동	
명세서		- 종래의 권취(捲取, 실, 코일 따위를 두루마리 형태로 등글게 말거나 감는 일)식 방충망은 슬라이더의 양측을 고정부가 지지하고 있기 때문에 장시간 사용 시 방충망을 잡아당기는 권취 수단의 힘에 의해 슬라이더의 중심부가 상방향으로 휘어지게 변형되어 걸림돌기가 걸림턱에 잘 결합되지 않게 되는 문제점이 있다. - 슬라이더가 슬라이딩 도어의 슬라이딩 방향, 즉 상하 방향에 대한 수직 방향인 전후 방향으로 이동하여 후방향으로 절곡된 걸림부와 결합되어 방충망을 고정시킬 수 있게 됨으로써, 비교적 간단한 구조를 이용하여 슬라이딩되어 인출되는 방충망을 견고하게 고정시킬 수 있고, 또한 용이하게 분리시킬 수 있다. - 가이드 돌기가 형성된 슬라이더와 이를 둘러싸고 있는 가이드홈, 스프링 등의 작동방식 등을 구체적으로 기재하고 있다.	
개시사항			- 손잡이를 하강시키면 고정구의 고정축이 고정프레임에 형성된 걸림턱에 걸리면서 잠금되고, 고정구를 당기면 그 잠금을 해제하는 회전당김식 잠금장치를 구비한 권취식 방충망 - ‘록(lock) 바 하우징 내부에서 축을 중심으로 움직이며 판스프링으로 탄성적으로 지지되는 록 바가 결합되고, 록 바에 형성된 록 리브(lock rib)가 가이드 프레임의 양측에 설치된 걸림턱에 걸리면서 잠금되며, 사용자가 푸쉬 버튼을 눌러 잠금을 해제하는’ 회전누름식 방충망
과제해결 원리	버튼부재의 힌지(hinge, 경첩)축을 이용한 회전	회전축을 전후 방향으로 작동시키는 방식으로 걸림을 해제하여 간단한 구조의 롤방충망 잠금장치를 구현	

- (1) 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는 기준에 대하여 설명하시오. (9점)
- (2) 과제해결원리가 동일한지를 판단하는 방법에 관하여 설명하시오. (8점)
- (3) 위의 사안에 대하여 판단하시오. (3점)

문제 4 모범답안

I. 설문 (1) — 권리범위 숙부 판단기준 (9점)

1. 판단의 구조

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(제97조). 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지는 i) **특허발명의 특징**, ii) **확인대상발명의 특징**을 한 후, iii) 양자를 대비하여 **구성요소완비의 원칙**과 **균등론**을 적용함으로써 특허발명의 실시인지를 판단하고, iv) **법률에 의한 제한·확장**을 고려하는 순서로 이루어진다.

2. 특허발명의 특징

보호범위는 청구범위 기재 그대로 정해지는 것은 아니고, 1) **청구범위 기준의 원칙**을 바탕으로 2) **발명의 설명 창작의 원칙**(발명의 설명·도면을 창작하되 청구범위를 제한·확장 해석할 수는 없다), 3) **공지기술 창작의 원칙**(기술발전 기여도에 따라 보호범위의 광협을 정하며, 공지기술과 동일하면 보호범위 부정), 4) **출원경과 창작의 원칙**, 5) **특허권 하자 창작의 원칙**을 고려하여 해석된 청구범위를 기준으로 특정한다.

3. 확인대상발명의 특징

확인대상발명은 **사회통념상 다른 것과 구별될 수 있을 정도로**, 그리고 특허발명의 구성요소와 대비하여 **차이점 판단에 필요한 정도로** 대응 부분의 구체적 구성이 특정되어야 한다. 특허발명의 구성요소에 대응하지 아니하는 구성요소는 자유실시기술 항변의 경우를 제외하고 대비 판단에 영향을 미치지 아니한다.

4. 구성요소완비의 원칙과 균등론의 적용 (2016마5698)

(1) 구성요소완비의 원칙

청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이므로, 확인대상발명이 청구범위에 기재된 **각 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 포함**하고 있으면 권리범위에 속하고, 구성요소 중 일부가 결여된 경우에는 원칙적으로 권리범위에 속하지 아니한다.

(2) 균등론

청구범위에 기재된 구성 중 **변경된 부분이 있는 경우에도** 1) **과제해결원리가 동일**하고, 2) **실질적으로 동일한 작용효과**를 나타내며, 3) 그 변경이 통상의 기술자가 **쉽게 생각해 낼 수 있는 정도**이면, 4) **자유실시기술**에 해당하거나 출원경과에서 **의식적으로 제외되는 등 특별한 사정이 없는 한** 균등한 것으로서 권리범위에 속한다(2016마5698). 적극적 요건은 특허권자가, 특별한 사정은 실시자가 증명한다.

5. 법률에 의한 제한·확장의 고려

구성요소완비의 원칙·균등론에 의하여 특허발명의 실시로 판단되더라도, 1) **특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위**(§ 96 — 연구·시험을 위한 실시 등), 2) **재심에 의하여 회복된 특허권의 효력 제한**(§ 181), 3) **특허료 추가납부 등으로 회복한 특허권의 효력 제한**(§ 81의3④) 등 법률의 제한에 해당하면 보호범위에 속하지 아니한다. 반대로 구성요소 전부의 실시가 아니더라도 **간접침해**(§ 127)에 해당하는 예비적 행위는 침해로 보는 확장이 인정된다.

6. 결론

권리범위 숙부는 위 순서에 따라 판단한다. 사안의 확인대상발명은 특허발명의 구성요소 1(프레임)·3(스프링)·4(걸림부)를 그대로 포함하나, 구성요소 2에서 특허발명은 '슬라이더의 전후 슬라이딩'인 데 반하여 확인대상발명은 '버튼부재의 힌지축 중심 회전'이라는 점에서 상이하므로, 문언침해(구성요소완비)는 부정되고 균등침해 — 특허 제1요건인 과제해결원리의 동일성 — 를 검토하여야 한다.

II. 설문 (2) — 과제해결원리 동일성 판단방법

1. 과제해결원리를 고려하는 취지

대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결은 "특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제해결원리를 고려하여야 한다"고 판시하였다.

2. 과제해결원리의 실질적 파악 — 발명의 설명 창작

대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 및 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결은 "과제해결원리가 동일한지를 가릴 때에는 **청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라**, 명세서에 적힌 **발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 창작**하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 **기술사상의 핵심**이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다"고 판시한다.

3. 공지기술 창작의 범위와 한계

(1) 창작의 취지

공지기술 등까지 창작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위함이다.

(2) 폭의 결정

따라서 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 과제해결원리를 **얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지**를 결정한다. 기술발전 기여도가 큰 경우 넓게, 이미 유사 기술이 공지된 경우 좁게 파악한다.

(3) 한계 — 기술사상 핵심 대체 금지

다만 발명의 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다. 그렇지 않으면 발명의 설명을 신뢰한 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다(2016후2546).

4. 결론

결국 과제해결원리 동일성은 1) 청구범위 형식적 추출이 아닌 명세서·공지기술을 참작한 기술사상 핵심의 실질적 탐구, 2) 기술발전 기여도에 따른 폭 결정, 3) 다만 명세서에 기재되지 않은 공지기술로 기술사상 핵심을 대체하지 않는 한도 내에서 판단된다.

Ⅲ. 설문 (3) — 사안의 판단**1. 특허발명의 기술사상의 핵심**

발명의 설명은 종래 권취식 방충망의 슬라이더 휘어짐 문제를 지적하면서, 슬라이더가 **전후 방향으로 이동**하여 절곡된 걸림부와 결합함으로써 간단한 구조로 견고한 고정과 용이한 분리를 달성한다고 기재한다. 회전당김식·회전누름식 방충망이 공지된 점을 참작하면, 기술사상의 핵심은 **'슬라이더를 전후 방향으로 작동시켜 걸림을 해제하는 간단한 구조'**로 좁게 파악하여야 한다.

2. 확인대상발명의 과제해결원리

확인대상발명은 버튼부재가 힌지축을 중심으로 회전 가능하게 장착되는 구조로서 **'버튼부재의 힌지축을 이용한 회전 누름식 잠금장치'**를 구현한 것이며, 공지된 회전누름식 방충망의 연장선상에 있다.

3. 과제해결원리 동일성 및 결론

특허발명은 '전후 슬라이딩 방식'인 반면 확인대상발명은 '힌지축 회전누름 방식'이므로, 확인대상발명은 특허발명과 같은 과제해결원리를 채택하지 아니한다. 균등침해 제1요건이 결여되어 확인대상발명은 **특허발명의 권리범위에 속하지 아니하므로**, 甲이 청구한 소극적 권리범위확인심판에서는 인용심결이 내려질 것이다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
(1) 판단의 구조(특허발명의 특정 → 확인대상발명의 특정 → 구성요소완비·균등론 → 법률의 제한·확장)	4점	\$97, 특허발명 특정의 5원칙(청구범위 기준·발명의 설명·참작·공지기술·참작·출원경과·참작·하자·참작), 확인대상발명 특정(사회통념상 구별·대비 필요 정도), 구성요소완비의 원칙
(1) 균등론(2016마5698)·법률의 제한·확장	5점	균등 5요건(과제해결원리 동일·실질적 동일작용효과·치환용어·자유실시기술 아님·의식적 제외 아님)과 입증책임 배분(2016마5698), 법률의 제한(\$96-\$181-\$81의3④)·확장(간접침해 \$127) 고려
(2) 과제해결원리 파악방법 — 발명의 설명·공지기술 참작	4점	청구범위 형식적 추출 배제, 명세서·공지기술 참작한 '기술사상의 핵심' 실질탐구(2016후2546)
(2) 공지기술 참작의 취지·한계	4점	기술발전 기여도에 따라 과제해결원리의 폭 결정, 명세서 미기재 공지기술로 기술사상 핵심을 대체 금지(제3자 예측가능성)
(3) 사안 포섭 — 특허발명·확인대상발명의 과제해결원리 대비	2점	특허=슬라이더 전후이동식 / 확인대상=버튼부재 힌지축 회전누름식, 공지기술에 회전방식 이미 존재 → 특허의 과제해결원리를 회전식까지 넓힐 수 없음
(3) 결론 도출	1점	과제해결원리 상이 → 균등침해 부정 → 권리범위 불속(소극적 확인심판 인용)

합계: 20점

특별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- (+) 대상 판례가 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결(방충망 사건)임을 인식하고, 균등침해 5요건 중 '제1요건(과제해결원리 동일성)'과 '공지기술 참작 범위'가 핵심 쟁점임을 포착.
- (+) 소극적 권리범위확인심판임을 인식하고 결론을 '불속(인용심결)' 방향으로 이끌었는가.
- (+) 표의 '공지기술' 항목이 단순 참고자료가 아니라 과제해결원리의 폭을 좁히는 근거임을 파악.
- (-) 균등요건만 나열하고 공지기술 참작 범리를 누락하거나, 진보성 판단 기준과 혼동하여 서술.
- (-) 소극적/적극적 심판 구분 없이 '침해 성립' 방향으로 결론을 오도.

2) 목차·구성(25%)

- (+) 설문 배점(9:8:3)에 비례하여 (1)은 문언+균등 두 축, (2)는 파악방법+공지기술 참작 두 축, (3)은 사안포섭 중심으로 분량 배분.
- (+) 조문(\$ 97)→판례(2016후2546)→사안 포섭 순의 정형 구조.
- (+) (1)에서 균등요건을 번호로 구분해 가시화, (3)에서 특허·확인대상의 과제해결원리를 대비표 형태로 정리.
- (-) (1)에서 문언침해 서술이 빈약하거나 균등 5요건 중 소극요건(자유실시기술·의식적 제외)을 누락.
- (-) (2)를 판례문언 전사에 그치고 취지·한계로 목차화하지 못한 경우.

3) 답안 작성·논증(35%)

- (+) 균등의 취지(문언한계·특허권 실질보호)와 요건을 판시(2016마5698 등) 인용으로 명시.
- (+) 과제해결원리를 '기술사상의 핵심' 관점에서 실질적으로 탐구한다는 최근 판례(2012후1132, 2017후424) 흐름 반영.
- (+) 공지기술(회전당김식·회전누름식 방충망)이 이미 존재하므로 특허의 기술사상 핵심을 '회전식까지 포함'하는 상위개념으로 넓힐 수 없음을 논증 — 이 논리가 결론 도출의 핵심.
- (+) 특허의 과제해결원리=슬라이더 전후이동 vs 확인대상=힌지축 회전누름 → 상이 → 균등침해 부정 → 소극적 권리범위확인심판 인용심결 예상, 이라는 일관된 결론.
- (-) 사실관계 단순 나열 후 결론만 제시(포섭 논증 부재), 특허/확인대상의 명세서·공지기술 자료를 구체적으로 인용하지 못한 답안.
- (-) 결론이 '균등 성립'이나 '권리범위 속함'으로 나오는 본문↔결론 모순.

감점 주의

- 균등 5요건을 열거만 하고 이 사안에서 다투어지는 것은 '제1요건'임을 특정하지 못하는 경우.
- 공지기술 참작 범위에서 '기술사상 핵심 대체 금지'를 빠뜨려 제3자 예측가능성 논거를 놓치는 경우.
- 설문(3) 배점이 3점에 불과함에도 사실관계를 장황하게 복사하고 정작 '왜 상이한가'의 논증을 빠뜨리는 경우.
- 소극적 권리범위확인심판임을 놓치고 결론을 '침해 성립/기각' 등으로 잘못 서술.
- 진보성(\$ 29②) 판단법리와 균등침해 판단법리를 혼동하여 목적·구성·효과 3요소로 서술.

PART 16

2025

제1문	전용실시권과 독점적 통상실시권의 의의·비교 · 독점적 통상실시권자의 특허법상 손해배상청구권 행사 가부	30점
제2문	존속기간 연장등록출원제도 개관 (§89, §92의2 취지·요건) · '약효를 나타내는 활성부분' 판례 법리	20점
제3문	출원의 일부취하서의 법적 취급(보정 선행) · 보정기간 경과 후 서류의 처리(시행규칙 제11조)	30점
제4문	[설문(1)] 공동발명자 판단 (甲·乙·丙의 실질적 기여) · [설문(1)] A사 출원의 하자(무권리자·공동출원 위반)	20점

2025년 제1문

사례형

30점

문제

甲은 명칭을 ‘다가 페럼구균 다당류-단백질 접합체 조성물’로 하는 특허발명(이하 ‘이 사건 특허발명’이라 함)의 발명자이자 특허권자이다. 이 사건 특허발명은 13종의 개별 원액을 포함하는 조성물에 관한 물건의 발명 및 13종의 개별 원액을 혼합하여 조성물을 제조하는 공정에 관한 방법의 발명을 청구항으로 포함하고 있다. 조성물은 13종의 개별 원액을 혼합하여 제조되는 공정을 통해 생산된다. 甲은 乙에게 이 사건 특허발명의 독점적 통상실시권을 허락하였다. 위 지문을 토대로 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 甲은 丙에게 이 사건 특허발명의 실시를 위한 전용실시권을 설정하고 이를 등록하였다. 이와 관련하여, 丙의 전용실시권과 乙의 독점적 통상실시권을 비교 설명하시오. (10점)

(2) 丁은 무단으로 이 사건 특허발명을 실시하고 있다. 乙은 丁을 상대로 특허법상의 손해배상청구권을 행사할 수 있는지 논하시오. (10점)

(3) 戊는 무단으로 13종의 개별 원액을 국내에서 생산하여 이를 甲이 특허출원 및 등록을 하지 않은 A국에 수출하였고, 이를 수입한 A국적의 a는 A국에서 이를 혼합하여 이 사건 특허발명에 속하는 조성물을 생산하였다. 戊가 甲의 특허권을 직접침해하는지 여부에 대해 논하시오. (5점)

(4) 위 (3)의 지문에서 戊가 甲의 특허권을 간접침해하는지 여부에 대해 논하시오. (5점)

모범답안

문제 1 모범답안

I. 설문 (1) — 전용실시권과 독점적 통상실시권의 비교

1. 의의

(1) **전용실시권**(§ 100): 특허권자와의 설정계약에 의해 설정행위로 정한 범위 내에서 업으로서 특허발명을 독점·배타적으로 실시할 수 있는 준물권적 권리이다. (2) **독점적 통상실시권**: 특허권자가 실시권자 외의 제3자에게 통상실시권을 부여하지 아니할 부작위 의무를 부담하기로 하는 약정(명시적·묵시적 불문)이 있는 경우에 판례상 인정되는 채권적 권리이고(2018다221676), 이러한 법리는 실용신안권·디자인권·상표권 등에도 동일하게 적용된다(2023다280358).

2. 공통점

(1) 정당권원 있는 실시로서 특허권자로부터 침해책임을 지지 아니한다. (2) 특허권자에게 실시권과 중복되는 범위에서 제3자 실시허락 금지 의무가 부과된다.

3. 차이점

(1) 발생요건

① 전용실시권: 설정계약 및 **설정등록이 효력발생요건**이다(§ 101①(2)). ② 독점적 통상실시권: 당사자 **의사의 합치(명시·묵시 불문)** 만으로 발생하며, 등록은 대항요건에 불과하다(§ 118).

(2) 권리의 성질과 효력

① 전용실시권: **준물권적·배타적 권리**이다. 침해금지청구(§ 126), 손해배상청구(§ 128), 신용회복청구(§ 131) 등 특허법상 구제가 가능하며, 침해죄에 의한 형사처벌도 가능하다(§ 225①). 다만 침해죄는 2020.10.20. 개정으로 종전의 친고죄에서 **반의사불벌죄**로 전환되어, 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다(§ 225②). ② 독점적 통상실시권: **채권적 권리**이다. 직접적 침해금지·특허법상 손해배상청구는 불가하고, 특허권자의 침해금지청구권을 채권자대위로 행사하거나, 민법 제750조에 의한 손해배상(제3자 채권침해)만 가능하다(설문(2) 상술).

(3) 특허권자의 실시 가부

① 전용실시권 설정 범위 내에서는 특허권자라도 전용실시권자의 허락 없이 특허발명을 실시할 수 없고, 실시하면 전용실시권 침해가 된다(§ 94① 단서). ② 독점적 통상실시권 설정 시, 특약이 없는 한 특허권자의 실시는 원칙적으로 허용된다.

(4) 이전·통상실시권 허락·질권 설정

① **(이전)**: 양자 모두 1) 실시사업과 함께 이전하는 경우와 2) 상속 그 밖의 일반승계의 경우에는 특허권자의 동의 없이 이전할 수 있고, 그 외에는 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권이면 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 이전할 수 있다(전용실시권 § 100③, 통상실시권 § 102⑤). ② **(통상실시권 허락)**: 전용실시권자는 특허권자의 동의를 받아 그 전용실시권을 목적으로 하는 통상실시권을 허락할 수 있으나(§ 100④), 독점적 통상실시권자는 채권적 권리자에 불과하므로 통상실시권의 재허락은 성질상 불가능하다. ③ **(질권 설정)**: 양자 모두 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권이면 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 질권을 설정할 수 있다(전용실시권 § 100④, 통상실시권 § 102⑥).

(5) 소멸

① **(공통)**: 실시권은 특허권에 부수하는 권리이므로 특허권이 존속기간 만료·무효심결 확정·포기 등으로 소멸하면 함께 소멸하고, 설정(허락)계약에서 정한 존속기간의 만료나 계약의 해제·해지에 의하여도 소멸한다. ② **(전용실시권)**: 포기하려면 질권자 또는 제100조 제4항에 따른 통상실시권자의 동의를 받아야 하고(§ 119②), 포기 등에 의한 소멸(혼동 제외)은 등록하여야만 효력이 발생한다(§ 101①(2)). ③ **(독점적 통상실시권)**: 채권적 권리이므로 계약해지·존속기간 만료 등 채권의 일반 소멸사유로 소멸하며, 소멸에 등록을 요하지 아니한다. 포기하려면 질권자의 동의를 받아야 한다(§ 119③).

4. 결론

丙의 전용실시권은 등록되어 대세적 효력을 갖는 반면, 乙의 독점적 통상실시권은 등록 여부가 불분명하여 丙에게 대항할 수 없으며, 오히려 乙이 실시하면 丙의 전용실시권 침해를 구성할 수 있다.

II. 설문 (2) — 乙의 특허법상 손해배상청구권 행사 가부**1. 침해 성립**

丁은 정당권원 없이 이 사건 특허발명을 업으로서 실시하고 있으므로 특허권 침해가 성립한다(§ 94①, § 126).

2. 특허법 제128조 제1항 주체적 요건

특허법상 손해배상청구권은 **특허권자 또는 전용실시권자**에 한하여 행사할 수 있다. 독점적 통상실시권자는 명문상 제외되어 있다.

3. 학설·판례

(1) **긍정설**: 독점적 지위에 비추어 전용실시권자에 준하여 인정하자는 견해이다. (2) **부정설(다수·판례)**: 제128조 제1항은 명문상 통상실시권자를 제외하고 있고, 민법상 청구권으로 충분히 구제되므로 무리하게 확장할 필요가 없다는 견해이다. (3) **특허법원 판례**: 「독점적 통상실시권자는 시장에서 해당 특허발명을 독점적으로 실시할 권리를 가지고, 그로 인해 비독점적 통상실시권자와 달리 독점적 실시로 향유하는 경제적 이익을 침해하는 제3자에 대하여 그 침해로 인한 손해배상을 청구할 수 있다」라고 판시하였는데, 이는 민법 제750조상 제3자 채권침해에 기한 손해배상을 인정한 것이다. (4) **대법원 판례**: 독점적 통상실시권자 지위를 부작위 의무 약정(명시적·묵시적 불문)의 존부를 기준으로 판단하면서, 그 구제를 특허법상 청구가 아니라 민법상 불법행위 법리(위법성·상당인과관계의 개별 판단)에 의하도록 하였다(대법원 2018다221676).

4. 검토

독점적 통상실시권은 채권적 권리이고 제128조 제1항이 그 주체를 명시적으로 제한하고 있으므로, 특허법상 손해배상청구는 부정함이 타당하다. 다만 민법상 불법행위(제3자 채권침해)에 의한 청구는 가능하다.

5. 관련문제 — 특허권자의 침해금지청구권에 대한 채권자대위 행사 가부

(1) **일반(비독점적) 통상실시권의 경우**: 제3자의 침해가 있더라도 매상 감소 등의 불이익이 예상될 뿐 통상실시권자의 특허발명 실시 자체가 불가능하게 되는 것은 아니므로, 대위행사의 요건이나 필요성을 갖추었다고 할 수 없다. 대위행사를 위해서는 피보전권리가 존재하여야 하나, 통상실시권자에게는 특허권자에 대하여 제3자의 침해를 배제하여 달라고 요구할 채권이 없으므로 채권자대위(민 § 404)는 부정함이 타당하다(다수설). 만약 이를 인정한다면 제3자에게 새롭게 실시권을 허락하거나 제3자의 실시를 묵인할 수 있는 특허권자의 자유를 박탈하는 결과를 초래하게 된다. (2) **독점적 통상실시권의 경우**: 특허권자는 계약상 실시권자 외 제3자에게 실시를 허락하지 아니할 의무를 부담하고, 제3자의 침해를 배제할 의무가 인정되는 이상 대위행사를 인정하더라도 특허권자의 자유를 부당하게 침해하는 것이 아니다. 따라서 독점적 통상실시권자는 계약상 침해배제무의 이행청구권을 피보전권리로 하여 특허권자의 침해금지청구권(§ 126)을 대위행사할 수 있다고 봄이 타당하다.

6. 결론

乙은 丁에 대하여 **특허법상 손해배상청구권을 행사할 수 없다**. 다만 민법 제750조에 기한 손해배상청구가 가능하고, 독점적 통상실시권자로서 甲의 침해금지청구권을 채권자대위로 행사할 수 있다(위 5. 참조).

III. 설문 (3) — 戊의 직접침해 여부**1. 문제의 소재**

현행법상 물건발명의 **수출도** 실시에 해당한다(§ 2(3) 가목). 다만 戊가 수출하는 것은 특허 조성물 자체가 아니라 13종의 개별 원액이므로, 국내에서의 개별 원액 생산을 특허물건의 '생산'으로 볼 수 있는지(반제품 법리)가 문제된다.

2. 물건발명 청구항에 대한 검토**(1) 속지주의·구성요소 완비의 원칙**

특허권의 효력은 등록국 영역 내에만 미치고(속지주의), 침해가 성립하려면 청구범위의 모든 구성요소와 유기적 결합관계가 침해물에 그대로 포함되어야 한다.

(2) 반제품 국내생산 예외(2019다222782)

① 국내에서 부품 전부 또는 대부분의 생산단계를 거쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, ② 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 예정되어 있으며, ③ 그 가공·조립이 극히 사소·간단하여 반제품 생산만으로도 특허발명의 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서의 작용효과를 구현

할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 실시제품이 생산된 것으로 본다.

(3) 엄격판단(2025다202970)

위 예외는 속지주의·구성요소 완비의 원칙을 고려하여 **엄격하게** 판단해야 한다.

(4) 사안 포섭

13종의 개별 원액은 단일 주체인 a에게 수출되어 A국에서 혼합이 예정되어 있으나, 혼합공정에 별도의 방법특허가 부여될 정도라면 '극히 사소·간단'하다고 평가하기 어렵고, 엄격판단 원칙상 반제품 국내생산으로 의제되지 아니한다. 따라서 **물건발명에 대한 직접침해는 성립하지 않는다**.

3. 방법발명 청구항에 대한 검토

혼합공정은 A국에서 a에 의해 이루어져 방법발명의 실시가 국내에 없으므로 속지주의상 직접침해가 성립하지 않는다.

4. 결론

특허물건의 생산이 의제되지 아니하는 이상 개별 원액의 수출은 특허물건의 수출에도 해당하지 아니하므로, 戊는 甲의 특허권을 직접침해하지 아니한다.

IV. 설문 (4) — 戊의 간접침해 여부

1. 간접침해 제도(\$127)

직접침해의 개연성이 높은 전 단계 행위를 침해로 간주하여 특허권을 실효적으로 보호하되, 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범위에서 인정된다.

2. 판례와 2025년 개정법

판례는 속지주의 원칙상 특허권의 효력은 등록국 영역 내에만 미치므로 제127조 제1호의 '생산'이란 국내생산을 의미하고, 최종 생산이 국외에서 일어나면 그 전 단계 행위가 국내에서 이루어져도 간접침해가 성립할 수 없다고 한다(2014다42110). 2025. 1. 21. 개정 특허법 제127조는 전용품의 '**수출**'을 침해 간주 행위에 추가하여 국외 최종 생산의 보호 공백을 보완하고자 하였으나, '물건의 생산'을 위 판례와 같이 국내생산으로 제한해석하면 수출에는 여전히 간접침해를 물을 수 없다는 문제가 지적되어, 수출 태양에서 위 판례 법리가 유지될지는 해석상 확립되어 있지 아니하다.

3. 사안 포섭

(1) 물건발명 청구항

13종의 개별 원액은 이 사건 조성물의 제조를 위하여 공급되는 것으로 다른 용도가 나타나지 아니하므로 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'(전용품)에 해당하고, 戊가 이를 업으로서 a에게 **수출**하는 행위는 개정 제127조 제1호의 행위 태양에 해당한다. 그러나 '물건의 생산'을 국내생산으로 제한해석하는 판례 법리에 따르면 최종 생산이 A국에서 이루어지므로 간접침해가 성립하지 아니한다. 다만 개정 취지를 중시하면 긍정될 여지가 있다.

(2) 방법발명 청구항

개별 원액이 혼합공정(방법발명)의 '실시에만 사용하는 물건'에 해당하는 경우 그 수출은 제127조 제2호의 행위 태양에 해당하나, 위 (1)과 같이 판례 법리상 간접침해가 성립하지 아니한다.

4. 결론

판례 법리에 따르면 완제품의 생산이 국외에서 이루어지는 이상 戊의 간접침해는 성립하지 아니한다. 다만 수출을 추가한 2025년 개정법 하에서는 해석의 논란이 있다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

설문	쟁점	배점	득점 포인트
(1)	전용실시권과 독점적 통상실시권의 의의·비교	10	발생(등록요건 vs 의사합치), 효력(물권적/채권적, 침해구제 가부), 이전·변동, 소멸 등 축별 비교
(2)	독점적 통상실시권자의 특허법상 손해배상청구권 행사 가부	10	제128조 제1항 주체적 요건(특허권자·전용실시권자에 한정) → 부정, 민법 제750조 제3자 채권침해로 청구 가능(특허법원 판례), 대위행사 가능성
(3)	국내 원액생산·해외 조립 사안에서 물건·방법 발명의 직접침해	5	속지주의·구성요소완비, 2019다222782(반제품 국내생산 예외 법리), 2025다202970 엄격판단, 물건/방법 각각 포섭
(4)	간접침해(§127) 성립 여부	5	판례(2014다42110)의 국내생산 제한해석에 따른 결론 도출, 2025년 개정 제127조(수출 추가)에 따른 해석 논란 지적, 물건·방법 각각 포섭
합계		30	

축별 채점 기준

1) 논점 추출(약 12점)

- (1) 두 권리의 공통점(정당권원·제3자 실시허락 부작위)과 차이점(발생·효력·이전·소멸)을 균형 있게 추출했는가.
- (2) '특허법상' 청구권 가부라는 발문 특징에 착안하여, 제128조 제1항 주체 제한을 논점으로 삼고 민법상 청구권(제3자 채권침해)을 부가 논점으로 파악했는가.
- (3)(4) 물건발명과 방법발명 청구항을 **각각** 나누어 포섭했는가(하나만 쓴 경우 감점). 2019다222782(반제품·녹다운 수출) 및 2025다202970(엄격판단) 최신판례를 포착했는가.
- 감점: 발문에 없는 쟁점(예: 취소신청, 무효심판 등)을 나열, 최신판례 미인용, 물건·방법 구분 누락.

2) 목차·구성(약 7점)

- (1)은 '의의 → 공통점 → 차이점(발생/효력/이전/소멸)' 또는 축별 병렬 목차로 체계화했는가.
- (2)는 '제128조 제1항 → 사안포섭 → 민법상 청구권 검토 → 소결' 흐름을 갖추었는가.
- (3)(4)는 배점 5점에 맞추어 간결하게 물건/방법 두 청구항을 각각 처리했는가(과도한 일반론 배제).
- 감점: 조문 전사식 나열, 배점 대비 서두 상황, 물건·방법 뭉뚱그림.

3) 답안 작성·논증(약 11점)

- 조문(§ 100, § 102, § 128, § 127, § 2(3)) → 판례(2018다221676, 2019다222782, 2025다202970, 2014다42110) → 사안포섭 → 결론 순의 일관된 논증.
- (1)에서 침해죄(§ 225)를 언급하는 경우 2020.10.20. 개정으로 **반의사불벌죄(§225②)**로 전환된 현행법에 맞춰 서술했는가('고소' 표현 사용 시 감점).
- (2)에서 특허법상 부정/민법상 긍정이라는 이원적 결론을 명확히 제시했는가.
- (3)에서 '엄격판단' 법리를 적용하여 반제품 국내생산 예외의 성부에 대해 조건부(또는 부정) 결론을 논리적으로 낸 경우 가점.
- (4)에서 판례(2014다42110)의 국내생산 제한해석에 따라 결론을 내리고, 2025년 개정 제127조(수출 추가)로 해석의 논란이 있음을 지적했는가.
- 감점: 결론 애매모호, 판례 문구만 인용하고 사안 포섭 없음, 본문·결론 모순.

감점 주의

- '독점적 통상실시권'을 전용실시권에 준하여 특허법상 손해배상청구를 곧바로 인정한 경우(판례·조문 반함) → 큰 감점.
- 침해죄를 '친고죄·고소 요건'으로 서술한 경우(§ 225②는 2020.10.20. 개정으로 반의사불벌죄로 전환됨) → 감점.
- 물건발명 청구항의 직접침해 판단에서 속지주의·구성요소완비 원칙만 언급하고 최신판례(2019다222782, 2025다202970)를 누락한 경우.
- 간접침해 판단에서 2025년 개정 제127조 수출 추가)과 그에 따른 해석 논란을 전혀 언급하지 않은 경우.
- 방법발명 청구항에 대한 별도 판단을 누락하고 물건발명만 쓴 경우.
- 현행 제2조 제3호 가목의 실시에 '수출'이 포함됨을 간과하거나, 특허물건이 아닌 개별 원액의 수출을 곧바로 특허물건의 실시로 오해한 경우.

2025년 제2문

사례형

20점

문제

甲이 출원하여 등록받은 이 사건 특허발명은 ‘생물학적 활성 화합물과 컨주게이팅되는 잔기를 갖는 폴리알킬렌 글리콜’이라는 명칭의 발명이다. 이 사건 특허발명은 식품의약품안전처장이 기허가한 의약품의 유효성분인 인터페론베타-1a에 폴리에틸렌글리콜(PEG)을 공유결합하여 폐길화(PEGylation)한 것인데, 인터페론베타-1a는 단백질 의약품질로 체내에서 활성을 가지며 비정상적인 면역작용을 조절함으로써 재발성 다발성 경화증의 치료효과를 가진다.

한편, 폴리에틸렌글리콜은 혈액 중의 짧은 반감기, 면역원성 및 항원성 유발과 같은 단백질 의약품질의 단점을 보완하기 위하여 단백질 의약품질에 결합되는 것으로 그 자체만으로는 체내에서 활성을 가지지 않는다. 이 사건 특허발명과 관련된 이 사건 의약품인 ‘폴리베타’는 기허가 의약품과 동일한 효능·효과인 재발성 다발성 경화증의 치료효과를 가지면서도 폐길화함으로써 인터페론베타-1a의 혈액 중 평균체류시간 및 반감기를 증가시킨 의약품이다.

甲은, 식품의약품안전처장으로부터 ‘폴리베타’의 수입품목허가를 받는 데 장기간이 소요되었다는 이유로, 그 실시할 수 없었던 기간만큼 이 사건 특허권의 존속기간 연장등록출원을 하였다. 위 지문을 토대로 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 특허권의 존속기간 연장등록출원제도를 설명한 후, 甲의 이 사건 특허권의 존속기간 연장등록출원에 대해 지식재산처는 어떠한 결정을 해야 하는지 논하시오. (10점)

(2) 乙은 甲의 ‘폴리베타’와 비교할 때 ‘숙신산염’에서 ‘푸마르산염’으로 변경한 ‘염 변경 의약품’인 ‘폴리JK’를 국내에서 생산하여 판매하였다. 푸마르산염과 숙신산염의 성질을 보면 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과가 다르다고 볼 수 없으며, 숙신산염의 체내 투여 및 흡수과정은 푸마르산염의 경우에도 동일하다는 것은 널리 알려져 있으므로, 숙신산염을 푸마르산염으로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 선택할 수 있다. 이 경우 존속기간이 연장된 이 사건 특허권의 효력이 乙의 ‘폴리JK’의 생산에 미치는지 논하시오. (단, 본 물음에서는 이 사건 특허권의 존속기간이 연장되었다고 가정하고, 특허권 존속기간 연장등록의 타당성, 의약품과 염의 실제 존부 및 효능에 대해서는 다루지 않는다.) (10점)

모범답안

I. 설문 (1) — 존속기간 연장등록출원제도 및 지식재산처의 결정

1. 특허권의 존속기간 연장등록출원제도

(1) 의의

특허권의 존속기간은 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지이다(§ 88①). 다만 그 기간이 실질적으로 잠식되는 두 경우를 구제하기 위하여 허가 등에 따른 연장(§ 89)과 등록지연에 따른 연장(§ 92의2)을 두고 있다.

(2) 허가 등에 따른 연장(§89)

특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록을 하여야 하고 그 허가 등에 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명(시행령 § 7)인 경우에는, 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년까지 한 차례만 존속기간을 연장할 수 있다(§ 89①본문). 다만 허가등을 받은 날부터 14년을 초과하여 연장할 수 없다(§ 89①단서).

(3) 등록지연에 따른 연장(§92의2)

특허출원에 대하여 특허출원일부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다(§ 92의2①). 출원인으로 인하여 지연된 기간은 연장에서 제외된다(§ 92의2②). 전자가 다른 법령상 허가 등으로 실시할 수 없었던 기간을, 후자가 심사·등록 절차의 지연으로 잠식된 기간을 보전한다는 점에서 구별된다.

2. 지식재산처의 결정

(1) 문제의 소재

甲의 출원은 허가 등에 따른 연장등록출원이므로, 그 특허발명이 ‘대통령령으로 정하는 발명’(§ 89①)에 해당하여야 한다. 시행령 제7조 제1호는 이를 「약사법」에 따라 품목허가를 받은 의약품 중 신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질)을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품의 발명으로 한정한다. 이 사건 특허발명은 기허가 의약품의 유효성분인 인터페론베타-1a에 그 자체로는 활성이 없는 PEG를 공유결합한 것이므로, 이러한 발명이 시행령 제7조의 신물질을 유효성분으로 한 의약품의 발명에 해당하는지가 문제된다.

(2) 판례의 법리(대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070, 폐길화 단백질 사건)

① 시행령 제7조의 '약효'는 품목허가 대상인 특정 질환·증상에 대한 **효능·효과**를, '약효를 나타내는 활성부분'은 인체 내에 작용하여 그 효능·효과를 발현하는 부분을 의미한다. ② 기허가 의약품의 공지된 활성부분이 발현하는 효능·효과의 정도에 영향을 미치기 위하여 그 자체로는 활성을 가지지 않는 부분을 부가한 의약품의 발명은 신물질질을 유효성분으로 하여 제조한 의약품의 발명이라 할 수 없다.

(3) 사안의 포섭

기허가된 인터페론베타-1a의 효능·효과는 재발성 다발성 경화증의 치료이고, 폴리베타도 같은 효능·효과를 가지며 이를 발현하는 활성부분 역시 인터페론베타-1a로 동일하다. PEG는 그 자체로는 체내 활성을 가지지 않고 반감기·평균체류시간을 증가시켜 효능·효과의 정도에 영향을 미치는 부분에 불과하다. 따라서 이 사건 특허발명은 신물질질을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품의 발명에 해당하지 아니한다.

(4) 결론

이 사건 특허발명은 시행령 제7조가 정하는 발명이 아니므로, 그 특허발명의 실시가 제89조 제1항에 따른 허가 등을 받을 필요가 있는 것으로 인정되지 아니하는 경우(§ 91(1))에 해당한다. 따라서 지식재산처장은 의견제출기회를 부여한 후(§ 93에 따른 § 63 준용) 甲의 존속기간 연장등록출원에 대하여 **연장등록거절결정**을 하여야 한다.

3. 결론

甲의 출원은 허가 등에 따른 연장등록출원인데, 이 사건 특허발명은 기허가 의약품과 동일한 활성부분을 유효성분으로 하고 그 자체로 활성이 없는 PEG를 부가한 것에 불과하여 시행령 제7조가 정하는 발명에 해당하지 아니한다. 따라서 지식재산처장은 제91조 제1호를 이유로 **연장등록거절결정**을 하여야 한다.

II. 설문 (2) — 존속기간이 연장된 특허권의 효력 범위**1. 특허권 침해의 성립요건**

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(§ 94①). 유효한 특허권 존속 중 정당권원 없는 자가 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 업으로 실시하면 침해가 성립한다.

2. 존속기간이 연장된 특허권의 효력 범위**(1) 제95조의 규정 및 문제점**

제95조는 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 「그 연장등록의 이유가 된 **허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시**」에만 미친다고 규정한다. '허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시'의 의미가 문제된다.

(2) 학설

- ① **(제품설)** 품목허가를 받은 의약품 그 자체에만 효력이 미친다고 본다.
- ② **(주성분설)** 품목허가를 받은 의약품 주성분의 실시에만 효력이 미친다고 본다.
- ③ **(유효성분설)** 품목허가를 받은 의약품의 유효성분의 유리형태 및 그 유효성분의 염과 에스테르의 실시에도 효력이 미친다고 본다.

(3) 특허법원 판례

허가된 품목과 실질적으로 동일한 품목으로 취급되는 범위에만 효력이 미친다고 하여 제품설을 취하였다(특허법원 2016나1929).

(4) 대법원 판례(대법원 2017다245798, 염 변경 의약품 사건)

① 제95조는 청구범위를 기준으로 하지 않고 '허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시'로 규정할 뿐, 허가 등의 대상 '**품목**'의 실시로 제한하지는 않았다. ② 따라서 존속기간이 연장된 특허권의 효력 범위는, 특허발명 실시를 위해 품목허가를 받은 의약품과 침해제품 사이에 **특정한 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일하지 여부를 중심으로** 판단해야 한다. ③ 특허권자가 품목허가를 받은 의약품과 침해제품이 약학적으로 허용 가능한 **염 등에서 차이가 있더라도**, 통상의 기술자가 이를 쉽게 선택할 수 있는 정도에 불과하고 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 **치료효과나 용도가 실질적으로 동일하다면**, 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 침해제품에 미친다.

(5) 검토

제95조의 문언이 '품목'으로 제한하지 아니하는 점, 유효성분은 명세서와 허가 정보에 모두 개시되나 의약품 그 자체는 허가 정보에만 개시되는 점, 대상물건을 의약품 그 자체로 보면 제3자가 유효성분의 함량이나 제형만을 변경하여 실시하여도 침해가 되지 아니하는 점을 고려하면, 유효성분을 기준으로 삼은 대법원 판례가 타당하다. 염의 변경만으로 존속기간 연장의 실효성을 잠탈하는 것을 막을 수 있다는 점에서도 그러하다.

3. 사안의 포섭

(1) 염 변경 의약품 해당 여부

: 폴리JK는 폴리베타의 유효성분(인터페론베타-1a 페길화체)은 동일하고 숙신산염을 푸마르산염으로 변경한 염 변경 의약품에 해당한다. ② **(용이 선택 여부(적극))**: 숙신산염의 체내 투여·흡수과정이 푸마르산염과 동일하다는 사실이 널리 알려져 있어, 숙신산염을 푸마르산염으로 변경하는 것은 통상의 기술자가 누구나 쉽게 선택할 수 있다. ③ **(치료효과의 실질적 동일성(적극))**: 두 염의 성질상 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의한 치료효과가 다르지 않다.

4. 결론

폴리JK는 존속기간이 연장된 이 사건 특허권의 효력범위 내에 있다. 따라서 존속기간이 연장된 이 사건 특허권의 효력은 **乙의 폴리JK의 생산에 미치고**, 乙의 생산행위는 이 사건 특허권을 침해한다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
(1) 존속기간 연장등록출원제도 개관 (§89, §92의2 취지·요건)	3점	허가 등에 따른 연장제도의 의의·취지, 대상 발명(시행령 §7) 서술, 제89조 제1항 '5년의 기간까지 한 차례만', 단서 '허가등을 받은 날부터 14년 초과 불가' 반영
(1) '약효를 나타내는 활성부분' 판례 법리	4점	대법원 판례(폐길화 단백질 사건): 약효=효능·효과, 활성부분=효능·효과 발현 부분, 자체로 활성 없는 부분 부가는 연장대상 아님
(1) 사안포섭 및 거절결정 결론	3점	인터페론베타-1a=기허가 활성부분, PEG=자체 활성 無 → 제91조 제1호 거절결정
(2) 존속기간 연장된 특허권의 효력(§95) 및 문제점	2점	제95조 문언, '허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시' 해석 문제 제기
(2) 염 변경 의약품 관련 대법원 판례 법리	4점	유효성분·치료효과·용도 중심 판단, 염 차이가 통상의 기술자 용이선택 + 실질적 동일이면 효력 미침 (2017다245798)
(2) 사안포섭 및 결론	4점	숙신산염→푸마르산염 용이선택, 치료효과 실질 동일 → 폴리JK 생산에 효력 미침

배점 합계: 20점

특별 채점 기준

1) 논점 추출(약 40%)

- **특점:** (1)에서 '약효를 나타내는 활성부분' 해석이 핵심 쟁점임을 파악하고, 자체 활성이 없는 PEG의 부가라는 사안의 특징을 정확히 포착. (2)에서 제95조의 '허가 등의 대상물건' 해석과 염 변경 의약품 판례를 핵심 쟁점으로 추출.
- **감점:** 존속기간 연장제도 일반론만 장황히 서술, 시행령 제7조 조문 미인용, 대법원 판례(2021후11070, 2017다245798) 미인용, 학설(제품설·주성분설·유효성분설) 나열만 하고 판례 결론 없음.

2) 목차·구성(약 25%)

- **특점:** (1) 제도 개관 → 거절이유(§ 91①(1)) → 판례 법리 → 사안포섭 → 결정 결론의 흐름. (2) 제94조 침해 요건 → 제95조 효력범위 → 학설·판례 → 사안 → 결론.
- **감점:** 제도 개관에 지나친 분량 할애(허가연장·등록지연 모두 상술), 판례 문언 없이 결론만 기재, 배점(각 10점)에 비해 사안포섭 소략.

3) 답안 작성·논증(약 35%)

- **특점:** 조문(§ 89, § 90②·③, § 91, § 95, 시행령 § 7) → 판례 문언 인용 → 사안의 인터페론베타-1a/PEG, 숙신산염/푸마르산염에 정확히 포섭 → 명확한 결론(거절결정 / 효력 미침).
- **감점:** 판례 법리의 취지(제도 남용 방지, § 95 문언상 '품목' 제한 없음) 미언급, 사안포섭에서 사실관계 옮겨쓰기만 하고 법리 대입 부재, 결론 애매.

감점 주의

- (1)에서 '신물질' 요건만 형식적으로 검토하고, 판례가 실시한 '약효를 나타내는 활성부분' 해석 법리를 놓치는 경우.
- (1)에서 PEG가 자체 활성이 없다는 사실을 포섭하지 않고 단순히 '동일 유효성분이므로 신물질 아님'만 서술.
- (1)에서 시기적 요건 근거를 시행령 제7조의2로 오지정하거나(존재하지 않는 조문), 출원인 적격을 제90조 제1항에서 도출하는 등 조문 근거를 잘못 특정하는 경우. 시기적 요건은 제90조 제2항 본문(허가일부터 3개월)·단서(만료 전 6개월 이후 불가), 공유 시 전원 공동출원은 제90조 제3항, 특허권자 아닌 자의 출원은 제91조 제4항에서 반사적으로 도출됨을 정확히 적시하여야 함.
- (1)에서 제89조 제1항 개정사항('5년의 기간까지 한 차례만 연장', '허가등을 받은 날부터 14년 초과 불가')을 언급하지 않는 경우.
- (2)에서 특허법원 판례(품목 동일성 기준)와 대법원 판례(유효성분·치료효과·용도 중심 + 염 용이변경)의 차이를 구분하지 못하는 경우.
- (2)에서 제95조 문언('청구범위 기준 아님, 품목 제한 없음')의 취지를 언급하지 않고 결론만 도출.
- 학설 나열에 그치고 자기 입장(판례 지지)의 논거를 밝히지 않는 경우.

2025년 제3문

사례형

30점

문제

甲은 발명 X에 대해 청구범위를 제1항 내지 제5항으로 구성하여 2024년 10월 11일 한국 지식재산처에 특허출원하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 甲은 청구항 제2항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다는 이유로 의견제출통지서를 받았으나 이에 대해 아무런 대응을 하지 아니하였고, 의견서 제출 기간이 경과하였다. 심사관은 2025년 7월 4일 특허거절결정을 하였고, 甲은 2025년 7월 7일 특허거절결정등본을 송달받았다. 다음 물음에 답하시오. **(10점)**

1. 甲은 의견서 제출 기간이 경과된 후 청구항 제2항을 취하하는 내용의 출원 취하서를 지식재산처에 제출하였으나, 지식재산처장은 이를 반려하였다. 지식재산처장의 처분이 적절한지 논하시오.
2. 특허거절결정등본을 송달 받은 甲이 등록받기 위해 취할 수 있는 특허법상의 조치를 논하시오.

(2) 심사관은 청구항 제1항 내지 제5항 모두 인용발명 Y에 비하여 진보성이 인정되지 않는다는 의견제출통지서를 발송하였다. 甲은 거절이유를 극복하기 위해 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 심사관은 거절이유가 해소되지 않았다고 특허거절결정을 하였다. 甲은 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 甲에게 의견제출의 기회를 부여하지 아니하고 “청구항 제1항 및 제2항은 진보성이 인정되지만, 청구항 제3항 내지 제5항은 인용발명 Y에 비하여 진보성이 인정되지 않는다”며 청구를 기각하는 심결을 하였다. 특허심판원의 심결이 적절한지 논하시오. **(6점)**

(3) 甲은 발명 X에 대해 특허등록을 받은 후 특허권 지분 50%를 乙에게 이전하였다. 특허권 지분을 이전한 후 甲은 乙의 동의 없이 대한민국 국적의 A사에게 발명 X의 생산을 의뢰하였고, A사는 발명 X를 생산하여 甲에게 납품하였다. 이러한 사실을 알게 된 乙이 취할 수 있는 법적 조치에 대하여 논하시오. **(14점)**

모범답안

I. 설문 (1) - 1)

1. 문제의 소재

甲은 의견제출기간 경과 후 청구항 제2항만을 취하하는 '출원취하서'를 제출하였다. 특허법은 출원 전체의 취하만을 규정할 뿐 일부 취하 규정을 두지 않으므로, 1) 이를 보정으로 선행할 수 있는지, 2) 보정기간 경과 후 제출된 서류의 취급이 문제된다.

2. 출원의 일부 취하의 취급

(1) 적용 법규정 부존재

특허법은 특허결정 전 출원의 일부를 취하할 수 있다는 규정을 두고 있지 않다.

(2) 판례(대법원 2001후1044)

"보정기간 경과 후에도 출원의 일부 취하를 허용하는 것은 출원의 보정에 엄격한 시기적 제한을 두고 있는 특허법의 취지에 반하므로, 출원인이 '출원의 일부 취하'라는 이름의 서류를 제출하였다고 하더라도 보정과 같은 목적을 달성하고자 하는 것이라면 보정과 마찬가지로 보아야 한다."

(3) 검토

청구항 삭제와 동일한 효과를 목적으로 하는 서류를 보정 시기 제한을 회피하는 수단으로 허용할 수 없으므로 판례(2001후1044)는 타당하다.

3. 보정기간 경과 후 제출된 보정서의 취급

특허법 시행규칙 제11조에 따라, 법정기간을 초과하여 제출된 서류는 소명기회 부여 후 반려대상이다. 특허법 제47조 제1항에 의해 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 내에만 보정이 허용되므로, 그 기간 초과 후의 보정서는 반려되어야 한다.

4. 결론

甲의 출원취하서는 청구항 제2항 삭제라는 보정과 같은 목적을 달성하고자 하는 것이므로 보정으로 취급되어야 한다. 그런데 이는 의견제출기간이 경과된 후 제출되었으므로 시행규칙 제11조에 따라 반려대상이다. 따라서 지식재산처장의 반려처분은 적법하다.

II. 설문 (1) - 2)

1. 재심사청구(§67의2)

甲은 등본 송달일부터 3개월 이내(2025.10.7. 이내)에 청구항 제2항의 삭제 또는 발명의 설명에 부합하도록 하는 보정을 수반하여 재심사를 청구할 수 있다. 거절이유가 뒷받침 요건 흠결로서 실제로 타당한 경우 유효한 조치이다.

2. 거절결정불복심판(§132의17)

甲은 등본 송달일부터 3개월 이내에 거절결정불복심판을 청구할 수 있다. 뒷받침 요건 흠결이 부당하다고 판단되는 경우 보정 없이 청구항 제2항의 뒷받침 인정을 다룰 수 있다.

3. 분할출원(§52) 및 분리출원(§52의2)

거절이유가 없는 청구항 제1항, 제3항 내지 제5항을 조기 등록받기 위해 재심사청구 또는 거절결정불복심판 청구와 함께 **분할출원**을 할 수 있다. 심판 기각 후에는 **분리출원**도 가능하다.

4. 국내우선권주장출원(§55)

뒷받침 흠결을 해소하기 위하여 발명의 설명에 새로운 내용을 추가하여야 하는 경우, 보정은 신규사항 추가가 금지되므로(§ 47②) 보정을 수반한 재심사 청구로는 극복할 수 없다. 사안은 선출원일(2024.10.11.)부터 1년의 우선기간 이내이고 거절결정이 확정되지도 아니하였으므로, 甲은 이 사건 출원을 선출원으로 하는 국내우선권주장출원을 하여 발명의 설명을 보강하면서, 선출원에 기재된 발명에 대하여는 판단시점의 소급을 인정받을 수 있다. 다만 선출원은 그 출원일로부터 1년 3개월이 지난 때에 취하된 것으로 본다(§ 56①).

5. 조치별 실익

재심사의 청구와 거절결정불복심판의 청구는 선택적으로 이용할 수 있다. 재심사의 청구는 신속한 권리화에, 거절결정불복심판의 청구는 넓은 권리범위의 확보에 실익이 있으므로, 甲은 뒷받침 요건 위반 여부에 대한 판단에 따라 조치를 선택하면 된다.

6. 결론

甲은 청구항 제2항의 뒷받침 요건 위반이 타당하다면 보정을 수반한 **재심사청구**로 신속한 권리화를 도모할 수 있고, 부당하다고 판단되면 거절결정불복심판을 청구하여 다룰 수 있다. 거절이유가 없는 나머지 청구항들은 재심사청구·심판청구와 함께 분할출원(심판 기각 후에는 분리출원)을 하여 조기 등록을 받을 수 있다. 발명의 설명에 신규사항의 추가가 필요한 경우에는 우선기간 내의 국내우선권주장출원으로 보강할 수 있다.

III. 설문 (2)

1. 문제의 소재

거절결정불복심판에서 특허심판원이 甲에게 의견제출기회를 부여하지 않고 청구항 3~5의 진보성 부정을 이유로 기각심결을 한 것이 절차적·실체적으로 적법한지 문제된다.

2. 적용 법규정 및 법리

(1) 다른 거절이유에 대한 의견제출기회와 강행규정성

특허거절결정불복심판에서 심사관의 거절결정 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 출원인에게 의견제출기회를 부여하여야 한다(§ 170, § 63 준용). 이는 출원인에게 해명 기회를 주지 않고 거절하는 것은 가혹하고 심사관의 오류 시정 기회를 확보할 필요가 있다는 취지의 강행규정이므로, 의견제출기회를 부여하지 않은 새로운 거절이유로써 거절결정이 결과적으로 정당하다는 이유로 심판청구를 기각한 심결은 위법하다(대법원 2015후2341).

(2) '주된 취지 부합' 법리와 구체적 사례

기각심결의 이유가 주된 취지에서 거절결정의 이유와 부합하면 이미 심사단계에서 그 거절이유에 대한 실질적인 의견제출·보정의 기회가 부여된 것이므로, 새로이 거절이유를 통지할 필요가 없다(대법원 98후300). "출원발명 전체가 진보성이 없다는 거절이유에는 일부 청구항이 진보성이 없다는 심결이유가 당연히 포함되므로 이를 '거절결정의 거절이유와 다른 거절이유'라고 할 수 없다"(특허법원 2001허89).

(3) 출원일제의 원칙(확립된 판례·실무 법리)

특허법 제215조는 청구항마다 특허가 되는 경우를 열거하고 있으나 거절결정에 관하여는 그러한 규정을 두고 있지 않으므로, 청구범위에 둘 이상의 청구항이 있는 경우 그 중 하나의 청구항이라도 거절이유가 해소되지 않으면 출원 전체가 거절되어야 한다는 것이 확립된 판례·실무의 태도이다(대법원 2007후3820).

3. 사안의 포섭

심사관은 청구항 제1항 내지 제5항 **모두**가 인용발명 Y에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 의견제출통지를 한 뒤 거절결정을 하였고, 심판원은 그중 청구항 제3항 내지 제5항이 같은 이유로 진보성이 부정된다고 하여 기각심결을 하였다. 전체 청구항이 진보성이 없다는 거절이유에는 그중 일부인 청구항 제

3항 내지 제5항이 진보성이 없다는 거절이유가 당연히 포함되므로(특허법원 2001허89), **기각심결의 주된 취지가 거절결정의 이유와 부합하여** '다른 거절이유'에 해당하지 않는다. 따라서 별도의 의견제출기회 부여는 요구되지 않는다. 또한 출원일체의 원칙상 청구항 제3항 내지 제5항의 거절이유가 유지되는 이상 청구항 제1항·제2항의 진보성이 인정되더라도 출원 전체가 거절되어야 한다.

4. 결론

특허심판원의 기각심결은 절차적·실체적으로 적법하다.

IV. 설문 (3)

1. 문제의 소재

甲·乙이 특허권을 공유하는 상태에서 甲이 乙의 동의 없이 A사에 발명 X의 생산을 의뢰하여 납품받았다. A사의 생산이 공유자 甲의 자기실시의 범위에 드는지에 따라 乙이 취할 수 있는 조치가 달라지므로, 乙의 A사에 대한 조치와 甲에 대한 조치를 나누어 검토한다.

2. 특허권 공유관계에서의 실시 제한

(1) 각 공유자의 자유실시(§99③)

특별한 약정이 없는 한 각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 그 특허발명을 스스로 실시할 수 있다.

(2) 지분양도·실시권 설정의 제한(§99②·제4항)

각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 지분을 양도하거나 제3자에게 실시권을 설정할 수 없다.

(3) 사안

甲과 乙은 발명 X의 특허권을 50:50으로 공유하므로, 甲은 스스로 실시할 수는 있으나 乙의 동의 없이 제3자에게 실시권을 설정할 수는 없다.

3. 乙의 A사에 대한 조치

(1) 공유자의 자기실시 범위

공유자 1명이 스스로 실시하지 아니하고 하청·외주를 준 경우 하청받은 자의 실시를 그 공유자의 실시로 볼 수 있는지가 문제된다. 자기실시의 범위를 너무 넓게 보면 제99조 제3항과 제4항의 구별이 없어져 다른 공유자의 권리를 해치고, 너무 좁게 보면 특허발명의 활용을 저해한다. 판례는 "실시행위의 전 과정이 공유자의 계산 아래 그의 지휘·감독 하에 이루어진 것이라면 공유자에 의한 자기실시로 볼 수 있다"고 하고(특허법원 2023나11078), 상표에서도 제3자가 사용권자와 주종관계를 맺고 그 실질적 통제 아래 사용하여 거래통념상 사용권자가 사용한다고 볼 수 있으면 제3자도 침해 책임을 지지 아니한다고 한다(대법원 2011다73793).

(2) 사안의 포섭

A사는 甲의 의뢰(계약관계)에 따라 발명 X를 생산하여 甲에게 납품하였을 뿐, 스스로 판매하는 등 주도적으로 실시한 사정이 보이지 않는다. A사의 생산이 甲의 계산 아래 그 지휘·감독 하에 이루어진 것으로 인정된다면 이는 甲의 자기실시로서 제99조 제3항의 적법한 실시에 흡수되므로, 乙은 A사에 대하여 침해를 이유로 한 조치를 취할 수 없다.

(3) 자기실시 범위를 벗어나는 경우

반면 A사가 甲의 지휘·감독을 벗어나 스스로의 계산으로 실시하는 경우(생산품을 직접 판매하는 경우 등)에는 정당한 권원 없는 실시로서 침해가 성립한다. 이 경우 乙은 1) 공유물의 보존행위로서 단독으로 침해금지청구(§126)를 할 수 있고, 2) 자신의 지분비율 한도에서 손해배상청구(§128)를 할 수 있으며, 3) 신용회복청구(§131)·부당이득반환청구도 가능하고, 4) 고의가 인정되면 침해죄(§225)로 처벌을 구할 수 있다.

4. 乙의 甲에 대한 조치

(1) 특허법상 직접 제재의 부재

A사의 생산이 甲의 자기실시 범위 내라면 이는 제99조 제3항의 적법한 실시이므로 乙이 이를 저지할 수 없다. 설령 甲의 의뢰가 자기실시 범위를 벗어나 사실상 실시허락에 해당하여 제99조 제4항 위반이 되더라도, 이를 위반한 공유자에 대하여는 특허법상 직접적인 제제조치가 없으며, 다른 공유자는 공유물분할청구를 통하여 공유관계에서 벗어날 수 있을 뿐이다.

(2) 공유물분할청구

판례는 공유물분할청구권을 인정하더라도 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 변동이 생긴다고 보기 어려워 제99조 제2항·제4항에 반하지 아니하고 분할청구를 금지하는 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구 규정이 적용될 수 있다고 한다(대법원 2013다41578). 다만 무체재산권의 성질상 현물분할은 허용되지 아니하고 경매에 의한 대금분할이나 가격배상에 의한 분할이 인정되므로, 乙은 분할금지 특약이 없는 한 공유물분할청구로 공유관계를 해소할 수 있다.

(3) 분할청구에 따른 통상실시권 (§122)

분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자가 분할청구 이전부터 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는, 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가지고, 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(§ 122, 2021. 10. 19. 개정). 사안에서 乙이 분할청구를 하는 경우 발명 X를 실시하고 있는 甲이 위 통상실시권을 가질 수 있다는 점을 유의하여야 한다.

5. 결론

A사의 생산·납품이 甲의 계산과 지휘·감독 하에 이루어진 것이라면 甲의 자기실시에 해당하여 乙은 A사에 대하여 침해를 이유로 한 조치를 취할 수 없으나, A사가 그 범위를 벗어나 스스로의 계산으로 실시하면 침해금지청구·손해배상청구 등 민·형사상 조치를 취할 수 있다. 甲에 대하여는 특허법상 직접적인 제재수단이 없으므로, 乙은 공유물분할청구권을 행사하여 공유관계를 해소할 수 있고, 이는 특허권의 성질상 경매에 의한 대금분할 또는 가격배상으로 실현된다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

설문	쟁점	배점	특점 포인트
(1)-1)	출원의 일부취하서의 법적 취급(보정 선택)	5	특허법상 일부취하 규정 부존재, 판례(2001후1044) 취지—보정과 같은 목적이면 보정으로 취급
(1)-1)	보정기간 경과 후 서류의 처리(시행규칙 제11조)	2	의견제출기간 경과 후 보정서 반려 → 처분 적법 결론
(1)-2)	거절결정에 대한 출원인의 조치	3	재심사청구(\$67의2), 거절결정불복심판(\$132의17), 분할출원(\$52), 분리출원(\$52의2), 조치별 실익(넓은 권리범위 vs 신속한 권리화)
(2)	제170조 제1항-제63조 준용 및 '다른 거절이유' 법리	3	강행규정성(2015후2341), '주된 취지 부합'(98후300) 법리 적시
(2)	출원일체의 원칙 및 사안 포섭	3	청구항 3~5의 진보성 부정 이유가 거절결정 이유와 주된 취지 부합 → 심결 적법 결론 (출원일체의 원칙은 확립된 판례·실무 법리로 인용)
(3)	공유특허 법률관계(\$99①③④)	4	甲·乙 공유, 甲의 자유실시 가능, 타공유자 동의 없는 실시권 설정 불가
(3)	자기실시의 범위 해당 여부 판단	4	甲의 지휘·감독, 전량 납품 요건 검토 → 성립 시 甲의 실시로 취급, 불성립 시 A사 침해
(3)	침해 성립 시 A에 대한 민·형사 조치	3	침해금지(보존행위, 단독행사), 손해배상(지분비율), 신용회복, 침해죄 고소 등
(3)	공유물분할청구권(민법 \$268, 2013다41578)	3	특허권 공유에도 민법상 공유물분할청구 적용, 乙이 공유관계 해소 수단으로 행사 가능

배점 합계: 30점

축별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- (1)-1): 출원취하와 보정의 관계 문제인식(판례 2001후1044) 포착
- (1)-2): 재심사청구와 거절결정불복심판을 병렬적으로 제시하고 분할출원 추가 언급
- (2): '주된 취지 부합' 판례 법리 + 출원일체의 원칙(확립된 판례·실무 법리)을 함께 포섭
- (3): 공유자의 자기실시 범위 해당 여부에 따른 경우 분류(특허법원 2023나11078) + 乙의 A사/甲에 대한 조치 구분 + 공유물분할청구권·제122조 통상실시권 논점 추출
- 감점: 공유물분할청구권 누락, 자기실시 범위 법리 미언급, 재심사·거불심 병렬 조치 누락

2) 목차·구성(25%)

- 설문별 배점 비례 분량 배분(설문(3) 14점에 최대 지면)
- 설문(3)에서 '甲·乙 공유관계 → A사의 지위(자기실시 범위) → A사/甲에 대한 조치'의 논리 흐름
- 조치 나열 시 사전적/민사적/형사적 조치 등 유형별 소재목 구성
- 감점: 설문(3)을 조치 나열식으로만 처리, 자기실시 인정/부정 경우분류 부재, 서론 장황

3) 답안 작성·논증(35%)

- 조문(\$ 47①, \$ 67의2, \$ 132의17, \$ 170①·\$ 63, \$ 99, 시행규칙 \$ 11) → 판례 → 사안 포섭 순 논증
- 판례 인용 정확성: 2001후1044(일부취하), 2015후2341(강행규정), 98후300(주된 취지 부합), 특허법원 2001허89(전체 진보성 부정 거절이유에 일부 청구항 거절이유 당연 포함), 2013다41578(공유물분할), 특허법원 2025. 5. 28. 선고 2023나11078(공유자의 계산·지휘감독 하 자기실시). ※ 출원일체의 원칙은 확립된 판례·실무 법리로 인용(특정 사건번호 미기재도 무방)
- 사안 포섭에서 자기실시 요건(계약관계·지휘감독·전량 인도)의 충족 여부에 따라 경우를 나눔
- 감점: 조문만 나열·판례 취지 부정확, 결론 애매, 본문↔결론 모순

감점 주의

- **설문(1)-(1):** 단순히 '보정기간 경과했으니 반려'로 결론짓고 '출원 일부취하 = 보정으로 선택' 판례 법리를 놓치면 감점
- **설문(1)-(2):** 재심사와 거불심 중 하나만 쓰거나 조치별 실익(넓은 권리 vs 신속) 미언급 시 감점
- **설문(2):** '주된 취지 부합' 문구 없이 결론만 적으면 감점, 출원일체의 원칙 누락 감점
- **설문(2):** 출원일체의 원칙을 무관한 청구범위 해석 판례로 인용하는 것은 판례 취지 불일치로 감점. 확립된 판례·실무 법리 또는 그에 부합하는 판례로 인용해야 함
- **설문(3):** 자기실시의 범위만 쓰고 공유물분할청구 누락 시 큰 감점(배점 14점 채우기 어려움)
- **설문(3):** 침해금지청구를 지분비율로 제한한다고 오기, 손해배상청구를 전액 청구 가능하다고 오기 시 감점
- 조문 인용을 구법 조문번호로 기재하는 경우 감점(현행 \$ 47, \$ 67의2, \$ 99, \$ 132의17 등)

2025년 제4문

사례형

20점

문제

甲, 乙 및 丙은 대학교 동기로서, 공동으로 ‘브로콜리 줄기에서 천연물 X를 추출하는 방법’(이하, ‘발명 Y’라 함)을 발명하기로 하였다. 甲은 관련 선행 논문을 제시하며 아이디어만을 제공하고, 연구에 필요한 설비 및 자금을 지원하였다. 乙은 천연물 X를 추출하는 방법에 관한 아이디어를 제시하고 구체적인 실험을 통해 발명 Y를 완성하였다. 丙 역시 다양한 아이디어를 제공하고 실제 실험을 통해 발명 Y를 구체화하고 완성하는데 기여하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 甲과 丙은 乙 몰래 발명 Y에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 대한민국 국적의 A사에 이전하였다. A사는 특허출원서에 甲과 丙을 발명자로 기재하고 2024년 11월 4일 한국 지식재산처에 특허출원하였다. 그 후 乙은 甲과 丙이 A사에 특허를 받을 수 있는 권리를 이전하여 발명 Y가 특허출원된 사실을 알게 되었다. 乙이 A사 및 특허출원에 대해 취할 수 있는 조치를 논하시오. (14점)

(2) 甲, 乙 및 丙은 서로 간의 합의를 통해 甲이 발명 Y를 단독으로 특허출원하게 되었다. 발명 Y가 특허등록 된 후 甲은 대한민국 국적의 B사에 특허권에 대한 유상의 통상실시권을 설정해 주었다. 그 후, B사의 연구원은 우연히 미국 국적의 C사가 발명 Y와 실질적으로 동일한 발명 Y'를 C사 카탈로그에 기재하여 발명 Y의 특허출원일 전에 반포하였다는 사실을 알게되었다. B사가 甲의 특허에 대해 특허심판원에 취할 수 있는 조치를 논하시오. (6점)

모범답안

I. 설문 (1) — 乙이 A사 및 특허출원에 대해 취할 수 있는 조치 (14점)

1. 문제의 소재

甲은 아이디어 제공과 설비·자금 후원에 그쳤고, 乙은 착상을 제시하고 실험으로 발명 Y를 완성하였으며 丙도 실험으로 완성에 기여하였는데, 甲·丙이 乙 몰래 권리를 A사에 이전하고 A사가 甲·丙을 발명자로 기재하여 출원하였다. 1) 공동발명자의 결정 (§ 33①·§ 2(1)), 2) 권리 양도의 적법성 (§ 37③), 3) 발명자 허위 기재의 취급을 검토한 후 乙이 취할 수 있는 조치를 본다.

2. 공동발명자의 결정 (§33①·§2(1))

발명자는 기술적 사상의 창작 (§ 2(1))에 실질적으로 기여한 자이므로 과제·아이디어만 제공하거나 자금·설비로 후원한 자는 공동발명자가 아니고, 실험의 과학인 화학발명에서는 실험을 통하여 발명을 구체화·완성하는 데 실질적으로 기여하였는지로 판단한다(대법원 2009다75178). 발명 Y는 화학발명이므로 후원에 그친 甲은 발명자가 아니고 乙과 丙이 공동발명자여서 특허를 받을 수 있는 권리는 乙·丙이 공유한다 (§ 33②).

3. 甲·丙의 권리 양도의 적법성 (§37③)

A사는 권리능력이 있어 권리를 승계할 수 있으나, 공유인 특허를 받을 수 있는 권리의 지분은 다른 공유자 모두의 동의를 받아야 양도할 수 있다 (§ 37③). 甲은 처분할 권원이 없고 丙의 지분 양도는 乙의 동의 없이 이루어져 무효이므로, A사는 무권리자이고 그 출원은 제33조 제1항 본문 위반으로서 거절이유 (§ 62)·정보제공사유 (§ 63의2)·무효사유 (§ 133①(2))에 해당한다. 다만 제44조 위반은 공유자 중 일부만 출원한 경우의 문제여서 무권리자 A사의 출원에 이를 적용할 수 있는지는 명확하지 아니하다(특허법원 2007허9040은 공동발명자 1인으로부터만 양수한 자의 출원을 § 44 위반으로 보았다).

4. 발명자 허위 기재의 취급

발명자 오기재 자체는 거절이유·무효사유가 아니고 정정 신청은 출원인 또는 특허권자만 할 수 있으므로(施則 § 28), 출원인이 아닌 乙이 이를 직접 다투기는 어렵다. 다만 무권리자 여부는 발명자란의 기재가 아니라 실질에 따라 판단하므로(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 취지), 甲을 발명자로 기재하고 乙을 누락한 허위 기재는 무권리자 출원을 증명하는 자료가 될 수 있다.

5. 乙이 A사에 대하여 취할 수 있는 조치

1. 출원인 명의변경 청구 — 혐의로 출원인 명의를 乙·丙으로 변경하게 할 수 있고, 불응 시의 명의변경 청구도 특허법원 판례가 긍정한다. 다만 丙은 A사에 지분을 양도한 자여서 공동명의의 변경에 협력하면 A사에 대한 민사상 책임을 질 수 있어 협력을 기대하기 어렵다. **2. 특허권 이전청구 (§99의2)** — 등록 후 乙은 자기 지분의 이전을 법원에 청구할 수 있고, 이전등록되면 특허권은 설정등록일부터 이전받은 자에게 귀속하며 다른 공유자의 동의를 요하지 아니한다. 다만 1) 이전등록 전에 무효사유를 알지 못하고 실시하거나 준비 중이던 A사는 법정통상실시권을 가지므로 (§ 103의2) 그 실시를 저지할 수 없고, 2) 乙 지분만 이전받으면 丙의 지분이 A사에 남아 공동출원 위반 (§ 44)의 무효사유가 존속한다. **3. 민·형사상 조치** — 출원 여부 선택권과 발명자 기재의 인격적 이익 침해를 이유로 甲·丙·A사에 불법행위에 기한 손해배상을 청구할 수 있고, 거짓행위의 죄 (§ 228)도 문제될 수 있다.

6. 乙이 특허출원에 대하여 취할 수 있는 조치

1. 심사판여 — 심사청구(§ 59②)를 하고, 무권리자 출원과 발명자 허위 기재를 증명하는 자료를 첨부한 정보제공(§ 63의2)으로 거절을 유도하며, 등록되면 무효심판(§ 133①(2))을 청구할 수 있다. 이때 청구인 적격은 이해관계인이 아니라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 인정되고, 무효심판은 특허 자체를 대상으로 하므로 자기 지분만에 대한 청구는 허용되지 아니한다(대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2432). **2. 정당한 권리자의 출원(§34-§35)** — 거절결정 확정일부터 30일 이내에 제34조의 출원을, 무효심결 확정일부터 30일 이내에 제35조의 출원을 하여 A사의 출원 시로 출원일을 소급받을 수 있다. 다만 이는 丙과의 공동출원(§ 44)을 요하는데 丙의 협력을 기대하기 어려우므로, 乙이 丙으로부터 지분을 양도받아(양수인이 공유자 본인이어서 § 37③의 동의도 문제되지 아니한다) 단독으로 출원하는 방안을 고려할 수 있다. 또한 A사가 무효심판청구 등록 전 선의로 실시하거나 준비 중이었다면 중용권(§ 104①(3))을 가지므로 그 실시에 침해를 주장할 수 없다.

7. 결론

공동발명자는 乙·丙이고 甲·丙의 양도는 무효이므로 A사의 출원은 무권리자 출원이며 발명자 기재도 허위이다. 乙은 A사에 대하여 명의변경 청구·특허권 이전청구(§ 99의2)와 민·형사상 조치를, 출원에 대하여는 심사판여를 거쳐 제34조·제35조의 출원을 할 수 있다. 최선의 방안은 乙이 丙의 지분을 양도받아 권리 전부를 확보한 다음 제34조·제35조에 따라 단독으로 재출원하거나 제99조의2에 따라 특허권 전부의 이전을 청구하는 것이며, 신속한 구제와 권리 범위 재설계의 실익을 비교하여 선택하면 된다. 다만 선의의 A사에게는 법정통상실시권(§ 103의2·§ 104①(3))이 인정됨을 유의하여야 한다.

II. 설문 (2) — B사가 특허심판원에 취할 수 있는 조치 (6점)

1. 문제의 소재

甲·乙·丙의 합의로 甲이 단독 출원하여 등록받았으므로 무권리자 출원의 하자는 없다. 다만 출원일 전에 미국 C사가 발명 Y와 실질적으로 동일한 Y'를 카탈로그에 기재하여 반포하였고 카탈로그는 제작되면 배부·반포되는 것이 사회통념이므로(대법원 98후270), 甲의 특허에는 신규성 위반(§ 29①(2))의 무효사유(§ 133①(1))가 있다. 따라서 유상의 통상실시권자인 B사에게 청구인 적격이 인정되는지를 중심으로 B사가 취할 수 있는 조치를 본다.

2. B사의 무효심판 청구인 적격

1. 법리(대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체) 무효심판은 이해관계인 또는 심사관이 청구할 수 있다(§ 133① 본문). 이해관계인이란 특허권의 존속으로 법률상 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 직접적·현실적 이해관계를 가진 자를 말하고, 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다.

2. 사안의 포섭 B사는 유상의 통상실시권자로서 특허가 무효로 되면 실시료 지급 의무를 면하는 등 법률상 불이익을 제거할 직접적·현실적 이해관계가 있으므로, 이해관계인으로서 청구인 적격이 인정된다.

3. B사가 특허심판원에 취할 수 있는 조치

1. 특허무효심판 청구(§133①(1)) B사는 이해관계인으로서 신규성 위반을 이유로 특허무효심판을 청구할 수 있고, 무효심결이 확정되면 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다(§ 133③).

2. 특허취소신청(§132의2) 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지는 누구든지 반포된 간행물(카탈로그)에 기초한 신규성 위반을 이유로 특허취소신청을 할 수 있으므로(§ 132의2①(1)), 甲의 특허가 아직 위 기간 내에 있다면 취소신청도 가능하다.

4. 결론

B사는 특허심판원에 신규성 위반을 이유로 한 특허무효심판(§ 133①(1))을 청구할 수 있고, 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지의 기간 내라면 간·신속한 특허취소신청(§ 132의2)도 선택할 수 있다. 특허취소신청과 특허무효심판은 일사부재리가 적용되지 않기에 둘 다 선택할 수도 있다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
[설문(1)] 공동발명자 판단 (甲·乙·丙의 실질적 기여)	4점	발명자=기술적 사상의 창작(제2조 제1호)에 실질적 기여한 자, 화학발명은 실험을 통한 구체화·완성 기여 관점 (2009다75178), 甲(아이디어·자금·설비) 부정 / 乙·丙 긍정 → 乙·丙 공유(제33조 제2항)
[설문(1)] A사 출원의 하자(무권리자·공동출원 위반)	3점	제37조 제3항(공유지분 이전 시 타 공유자 동의 필요)을 거쳐 제33조 제1항 본문 위반(무권리자 출원) 도출, 제44조 위반 단정의 부적절성(공유자 일부의 출원 사안이 아님) 인식
[설문(1)] 출원에 대한 조치(정보제공·심사청구·정당권리자 출원)	3점	심사청구(\$59②)·정보제공(\$63의2)의 심사관여, 거절확정 시 \$34·무효확정 시 \$35의 정당권리자 출원(丙 협력 곤란 → 지분 양수 후 단독 출원 방안), 선의 A사의 중용권(\$104①(3)) 한계
[설문(1)] A사에 대한 조치(명의변경신청·합의/불합의)	2점	명의변경 청구(丙의 민사상 책임으로 협력 곤란), \$99의2 이전청구(설정등록일 소급·동의 불요 / 한계: \$103의2 선의 실시권·지분만 이전 시 \$44 무효사유 존존), 민·형사상 조치
[설문(1)] 발명자 기재 관련 조치(발명자 정정 신청)	2점	발명자 오기재는 거절·정보제공·무효사유 아님(정정은 출원인만, 施則\$28), 무권리자 여부는 실질 판단(2009후2463) 이므로 허위 기재는 무권리자 출원의 증명자료
[설문(2)] 신규성 위반(\$29①) 인정	2점	카탈로그 제작 인정 시 반포 추정(98후270)·국외 반포 간행을 포함 → 신규성 상실(\$29①(2)). 무효사유 판단은 문제의 소재에서 간결히 처리
[설문(2)] 실시권자(B사)의 청구인 적격 인정	3점	제133조 제1항 이해관계인, 전합판례(대법원 2017후2819 — 실시권자라는 사정만으로 이해관계 소멸 부정), 유상 통상실시권자 B사 긍정
[설문(2)] 취할 수 있는 조치(무효심판, 취소신청)	1점	특허무효심판 청구 가능(\$133), 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 라면 특허취소신청(\$132의2①) 언급, 취소신청은 심판이 아니어서 일사부재리가 적용되지 않아 무효심판과 병용 가능함을 지적

배점 합계: 20점

특별 채점 기준

1) 논점 추출 (약 8점)

- **[+]** 발명자란 기재와 무관하게 실질적 기여 관점에서 공동발명자를 판단해야 함을 포착
- **[+]** 甲의 기여(아이디어·자금·설비 제공)를 판례법리에 포섭하여 공동발명자 부정 결론
- **[+]** '몰래' 이전이라는 사실관계에서 제37조 제3항(공유지분 이전 시 타 공유자 동의) 위반 및 제33조 제1항 본문 위반(무권리자 출원)의 하자 포착 — 제44조 위반 단정은 부정확함을 인식
- **[+]** 설문(1)이 'A사에 대한 조치'와 '특허출원에 대한 조치'를 별도로 물음을 인지하여 이원적으로 답안 구성
- **[+]** 설문(2)에서 실시권자의 이해관계(청구인 적격) 쟁점이 핵심임을 포착
- **[-]** 공동발명자 판단을 건너뛰고 곧바로 무권리자·공동출원 위반만 서술한 경우 감점
- **[-]** 발명자 오기재 관련 조치 부재를 언급하지 않은 경우 소폭 감점

2) 목차·구성 (약 5점)

- **[+]** '문제의 소재 → 공동발명자의 결정 → 양도의 적법성 → 발명자 허위 기재의 취급 → A사에 대한 조치 → 특허출원에 대한 조치 → 결론' 순의 체계적 목차
- **[+]** 14점 배점에 맞추어 공동발명자 판단·조치 부분에 분량 배분
- **[+]** 설문(2)는 6점 배점에 맞추어 무효사유를 문제의 소재에 녹이고 '청구인 적격 → 조치 → 결론'으로 간결하게 구성
- **[-]** 조치별 적용 법규정 없이 나열만 한 경우 감점
- **[-]** 서론 장황·일반론 나열로 사안 포섭 분량 부족 시 감점

3) 답안 작성·논증 (약 7점)

- **[+]** 공동발명자 판례(2009다75178)의 '공동발명자로 볼 수 없는 유형(단순 아이디어·자금·설비 제공)'과 화학발명의 실험 기여 기준을 인용하여 甲·乙·丙에 정확히 포섭
- **[+]** 제37조 제3항 → 제33조 제1항 본문 위반의 조문 연결관계를 논리적으로 서술하고, 이전청구 후에도 공동출원 위반(제44조)의 무효사유가 존속할 수 있음을 지적
- **[+]** 설문(2)에서 전합판례(실시권자의 이해관계 소멸 부정) 인용하여 유상 통상실시권자인 B사에도 이해관계 긍정 결론 도출
- **[+]** 조치별로 조문 근거 (§ 59·§ 63의2·§ 34·§ 35·§ 99의2·§ 103의2·§ 104①(3), 施則 § 26·§ 28 등) 명시
- **[+]** 무효심판의 청구인 적격이 '특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자'로 한정되고 지분만의 무효심판 청구가 불가함(2012후2432)을 지적
- **[-]** '무권리자 출원이므로 무효'라고만 쓰고 등록 전 단계 조치(정보제공·명의변경 등)를 누락하면 감점
- **[-]** 신규성 적용 법규정 (§ 29①(2)) 미인용, 결론 없이 절차만 나열 시 감점

- [-] 특허취소신청 기간을 '등록공고일부터 6개월'로 잘못 기재한 경우 감점(정확한 문언: **설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지** — § 132의2①)

감점 주의

- 발명자란에 기재된 대로 甲·丙을 발명자로 단정하여 답안 전체 방향을 잘못 잡는 경우(발명자 판단은 실질적으로 하는 것임을 농침)
- 공동발명자 판단만 길게 쓰고 정작 '조치' 부분을 소홀히 하는 경우(설문이 '조치'를 묻고 있음)
- 제37조 제3항 위반과 제44조 위반, 제33조 제1항 본문 위반의 조문 관계를 혼동
- 설문(2)에서 '실시권자는 특허권자의 대항을 받지 않으므로 이해관계 없다'는 종전 판례만 언급하고 전합판례(2017후2819 등)를 놓치는 경우
- 설문(2)에서 무효심판만 언급하고 취소신청(§ 132의2) 가능성을 부기하지 않은 경우(가점 요소 상실). 취소신청과 무효심판은 일사부재리가 적용되지 않아 병용 가능함을 지적하면 가점
- 설문(2)에서 특허취소신청 기간의 시기(始期)를 '등록공고일'로 잘못 특정한 경우(정확한 시기는 '설정등록일', 종기는 '등록공고일 후 6개월이 되는 날')
- 발명자 오기재 자체는 거절·무효사유가 아님을 밝히지 않은 채 발명자 정정을 조치로 나열하는 경우
- 각 조치의 한계(丙의 협력 곤란, 선의 A사의 법정실시권 § 103의2·§ 104①(3), 乙 지분만 이전 시 § 44 무효사유 잔존)를 전혀 언급하지 않고 조치만 나열한 경우

PART 17

2026

제1문	구성요소완비의 원칙에 의한 문언침해와 재판상 자백의 성부 · 무효사유 명백성에 기한 권리남용 항변(2010다95390)	30점
제2문	신규성 일반론(§29①(1)·(2)) · 사실관계 가나 포섭	20점
제3문	정정의 적법성 (§136①·④) · §42③·④ 기재요건	30점
제4문	공지예외 요건(§30①·②) 및 12개월 요건 검토 · 2025.1.10. X 공개에 대한 공지예외 적용 여부	20점

2026년 제1문

사례형

30점

문제

甲과 乙은 모두 이차전지용 장치 및 장비와 관련된 주식회사이다. 甲은 '구성 A+B+C로 이루어진 이차전지용 극판 스택킹(stack) 장치'에 대한 특허권자로서, 구성 A+B+C로 이루어진 이차전지용 극판 스택킹 장치가 포함된 이차전지용 노칭(notching)장비를 생산·판매하고 있는 乙을 상대로 2025. 2. 1. 특허권 침해금지 및 손해배상 청구의 소를 제기하였다.

소송 중 乙은 "乙의 이차전지용 노칭장비에 포함된 이차전지용 극판 스택킹 장치는 구성 A+B+C로 이루어졌고, 甲의 특허발명은 특허법 제29조 제2항의 진보성이 인정된다"고 법정에서 진술하였다가 나중에 부인하면서 다투었다. 한편 甲의 특허발명의 출원 전에 丙의 논문(인용발명 1)에 구성 A+B가 개시되어 있고 丁의 논문(인용발명 2)에 구성 C'가 개시되어 있으나, 인용발명 1, 2를 결합하여 甲의 특허발명에 이르기 위해서는 인용발명들의 내용을 상당히 변경하여야 한다. 또한 통상의 기술자라면 그 출원 당시의 기술수준에 비추어 필연적으로 甲의 특허발명과 인용발명 1, 2의 차이를 극복하여 甲의 특허발명을 생각해내기에 이를 것이라는 사정을 인정할만한 자료가 없다. 한편 甲의 특허발명이 출원공개된 후 현재는 구성 A+B+C는 통상의 기술자가 누구라도 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인식되어 있다.

(1) 甲의 乙에 대한 특허권 침해금지 청구에 관하여, 甲의 주장 및 乙의 주장을 예상하고 이들을 검토한 후, 종합적인 결론을 논하시오. (10점)

(2) 甲의 乙에 대한 손해배상 청구에 관하여, 침해기간 동안 발생한 아래 기재된 각 내용들을 고려하여 다음 물음에 답하시오. (아래 기재된 각 내용들은 甲 또는 乙의 주장으로 사용할 수 있고, 그에 대한 검토에 사용할 수 있음.) (20점)

[아래]

- 乙의 이차전지용 노칭장비는, 극판 스택킹 장치(이하, '침해제품') 이외에도 커팅 장치, 클리닝 장치, 비전검사 장치가 각 1대씩 결합하여 구성되어 있다.
- 甲과 乙은 서로 경영관계에 있다.
- 甲은 판매량 일실에 대한 상당한 금액의 손해를 입었다는 자료가 있다.
- 甲의 특허발명은 乙의 이차전지용 노칭장비의 판매량 향상에 상당한 기여를 한 것으로 인정된다.
- 甲은 乙의 이차전지용 노칭장비의 등장 이후 판매가격 하락에 대한 1억원의 손해를 입었다는 자료가 있다.
- 乙은 이차전지용 노칭장비에 관한 다수의 특허를 보유하고 있고, 관련 기술에 대한 표창 수상 이력이 있다.
- 甲의 기존인력과 유휴인력을 전부 동원하여 작업할 수 있는 특허제품의 최대 생산가능 수량은 1,000대라는 자료가 있다.
- 甲은 특허제품을 500대 판매하였다는 자료가 있다. (가격: 150만원/대, 이익액: 100만원/대)
- 乙은 이차전지용 노칭장비를 400대 판매하였다는 자료가 있다. (이 중 침해제품의 가격: 100만원/대, 이익액: 50만원/대)
- 甲은 乙의 침해행위 이외의 사유로 甲의 특허제품을 판매할 수 없었던 사정은 없다.
- 甲의 최대 생산가능 수량을 산정할 때 계산된 甲의 유휴인력의 작업 가능시간은 해당 인력이 해야 하는 특허제품에 관한 작업 수행과 여러 다른 작업 수행 시간을 합한 것이며, 실제 작업 수행 시간의 비율은 객관적으로 계산하기 어렵다.
- 乙의 해당 이익액을 산정할 때 乙의 회계부서는 원가(비용) 계정을 침해제품 이외에도 여러 다른 제품에 대한 원가(비용)까지 혼재하여 관리하고 있으며, 침해제품에만 특정하여 식별 및 계산하는 것이 구조적으로 불가능하다.
- X 협회에서 전문조사기관(M)에 의뢰하여 조사한 甲의 특허발명에 대한 해당 업계의 합리적 실시료율은 매출액의 40%라는 공식 보고서가 존재한다.
- Y 협회에서 전문조사기관(N)에 의뢰하여 조사한 甲의 특허발명에 대한 해당 업계의 합리적 실시료율은 매출액의 10%라는 공식 보고서가 존재한다.
- 甲과 乙이 제출한 증거 조사의 결과 및 변론 전체의 취지에 비추어 乙의 이차전지용 노칭장비의 매출액은 20억원, 한계이익율은 15% 정도로 인정된다.
- 乙의 이차전지용 노칭장비 전체 구성 중 甲의 특허발명의 구성이 차지하는 기술적 기여도를 포함하여 甲의 특허발명의 실시가 乙의 이차전지용 노칭장비의 매출액에 미친 영향은 甲은 60%를 주장하고 乙은 20%를 주장하므로, 그 평균 정도로 산정함이 적절하다.
- 乙은 甲이 소를 제기하기 전에 甲으로부터 특허권 침해행위를 중지하라는 경고장을 받은 적이 없다.
- 乙은 甲과 동업 또는 하도급 등 특별한 거래관계가 아니다.

1. 甲의 판매량 일실 및 판매가격 하락에 대하여 乙의 손해배상책임의 발생 여부에 관하여 논하시오.

2. 아래 각 조항별로 특징을 설명하고 甲의 주장 및 乙의 주장을 예상하고 이들을 검토한 후, 乙의 손해배상의 범위에 관하여 종합적인 결론을 논하시오.

① 특허법 제128조 제2항

② 특허법 제128조 제4항

③ 특허법 제128조 제5항

④ 특허법 제128조 제7항

⑤ 특허법 제128조 제8항

모범답안

I. 설문 (1) — 침해금지청구에 관한 쌍방 주장과 검토 (10점)

1. 문제의 소재

번복된 乙의 법정 진술에 재판상 자백이 성립하는지, 출원공개 후 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인식되었다는 사정을 들어 무효사유가 명백함을 이유로 한 권리남용의 항변이 성립하는지가 문제된다.

2. 甲의 주장

(1) 구성요소완비의 원칙에 의한 문언침해

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정하여지고(§ 97), 청구항에 기재된 구성요소 전부를 실시하여야 그 보호범위에 속한다(구성요소완비의 원칙). 침해품은 구성요소 A, B, C 전부를 그 유기적 결합관계를 유지한 채 그대로 구비하고 있으므로 문언침해가 성립한다. 침해품이 노칭장비의 일부라는 사정은 구성요소의 부가에 불과하다.

(2) 재판상 자백에 의한 뒷받침

乙이 침해품은 구성 A+B+C로 이루어졌다고 한 진술은 제품이 어떤 구성요소를 가지고 있는지에 관한 사실의 진술로서 재판상 자백이 성립한다. 자백한 사실은 증명을 요하지 아니하고, 진실에 어긋나는 자백도 착오로 말미암은 것임을 증명하여야 취소할 수 있다(민사소송법 제288조).

(3) 진보성의 인정

인용발명 1과 2를 결합하여 특허발명에 이르려면 그 내용을 상당히 변경하여야 하므로 결합의 곤란성이 인정되어 진보성이 부정되지 아니한다.

3. 乙의 주장

(1) 자백의 부정 — 법적 평가에 관한 진술

위 진술은 침해품의 구성이 甲의 특허발명의 구성요소와 동일하다는 취지로서 법적 판단 내지 평가에 관한 것이므로 자백의 대상이 될 수 없고, 진보성이 인정된다는 진술도 마찬가지로 반복하여 다룰 수 있다.

(2) 권리남용의 항변

현재 구성 A+B+C는 누구라도 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인식되어 진보성이 부정되므로, 무효로 될 것이 명백한 특허권에 기초한 침해금지청구는 권리남용에 해당한다.

4. 검토

(1) 자백의 성부

자백의 대상은 사실이고, 법적 판단 내지 평가는 그 대상이 아니다(2000후1542). 어느 쪽인지는 진술의 내용과 경위, 변론의 진행 경과 등을 종합하여 판단한다. 판례는 침해제품이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 침해판단의 전제가 되는 주요사실로서 자백의 대상이 되는 반면, 그 구성요소가 특허발명의 구성요소와 동일 또는 균등하다는 것은 법적 평가에 관한 진술이라고 한다(2019다277751, 2026다202753). 사안에서 구성 A+B+C로 이루어졌다는 부분은 제품 자체의 구성에 관한 사실의 진술이므로 자백이 성립하고, 취소사유도 없으므로 법원은 이에 구속된다. 반면 특허발명과 동일하다는 부분과 진보성이 인정된다는 부분은 법적 평가여서 자백이 성립하지 아니하므로 乙은 이를 다룰 수 있다.

(2) 침해의 성부

다만 자백으로 확정된 구성 A+B+C는 특허발명의 구성요소 전부를 일체성을 유지한 채 포함하므로, 동일 여부를 법원이 스스로 평가하더라도 문언침해라는 결론은 같다.

(3) 진보성의 판단

진보성은 출원 당시를 기준으로 판단하여야 하고, 특허발명의 내용을 알고 난 뒤의 지식으로 쉽다고 하는 사후적 고찰은 허용되지 아니한다(2007후3660). 사안에서는 결합에 상당한 변경이 필요하고 출원 당시 그 차이를 극복하리라고 볼 자료도 없으므로 곤란성이 인정된다. 현재 용이하게 인식된다는 사정은 출원공개로 공중에 알려진 결과일 수 있으므로 진보성 부정의 근거가 될 수 없다.

(4) 권리남용 항변의 성부

판례는 무효사유가 명백한 특허권에 기초한 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하고, 침해소송 법원도 무효심결 확정 전에 그 당부를 심리할 수 있다고 한다(2010다95390 전원합의체). 그러나 진보성이 인정되는 이상 무효사유가 명백하지 아니하다.

5. 결론

침해품은 구성요소 전부를 구비하여 보호범위에 속하고 진보성도 부정되지 아니하므로, 권리남용의 항변은 이유 없고 甲의 침해금지청구는 인용된다(§ 126①).

II. 설문 (2) — 손해배상 (20점)

1. 손해배상책임의 발생

(1) 요건

특허권 침해로 인한 손해배상책임이 성립하려면 i) 침해행위, ii) 침해자의 고의 또는 과실, iii) 손해의 발생, iv) 침해와 손해 사이의 인과관계가 있어야 한다(§ 128①). 침해자의 과실은 추정된다(§ 130).

(2) 사안의 포섭

침해는 설문 (1)에서 본 바와 같이 성립하고, 乙이 과실의 추정을 반복할 자료는 없다. 甲과 乙은 영업관계에 있고 甲에게 판매량 일실의 손해가 있다는 자료가 있으며 특허발명이 乙 장비의 판매량 향상에 상당히 기여하였으므로, 판매량 일실과 침해 사이의 인과관계가 인정된다. 반면 판매가격 하락 1억원은 乙의 장비가 등장한 뒤에 생겼다는 선후만 제시되어 있을 뿐, 그 하락이 영업상의 사정이나 시장경쟁이 아니라 침해행위로 말미암은 것임을 인정할 자료가 없다. 가격 인하로 인한 손해는 제2항부터 제5항까지가 예정한 유형이 아니어서 제1항의 일반 법리에 따르고 그 인과관계는 甲이 증명하여야 하므로, 상당 인과관계를 인정하기 어렵다.

(3) 결론

판매량 일실에 관하여는 乙의 손해배상책임이 발생한다. 판매가격 하락 1억원은 침해행위와의 상당인과관계가 증명되지 아니하므로 배상범위에서 제외한다.

2. 각 조항의 특징과 손해배상의 범위

(1) 제128조 제2항

① **(특징)** 제1호는 침해품의 양도수량(침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량은 뺀다) 중 특허권자의 생산가능수량에서 실제 판매수량을 뺀 한도 내의 수량에 특허권자의 단위수량당 이익액을 곱한 금액이고, 제2호는 그 한도를 넘는 수량 등에 대한 합리적 실시료로서, 양자의 합계액을 손해액으로 한다.

② **(甲의 주장)** 공제할 사정이 없어 양도수량은 400대이고, 한도는 1,000대에서 500대를 뺀 500대이다. 400대가 한도 이내이므로 단위수량당 이익액 100만원을 곱한 4억원이 제1호의 금액이다.

③ **(乙의 주장)** 최대 생산가능 수량의 산정에 쓰인 유희인력의 작업시간에는 특허제품 외의 작업시간이 섞여 있고 그 비율을 객관적으로 계산할 수 없으므로 1,000대를 그대로 인정할 수 없다. 또한 침해품은 노칭장비의 일부에 지나지 아니하므로 기여도를 반영하여야 한다.

④ **(검토)** 제1호의 한도가 되는 「생산할 수 있었던 물건의 수량」은 甲이 내세우는 1,000대에서 나오는데, 그 산정에 쓰인 유희인력의 작업 가능시간에는 특허제품 외의 작업시간이 섞여 있고 그 비율을 객관적으로 계산할 수 없다. 그렇다면 1,000대를 그대로 인정하여 한도를 500대로 확정하기 어렵고, 달리 400대의 추가 생산이 가능하였다고 볼 자료도 없다. 한편 사안의 기여도는 乙의 노칭장비 매출액에 미친 영향이어서 제1호에 곱할 것이 아니고, 공제할 수량이 없어 제2호가 정한 수량도 없다. 따라서 제2항으로 산정하기는 곤란하고 이 부분은 제7항의 문제로 넘어간다.

(2) 제128조 제4항

① **(특징)** 침해자가 침해행위로 얻은 이익액을 특허권자의 손해액으로 추정한다. 침해품이 완성품의 일부인 경우에는 그 특허가 구매동기를 유발한 정도를 기여율로 평가하여 이를 곱한 금액을 손해액으로 하고, 기여율을 다투는 사정은 침해자가 증명하여야 한다(2018나1893).

② **(甲의 주장)** 乙은 침해품 400대에 대당 이익 50만원을 곱한 2억원의 이익을 얻었고, 특허발명이 노칭장비의 매출액에 미친 영향은 60퍼센트이므로, 이를 곱한 1억 2천만원이 손해액으로 추정된다.

③ **(乙의 주장)** 침해품은 커팅·클리닝·비전검사 장치와 결합된 노칭장비의 한 구성에 지나지 아니하므로 기여율을 반영하여야 하고, 그 비율은 20퍼센트가 타당하다.

④ **(검토)** 기여율은 甲이 주장하는 60퍼센트와 乙이 주장하는 20퍼센트의 평균인 40퍼센트로 봄이 상당하므로, 2억원에 이를 곱한 8천만원이 된다. 다만 乙의 원가 계정이 다른 제품과 혼재되어 침해품만의 원가를 특정하는 것이 구조적으로 불가능한 이상 대당 이익 50만원 자체의 증명이 곤란하므로, 이 부분은 제7항의 문제로 넘어간다.

(3) 제128조 제5항

① **(특징)** 합리적으로 받을 수 있는 금액을 손해액으로 청구할 수 있다. 실시계약 기회의 상실에 대한 보상으로서 손해의 하한액이고, 스스로 실시하지 아니하여도 적용된다. 초과액도 청구할 수 있으나 고의·중과실이 없으면 법원이 참작할 수 있다(§ 128⑥).

② **(甲의 주장)** 실시료의 기초가 되는 매출액은 침해품 400대에 해당 가격 100만원을 곱한 4억원이고, X 협회 보고서의 40퍼센트를 적용하면 1억 6천만원이다.

③ **(乙의 주장)** Y 협회 보고서의 10퍼센트가 타당하므로 4천만원이다.

④ **(검토)** 실시료는 특허발명이 구현된 침해품의 매출액을 기초로 하여야 하므로 4억원이 기준이 된다. 두 보고서 모두 전문조사기관의 것이나, 40퍼센트를 적용하면 해당 실시료가 40만원이 되어 해당 이익 50만원의 대부분을 잠식하므로 실시권 설정이 성립할 수 있는 수준이라고 보기 어렵다. 따라서 10퍼센트를 취하여 4천만원으로 봄이 상당하다.

(4) 제128조 제7항

① **(특징)** 손해의 발생은 인정되나 그 액수의 증명이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. 이는 증명도를 경감한 것일 뿐 법원에 자유재량을 준 것이 아니다(2010다58728, 2018나1275).

② **(甲의 주장)** 유희인력의 작업시간 비율과 원가 혼재로 해당 이익액을 특정할 수 없어 액수의 증명이 극히 곤란하고, 기여율은 60퍼센트이다.

③ **(乙의 주장)** 이 항은 증명도를 경감한 것일 뿐이므로 객관적으로 수긍할 수 있는 금액만 인정될 수 있고, 기여율은 20퍼센트에 그친다.

④ **(검토)** 유희인력의 작업시간 비율과 침해품 해당 이익액은 모두 그 성질상 증명이 극히 곤란하므로 이 항이 적용된다. 법원은 간접사실을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 금액을 산정하여야 하는바, 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 비추어 乙의 노칭장비 매출액 20억원과 한계이익률 15퍼센트가 인정되므로, 그 한계이익 3억원에 쌍방 주장의 평균인 기여율 40퍼센트를 곱한 1억 2천만원을 제4항에 갈음하는 상당한 손해액으로 인정할 수 있다.

(5) 제128조 제8항

① **(특징)** 침해가 고의적이면 제2항부터 제7항까지에 따라 인정된 금액의 5배 이내에서 배상액을 정할 수 있고, 침해자의 우월적 지위·고의의 정도·피해규모·취득 이익·침해 기간·재산상태·피해구제 노력 등을 고려한다(§ 128⑨).

② **(甲의 주장)** 乙은 영업관계에 있으면서 침해품으로 장비의 판매량을 높여 이익을 얻었으므로 고의가 인정된다.

③ **(乙의 주장)** 소 제기 전에 경고장을 받은 적이 없고, 노칭장비에 관한 다수의 특허와 표창 수상 이력을 가진 기술력을 갖추고 있으며, 甲과 특별한 거래관계도 없으므로 甲의 특허권을 알고 침해하였다고 볼 수 없다.

④ **(검토)** 제130조는 과실을 추정할 뿐이고 이 항은 고의를 요구한다. 경고장을 받은 바 없고 독자적인 기술개발을 뒷받침하는 사정이 있으며 특별한 거래관계도 없는 이상 고의를 인정하기 어려우므로, 증액배상은 인정되지 아니한다.

(6) 종합적 결론

제2항·제4항·제5항은 선택적으로 주장할 수 있으나, 제2항은 생산가능수량의 한도를, 제4항은 해당 이익액을 각 확정할 수 없어 그대로 적용하기 곤란하고 제5항은 4천만원에 그친다. 손해의 발생은 인정되나 액수의 증명이 극히 곤란하므로 제7항에 따라 매출액 20억원에 한계이익률 15퍼센트와 기여율 40퍼센트를 곱한 1억 2천만원을 상당한 손해액으로 인정한다. 이는 제5항의 금액을 넘으므로 배상범위는 1억 2천만원이고, 판매가격 하락 1억원은 상당인과관계가 증명되지 아니하여 더하지 아니한다. 고의가 인정되지 아니하므로 제8항의 증액배상도 인정되지 아니한다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	득점 포인트
설문 (1) 구성요소완비의 원칙에 의한 문언침해와 재판상 자백의 성부	3점	청구항 구성요소 전부를 일체성 유지한 채 구비 → 문언침해(§97). 제품이 어떤 구성요소를 가지는지=사실(자백 대상), 특허발명과의 동일 여부·진보성=법적 평가(자백 대상 아님)의 구별(2019다277751, 2026다202753), 취소요건 (민사소송법 제288조)
설문 (1) 무효사유 명백성에 기한 권리남용 항변(2010다95390)	5점	진보성 판단의 사후적 고찰 금지, 결합의 곤란성·필연성 결여로 진보성 인정, 권리남용 불성립
설문 (1) 침해금지청구 인용 결론	2점	자백으로 확정된 구성이 구성요소 전부를 포함, 진보성 유효 → §126① 인용
설문 (2)-1 손해배상책임의 발생 (§128①)	3점	고의·과실, 위법·인과관계. 판매량 일실은 경업관계·기여 인정 침해 외 사유 부존재로 인과관계 인정. 가격하락은 §128① 일반 법리에 따라 특허권자가 인과관계를 증명하여야 하는데 '등장 이후'라는 선후만 제시됨 — 이를 논점으로 세웠는지 가 채점 대상(결론은 어느 쪽도 가점)
설문 (2)-2 ① §128② 특징·포섭	4점	1호 구조(양도수량 400대, 공제 0, 단위이익 100만원)를 계산 과정으로 제시하되, 한도의 기초인 1,000대는 유희인력 작업시간 비율을 계산할 수 없어 그대로 인정하기 어렵다는 점까지 논증 → 제2항 적용 곤란(§7로 이행). 기여도를 제1호에 곱하지 아니함, 2호 해당 수량 부존재
설문 (2)-2 ② §128④ 특징·포섭	3점	침해자 이익 400대×50만원=2억원 추정, 완성품 일부 → 기여율 대립(甲 60%·乙 20%) → 평균 40%(2018나1893) → 8천만원, 원가 혼재로 해당 이익 자체의 증명 곤란 → §128⑦로 이행
설문 (2)-2 ③ §128⑤ 특징·포섭	3점	합리적으로 받을 수 있는 금액(하한액·실시 불요), 기초 매출액=침해품 400대×100만원=4억원, 40%는 해당 실시료 40만원이 해당 이익 50만원을 잠식하여 배척 → 10% 4천만원, §128⑥ 초과액 청구
설문 (2)-2 ④ §128⑦ 특징·포섭	2점	증명도 경감이지 자유재량 아님(2010다58728), 유희인력 비율·침해품 해당 이익의 증명 곤란에 적용, 매출 20억×한계이익률 15%×기여율 40% = 1억 2천만원을 §128④에 갈음
설문 (2)-2 ⑤ §128⑧ 특징·포섭	3점	고의 요건 판단(경고장 부존재·경업관계·자체 특허 보유), 5배 이내 증액 여부
종합적 결론(최대액 산정 방식)	2점	제2항~제5항의 선택적 관계와 제7항의 보충적 성격 을 밝히고, §2-§4의 증명 곤란 → §7(20억×15%×40%=1억 2천만원), §5(4천만원)와 비교하여 최종 배상범위를 1억 2천만원으로 결론

배점 합계: 30점

특별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- **득점 포인트:** (1)에서 구성요소완비의 원칙에 따른 문언침해, 자백의 대상이 되는 사실과 그렇지 아니한 법적 평가의 구별, 권리남용 항변(진보성 판단 사후적 고찰 금지)을 모두 포착. (2)에서 각 항의 요건·특징을 구별하여 사안의 특정 사실(유희인력 산정 곤란, 원가 혼재, 두 실시료 보고서, 기여도 대립, 경고장 부존재)을 각 조항에 정확히 대응시킴.
- **감점 포인트:** 진보성 사후적 고찰 금지를 놓치고 '현재 용이발명 가능'이라는 사실만으로 권리남용을 인정하는 답안. §128⑧ 고의성을 무비판적으로 인정. §128② 1호와 2호의 병합 구조를 설명하고도 사안에서 2호 해당 수량이 없어 0원이라는 결론을 내리지 아니함.

2) 목차·구성(25%)

- **득점 포인트:** 설문(1)-甲주장/乙주장/검토/결론, 설문(2)-1과 (2)-2를 명확히 분리하고 (2)-2는 5개 항을 소재목으로 구분하며 각 항 안에서 특징→甲·乙 주장→검토 순으로 서술. 배점(20점) 중 (2)-2에 지면을 집중.
- **감점 포인트:** §128 각 항의 조문 전사 나열, 사안 포섭 없이 일반론만 서술.

3) 답안 작성·논증(35%)

- **득점 포인트:** 조문→판례(2010다95390, 2018나1893, 2018나1275)→사안 포섭→결론의 흐름. 계산 근거를 수치로 제시(예: §128⑦은 매출 20억×한계이익률 15%×기여율 40%). 학설·판례가 갈리는 부분(권리남용 특별사정, 기여도 산정)에서 자기 입장 명시.
- **감점 포인트:** 계산 근거·기여도 반영 누락. 침해금지와 손해배상에서 진보성 심리가능 여부를 동일하게 취급.

감점 주의

- 발문의 '출원 전' 결합의 곤란성·필연성 자료 부존재를 놓치고, '현재 용이발명 가능'만으로 무효를 단정하는 오류(사후적 고찰 금지 위반).
- 재판상 자백을 '진보성 인정'이나 '특허발명과 동일하다'는 법적 평가에까지 확장 적용(평가는 자백의 대상이 아님).
- §128②의 손해액에 기여도를 곱하는 오류(기여도는 침해자의 이익을 기준으로 하는 §128④에서 문제 됨).
- §128② 1호의 '생산가능수량' 산정에서 유희인력 실제 작업시간 분리 불가 사정을 논하지 않고 한도 500대를 그대로 확정하는 답안.
- §128④의 '침해자 이익액'을 매출 그대로 잡거나 기여율 적용을 누락.

- 매출액 20억원·한계이익률 15퍼센트를 당사자의 주장 자료로 배치하는 오류(변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초한 § 128⑦의 법원 인정 자료).
- § 128⑤의 기초 매출액을 노칭장비 전체 매출 20억원으로 잡는 오류(실시료는 특허발명이 구현된 침해품의 매출 4억원 기준).
- § 128⑤의 두 실시료율 중 40%를 그대로 채택하거나 양자의 평균을 취하는 등 신빙성 심사 없이 결론.
- § 128⑧ 고의성 판단에서 경고장 부존재, 乙의 자체 특허·표창 보유(과실 항변 자료)를 언급하지 않고 5배 증액을 인정.
- '특허청'·'특허청구범위' 등 구용어 사용.

2026년 제2문

사례형

20점

문제

甲은 구성 A+B+C로 이루어진 특허발명 X의 특허권자로서, 동종업자인 乙과 특허법상 전용실시권 설정계약을 체결하였다. 다만, 乙은 이를 지식 재산처에 등록하지 않고 특허발명 X를 실시하고 있다. 한편 甲은 동종업자인 丙과 상호협력계약을 체결하였는데 여기에는 '甲의 허락 없이 특허 발명 X를 실시할 수 없다.'는 조항이 포함되어 있다.

최근 甲의 특허발명 X에 특허법 제29조 제1항의 신규성 위반의 무효 사유가 있다고 판단한 乙은 甲의 특허에 대하여 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였다. 甲의 특허발명 X의 출원 전에 발생한 아래 사실관계를 고려하여 다음 물음에 답하시오.

[사실관계]

가. 공지기술문헌 1에 구성 A+B가 개시되어 있고, 공지기술문헌 2에 구성 C가 개시되어 있음.

나. 공지기술문헌 3에 구성 A+B+C가 개시되어 있으나, 미완성발명으로 통상의 기술자에게 경험칙상 기술내용 파악이 용이하지 않음.

다. 구성 A+B+C로 이루어진 제품이 국가기록원 나라기록관에 설치되어 인도됨. 다만, 해당 장소는 외부인 누구나 마음대로 출입할 수 있는 곳이 아님.

라. 甲이 비밀유지계약이 체결된 OEM업체의 허가된 인원과 함께 구성 A+B+C로 이루어진 시제품의 시운전을 하였음.

(1) 특허법 제29조 제1항의 신규성에 관하여 설명하고, 乙이 청구한 심판의 결과를 논하시오. (13점)

(2) (별개의 사안임) 만약 甲의 특허가 무효심결 확정된 경우, 아래 소송의 결과를 논하시오. (7점)

1. 乙이 甲에 대하여, 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안에 甲이 이미 지급받은 특허실시료에 대한 부당이득반환청구의 소를 제기한 경우
2. 甲이 乙에 대하여, 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안에 乙이 아직 지급하지 않은 특허실시료에 대한 지급청구의 소를 제기한 경우
3. 甲이 丙에 대하여, 상호협력계약이 유효하게 존재하는 기간 동안에 丙이 특허발명 X를 실시하였다는 이유로 채무불이행에 따른 손해배상 청구의 소를 제기한 경우(소송 중 丙은 특허발명 X는 자유실시기술이라고 주장하였음.)

모범답안

I. 설문 (1) — 신규성과 무효심판의 결과 (13점)

1. 문제의 소재

乙이 청구한 등록무효심판에서 i) 전용실시권 설정등록을 마치지 아니한 乙에게 청구인적격이 있는지, ii) 사실관계 가부터 라까지의 사정이 각각 신규성 상실사유가 되어 특허발명 X에 제29조 제1항 위반의 무효사유가 있는지가 문제된다.

2. 청구인적격

무효심판은 이해관계인 또는 심판관이 청구할 수 있다(§ 133①). 전용실시권은 등록하여야 효력이 발생하므로(§ 101①(2)) 乙은 전용실시권을 취득하지 못하고 계약의 채권적 효력에 따라 실시할 수 있을 뿐이다. 그러나 이해관계인이란 특허발명의 권리존속으로 법률상 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 직접적·현실적 이해관계를 가진 사람을 말하고 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함되며, 실시권자라는 이유만으로 그 이해관계가 소멸된다고 볼 수 없다(2017후2819 전원합의체). 乙은 X를 실시하는 동종업자이므로 청구인적격이 인정된다.

3. 신규성

(1) 의의와 취지

신규성이란 발명의 내용이 사회 일반에 아직 알려지지 아니한 것을 말한다. 특허법은 신규한 발명을 공개한 자에게만 공개의 대가로 특허권을 부여하고 공개된 기술을 이용하여 산업발전에 이바지하기 위하여 이를 특허요건으로 정하면서, 상실사유를 제한적으로 열거하여 객관성을 확보하고 있다.

(2) 상실사유

i) 공지란 불특정인이 알 수 있는 상태에 놓인 것을 말한다. 불특정인이란 비밀유지의무가 없는 자를 뜻하므로 한 사람에게라도 비밀상태가 해제되면 공지이나, 다수인이라도 모두 비밀유지의무를 부담하면 공지가 아니다. 알 수 있는 상태로 족하고 현실의 인식은 요하지 아니한다. ii) 공연실시란 실시 의

하여 발명이 불특정인에게 알려지거나 알려질 수 있는 상태에 놓인 것을 말한다(§ 29①(1)). iii) 그 밖에 반포된 간행물에 게재되거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 발명도 신규성을 상실한다(§ 29①(2)).

(3) 판단기준

출원 시를 기준으로 국내·국외를 묻지 아니하고, 청구항에 기재된 발명을 하나의 인용발명과 개별적으로 대비하여 동일성 여부로 판단한다. 복수의 인용발명을 결합하여 대비하는 것은 진보성의 영역이다. 공지 또는 공연실시의 사실은 무효를 주장하는 자가, 비밀유지의무의 존재는 이를 다투는 특허권자가 각 주장·증명하여야 한다.

(4) 미완성발명의 인용례 적격

판례는 신규성 판단에 제정되는 인용발명은 기술적 구성요소 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라 미완성발명이나 자료의 부족으로 표현이 불충분한 것이라도 통상의 기술자가 경험칙에 의하여 극히 쉽게 기술내용을 파악할 수 있으면 그 대상이 될 수 있다고 한다(98후270). 미완성발명이라는 이유만으로 인용례에서 배제되는 것이 아니라 기술내용의 파악 가능성이 기준이 된다.

4. 사안의 포섭

(1) 사실관계 가 — 문헌1(A+B)과 문헌2(C)

어느 문헌도 단독으로는 A+B+C를 모두 개시하지 못한다. 두 문헌을 결합하여야 비로소 X에 이르는데 이는 진보성의 문제이므로 신규성은 부정되지 아니한다.

(2) 사실관계 나 — 문헌3(A+B+C, 미완성발명)

문헌3에는 A+B+C가 모두 개시되어 있으나, 미완성발명으로서 통상의 기술자가 경험칙상 기술내용을 파악하기 용이하지 아니하다. 위 법리에 비추어 인용발명이 될 수 없으므로 신규성이 부정되지 아니한다.

(3) 사실관계 다 — 나라기록관 설치·인도

해당 장소가 외부인 누구나 마음대로 출입할 수 있는 곳이 아니라는 사정만으로 달리 볼 것은 아니다. 그곳의 직원들이 비밀유지의무를 부담한다는 점은 이를 다투는 甲이 증명하여야 하는데 그러한 사정이 보이지 아니하는 이상 그들은 불특정인이고, 제품이 설치·인도된 것만으로 A+B+C는 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓였다(2011후4011). 따라서 X는 출원 전에 공지되었다(§ 29①(1)).

(4) 사실관계 라 — 시제품 시운전

비밀유지계약이 체결된 OEM업체의 허가된 인원은 계약상 비밀유지의무를 부담하는 자이므로 불특정인이 아니다. 따라서 그들과 함께 한 시운전만으로는 공지·공연실시에 해당하지 아니한다.

5. 결론

사실관계 가·나·라는 신규성 상실사유가 되지 못하나, 다의 설치·인도로 X는 출원 전에 공지되어 제29조 제1항 제1호 위반의 무효사유가 있다(§ 133①(1)). 따라서 乙의 무효심판 청구는 인용된다.

II. 설문 (2) — 무효심결 확정과 각 소송의 결과 (7점)

1. 문제의 소재

무효심결이 확정되면 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보는데(§ 133③), 그 소급효가 특허발명 실시계약과 실시금지계약에 어떠한 영향을 미치는지가 문제된다.

2. 공통 법리

실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 실시에 대하여 침해로 인한 손해배상이나 금지를 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라, 무효로 확정되기 전에는 특허권의 독점·배타적 효력에 의하여 제3자의 실시가 금지되는 이익이 있다. 따라서 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 실시계약이 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수 없고, 다만 무효가 확정된 때부터 이행불능 상태에 빠질 뿐이다(2012다42666). 특허권자와 제3자 사이의 실시금지계약에도 같은 법리가 적용된다(2024다270105).

3. 소송 1) — 기지급 실시료의 부당이득반환청구

실시계약이 원시적으로 이행불능이었다거나 계약 자체에 별도의 무효사유가 있는 것이 아닌 이상, 甲이 이미 지급받은 실시료 중 계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 부당이득으로 반환할 의무는 없다(2012다42666). 乙이 설정등록을 마치지 아니하여 전용실시권을 취득하지 못하였더라도 계약의 채권적 효력에 따라 실시할 수 있었던 이상 달리 볼 것이 아니다. 따라서 乙의 청구는 기각된다.

4. 소송 2) — 미지급 실시료의 지급청구

같은 법리에 따라 계약이 유효하게 존재하는 기간의 실시료 지급의무는 소멸하지 아니하므로, 특허권자는 무효심결이 확정되더라도 그 기간의 실시료 지급을 청구할 수 있다(2018다287362). 따라서 甲의 청구는 인용된다.

5. 소송 3) — 채무불이행 손해배상청구

상호협력계약의 甲의 허락 없이 X를 실시할 수 없다는 조항은 실시금지계약으로서, 특허가 무효로 확정된 때부터 이행불능에 빠질 뿐이므로 그 전에 계약이 유효하게 존재하던 기간에 이를 위반한 丙은 채무불이행책임을 진다. 한편 자유실시기술의 항변은 특허발명과 대비되는 발명이 공지기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우 특허발명과 대비할 필요 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다는 것으로서(99후710), 특허권의 효력이 자유기술의 영역까지 미치는 것을 제한하기 위한 것이다. 따라서 丙이 실시한 구체적인 형태가 자유실시기술에 해당한다고 하더라도, 그러한 사정만으로 당사자의 의사 합치에 따른 실시금지계약의 구속력에서 벗어난다고 볼 수 없다(2024다270105). 그러므로 甲의 청구는 인용된다.

6. 결론

소송 1)은 기각되고, 소송 2)와 소송 3)은 인용된다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특점 포인트
설문 (1) — 신규성 일반론 (§29①(1)·(2))	3	공지·공연실시·간행물 게재·전기통신회선 이용가능 개념, 판단 기준(출원 시), 신규성 판단방법(청구항별 전체 대비)
설문 (1) — 사실관계 가나 포섭	3	문헌1(A+B)·문헌2(C)로는 신규성 부정 불가(별개 문헌 결합은 진보성 문제), 문헌3은 미완성발명도 공지기술의 지위가 인정되나 통상의 기술자가 경험칙에 의하여 극히 쉽게 기술내용을 파악할 수 있어야 한다는 법리(98후270)를 전제로, 사안은 파악이 용이하지 아니하여 인용례가 될 수 없음
설문 (1) — 사실관계 다라 포섭(공지·공연실시 여부)	3	나라기록관 설치·인도: 외부인 자유출입 불가는 달리 볼 사정이 아니고, 비밀유지의무의 존재는 이를 다투는 특허권자가 증명하여야 하는데 그러한 사정이 없어 직원들은 불특정인 → 공지 성립(2011후4011) → 신규성 부정. OEM 시운전: 비밀유지의무자와의 시운전 → 공지·공연실시 불성립
설문 (1) — 청구인적격과 심판 결과	2	이해관계인 요건 충족(동종업자·실시자 — 2017후2819 전합), 결론적으로 사실관계 다의 공지에 의한 §29①(1) 위반의 무효사유 존재 → 심판청구 인용(특허 무효)
전용실시권 미등록의 효과	2	등록이 효력발생요건(§101①(2))이며서 乙은 전용실시권을 취득하지 못하고 계약의 채권적 효력에 따라 실시할 수 있을 뿐이나, 이해관계인 여부와는 별개
설문 (2)-1) 기지급 실시료 부당이득반환	2.5	무효심결 확정(§133③)에도 불구하고, 실시계약이 원시적·객관적 불능이 아니어서 계약은 유효하게 존속, 기지급 실시료는 부당이득 불성립(대법원 2012다42666·42673 법리) → 청구 기각
설문 (2)-2) 미지급 실시료 지급청구	2	무효심결 확정 이후에는 계약 목적 달성 불능이나, 확정 전 유효 기간 동안의 실시료 지급의무는 존속 → 인용
설문 (2)-3) 丙에 대한 채무불이행 손해(자유실시기술 항변)	2.5	상호협력계약상 부작위의무 위반은 별개의 계약상 채무이며, 자유실시기술 항변의 의의(99후710)를 밝힌 뒤, 실시금지계약은 무효 확정 시부터 이행불능에 빠질 뿐이어서 그 전 기간의 위반에 대하여는 책임이 성립하고 자유실시기술이라는 사정만으로 계약의 구속력을 벗어나지 못함(2024다270105) → 인용

합계: 20점

특별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- (+) § 29 제1항 각호를 정확히 인용하고, 사실관계 가~라를 각각 독립된 인용례로 나누어 분석했는가.
- (+) 미완성발명도 공지기술의 지위가 인정되나 통상의 기술자가 경험칙에 의하여 극히 쉽게 기술내용을 파악할 수 있어야 한다는 기준(98후270)을 세우고, 사안이 그에 미치지 못함을 밝혔는가.
- (+) 공지·공연실시의 요건인 '불특정인이 알 수 있는 상태'와 '비밀유지의무'의 유무를 논점으로 포착하고, 비밀유지의무의 존재에 관한 증명책임이 특허권자에게 있음을 사실관계 다의 포섭에 활용했는가(2011후4011).
- (+) 설문 (2)에서 무효심결 확정(§ 133③)과 실시계약의 유효성이라는 대립축을 설정했는가.
- (+) 丙에 대한 청구가 특허권 침해가 아닌 '계약상 채무불이행'이라는 점, 자유실시기술 항변의 적용 국면을 구별했는가.
- (-) 문헌1·2를 결합하여 신규성 부정으로 단정하거나, 진보성(§ 29②) 쟁점을 신규성과 혼동한 서술.
- (-) 전용실시권 미등록 사유만으로 심판청구인적격을 부정한 결론.

2) 목차·구성(25%)

- (+) 설문 (1)에서 '신규성 일반론 → 사실관계 개별 검토 → 결론' 순의 체계.
- (+) 설문 (2)에서 세 개 소송을 각각 소제목으로 분리하고 청구원인·항변·결론을 병렬 배치.
- (+) 배점 비례(13:7)로 (1) 서술이 (2)보다 두드러짐 안배.
- (-) 신규성 일반론에 지면을 과도하게 할애하고 사안 포섭이 빈약한 경우.

3) 답안 작성·논증(35%)

- (+) 각 사실관계마다 조문 문언(공지·공연실시·간행물 게재)에 포섭한 근거 제시.
- (+) 미완성발명의 인용례 적격, 비밀유지의무자와 함께 한 실시가 공지·공연실시가 아니라는 법리를 판례에 근거하여 제시.
- (+) 설문 (2)-1), 2)에서 특허무효 소급효와 실시계약의 유효성의 조화(원시적 불능 아닌 후발적 사정)에 관한 법리를 판례(2012다42666·2018다287362)로 명확히 서술.
- (+) 설문 (2)-3)에서 자유실시기술 항변이 특허권 침해판단의 항변임을 명시하고, 계약상 채무불이행에는 적용되지 않으며 실시금지계약은 무효 확정 시부터 이행불능에 빠질 뿐임(2024다270105)을 논증.
- (-) 조문 나열·법전 전사, 사안 포섭 없이 학설만 나열, 결론과 이유의 모순.

감점 주의

- 별개의 공지기술문헌 두 개(문헌1·문헌2)를 결합하여 신규성 부정이라고 결론짓는 경우(→ 진보성 쟁점과 혼동).
- 미완성발명이라는 이유만으로 곧바로 § 29 제1항의 인용례가 될 수 없다고 단정하는 오류(기술내용의 파악 가능성이라는 기준을 세우지 아니한 경우).
- 나라기록관 설치·인도를 '외부인 자유출입 불가'만을 이유로 공지 부정(2011후4011 판시에 반하는 결론).
- 발문에 없는 '직원들이 비밀유지의무를 부담하지 아니한다'는 사실을 전제로 삼는 서술(증명책임 배분으로 논증하여야 함).
- OEM업체 시운전을 공연실시로 인정(비밀유지계약 존재를 간과).
- 전용실시권 미등록을 이유로 심판청구인적격 자체를 부정한 결론.
- 설문 (2)에서 특허무효 소급효(§ 133③)만을 들어 기지급 실시료의 부당이득반환을 인정한 결론(대법원 2012다42666 법리 반영 필요).
- 자유실시기술 항변을 계약상 채무불이행 소송에 그대로 적용한 결론.

2026년 제3문

사례형

30점

문제

甲은 '고혈압 치료용 복합제'에 관한 특허권자로서, 아래는 [발명의 설명]에 관한 주요 내용이다

[아래]

1. [R칼륨염]과 [활성성분 R]은 분자량이 달라 [R칼륨염] 33.2mg이 [활성성분 R] 30mg에 해당한다.
2. [S베실산염] 6.9mg이 [활성성분 S] 5mg에 해당한다.
3. 실시례는 [R칼륨염] 33.2mg, [S베실산염] 6.9mg 및 [P물질] 20mg을 사용한 하나뿐이다.
4. [P물질]이 10mg 미만이면 안정성이 저하되고, 50mg을 넘으면 용출률이 저하될 수 있다는 일반적 설명만 있을 뿐, [P물질] 10~50mg 전체 범위의 실험자료는 없다.
5. [P물질] 20mg 실시례에서는 두 활성성분의 병용으로 예상보다 우수한 혈압 강하 효과가 관찰되었다.

[청구범위]

청구항 1. [R칼륨염] 30mg, [S베실산염] 5mg 및 [P물질] 10~50mg을 포함하는 1일 1회 투여용 혈압 강하 조성물.

[선행발명 1]에는 [R칼륨염] 30mg과 [S베실산염] 5mg을 포함하는 복합제가 기재되어 있으나 [P물질]은 포함되어 있지 않다.

[선행발명 2]에는 [R칼륨염] 30mg과 [S베실산염] 5mg을 포함하는 복합제에서 용출 안정성을 높이기 위하여 [P물질] 10~50mg을 첨가할 수 있다고 기재되어 있다.

乙 주식회사가 이 사건 특허의 등록무효심판을 청구하자, 甲은 청구범위를 다음과 같이 정정 청구하였다.

[청구범위]

청구항 1. [R칼륨염] 30mg([활성성분 R]로서 30mg), [S베실산염] 5mg([활성성분 S]로서 5mg) 및 [P물질] 10~50mg을 포함하는 1일 1회 투여용 혈압강하 조성물.

위 지문을 토대로 다음 물음에 답하시오.

- (1) 甲의 정정이 적법한지 논하시오. (8점)
- (2) 위 (1)의 결과를 토대로 하여, <청구항 1>은 특허법 제42조 제3항과 제4항의 요건을 충족하는지 논하시오. (10점)
- (3) 위 (1)의 결과를 토대로 하여, <청구항 1>의 진보성이 인정되는지 논하시오. (12점)

모범답안

I. 설문 (1) — 정정의 적법성 (8점)

1. 문제의 소재

甲의 정정은 「R칼륨염 30mg」과 「S베실산염 5mg」 뒤에 각각 활성성분 환산량을 괄호로 부가하는 것이다. 이것이 제136조 제1항 각 호의 정정사유에 해당하는지, 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것은 아닌지가 문제된다.

2. 정정의 요건

정정은 i) 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 또는 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 중 어느 하나에 해당하여야 하고(§ 136①), ii) 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 하며(§ 136③), iii) 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다(§ 136④). 무효심판절차에서의 정정청구에도 위 요건이 준용된다(§ 133의2④).

「청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한다」란 청구범위에 적혀 있는 발명의 내용·범위·성질 등을 확장하거나 변경하여 정정 전후에 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이가 발생하는 것을 말하고, 그 해당 여부는 청구범위의 형식적 기재만이 아니라 명세서 전체의 내용과 관련하여 정정 전후의 청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단한다.

3. 청구범위의 해석

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정하여지므로(§ 97), 청구범위의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서 발명의 설명 등을 참작하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 의미를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다. 다만 발명의 설명 등을 참작하더라도 그 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 아니한다(2023후11487).

4. 사안의 포섭

(1) 정정사유 해당 여부

명세서의 R칼륨염 33.2mg이 활성성분 R 30mg에, S베실산염 6.9mg이 활성성분 S 5mg에 각 해당한다고 하여 양자를 구별하여 표시하고, 유일한 실시례도 염을 기준으로 33.2mg·6.9mg을 기재하고 있다. 이를 참작하면 원 청구항의 「R칼륨염 30mg」과 「S베실산염 5mg」은 염 자체의 중량을 가리키는 것이 분명하고 달리 해석할 여지가 없다. 따라서 분명하지 아니하게 기재된 사항이 아니어서 이를 명확하게 하는 경우(§ 136①(3))에 해당하지 아니하고, 오기를 바로잡는 것도 아니어서 잘못 기재된 사항의 정정(§ 136①(2))에도 해당하지 아니한다.

(2) 실질적 변경 해당 여부

정정 후 청구항은 활성성분 R로서 30mg을 요구하므로 염으로는 33.2mg이 되어야 하는 반면, 정정 전 청구항의 염 30mg은 활성성분으로 환산하면 약 27.1mg에 그친다. S성분도 5mg과 약 3.6mg의 차이가 있다. 즉 약리효과인 혈압강하 효과를 나타내는 활성성분의 용량이 정정 전후로 달라져 발명의 효과가 변경될 수 있고, 등록된 명세서를 신뢰한 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 있으므로 청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당한다(§ 136④).

5. 결론

甲의 정정청구는 제136조 제1항 각 호의 사유에 해당하지 아니하고 청구범위를 실질적으로 변경하는 것이어서 부적법하다. 따라서 이하의 무효사유는 정정 전 청구항을 기준으로 판단한다.

II. 설문 (2) — 제42조 제3항·제4항의 충족 여부 (10점)

1. 문제의 소재

정정이 부적법하므로 정정 전 청구항 1(「R칼륨염 30mg, S베실산염 5mg 및 P물질 10~50mg을 포함하는 1일 1회 투여용 혈압강하 조성물」)을 기준으로, 발명의 설명이 실시가능요건(§ 42③(1))을 갖추었는지와 청구범위가 뒷받침 요건 및 명확성 요건(§ 42④(1)(2))을 갖추었는지 문제된다. 두 요건은 서로 독립된 특허요건이므로 어느 하나의 위반이 곧 다른 하나의 위반이 되는 것은 아니고 각각의 판단법리에 따라 개별적으로 판단하여야 한다(2012후832).

2. 제42조 제3항 제1호 — 실시가능요건

(1) 적용 법규정 및 범위

발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다. 물건의 발명에서 실시란 그 물건을 생산·사용하는 행위를 말하므로, 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고 명세서의 기재에 의하여 물건 자체를 생산·사용할 수 있고, 구체적인 실험으로 증명되어 있지 아니하더라도 그 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있으면 이 요건을 충족한다(2014후2061). 수치로 한정된 물건의 발명에서 수치범위 전체를 보여주는 실시례까지 요구되는 것은 아니나, 명세서의 기재만으로 그 수치범위 전체에 걸쳐 물건을 생산하거나 사용할 수 없다면 이 요건을 충족하지 못한다(2013후518).

(2) 사안의 포섭

乙은 청구항의 조성을 그대로 갖는 실시례가 없고 10~50mg 전체 범위의 실험자료도 없어 재현이 불가능하다고 다룰 것이다. 그러나 명세서는 P물질이 10mg 미만이면 안정성이, 50mg을 넘으면 용출률이 각 저하된다는 이유를 밝히고 있어 그 사이의 값을 정하는 것은 통상적·반복적 실험으로 가능하고, 염의 함량을 30mg·5mg으로 조절하는 것에도 특별한 어려움이 없다. 또한 두 성분이 혈압강하 작용을 한다는 점은 선행발명 1에도 나타나 있어 효과의 발생 자체는 충분히 예측할 수 있다. 한편 효과의 정도가 미미한지는 진보성 판단의 영역이므로 이 요건의 위반사유가 되지 아니한다.

(3) 결론

제42조 제3항 제1호는 충족한다.

3. 제42조 제4항 제1호 — 뒷받침 요건

(1) 적용 법규정 및 범위

청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다. 이는 출원인이 공개하지 아니한 발명에까지 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위한 것으로서, 출원 당시의 기술수준을 기준으로 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지에 따라 판단한다(2012후832). 발명의 설명에 기재된 내용을 청구된 발명의 범위까지 확장하거나 일반화할 수 없는 경우에는 뒷받침된다고 할 수 없다.

(2) 사안의 포섭

i) 청구항의 「R칼륨염 30mg」·「S베실산염 5mg」에 대응되는 사항이 발명의 설명에 없다. 실시례는 33.2mg·6.9mg이고, 명세서는 오히려 그 수치가 활성성분 30mg·5mg에 해당한다고 하여 청구항의 염 기준 수치와 어긋난다. ii) P물질 10~50mg 중 실시례는 20mg 하나뿐이고, 하한과 상한을 벗어나면 안정성 또는 용출률이 저하된다는 일반적 설명만으로는 그 사이의 전 구간에서 청구된 조성물이 성립한다는 데까지 확장·일반화할 수 없다. iii) 명세서가 내세우는 예상보다 우수한 혈압강하 효과도 20mg 실시례에서만 확인된 것이어서 청구항 전 범위의 것으로 볼 수 없다.

(3) 결론

제42조 제4항 제1호를 충족하지 못한다.

4. 제42조 제4항 제2호 — 명확성 요건

청구항은 성분과 함량을 수치로, 투여용법을 「1일 1회 투여용」으로 각 특정하고 있어 통상의 기술자가 발명을 명확하게 파악할 수 있으므로 이 요건은 충족한다.

5. 결론

청구항 1은 제42조 제4항 제1호를 충족하지 못한다. 제42조 제3항 제1호와 제42조 제4항 제2호는 충족한다.

Ⅲ. 설문 (3) — 진보성 인정 여부 (12점)**1. 문제의 소재**

정정 전 청구항 1을 기준으로, i) 선행발명 1과 2의 결합으로 그 구성을 쉽게 도출할 수 있는지, ii) P물질 10~50mg이라는 수치한정에 임계적 의의가 있는지, iii) 「1일 1회 투여용」이 진보성에 기여하는 구성요소인지, iv) 병용에 따른 혈압강하 효과가 현저한지가 문제된다(§ 29②).

2. 진보성 판단의 법리**(1) 일반 법리**

통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있으면 진보성이 부정된다(§ 29②). 결합발명에서는 선행발명들을 결합할 동기 또는 암시가 있는지와 결합에 기술적 곤란성이 있는지를 살펴, 청구항 전체의 구성과 그로부터 얻어지는 효과를 종합하여 판단한다.

(2) 수치한정발명

선행발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로 한정하여 표현한 경우에는, 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어 수치한정이 보충적 사항에 불과한 것이 아닌 이상, 통상적이고 반복적인 실험으로 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정으로서 공지된 발명과 비교하여 이질적인 효과나 한정된 수치범위 내에서 현저한 효과의 차이가 생기지 아니하면 진보성이 부정된다(2022후10180, 2008후4998). 그 현저한 효과는 통상의 기술자가 명세서의 기재 자체로 인식할 수 있을 정도로 적혀 있어야 하고, 추후의 실험자료로 이를 보충할 수 없다.

(3) 투여용법·투여용량

의약이라는 물건의 발명에서 대상 질병 또는 약효와 함께 부가된 투여용법과 투여용량은 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 그 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다(2014후768 전원합의제).

3. 구성의 대비와 결합의 용이성

선행발명 1은 R칼슘염 30mg과 S베실산염 5mg의 복합제를, 선행발명 2는 같은 복합제에서 용출 안정성을 높이기 위하여 P물질 10~50mg을 첨가할 수 있음을 각 기재하고 있다. 청구항 1의 성분과 함량은 두 선행발명에 문언 그대로 개시되어 있다.

두 선행발명은 동일한 복합제를 대상으로 하고, 선행발명 2가 선행발명 1의 복합제에 P물질을 첨가하는 구성을 명시적으로 교시하고 있으므로 결합의 동기가 뚜렷하며 결합에 기술적 곤란성도 보이지 아니한다.

4. 수치한정의 임계적 의의

청구항의 10~50mg은 선행발명 2에 그대로 개시된 범위이므로 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 정도에 지나지 아니한다. 명세서에는 10mg 미만이면 안정성이, 50mg을 넘으면 용출률이 저하될 수 있다는 일반적 설명만 있을 뿐, 한정된 수치범위의 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다는 점을 통상의 기술자가 인식할 수 있을 정도의 기재가 없다. 따라서 이 수치한정에 임계적 의의를 인정할 수 없다.

5. 「1일 1회 투여용」의 평가

이 부분은 위 법리에 따라 조성물에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있고, 선행발명 1·2에 나타나 있지 아니하므로 구성상의 차이에 해당한다. 그러나 명세서에는 1일 1회 투여를 뒷받침하는 약동학적 자료나 복약 편의성·부작용 감소에 관한 기재가 없고, 유일한 실시례도 두 활성성분의 병용에 따른 혈압강하 효과를 보일 뿐 1일 1회 투여에 특유한 효과를 나타내지 아니한다. 그렇다면 이는 통상의 기술자가 복약 편의를 위하여 적절히 선택할 수 있는 사항에 지나지 아니하여 진보성에 기여한다고 보기 어렵다.

6. 효과의 현저성

甲은 20mg 실시례에서 두 활성성분의 병용으로 예상보다 우수한 혈압강하 효과가 관찰되었음을 들어 진보성을 주장할 것이다. 그러나 i) 그 효과는 R성분과 S성분의 병용에서 비롯된 것인데 두 성분의 복합제는 이미 선행발명 1에 개시되어 있고, ii) 위 효과는 P물질 20mg의 실시례 하나에서만 관찰된 것이어서 청구된 10~50mg 전 범위에 걸친 효과로 인식할 수 없다. 따라서 선행발명들로부터 예측되는 정도를 넘는 현저한 효과라고 보기 어렵다.

7. 결론

청구항 1의 구성은 선행발명 1과 2의 결합으로 쉽게 도출할 수 있고, 수치한정에 임계적 의의가 없으며 「1일 1회 투여용」도 적절히 선택할 수 있는 사항에 지나지 아니한다. 명세서가 개시하는 효과도 현저하다고 볼 수 없으므로 청구항 1의 진보성은 부정된다(§ 29②).

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	득점 포인트
설문 (1) 정정의 적법성 (§136①·④)	8	① 정정요건 3축(§136① 각 호 해당 / §136③ 기재범위 / §136④ 실질적 확장·변경) 정리 ② 청구범위 해석 법리(2023후11487)로 원 청구항의 「R칼륨염 30mg」이 염 자체의 중량임이 분명하여 달리 해석할 여지가 없음 → 석명사유(§136③(3)) 부해당 ③ 정정 전 활성성분 약 27.1mg ↔ 정정 후 30mg으로 약리효과 용량이 달라져 발명의 효과가 변경될 수 있음 → 실질적 변경(§136④) ④ 결론(부적법·정정 전 청구항 기준)
설문 (2) §42③·④ 기재요건	10	① 두 조항이 독립된 요건이어서 어느 하나의 위반이 곧 다른 하나의 위반이 아님(2012후832)을 전제로 규범 정리 ② §42③(1)은 수치범위 전체의 실시례까지 요구되지 아니하고(2013후518) 효과 발생의 예측 가능성으로 족하므로(2014후2061) 충족 ③ §42④(1)은 청구항 수치(30mg·5mg)에 대응하는 사항이 발명의 설명에 없고 20mg 단일 실시례를 10~50mg 전 구간으로 확장·일반화할 수 없어 위반 ④ §42④(2)는 충족
설문 (3) 진보성	12	① 선행발명 1+2 결합의 동기(선행발명 2가 용출 안정성을 위한 P물질 첨가를 명시)와 기술적 곤란성 부존재 ② 수치한정발명 법리(2022후10180, 2008후4998)로 10~50mg의 임계적 의의를 부정 — 상·하한 이탈 시의 일반적 설명만으로는 수치범위 내외의 현저한 효과 차이를 인식할 수 없음 ③ 「1일 1회 투여용」은 구성요소가 될 수 있으나(2014후768 전합) 이를 뒷받침하는 기재가 없어 적절히 선택할 수 있는 사항 ④ 20mg 단일 실시례의 상승효과는 선행발명 1의 병용에서 비롯된 것이고 전 범위의 현저효과로 볼 수 없음 ⑤ 결론(진보성 부정)

합계: 30점

특별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- **득점:** 정정 청구의 실체(염 기준 수치를 활성성분 환산 기준으로 바꾸는 것)를 정확히 포착하고, 원 청구항이 이미 명확하다는 점(석명사유 부해당)과 약리효과·용량의 변경(실질적 변경)을 순서대로 논증. § 42③(1)과 § 42④(1)을 별개 요건으로 분리 판단(2012후832). 수치범위 발명에서 실시례 지지 정도를 쟁점화.
- **감점:** 정정 3사유 중 어느 하나만 언급, § 42③과 § 42④ 혼동, 진보성 분석에서 선행발명 결합 용이성을 다루지 않고 현저효과만 논함, 단일 실시례로 수치범위 전체를 뒷받침하는지 문제를 놓친 경우.

2) 목차·구성(25%)

- **득점:** 설문별로 문제소재→법리→포섭→결론의 4단 구성, § 42③/§ 42④(1)/§ 42④(2)를 소목차로 분리, 진보성은 구성 대비→작용효과 순으로 배치. 배점(8/10/12) 비율에 맞춰 (3)에 가장 많이 지면 할애.
- **감점:** 총괄 결론 별도 항목 신설, 일반론(수치범위 발명 이론) 과잉 서술, (1) 답을 (2)·(3)의 전제로 활용하지 않은 경우.

3) 답안 작성·논증(35%)

- **득점:** § 136①·③·④, § 42③(1)·§ 42④(1)(2), § 29②의 각 조문 명시. 2023후11487(청구범위 해석), 2012후832(기재요건의 독립성), 2013후518·2014후2061(실시가능요건), 2022후10180(수치한정발명 진보성), 2014후768 전원합의체(투여용법·용량의 구성요소성)를 사안에 포섭. 환산 수치를 계산하여 제시.
- **감점:** 조문 전사, 판례 요지 나열 후 사안 미포섭, 결론이 애매("가능성이 있다" 정도)한 경우.

감점 주의

- 정정을 단순히 '감축' 또는 '석명'으로 보고 적법하다고 결론짓는 오류(원 청구항이 이미 명확하다는 점을 먼저 밝혀야 함).
- 발명의 설명을 참작한다는 이유로 청구범위를 제한·확장 해석하여 원 청구항의 「30mg」을 활성성분 기준으로 읽는 오류(2023후11487).
- § 42④(1) 위반이라는 이유만으로 § 42③(1) 위반까지 인정하는 오류(둘은 독립된 요건 — 2012후832).
- 효과의 정도가 미미하다는 사정을 § 42③(1) 위반사유로 삼는 오류(효과의 현저성은 진보성 판단의 영역).
- 20mg 실시례에서 나타난 상승효과를 근거로 10~50mg 전 범위의 진보성을 인정하는 결론.
- 수치한정의 임계적 의의를 검토하지 아니한 채 결합 용이성만으로 결론을 내는 경우.
- 선행발명 2가 이미 P물질 10~50mg 첨가를 명시적으로 교시하는데도 결합 용이성 판단을 생략.
- 「1일 1회 투여용」이 청구범위의 구성요소가 될 수 있음(2014후768 전합)을 놓치고 조성물만 대비.

2026년 제4문

사례형

20점

문제

甲은 휴대용 배터리의 과열을 차단하는 장치를 개발한 후, 2025. 1. 10. 핵심장치인 온도감지회로와 차단스위치로 구성된 시제품 X를 자신의 유튜브 채널에 공개하였고, 2025. 3. 1. 동일한 회로와 스위치를 사용하되 외부 형태와 배선 길이만 변경한 시제품 Y를 국제박람회에 전시하였다.

[사실관계]

2025. 12. 20. 甲은 시제품 Y에 자동복귀기능을 추가한 발명을 특허출원하였다.
- 甲은 2025. 1. 10. 공개에 관하여 특허법 제30조의 적용을 받겠다는 취지를 출원서에 기재하고 증명서류를 적법하게 제출했으나, 2025. 3. 1. 전시에 대해서는 특허법 제30조 적용에 관한 별도의 주장을 하지 않았다.
- 위 발명에 대한 甲의 특허등록 후 乙은 甲의 특허발명과 모든 구성이 동일한 제품 Z를 생산하였다.
- 乙은 소극적 권리범위 확인심판을 청구하면서 다음과 같이 주장하였다: “제품 Z의 기술은 甲이 이미 공개한 X 또는 Y로부터 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술이므로 甲의 특허권 권리범위에 속하지 않는다.”

위 지문을 토대로 다음 물음에 답하시오.

- (1) 甲의 특허출원에 대한 공지의예외의 적용범위를 논하시오. (12점)
- (2) 乙의 소극적 권리범위 확인심판의 결과를 논하시오. (8점)

모범답안

I. 설문 (1) — 공지의예외의 적용범위 (12점)

1. 문제의 소재

甲은 시제품 X를 유튜브에 공개하고(2025. 1. 10.) 시제품 Y를 국제박람회에 전시한 뒤(2025. 3. 1.) Y에 자동복귀기능을 추가한 발명을 출원하였으나(2025. 12. 20.), X 공개에 관하여만 제30조의 취지 기재와 증명서류 제출을 하였다. i) X 공개에 공지의예외가 적용되는지, ii) 절차를 밟지 아니한 Y 전시에도 그 효과가 미치는지, iii) 공개에 포함되지 아니한 자동복귀기능이 추가된 점이 공지의예외의 적용을 방해하는지가 문제된다.

2. 공지의예외의 의의와 취지

공지의예외란 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 제30조 제1항 각 호의 사유로 공지 등이 되더라도 그 날부터 12개월 이내에 출원하면 제29조 제1항-제2항을 적용할 때 그 발명을 공지 등이 되지 아니한 것으로 보는 제도이다. 이를 두지 아니하면 자기 공개로 특허를 받지 못하게 되어 권리자에게 지나치게 가혹하고, 산업발전에 이바지한다는 특허법의 목적에도 맞지 아니하기 때문이다.

3. 요건 및 절차

(1) 요건

i) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 되어야 한다(§ 30①(1) 본문). 다만 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 제외된다(같은 호 단서). ii) 최선의 공지일로부터 12개월 이내에 출원하여야 한다.

(2) 절차

출원서에 그 취지를 적어 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 출원일로부터 30일 이내에 지식재산처장에게 제출하여야 한다(§ 30②). 다만 보완수수료를 납부하면 제47조 제1항에 따라 보정할 수 있는 기간이나 특허결정 또는 특허거절결정 취소심결의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간에도 그 취지를 적은 서류 또는 증명서류를 제출할 수 있다(§ 30③).

4. 2025. 1. 10. X 공개

유튜브를 통한 공개는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 것으로서 제29조 제1항 제2호에 해당하고, 甲 자신의 의사에 의한 공개이다. 공개일부터 출원일까지 12개월이 지나지 아니하였고 취지 기재와 증명서류 제출도 적법하게 이루어졌으므로, X는 공지의예외의 적용을 받는다.

5. 2025. 3. 1. Y 전시

(1) 문제점

국제박람회 전시는 제29조 제1항 제1호의 공지 또는 공연실시에 해당하나, 甲은 이에 관하여 취지 기재나 증명서류 제출을 하지 아니하였다. 복수의 공지 행위가 있으면 각각에 대하여 공지예외를 주장하는 것이 원칙이고, 심사실무는 어느 하나의 공지와 밀접불가분의 관계에 있는 복수의 공지에 한하여 두 번째 이후의 절차를 생략할 수 있다고 본다. 유튜브 공개와 박람회 전시는 별개의 공개행위이므로 이에 해당하지도 아니한다.

(2) 동일성이 인정되는 범위의 반복 공개

판례는 12개월의 기간 이내에 여러 번의 공개행위를 하고 그중 가장 먼저 공지된 발명에 대해서만 절차에 따라 공지예외의 주장을 하였더라도, 공지된 나머지 발명들이 가장 먼저 공지된 발명과 동일성이 인정되는 범위에 있다면 나머지 발명들까지 공지예외의 효과가 미친다고 한다(2023후10712).

(3) 사안의 포섭

Y는 X와 동일한 온도감지회로와 차단스위치를 사용하고 외부 형태와 배선 길이만 변경한 것이다. 기술적 사상을 이루는 구성이 그대로 유지되고 외형과 배선 길이의 변경은 부수적 사항에 지나지 아니하므로, Y는 X와 동일성이 인정되는 범위에 있다. 따라서 X에 관한 절차의 효과가 Y에까지 미친다.

한편 甲의 특허는 이미 설정등록되었으므로 제30조 제3항에 따라 Y에 관한 서류를 보완할 수 있는 기간은 이미 지났다.

6. 자동복귀기능이 추가된 점

출원발명은 「Y + 자동복귀기능」으로서 공개된 X·Y와 구성에 차이가 있다. 그러나 제30조 제1항 제1호는 공지예외의 효과가 미치는 자기공지된 발명과 출원의 대상인 특허출원된 발명을 문언상 구별하고 있는데, 이는 특허출원된 발명이 자기공지 이후의 추가적인 연구개발이나 개량 등을 통하여 자기공지 되었던 발명과 구성이나 효과에 차이가 생길 수 있음을 고려한 것이다. 따라서 자기공지된 발명이 특허출원된 발명과 동일하여야 한다거나 자기공지된 발명 그 자체가 출원되어야 하는 것은 아니다(2023후10712). 자동복귀기능이 추가되었다는 사정은 공지예외의 적용을 방해하지 아니한다.

7. 결론

X 공개는 제30조 제1항 제1호·제2항의 요건을 모두 갖추어 공지예외가 적용되고, Y 전시는 별도의 절차가 없었으나 X와 동일성이 인정되는 범위에 있어 X에 관한 절차의 효과가 미친다. 따라서 X·Y는 모두 甲 출원발명의 신규성·진보성을 판단할 때 공지 등이 되지 아니한 것으로 본다.

II. 설문 (2) — 소극적 권리범위확인심판의 결과 (8점)

1. 문제의 소재

乙은 제품 Z가 甲이 공개한 X 또는 Y로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술이라고 주장한다. i) 乙에게 소극적 권리범위확인심판을 청구할 확인의 이익이 있는지, ii) 공지예외의 적용 근거가 된 공지기술을 들어 자유실시기술을 주장할 수 있는지가 문제된다.

2. 자유실시기술의 항변

확인대상발명이 공지기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다. 이는 특허발명이 애당초 특허를 받을 수 없었던 자유기술의 영역까지 권리범위가 확장되는 것을 제한하기 위한 것으로서, 문언침해가 문제 되는 경우에도 적용된다(2016후366).

3. 공지예외의 근거가 된 공지기술에 기초한 주장의 허부

그러나 공지예외의 규정을 적용받아 특허를 받은 특허발명의 경우, 확인대상발명이 그 권리범위에 속하는지를 판단할 때 통상의 기술자가 공지예외 적용의 근거가 된 공지기술로부터 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있다는 취지의 자유실시기술 주장은 허용되지 아니한다(2023후11562). 이를 허용하면 요건과 절차를 갖추어 등록된 특허가 곧바로 권리를 행사할 수 없게 되어 공지예외 제도가 형해화되고, 입법적 결단에 따라 공중의 영역에서 이탈한 공지기술을 다시 공중의 영역에 두는 것이 되기 때문이다. 디자인보호법의 신규성 상실 예외에 관하여도 같은 취지의 판시가 있다(2022후10012).

4. 사안의 포섭

(1) 확인의 이익

소극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 특허권자 등으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 자를 말한다(2022후10746). 乙은 甲의 특허발명과 모든 구성이 동일한 제품 Z를 생산하고 있어 권리의 대항을 받을 염려가 있는 자이므로 확인의 이익이 인정된다.

(2) X·Y의 선행기술 적격

X는 공지예외의 적용을 받고 Y도 X와 동일성이 인정되는 범위에 있어 그 효과가 미치므로, 두 공개는 모두 공지예외 적용의 근거가 된 공지기술이다. 이를 들어 Z가 자유실시기술이라고 주장하는 것은 허용되지 아니한다.

(3) 가정적 검토

설령 Y에 공지예외의 효과가 미치지 아니한다고 보더라도, Y에는 특허발명의 구성인 자동복귀기능이 없다. 통상의 기술자가 Y로부터 자동복귀기능을 부가하여 Z를 쉽게 실시할 수 있다고 볼 사정도 보이지 아니하므로, Y만으로 Z를 자유실시기술이라고 할 수 없다.

(4) 권리범위 속부

확인대상발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으면 그 권리범위에 속한다(2024후11590). Z는 甲의 특허발명과 모든 구성이 동일하므로 문언침해에 해당한다.

5. 결론

乙의 자유실시기술 주장은 받아들일 수 없고 Z는 甲 특허발명의 권리범위에 속하므로, 乙의 소극적 권리범위확인심판 청구는 기각된다.

채점기준

핵심 쟁점과 배점

쟁점	배점	특정 포인트
설문 (1) 공지의예외 요건(§30①·②) 및 12개월 요건 검토	3점	관리자에 의한 공개, 12개월 이내 출원, 취지 기재·증명서류 제출(30일)·보완수수료에 의한 사후 보완(§30③) 요건을 조문에 근거해 정리
설문 (1) 2025.1.10. X 공개에 대한 공지의예외 적용 여부	2점	절차 요건 충족을 확인하고, 유튜브 공개가 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 것으로서 제29조 제1항 제2호에 해당함을 포섭
설문 (1) 2025.3.1. Y 전시에 대한 공지의예외 적용 여부(핵심)	5점	① 복수의 공지행위는 각각 주장이 원칙이고 심사실무의 밀접불가분 예외에도 해당하지 아니함, ② X와 Y는 회로·스위치가 동일하고 외형·배선만 변경되어 동일성이 인정되는 범위에 있으므로 X에 관한 제30조 절차의 효과가 Y에까지 미침 (2023후10712), ③ 이미 설정등록되어 §30③에 따른 보완기간은 도과
설문 (1) 출원발명 (Y+자동복귀기능)과 자기공지된 발명의 관계	2점	§30①(1)이 '자기공지된 발명'과 '특허출원된 발명'을 문언상 구별하는 것은 자기공지 이후의 추가 연구개발·개량으로 구성·효과에 차이가 생길 수 있음을 고려한 것이므로, 양자가 동일하여야 하거나 자기공지된 발명 자체가 출원되어야 하는 것은 아님(2023후10712)
설문 (2) 자유실시기술 항변의 법리	3점	자유실시기술 = 확인대상발명이 공지기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있으면 특허발명과 대비할 필요 없이 권리범위에 속하지 아니함. 특허발명의 권리범위가 자유기술의 영역까지 확장되는 것을 제한하기 위한 것이어서 문언침해에도 적용됨(2016후366)
설문 (2) X·Y가 선행기술 자격을 갖는지	3점	X는 제30조 적용으로 선행기술 지위 상실, Y는 X와 실질 동일 → 마찬가지로 선행기술로 원용 불가, 설령 Y에 제30조가 미치지 않는다 하더라도 자동복귀기능 부가로 인해 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있다고 보기 어려움
설문 (2) 결론(확인·이익·청구 기각)	2점	乙은 Z를 생산 중인 자로서 이해관계인에 해당하여 확인의 이익 인정(2022후10746), 자유실시기술 항변 배척(문언침해에도 적용되나 공지의예외 적용의 근거가 된 공지기술에 기초한 주장은 불허 — 2023후11562, 디자인 사건 2022후10012 동지), Z=특허발명과 모든 구성 동일 → 문언침해 → 권리범위에 속함(청구 기각)

합계: 20점

특별 채점 기준

1) 논점 추출(40%)

- 득점: X 공개와 Y 공개의 처리를 **분리해서** 논하되, 두 공개가 **동일성이 인정되는 범위에** 있음을 포착해 X에 관한 제30조 절차의 효과가 Y에 미치지 않을 핵심 쟁점으로 잡았는가.
- 득점: 자유실시기술 항변에서 원용된 선행기술 X·Y가 **甲 자신의 공개임**을 포착해, 공지의예외 적용 여부와 자유실시기술 판단을 연동하여 논했는가.
- 감점: X·Y를 구분하지 않고 일괄 처리, 자동복귀기능이 추가된 점을 놓친 경우.

2) 목차·구성(25%)

- 득점: 설문 (1)은 (X 공개 → Y 공개 → 자동복귀기능) 순으로, 설문 (2)는 (자유실시기술 법리 → X·Y의 선행기술 지위 → 확인의 이익을 먼저 짚은 포섭 → 결론) 순으로 구성.
- 감점: 서론에 공지의예외의 일반론을 지나치게 상세히 서술, 설문 (2)에 균등침해 일반론을 장황하게 전개.

3) 답안 작성·논증(35%)

- 득점: 제30조 제1항·제2항·제3항을 조문 문언에 따라 정확히 인용, 실질적 동일 발명에 대한 절차 확장을 판례 법리로 뒷받침.
- 득점: 자유실시기술 항변 부정의 결론과 「Z가 특허발명과 모든 구성 동일」이라는 사실관계를 연결하여 문언 침해 결론까지 도출.
- 감점: '독립특허요건' 등 강학상 조어 남용, 조문번호 오기, 서술어 완결 없이 개조식 나열, 결론 애매.

감점 주의

- Y 전시에 대해 甲이 제30조 주장을 하지 않았다는 사실만 보고 곧바로 공지의예외 적용 불가로 단정하는 것 — X와 Y의 동일성 검토를 누락하면 감점.
- 제30조 제3항(보완수수료에 의한 사후 제출)을 요건에서 누락하는 경우.
- 이미 설정등록이 이루어졌음에도 § 30③에 따라 Y에 관한 서류를 보완할 수 있다고 서술하는 오류(보정기간·특허결정 등본 송달 후 3개월이 모두 도과).
- 2016후366을 전원합의체 판결로 인용하는 오류.
- 자유실시기술 항변에서 확인대상발명(Z)이 특허발명과 동일하다는 점을 간과하고 균등침해 판단으로 넘어가는 경우 — Z=특허발명이므로 문언 대비만으로 침해가 명백함.
- '특허청'·'특허청구범위'·'발명의 상세한 설명' 등 구 용어 사용.
- 설문 (2)에서 자유실시기술 항변을 인정하여 청구 인용으로 결론짓는 경우(사실관계상 명백한 오답).